

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Autores:

Jaylton Lopes Jr., Maurício Cunha
e Rodrigo Pinheiro

Organizado por CP Iuris

ISBN 978-85-5805-023-4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1ª edição

Brasília

CP Iuris

2020

SOBRE OS AUTORES

JAYLTON LOPES JR. Juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Mestrando em ciências jurídicas. Pós-graduado em Direito Tributário. Professor de Direito Processual Civil em cursos preparatórios em Brasília-DF. Professor de direito processual civil em curso de pós-graduação. Professor de técnicas de sentença cível do CP Iuris. É autor do livro "Sentença Cível: Construção e Estruturação" e coautor do livro "#VouSerJuiz – 480 Questões Objetivas Comentadas", ambos pela editora CP Iuris. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Civil – ABPC. Foi aprovado nos concursos para os cargos de analista judiciário, na área de execução de mandados do TJDFT; de promotor de justiça do Ministério Público Estadual do Tocantins (MPTO); e de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). Também foi aprovado e classificado para a prova oral do concurso para juiz de direito substituto do estado do Rio Grande do Norte, tendo desistido de prestar a referida prova em razão da posse no cargo de juiz de direito substituto do TJDFT.

MAURÍCIO CUNHA. Juiz de Direito (TJMG). Pós-doutorando pela UdG (Universidade de Girona/Espanha). Doutor em Direito Processual (PUC/Minas). Mestre em Direito Processual Civil (PUC/Campinas). Professor dos cursos de graduação (provimento) e de pós-graduação *lato sensu* da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – campus Poços de Caldas. Membro da ABDPro (Associação Brasileira de Direito Processual). Membro do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Processual). Membro do IDPro (Instituto de Direito Processual).

RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO. Possui graduação em Direito. Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor de Direito Processual Civil. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Civil – ABPC.

Capítulo 1 — Introdução ao Direito Processual Civil e Normas Fundamentais do Processo Civil.	26
1. Introdução ao direito processual civil.....	26
2. Evolução metodológica do processo civil.....	26
2.1. Praxismo e sincretismo	26
2.2. Processualismo	26
2.3. Instrumentalismo	26
2.4. Neoprocessualismo.....	27
3. Fontes do direito processual civil	27
3.1. Fontes normativas do direito processual civil.....	27
4. Normas fundamentais do processo civil	28
4.1. Princípio do devido processo legal	28
4.1.1. Conceito	28
4.1.2. Origem e compreensão atual.....	28
4.1.3. Devido processo legal formal e material	29
4.1.4. Devido processo legal e relações particulares.....	29
4.2. Princípio do contraditório	30
4.2.1. Art. 9º do CPC/2015	30
4.2.2. Art. 10 do CPC/2015	30
4.3. Princípio da ampla defesa	31
4.4. Princípio da razoável duração do processo	31
4.5. Princípio da publicidade dos autos processuais.....	32
4.6. Princípio da motivação (ou fundamentação) das decisões judiciais.....	32
4.7. Princípio da isonomia.....	33
4.8. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (princípio do acesso à justiça).....	33
4.8.1. Primeira onda renovatória do acesso à justiça	34
4.8.2. Segunda onda renovatória do acesso à justiça.....	34
4.8.3. Terceira onda renovatória do acesso à justiça	34
4.8.4. Flexibilização do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.....	34
4.9. Princípio do juízo natural	35
4.10. Princípio do duplo grau de jurisdição	35
4.11. Princípio da boa-fé processual.....	35
4.11.1. Proibição de litigância de má-fé	36
4.11.2. Proibição de criação dolosa de posições jurídicas	36
4.11.3. Responsabilidade pessoal e regressiva do juiz	37
4.11.4. Proibição do abuso de direito	37
4.11.5. vedação de comportamento contraditório (<i>venire contra factum proprium</i>)	37

4.12. Princípio da cooperação	38
4.12.1. Adversarial.....	38
4.12.2. Inquisitorial.....	38
4.12.3. Cooperativo	38
4.13. Princípio da adequação (adaptabilidade ou flexibilização) do procedimento	39
4.14. Ordem cronológica.....	39
Questões	40
Comentários	41
Capítulo 2 — Jurisdição e Competência	43
1. Jurisdição.....	43
1.1. Introdução.....	43
1.2. Características da jurisdição	43
1.2.1. Substitutividade	43
1.2.2. Inércia.....	43
1.2.3. Lide.....	43
1.2.4. Manifestação de poder.....	44
1.2.5. Atividade criativa	44
1.2.6. Definitividade	44
1.2.7. Terceiro imparcial	44
1.3. Princípios da jurisdição	44
1.3.1. Princípio da investidura	45
1.3.2. Princípio da territorialidade (ou aderência ao território)	45
1.3.3. Princípio da indelegabilidade.....	45
1.3.4. Princípio da inevitabilidade	45
1.3.5. Princípio da inafastabilidade da jurisdição	45
1.3.6. Princípio do juiz natural.....	46
1.4. Jurisdição contenciosa X Jurisdição voluntária	46
1.5. Equivalentes jurisdicionais	46
1.5.1. Autotutela	47
1.5.2. Autocomposição	47
1.5.3. Mediação (Lei nº 13.140/15).....	47
1.5.4. Conciliação.....	48
1.5.5. Arbitragem (Lei nº 9.307/96)	48
1.5.6. Dispute resolution board	50
1.6. Limites da jurisdição nacional.....	50
1.6.1. Competência concorrente	51
1.6.2. Competência exclusiva	51
1.6.3. Homologação das decisões estrangeiras no Brasil	51

1.7. Cooperação jurídica internacional	52
2. Competência	53
2.1. Competência absoluta X competência relativa	53
2.2. Princípio da Kompetenz-kompetenz	55
2.3. Princípio da <i>Perpetuatio jurisdictionis</i>	55
2.3.1. <i>Perpetuatio jurisdictionis</i> e alteração da competência absoluta após a sentença..	56
2.3.2. <i>Perpetuatio jurisdictionis</i> e desmembramento da Comarca	56
2.3.3. <i>Perpetuatio jurisdictionis</i> e princípio do juízo imediato.....	57
2.4. Critérios determinativos da distribuição de competência	57
2.4.1. Critério objetivo	57
a) Competência em razão da pessoa	57
b) Competência em razão da matéria	57
c) Competência em razão do valor da causa	57
2.4.2. Critério funcional	58
a) Critério funcional por grau de jurisdição	58
b) Critério funcional por fase do processo	58
c) Critério funcional por objeto litigioso	58
2.4.3. Critério territorial.....	59
2.5. Competência da justiça federal	59
2.5.1. Ações previdenciárias e delegação da competência para a justiça estadual	60
2.5.2. Delegação da competência nas execuções fiscais.....	61
2.5.3. Competência da justiça federal para ações ajuizadas contra o CNJ e CNMP	61
2.5.4. Tramitação da ação na justiça estadual e remessa à justiça federal: procedimento para aferição do interesse federal	62
2.6. Foro comum e foros especiais de competência	63
2.6.1. Foro comum.....	63
2.6.2. Foros especiais	63
a) Ação fundada em direito real imobiliário	63
b) Ação de inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e demais ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro	63
c) Ação em que o incapaz for réu	63
d) Ação em que a União, Estados, DF ou municípios forem autores	63
e) Ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável	64
f) Ação de alimentos	64
g) Demais hipóteses de competência territorial (competência relativa)	64
h) Foro do lugar do ato ou fato para a ação.....	64

i) Foro nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.....	65
2.7. Competência de foro X competência de juízo	65
2.8. Modificação da competência relativa	65
2.8.1. Considerações iniciais.....	65
2.8.2. Critério legal	65
a) Conexão.....	65
b) Continência.....	66
2.8.3. Critério convencional	67
a) Não alegação de incompetência relativa como preliminar de contestação	67
b) Cláusula de eleição de foro.....	67
2.9. Conflito de competência	67
Questões	69
Comentários	70
Capítulo 3 — Ação	72
1. Ação	72
1.1. Conceito	72
1.1.1. Teoria imanentista.....	72
1.1.2. Teoria da ação como direito concreto	72
1.1.3. Teoria da ação como direito potestativo	72
1.1.4. Teoria da ação como direito abstrato.....	72
1.1.5. Teoria eclética da ação	73
1.2. Ação e execução	73
1.3. Elementos da ação.....	73
1.3.1. Partes	73
1.3.2. Causa de pedir	74
1.3.3. Pedido	74
1.4. Desistência da ação	74
Questões	75
Comentários	76
Capítulo 4 — Processo	77
1. Processo	77
1.1. Conceito	77
1.2. Pressupostos processuais.....	77
1.2.1. Pressupostos processuais de existência.....	77
a) Pressupostos de existência de caráter subjetivo.....	77
b) Pressupostos de existência de caráter objetivo	77
1.2.2. Pressupostos processuais de validade	78

a) Pressupostos de validade de carácter subjetivo	78
b) Pressupostos de validade de carácter objetivo	78
1.2.3. Legitimidade <i>ad causam</i>	79
1.2.4. Interesse de agir.....	81
1.2.5. Legitimidade e interesse: condições da ação?.....	81
1.2.6. Teoria da asserção.....	81
Questões	82
Comentários	83
Capítulo 5 — Sujeitos Processuais	85
1. Sujeitos processuais	85
1.1. Partes.....	85
1.1.1. Sucessão e substituição das partes e dos procuradores	85
1.2. Curador especial	86
1.3. Capacidade das pessoas casadas	86
1.4. Juiz.....	87
1.4.1. Condução do processo.....	87
1.5. Princípio do <i>non liquet</i> (art. 140, CPC).....	88
1.6. Princípio do dispositivo	88
1.7. Responsabilidade regressiva do juiz	89
1.8. Impedimento e suspeição	89
1.8.1. Procedimento de incidente de impedimento ou de suspeição	90
2. Ministério Público	91
2.1. Formas de atuação do Ministério Público	91
2.1.1. Ministério Público como parte.....	91
2.1.2. Como fiscal da ordem jurídica	92
2.2. Consequência da não intimação do MP	93
2.3. Aspectos processuais da intervenção do MP	93
Capítulo 6 — Litisconsórcio	95
1. Litisconsórcio	95
1.1. Conceito e fontes do litisconsórcio	95
1.2. Classificação do litisconsórcio.....	95
1.2.1. Quanto à posição processual	95
1.2.2. Quanto ao momento da formação	95
1.2.3. Quanto à uniformidade da solução	96
1.2.4. Quanto à obrigatoriedade da formação	96
1.3. Tratamento dos litisconsortes	96
1.4. Consequências da não formação do litisconsórcio.....	97
1.5. Combinações de regimes de litisconsórcio	97

1.6. Intervenção <i>iussu iudicis</i>	98
1.7. Limitação do número de litisconsortes (litisconsórcio multitudinário)	98
Capítulo 7 — Intervenção de Terceiros	100
1. Intervenção de terceiros.....	100
1.1. Conceito	100
1.2. Assistência.....	100
1.2.1. Cabimento	100
1.2.2. Procedimento	100
1.2.3. Assistência simples X Assistência litisconsorcial.....	100
a) Assistência simples.....	101
b) Assistência litisconsorcial	101
1.3. Denúnciação da lide.....	102
1.3.1. Conceito e hipóteses de cabimento.....	102
1.3.2. Facultatividade da denúnciação da lide.....	102
1.3.3. Denúnciação sucessiva	102
1.3.4. Denúnciação <i>per saltum</i>	103
1.3.5. Procedimento	103
1.3.6. Denúnciação como ação regressiva eventual.....	103
1.3.7. Cumprimento de sentença.....	104
1.4. Chamamento ao processo	104
1.4.1. Conceito e hipóteses de cabimento.....	104
1.4.2. Prazo para chamamento ao processo.....	104
1.4.3. Título executivo judicial.....	104
1.5. Incidente de descon sideração da personalidade jurídica	105
1.5.1. Introdução	105
1.5.2. Aspectos processuais da descon sideração	106
a) Cabimento	106
b) Momento para requerer a descon sideração da personalidade jurídica	106
c) Legitimidade	106
d) Procedimento	106
1.6. Amicus Curiae.....	107
1.6.1. Cabimento e características	107
1.6.2. Procedimento	108
1.6.3. Recurso.....	108
Questões	109
Comentários	110
Capítulo 8 — Tutela Provisória	114

1. Tutela Provisória	114
1.1. Introdução.....	114
1.2. Características da tutela provisória.....	114
1.3. Momento para requerer	115
1.4. Competência	115
1.5. Tutela de urgência	115
1.5.1. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente	116
a) Estabilização	116
1.5.2. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente.....	117
b) Cessação dos efeitos da tutela cautelar	118
c) Renovação do pedido de tutela cautelar	119
1.6. Tutela da evidência.....	119
1.7. Enunciados das Jornadas de Direito Processual Civil sobre tutela provisória	121
Questões	121
Comentários	122
Capítulo 9 — Atos e Negócios Jurídicos Processuais	124
1. Atos e negócios processuais.....	124
1.1. Introdução.....	124
1.2. Princípios.....	124
1.2.1. Princípio da liberdade de forma dos atos processuais.....	124
1.2.2. Princípio da documentação	124
1.2.3. Princípio da publicidade	125
1.3. Classificação dos atos processuais	125
1.4. Tempo para a prática dos atos processuais.....	125
1.5. Lugar para a prática dos atos processuais	125
1.6. Prazo para a prática dos atos processuais	126
1.7. Consequências processuais em razão da perda de um prazo	126
1.8. Classificação dos prazos.....	127
1.9. Contagem dos prazos.....	127
1.10. Atos processuais praticados por meio eletrônico	128
1.11. Negócios processuais	128
1.11.1 Negócio processual para a modificação do procedimento.....	129
1.11.2. Negócio processual para a criação de calendário para a prática de atos processuais	129
1.11.3. Negócio processual para que o saneamento do processo possa ser efetuado pelas próprias partes	129
1.11.4. Negócio processual para a inversão do ônus da prova	130

1.11.5. Negócio processual visando à renúncia à impenhorabilidade de bens por convenção entre as partes	130
1.11.6. Negócio processual visando à renúncia à força executiva do título extrajudicial por convenção processual.....	130
1.11.7. Negócio processual para renúncia prévia ao direito de recorrer ou de produzir provas.....	130
1.11.8. Negócio processual para alteração dos prazos peremptórios	131
1.11.9. Meios para nulificar os negócios processuais.....	131
Questões	131
Comentários	133
2. Vícios dos atos processuais	136
2.1. Princípios reitores.....	136
2.1.1. Princípio da instrumentalidade das formas	137
2.1.2. Princípio do prejuízo (art. 282, §1º, CPC)	137
2.1.3. Princípio da causalidade (art. 281, CPC).....	137
2.1.4. Princípio do interesse (art. 276, CPC)	137
2.2. Espécies de vícios processuais	137
2.2.1. Inexistência.....	138
2.2.2. Nulidade absoluta e nulidade relativa	138
2.2.3. Rescindibilidade	138
2.2.4. Irregularidade	139
2.3. Convalidação do ato processual	139
Questões	139
Comentários	140
Capítulo 10 — Processo de Conhecimento.....	141
1. Processo de conhecimento e o procedimento comum	141
1.1. Distinção entre processo e procedimento.....	141
1.2. Indisponibilidade do procedimento	141
1.3. Procedimento comum.....	141
2. Petição inicial	142
2.1. Requisitos da petição inicial	142
2.1.1. Identificação e qualificação das partes	142
2.1.2. Causa de pedir	143
2.1.3. Pedido	143
2.1.4. Indicação do valor da causa	146
2.1.5. Indicação das provas que se pretende produzir	147
2.1.6. Indicação da opção pela realização ou não de audiência conciliação ou de mediação	147
2.1.7. Indicação do endereço do patrono e assinatura	147

2.1.8. Forma da petição inicial.....	147
2.2. Propositura da ação e seu juízo inicial	148
2.2.1. Distribuição.....	148
2.2.2. Possibilidade de emenda da petição inicial	149
2.2.3. Indeferimento da petição inicial	149
2.2.3. Improcedência liminar.....	150
2.4. Despacho liminar de conteúdo positivo	150
3. Comunicação dos atos processuais	150
3.1. Citação	151
3.1.1. Teoria da aparência.....	151
3.1.2. Situações em que a citação não pode ser realizada.....	151
3.1.3. Modalidades de citação.....	152
3.1.4. Efeitos da citação	155
3.1.5. Consequências da falta de citação ou nulidade da citação	155
3.2. Intimação	155
3.3. Cartas.....	156
3.3.1. Carta precatória	156
3.3.2. Carta de ordem	157
3.3.3. Carta arbitral.....	157
3.3.4. Pedido de cooperação internacional: auxílio direto e carta rogatória	157
4. Audiência de conciliação e mediação	158
4.1. Introdução.....	158
4.2. Procedimento da audiência de conciliação e mediação	159
4.3. Casuística envolvendo a incompetência do juízo em que audiência será realizada	159
5. Reconhecimento do pedido ou inércia	159
5.1. Introdução.....	159
5.2. Reconhecimento da procedência do pedido	160
5.3. Ausência de resposta (revelia).....	160
5.4. Diferença entre contumácia, revelia e ônus da impugnação especificada da prova	160
5.5. Revelia em desfavor da Fazenda Pública.....	161
5.6. Revelia nos embargos à execução	161
6. Apresentação de resposta	161
6.1. Contestação.....	161
6.1.1. Prazo para apresentação da contestação	161
6.1.2. Questões preliminares e questões prejudiciais.....	162
6.1.3. Princípio da eventualidade	162
6.1.4. Princípio da impugnação específica dos fatos.....	163
6.2. Reconvenção	163

6.2.1. Distinção entre reconvenção, pedido contraposto e as ações dúplices	163
6.2.2. Processos e procedimento que admitem a reconvenção.....	164
6.2.3. Procedimento na reconvenção	164
7. Providências preliminares.....	165
7.1. Julgamento conforme o estado do processo no sentido da extinção.....	165
7.2. Julgamento antecipado do mérito do processo.....	166
7.3. Julgamento antecipado parcial do mérito	166
7.4. Saneamento do processo	166
Capítulo 11 — Provas.....	168
1. Provas.....	168
1.1. Classificação das provas	168
1.1.1. Provas típicas e atípicas	168
1.1.2. Provas ilícitas	168
1.1.3. Provas indiciárias/indireta	168
1.1.4. Prova emprestada	168
1.1.5. Prova de fora da terra	169
1.1.6. Prova diabólica	169
1.2. Objeto da prova.....	169
1.3. Fatos que independem de prova	169
1.4. Etapas para a produção da prova	170
1.5. Critérios para a valoração da prova	170
1.6. Ônus da prova	170
1.6.1. Distinção entre inversão do ônus da prova e dispensa do ônus da prova.....	171
1.6.2. Momento de inversão do ônus da prova	171
1.6.3. Ônus financeiro da prova determinada de ofício pelo juiz.....	171
1.7. Produção antecipada de provas	171
1.8. Provas em espécie	172
1.8.1. Ata notarial.....	172
1.8.2. Depoimento pessoal.....	172
1.8.3. Confissão	173
1.8.4. Exibição de documento ou coisa	174
1.8.5. Prova documental	175
1.8.6. Arguição de falsidade do documento	179
1.8.7. Documentos eletrônicos.....	179
1.8.8. Prova testemunhal	180
1.8.9. Prova pericial	181
1.8.10. Inspeção judicial.....	182
1.8.11. Interceptação de dados telemáticos e uso desta prova no processo civil	182

2. Audiência de instrução e julgamento	182
2.1. Conceito	182
2.2. Princípios informativos	182
2.3. Adiamento da audiência de instrução e julgamento.....	183
2.4. Estrutura da audiência de instrução e julgamento.....	183
3. Sentença	184
3.1. Conceito	184
3.2. Fundamentos da sentença	184
3.2.1. Fundamento sem resolução do mérito (coisa julgada formal)	184
3.2.2. Fundamento com resolução do mérito (coisa julgada material)	185
3.3. Espécies de sentença	186
3.4. Estrutura da sentença	187
3.4.1. Relatório	188
3.4.2. Fundamentação	188
a) Fundamentação <i>per relationem</i> (<i>aliunde</i> ou por referência).....	189
3.4.3. Dispositivo	190
3.5. Assinatura	190
3.6. Fixação da sucumbência: honorários e custas	190
3.6.1. Fixação da sucumbência à luz do art. 85 do CPC	191
3.6.2. Sucumbência na cumulação subjetiva de ações (litisconsórcio).....	191
3.6.3. Sucumbência e gratuidade de justiça	192
3.6.4. Sucumbência no mandado de segurança e <i>habeas data</i>	192
3.6.5. Sucumbência na ação civil pública	192
3.6.6. Sucumbência na ação popular	192
3.7. Vícios na sentença	192
3.7.1. Sentença ultra, extra e citra petita	193
3.7.2. Sentença condicional.....	193
3.7.3. Correção da sentença	194
3.8. Efeitos da sentença.....	194
3.9. Hipoteca Judiciária (art. 495, CPC)	194
3.10. Sentença e fato superveniente	195
3.11. Coisa julgada	196
3.11.1. Cognição e atos que podem gerar coisa julgada.....	197
3.11.2. Coisa julgada, preclusão e estabilidade da decisão	197
3.11.3. Classificação da coisa julgada.....	198
3.11.4. Coisa julgada <i>pro et contra</i>	198
3.11.5. Limites subjetivos da coisa julgada.....	198
3.11.6. Limites objetivos da coisa julgada	199

3.11.7. Efeitos da coisa julgada.....	199
3.11.8. Coisa julgada no mandado de segurança	200
3.11.9. Coisa julgada nas sentenças determinativas	200
3.11.10. Relativização da coisa julgada nas ações de desapropriação	200
3.11.11. Relativização da coisa julgada nas ações de estado.....	200
3.11.12. Coisa julgada inconstitucional	201
Questões	201
Comentários	203
Informativos de Jurisprudência	207
Capítulo 12 — Liquidação de sentença	211
1. Liquidação.....	211
1.1. Considerações gerais	211
1.2. Liquidação por arbitramento.....	212
1.3. Liquidação pelo procedimento comum.....	212
2. Cumprimento de sentença.....	213
2.1. Considerações iniciais.	213
3. Cumprimento provisório da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa	216
4. Cumprimento definitivo da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa	217
5. Cumprimento da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos	220
6. Cumprimento da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.....	222
7. Cumprimento da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer.	223
8. Cumprimento da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. .	225
Questões	225
Comentários	226
Capítulo 13 — Processo de Execução	228
1. Introdução	228
2. Conceito e classificação	228
2.1. Execução comum e execução especial	228
2.2. Execução de título judicial e execução de título extrajudicial.....	228
2.3. Execução direta e execução indireta	228
2.4. Execução provisória e execução definitiva	229
3. Princípios da execução	229
3.1. Princípio da patrimonialidade (ou realidade)	229
3.2. Princípio da menor onerosidade da execução	229

3.3. Princípio da disponibilidade do processo executivo	229
3.4. Princípio do exato adimplemento (ou especificidade da execução)	230
3.5. Princípio do desfecho único	230
4. Concentração dos poderes de execução do juiz	230
5. Partes no processo de execução	231
5.1. Legitimidade ativa	231
5.2. Legitimidade passiva.....	232
6. Cumulação de execuções.....	233
7. Competência para a execução	233
8. Requisitos necessários para realizar qualquer execução	233
8.1. Inadimplemento do devedor.....	234
8.2. Título executivo	234
9. Atributos da obrigação representada no título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade	234
9.1. Certeza.....	234
9.2. Liquidez.....	234
9.3. Exigibilidade	235
10. Títulos Executivos Extrajudiciais.....	235
10.1. Letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque	235
10.2. Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor.....	236
10.3. Documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.....	237
10.4. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal.....	237
10.5. Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução	237
10.6. Contrato de seguro de vida em caso de morte	238
10.7. Crédito decorrente de foro e laudêmio.....	238
10.8. Crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.....	239
10.9. Certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei.....	239
10.10. Crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas	239
10.11. Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei	240
11. Exigibilidade da obrigação e responsabilidade patrimonial do executado.....	240
11.1. Sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória.....	240

11.2. Sócio nos termos da lei	240
11.3. Devedor, ainda que em poder de terceiros	241
11.4. Cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida	241
11.5. Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução.....	241
11.6. Cujas alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores.....	242
11.7. Do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.....	242
12. Bens não sujeitos à execução.....	242
12.1. Bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução.....	242
12.2. Bens móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.....	243
12.3. Vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor	243
12.4. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º	243
12.5. Livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.....	244
12.6. Seguro de vida	244
12.7. Materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas	244
12.8. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família	245
12.9. Recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social	245
12.10. Quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.....	246
12.11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei.....	246
12.11. Créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra	247
12.12. Impenhorabilidade do bem de família	247
13. Bens submetidos ao regime de direito real de superfície	248
14. Fraude à execução.....	248
14.1. Fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica	249
15. Execução e direito de retenção	250
16. Responsabilidade Objetiva do Exequente.....	250
17. multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça	250
Capítulo 14 — Diversas Espécies de Execução	251

1. Introdução	251
2. Disposições gerais pertinentes às diversas espécies de execução	251
2.1. Petição inicial	251
2.2. Intimação de terceiros	251
2.3. Medidas urgentes	253
2.4. Averbação da pendência da execução	253
2.5. Obrigações alternativas	253
2.6. Emenda da petição inicial.....	253
2.7. Despacho inicial.....	254
2.8. Nulidade da execução	254
3. Execução para entrega de coisa CERTA.....	254
4. Execução para entrega de coisa certa.....	255
5. Execução das obrigações de fazer ou de não fazer	256
5.1. Procedimento da execução de obrigação de fazer fungível.....	256
5.2. Procedimento da execução de obrigação de fazer infungível.....	256
5.3. Procedimento da execução de obrigação de não fazer	257
6. Execução por quantia certa.....	257
6.1. Petição inicial	257
6.2. Citação do devedor	257
6.3. Mandado de citação e arresto prévio (ou pré-penhora)	258
6.4. Penhora.....	259
6.4.1. Bens não sujeitos à penhora	259
6.4.2. Bens penhoráveis e ordem preferencial	259
7. Formalização da penhora: bens imóveis e móveis em geral	261
7.1. Auto ou termo de penhora.....	261
7.2. Formalização da penhora de bens imóveis e veículos automotores	261
7.3. Resistência do executado e ordem de arrombamento.....	261
7.4. Depósito.....	262
7.5. Intimações.....	262
8. Formalização da penhora: especialidades	263
8.1. Penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.....	263
8.2. Penhora de créditos.....	264
8.3. Penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas	264
8.4. Penhora de empresa, outros estabelecimentos e semoventes	265
8.5. Penhora de percentual de faturamento de empresa	266
8.6. Penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel:.....	266
9. Modificações da penhora	267
9.1. Substituição da penhora	267

9.2. Redução ou ampliação da penhora.....	267
9.3. Renovação da penhora	268
9.4. Alienação antecipada de bens penhorados	268
10. Avaliação	268
11. Expropriação	269
11.1. Adjudicação	269
11.1.1. Remição	270
11.2. Alienação.....	270
11.2.1. Alienação por iniciativa particular	271
11.2.2. Alienação em leilão judicial	271
a) Características do leilão judicial	271
b) Leiloeiro	272
c) Edital do leilão	272
d) Intimações	273
e) Não realização do leilão	273
f) Arrematação.....	273
g) Pagamento.....	274
h) Suspensão da arrematação e do leilão	275
i) Auto de arrematação	275
11.2.3. Invalidação, ineficácia e resolução da arrematação	276
11.2.4. Ação anulatória autônoma	276
11.2.5. Desistência da arrematação	277
11.2.6. Ato atentatório à dignidade da justiça	277
11.3. Pagamento ao credor	277
12. Execução contra a fazenda pública	278
12.1. Introdução.....	278
12.2. Procedimento	278
13. Execução de alimentos	278
14. Embargos à execução	280
14.1. Introdução.....	280
14.2. Competência	280
14.3. Prazo	280
14.4. Parcelamento	281
14.5. Objeto dos embargos	282
14.5.1. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação	282
14.5.2. Penhora incorreta ou avaliação errônea.....	282
14.5.3. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções	282

14.5.4. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa.....	283
14.5.5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução.....	283
14.5.6. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento	283
14.6. Alegação de suspeição ou impedimento do juiz	283
14.7. Procedimento dos embargos à execução	283
14.8. Efeito suspensivo	284
15. Exceção de pré-executividade	285
16. Suspensão e extinção do processo de execução.....	285
16.1. Suspensão da execução	285
16.1.1. Prescrição intercorrente	286
16.2. Extinção da execução	287
Questões	287
Comentários	288
Capítulo 15 — Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa e Voluntária	290
1. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa	290
1. 1. Ação de consignação em pagamento	290
1.2. Ação de exigir contas	292
1.3. Ações possessórias	294
1.3.1. Considerações gerais sobre todas as ações possessórias.....	294
1.3.2. Considerações procedimentais sobre as ações possessórias	296
1.4. Ação de divisão e de demarcação de terras particulares.....	298
1.4.1. Disposições gerais sobre ambas as ações	298
1.4.2. Ação demarcatória	298
1.4.3. Ação divisória.....	299
1.5. Ação de dissolução parcial de sociedade.....	300
1.6. Inventário e partilha	302
1.6.1. Considerações gerais sobre o inventário judicial.....	302
1.6.2. Jurisdição, competência, legitimidade e cumulação.....	303
1.6.3. Inventariante e primeiras declarações	303
1.6.4. Citações e impugnações	305
1.6.5. Avaliação de bens e pagamento das dívidas	305
1.6.6. Partilha	306
1.6.7. Arrolamento comum e sumário	308
1.7. Embargos de terceiro	308
1.8. Oposição	310
1.9. Ações de família	312

1.9.1. Considerações gerais	312
1.9.2. Ação de separação ou divórcio	313
1.9.3. Ação de reconhecimento de união estável	313
1.9.4. Ação de alimentos gravídicos.....	314
1.9.5. Ação investigatória de paternidade	314
1.9.6. Ação de alimentos.....	315
1.10. Ação monitória	316
1.11. Restauração de autos.....	318
1.12. Regulação de avaria grossa	319
1.13. Homologação de decisão estrangeira	320
1.14. Homologação de penhor legal	322
2. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária.....	323
2.1. Considerações iniciais	323
2.2. Notificação, interpelação e protesto.....	324
2.3. Alienação judicial.....	324
2.4. Divórcio e separação consensual, extinção consensual da união estável e alteração do regime de bens do matrimônio	325
2.5. Testamentos e codicilos	325
2.6. Herança jacente.....	326
2.7. Bens dos ausentes	327
2.8. Coisas vagas	328
2.9. Interdição.....	328
2.10. Tutela e curatela	329
2.11. Organização e fiscalização das fundações	329
2.12. Ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo.....	330
Questões	330
Comentários	331
Capítulo 16 — Processos nos Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões Judiciais	333
1. Teoria geral dos recursos	333
1.1. Conceito de recurso	333
2. Princípios recursais.....	334
2.1. Princípio do duplo grau de jurisdição	334
2.2. Princípio da taxatividade.....	334
2.3. Princípio da singularidade, unicidade, ou unirrecorribilidade	334
2.4. Princípio da fungibilidade.....	334
2.5. Princípio da non reformatio in pejus.....	335
3. Classificação dos recursos	335

3.1. Quanto à extensão.....	335
3.2. Quanto à fundamentação	335
3.3. Quanto à forma de interposição.....	336
4. Juízo de admissibilidade e de mérito dos recursos.....	337
4.1. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade.....	337
4.1.1. Cabimento	337
4.1.2. Legitimidade para recorrer	337
4.1.3. Interesse para recorrer	338
4.2. Pressupostos extrínsecos de admissibilidade	338
4.2.1. Tempestividade.....	338
4.2.2. Preparo.....	339
4.2.3. Regularidade formal.....	340
4.3. Competência para a realização do juízo de admissibilidade.....	340
4.4. Juízo de mérito	340
5. Efeitos dos recursos.....	341
5.1. Efeito suspensivo e efeito ativo	341
5.2. Efeito devolutivo	341
5.3. Efeito expansivo subjetivo e objetivo	342
5.4. Efeito impeditivo	343
5.5. Efeito substitutivo	343
5.6. Efeito regressivo	343
6. Desistência e renúncia ao recurso	343
7. Ordem dos processos nos Tribunais	344
7.1. Ingresso do processo ou recurso no Tribunal	344
7.2. Poderes do relator	345
7.2.1 Poderes diretivos	345
7.2.2 Poderes instrutórios	346
7.2.3 Poderes decisórios	346
7.3. Julgamento colegiado	347
7.4. Sustentação oral.....	347
7.5. Votação.....	348
7.6. Ampliação do colegiado	348
7.7. Conclusão do julgamento	349
8. Recursos em espécie	350
8.1. Apelação	350
8.1.1. Considerações iniciais.....	350
8.1.2. Efeitos	350
a) Efeito suspensivo	350

b) Efeito devolutivo.....	351
8.1.3 Forma e procedimento	351
8.1.4. Teoria da causa madura.....	352
8.2. Agravo de instrumento	353
8.2.1. Considerações iniciais.....	353
8.2.2. Hipóteses de cabimento	353
8.2.3. Efeitos, instrução e forma	354
8.2.4. Julgamento	355
8.3. Recurso ordinário constitucional – ROC	356
8.4. Remessa necessária	357
8.5. Agravo interno.....	359
8.6. Embargos de declaração	359
8.6.1. Cabimento	359
8.6.2. Prazo, admissibilidade, contraditório e procedimento	360
8.6.3. Prequestionamento.....	360
8.6.4. Efeitos	361
8.6.5. Reiteração de embargos de declaração e multas	362
8.7. Recurso especial, recurso extraordinário e seus respectivos agravos denegatórios	362
8.7.1. Pressupostos de admissibilidade comuns a ambos os recursos excepcionais	363
8.7.2. Pressuposto de admissibilidade específico do recurso extraordinário – repercussão geral.....	363
8.7.3. Efeitos	364
8.7.4. Procedimento	366
a) Recurso excepcional admitido	366
b) Recurso excepcional inadmitido	366
8.7.5. Agravo em recurso especial e em recurso extraordinário (agravo denegatório) ...	367
8.7.6. Procedimento dos recursos excepcionais após o ingresso no Tribunal Superior ...	368
8.8. Embargos de divergência	369
9. Precedentes	371
9.1. Considerações iniciais	371
9.2. Técnicas de formação de precedentes	372
9.2.1. Recursos especial e extraordinário repetitivos	372
9.2.2. Incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR	375
9.2.3. Incidente de assunção de competência – IAC	379
10. Ações autônomas de impugnação e incidentes nos Tribunais.....	381
10.1. Ação rescisória.....	381
10.1.1. Considerações iniciais	381
10.1.2. Hipóteses de cabimento – decisões de mérito	381

a) Prevaricação, concussão ou corrupção passiva do juiz (art. 966, I, CPC).....	381
b) Juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente (art. 966, II, CPC).....	381
c) Dolo ou coação do vencedor em detrimento do vencido; simulação ou colusão entre as partes (art. 966, III, CPC).....	382
d) Ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, CPC).	382
e) Violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC).....	382
f) Prova falsa apurada no processo-crime ou na própria ação rescisória (art. 966, VI, CPC).....	383
g) Prova nova posterior ao trânsito, cuja existência era ignorada pelo autor ou de que não poderia ele fazer uso, capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, CPC).....	383
h) Erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII e §1º, CPC).....	384
10.1.3. Hipóteses de cabimento – decisões sem resolução de mérito	384
10.1.4. Legitimidade ativa e passiva	385
10.1.5. Prazo.....	385
10.1.6. Competência	386
10.1.7. Petição inicial, tutela provisória, procedimento e julgamento.....	387
10.2. Reclamação constitucional	388
10.2.1. Cabimento	388
10. 2.2. Reclamação e trânsito em julgado.....	389
10.2.3. Procedimento	389
10.2.4. Incidente de arguição de inconstitucionalidade	391
Questões	392
Comentários	393
Capítulo 17 — Processo Coletivo	395
1. Considerações iniciais.....	395
2. Princípios específicos do processo coletivo.....	395
3. Competência e legitimidade	396
4. Litispendência	396
5. Recorribilidade das interlocutórias proferidas em ações coletivas.....	397
6. Coisa julgada	397
7. Liquidação e execução das sentenças coletivas	398
Capítulo 18 — Juizados Especiais.....	399
1. Microssistema dos Juizados Especiais	399
1.1. Introdução.....	399
1.2. Procedimento sumaríssimo	399
1.3. Critérios adotados nos Juizados Especiais	399
1.4. Competência nos Juizados Especiais	399

1.5. Opção entre o Juízo Cível Estadual e o Juizado Especial Estadual	401
1.6. Conflito de competência entre Juízo Cível e Juizado Especial	401
1.7. Legitimação ativa e capacidade postulatória.....	401
1.7.1. Juizados Especiais Estaduais	401
1.7.2. Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública	401
1.8. Legitimação passiva	402
1.8.1. Juizados Especiais Estaduais	402
1.8.2. Juizados Especiais Federais	402
1.8.3. Juizados Especiais da Fazenda Pública	402
1.9. Intervenção de terceiros	402
1.10. Petição inicial e procedimento padrão	402
1.11. Tutela provisória de urgência	403
1.12. Citação	403
1.13. Audiência de conciliação	403
1.14. Resposta do réu	404
1.15. Audiência de instrução e julgamento	404
1.16. Sentença.....	404
1.17. Recurso, ações autônomas de impugnação e incidentes.....	405
1.17.1. Embargos de declaração	405
1.17.2. Recurso inominado, agravo interno e recurso extraordinário.....	405
1.17.3. Mandado de segurança, ação rescisória e reclamação	405
1.17.4. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal	406
1.18. Execução por quantia certa no Juizado Especial Estadual	406
1.19. Execução por quantia certa no Juizado Especial Federal e Fazendário	407
1.19.1. Execução por quantia certa em título judicial	407
1.19.2. Execução por quantia certa em título extrajudicial	407
Questões	407
Comentários	409
Referências Bibliográficas	414

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

1. INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

A ideia de processo não se limita ao direito processual. Processo é caminho, é meio de se alcançar algo. É instrumento para o exercício de um direito ou poder. Nessa perspectiva, o processo pode ser compreendido como um complexo de relações jurídicas que instrumentaliza a criação de uma norma jurídica. Basta imaginar, por exemplo, o processo legislativo, cujas regras para a criação das leis encontram-se previstas nos arts. 59 e seguintes da Constituição Federal.

No campo do processo judicial, que se desenvolve em contraditório, enquanto o processo corresponde ao complexo de relações jurídicas que instrumentaliza a criação da norma jurídica individualizada do caso concreto, o procedimento é a forma como esse complexo de relações se exterioriza no mundo fenomênico.

Diz-se, então, que o procedimento é a exteriorização do processo, na medida em que se revela por meio de uma sequência encadeada de atos que levam à prolação de uma decisão de mérito.

2. EVOLUÇÃO METODOLÓGICA DO PROCESSO CIVIL

Podem ser identificadas quatro fases evolutivas do processo. Vejamos:

2.1. PRAXISMO E SINCRETISMO

Nesta fase, o direito processual civil era compreendido apenas em seu aspecto prático. Não havia qualquer preocupação teórica e a ele não se atribuía cientificidade. O processo nada mais era do que um anexo ou subproduto do direito material.

2.2. PROCESSUALISMO

Nesta fase, buscou-se distinguir a relação jurídica de direito material da relação jurídica de direito processual. O marco para o desenvolvimento dessa nova fase evolutiva do processo civil pode ser atribuído à obra do alemão Oskar Von Bülow sobre pressupostos processuais e exceções dilatórias (*Die lehre von den processeinreden und die processvoraussetzungen*), no ano de 1868, em que o referido jurista demonstrou a autonomia do processo frente ao direito material, tendo em vista a natureza pública do processo. Para Bülow, há uma relação jurídica especial entre os sujeitos do processo (juiz, autor e réu) que não se confunde com a relação material litigiosa.

2.3. INSTRUMENTALISMO

A despeito da autonomia existente entre esses dois ramos do direito, não se pode perder de vista que o direito processual é instrumento de realização do direito material. Nesse sentido, **é possível identificar a existência de uma relação circular entre processo e direito material. Isso porque ao mesmo tempo em que o processo serve ao direito material, é por ele servido.**



2.4. NEOPROCESSUALISMO

Compreendida como a atual fase de desenvolvimento do processo civil, o neoprocessualismo (ou formalismo-valorativo) é, de certa forma, fruto do movimento que convencionou chamar de *neoconstitucionalismo*. Tal movimento se assenta em três grandes marcos: i - histórico (pós-segunda guerra); ii - filosófico (pós-positivismo); iii - teórico (força normativa da constituição, expansão da jurisdição constitucional, desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional)¹.

Nesse sentido, o processo civil, com seus inúmeros institutos, não mais poder ser visto em seu caráter eminentemente instrumental. O constitucionalismo moderno exige, em primeiro lugar, uma leitura e uma aplicação do processo em consonância com os objetivos consagrados na Constituição Federal. A aplicação das normas processuais não pode perder de vista a pauta dos direitos fundamentais. É o que se extrai do art. 8º do CPC/2015, segundo o qual “**ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência**”.

3. FONTES DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

O direito processual tem uma **finalidade, que é disciplinar a forma pela qual o Estado presta a atividade jurisdicional**. O Estado presta a atividade jurisdicional por meio de um **processo**, o qual nasce a partir de uma provocação do exercício do direito de ação.

3.1. FONTES NORMATIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

As fontes normativas podem ser divididas em fontes primárias e fontes secundárias. São **fontes primárias** do direito processual civil:

- **Constituição Federal:** existem regras processuais na própria Constituição, como quando a CF estabelece as competências dos Tribunais Superiores ou mesmo o processo legislativo. Portanto, a Constituição é fonte do direito processual civil.
- **Leis Federais:** além da Constituição Federal, as leis federais (lei complementar ou lei ordinária) são fontes do direito processual. Nos termos do art. 22, I, da CF, compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Registre-se, por fim, que medida provisória não pode **criar normas de direito processual**.
- **Lei de Organização Judiciária dos Estados:** como as normas de direito processual abrangem também as normas de organização judiciária, é necessário reconhecer que **os Estados têm competência para tratar dessa matéria**, conforme art. 125, §1º, da CF, o qual diz que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Nesse caso, **essas leis estaduais trazem regras de competência** (ex.: competência das varas da fazenda pública, varas de registros públicos, varas de recuperação judicial e falência etc.).
- **Tratados e convenções internacionais já internalizados no Brasil:** esse tratados têm, como regra, natureza de lei ordinária. Sendo de direitos humanos, podem ter status de emenda constitucional (art. 5º, §3º, CF) ou de norma suprallegal.

¹ Sobre o tema: BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil).

As **fontes secundárias**, por sua vez, devem ser aplicadas quando as fontes primárias não se mostrarem suficientes. São elas:

- **Analogia**
- **Costumes**
- **Princípios gerais do direito**

4. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

O novo código de processo civil, Lei nº 13.105/2015, no título único do livro I da parte geral, dedicou-se exclusivamente às *normas fundamentais do processo civil*. Tais normas, em sua maioria dotadas de abertura semântica, alinham-se à pauta dos direitos fundamentais.

Embora represente uma inovação em relação ao CPC/73, a previsão expressa de um rol de normas fundamentais em um código de processo civil não é criação tupiniquim. Em verdade, o nosso legislador se inspirou no Código de Processo Civil Português, de 2013, o qual estabelece em seus nove primeiros artigos *as disposições e os princípios fundamentais*.

Registre-se, ainda, que o rol de normas fundamentais apresentado pelo CPC/2015 não é exaustivo (enunciado 369 do FPPC). Ademais, as normas fundamentais podem ser *normas regras* ou *normas princípios* (enunciado 370 do FPPC)².

Os princípios são considerados **normas jurídicas**, apesar de maior abstração, quando comparados às regras. Tratam-se de **mandados de otimização** (Robert Alexy), visto que ordenam que algo deva ser realizado na maior medida possível, considerando as possibilidades fáticas e as possibilidades jurídicas existentes.

Por conta disso, num conflito entre princípios deve ser feita a **ponderação**. Via de regra, apesar de entendimento contrário, no conflito entre regras não há ponderação, e sim subsunção.

Vamos às normas fundamentais.

4.1. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

4.1.1. CONCEITO

Trata-se de um direito fundamental previsto na Constituição Federal, em uma cláusula geral (art. 5º, LIV da CF), o qual se revela por meio de um conjunto de normas (regras e princípios) instituidoras de garantias processuais e materiais, permitindo que a norma jurídica individualizada a ser produzida no processo seja mais justa, tempestiva e efetiva possível.

4.1.2. ORIGEM E COMPREENSÃO ATUAL

Atribui-se à Carta Magna de 1215 a origem do princípio do devido processo legal, a qual representou um pacto entre o Rei João Sem Terra e os barões ingleses. O objetivo da cláusula do devido processo legal foi limitar o poder do soberano. Assim, consignou-se que “nenhum homem livre será molestado, ou aprisionado, ou despojado, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo aniquilado, nem nós iremos contra ele, nem permitiremos que alguém o faça, exceto pelo julgamento legal de seus pares ou pelo Direito da terra”.

² A título de exemplo, o art. 12 do CPC, que determina a observância, preferencialmente, da ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças e acórdãos, é uma **norma-regra** fundamental.

Trata-se, portanto, de um limite ao poder do Estado. Por se tratar de uma cláusula aberta, o princípio do devido processo legal permitiu se amoldar às realidades históricas. Foi sendo preenchido no decorrer dos séculos por novos valores e direitos fundamentais reconhecidos pelas Constituições escritas que foram surgindo. Hoje, processo devido deve ser compreendido como processo justo. Em outras palavras, processo devido é aquele cujo procedimento tem previsão em lei, que se desenvolve em tempo razoável perante um juízo natural e competente, que garante a participação em cooperação e com boa-fé de todos os atores do processo, que garante o efetivo contraditório a ambas as partes, e que culmina em uma decisão de mérito devidamente fundamentada.

4.1.3. DEVIDO PROCESSO LEGAL FORMAL E MATERIAL

O princípio do devido processo legal deve ser compreendido em duas dimensões: formal e material.

O devido processo legal em sua **dimensão formal** se refere à observância das garantias processuais, ou seja, que dizem respeito ao procedimento. Trata-se das “regras do jogo” (observância do juízo natural, das regras de competência, conexão, continência etc.).

Por sua vez, o princípio do devido processo legal em sua **dimensão material (ou substancial)** representa um verdadeiro controle, por parte do Poder Judiciário, de eventual atividade legislativa abusiva, desproporcional. Tal dimensão se projeta para o campo da interpretação. Assim, por meio da atividade interpretativa, cabe ao juiz, no caso concreto, extrair do texto legal a norma jurídica mais consentânea com os direitos fundamentais, ou seja, a norma jurídica mais razoável e proporcional³.

É importante registrar que, conforme entendimento do STF⁴, **as máximas da proporcionalidade e razoabilidade são extraídas do caráter substancial do princípio do devido processo legal** (*substantive due process*). Tal compreensão pode ser extraída do art. 8º do CPC/2015, *in verbis*:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

4.1.4. DEVIDO PROCESSO LEGAL E RELAÇÕES PARTICULARES

O princípio do devido processo legal, embora surgido como cláusula limitadora dos poderes do soberano, não se restringe às relações entre particulares e Estado. Por se tratar de direito fundamental, possui eficácia horizontal (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).

Nessa perspectiva, o STF, no julgamento do RE 201.819/RJ, firmou entendimento de que o princípio do devido processo legal também pode ser invocado nas relações entre particulares, como é o caso da exclusão sumária de associado no âmbito das associações particulares. Entendeu-se que o art. 57 do CC impõe a observância do devido processo legal.

“Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.”

³ Registre-se que texto legal não se confunde com norma jurídica. O enunciado normativo é uma prescrição genérica e abstrata. A norma jurídica é o resultado da interpretação. É a partir da interpretação realizada pelo operador do direito, portanto, que se extrai do texto a verdadeira norma jurídica.

⁴ ARE 915424 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27-11-2015 PUBLIC 30-11-2015.



4.2. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

O princípio do contraditório é um direito fundamental previsto em uma cláusula geral (art. 5º, LV, da CF). Tal princípio decorre da cláusula geral do devido processo legal⁵. O contraditório é direito de ambas as partes e não necessariamente do réu. O mesmo raciocínio vale para o princípio da ampla defesa, o qual será analisado mais adiante.

O princípio do contraditório contém uma dupla dimensão (ou duplo aspecto): formal e material (ou substancial). Ao falarmos em contraditório, devemos ter em mente três importantes sentidos: contraditório é *reação*, *participação* e *influência*.

A reação corresponde ao direito de se insurgir (reagir) a uma demanda. Ação, portanto, gera uma natural reação. Talvez este seja o sentido atribuído pelo senso comum.

A participação se revela, dentre outras formas, pelo direito da parte de apresentar a sua resposta formal, de ter um prazo razoável para responder, de interpor recurso, de se fazer presente em audiência, de produzir provas, de ser intimado e cientificado de todos os atos processuais. Nessa perspectiva, a participação corresponde ao aspecto formal do princípio do contraditório.

A influência, por sua vez, não é apenas um direito. Trata-se de verdadeiro poder conferido às partes. Isso porque não basta garantir às partes a simples participação formal. É preciso que elas possam, de alguma forma, influir na decisão de mérito. Isso porque, se o processo é instrumento de criação de uma norma jurídica individualizada, a decisão de mérito terá sido democrática se todos os sujeitos exerceram o poder de apresentar elementos, teses e argumentos para, de alguma forma, influenciar na construção dessa norma jurídica. Assim, o poder de influência corresponde à dimensão material (ou substancial) do princípio do contraditório.

É justamente esse princípio que fundamenta a proibição de decisão surpresa.

A dimensão substancial do princípio do contraditório se manifesta, dentre outros, por meio dos seguintes dispositivos:

4.2.1. ART. 9º DO CPC/2015

Segundo o art. 9º do CPC/2015, nenhuma decisão pode ser proferida contra uma parte sem que ela seja previamente ouvida. A prévia oitiva da parte serve justamente para que ela possa buscar influir na decisão.

O referido dispositivo comporta três mitigações, ou seja, hipóteses em que a decisão poderá ser proferida contra alguém sem a sua prévia manifestação. São elas: i - tutela provisória de urgência; ii - tutelas de evidência previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC/2015; iii - decisão prevista no art. 701 do CPC/2015 (estando presentes os requisitos da ação monitória, o juiz, antes mesmo de ouvir o réu, determinará a expedição de um mandado de pagamento). Registre-se que em todas as hipóteses ora mencionadas, não há dispensa do contraditório, mas sim mera postergação. O contraditório, em tais casos, é diferido.

4.2.2. ART. 10 DO CPC/2015

Segundo o referido dispositivo, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

⁵ O princípio do devido processo legal é um é gênese dos demais princípios, pois todos os demais princípios acabaram decorrendo dele.

Evita-se, aqui também, decisão surpresa. Isso porque o fundamento constante na decisão de mérito deve ter sido submetido ao contraditório, ao exercício do poder de influência das partes. É o que ocorre, por exemplo, com o reconhecimento de prescrição ou decadência. Se o juiz, no curso do processo, entender que a pretensão da parte está prescrita ou o seu direito encontra-se fulminado pela decadência e se nenhuma das partes discutiu tal questão no curso do processo, deverá o juiz, antes de pronunciar a prescrição ou decadência, intimar as partes para se manifestar.

Contudo, é preciso ter cuidado com uma situação peculiar: quando a prescrição ou decadência for fundamento para o julgamento da improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1º, do CPC). Nesse caso, o juiz não precisará intimar previamente a parte autora para prolatar a sentença de improcedência liminar do pedido com base no art. 332, § 1º, do CPC. Essa ressalva é feita pelo próprio parágrafo púnico do art. 487 do CPC (“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”).

Por fim, impende destacar que, para parte da doutrina, todas as hipóteses do art. 332 do CPC não se submetem à observância do art. 10 do CPC, pois, segundo os referidos autores, no recurso de apelação contra a sentença que julga improcedente liminarmente o pedido cabe juízo de retratação, sendo a apelação, portanto, o meio que a parte deve se valer para se manifestar e buscar infirmar a conclusão adotada pelo juiz é a oportunidade que a parte tem de se manifestar.

Compreendemos, todavia, que tal entendimento não é o que melhor se coaduna com o espírito do novo CPC. Isso porque, em termos de restrição de direitos e de participação democrática, deve haver previsão expressa. Não somente, tal previsão somente existe em relação à hipótese do § 1º do art. 332 do CPC e não para os demais casos de improcedência liminar do pedido.

4.3. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

Enquanto o contraditório é, a um só tempo, o direito de participação (aspecto formal) e o poder de influência (aspecto substancial) que devem ser assegurados no processo; a ampla defesa é a sua realização empírica. Em outras palavras, a ampla defesa nada mais é senão a concretização, no mundo fenomênico, do princípio do contraditório (formal e material). Portanto, sempre que houver, na prática, a efetiva participação e o efetivo exercício do poder de influência pela parte, diz-se, então, que a ampla defesa foi exercida.

4.4. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

O referido princípio foi instituído pela Emenda Constitucional 45/2004, e não se confunde com o princípio da celeridade. Tal princípio tem expressa previsão no art. 5º, LXXVIII, da CF e no art. 4º do CPC.

Processo devido é processo célere? Não!

Processo devido é aquele que se desenvolve em tempo razoável. O processo, portanto, deve durar o tempo que for necessário para a construção da norma jurídica.

O princípio da razoável duração do processo se dirige a todos os atores do processo. Em relação ao juiz, cabe a ele, nos termos do art. 139, II, do CPC, velar pela razoável duração do processo. É possível inferir a concretização deste princípio, por exemplo, na previsão de tutelas provisórias, julgamento de improcedência liminar do pedido, julgamento antecipado parcial do mérito, procedimentos especiais etc.

4.5. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS AUTOS PROCESSUAIS

O princípio da publicidade dos atos processuais decorre de uma imposição constitucional (art. 93, IX, da CF).

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

A atuação do Poder Judiciário corresponde um agir do próprio Estado. Assim, a publicidade dos atos e decisões presta obséquio à supremacia do interesse público. Nesse sentido, prescreve o art. 11 do CPC “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Tal princípio também é reafirmado pelo art. 8º do CPC.

O princípio da publicidade dos atos processuais revela uma dupla garantia: a) garantia de controle e fiscalização da sociedade em geral em relação aos atos do poder público, em especial da atividade jurisdicional; b) garantia de imparcialidade do julgador.

É importante registrar que este princípio não é absoluto, comportando, pois, mitigações, as quais constam do art. 189 do CPC, *in verbis*:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Por fim, a preocupação do legislador com a publicidade dos atos processuais ainda se assenta na previsão constante do art. 367, §§ 5º e 6º, do CPC, que admite que a audiência seja integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que seja assegurado o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, independentemente de autorização judicial.

4.6. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO (OU FUNDAMENTAÇÃO) DAS DECISÕES JUDICIAIS

Assim como ocorre com o princípio da publicidade dos atos processuais, o princípio da fundamentação das decisões judiciais decorre de uma imposição constitucional (art. 93, IX, da CF).

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

O inciso X do art. 93 da CF também traz previsão expressa quanto à observância do dever de motivação das decisões administrativas dos tribunais.

“X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros”.

Nesse sentido, prescreve o art. 11 do CPC “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O princípio da motivação das decisões judiciais revela, também, uma dupla garantia: a) garantia de fiscalização da sociedade em geral; b) garantia do exercício do duplo grau de jurisdição, pois permite que as partes conheçam as razões que levaram o órgão julgador a decidir em determinado sentido.

Por fim, registre-se que o CPC se preocupou de tal maneira com a motivação das decisões judiciais que o § 1º do seu art. 489 elenca um rol de situações em que a decisão será considerada como não fundamentada. Vejamos:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

4.7. PRINCÍPIO DA ISONOMIA

O princípio da isonomia está previsto no artigo 7º do CPC. O art. 139, inciso I, do CPC dirige uma obrigação ao juiz, uma vez que ele deve velar pelo tratamento igualitário das partes. Este princípio decorre do princípio da igualdade, previsto no art. 5º, *caput* da CF. Por meio do princípio da isonomia, busca-se uma igualdade não apenas formal entre as partes, mas sim uma igualdade material, que na visão aristotélica nada mais é do que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Busca-se a chamada “paridade de armas”.

No processo, o princípio da isonomia se concretiza, por exemplo, na dilação de prazos processuais; prazo em dobro para o Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria Pública e litisconsortes com advogados distintos de escritórios advocacia distintos.

4.8. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO (PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA)

Tal princípio está consagrado no inciso XXXV do art. 5º da CF, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nesse sentido, a despeito do aumento vertiginoso da judicialização de interesses, o acesso à justiça é um direito fundamental, sendo, portanto, inconstitucionais eventuais barreiras a esse acesso.

O art. 3º do CPC, por sua vez, reproduziu o comando constitucional, dispondo que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. Entretanto, a referida inafastabilidade não impede que as próprias partes elejam um juízo arbitral para solucionar o conflito. Vale, aqui, o princípio da autonomia da vontade. De igual forma, a inafastabilidade não obsta a que os envolvidos no litígio busquem outras formas, estatais ou não estatais, de solução de conflito, como, por exemplo, a conciliação e a mediação.

O princípio do acesso à justiça, ao longo dos anos, foi evoluindo, ganhando, assim, nova roupagem. Tal evolução não passou despercebidas para Mauro Cappelletti, que identificou três grandes **ondas renovatórias**, a saber:

4.8.1. PRIMEIRA ONDA RENOVATÓRIA DO ACESSO À JUSTIÇA

Relaciona-se ao fim dos entraves financeiros do processo. Em outras palavras, não se pode negar acesso à justiça à pessoa pelo simples fato de ela sofrer delimitações financeiras. Nesse sentido, identifica-se esta primeira onda renovatória, no Brasil, na edição da Lei nº 1.060/50 (lei da gratuidade de justiça) e na criação e estruturação da Defensoria Pública.

4.8.2. SEGUNDA ONDA RENOVATÓRIA DO ACESSO À JUSTIÇA

Relaciona-se ao acesso à justiça pela coletividade. Há violação a direitos transindividuais cuja tutela deve ser buscada de forma coletiva. Em outras palavras, admite-se o acesso à justiça pela coletividade através de legitimados específicos.

No Brasil, podem ser citadas, dentre outras, as seguintes leis: Leis nº 4.717/65 (lei da ação popular), 7.347/85 (lei da ação civil pública), 8.078/90 (código de defesa do consumidor), 8.429/90 (lei de improbidade administrativa), entre outras.

4.8.3. TERCEIRA ONDA RENOVATÓRIA DO ACESSO À JUSTIÇA

Refere-se à busca por uma maior efetividade ao processo. Isso porque o processo é instrumento de realização do direito material. Cite-se, como exemplo, a Lei nº 11.232/2005, que alterou o CPC/73, para estabelecer a fase de cumprimento das sentenças no processo de conhecimento, em substituição à necessidade de se ajuizar uma ação executiva autônoma da sentença, tornando, assim, o processo sincrético e muito mais efetivo. Outro exemplo é a Lei nº 9.099/95 (lei dos juizados especiais) que estabelece um procedimento mais célere e adequado às causas menos complexas.

4.8.4. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFSTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO

É possível identificar três mitigações (ou flexibilizações) ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. São hipóteses nas quais o acesso ao sistema de justiça está condicionado à observância de certos critérios (constitucionais ou legais). Vejamos:

- **Lides desportivas:** para se ajuizar uma ação envolvendo lide desportiva, é necessário o **esgotamento** da via administrativa (desportiva), nos termos do art. 217, § 1º da CF.
- **Habeas data:** nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.507/97, a petição inicial deverá ser instruída com a prova: I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem qualquer decisão sobre tal pedido; II - da recusa em fazer a retificação ou transcurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou III - da recusa em fazer a anotação a que se refere o §2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. É importante destacar que no caso do *habeas data*, não se exige o esgotamento da via administrativa, mas tão somente a demonstração de tais requisitos na petição.
- **Ações previdenciárias:** para o ajuizamento de uma ação objetivando a concessão de benefício previdenciário, é necessário que tenha havido o prévio requerimento administrativo, ainda que não haja decisão administrativa definitiva junto ao respectivo órgão. Ora, se não há prévio requerimento administrativo, não há lide. Note que não se exige o esgotamento da via administrativa. Assim, havendo negativa da administração



ou demora excessiva no julgamento do pedido, estará configurada a resistência à pretensão (lide), revelando-se, por via consequencial, o interesse de agir⁶.

4.9. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL

O princípio do juízo natural impede a escolha casuística de juiz (ou juízo) para o processamento e julgamento de determinada causa. É preciso que as regras de competência previstas na Constituição Federal e nas leis sejam anteriores ao fato, sob pena de se criar, para o caso, um indevido juízo (ou tribunal) de exceção.

O princípio do juízo natural pode ser extraído dos incisos XXXVII e LIII do art. 5º da CF. Vejamos:

“XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção”.

“LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

É possível falar em princípio do promotor natural?

Segundo o entendimento do STF e do STJ, deve ser garantido no processo o chamado “promotor natural”, ou seja, veda-se, como regra, a designação casuística de órgãos de execução do Ministério Público (Promotores de Justiça e Procuradores da República) para determinados casos específicos para os quais, pelas regras de distribuição e divisão das atividades (promotorias e procuradorias da república), não possuem atribuição. Todavia, é perfeitamente possível a criação de forças tarefas com diversos promotores (ou procuradores), em razão da complexidade do caso, desde que seja garantida a atuação do promotor (procurador) natural. Tal princípio pode ser extraído da expressão “processado”, prevista no inciso LIII do art. 5º da CF.

4.10. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Tal princípio não possui previsão constitucional e não se trata de um direito fundamental previsto na CF. O princípio do duplo grau de jurisdição garante que a parte não fique vinculada apenas a uma única decisão. O referido princípio evita a concentração do poder nas mãos de um único órgão julgador e permite que a decisão seja revista por outro órgão jurisdicional.

O controle da atividade jurisdicional é interno, pois exercido pelo próprio Poder Judiciário.

Impende destacar que o princípio do duplo grau de jurisdição não impõe que qualquer decisão seja suscetível de recurso. Basta imaginar que os despachos de mero expediente são irrecorríveis. Além disso, nem toda decisão interlocutória está sujeita ao agravo de instrumento.

4.11. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL

A boa-fé processual é uma norma de conduta que impõe a todos os sujeitos que participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo. Por ser uma norma de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé objetiva. Nos termos do art. 5º do CPC, “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Tal princípio tem suas raízes na Constituição Federal, a saber: a) art. 1º, inciso III, da CF (dignidade da pessoa humana); b) art. 3º, inciso I, da CF (solidariedade); c) art. 5º, inciso LIV, da CF (princípio do devido processo legal).

⁶ Nesse sentido: STF: RE 631.240- MG.

É possível identificar três importantes funções do princípio da boa-fé processual:

- **Função interpretativa:** em linhas gerais, quer dizer que as manifestações das partes, bem como as decisões judiciais devem ser interpretadas de acordo com a boa-fé. Nos termos do § 2º do art. 322 do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Por sua vez, o § 3º do art. 489 do CPC prevê que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
- **Função integrativa:** refere-se à norma de conduta imposta aos atores do processo em suas relações para com o outro no processo. Tal função decorre do próprio art. 5º do CPC, segundo o qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
- **Função limitadora (ou de controle):** o princípio da boa-fé processual tem por função proibir o abuso do direito. O abuso do direito é comportamento que atenta contra a boa-fé processual, podendo gerar, conforme o caso, severas sanções à parte, como, por exemplo, na hipótese do art. 311, I, do CPC

São diversas as formas de concretização do princípio da boa-fé processual. Podem ser citadas, dentre outras, as seguintes:

4.11.1. PROIBIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Aquele que litiga de má-fé viola a boa-fé processual. Nos termos do art. 79 do CPC, “responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”. Por sua vez, o art. 80 do CPC elenca as hipóteses de litigância de má-fé. Vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

- I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
- II - alterar a verdade dos fatos;
- III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
- IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
- V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
- VI - provocar incidente manifestamente infundado;
- VII - interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

Nos termos do art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

4.11.2. PROIBIÇÃO DE CRIAÇÃO DOLOSA DE POSIÇÕES JURÍDICAS

O princípio da boa-fé processual veda que uma parte crie, de forma dolosa, uma situação (ou posição) jurídica desfavorável à parte contrária. Cite-se, como exemplo, o art. 258 do CPC. Imagine o seguinte exemplo: Tício ajuíza uma ação contra Mévio, informando na petição inicial que o réu encontra-se em local incerto e não sabido. Tício conhece o endereço de Mévio, mas força a citação por edital, porque sabe que, se isso ocorrer, será nomeado um curador especial à Mévio, o qual apresentará contestação por negativa geral, aumentando as chances de vitória de Tício.

4.11.3. RESPONSABILIDADE PESSOAL E REGRESSIVA DO JUIZ

Juiz que age com dolo ou fraude responde pessoalmente e regressivamente pelos danos causados à parte. Trata-se de comportamento violador da boa-fé processual. O mesmo ocorrerá quando o Ministério Público (art. 181 do CPC), o Advogado Público (art. 184 do CPC) e o Defensor Público (art. 187 do CPC) agirem com dolo ou fraude.

4.11.4. PROIBIÇÃO DO ABUSO DE DIREITO

Trata-se da função limitadora (ou de controle) do princípio da boa-fé processual. Aquele que abusa do seu direito no processo viola o princípio da boa-fé processual. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese do art. 311, I, do CPC, o qual permite ao juiz conceder a tutela da evidência contra aquele que abusar do seu direito de defesa ou atuar com propósito protelatório. Outro exemplo é o do § 2º do art. 1.026 do CPC, que prevê: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

4.11.5. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (*VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM*)

O princípio da boa-fé processual veda o comportamento contraditório. Significa dizer que a parte não pode criar uma legítima expectativa na parte contrária, em razão de um comportamento que ela própria apresentou, e, posteriormente, surpreendê-la negativamente com outro comportamento contraditório. Vejamos dois exemplos previstos no CPC:

“Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.”

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.”

O que se entende por nulidade de algibeira?

Trata-se da nulidade de bolso. A parte, ao invés de alegar uma nulidade na primeira oportunidade que tem de falar nos autos, prefere guardá-la para invocá-la no momento em que lhe parecer mais conveniente. Trata-se de comportamento violador do princípio da boa-fé processual, tanto no âmbito cível, quanto no âmbito criminal, conforme entendimento do STF e STJ.

Por fim, é importante elencar três enunciados do FPPC sobre o tema:

“O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva” (Enunciado 375 do FPPC).

“A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional” (Enunciado 376 do FPPC).

“A boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável às situações de fato análogas, ainda que em processos distintos” (Enunciado 377 do FPPC)



4.12. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO

Nos termos do art. 6º do CPC “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Quando falamos em princípio da cooperação, é necessário compreender 3 (três) tipos de **sistemas de estruturação do processo**.

4.12.1. ADVERSARIAL

O processo é visto como uma disputa entre autor e réu. O juiz, por outro lado, apresenta-se como um terceiro imparcial passivo e equidistante das partes, a quem cabe apenas decidir o conflito. O juiz não tem qualquer iniciativa. Neste sistema, prepondera o princípio dispositivo (art. 2º do CPC).

4.12.2. INQUISITORIAL

Neste sistema, o juiz é um terceiro que tem interesse na solução do conflito e, portanto, pode agir de ofício. Prepondera neste sistema o princípio inquisitivo. Há resquícios deste sistema no novo CPC, como, por exemplo, no campo probatório, em que o juiz, de ofício, pode determinar a produção de provas, ainda que não requeridas pelas partes (art. 370 do CPC).

4.12.3. COOPERATIVO

Nesse sistema, há um redimensionamento do princípio do contraditório. A criação da norma jurídica individualizada interessa a todos os atores do processo, inclusive ao juiz. Assim, todos os atores devem cooperar e participar ativamente, com boa-fé, para a construção do resultado mais justo, efetivo e tempestivo possível.

Tal sistema não corresponde ao abandono total dos demais, mas sim uma nova forma de compreender o sentido e a função do processo sob uma perspectiva constitucional e solidária. Trata-se do sistema (ou modelo) adotado pelo novo CPC, que, como disse, não abandonou por completo os demais sistemas. Ainda prepondera o princípio dispositivo no tocante à iniciativa do processo (art. 2º do CPC) e no campo probatório, tem-se resquícios de um sistema inquisitorial.

Nessa perspectiva, o princípio da cooperação surge exatamente desse novo pensar processual. Tal princípio se concretiza por meio de quatro importantes deveres:

- **Dever de esclarecimento e consulta (art. 10, CPC):** se o juiz tiver dúvida em algum ponto do processo ou em relação a algum fato alegado pelas partes, não pode simplesmente desconsiderá-lo pelo simples fato de não o ter compreendido. Caberá ao juiz, nesse caso, intimar a parte para que ela esclareça. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese do art. 139, VIII, do CPC.
- **Dever de prevenção (art. 139, IX do CPC e art. 321, CPC):** o processo deve marchar para a resolução do mérito, cabendo aos atores do processo buscar sanar vícios processuais e evitar decisões de extinção prematura do processo.
- **Dever de lealdade:** por meio deste dever, proíbe-se a litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC).
- **Dever de proteção:** cabe à parte evitar causar prejuízos à parte contrária. Tal dever se concretiza na revisão de responsabilidade objetiva (teoria do risco-proveito) do exequente, caso, após a prática de atos constritivos, sobrevier decisão reformadora



do título ou extintiva do processo executivo ou da fase de cumprimento de sentença (arts. 520, I e 776 do CPC).

4.13. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO (ADAPTABILIDADE OU FLEXIBILIZAÇÃO) DO PROCEDIMENTO

Processo devido é processo adequado às peculiaridades da causa. Nesse sentido, pode o juiz adequar/flexibilizar o procedimento, inclusive com a dilação de prazos processuais, para adequar o processo às peculiaridades da causa, conforme previsão do art. 139, VI, do CPC.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: VI – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

Impende destacar, contudo, que a dilação do prazo processual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 139 do CPC, somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

O princípio da adequação do procedimento se dirige tão somente ao juiz?

Não!

Além do juiz, são destinatários do referido princípio o legislador e as próprias partes.

Cabe ao legislador criar procedimentos adequados à realidade e peculiaridades dos seus destinatários. É o que ocorre, por exemplo, com a Lei nº 9.099/95 (lei dos juizados especiais), que foi pensada para atender a determinadas peculiaridades (causas menos complexas de até quarenta salários mínimos).

As partes também podem, mediante celebração de negócio jurídico processual atípico (art. 190 do CPC⁷), adequar o procedimento às suas peculiaridades. Ademas, no campo probatório, dispõe o § 3º do art. 373 do CPC que “a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”.

4.14. ORDEM CRONOLÓGICA

Trata-se de norma processual regra. Não é um princípio.

De acordo com o art. 12 do CPC, os juízes e os tribunais atenderão, **preferencialmente**, à ordem cronológica de conclusão para proferir **sentença ou acórdão**. Verifica-se, portanto, que as decisões interlocutórias e os despachos não se sujeitam à ordem cronológica.

O princípio orientador e justificador desta regra é o da isonomia, pois na observância da ordem cronológica de conclusão do processo, estar-se-á garantindo o tratamento isonômico às partes, evitando-se que seja escolhido o processo pela capa (matéria a ser decidida ou partes envolvidas).

Admite-se negócio jurídico processual para afastar esta regra?

Não!

O negócio jurídico processual está previsto no art. 190 do CPC e oportuniza às partes a celebração de uma convenção sobre deveres, prerrogativas, ônus, poderes processuais etc. Todavia,

⁷ Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

o negócio jurídico processual não pode ser aplicado para dispor sobre a ordem cronológica de conclusão do processo, vez que se trata de uma norma de interesse público e, uma vez modificada a ordem por mero interesse das partes, haverá prejuízo às partes dos demais processos, além de dar ensejo à criação de um verdadeiro “comércio” para modificação das posições ocupadas por cada processo dentro do sistema de justiça.

Impende destacar que a ordem cronológica não é uma regra absoluta. § 2º do art. 12 estabelece algumas mitigações. Vejamos:

§2º estão excluídos da regra do *caput*:

- I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;
- II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
- III - o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;
- IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
- V - o julgamento de embargos de declaração;
- VI - o julgamento de agravo interno;
- VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça;
- VIII - os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal;
- IX - a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.

É importante destacar que este rol é meramente exemplificativo.

Registre-se, ainda, que a inobservância, pelo juiz, da ordem cronológica não gera nulidade da sentença proferida, tendo em vista a ausência de prejuízo às partes envolvidas (*pas de nullité sans grief*). O terceiro que foi preterido, apesar de prejudicado, nada ganha com a anulação da sentença. Assim, o desrespeito à ordem cronológica pode ser apurado no plano disciplinar/correcional.

QUESTÕES

1- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I – Na fase instrumentalista o direito processual não tinha distinção com o direito material, não era uma ciência autônoma, assim, o direito processual seria o próprio direito material.

II – Com início em 1868 com a publicação da obra “teoria dos pressupostos processuais e exceções dilatórias”, de Oskar Von Bulow, o direito processual passou a ser visto como uma ciência autônoma, não mais se confundindo com o direito material.

III – Para o instrumentalismo, que tem como base o processualismo, há uma relação entre os direitos processual e material, apesar de ser reconhecida a autonomia do direito processual. Há uma relação circular entre estes dois ramos do direito, sendo direito processual civil o instrumento de realização do direito material.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão incorretas

2 - A respeito das normas fundamentais do processo civil, assinale a alternativa CORRETA.

a) Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, mesmo nos casos de tutela provisória de urgência.



- b) As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, salvo a atividade satisfativa.
- c) Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão
- d) O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
- e) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de inexistência.

3- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

- a) Empregar conceitos jurídicos indeterminados, mesmo quando explique o motivo concreto de sua incidência no caso.
- b) Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo mesmo não capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
- c) Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
- d) Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, identificando seus fundamentos determinantes e demonstrando que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
- e) Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, explicando sua relação com a causa ou a questão decidida.

4- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I – Na forma da lei a arbitragem é permitida, devendo o Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

II – Todos os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

III – O processo sempre começará por iniciativa da parte e se desenvolverá por impulso oficial, tendo o NCPC excluído as hipóteses de pronunciamento de ofício do ordenamento jurídico.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: D

Praxismo - O direito processual não tinha distinção com o direito material. Não era uma ciência autônoma. O direito processual seria o próprio direito material.

Processualismo – O direito processual passou a ser visto como uma ciência autônoma, não se confunde com o direito material. Oskar Von Bulow (1868) – Teoria dos pressupostos processuais e exceções dilatórias (processo civil possui institutos próprios, é uma ciência autônoma – autonomismo).

Instrumentalismo – Tem como base o processualismo. Há uma relação entre os direitos processual e material, apesar de ser reconhecida a autonomia do direito processual. Há uma relação circular entre estes dois ramos do direito, pois não existe direito oco. O direito processual civil é o instrumento de realização do direito material.

Neoprocessualismo (formalismo valorativo ou positivismo reconstruído) – tem a mesma ideia do neconstitucionalismo, pois traz as premissas metodológicas apontadas, além de toda produção doutrinária a respeito do tema. O processo à luz da Constituição.

2. Gabarito: D

a) Art. 9º, CPC. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência;

II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III – à decisão prevista no art. 701.

b) Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

c) Art. 12, CPC. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.

d) Art. 2º, CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

e) Art. 11, CPC. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

3. Gabarito: C

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

4. Gabarito: B

I - CORRETA - Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

II - CORRETA Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

III - INCORRETA - Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.



CAPÍTULO 2 — JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

1. JURISDIÇÃO

1.1. INTRODUÇÃO

A palavra jurisdição significa “**dizer o direito**”. Atualmente, deve ser compreendida não apenas como dizer o direito, mas também como “**efetivar o direito**”. A jurisdição é, a um só tempo, poder, função e atividade, por meio dos quais o Estado diz e realiza o direito no caso concreto, produzindo-se uma norma jurídica individualizada.

A jurisdição é desempenhada por uma pessoa que tem poder para exercer a jurisdição. Este desempenho se dá através da **investidura**, via de regra **por concurso público de provas e títulos**. No entanto, há outras hipóteses de investidura previstas na Constituição federal, como o **quinto constitucional** e livre **nomeação, pelo Presidente da República, para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal**.

A jurisdição busca a realização de três importantes objetivos: a) pacificação social; b) afirmação do poder estatal; c) dizer e realizar o direito no caso concreto

1.2. CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO

As características da jurisdição se revelam muito importantes na identificação da atividade estatal como sendo jurisdicional. Não se confundem, portanto, com os princípios relacionados à jurisdição. Vejamos, em primeiro lugar, as características.:

1.2.1. SUBSTITUTIVIDADE

Por meio da jurisdição, o Estado substitui a vontade das partes e diz o direito no caso concreto. Em outras palavras, o Estado, não permitindo a realização de uma “justiça com as próprias mãos”, substituiu a vontade das partes para solucionar o conflito.

Ocorre que há casos em que a constituição ou desconstituição de uma situação jurídica depende, necessariamente, da chancela do Estado. Fala-se, assim, em “**ação constitutiva necessária**”, ou seja, ações que somente por meio da chancela estatal é possível criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. É o que ocorre, por exemplo, nas ações de divórcio envolvendo filho incapaz, a qual necessariamente dependerá de uma sentença por parte do Poder Judiciário. Outro exemplo é a ação de interdição. Em relação às ações constitutivas necessárias, a doutrina a doutrina vai dizer que não há que se falar em substitutividade, pois o Estado não pode substituir algo que as próprias partes não podem resolver sozinhas.

1.2.2. INÉRCIA

A jurisdição, para ser exercida, precisa ser provocada. Isso porque, o juiz, como regra, não pode agir de ofício. Desta característica decorre o princípio da demanda (art. 2º do CPC) e o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

1.2.3. LIDE

Segundo Francesco Carnelutti, lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Para que se busque a tutela jurisdicional, é necessária a ocorrência de um

litígio/conflito de interesses, seja porque a pretensão de alguém foi resistida por outrem, seja porque a pretensão foi apenas insatisfeita. Aliás, é a partir da ideia de lide que se identifica o interesse de agir.

Parte da doutrina sustenta que a lide não é característica exclusiva da jurisdição, pois pode haver jurisdição sem lide, como, por exemplo, no procedimento especial de jurisdição voluntária. Todavia, quem defende essa posição entende que a jurisdição voluntária é jurisdição. Uma outra vertente doutrinária, contudo, entende que na jurisdição voluntária não há exercício de jurisdição propriamente dita, mas sim uma administração estatal de interesses privados. O tema será abordado mais à frente.

1.2.4. MANIFESTAÇÃO DE PODER

Por meio da jurisdição, o Estado exerce o seu poder. Decorrem desta característica da jurisdição duas outras importantes características: **imperatividade e inevitabilidade**. A jurisdição é **imperativa**, porque o Poder Judiciário faz cumprir as suas decisões. Decorre do poder-dever geral de efetivação, previsto nos artigos 139, inciso IV e art. 537, ambos do CPC. A jurisdição também é **inevitável**, porque uma vez exercida, o seu destinatário não pode simplesmente não concordar. Aliás, ninguém tem o direito ou o poder de decidir se se aceita ou não se submeter à jurisdição.

1.2.5. ATIVIDADE CRIATIVA

O juiz, mediante atividade interpretativa, extrai do texto legal a norma jurídica mais justa para o caso. Por meio da interpretação, recria-se a norma jurídica para o caso concreto.

Um exemplo muito marcante acerca da atividade criativa foi o julgamento, pelo STF, da ADI nº 4277, no qual se discutiu a possibilidade de união homoafetiva. O STF, na ocasião, interpretou o artigo 1.723 do Código Civil à luz da Constituição Federal e extraiu do texto sua verdadeira norma jurídica, qual seja, a de que é inconstitucional qualquer interpretação dada ao art. 1.723 do CC que proíba a união, como entidade familiar, de pessoas do mesmo sexo.

1.2.6. DEFINITIVIDADE

A definitividade é a característica da jurisdição que se revela pela aptidão que a decisão de mérito possui para tornar-se imutável (coisa julgada material).

1.2.7. TERCEIRO IMPARCIAL

A jurisdição é exercida por um terceiro imparcial e competente: o juiz. É importante ressaltar que o terceiro imparcial não é uma característica exclusiva da jurisdição. Podemos nos deparar com a imparcialidade, por exemplo, na mediação e na conciliação. Ou seja, a título de exemplo, é perfeitamente cabível que haja conciliação/mediação no âmbito de uma comunidade ou de uma associação, de tal modo que haverá uma atividade não jurisdicional de solução do conflito exercida por um terceiro imparcial.

1.3. PRINCÍPIOS DA JURISDIÇÃO

As características da jurisdição, como já estudado, são elementos que irão identificar o exercício da função jurisdicional do Estado. Em contrapartida, os princípios são fundamentos para as regras, correspondendo, em certa medida, aos pilares da estruturação da função jurisdicional e respectivas regras a ela relacionadas.

1.3.1. PRINCÍPIO DA INVESTIDURA

A jurisdição somente pode ser exercida por juiz investido nesta função. Como regra, a investidura decorre da aprovação em concurso público de provas e títulos. A Constituição Federal assegura outras formas de acesso, ou seja, hipóteses em que uma pessoa se torna juiz sem ser aprovado em concurso público para a magistratura, como ocorre, por exemplo, no quinto constitucional e na livre nomeação de Ministros do STF pelo Presidente da República.

A violação ao princípio da investidura atinge a própria existência do processo. Em outras palavras, processo que tramita perante um não juiz é um não processo. Veja-se que, neste caso, haverá violação a um pressuposto de existência do processo, pois para que o processo exista, deve ser instaurado perante um órgão investido de jurisdição.

1.3.2. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE (OU ADERÊNCIA AO TERRITÓRIO)

A jurisdição é una e exercida em todo o território nacional. Porém, por questões de funcionalidade, a própria Constituição e as leis estabelecem limites para o exercício da função jurisdicional. A esses limites, dá-se o nome de competência.

1.3.3. PRINCÍPIO DA INDELEGABILIDADE

O exercício da jurisdição é indelegável. O juiz não pode delegar a outrem o exercício da função jurisdicional. Contudo, há certas mitigações a este princípio, como por exemplo, nas cartas de ordem (art. 102, I, “m” da CF e art. 237, I do CPC). Nesse sentido, o STF, por exemplo, em uma ação de competência originária, objetivando ouvir uma determinada testemunha, pode expedir carta de ordem para ser cumprida por um Juiz Federal da subseção judiciária de domicílio da testemunha.

E em relação à carta precatória, trata-se de mitigação ao princípio da indelegabilidade?

A carta precatória (art. 237, III do CPC) não pode ser considerada mitigação ao princípio da indelegabilidade, pois a sua expedição decorre justamente do fato de que a função jurisdicional do juízo deprecante não pode ser exercida no juízo deprecado. A título de exemplo, se um juiz do Distrito Federal precisa ouvir determinada testemunha que reside em São Paulo, deverá expedir uma carta precatória para que seja realizada a oitiva da testemunha em São Paulo. Note que neste caso o juiz do Distrito Federal somente exerce jurisdição nesta unidade da federação. Logo, se ele não pode exercer sua função jurisdicional no estado de São Paulo, a carta precatória não pode corresponder a uma mitigação ao princípio da indelegabilidade. Em outras palavras, o juiz não pode delegar algo que não possui (competência para exercer a função jurisdicional em São Paulo).

A situação da carta precatória é diferente da carta de ordem, porque nesta (carta de ordem) o STF exerce jurisdição e tem competência em todo o território nacional.

1.3.4. PRINCÍPIO DA INEVITABILIDADE

Decorre da característica da manifestação de poder, já estudada. A jurisdição é imperativa e inevitável.

1.3.5. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (ou acesso à justiça) já foi estudado.



1.3.6. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

O princípio do juiz natural já foi estudado.

1.4. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA X JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

A distinção entre a jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa está centrada na existência ou não de um litígio. Enquanto se diz que a **jurisdição contenciosa** pressupõe-se o litígio, fala-se que na jurisdição voluntária não há litígio, pois apenas cancela-se uma situação jurídica que depende do Poder Judiciário.

Há duas correntes doutrinárias acerca da discussão sobre a jurisdição voluntária ser ou não uma jurisdição:

- **1ª Corrente:** a jurisdição voluntária não é jurisdição. Para esta corrente, jurisdição voluntária nada mais é do que a função de administração estatal de interesse privado, tendo em vista a ausência das características da jurisdição. Trata-se de corrente adotada pelo professor Humberto Theodoro Junior. Há julgados do STJ nesse sentido.
- **2ª Corrente:** a jurisdição voluntária é jurisdição. O fato de não haver lide não afasta o exercício da atividade jurisdicional do Estado. Em outras palavras, se houve uma resposta estatal, ainda que para cancelar uma situação jurídica, pressupõe-se o exercício da função jurisdicional. Na jurisdição voluntária há coisa julgada e definitividade sobre a sentença.

É perfeitamente possível que uma ação se inicie através de um procedimento especial de jurisdição voluntária e no curso do processo seja convertida em jurisdição contenciosa. O juiz poderá realizar essa conversão, segundo o entendimento do STJ.

Impende destacar ainda que no âmbito dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, o juiz não está vinculado à legalidade estrita (art. 723, §1º, do CPC). Permite-se o julgamento por equidade.

Não se pode confundir, contudo, julgamento por equidade com julgamento com equidade.

O **julgamento por equidade** é o que ocorre na jurisdição voluntária. Ou seja, o julgador, por conveniência ou oportunidade, profere a decisão mais conveniente, oportuna e mais coerente, ainda que não se observe a legalidade estrita. Quando se fala em **julgamento com equidade**, tem-se que todo juiz, independentemente de se tratar de jurisdição voluntária ou contenciosa, deve buscar a decisão mais justa possível e mais proporcional ao caso concreto.

1.5. EQUIVALENTES JURISDICIONAIS

O CPC/2015 instituiu um modelo (ou sistema) “multiportas” na busca da pacificação dos conflitos. Quando a solução do conflito ocorre por uma via diversa do Poder Judiciário, fala-se em equivalente jurisdicional, meios alternativos de solução dos conflitos ou meios adequados de solução dos conflitos.

Os meios alternativos de solução dos conflitos favorecem o diálogo entre as partes envolvidas no litígio e o poder de negociação. São modelos autocompositivos. Nessa perspectiva, o ideal é tratá-los como “meios adequados” de solução dos conflitos.

O incentivo do CPC/2015 é tamanho que após receber a petição inicial, deverá o juiz designar a audiência de conciliação ou mediação (art. 334), ou seja, antes mesmo da apresentação de contestação pelo réu. E se a parte não comparecer, tal comportamento será considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

Por fim, o CPC/2015 também passou a prever a existência de câmaras privadas de mediação e conciliação, empresas devidamente capacitadas e habilitadas que, juntamente com os mediadores e conciliadores, poderão atuar na pacificação dos conflitos em caráter judicial e extrajudicial.

Vejamos os principais equivalentes jurisdicionais:

1.5.1. AUTOTUTELA

A autotutela é o sacrifício de uma pretensão alheia por uma pretensão própria, ou seja, o fazer valer a pretensão pelo uso da força. Como regra, a autotutela não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro.

No entanto, há resquícios da autotutela no ordenamento jurídico brasileiro, são eles: a) legítima defesa da posse (desforço imediato), previsto no art. 1210, § 1º do CC; b) direito de retenção (art. 1.219 do CC); c) direito de greve (art. 9º da CF).

1.5.2. AUTOCOMPOSIÇÃO

É o sacrifício mútuo de pretensões, podendo ser total ou parcial, mas de forma voluntária, sem o uso da força. O artigo 487, inciso III do CPC identifica as hipóteses de autocomposição. São elas: a) reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Impende destacar que a autocomposição pode ocorrer tanto na via judicial quanto na via extrajudicial.

1.5.3. MEDIAÇÃO (LEI Nº 13.140/15)

Trata-se de meio adequado de resolução do conflito, exercido por um terceiro imparcial, o qual é um facilitador. Cabe ao mediador, mediante uso de técnicas adequadas, fazer com que as próprias partes identifiquem a origem do litígio, a fim de que elas mesmas ponham fim ao conflito.

Nos termos do § 3º do art. 165 do CPC,

o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 13.140/15, “a mediação será orientada pelos seguintes princípios: I - imparcialidade do mediador; II - isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; V - autonomia da vontade das partes; VI - busca do consenso; VII - confidencialidade; VIII - boa-fé.

Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação (art. 3º). A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele (art. 3º, § 1º).

Tratando-se de direitos indisponíveis, mas transigíveis, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público (art. 3º, § 2º).



A Lei nº 13.140/15 também admite a mediação no âmbito da Fazenda Pública. Dispõe o seu art. 32 que

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para: I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público; III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.

O modo de composição e funcionamento das câmaras de mediação será estabelecido em regulamento de cada ente federado (art. 32, § 1º). Contudo, a submissão do conflito às câmaras de mediação é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado (art. 32, § 2º).

Havendo consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial (art. 32, § 3º).

O § 4º do art. 32 da referida lei de regência traz uma importante ressalva: “não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos a autorização do Poder Legislativo”.

Por fim, impende destacar que estão compreendidas na competência das câmaras de mediação a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares.

1.5.4. CONCILIAÇÃO

Trata-se de meio autocompositivo no qual um terceiro imparcial auxilia as partes na solução do conflito. Diferentemente da mediação, na conciliação, o terceiro imparcial pode sugerir resultados. Nos termos do § 2º do art. 165 do CPC, “o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem”.

1.5.5. ARBITRAGEM (LEI Nº 9.307/96)

A arbitragem é o meio adequado de solução do conflito por meio do qual um terceiro imparcial (árbitro) será o juiz do caso. Trata-se, segundo entendimento do STJ, do exercício de uma jurisdição não estatal. A arbitragem, portanto, não é equivalente jurisdicional, mas verdadeira jurisdição não estatal. Ademais, não é meio autocompositivo, mas sim **heterocompositivo**.

Para que o litígio seja resolvido pela arbitragem, é necessária a existência de uma convenção de arbitragem, a qual é formada pela cláusula compromissória e pelo compromisso arbitral.

- **Cláusula compromissória:** é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato (art. 4º da Lei nº 9.307/96). A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira (art. 4º, § 1º). Tratando-se de contrato de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em

documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula (art. 4º, § 2º).

- **Compromisso arbitral:** é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9º). Em outras palavras, é o instrumento que leva o litígio ao árbitro. Trata-se do documento que tem por objetivo escolher o árbitro (ou árbitros), estabelecer o procedimento, entre outras questões procedimentais. O compromisso arbitral é firmado após a ocorrência do litígio. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda (art. 9º, § 1º). O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público (art. 9º, § 2º).

É importante ter em mente que é possível que própria cláusula compromissória compreenda tudo aquilo que deveria estar previsto no compromisso arbitral. Em outras palavras, é possível que na própria cláusula compromissória já se estabeleça todas as questões procedimentais, inclusive a escolha do árbitro. Neste caso, estar-se-á diante de uma **“cláusula compromissória cheia”**. Segundo entendimento do STJ, quando houver cláusula compromissória cheia, o compromisso arbitral será dispensado (REsp 1389763/PR).

A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.

Assim como ocorre na mediação, admite-se a arbitragem no âmbito da Fazenda Pública. Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.307/96 “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Nesse caso, a autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações (art. 1º, § 2º).

É importante destacar que **a arbitragem envolvendo a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade**.

O caráter jurisdicional da arbitragem pode ser extraído do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96, *in verbis*:

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Segundo o STJ, “a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória”⁸.

⁸REsp 1550260/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018.

Excepcionalmente, é possível que o Poder Judiciário, nos casos em que a nulidade da convenção é manifesta (ex.: celebrada por pessoa incapaz), decrete a sua nulidade, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral.

1.5.6. DISPUTE RESOLUTION BOARD

Também conhecido como *comitê de resolução de controvérsias*, é um importante instrumento para se buscar um maior equilíbrio nas relações negociais, solucionar problemas e controvérsias surgidos na execução de um contrato e, conseqüentemente, evitar a propositura de ação judicial ou amenizar eventuais efeitos dela decorrentes. Tal método tem origem no direito norte-americano e foi utilizado, no Brasil, em mais de uma dezena de contratos internacionais relativos aos jogos olímpicos e paraolímpicos do Rio de Janeiro no ano de 2016.

O *Dispute resolution board* ainda não foi disciplinado no Brasil, porém o permissivo legal para a sua criação pode ser extraído do art. 3º, § 2º, do CPC, já que se revela como um meio alternativo de solução de conflito.

Com efeito, a I Jornada sobre Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, editou três importantes enunciados, que passam a ser importantes nortes para a admissão e instituição do *dispute resolution board*. São eles:

“Enunciado 49. Os Comitês de Resolução de Disputas (*Dispute Boards*) são método de solução consensual de conflito, na forma prevista no § 3º do art. 3º do Código de Processo Civil Brasileiro”.

Enunciado 76. As decisões proferidas por um Comitê de Resolução de Disputas (*Dispute Board*), quando os contratantes tiverem acordado pela sua adoção obrigatória, vinculam as partes ao seu cumprimento até que o Poder Judiciário ou o juízo arbitral competente emitam nova decisão ou a confirmem, caso venham a ser provocados pela parte inconformada.

Enunciado 80. A utilização dos Comitês de Resolução de Disputas (*Dispute Boards*), com a inserção da respectiva cláusula contratual, é recomendável para os contratos de construção ou de obras de infraestrutura, como mecanismo voltado para a prevenção de litígios e redução dos custos correlatos, permitindo a imediata resolução de conflitos surgidos no curso da execução dos contratos.

1.6. LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

É possível que uma mesma demanda possa ser solucionada tanto pela jurisdição brasileira, quanto pela jurisdição estrangeira. Daí a importância de se conhecer os limites da jurisdição nacional.

O CPC estabelece hipóteses em que determinada demanda será julgada pela jurisdição nacional concorrentemente à jurisdição estrangeira, bem como as hipóteses de competência exclusiva da jurisdição nacional.

Há três importantes dispositivos que tratam dos limites da jurisdição nacional (arts. 21, 22 e 23 do CPC). Os arts. 21 e 22 do CPC tratam da competência concorrente, ou seja, hipóteses em que tanto a autoridade judiciária brasileira quanto a autoridade judiciária estrangeira terão competência para a causa. Já o art. 23 do CPC elenca as hipóteses de competência exclusiva da jurisdição brasileira.

Vejamos.

1.6.1. COMPETÊNCIA CONCORRENTE

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal”.

Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações:

I - de alimentos, quando:

a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;

b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos;

II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil;

III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional.

1.6.2. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

1.6.3. HOMOLOGAÇÃO DAS DECISÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL

Com a EC 45, a competência que era do STF passou a ser do STJ para homologação, no Brasil, de sentença estrangeira.

Cabe ressaltar que o STJ não analisa o mérito da sentença estrangeira. A atuação do STJ se limita a verificar a forma, competência, autenticidade, se há ofensa ou não à ordem pública, ou seja, há apenas um juízo de delibação. **Nos casos de competência exclusiva, a sentença estrangeira não pode ser homologada, pois não tem aptidão para produzir efeitos no Brasil.**

Após a homologação da sentença estrangeira, o título executivo passa a ser a decisão brasileira que homologou a sentença e não a sentença estrangeira em si. A decisão homologatória é **título executivo judicial** e o seu cumprimento (execução) ocorrerá perante a **Justiça Federal de 1º grau**.

O regime anterior (CPC 1973) adotava a alcunha de homologação de sentença estrangeira. No entanto, o CPC/2015, de forma mais técnica, fala em homologação de decisão estrangeira, abrangendo também acórdãos, decisões monocráticas e interlocutórias estrangeiras.

As decisões estrangeiras decididas em processo de jurisdição voluntária também precisam ser homologadas, inclusive aquelas que versam sobre estado da pessoas. Contudo, não se pode perder de vista que em relação ao divórcio consensual ocorrido no estrangeiro, o CPC dispensa a sua homologação pelo STJ, prevendo que, nesse caso, a decisão que decreta o divórcio no estrangeiro **produz desde logo efeitos regulares no Brasil** (art. 961, §5º).

1.7. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

A cooperação jurídica internacional ocorrerá, via de regra, por meio de homologação de sentença estrangeira, auxílio direto e carta rogatória e será regida por tratado de que o Brasil faz parte, observando-se: i - o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; ii - a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados; iii - a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente; iv - a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação; v - a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.

Caso não haja tratado internacional, a cooperação poderá ocorrer pela via diplomática, à luz do princípio da reciprocidade, **salvo no caso de homologação de sentença estrangeira, a qual dispensa a reciprocidade.**

Quanto ao objeto da cooperação jurídica internacional, este pode ser: i - citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial; ii - colheita de provas e obtenção de informações; iii - homologação e cumprimento de decisão; iv - concessão de medida judicial de urgência; v - assistência jurídica internacional; vi - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.

O auxílio direito será cabível quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Inexiste, portanto, comunicação direta entre autoridades jurisdicionais.

O auxílio direto pode ser ativo ou passivo. Será ativo quando solicitado pelo Estado brasileiro a um Estado estrangeiro; será passivo quando solicitado por Estado estrangeiro ao Estado brasileiro.

Quando o Estado brasileiro solicita o auxílio direto de Estado estrangeiro, a lei processual a ser observada é a do próprio país estrangeiro responsável pela diligência (*lex diligentiae*). Isso não impede, contudo, que o Estado brasileiro (solicitante), requeira ao Estado estrangeiro que na execução da diligência seja observado algum procedimento específico, desde que não haja ônus ao Estado requerido ou contrarie a ordem pública.

O pedido será encaminhado pela autoridade central estrangeira à autoridade central brasileira (Ministério da Justiça)⁹, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido.

A autoridade central brasileira, por sua vez, comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado.

Nos termos do art. 30 do CPC, além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: i - obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso; ii - colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira; iii - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.

⁹ Nos termos do § 4º do art. 26 do CPC, “o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica”.

Quando se tratar de auxílio direto que tenha por objeto a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitam de prestação jurisdicional, a autoridade central deverá adotar as providências necessárias para seu cumprimento (ex.: pedido de cópia de uma certidão imobiliária).

Recebido o pedido de auxílio direto, a autoridade central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central.

Por fim, registre-se que compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional (art. 34 do CPC).

Diferentemente do que ocorre no auxílio direto, na carta rogatória há comunicação direta entre as autoridades jurisdicionais. Recebida uma carta rogatória estrangeira para cumprimento, ela será encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores ao Superior Tribunal de Justiça para a análise do *exequatur* (art. 515, IX, do CPC).

O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Nesse procedimento, eventual defesa apresentada deve se restringir à discussão quanto ao atendimento ou não dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil, **sendo, em qualquer hipótese, vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira.**

2. COMPETÊNCIA

A jurisdição é una e exercida em todo o território nacional. Contudo, por uma questão de funcionalidade do próprio sistema de justiça, a Constituição e a lei podem limiar o exercício desse poder. Tal limite é o que se entende por competência, ou seja, o espaço em que o juiz exerce o seu poder jurisdicional.

A competência tem natureza jurídica de pressuposto processual de validade.

2.1. COMPETÊNCIA ABSOLUTA X COMPETÊNCIA RELATIVA

As regras que disciplinam a competência absoluta são de ordem pública, pois se relacionam ao próprio exercício da função jurisdicional. Já as regras que disciplinam a competência relativa referem-se a interesses provados das partes.

Para melhor elucidar a distinção entre competência absoluta e competência relativa, vejamos a tabela abaixo:

	COMPETÊNCIA ABSOLUTA	COMPETÊNCIA RELATIVA
Interesse	As regras de competência absoluta têm por objetivo preservar o interesse público	As regras de competência relativa têm por objetivo preservar o interesse particular das partes
Reconhecimento de ofício da incompetência	A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.	Via de regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz (súmula 33 do STJ). Exceção. Nos juizados especiais, a incompetência territorial pode ser conhecida de ofício (art. 51, III, da Lei nº 9.099/95).



Alteração pela vontade das partes	A competência absoluta não pode ser alterada pela vontade das partes . Em outras palavras, uma cláusula de eleição de foro não pode ter por objeto a modificação de uma regra de competência absoluta.	A competência relativa pode ser alterada pela vontade das partes (ex: cláusula de eleição de foro).
Alteração por conexão/continência	A competência absoluta não pode ser modificada por regras de conexão ou continência . É inderrogável (art. 62 do CPC).	A competência relativa pode ser modificada por regras de conexão ou continência . É derogável (arts. 55, 56 e 57 do CPC).
Mudança superveniente de uma regra de competência (absoluta ou relativa)	A mudança superveniente de uma regra de competência absoluta deslocará a competência , ou seja, os processos que tramitam perante um determinado juízo devem ser remetidos para o novo juízo absolutamente competente (ex: em determinada Comarca, havia uma única Vara Cível. Com a criação de uma Vara de Família, os processos que até então tramitavam na vara cível deverão ser remetidos para a nova vara criada, haja vista que esta tem competência absoluta em razão da matéria).	A mudança superveniente de uma regra de competência relativa não deslocará a competência . Aplica-se, neste caso, o princípio da <i>perpetuatio jurisdictionis</i> (art. 43 do CPC). Ex.: Foi ajuizada uma ação no foro de domicílio do réu (São Paulo). No curso do processo, o réu se muda para o Rio de Janeiro. Nesse caso, tendo em vista que a competência pelo domicílio do réu é relativa, não haverá deslocamento da competência.
Consequência do reconhecimento da incompetência	Reconhecendo-se a incompetência absoluta, haverá remessa dos autos ao juízo competente . Os atos decisórios e não decisórios manter-se-ão válidos, podendo o juiz competente, ao receber os autos, decidir quanto a validade ou invalidade dos atos praticados perante o juízo incompetente (art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC).	Reconhecendo-se a incompetência relativa, haverá remessa dos autos ao juízo competente . Os atos decisórios e não decisórios manter-se-ão válidos, podendo o juiz competente, ao receber os autos, decidir quanto a validade ou invalidade dos atos praticados perante o juízo incompetente (art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC).

A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação (art. 64, *caput*, do CPC). Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício pelo juiz (art. 64, § 1º, do CPC). No caso da incompetência relativa, esta deve ser alegada pelo réu como preliminar de contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência (art. 65, *caput*, do CPC).

Além do réu, o Ministério Público, quer seja como parte, quer seja como fiscal da ordem jurídica, tem legitimidade para arguir a incompetência, absoluta ou relativa.



Alegada a incompetência, a parte contrária deve ser ouvida, devendo o juiz decidir imediatamente após (art. 64, § 2º, do CPC). Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (art. 64, § 3º, do CPC). Repise-se, ainda, que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC).

2.2. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ

O princípio da *kompetenz-kompetenz* (ou competência da competência), embora não previsto expressamente na Constituição, decorre do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Por meio dele, todo juiz tem uma parcela mínima de competência. Isso porque, ainda quando absolutamente incompetente, o juiz terá competência para declarar a sua própria incompetência.

Trata-se de princípio que também se aplica à arbitragem, podendo ser extraído do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96.

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Impende destacar que o STF extrai do parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.307/96 a natureza jurisdicional da arbitragem.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória (STJ, INF 622 – REsp 1.550.260-RS).

“A instituição arbitral, por ser simples administradora do procedimento arbitral, não possui interesse processual nem legitimidade para integrar o polo passivo da ação que busca a sua anulação” (STJ, INF 613 - REsp 1.433.940-MG.).

2.3. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS

Pelo princípio da *perpetuatio jurisdictionis*, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, razão pela qual qualquer alteração superveniente do estado de fato ou de direito não poderá, como regra, gerar o deslocamento da competência.

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Extraí-se do referido princípio que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição. Desse modo, a petição inicial será registrada quando houver na comarca um único juízo competente (ex.: comarca com uma única vara cível). Por outro lado, a petição inicial será distribuída quando houver mais de um juízo competente na mesma comarca (ex.: comarca com duas



varas cíveis igualmente competentes).

Ademais, quando se ingressa com uma ação, deve-se verificar as regras de competência no momento do registro ou da distribuição, pois, caso haja alguma modificação no estado de fato ocorrida posteriormente (Ex.: mudança de domicílio do réu), não ocorrerá a modificação da competência.

Vejamos dois exemplos de aplicação do princípio da *perpetuatio jurisdictionis*:

- **Exemplo 1:** uma ação foi proposta no foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC). No curso do processo o réu passa a residir em outro estado da federação. Neste caso, **trata-se de modificação superveniente do estado de fato** (mudança de domicílio), a qual é irrelevante, já que quando da distribuição da petição inicial, o réu residia na comarca onde a ação foi proposta. Logo, aplica-se o princípio da *perpetuatio jurisdictionis* e o processo continuará a tramitar na comarca de origem.
- **Exemplo 2:** uma ação de reparação civil foi proposta perante a justiça comum estadual pelo procedimento comum, tendo em vista que o valor pleiteado equivale a 50 (cinquenta) salários mínimos. No curso do processo, sobrevém lei federal que altera a Lei nº 9.099/95, aumentando o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para 60 (sessenta) salários mínimos. Trata-se de **modificação superveniente do estado de direito**. Assim, aplica-se o princípio da *perpetuatio jurisdictionis* e o processo continuará a tramitar no juízo de origem, tendo em vista que quando da propositura da ação, o juizado especial cível não detinha competência para o processo e julgamento da referida demanda.

Não se pode perder de vista que a parte final do art. 43 do CPC traz duas importantes mitigações ao princípio da *perpetuatio jurisdictionis*, ou seja, situações em que a modificação superveniente do estado de direito gerará o deslocamento da competência.

- **1ª mitigação:** supressão de órgão judiciário (ex.: Emenda Constitucional extingue o STJ e cria dois novos tribunais superiores. Os processos que até então tramitavam no STJ deverão ser remetidos para os novos tribunais, conforme as novas regras criadas pela Emenda Constitucional).
- **2ª exceção:** alteração da competência absoluta (ex.: em determinada Comarca, havia uma única vara cível. Posteriormente é instalada uma vara de família. Nesse caso, como a competência da vara de família é absoluta em razão da matéria, os processos de família que até então tramitavam na vara cível, serão remetidos para a vara de família.

2.3.1. PERPETUATIO JURISDICTIONIS E ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA APÓS A SENTENÇA

Se houver alteração da competência absoluta somente após a prolação da sentença, não haverá remessa dos autos.

2.3.2. PERPETUATIO JURISDICTIONIS E DESMEMBRAMENTO DA COMARCA

Caso haja desmembramento de comarca, como regra, os processos somente serão remetidos para a nova comarca se houver a modificação de competência absoluta. Exemplo: as cidades “A” e “B” fazem parte da mesma comarca (comarca “A”). É editada uma lei que desmembra a comarca “A”, para que a cidade “B” passe a ser também comarca própria (comarca “B”). A comarca “B” é



devidamente instalada e passa a funcionar. Nesse caso, como regra, os processos que já estão tramitando na comarca “A” deverão continuar a tramitar nela, aplicando-se o princípio da *perpetuatio jurisdictionis*. Contudo, se o desmembramento das comarcas também modificar a competência absoluta, deverá haver remessa dos processos (ex.: ação real imobiliária referente a imóvel situado na cidade “B” que até então tramitava na comarca “A”, tendo em vista que quando da distribuição da ação a cidade “B” ainda pertencia à comarca “A”. Como o art. 47 do CPC estabelece uma regra de competência absoluta, a criação da comarca “B” gerou a modificação da competência absoluta em relação ao foro de situação da coisa. Assim, o referido processo deve ser remetido à nova comarca).

2.3.3. PERPETUATIO JURISDICTIONIS E PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO

O princípio do juízo imediato pode ser extraído do art. 147 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Nas ações para a tutela dos interesses de criança e adolescente, conforme previstas no ECA, a competência será do foro do local onde a criança ou o adolescente exerce com habitualidade o seu direito ao convívio familiar e comunitário. Para o STJ, o art. 147 estabelece uma regra de competência absoluta, pois fundada no **princípio do juízo imediato (juízo mais próximo à criança ou adolescente)**, razão pela qual **não será aplicado o princípio da *perpetuatio jurisdictionis***. Assim, caso a criança ou o adolescente, no curso do processo, passe a residir em outra comarca, os autos deverão ser remetidos para a comarca de domicílio do infante¹⁰.

2.4. CRITÉRIOS DETERMINATIVOS DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA

As regras de determinação da competência podem ser classificadas em três grandes critérios: objetivo, funcional e territorial.

2.4.1. CRITÉRIO OBJETIVO

Se relaciona com os elementos da ação. Podem ser divididos:

A) COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA

Refere-se ao elemento “partes”. Determinadas pessoas devem ser julgadas em um determinado juízo. Leva em consideração a qualidade da pessoa que figura em um dos polos da relação jurídica processual. Exemplo: a ação ajuizada na comarca de Salvador em que figure como réu o estado da Bahia deve ser distribuída a uma das varas da fazenda pública da comarca de Salvador/BA.

B) COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA

Diz respeito ao elemento “causa de pedir”. Dependendo da matéria discutida no processo, pode haver um juízo com competência absoluta. Exemplo: se na comarca houver vara de família, esta terá competência absoluta para as ações de família.

C) COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA

Tem a ver como o elemento “pedido”. Uma regra de competência pode ser determinada com base no valor da causa. Exemplo: Nos termos do art. ___, da Lei nº 9.099/95, os juizados especiais

¹⁰ C.f. CC 119318-DF

cíveis têm competência para as ações de menor complexidade cujo valor da causa não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos.

É importante destacar, contudo, que, **como regra, nos Juizados Especiais Estaduais a competência é relativa** para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos. Isso significa dizer que se alguém pretende ajuizar uma ação de cobrança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a ação pode ser ajuizada no juizado especial cível ou na vara cível pelo procedimento comum. Por outro lado, se valor da causa é superior a 40 (quarenta) salários mínimos, o juizado especial é absolutamente incompetente. A parte somente poderá ajuizar a ação se renunciar ao valor excedente a 40 (quarenta) salário mínimo.

Cumprido destacar, ainda, que no tocante ao Juizado Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência será sempre absoluta.

2.4.2. CRITÉRIO FUNCIONAL

O critério funcional está relacionado à função exercida pelo órgão jurisdicional no processo. Pode ser assim dividido:

A) CRITÉRIO FUNCIONAL POR GRAU DE JURISDIÇÃO

A competência é distribuída conforme o grau de jurisdição exercida pelo órgão. Exemplo: compete aos TJs e TRFs o julgamento do recurso de apelação contra sentença dos juízes a eles vinculados.

B) CRITÉRIO FUNCIONAL POR FASE DO PROCESSO

A competência é definida com base na fase do processo. Assim, o juízo prolator da sentença será o competente para o cumprimento da sentença. O juízo prolator da sentença penal que fixou o valor mínimo de indenização à vítima (art. 387 ____ CPP) não terá competência para o cumprimento da sentença em relação à indenização. Nesse caso, para a fase de cumprimento, a competência será do juízo cível.

C) CRITÉRIO FUNCIONAL POR OBJETO LITIGIOSO

A depender do objeto do litígio, pode ser que um órgão jurisdicional específico seja o competente. É o que ocorre, por exemplo, no incidente de arguição de inconstitucionalidade no tribunal (art. 948 do CPC). Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. Acolhida a arguição, a questão (inconstitucionalidade) será submetida ao plenário ou ao órgão especial, onde houver¹¹. Julgada a questão, os autos retornarão à turma (ou câmara) para o julgamento do recurso de apelação, o qual deverá adotar como uma das premissas de julgamento a decisão do plenário do tribunal (ou órgão especial) acerca da inconstitucionalidade arguida.

Note que, no mesmo processo, o julgamento quanto à (in)constitucionalidade da lei ou ato normativo em controle difuso é feito por um órgão e o julgamento do recurso é realizado por outro.

¹¹ Nos termos do inciso XI do art. 93 da CF/88, “nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno”.

2.4.3. CRITÉRIO TERRITORIAL

Diz respeito ao lugar. Assim, a competência pelo foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), por exemplo, é um critério territorial de determinação da competência. A competência territorial, como regra geral, é relativa. Contudo, há hipóteses de competência territorial absoluta, como, por exemplo, a competência do foro da situação da coisa para as ações reais imobiliárias (art. 47 do CPC) e a competência do foro do local onde ocorrer o dano para a ação civil pública (art. 2º da Lei nº 7.347/85).

Analisados os três critérios determinativos da competência (material, funcional e territorial), vê-se nos termos do art. 62 do CPC que **a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, é inderrogável por convenção das partes, ou seja, absoluta**. Em contrapartida, competência em razão do valor e competência territorial, como regra, é relativa, observadas as exceções já apresentadas.

2.5. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A justiça federal está compreendida dentro da justiça comum, ao lado da justiça estadual. As hipóteses de competência da justiça federal encontram-se elencadas no art. 109 da Constituição Federal.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

- I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
- II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
- III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
- IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
- V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
- V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;
- VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;
- VII - os *habeas corpus*, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
- VIII - os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
- IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
- X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
- XI - a disputa sobre direitos indígenas.

O art. 45 do CPC, na linha do citado art. 109 da CF, estabelece a competência cível da justiça federal.



Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

- I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;
- II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

Com efeito, não há previsão constitucional das hipóteses de competência da justiça estadual. Isso porque a sua competência é residual. Em outras palavras, se a ação não for da competência originária de tribunal superior, de alguma justiça especializada (militar, trabalho e eleitoral) ou da justiça federal, a competência será da justiça estadual.

Os conselhos de fiscalização de atividade profissional possuem natureza de autarquias, por isso a competência da Justiça Federal (art. 45 do CPC), embora não haja previsão expressa no art. 109 da CF. Por outro lado, ainda que haja interesse da União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, a competência não será da Justiça Federal quando se tratar de falência, recuperação judicial, insolvência civil, acidentes de trabalho, causas sujeitas à Justiça Eleitoral e causas sujeitas à Justiça do Trabalho, incluindo, portanto, a recuperação judicial e a insolvência civil – art. 45, inciso I do CPC.

Nas ações de falência, recuperação judicial e insolvência civil, ainda que haja interesse da União ou de qualquer dos entes federais, a competência será da Justiça Estadual. Assim, tratando-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho (causa de pedir), ainda que em face do INSS (autarquia federal), a competência será da Justiça Estadual

Quanto às fundações públicas, a luz do direito administrativo, elas podem ser subdivididas em: a) fundações públicas de direito público: são exemplos de autarquias. Tanto é que a doutrina clássica as chama de autarquias fundacionais e; b) fundações públicas de direito privado: a despeito da sua natureza de direito privado, o STJ entende que, muito embora as fundações públicas de direito público sejam modalidades de autarquias fundacionais, as fundações públicas de direito privado se equivaleriam às empresas públicas para fins de determinação da competência.

Assim, tratando-se de fundação pública federal (de direito público ou de direito privado), a competência será da Justiça Federal.

2.5.1. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL

As ações previdenciárias ajuizadas contra o INSS são da competência da justiça federal, tendo em vista que o INSS é uma autarquia federal (art. 109 da CF e art. 45 do CPC). Ademais, a súmula 689 do STF prevê que o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do estado-membro. Tal entendimento revela a existência de foros concorrentes para o segurado.

O § 3º do art. 109 da CF, por sua vez, prevê hipótese de delegação da competência federal para a justiça estadual.

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

A redação do § 3º do art. 109 da CF foi dado pela EC 103/2019, no pacote de transformações legislativas denominada “reforma da previdência”.



Para dar concretude ao aludido dispositivo, a Lei nº 13.879/2019 promoveu sensíveis alterações na Lei nº 5.010/66 (lei que organiza a Justiça Federal), dentre as quais a previsão da competência delegada da justiça estadual para ações previdenciárias. Vejamos o teor do art. 15, inciso III, da Lei nº 5.010/66 (lei que organiza a Justiça Federal):

Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:

III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal.

Infere-se do aludido dispositivo que quando a pessoa estiver domiciliada a mais de 70 km de município sede de vara federal, ela poderá ajuizar a ação tanto na justiça estadual (competência delegada) quanto na justiça federal. Tem-se, neste caso, foros concorrentes (*fórum shopping*). Contudo, se ela residir a menos de 70 km de município sede de vara federal, a justiça estadual será absolutamente incompetente para o feito, devendo o autor propor a ação, necessariamente, na justiça federal.

Há dois grandes problemas acerca da nova redação. O primeiro é que o dispositivo, que veio para regulamentar o § 3º do art. 109 da CF, foi publicado antes mesmo da norma constitucional. Há, aparentemente, inconstitucionalidade formal. Contudo, entendo que a própria redação anterior do § 3º do art. 109 da CF, bem como o fato de a Justiça Federal, atualmente, já estar interiorizada, ou seja, presente em todos os estados da federação e em inúmeras cidades do interior, já permitiam uma mudança no art. 15 da Lei nº 5.010/66. Ademais, ambas as mudanças (art. 109, § 3º, da CF e art. 15, III, da Lei nº 5.010/66) são fruto de um movimento legislativo de reforma da previdência. Some-se a isso o fato de que a modificação do texto do art. 15, III, da Lei nº 5.010/66 somente entrou em vigor após a publicação da EC 103/2019. Por todos esses fatores, entendo que não deve ser reconhecida qualquer inconstitucionalidade do dispositivo.

Por fim, registre-se que tal delegação ocorrerá apenas no primeiro grau de jurisdição, pois nos termos do § 4º do art. 109 da CF, **“o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”**.

2.5.2. DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA NAS EXECUÇÕES FISCAIS

O art. 15, I, da Lei nº 5.010/66 previa a delegação da competência federal para a justiça estadual para processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas, quando no local não houver vara federal. Contudo, a Lei nº 13.043/14 revogou expressamente o inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010/66, exterminando, assim, a delegação de competência para as execuções fiscais propostas pela União e demais entidades federais. Por conseguinte, as execuções fiscais da União e de suas autarquias somente poderão ser ajuizadas perante a justiça federal, ainda que no foro de domicílio do executado não haja vara federal.

2.5.3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AÇÕES AJUIZADAS CONTRA O CNJ E CNMP

A doutrina, de uma forma geral, entende que o art. 109 da CF elenca os casos de competência da justiça federal, admitindo uma interpretação restritiva. No entanto, o STF já temperou esse entendimento, ao reconhecer **competência da Justiça Federal de 1ª instância para julgar ações ajuizadas em face do CNJ, desde que não se trate de MS, MI, HD ou HC**, pois nestes casos a competência é do Supremo Tribunal Federal. Conferiu-se, assim, uma interpretação extensiva em relação ao art. 109 da CF, pois compete ao STF as demandas em que o próprio CNJ ou CNMP

figurarem no polo passivo. Assim, a competência do STF para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP limita-se às ações tipicamente constitucionais: MS, MI, HC e HD.

No caso de serem propostas ações ordinárias para impugnar atos do CNJ e CNMP, quem irá figurar como ré no processo é a União, já que os Conselhos são órgãos federais. Logo, tais demandas serão julgadas pela Justiça Federal de 1ª instância, com base no art. 109, I, da CF/88.

Cabe ressaltar que o entendimento acima é a regra.

No informativo 851 do STF, a Min. Relatora Cármen Lúcia invocou dois argumentos para fixar a competência no STF:

- **1º) O caso concreto discutia os poderes do CNJ para afastar lei inconstitucional.** Se o STF não julgasse a causa, isso significaria conferir à Justiça Federal de 1ª instância a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao CNJ para o cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida.
- **2º) Além da ação ordinária proposta pelo Sindicato, diversos servidores impetraram mandados de segurança contra a decisão do CNJ.** Assim, mesmo que a ação ordinária fosse remetida para a Justiça Federal de 1ª instância, continuariam no STF os mandados de segurança individuais. Desse modo, o mais recomendável seria a reunião dessas ações a fim de garantir, com a tramitação e o julgamento conjuntos, a prolação de decisões harmônicas sobre a legitimidade da situação jurídica afetada pelo CNJ.

2.5.4. TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL: PROCEDIMENTO PARA AFERIÇÃO DO INTERESSE FEDERAL

Caso o processo esteja tramitando na justiça estadual e a União, empresa pública federal, entidade autárquica federal, fundação federal ou conselho de fiscalização de atividade profissional manifestar interesse na causa, o juiz estadual deverá remeter os autos à justiça federal, pois somente o juiz federal possui competência para definir se a União ou entidade federal possui interesse ou não interesse. Decidindo o magistrado pela existência de interesse federal, o processo tramitará na justiça federal. Por outro lado, entendendo pela ausência de interesse federal o juiz Federal devolverá os autos à justiça estadual, sem, contudo, suscitar conflito de competência.

O novo CPC consagrou o entendimento há muito firmado pelo STJ na súmula 224 do STJ, a qual estabelece que, excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito.

O referido procedimento tem previsão nos §§ 1º e 3º do art. 45 do CPC

§ 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

Por fim, se a parte autora propõe a ação na justiça federal, mas cumula dois ou mais pedidos, sendo um deles de competência da justiça federal, o juiz estadual não admitirá a cumulação de pedidos, pois incompetente em relação àquele de competência da justiça federal, devendo indeferir a petição inicial em relação a ele. Vejamos a redação do § 2º do art. 45 do CPC:

§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.

2.6. FORO COMUM E FOROS ESPECIAIS DE COMPETÊNCIA

2.6.1. FORO COMUM

Domicílio do réu (art. 46 do CPC)

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

Se o réu tiver mais de um domicílio ou a ação for proposta contra mais de um réu, a competência será do foro de qualquer domicílio (qualquer domicílio do réu ou domicílio de qualquer dos réus, no caso de litisconsórcio passivo)

Se for incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

Se o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se ninguém tiver domicílio no Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

2.6.2. FOROS ESPECIAIS

A) AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL IMOBILIÁRIO

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

B) AÇÃO DE INVENTÁRIO, PARTILHA, ARRECADAÇÃO, CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE, IMPUGNAÇÃO OU ANULAÇÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL E DEMAIS AÇÕES EM QUE O ESPÓLIO FOR RÉU, AINDA QUE O ÓBITO TENHA OCORRIDO NO ESTRANGEIRO

Regra geral: domicílio do autor da herança, no Brasil.

Se o autor da herança não possuía domicílio certo, a competência será: i - do foro de situação dos bens imóveis; ii - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes foros; iii - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

C) AÇÃO EM QUE O INCAPAZ FOR RÉU

A ação será proposta no foro de domicílio do representante ou assistente do incapaz.

D) AÇÃO EM QUE A UNIÃO, ESTADOS, DF OU MUNICÍPIOS FOREM AUTORES

A ação será proposta no foro de domicílio do réu.



E se a União for demandada, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.

Se o Estado ou DF forem réus, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

E) AÇÃO DE DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO, ANULAÇÃO DE CASAMENTO E RECONHECIMENTO OU DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

As regras são estabelecidas pelo art. 53, I, do CPC

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

- a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
- b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
- c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;
- d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)¹²

F) AÇÃO DE ALIMENTOS

Foro do alimentando.

G) DEMAIS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL (COMPETÊNCIA RELATIVA)

O inciso III do art. 53 do CPC elenca uma série de hipóteses de competência territorial relativa, levando em consideração o domicílio de uma das partes da demanda. Vejamos:

- **Ação em que for ré pessoa jurídica:** local onde está a sede da pessoa jurídica;
- **Ação que tem por objeto obrigação contraída pela pessoa jurídica:** local onde se acha agência ou sucursal;
- **Ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica:** local onde a sociedade ou associação exerce suas atividades;
- **Ação que tem por objeto a exigibilidade do cumprimento de obrigação:** local onde a obrigação deve ser satisfeita;
- **Ação que tem por objeto direito previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03):** foro de residência do idoso;
- **Ação de reparação de dano por ato praticado por serventia notarial ou de registro em razão do ofício:** foro da sede da serventia notarial ou de registro.

H) FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO PARA A AÇÃO

O art. 53, IV, do CPC dispõe estabelece a competência pelo lugar do ato ou fato para as seguintes hipóteses: i – ação de reparação de dano; e ii - ação em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios.

¹² Alínea inserida pela Lei nº 13.849/19.



I) FORO NAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM RAZÃO DE DELITO OU ACIDENTE DE VEÍCULOS, INCLUSIVE AERONAVES

Domicílio do autor ou local do fato.

2.7. COMPETÊNCIA DE FORO X COMPETÊNCIA DE JUÍZO

Foro diz respeito ao território, ao local (comarca, subseção da Justiça Federal).

Juízo diz respeito a um dos órgãos jurisdicionais que atuam no foro (ex: 1ª vara cível da comarca “x”, 2ª vara cível da subseção judiciária “x” etc.).

A competência de foro é determinada pela CF, pelo CPC e por outras leis (ex.: LACP). Já a competência de juízo é determinada pelas leis de Organização Judiciária (ex.: criação de vara especializada em determinada comarca, seção ou subseção judiciária).

2.8. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA

2.8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As regras de competência decorrem de previsão constitucional e legal. Contudo, é possível que a lei preveja hipóteses de modificação da competência. Em outras palavras, uma regra de competência prevista em lei sofre derrogação pela própria lei. Além disso, é possível que essa derrogação ocorra pela vontade das partes.

É preciso ter em mente, contudo, a modificação da competência somente se aplica à competência relativa. Isso porque a competência absoluta é inderrogável. Assim, todas as hipóteses de modificação da competência que serão estudadas doravante se referem somente se aplicam à competência relativa.

Há, basicamente, dois critérios de modificação da competência: legal e convencional.

2.8.2. CRITÉRIO LEGAL

O CPC prevê duas formas de modificação legal da competência relativa: conexão e continência.

A) CONEXÃO

Nos termos do art. 55, “caput”, do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Note que a existência identidade entre um desses elementos da ação (causa de pedir ou pedido) é capaz de gerar decisões conflitantes, de tal modo que, por questões de segurança jurídica, faz-se necessária a reunião dos processos para julgamento conjunto em um único juízo.

Além da identidade entre causa de pedir ou pedido, consideram-se conexas, ainda, as seguintes ações:

- Ação de execução de título extrajudicial e ação de conhecimento quando decorrentes do mesmo ato jurídico (art. 55, § 2º, I, do CPC);
- Ações de execução fundadas no mesmo título executivo (art. 55, § 2º, II, do CPC).

Registre-se que o CPC, na hipótese prevista no “caput” do art. 55 levou em consideração a identidade entre elementos da ação. por outro lado, nas hipóteses previstas no § 2º do art. 55 do CPC, levou-se em consideração a identidade (ou afinidade) da relação jurídica.

Com efeito, além das hipóteses acima mencionadas, o § 3º do art. 55 do CPC prevê que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Neste ponto, o novo código encampou entendimento do STJ vigente desde o CPC/73, que adotou a chamada “teoria materialista da conexão”. Para esta teoria, deve ser reconhecida a conexão entre duas ou mais ações pelo simples risco de haver a prolação de decisões conflitantes, ainda que formalmente não haja conexão.

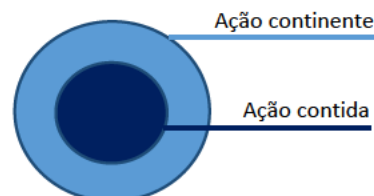
Reconhecendo-se a conexão, os processos serão reunidos para julgamento simultâneo perante o juízo prevento (art. 58 do CPC), ou seja, aquele onde ocorreu o primeiro registro ou distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC), salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1º, do CPC e súmula 235 do STJ).

B) CONTINÊNCIA

Nos termos do art. 56 do CPC, “dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

Exemplificando, todos os pedidos que a ação mais restrita (ação contida) possui, também estarão na ação mais ampla (ação continente). Todavia, nem todos os pedidos que a ação mais ampla possui, estarão na ação restrita.

A relação entre ação continente e contida pode ser ilustrada da seguinte forma:



A ação com pedidos mais amplos é chamada de ação continente, já a ação com pedidos mais restritos denomina-se de ação contida.

Assim como ocorre com a conexão, os processos continentes serão reunidos para julgamento simultâneo perante o juízo prevento (art. 58 do CPC), ou seja, aquele onde ocorreu o primeiro registro ou distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC).

Sob a perspectiva da ação contida, verifica-se que há entre ela e a ação continente uma litispendência, na medida em que todos os elementos da ação contida são idênticos aos da ação continente (partes, causa de pedir e pedido). Nessa perspectiva, o art. 57 do CPC dispõe que “quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.

São dois cenários diferentes:

- A ação contida foi proposta em primeiro lugar: a ação continente deve ser reunida à ação contida para julgamento simultâneo (arts. 58 e 59 do CPC);
- A ação continente foi proposta em primeiro lugar: a ação contida deverá ser extinta

sem resolução do mérito, tendo em vista que todos os seus elementos (partes, causa de pedir e pedido) já constam na ação continente (art. 57 do CPC).

2.8.3. CRITÉRIO CONVENCIONAL

É possível a modificação de uma regra de competência relativa por vontade das partes. Tal modificação ocorrerá em duas hipóteses: a) não alegação de incompetência relativa como preliminar de contestação; b) cláusula de eleição de foro.

A) NÃO ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA COMO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO

A incompetência relativa deve ser alegada pelo réu como preliminar de contestação, nos termos do art. 337, II, do CPC. A não alegação gera a prorrogação da competência, ou seja, o juízo, que até então era relativamente incompetente, passará a ser o competente para a causa. Nesse sentido, dispõe o art. 65 do CPC que “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

Note que a modificação da competência, neste caso, se dá pela inação do réu, ou seja, por não ter, no momento processual oportuno, alegado a incompetência relativa.

B) CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

A cláusula de eleição de foro é o negócio jurídico escrito por meio do qual as partes elegem o foro (local) competente para a resolução de eventual litígio decorrente do negócio jurídico subjacente.

Dispõe o art. 63, *caput*, do CPC que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico (art. 63, § 1º, do CPC). Note que não é possível cláusula de eleição de foro verbal. Ademais, o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes (art. 63, § 2º, do CPC).

É possível que a cláusula de eleição de foro seja abusiva. Basta imaginar, por exemplo, a cláusula inserida em contrato de consumo de adesão, forçando o consumidor a ter que demandar em foro muito distante daquele do seu domicílio. Qualquer das partes pode alegar a abusividade. O autor, na petição inicial, o réu, na contestação, sob pena de preclusão (art. 64, § 4º, do CPC). O juiz, por sua vez, pode conhecer de ofício, desde que antes da citação, ocasião em que deverá o juiz determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu (art. 63, § 3º, do CPC). É importante registrar que o juiz não decretará a nulidade da cláusula de eleição de foro, mas sim sua ineficácia.

2.9. CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Haverá conflito de competência quando: a) 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes (conflito positivo de competência); b) 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência (conflito negativo de competência); c) entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos (art. 66, *caput*, do CPC).

Quando o juiz se declara incompetente, cabe a ele, na decisão, apontar qual o juízo competente. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo (art. 66, parágrafo único, do CPC).

Suscitado o conflito pelo juízo declinado, instaura-se um incidente processual, o qual tramitará em um tribunal. Tal incidente tem por objetivo definir qual é o órgão competente para processar e julgar a demanda.

O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes (por petição), pelo Ministério Público (por petição) ou pelo juiz (por ofício). Caso uma das partes já tenha alegado a incompetência relativa do juízo, ela não poderá suscitar o conflito de competência (art. 952 do CPC). Porém, caso ela não tenha suscitado o conflito, poderá alegar a incompetência relativa (art. 952, parágrafo único, do CPC)

A competência para julgar o conflito dependerá dos órgãos envolvidos. Vejamos:

CONFLITO	ÓRGÃO COMPETENTE
STJ X quaisquer Tribunais	STF
Tribunal Superior X Tribunal Superior	STF
TJ/TRF X TJ/TRF	STJ
Juiz Federal X Juiz Estadual	STJ
Juízes estaduais ou federais X juízes estaduais ou federais de tribunais diferentes	STJ
Juiz Federal X Juiz Estadual investido de jurisdição federal	TRF
Juízes X Juízes do mesmo tribunal	Respectivo tribunal (TJ/TRF)
Juiz Federal X Juiz do Juizado Especial federal da mesma seção judiciária	Respectivo TRF ¹³

Suscitado o conflito, o suscitante deverá instruir a petição (ou o ofício, quando o conflito for suscitado pelo juiz) com os documentos necessários à prova do conflito (art. 953, parágrafo único, do CPC).

O incidente será distribuído a um relator, que determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. O relator poderá, ainda, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC).

Se já houver tese firmada em súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência sobre a competência discutida no incidente, o relator poderá julgar de plano o conflito.

Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento. O Ministério Público somente será ouvido se se tratar de processo envolvendo alguma

¹³ “Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária” (Súmula 428 do STJ).

hipótese de intervenção obrigatória (art. 178 do CPC), conforme prevê o art. 951, parágrafo único, do CPC.

Em sessão de julgamento, o órgão competente do tribunal julgará o conflito e declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Por conseguinte, os autos do processo em que se deu o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente (art. 957 do CPC).

No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal (art. 957 do CPC).

De igual forma, o regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre **autoridade judiciária e autoridade administrativa (art. 958 do CPC)**.

QUESTÕES

1-

- a) Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.
- b) Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil.
- c) Julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil.
- d) Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.
- e) Em matéria de sucessão hereditária, proceder e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

2-Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da competência.

- a) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
- b) A decisão do Juízo Federal que não exclui da relação processual ente federal pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
- c) Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente.
- d) O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.
- e) Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas no CPC ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

3-Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.
- b) A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo Estadual da situação do imóvel.
- c) A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato.
- d) Em nenhuma hipótese a incompetência relativa poderá ser reconhecida de ofício.
- e) O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

2. Gabarito: B

a) art. 43, CPC. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

b) Súmula 254, STJ - A decisão do Juízo Federal que não exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

c) Art. 45, CPC. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

d) Art. 45, § 3º, CPC O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

e) Art. 44, CPC. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.



3. Gabarito: D

- a) Súmula 206-STJ: A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.
- b) Súmula 238-STJ: A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo Estadual da situação do imóvel.
- c) Súmula 363-STF: A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato.
- d) Trata-se da redação da Súmula 33-STJ (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício).

O artigo 63, §3º prevê uma exceção à sumula 33 do STJ: § 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao ". Assim, em regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ou seja, a própria parte prejudicada é quem deverá alegar. **Exceção:** o foro de eleição é uma regra de competência relativa. Mesmo assim, ela pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado se o foro de eleição for abusivo.

CAPÍTULO 3 — AÇÃO

1. AÇÃO

1.1. CONCEITO

Em sentido amplo, ação é o meio de se provocar a atividade jurisdicional.

Em sentido estrito, o conceito de ação sofreu sensíveis transformações ao longo da história. Nesse sentido, é importante conhecer as teorias explicativas do direito de ação.

1.1.1. Teoria imanentista

Para esta teoria, defendida por **Savigny**, o direito de ação seria o próprio direito material em movimento, que estaria reagindo a uma agressão ou ameaça. Não há distinção entre direito material e direito de ação.

1.1.2. TEORIA DA AÇÃO COMO DIREITO CONCRETO

Foi uma das primeiras teorias a distinguir o direito de ação do direito material. Desenvolvida pelo alemão **Adolf Wach**, a ação seria um direito exercido pelo indivíduo contra o Estado, objetivando a obtenção de uma sentença favorável. Tal teoria, de certa forma, tem como base de desenvolvimento a ideia de autonomia do processo em relação ao direito material, desenvolvida por Oskar Von Bülow.

Adolf Wach demonstrou a autonomia do direito de ação em relação ao direito material, citando, como exemplo, a ação declaratória, pois é possível ajuizar uma ação para a obtenção de declaração de inexistência de relação jurídica de direito material. Não se pode perder de vista, contudo, que, para a teoria concretista, somente haverá direito de ação se a sentença for favorável. Ação é o direito, voltado contra o Estado, para a obtenção de uma sentença favorável.

1.1.3. TEORIA DA AÇÃO COMO DIREITO POTESTATIVO

Para esta teoria, desenvolvida por **Chiovenda**, a ação não seria um direito voltado contra o Estado, mas sim um poder exercido contra o réu que, diante de uma sentença favorável ao autor, se submete aos efeitos da decisão judicial, independentemente de sua vontade. Tal teoria tem base concretista, pois defende que somente haverá direito de ação se, ao final, a sentença for procedente.

1.1.4. TEORIA DA AÇÃO COMO DIREITO ABSTRATO

Desenvolvida por **Degenkolb** (Alemão) e **Plósz** (Húngaro), tal teoria defende que a ação é o direito público, subjetivo e abstrato à obtenção de um pronunciamento do Estado, que pode ou não ser favorável ao autor. Daí decorre o acento tônico desta teoria: seu caráter abstrato. Dizendo por outras palavras, ainda que, ao final, o pedido do autor não lhe seja favorável, ele terá exercido o direito de ação. Podem ser apontadas três importantes características desta teoria: a) separação entre direito de ação e direito material; b) direito à obtenção de um pronunciamento do Estado-Juiz; c) direito que subsiste ainda que a sentença não seja favorável ao autor.



1.1.5. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO

Desenvolvida por **Liebman**, a teoria eclética tem base na teoria abstrata. Pode ser compreendida como o direito a obtenção de uma resposta de mérito. Embora o direito der ação seja incondicionado, para o seu exercício, exige-se a observância das denominadas “condições da ação”. São elas: a) legitimidade para a causa; b) interesse de agir; e c) possibilidade jurídica do pedido.

Foi a teoria adota pelo CPC/73 e, para parte da doutrina, também no novo CPC.

A possibilidade jurídica do pedido se revelava sempre que o pedido do autor não encontrasse proibição no ordenamento jurídico. Assim, se alguém ajuizasse uma ação de cobrança de dívida de jogo, seria carente de ação, haja vista que a cobrança de dívida de jogo é proibida pelo ordenamento jurídico (art. 814 do CC). Contudo, a doutrina sempre criticou essa condição da ação, na medida em que, ao fim e ao cabo, se um determinado pedido encontra proibição no ordenamento jurídico, o caso é de improcedência, ou sejam de resolução do mérito, e não de carência de ação e, consequentemente, extinção do processo sem resolução do mérito.

O CPC/2015 abandonou a possibilidade jurídica do pedido como uma espécie de “condição da ação”. nos termos do art. 17 do CPC/2015, “**para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade**”. Aliás, o novo código sequer utiliza a expressão “condições da ação”, fazendo nascer sérias dúvidas quanto à manutenção ou não da teoria eclética.

1.2. AÇÃO E EXECUÇÃO

Compreendido o conceito de ação, pode surgir alguma dúvida sobre se a execução é, de fato, ação. e a resposta é sim, Isso porque na execução há resposta de mérito, mediante a prática de atos que visam a satisfação do direito da parte, como, por exemplo, penhora e alienação de bens do executado.

1.3. ELEMENTOS DA AÇÃO

Os elementos da ação servem para identificar se uma ação é idêntica à outra, ou melhor, serve para distinguir uma ação de outra.

São três os elementos da ação: a) partes, b) causa de pedir; c) pedido.

Havendo a existência de duas ações contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, haverá **litispendência**. Por conseguinte, a ação que foi proposta em segundo lugar será extinta, sem resolução de mérito, nos moldes no art. 485, V, do CPC.

Por outro lado, caso seja proposta uma ação contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de outra ação já ajuizada e julgada, o seu processamento não será possível, em razão da existência de **coisa julgada**. Por conseguinte, o processo deverá ser extinto, sem resolução de mérito, nos moldes no art. 485, V, do CPC.

Vejamos os elementos da ação:

1.3.1. PARTES

São partes: autor e réu. O primeiro é o que promove a ação. O segundo é aquele contra quem se promove a ação. excepcionalmente, pode haver processo sem autor (ex.: arrecadação de coisa vaga – art. 744 do CPC) e ação sem réu (ex.: ação de reconhecimento e dissolução de união estável *post mortem* sem que o *de cujus* tenha deixado qualquer herdeiro).

1.3.2. CAUSA DE PEDIR

A doutrina trabalha com a causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A **causa de pedir remota** corresponde aos fatos em si, ou seja, os fatos que geraram aquela demanda/litígio. Quanto à **causa de pedir próxima**, está se revela nas consequências/repercussão jurídica.

A título de exemplo, ajuizada uma ação indenizatória em decorrência de um acidente de trânsito, a causa de pedir remota são os fatos (colisão). Por sua vez, a causa de pedir próxima corresponde à repercussão jurídica dos fatos (responsabilidade civil do réu).

1.3.3. PEDIDO

Segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, a pretensão da parte autora é bifronte, pois o pedido sempre será de duas ordens: pedido imediato ou pedido mediato.

O **pedido imediato** é a resposta estatal, já o **pedido mediato**, é o bem da vida pretendido Ex.: pedido de reparação civil dos danos para condenar e determinar que a parte se abstenha de praticar determinada conduta - obrigação de fazer ou não fazer, dentre outras.

É possível ainda, que haja identidade entre as partes e entre os pedidos (causa de pedir próxima).

Se, no entanto, a causa de pedir for apenas remota, não há identidade entre as ações e, portanto, não se fala em litispendência e coisa julgada. Ex.: Quando se ajuíza uma ação de despejo, em razão da falta de pagamento e, na defesa, o locatário comprova o pagamento, o juiz julgará improcedente a ação. No entanto, se após três meses, o autor ajuíza nova ação de despejo, com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir próxima (resolução do contrato e, conseqüentemente, o despejo), mas com causa de pedir remota distinta da primeira ação. Neste caso, há duas ações distintas.

1.4. DESISTÊNCIA DA AÇÃO

A ação é um direito público subjetivo e abstrato. Uma vez proposta a ação, é possível que a parte autora dela desista. Eventualmente, a homologação da desistência dependerá do consentimento do réu (art. 485, § 4º, do CPC). O CPC estrutura a questão da seguinte forma:

- Desistência apresentada antes da contestação apresentada pelo réu: a homologação independe do consentimento do réu;
- Desistência apresentada após a contestação apresentada pelo réu, mas antes da sentença: a homologação depende do consentimento do réu. Contudo, a parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, **ainda que já apresentada contestação**, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia (art. 1.040, §§ 1º e 3º, do CPC). Nesse caso, se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência (art. 1.040, § 2º, do CPC).

No âmbito do processo de execução e cumprimento de sentença, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Contudo, deve ser observada a seguinte regra, nos termos do art. 775 do CPC:

- Se o executado opôs embargos à execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença) versando apenas sobre questões processuais, a desistência da execução não

dependerá do consentimento do executado e gerará a extinção da execução e dos embargos;

- Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

No âmbito recursal, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (art. 998 do CPC).

Desistência da ação não se confunde com renúncia. Enquanto aquela se refere ao prosseguimento do processo e gera sua extinção sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), esta última se refere ao próprio direito material discutido em juízo e gera a resolução do mérito (art. 487, III, “c”, do CPC). Contudo, ambas constituem ato processual dispositivo, exigindo do advogado poderes especiais, conforme previsão do art. 105 do CPC.

QUESTÕES

1-Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I – O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, mas não a autenticidade ou da falsidade de documento.

II – É inadmissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual.

III – Salvo quando tenha ocorrido a violação do direito, é admissível a ação meramente declaratória.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

2-Acerca das teorias do direito de ação, marque a alternativa INCORRETA.

a) Para a teoria imanentista, defendida por Savigny, o direito de ação seria o próprio direito material em movimento, que estaria reagindo a uma agressão ou ameaça. Não há distinção entre direito material e direito de ação.

b) Para a teoria concretista, também conhecida como teoria do direito concreto de ação – que foi uma das primeiras teorias a distinguir o direito de ação do direito material –, desenvolvida pelo alemão Adolf Wach, a ação seria um direito exercido pelo indivíduo contra o Estado, objetivando a obtenção de uma sentença favorável.

c) Para a teoria da ação como direito potestativo, a ação não seria um direito voltado contra o Estado, mas sim um poder exercido contra o réu que, diante de uma sentença favorável ao autor, se submeteria aos efeitos da decisão judicial, independentemente da sua vontade.

d) Desenvolvida por Degenkolb e Plósz, a teoria abstrata pode ser compreendida através das seguintes características: a) separação entre direito de ação e direito material; b) é o direito a obtenção de um pronunciamento do Estado-Juiz; c) o direito de ação existe ainda que a sentença não seja favorável ao autor; d) o direito de ação depende das seguintes condições: i – legitimidade para a causa; ii – interesse de agir e; iii – possibilidade jurídica do pedido.

e) A denominada teoria da asserção, inspirada no direito italiano, é aceita pela doutrina brasileira e STJ.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: E

I – INCORRETA - Art. 19, CPC. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento.

II – INCORRETA - Súmula 181, TJ “É admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual”.

III – INCORRETA - Art. 20, CPC. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.

2. Gabarito: D

a) CORRETA.

b) CORRETA.

c) CORRETA.

d) INCORRETA. O erro desta assertiva está na característica “d”. Isso porque, a teoria abstrata não trabalhou com a ideia de condições da ação. As chamadas condições da ação foram desenvolvidas por Liebman na teoria eclética do direito de ação. É importante destacar que a teoria eclética tem como ponto de partida a teoria abstrata, distinguindo-se desta, especificamente, no tocante às condições da ação.

e) Correta. Segundo a teoria da asserção (*in status assertionis* ou *della prospettazione*), as condições da ação devem ser verificadas partindo-se do pressuposto de que as alegações do autor são verdadeiras. A doutrina vem defendendo que, uma vez iniciada a fase probatória, caso eventual carência de ação seja detectada por ocasião da instrução processual, e não pela simples leitura da petição inicial, não se pode mais extinguir o feito por carência de ação, devendo o juiz, conforme o caso, julgar improcedente o pedido, ou seja, resolver o mérito.

CAPÍTULO 4 — PROCESSO

1. PROCESSO

1.1. CONCEITO

Quando falamos em processo, devemos ter em mente a chamada *instrumentalidade do processo*, que designa a ideia de que o processo é o instrumento de realização do direito material. Através dele, o Poder Judiciário exerce a jurisdição. Processo é, assim também, o instrumento da jurisdição.

O processo pode ser compreendido sob dois grandes aspectos:

- **Aspecto objetivo:** o processo é um conjunto de atos ordenados e encadeados que devem ser praticados para se chegar à tutela jurisdicional. Processo como procedimento.
- **Aspecto subjetivo:** o processo é uma relação jurídica que se forma e se desenvolve entre autor e réu.

Diante disso, temos que o processo deve ser compreendido como um procedimento que se desenvolve dentro de uma relação jurídica.

O **processo de conhecimento** tem por objetivo resolver uma crise de certeza, e pode ser dividido em ação condenatória, constitutiva e declaratória.

O **processo de execução**, por sua vez, tem a finalidade de resolver uma crise de efetividade. Nele, há certeza quanto ao direito, o qual, contudo, precisa ser efetivado. Esse processo pode ser dividido em execução de título executivo extrajudicial e cumprimento de sentença.

1.2. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

O NCPC, no art. 485, estabelece que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando ausente os pressupostos processuais.

Os pressupostos processuais podem ser divididos da seguinte forma:

1.2.1. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE EXISTÊNCIA

As leis processuais não estabelecem um rol de quais seriam os pressupostos processuais de existência. De forma geral, para que um processo tenha existência jurídica, exige-se:

A) PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DE CARÁTER SUBJETIVO

- Em relação ao juízo: órgão investido de jurisdição
- Em relação às partes: capacidade de ser parte. É a capacidade de fato (art. 1º do CC), ou seja, a aptidão que toda pessoa tem de ser titular de direitos e obrigações. O CPC também confere a certos entes despersonalizados a capacidade de ser parte (ex.: condomínio, massa falida, sociedade de fato etc.)

B) PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DE CARÁTER OBJETIVO

- Existência de uma demanda: não há processo sem demanda.



1.2.2. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE

Os pressupostos processuais de validade podem ser divididos da seguinte forma:

A) PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DE CARÁTER SUBJETIVO

- **Em relação ao juízo:** competência e imparcialidade
- **Em relação às partes:** capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória e legitimidade:
 - ⇒ **Capacidade de estar em juízo:** diz respeito à capacidade de exercício. Nos termos do art. 70 do CPC, “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Tal dispositivo decorre da capacidade civil conferida pelo Código Civil aos maiores de dezoito anos, que possuem a chamada capacidade de exercício (art. 3º do CC);
 - ⇒ **Capacidade postulatória:** é a aptidão técnica e especial conferida a determinadas pessoas para a prática de certos atos processuais. Via de regra, somente os advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil possuem capacidade postulatória, a qual lhes confere a prerrogativa de peticionar perante o órgão jurisdicional, recorrer das decisões, apresentar arrazoados, formular perguntas às testemunhas etc. Não obstante, há situações nas quais a própria parte, mesmo sem ser advogada, detém capacidade postulatória. São exemplos: a) capacidade postulatória do próprio jurisdicionado para as causas de até 20 (vinte) salários mínimos no procedimento da Lei nº 9.099/95¹⁴; b) capacidade postulatória dos membros do Ministério Público (art. 129 da CF/88); e c) capacidade postulatória do Presidente da República e Governadores de Estado para o ajuizamento de ADI, ADC, ADO e ADPF (art. 103 da CF/88);
 - ⇒ **Legitimidade “ad causam”:** é a pertinência subjetiva para a demanda. Em regra, os titulares da relação jurídica processual devem ser os mesmos da relação jurídica de direito material. Contudo, há casos em que tal simetria não ocorrerá, nascendo, então, a chamada legitimação extraordinária (quando o ordenamento jurídico autoriza que alguém, em nome próprio, defenda pretensão jurídica de outrem.

B) PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DE CARÁTER OBJETIVO

- **Pressupostos de validade objetivos intrínsecos:** são todos os elementos que dizem respeito à marcha do processo. Em outras palavras, são os elementos formais do processo (formalidade do processo).
- **Pressupostos de validade objetivos extrínsecos:** podem ser de duas ordens: i – objetivo; ii – subjetivos.
 - ⇒ **Positivo:** interesse de agir.
 - ⇒ **Negativos:** circunstâncias que não podem estar presentes para que o processo tenha validade. São elas:

¹⁴Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

- **Inexistência de litispendência:** haverá litispendência quando for proposta uma ação idêntica (mesmas partes, causa de pedir e pedido) a outra já em curso;
- **Inexistência de perempção:** haverá perempção quando o autor der causa à extinção do processo por abandono por três vezes;
- **Inexistência de coisa julgada:** haverá coisa julgada quando for proposta uma ação idêntica (mesmas partes, causa de pedir e pedido) a outra já transitada em julgado.

PERGUNTAS

1- Toda falta de pressuposto processual gera inadmissibilidade da demanda?

R: Não. Basta imaginar a incompetência (relativa ou absoluta). O reconhecimento da incompetência não gera a extinção do processo, mas a sua remessa ao juízo competente.

2- Toda ausência de pressuposto processual pode ser conhecida de ofício?

R: Não.

Ex. 1: Súmula 33 do STJ – “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Ex. 2: Juiz não pode reconhecer de ofício convenção de arbitragem.

3- Toda falta de pressuposto processual pode ser conhecida a qualquer tempo?

R: Via de regra, os pressupostos processuais são questões de ordem pública e conhecíveis de ofício. Todavia, nem toda ausência de pressuposto processual pode ser reconhecida de ofício e em qualquer tempo. Por exemplo, o juiz não pode conhecer de ofício a incompetência relativa e a existência de convenção de arbitragem. Ademais, se tais questões não forem suscitadas pelo réu em preliminar de contestação, haverá preclusão.

1.2.3. LEGITIMIDADE AD CAUSAM

A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda. Trata-se de qualidade conferida pelo ordenamento jurídico para que determinada pessoa formule, em nome próprio, uma pretensão em juízo. E essa legitimidade decorrerá ou do fato de a pessoa ser titular da relação jurídica de direito material discutida ou de expressa autorização constitucional ou legal.

Como regra, tem legitimidade, ativa ou passiva, o titular da relação jurídica de direito material subjacente. Trata-se da chamada **legitimação ordinária**. Assim, a ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda, por exemplo, deve ser ajuizada por um dos contratantes contra o outro; a ação de despejo, da mesma forma, deve ser ajuizada pelo locador contra o locatário.

Não obstante, é possível que o próprio ordenamento jurídico permita que o não-titular da relação jurídica de direito material defenda, em nome próprio, pretensão alheia. Quando isso ocorre, fala-se em **legitimação extraordinária (ou substituição processual)**.

O legitimado extraordinário defende em juízo, em nome próprio, interesse alheio. O titular da relação jurídica processual não é titular da relação jurídica de direito material subjacente, mas está autorizado pelo ordenamento jurídico a ocupar um dos polos do processo como substituto processual. Nesse caso, o legitimado é *parte processual*, mas não é *parte material (parte do litígio)*.

Exemplo: legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação em defesa dos interesses, ainda que



individuais, de incapaz¹⁵; alienante de coisa litigiosa na hipótese de o seu adversário não consentir com a sucessão processual pretendida pelo adquirente (art. 109 do CPC).

Essa distinção, entre legitimação ordinária e legitimação extraordinária é extraída da parte final do art. 18, *caput*, do CPC (“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”). É o que ocorre, por exemplo, na legitimidade do Ministério Público para as ações coletivas.

A legitimidade extraordinária pode ser autônoma ou subordinada.

A *legitimidade extraordinária autônoma* significa que o ordenamento jurídico não exige a presença do titular da relação jurídica de direito material, ou seja, atribui legitimidade unicamente para determinado ente. O legitimado poderá agir sozinho. É exemplo dessa modalidade de legitimidade, o que ocorre nos contratos de consórcio, em que há o grupo consorciado e a administradora do consórcio. A administradora do consórcio defende em nome próprio interesse alheio (interesses do grupo). Veja-se, que a administradora possui legitimidade para ajuizar ação sem a necessidade de participação do grupo.

Na *legitimidade extraordinária subordinada*, o ordenamento jurídico exige a presença do titular da relação jurídica de direito material. Ex.: art. 121 do CPC, a figura do assistente simples na relação processual. Para que seja possível a atuação do assistente simples, é imprescindível a presença do assistido.

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissor o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.

O assistido pode até ser omissor e revel, mas deve fazer parte do processo. Nessa mesma linha, se o assistido desistir da ação, reconhecer a procedência do pedido, renunciar a pretensão ou transigir no processo, o assistente nada poderá fazer, uma vez que ele segue a sorte do assistido. Trata-se, portanto, de uma legitimidade extraordinária subordinada, pois depende da existência de outra pessoa.

Fala-se, ainda, em legitimidade exclusiva e concorrente. Na **exclusiva**, o ordenamento jurídico só admite a atuação de um único legitimado, seja ele ordinário ou extraordinário. Na **concorrente**, há mais de um legitimado. Dentro da chamada legitimidade concorrente, temos a legitimidade concorrente conjuntiva e disjuntiva.

- *Legitimidade concorrente conjuntiva*: há a necessidade de atuação de todos os legitimados concorrentes. Exemplo: litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges na ação reação imobiliária (art. 73 do CPC).
- *Legitimidade concorrente disjuntiva*: há mais de um legitimado, mas a lei não impõe a atuação de todos. Exemplo: determinada pessoa exerce posse e propriedade em condomínio com outras pessoas. Caso haja invasão dessa propriedade, a lei não exige a formação de litisconsórcio, sendo que qualquer um dos proprietários-

¹⁵ DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, aprovam-se as seguintes teses: 1.1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente. 1.2. A legitimidade do Ministério Público independe do exercício do poder familiar dos pais, ou de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. 2. Recurso especial provido. (REsp 1265821/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 04/09/2014)



possuidores (legitimidade concorrente) poderá ajuizar a ação de reintegração ou manutenção de posse (litisconsórcio facultativo).

1.2.4. INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir (ou interesse processual) é um pressuposto processual de validade extrínseco positivo. Se revela por meio de um binômio: *interesse-utilidade* e *interesse-necessidade*.

- **Interesse-utilidade:** o processo deve ter aptidão para proporcionar à parte algum proveito jurídico. **Exemplo:** a ação de despejo contra o locatário que, mesmo após o encerramento do contrato de locação, não desocupou o imóvel, é útil ao locador, pois, por meio dela, ele terá o bem novamente à sua disposição. Haverá, portanto, um proveito jurídico e econômico ao autor-locador. Por outro lado, se a ação de despejo for ajuizada após a desocupação do locatário, o pedido de despejo não é útil ao autor e, portanto, pelo menos em relação a este pedido, não haverá interesse de agir.
- **Interesse-necessidade:** haverá necessidade sempre que o bem da vida pretendido pelo autor não puder ser obtido de outra forma que não mediante o processo. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de solução do conflito por meios alternativos (equivalentes jurisdicionais), por si só, não retira o interesse de agir no que tange ao aspecto da *necessidade*. Isso porque, como regra, ninguém pode ser obrigado a buscar uma determinada forma de solução de conflito. É possível, contudo, que a lei exija, para a obtenção do bem da vida, o prévio requerimento administrativo. Nesse caso, a ausência do prévio requerimento conduz ao reconhecimento da ausência de interesse de agir. **Exemplo:** ação objetivando a percepção de benefício previdenciário. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise¹⁶.

1.2.5. LEGITIMIDADE E INTERESSE: CONDIÇÕES DA AÇÃO?

Nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O novo código não fala mais em “condições da ação”. Também não faz referência à “carência de ação”, o que levou parte da doutrina a defender que a legitimidade e o interesse de agir migraram das condições da ação para os pressupostos processuais. Contudo, vem prevalecendo que as condições da ação não foram abandonadas pelo novo código. A questão é meramente teórica.

1.2.6. TEORIA DA ASSERÇÃO

A legitimidade para a causa e o interesse de agir podem ser conhecidos a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC. A inobservância desses pressupostos processuais leva à extinção do processo (ou de parcela dele) sem resolução do mérito.

Com efeito, nem sempre é fácil fazer a distinção entre o que é pressuposto processual/condição da ação (legitimidade e interesse de agir) e o que é mérito. Isso porque em

¹⁶ Tal entendimento, contudo, não se aplica à ação de revisão de benefício previdenciário. De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que não é necessário prévio requerimento administrativo para se configurar o interesse de agir de demanda revisional previdenciária. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 932.436/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014 e EDcl no AgRg no REsp 1.479.024/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 4/8/2015.

muitos casos somente é possível descobrir que a parte é ilegítima ou que o autor não possui interesse de agir após a instrução processual. Em tal caso, admitir o reconhecimento da ilegitimidade ou ausência de interesse de agir após o decurso de longa marcha processual viola a segurança jurídica, a economia processual, a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo.

É justamente nesse contexto que nasceu, na Itália, a teoria da asserção (*in status assertion* *isu della prospettazione*), segundo a qual a análise da legitimidade e do interesse de agir deve ser feita pelo juiz levando-se em consideração apenas, e de forma abstrata, os fatos alegados pelas partes, que serão tomados, em um exame inicial, como se verdadeiros fossem.

Nesse sentido, se antes da instrução processual o juiz verificar que pela simples leitura da petição inicial, há ilegitimidade de parte ou ausência de interesse de agir, deverá, caso não seja possível corrigir o vício, proferir sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Contudo, se somente após a instrução do processo ficar demonstrado que desde a propositura da ação, uma das partes já era ilegítima ou que o autor não detinha interesse de agir, deverá o juiz julgar o pedido improcedente, resolvendo, pois, o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Note, assim, que a análise da legitimidade e do interesse de agir deve ser feita de forma abstrata, partindo-se do pressupostos de que tudo o que consta na petição inicial é verdadeiro. O juiz se fará a seguinte pergunta: imaginando que tudo o que o autor narrou é verdadeiro, há ilegitimidade ou ausência de interesse de agir? Se a resposta for positiva, é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Se a resposta for negativa, o processo terá sua marcha normal, porém, se, após a instrução processual, for revelado que, em verdade, há ilegitimidade de parte ou ausência de interesse de agir, o juiz deverá resolver o mérito, julgando improcedente o pedido do autor.

QUESTÕES

1- Assinale a alternativa INCORRETA, nos termos do CPC.

- a) Apenas quando autorizado pelo ordenamento jurídico um terceiro poderá pleitear direito alheio em nome próprio.
- b) Ainda que haja a violação do direito, é admissível a ação meramente declaratória.
- c) É necessário ter capacidade e interesse para postular em juízo.
- d) O substituído, no caso de substituição processual, poderá intervir como assistente litisconsorcial.

2- Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do CPC.

- a) Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
- b) Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é dispensável nas hipóteses de composses ou de ato por ambos praticado.
- c) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
- d) O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.



e) Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias.

3-Assinale a alternativa correta:

- a) Fala-se em legitimidade anômala quando um terceiro é “chamado” a integrar a relação processual, como ocorre no chamamento ao processo e na denunciação à lide.
- b) Se diz bifronte a pretensão que a petição inicial apresenta ao juiz, pois a exigência representada pela demanda desdobra-se em duas: a de obter o provimento jurisdicional e a de obter o bem da vida.
- c) A efetiva observância das regras do procedimento não se insere na garantia do devido processo legal.
- d) O CPC trata como sinônimas as figuras da substituição processual e sucessão processual.
- e) Não há, no plano do direito processual, presunção absoluta.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C

- a) Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
- b) Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
- c) Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
- d) Art. 18, Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

2. Gabarito: B

- a) Art. 75, § 1º, CPC. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
- b) Art. 73, § 2º, CPC. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composses ou de ato por ambos praticado.
- c) Art. 76, CPC. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
- d) Art. 73, CPC. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.
- e) Art. 75, § 4º, CPC. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias.

3. Gabarito: B

- a) INCORRETA. Legitimação anômala é a legitimidade extraordinária. Cite-se, como exemplo, a legitimação do Ministério Público nas ações coletivas. Não se pode confundir legitimidade anômala com “intervenção anômala” (ou anódina). Esta é a intervenção da Fazenda Pública em uma demanda, conforme previsão do parágrafo único do art. 5º da lei 9.469/1997, que estabelece que “A



União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes”.

b) CORRETA. Quando se diz que a pretensão deduzida na petição inicial é bifronte, deve se entender que há, em verdade, dois pedidos (ou pretensões): o primeiro é o de obter um provimento jurisdicional, uma resposta do Estado-Juiz (pedido imediato); o segundo é o de obter o próprio bem da vida. (Vide: DINAMARCO. Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. Malheiros: São Paulo, 2002).

c) INCORRETA. Vide comentários à assertiva “b” da questão 12.

d) INCORRETA. Na substituição processual, a pessoa, em nome próprio, defende direito alheio. Não há alteração subjetiva da demanda. Decorre da lei, conforme art. 18 do NCPC. Já na sucessão processual, um sujeito sucede outrem, havendo alteração subjetiva da demanda, seja em razão da lei, de um fato ou mesmo por ato voluntário (Ex. morte, fusão de empresas, alienação de coisa litigiosa etc.). O art. 42 do CPC/73 gerou certa confusão, diante do emprego inadequado da palavra “substituição” em seu § 1º, quando se referia, em verdade, à sucessão processual. O NCPC corrigiu o problema, ao dispor, no parágrafo único do art. 109, que “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”.

e) INCORRETA. No plano do direito processual, pode haver presunção absoluta. Basta lembrar as hipóteses de impedimento do juiz (art. 144 do NCPC). Em tais casos, presume-se, de forma absoluta, a parcialidade do juiz.

CAPÍTULO 5 — SUJEITOS PROCESSUAIS

1. SUJEITOS PROCESSUAIS

1.1. PARTES

Autor (aquele que pede) e réu (aquele contra a quem se pede algo). O tema já foi estudado.

1.1.1. SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Sucessão processual nada mais é do que a **exclusão de uma das partes para ingresso de outra**. Uma das partes primitivas sai, advindo outro sujeito que ocupará o lugar daquela.

Essa sucessão poderá ocorrer tanto no polo ativo como no polo passivo, e poderá decorrer de ato entre vivos (ex.: alienação da coisa objeto da demanda no curso do processo) ou de *causa mortis* (ex.: falecimento da parte e sucessão pelos seus herdeiros).

No ato entre vivos, nada impede que no processo de conhecimento, o demandante venha a transferir direito ou a coisa litigiosa a terceiro. Neste caso, a legitimidade das partes não será alterada como regra.

Contudo, o terceiro adquirente poderá requerer o seu ingresso no processo, a fim de suceder o alienante. Nesse caso, a parte contrária será intimada. Se ela consentir, haverá a sucessão processual, passando o terceiro a ocupar o polo processual até então ocupado pelo alienante. Se a parte contrária não consentir, o alienante (parte originária) continuará no processo, mas agora como substituta processual do adquirente, pois passará a defender, em nome próprio, um direito que foi transferido a outrem (terceiro).

Dizendo por outras palavras, na alienação de coisa litigiosa, quando a parte contrária consente com o ingresso do terceiro adquirente, haverá a sucessão processual. Quando não há esse consentimento, haverá mera substituição processual (a parte originária continua, mas agora como substituta processual do terceiro). O não consentimento da parte contrária, contudo, não impede que o terceiro ingresse no processo na qualidade de assistente litisconsorcial do alienante. Em todo o caso, os efeitos da sentença atingirão o terceiro.

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º do CPC (art. 110 do CPC).

O CPC prevê, ainda, a substituição dos procuradores das partes, o que se dá por meio da revogação do mandato ou renúncia pelo próprio profissional.

A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assumo o patrocínio da causa (art. 111 do CPC). Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 do CPC (art. 111, parágrafo único, do CPC).

O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor (art. 112 do CPC). Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112, § 1º, do CPC). Dispensa-se a comunicação ora referida quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia (art. 112, § 2º, do CPC).

1.2. CURADOR ESPECIAL

Pode-se definir o curador especial como o sujeito processual que ingressa no processo para defender, em nome próprio, interesses de determinadas pessoas que se encontram em uma situação de desigualdade processual em relação ao seu adversário.

O exercício da curadoria especial é atribuição da Defensoria Pública (art. 72, parágrafo único, do CPC), configurando verdadeira função institucional, nos termos do art. 4º, XVI, da LC 80/94. Contudo, se na localidade não houver Defensor Público, caberá ao juiz nomear uma pessoa idônea para o exercício desse múnus.

Será nomeado curador especial nas seguintes hipóteses, nos termos do art. 72 do CPC: a) ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; b) ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Os poderes do curador especial são, predominantemente, de defesa/exercício do direito de defesa. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem ampliando demasiadamente os poderes do curador especial. Inicialmente, por meio da súmula 196, firmou entendimento no sentido de que **“ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”**. Tal entendimento, diante da peculiaridade do rito da execução, nos parece razoável, na medida em que a despeito da natureza jurídica de ação, os embargos à execução permitem ao executado contrapor-se à pretensão do exequente, exercendo uma espécie de “defesa” em relação à pretensão do exequente. Mais recentemente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1088068/MG, firmou entendimento no sentido de que **o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital**, sob o fundamento de que tal poder encontra-se inserido no amplo conceito de defesa¹⁷.

1.3. CAPACIDADE DAS PESSOAS CASADAS

O CPC, no art. 73, estabelece as hipóteses em que o autor necessitará do consentimento do seu cônjuge para propor determinadas ações, bem como as hipóteses em que ambos os cônjuges deverão ser necessariamente citados.

O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor uma ação, quando se tratar de uma ação real imobiliária, salvo se casado pelo regime da separação absoluta de bens (art. 73, caput, do CPC). Não se trata de litisconsórcio ativo, mas de mero consentimento. Tanto que, caso o cônjuge não consinta, o autor poderá pleitear, em procedimento próprio, que o juiz supra o consentimento.

Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo.

¹⁷ REsp 1088068/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017.

Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo.

No tocante ao polo passivo, o § 1º do art. 73 do CPC prevê as hipóteses em que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. São elas: a) quando a ação versar sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; b) ação resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; c) ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; d) ação que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

A participação do cônjuge do autor ou do réu nas **ações possessórias** somente será necessária quando se tratar de composses ou de ato praticado por ambos (art. 73, §2º do CPC).

1.4. JUIZ

É o órgão que participa da relação jurídica processual como mais um dos integrantes do diálogo processual.

1.4.1. CONDUÇÃO DO PROCESSO

O art. 139 do CPC revela muitos institutos e concretiza inúmeras normas fundamentais e princípios processuais. Em rol exemplificativo, o art. 139 estabelece as principais incumbências do juiz na direção e gestão do processo. Vejamos:

- Assegurar às partes igualdade de tratamento: concretização do princípio da isonomia/paridade de armas;
- Velar pela duração razoável do processo: princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF);
- Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias: assegurar a boa-fé processual e cooperação;
- Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária: esse inciso atribui ao magistrado o **poder-dever geral de efetivação**. Ou seja, ainda que a parte não requeira determinada medida, o juiz pode adotá-la de ofício (ex.: fixação de *astreinte*);
- Promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais: revela o *sistema multiportas* de solução de conflitos. É importante mencionar, que a solução de conflitos não deve ser realizada tão somente pelo órgão judiciário, podendo as partes se valer de meios extrajudiciais. A conciliação será adotada, **preferencialmente**, nas demandas em que não há relação anterior entre as partes(ex.: ação envolvendo relação de consumo). Por outro lado, a mediação será adotada, preferencialmente, nas demandas em que há relação anterior entre as partes(ex.: ação de família).
- Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito: revela o princípio da adaptabilidade do processo ou do procedimento, também conhecido como princípio da adequação/flexibilização do processo ou do procedimento. **Cuidado!** O juiz somente poderá dilatar (ampliar) o prazo processual quando este ainda não transcorreu, conforme prevê o parágrafo único do art. 139. O juiz poderá, ainda, adaptar a ordem de produção das provas, a distribuição do ônus da



prova, sem prejuízo de as partes adaptarem também o procedimento por meio de um negócio jurídico processual.

- Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais: poder administrativo do juiz na gestão dos trabalhos do fórum.
- Determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso: cuidado! Não confundir o interrogatório (art. 139, VIII, do CPC) com o depoimento pessoal (art. 385 do CPC). No simples interrogatório não haverá aplicação da pena de confesso, pois, diferentemente do depoimento pessoal (art. 385 do CPC), não se trata de meio de prova.
- Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais: esse inciso se concretiza através do princípio da sanabilidade dos vícios processuais e princípio da primazia do julgamento de mérito (processo deve caminhar para a resolução do mérito);
- Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.

1.5. PRINCÍPIO DO *NON LIQUET* (ART. 140, CPC)

O princípio do *non liquet* se extrai do artigo 140 do CPC, vejamos:

Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.

Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

Não se pode confundir “julgamento com equidade” com “julgamento por equidade”. Todo julgamento deve ser com equidade, ou seja, justo. O julgamento por equidade, por outro lado, é aquele no qual o juiz poderá se valer de critérios de conveniência e oportunidade. O julgamento por equidade depende de previsão legal. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz pode julgar por equidade, conforme art. 723, parágrafo único, do CPC.

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

O princípio do *non liquet*, portanto, assegura que o juiz promova o julgamento da demanda, ainda que não haja na lei solução específica para o caso. Em outras palavras, o juiz não pode deixar de decidir alegando lacuna na lei.

1.6. PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO

O princípio do dispositivo sustenta que o juiz não poderá agir de ofício. Decorre do art. 2º do CPC:



“Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.”

Em regra, o juiz não pode agir de ofício. Ressalta-se, no entanto, que para algumas situações o juiz possui iniciativa probatória, como, por exemplo, no campo probatório (art. 370 do CPC).

1.7. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA DO JUIZ

Como regra, juiz não responde por atos praticados no exercício da jurisdição, pois o sistema confere mecanismos de controle dos atos judiciais (recursos, ações impugnativas etc.). excepcionalmente, contudo, o juiz poderá responder pessoalmente e regressivamente pelos seus atos, conforme hipóteses contidas no art. 143 do CPC.

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

A responsabilidade do juiz será pessoal e regressiva. A parte, primeiramente, ajuizará ação contra o Estado e este, de forma regressiva, poderá demandar contra o juiz. Enquanto a responsabilidade do Estado é objetiva em relação à partes, a responsabilidade do juiz em relação ao Estado é subjetiva.

Tal regra é aplicável para os membros do Ministério Público (art. 181 do CPC), ao Advogado Público (art. 184 do CPC) e a Defensoria Pública (art. 187 do CPC).

1.8. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

Nas causas de impedimento, há uma presunção absoluta de parcialidade. Nas causas de suspeição, há uma presunção relativa de parcialidade. O impedimento e a suspeição se referem à pessoa do juiz e não ao órgão jurisdicional. O processo continua naquele juízo, mas o juiz é afastado do julgamento da causa.

Há alguma hipótese na qual a parcialidade pode ser do próprio órgão ou do próprio Tribunal? Sim. O artigo 102, inciso I, alínea “n” da CF vai dizer que será da competência originária do STF “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.

As hipóteses de impedimento do juiz encontram-se previstas no art. 144 do CPC, vejamos:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



- V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
- VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
- VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
- VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
- IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

O CPC veda expressamente a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, pois, nesse caso, haverá violação ao princípio do juízo natural.

O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se elencadas no art. 145 do CPC:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

- I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
- II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
- III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
- IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Poderá o juiz, ainda, declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

A alegação de suspeição será considerada ilegítima em duas hipóteses: a) quando houver sido provocada por quem a alega; b) quando a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

1.8.1. PROCEDIMENTO DE INCIDENTE DE IMPEDIMENTO OU DE SUSPEIÇÃO

Trata-se de um incidente processual. O incidente possui a seguinte estrutura:

- Legitimidade para arguir: as partes e o Ministério Público nas causas em que intervier.
- Prazo para suscitar o impedimento ou a suspeição: 15 dias a contar do fato que gerou a suspeição. A doutrina vai dizer que esse prazo será preclusivo para as hipóteses de suspeição. Esse prazo de 15 dias não se aplica as hipóteses de impedimento, visto que, nesse caso, há uma presunção absoluta de parcialidade.
- *Endereçamento*: a parte vai endereçar o incidente ao próprio juiz suspeito ou impedido. Neste caso, poderá o juiz: a) reconhecer o impedimento ou a suspeição e remeter o processo para o substituto legal; ou b) não reconhecer o impedimento ou a suspeição.
- *Processamento*: não reconhecendo o impedimento ou a suspeição, o juiz, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, com a juntada de eventuais documentos, após, remeterá os autos para o Tribunal. No Tribunal, será sorteado um relator, e desde já, ele



proferirá uma decisão atribuindo efeitos para estes autos, podendo suspender ou não o curso do processo. Caso o relator não suspenda o processo, o substituto legal do juiz continuará a atuar. Durante o incidente de suspeição ou de impedimento, a parte poderá requerer uma tutela provisória, a qual será decidida pelo substituto legal. Ao julgar o incidente, o tribunal poderá rejeitá-lo, por reconhecer ausentes quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, ou acolhê-lo, por reconhecer a parcialidade do juiz, hipótese em que os autos deverão ser remetidos ao substituto legal. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado e decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Do acórdão que julgar o incidente de impedimento ou suspeição, serão cabíveis recurso especial e recurso extraordinário.

As causas de suspeição e impedimento se aplicam ao Ministério Público, no entanto, o incidente não tramitará no Tribunal. O juiz que decidirá se há ou não suspeição ou impedimento do membro do Ministério Público.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1. FORMAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pode atuar como parte ou fiscal da ordem jurídica.

2.1.1. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO PARTE

A legitimidade para atuar como autor decorre do art. 129, inciso III da CF.

O art. 129, III, da CF estabelece, como uma das atuações institucionais do Ministério Público, a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Nesse sentido, o Ministério Público se apresenta como o principal defensor dos interesses metaindividuais, quais sejam:

- **Interesses ou direitos difusos:** são interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- **Interesses ou direitos coletivos em sentido estrito:** são interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- **Interesses ou direitos individuais homogêneos:** são interesses ou direitos decorrentes de origem comum¹⁸.

A Constituição conferiu aos membros do Ministério Público ampla capacidade postulatória. Ademais, sua legitimidade para o ajuizamento de ações coletivas decorre não apenas do art. 129 da CF, mas também dos arts. 5º, I, da Lei nº 7.347/85 (lei da ação civil pública) e 82, I, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

¹⁸Na linha de pensamento de Barbosa Moreira, os chamados direitos individuais homogêneos são, e verdade, direitos eminentemente individuais, mas com projeção coletiva, o que permite a sua defesa também de forma coletiva. Por isso, o saudoso processualista os denomina de direitos acidentalmente coletivos.



Vejamos alguns exemplos de legitimidade do Ministério Público na defesa dos interesses metaindividuais, conforme entendimento jurisprudencial:

- Legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público (súmula 601 do STJ);
- Legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público (súmula 329 do STJ);
- Legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT (STF, RE 631.111-GO);
- Legitimidade para figurar no polo ativo de ação civil pública e de ações coletivas contra operadoras de planos de saúde para questionar cláusulas contratuais tidas por abusivas, seja em face da indisponibilidade do direito à saúde, seja em decorrência da relevância da proteção e do alcance social (STJ, REsp 1554448/PE).

Perguntas

1- Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil “*ex delicto*”?

R: A ação civil *ex delicto*, encontra-se prevista no artigo 68 do Código de Processo Penal.

O STF declarou inconstitucional esse dispositivo alegando que o art. 68 padecia de inconstitucionalidade progressiva, porque a Defensoria Pública, à época, não havia se estruturado em todo o território nacional. Tem-se que, cabe a Defensoria ajuizar ação civil *ex delicto* na defesa dos interesses de pessoas hipossuficientes e não o Ministério Público.

Segundo o STF, o art. 68 goza de uma constitucionalidade progressiva, visto que, na medida em que a Defensoria Pública for se estruturando, a inconstitucionalidade vai aumentando.

2 - Tendo em vista a estruturação cada vez mais acentuada da Defensoria Pública nos estados da federação, se nos dias atuais o Ministério Público ajuizar uma ação civil *ex delicto*, deverá o juiz, de plano, extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade do *parquet*, que, por sua vez, decorre da inconstitucionalidade do art. 68 do CPP?

R. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 888.081/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, firmou entendimento de que a despeito da inconstitucionalidade progressiva do art. 68 do CPP, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público deve ser precedido de intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da ação civil *ex delicto*, sob pena de violação ao próprio art. 68 do CPP.

Ao atuar como parte, o Ministério Público, caso seja derrotado no processo, não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, conforme exegese do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Por uma questão de simetria, caso seja vencedor, também não fará jus a honorários advocatícios¹⁹.

2.1.2. COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA

O art. 178 do CPC traz as hipóteses de intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica.

¹⁹Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 828.525/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018.



Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Perguntas

1- MP deve intervir obrigatoriamente nas ações de família?

R: Como regra, não. Por exemplo, em um divórcio sem o interesse de incapaz, não é necessária a intervenção do Ministério Público. Contudo, a Lei nº 13.894/19 inseriu no CPC uma hipótese de intervenção obrigatório do Ministério Público nas ações de família, independentemente da existência de interesse de incapaz. Nos termos do parágrafo único do art. 698 do CPC, “o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”.

2- MP deve intervir obrigatoriamente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica?

R: Não. Nos termos do art. 133 do CPC, “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. Desse modo, o MP somente irá intervir, quando presentes uma das hipóteses do art. 178 do CPC. Além disso, se o MP estiver atuando como fiscal da ordem jurídica em algum processo, ele terá legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, quando se tratar de um processo qualquer, em que não há intervenção do MP, não pode o *parquet* ingressar no feito com o propósito de requerer a desconsideração.

3- Há hipóteses fora do art. 178 de previsão de intervenção obrigatória?

R: É possível, pois no *caput* do art. 178, fala em “hipóteses previstas em lei”. Diante disso, verifica-se que as hipóteses de intervenção do MP não estão restritas à previsão do art. 178 do CPC (ex.: ação de interdição – art. 752, § 1º, do CPC).

2.2. CONSEQUÊNCIA DA NÃO INTIMAÇÃO DO MP

A ausência de intervenção do MP é causa de nulidade do processo. Essa consequência está prevista no artigo 279 do CPC: “É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”. A nulidade incidirá sobre os atos processuais praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado para intervir.

Sempre haverá nulidade ou é possível convalidar aqueles atos processuais que foram praticados? É possível convalidá-los, pois o CPC, no artigo 279, estabelece que, antes de o juiz declarar a nulidade, deverá intimar o MP para que ele se manifeste quanto à existência ou não de prejuízo. Se o MP se manifestar pela ocorrência de prejuízo, o juiz decretará a nulidade. Se o MP se manifestar pela ausência de prejuízo, os atos serão convalidados e o processo prosseguirá.

2.3. ASPECTOS PROCESSUAIS DA INTERVENÇÃO DO MP

Vejamos os principais aspectos processuais



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



- O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º;
- Ministério Público deve ter vista dos autos depois das partes, podendo, inclusive, produzir provas e requerer qualquer medida processual que entender adequada.



CAPÍTULO 6 — LITISCONSÓRCIO

1. LITISCONSÓRCIO

1.1. CONCEITO E FONTES DO LITISCONSÓRCIO

Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de sujeitos no polo ativo ou passivo de uma demanda ou, até mesmo, em ambos os polos ao mesmo tempo. As fontes do litisconsórcio, ou seja, as hipóteses autorizadoras de sua formação estão elencadas no artigo 113 do CPC.

Assim, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

- **Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide:** é o que ocorre, por exemplo, na ação reivindicatória ajuizada por todos os coproprietários do imóvel. Há, entre eles, uma comunhão de direitos em relação à coisa.
- **Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir:** o instituto na conexão, como já estudado, encontra-se previsto no artigo 55 do CPC. Haverá conexão quando houver identidade entre as causas de pedir ou os pedidos. Exemplo: acidente de trânsito envolvendo várias vítimas. Cada vítima poderá ajuizar ação autônoma em face do causador do acidente, porém, caso queiram, elas poderão ingressar com uma única ação, formando no polo ativo um litisconsórcio.
- **Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito:** a formação do litisconsórcio nesta hipótese é permitida, tão somente, porque há questões afins de fato ou de direito. Segundo Pontes de Miranda, trata-se de litisconsórcio facultativo impróprio.

1.2. CLASSIFICAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO

A doutrina classifica o litisconsórcio, quanto à posição processual; quanto ao momento da formação e quanto à uniformidade da solução.

1.2.1. QUANTO À POSIÇÃO PROCESSUAL

Podem ser classificadas como litisconsórcio **ativo**, **passivo** ou **misto**. Haverá litisconsórcio **ativo** quando duas ou mais pessoas estiverem no polo ativo. Quanto ao litisconsórcio **passivo**, ocorrerá quando houver duas ou mais pessoas no polo passivo. E no litisconsórcio **misto**, quando houver pluralidade de sujeitos em ambos os polos da relação processual.

1.2.2. QUANTO AO MOMENTO DA FORMAÇÃO

O litisconsórcio poderá ser **inicial** ou **ulterior**. No primeiro caso, a ação já se inicia com a formação do litisconsórcio (ex.: ação real imobiliária ajuizada em face de duas pessoas casadas, nos termos do art. 73, § 1º, I, do CPC). No segundo caso, o litisconsórcio é formado após a propositura da ação (ex.: chamamento ao processo, em que, após ser citado, o réu chama ao processo o codevedor, passando, ambos, a atuar em litisconsórcio passivo).



1.2.3. QUANTO À UNIFORMIDADE DA SOLUÇÃO

O litisconsórcio poderá ser **simples** ou **unitário**. Será simples, quando a decisão não for uniforme para todos os litisconsortes (ex.: ação indenizatória ajuizada por várias vítimas de acidente de trânsito contra o mesmo causador. A sentença poderá ser diferente para cada uma delas, conforme extensão de cada dano). Será **unitário**, quando a decisão judicial for uniforme para todos os litisconsortes (ex.: na ação reivindicatória proposta pelos coproprietários, a sentença será uniforme para todos eles. O acento tônico do litisconsórcio unitário está na indivisibilidade da relação jurídica discutida. Nesse sentido, dispõe o art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”).

1.2.4. QUANTO À OBRIGATORIEDADE DA FORMAÇÃO

O litisconsórcio poderá ser **facultativo** ou **necessário**. No litisconsórcio **facultativo**, como o próprio nome indica, não há a obrigatoriedade de sua formação. Já no litisconsórcio **necessário**, a lei ou a natureza da relação jurídica impõe a sua formação

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Quanto ao litisconsórcio necessário decorrente de imposição legal, cite-se a ação real imobiliária ajuizada contra duas pessoas casadas (art. 73, § 1º, I, do CPC). Já em relação ao litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica, pode ser citada, a título de exemplo, a ação de nulidade contratual ajuizado por um terceiro. Nesse caso, o polo passivo será necessariamente ocupado pelos celebrantes do negócio jurídico.

O litisconsórcio necessário, pode ou não ser unitário.

O litisconsórcio unitário no polo passivo será sempre NECESSÁRIO.

O litisconsórcio unitário no polo ativo, por sua vez, será FACULTATIVO, pois não é possível obrigar alguém a demandar, assim como é possível impedir que alguém demande, pelo simples fato de o seu litisconsorte não querer demandar, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

1.3. TRATAMENTO DOS LITISCONSORTES

Nos termos do art. 117 do CPC, “os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.

O referido dispositivo estabelece que, quando se tratar de um **litisconsórcio simples**, cada litisconsorte será considerado como litigante distinto, ou seja, o ato praticado por um não interfere na esfera jurídica do outro. Por outro lado, quando se tratar de **litisconsórcio unitário**, tendo em vista a indivisibilidade da relação jurídica, os atos praticados por um dos litisconsortes, se benéficos, aproveitarão aos demais. Os atos prejudiciais, todavia, não os atingirão.

O ato praticado por um litisconsorte simples não pode beneficiar o outro litisconsorte simples? Como são considerados litigantes distintos, como regra, o ato praticado por um não atinge a esfera jurídica do outro. Todavia, tal regra comporta exceções, vejamos:

- Se um dos litisconsortes apresentar contestação, aquele que for revel não suportará o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 345, I, do CPC);
- Princípio da comunhão da prova. A prova não pertence à parte, mas ao processo e o juízo é o destinatário último das provas. Assim, se um litisconsorte não requerer a produção de prova, mas outro litisconsorte a requerer, aquele que não requereu poderá se beneficiar da prova produzida;
- À luz do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, o recurso interposto por um dos devedores solidários, poderá aproveitar os outros devedores solidários que não recorreram da sentença.

Havendo solidariedade na obrigação (ativa ou passiva), o litisconsórcio será sempre unitário? Não, pois sequer haverá a necessidade de formação de litisconsórcio. A título de exemplo, prevê o art. 275 do CPC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

1.4. CONSEQUÊNCIAS DA NÃO FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO

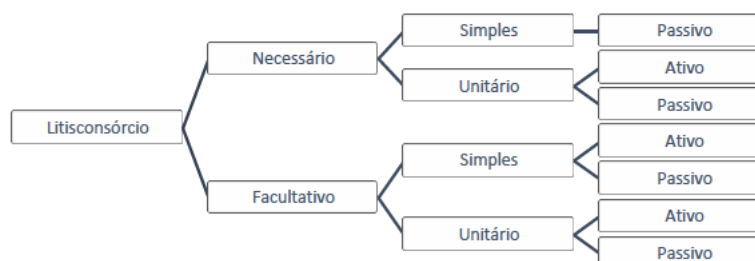
Diz o artigo 115 do CPC:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

A expressão “todos que deveriam”, consoante ao inciso I do artigo 115 do CPC, significa dizer que a integração era obrigatória. Logo, o referido inciso se refere ao litisconsórcio necessário e unitário. A hipótese do inciso II, por outro lado, se refere ao litisconsórcio necessário e simples.

Dizendo por outras palavras: no caso de litisconsórcio necessário e unitário, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula (inciso I); por outro lado, tratando-se de litisconsórcio necessário e simples, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será ineficaz para os que não foram citados.

1.5. COMBINAÇÕES DE REGIMES DE LITISCONSÓRCIO



Vamos aos exemplos:

- **Litisconsórcio necessário simples**
 - ⇒ **Polo ativo:** não ocorrerá.
 - ⇒ **Polo passivo:** na ação de usucapião, todos os confinantes deverão ser citados (litisconsórcio necessário). Todavia, a decisão poderá ser diferente para cada um deles (litisconsórcio simples).

- **Litisconsórcio necessário unitário**

- ⇒ **Polo ativo:** somente ocorrerá em situações excepcionabilíssimas. É o que ocorre na hipótese prevista no art. 154, § 4º, da Lei nº 6.404/76²⁰.
- ⇒ **Polo passivo:** é o que ocorre na ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por terceiro prejudicado contra os contraentes.

- **Litisconsórcio facultativo simples**

- ⇒ **Polo ativo:** ação ajuizada por dois credores solidários contra o devedor comum cuja obrigação não é indivisível (art. 267 do CC);
- ⇒ **Polo passivo:** ação ajuizada pelo credor comum contra dois devedores solidários cuja obrigação não é indivisível (art. 275 do CC).

- **Litisconsórcio facultativo unitário**

- ⇒ **Polo ativo:** ação reivindicatória ajuizada por apenas um dos coproprietários;
- ⇒ **Polo passivo:** litisconsórcio formado entre o réu-alienante de coisa litigiosa e o respectivo adquirente (art. 109, § 2º, do CPC).

1.6. INTERVENÇÃO *IUSSU IUDICIS*

A intervenção *iussu iudicis* é aquela provocada, de ofício, pelo juiz. O juiz, verificando a existência de terceiro interessado (ou mesmo litisconsorte), sem que o réu tenha requerido a sua citação, determina a sua citação. Esse tipo de intervenção não é admitida, como regra, pelo sistema processual civil brasileiro.

Nos termos do parágrafo único do art. 115 do CPC, “nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

É possível identificar no código, contudo, hipóteses de intervenção *iussu iudicis*, como é o caso da ação de produção antecipada de provas. Nos termos do § 1º do art. 382 do CPC, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso”. Outra hipótese é a prevista no parágrafo único do art. 675 do CPC, que trata dos embargos de terceiro. Segundo o mencionado dispositivo, “caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente”.

1.7. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITISCONSORTES (LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO)

Fala-se em litisconsórcio multitudinário quando há um grande número de sujeitos em um (ou ambos) dos polos da relação processual. Nesse caso, o § 1º do art. 113 do CPC prevê que “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”.

²⁰ Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. (...) § 4º Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social.

Contudo, não poderá haver essa limitação quando se tratar de litisconsórcio necessário.

CAPÍTULO 7 — INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

1. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

1.1. CONCEITO

A intervenção de terceiros nada mais é do que um incidente processual por meio do qual um terceiro, até então estranho à relação processual, ingressa no processo impondo-lhe alguma modificação. São modalidades de intervenção de terceiros: a) assistência; b) denunciação da lide; c) chamamento ao processo; d) incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e) *amicus curiae*.

1.2. ASSISTÊNCIA

1.2.1. CABIMENTO

Nos termos do art. 119 do CPC, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Para que se possa admitir a assistência, deve haver a) um processo pendente; b) um terceiro estranho a relação processual; c) interesse jurídico do terceiro. O interesse jurídico do terceiro decorre do fato de a sentença a ser proferida no processo poder atingi-lo direta ou reflexamente.

A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Contudo, não será admitida nos juizados especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95) e no mandado de segurança (art. 24 da Lei nº 12.016/09)²¹.

O CPC prevê duas modalidades de assistência: a) assistência simples; b) assistência litisconsorcial. Nessas duas modalidades, o terceiro ingressará no processo para assistir uma das partes, pois eventual derrota da parte assistida impactará, de alguma forma, a esfera jurídica do terceiro-assistente.

1.2.2. PROCEDIMENTO

O terceiro, por petição, requer o seu ingresso na qualidade de assistente do autor ou do réu. Sendo evidente a ausência de interesse do terceiro, o juiz rejeitará liminarmente o pedido. Por outro lado, se o juiz verificar que, em tese, há interesse, intimará as partes (autor e réu) para que se manifestem quanto ao pedido de assistência no prazo de 15 dias.

Após a manifestação das partes, o juiz decidirá por meio de uma decisão interlocutória, admitindo ou rejeitando o ingresso do terceiro. Da decisão judicial caberá agravo de instrumento. Durante o procedimento, o processo NÃO FICARÁ SUSPENSO.

1.2.3. ASSISTÊNCIA SIMPLES X ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL

A assistência poderá ser simples ou litisconsorcial.

²¹ STF, MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014.



A) ASSISTÊNCIA SIMPLES

O traço identificador da assistência simples está no interesse jurídico alegado pelo terceiro. Nessa modalidade, o terceiro afirma ter uma relação jurídica com uma das partes e conexa com a relação jurídica discutida no processo. **A decisão a ser proferida no processo atingirá reflexamente a esfera jurídica do terceiro-assistente.** É o que ocorre, por exemplo, na ação de despejo ajuizada pelo locador contra o locatário, na qual o sublocatário (terceiro) ingressa no processo para assistir o réu (locatário/sublocador), tendo em vista que os efeitos de eventual sentença que decretar o despejo do réu-locatário (assistido) atingirá reflexamente a relação jurídica estabelecida entre ele e o sublocatário (assistente).

A assistência simples possui as seguintes características:

- O assistente responde pelas custas e despesas processuais proporcionalmente à sua atuação no processo;
- O assistente simples atua como mero auxiliar da parte (do assistido). Portanto, o assistente exercerá os mesmos poderes e se sujeitará aos mesmos ônus do assistido;
- O assistente será considerado um substituto processual, ou seja, legitimado extraordinário, pois atuará, em nome próprio, na defesa de um interesse alheio. Por essa razão, o parágrafo único do art. 121 do CPC dispõe que “sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissor o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual”. Contudo, a assistência simples não impede que o assistido reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou renuncie a sua pretensão (art. 122 do CPC). Ocorrendo alguns desses três casos, o assistente nada poderá fazer.

B) ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL

A assistência litisconsorcial nada mais é do que um litisconsórcio facultativo e ulterior. O artigo 124 do CPC estabelece que “considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”.

Imagine o seguinte exemplo: Tício ajuíza uma ação reivindicatória em face de Mévio. Estando o processo em curso, Zacarias, coproprietário do imóvel, requer o seu ingresso no processo na qualidade de assistente de Tício. Note que, por ser coproprietário, Zacarias poderia ter formado, desde o início, um litisconsórcio ativo com Tício, porém, por alguma razão, não o fez. Há, entre Zacarias e o adversário de Tício uma relação jurídica, já que Zacarias é coproprietário do bem e tem direito de buscar proteção ao seu direito de propriedade. Nesse caso, ingressando Zacarias no curso do processo para assistir Tício, essa assistência será litisconsorcial.

Vê-se, assim, que a assistência litisconsorcial é, em verdade, um litisconsórcio facultativo ulterior.

Aplicam-se à assistência litisconsorcial os mesmos poderes existentes na assistência simples. Todavia, não serão aplicadas eventuais limitações. Portanto, o parágrafo único do artigo 121 e, sobretudo, o artigo 122, ambos do CPC não se aplicam à assistência litisconsorcial. Assim, ainda que haja renúncia, desistência, transação ou mesmo o reconhecimento da procedência do pedido por parte do assistido, o assistente litisconsorcial poderá prosseguir na ação, pois também é titular da relação jurídica discutida.



1.3. DENUNCIAÇÃO DA LIDE

1.3.1. CONCEITO E HIPÓTESES DE CABIMENTO

Denúnciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiros por meio da qual, ao mesmo tempo em que se noticia a existência de uma demanda a um terceiro, se propõe contra ele uma demanda regressiva eventual.

As hipóteses de cabimento de denúnciação da lide encontram-se previstas no artigo 125 do CPC.

Art. 125. É admissível a denúnciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A hipótese prevista no inciso I refere-se à evicção. A evicção gera para o evicto um direito de regresso a ser exercido contra o alienante imediato, nos termos do art. 450 do CC²². É justamente esse direito de regresso que pode ser exercido, de forma antecipada, por meio da denúnciação da lide. Diz-se antecipada porque o denunciante ainda não perdeu a coisa, porém corre um sério risco de perdê-la, já que está discutindo-a em um processo judicial. Logo, a denúnciação da lide é promovida justamente para que, uma vez perdida a coisa no processo judicial, o evicto aproveite o mesmo processo para buscar a condenação do alienante imediato, de forma regressiva, ou seja, *exercer os direitos que da evicção lhe resultam*.

Na hipótese do inciso II, a denúnciação da lide funda-se na existência de uma obrigação regressiva, preexistente estabelecida na lei (ex.: direito de regresso do empregador contra o empregado que praticou ato ilícito a outrem – arts. 932, III e 934 do CC) ou no contrato (ex.: contrato de seguro).

1.3.2. FACULTATIVIDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A denúnciação da lide não é obrigatório. Isso significa dizer que, ainda que a parte não promova a denúnciação da lide ou ainda que o juiz indefira o pedido de denúnciação da lide, será possível o ajuizamento de ação regressiva autônoma, conforme dispõe o § 1º do art. 125 do CPC.

“§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denúnciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

1.3.3. DENUNCIAÇÃO SUCESSIVA

Promovida a denúnciação da lide, é possível que o denunciado promova uma denúnciação sucessiva. Exemplo: o réu requereu a denúnciação sucessiva ao seu alienante imediato e este ao seu alienante imediato, sucessivamente. Vejamos na ilustração abaixo:

²² Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se eventeu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.



Nesse sentido, dispõe o § 2º do art. 125 do CPC que “admite-se uma única denúncia sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denúncia, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”.

1.3.4. DENÚNCIAÇÃO *PER SALTUM*

É possível que dentro da cadeia de responsáveis regressivos o denunciante escolha o seu denunciado?

O art. 456, *caput*, do CC dispunha que “para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo”. O texto parecia indicar a possibilidade de uma denúncia *per saltum*. Contudo, o art. 1.072 do CPC/2015 expressamente revogou o art. 456 do CC, o que reforça a ideia de que o sistema processual civil vigente não admite a denúncia da lide *per saltum*.

Assim, tem prevalecido o entendimento de que não é cabível a denúncia *per saltum*.

1.3.5. PROCEDIMENTO

A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131 do CPC.

Feita a denúncia pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Feita a denúncia pelo réu, abrem-se três possibilidades:

- Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;
- Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva;
- Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso.

1.3.6. DENÚNCIAÇÃO COMO AÇÃO REGRESSIVA EVENTUAL

A denúncia da lide é uma ação regressiva eventual. Isso significa o juiz somente analisará a denúncia (pedido de condenação regressiva), caso o denunciante seja derrotado na ação, pois, se o denunciante for vencedor no processo, não haverá qualquer direito de regresso. Nesse sentido, prevê o art. 129 do CPC que “se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denúncia da lide”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 129 dispõe que “se o

denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

1.3.7. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Se tanto o denunciante quanto o denunciado forem derrotados no processo (ex.: juiz julgou procedente o pedido do autor contra o réu-denunciante e procedente o pedido do réu-denunciante contra o denunciado), o vencedor poderá requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste.

É o que dispõe o parágrafo único do art. 128 do CPC (“Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva”).

1.4. CHAMAMENTO AO PROCESSO

1.4.1. CONCEITO E HIPÓTESES DE CABIMENTO

Trata-se de modalidade forçada de intervenção de terceiros promovida sempre no polo passivo. Por meio dela, forma-se um litisconsórcio facultativo passivo ulterior. As hipóteses estão previstas no art. 130 do CPC.

O réu, uma vez citado, poderá requerer a o chamamento ao processo:

- Do afiançado, na ação em que o fiador for réu: ex.: o autor ajuíza ação somente contra o fiador. O fiador, ao ser citado, promove o chamamento ao processo do afiançado (devedor principal);
- Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles: há vários devedores, mas somente um é demandado. Este poderá promover o chamamento dos demais fiadores.
- Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum: no caso de solidariedade na obrigação, se qualquer dos devedores for demandado, poderá promover o chamamento dos demais codevedores.

1.4.2. PRAZO PARA CHAMAMENTO AO PROCESSO

O chamamento deve ser requerido na contestação. Ao requerer o chamamento, o réu deve diligenciar no sentido de possibilitar a citação do chamado, nos seguintes prazos, sob pena de ficar sem efeito:

- 30 (trinta) dias, se o chamado residir na mesma comarca, seção ou subseção judiciárias;
- 2 (dois) meses, se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto.

1.4.3. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar (art. 132 do CPC).



1.5. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

1.5.1. INTRODUÇÃO

São modalidades de desconconsideração da personalidade jurídica:

- **Desconsideração direta**, ou seja, retira-se momentaneamente o véu da personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir o patrimônio da pessoa física dos seus sócios.
- **Desconsideração inversa**, o devedor é a pessoa física, mas há uma confusão patrimonial de seus bens com o patrimônio da pessoa jurídica. Portanto, afasta-se a pessoa física para atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Muito recorrente nas ações de família e o CPC admite expressamente.
- **Desconsideração expansiva** é aquela na qual se atinge o sócio oculto. Ou seja, nos atos constitutivos da pessoa jurídica devedora consta, expressamente, o nome dos sócios formais. Todavia, o verdadeiro “sócio administrador” é uma pessoa oculta. O sócio administrador se vale de “testas de ferro” ou “laranjas”, que são aqueles que figuram formalmente no contrato social. Nessas situações, desconsideira-se a personalidade jurídica para atingir também o patrimônio do sócio oculto.
- **Desconsideração indireta** é aquela na qual há uma sociedade controladora e uma sociedade controlada. Afasta-se o véu da personalidade jurídica da sociedade controlada para se atingir o patrimônio da sociedade controladora. A desconsideiração direta e inversa estão expressamente previstas no CPC. No que tange à desconsideiração expansiva e indireta, a doutrina e a jurisprudência admitem esse tipo de desconsideiração.

Para fins de desconsideiração da personalidade jurídica, há duas grandes teorias:

- **Teoria maior:** é a regra geral e encontra-se prevista no artigo 50 do CC. Para que possa haver a desconsideiração da personalidade jurídica, deve ficar demonstrado o **abuso na personalidade jurídica**, o qual se revela pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nos termos do art. 50 do CC, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsideira-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”). O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, § 1º, do CC). Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: a) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
- **Teoria menor:** está prevista no artigo 28 do CDC. Basta que a pessoa jurídica seja, de alguma forma, óbice à reparação civil dos danos. Não se exige, portanto, a demonstração do desvio ou confusão patrimonial. Nos termos do art. 28 do CDC “o juiz poderá desconsideira a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideiração também será



efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.

1.5.2. ASPECTOS PROCESSUAIS DA DESCONSIDERAÇÃO

A) CABIMENTO

O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. De igual forma, é plenamente possível a desconconsideração da personalidade jurídica no processo falimentar, conforme orientação firmada no enunciado 247 do FPPC (“Aplica-se o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no processo falimentar”).

O CPC/2015, de forma expressa, prevê a instauração do incidente também na hipótese de pedido de desconconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133, § 2º, do CPC). Por conseguinte, o incidente também deve ser admitido nas hipóteses de desconconsideração indireta e expansiva. Esse, inclusive, é o entendimento firmado no enunciado nº 11 da I Jornada de Direito Processual Civil (“Aplica-se o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica”).

B) MOMENTO PARA REQUERER A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

- **Petição inicial:** requerida na petição inicial, o juiz determinará a citação da pessoa jurídica e dos sócios. Dispensa-se a instauração do incidente. Em verdade, o que há é a formação de um litisconsórcio passivo entre a pessoa jurídica e os sócios (enunciado 125 do FPPC).
- **No curso do processo:** requerida a desconconsideração da personalidade jurídica após a petição inicial, ou seja, no curso do processo, deverá ser instaurado o respectivo incidente. Note que somente haverá a instauração do incidente, se a desconconsideração for requerida no curso do processo.

C) LEGITIMIDADE

Têm legitimidade as partes e o MP nas causas em que intervier (como parte ou fiscal da ordem jurídica).

D) PROCEDIMENTO

Conforme mencionado, somente haverá a instauração do incidente quando a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida após a apresentação da petição inicial.

Na petição, a parte deverá demonstrar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da desconconsideração. Verificando o juiz que o pedido é manifestamente improcedente (ex.: pedido de desconconsideração fundado no simples fato de a pessoa jurídica ter encerrado suas atividades²³), a

²³ Nos termos do enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil, “o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica”.

instauração do incidente deverá ser liminarmente rejeitada. Por outro lado, se houver indícios da presença dos pressupostos legais, a instauração do incidente será admitida.

Admitida a instauração do incidente, o juiz deverá: i - comunicar imediatamente ao distribuidor judicial para as anotações devidas (art. 134, § 1º, do CPC); ii - determinar a imediata suspensão do processo (art. 134, § 3º, do CPC); iii - determinar a citação do sócio (na desconconsideração direta) ou da pessoa jurídica (na desconconsideração inversa) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC). Havendo necessidade, seguir-se-á à instrução do incidente e, após, ao seu julgamento.

Em decisão interlocutória fundamentada, o juiz decidirá o incidente, rejeitando ou acolhendo o pedido. Em caso de rejeição, cessará a suspensão do processo, retomando-se o seu curso natural em relação às partes originárias. Acolhido o incidente, a decisão decretará a desconconsideração da personalidade jurídica, estabelecerá eventuais limites, apontará quais sócios serão atingidos²⁴ e o processo principal retomará o seu curso natural com a inclusão do terceiro. Note que no caso de acolhimento do pedido, um terceiro (sócio ou sociedade²⁵), até então estranho à relação jurídica processual, passa a integrar a relação processual.

Além das consequências supra descritas, a decretação da desconconsideração da personalidade jurídica produz um importante efeito, qual seja: a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente (art. 137 do CPC).

Contra a decisão que defere ou indefere o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica caberá agravo de instrumento.

Muito embora o art. 10 da Lei nº 9.099/95 vede a intervenção de terceiros no âmbito dos Juizados Especiais, o artigo 1.062 do CPC prevê o cabimento do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Assim, com o advento do novo CPC, o art. 10 da Lei nº 9.099/95 deve ser lido no sentido de que, no âmbito dos Juizados Especiais, a única modalidade de intervenção de terceiros admitida é o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, por força do art. 1.062 do CPC.

Por fim, registre-se que, nos termos do enunciado nº 42 da I Jornada de Direito Processual Civil “é cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconconsideração da personalidade jurídica”.

1.6. AMICUS CURIAE

1.6.1. CABIMENTO E CARACTERÍSTICAS

Nos termos do art. 138 do CPC,

o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

A admissão do *amicus curiae* depende da demonstração de um dos pressupostos não cumulativos previstos no supracitado dispositivo, quais sejam: a) relevância da matéria; b) especificidade do tema objeto da demanda; ou c) repercussão social da controvérsia.

²⁴ É possível que o incidente seja instaurado, por exemplo, contra três sócios, mas apenas dois (os que detinham a administração da sociedade) sejam atingidos pela desconconsideração.

²⁵ Conforme se trate de desconconsideração direta ou inversa.



Poderá intervir como *amicus curiae* pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada. A chamada *representativa adequada* tem a ver com a pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o objeto da controvérsia. A título de exemplo, uma associação de médicos não teria, em tese, representatividade adequada para intervir como *amicus curiae* em controvérsia envolvendo posse sobre terras indígenas.

É importante registrar que o *amicus curiae* é a única modalidade de intervenção de terceiros que pode ser admitida de ofício pelo juiz ou relator. A intervenção pode ocorrer em qualquer momento processual.

1.6.2. PROCEDIMENTO

O ingresso do *amicus curiae* pode se dar por determinação do juiz ou relator, de ofício, ou após requerimento do próprio terceiro que pretenda intervir, da parte interessada ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no feito.

A decisão que defere ou indefere o ingresso do *amicus curiae*, segundo dispõe o art. 138, *caput*, do CPC e conforme entendimento do STF, é irrecorrível.

Admitida a intervenção, o *amicus curiae* terá o prazo de 15 (quinze) para se manifestar, devendo, a partir de então, participar amplamente do diálogo processual, podendo, para tanto, apresentar informações, manifestações, pareceres, participar da instrução processual, realizar sustentação oral etc. O CPC/2015 não elenca os poderes do *amicus curiae*, cabendo ao juiz (ou relator), de forma casuística, definir os limites da intervenção.

Verificando o juiz (ou o relator) o preenchimento de um dos requisitos objetivos para a admissão do *amicus curiae* (relevância da matéria, repercussão social da controvérsia ou especificidade do tema objeto da demanda), poderá promover a ampla divulgação do processo, inclusive por meio dos cadastros eletrônicos dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça, para incentivar a participação de mais sujeitos na qualidade de *amicus curiae*²⁶.

É possível que em um mesmo processo haja pluralidade de pedidos de admissão de *amicus curiae*. Quando isso ocorrer, deverá o juiz ou relator observar, como critério para definição daqueles que serão admitidos, o equilíbrio na representatividade dos diversos interesses jurídicos contrapostos no litígio, velando, assim, pelo respeito à amplitude do contraditório, paridade de tratamento e isonomia entre todos os potencialmente atingidos pela decisão²⁷.

1.6.3. RECURSO

Viu-se que a decisão que admite ou inadmite a intervenção do *amicus curiae* é irrecorrível. Já no tocante à decisão de mérito proferida no processo em que interveio o *amicus curiae*, devem ser observadas duas situações distintas:

- **Regra geral:** contra a decisão de mérito, o *amicus curiae* somente pode opor embargos de declaração (art. 138, § 1º, do CPC). Portanto, como regra, sua legitimidade recursal é restrita.
- **Exceções:** o *amicus curiae*, contudo, terá legitimidade recursal ampla em duas hipóteses: i - contra acórdão que julgar o incidente de resolução de demandas

²⁶ Nesse sentido é o entendimento firmado no enunciado nº 575 do FPPC.

²⁷ Nesse sentido é o entendimento firmado no enunciado nº 82 da I Jornada de Direito Processual Civil. Embora o referido enunciado refira-se a “relator”, tal entendimento deve ser aplicado aos pedidos de intervenção de *amicus curiae* formulados ao juízo de primeiro grau.

repetitivas (art. 138, § 3º, do CPC); ii - contra acórdão que julgar recurso especial e recurso extraordinário repetitivos (enunciado 391 do FPPC).

QUESTÕES

1- No tocante ao litisconsórcio e da intervenção de terceiros, responda a assertiva correta.

- a) Todo litisconsórcio facultativo será, também, simples.
- b) A assistência tem lugar em qualquer tipo de procedimento e até a sentença de primeiro grau, mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
- c) A posição não configura um incidente do processo, mas sim um processo incidente, pois não é espécie de intervenção de terceiros.
- d) O chamamento ao processo é obrigatório ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam.
- e) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá denunciar à lide o proprietário ou o possuidor.

2- Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Quando por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, este será necessário.
- b) Ocorrendo afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito duas pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente.
- c) Se o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes em razão da natureza da relação jurídica, o litisconsórcio será unitário.
- d) Contanto que o faça na fase de conhecimento, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o posterior cumprimento da sentença.
- e) Será nula a sentença mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.

3- Acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do *amicus curiae*, é correto afirmar:

- a) Embora admitida pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica não encontra-se prevista expressamente no NCPC, o que não afasta, entretanto, a sua aplicação na prática.
- b) A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ocorrer na fase de execução ou cumprimento e sentença.
- c) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será dispensado, se esta for requerida na própria petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica, conforme o caso.
- d) O *amicus curiae*, espécie de intervenção de terceiros, somente é cabível no âmbito do TJ/TRF ou dos tribunais superiores, cabendo ao relator, uma vez cumpridos os requisitos legais, admitir a

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

e) Quando intervier no incidente de resolução de demandas repetitivas, o *amicus curiae* não poderá recorrer da decisão prolatada nesse incidente.

4- Sebastião devia a Joaquim a quantidade R\$20.000,00, sendo tal dívida garantida por Jonas e Sérgio, os quais se obrigaram solidariamente ao pagamento. Vencida a dívida Joaquim acionou judicialmente Sérgio.

Na situação hipotética acima narrada, pode-se afirmar que:

- a) Sérgio deverá pagar a dívida, a qual somente pode ser cobrada de Sebastião em ação regressiva.
- b) Sérgio poderá chamar ao processo Sebastião e Jonas.
- c) Sérgio procederá à denúncia da lide a Sebastião.
- d) Sérgio deverá denunciar à lide a Sebastião e Jonas.
- e) Jonas não pode ser chamado ao processo.

5- Assinale a alternativa CORRETA de acordo com as disposições do CPC.

- a) Havendo denúncia da lide a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.
- b) Acolhido o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será considerada nula.
- c) O relator, considerando a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, poderá, desde que requerido pelas partes ou por quem pretenda manifestar-se, admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.
- d) O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
- e) A intervenção do *amicus curiae* não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, cabendo ao juiz definir os poderes do *amicus curiae*.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C

a) INCORRETA. O litisconsórcio pode ser assim classificado: a) ativo, passivo e misto (conforme a posição dos litisconsortes na relação processual); b) inicial (formado desde a propositura da ação) ou ulterior (formado após a propositura da demanda = ex.: a oposição implica na formação de um litisconsórcio); c) necessário (a lei ou a relação jurídica material impõe a sua formação = ex1.: usucapião de imóvel, em que a lei impõe que sejam demandados o antigo proprietário e os confrontantes do imóvel; ex2: ação anulatória de negócio jurídico promovido por terceiro, em que os réus deverão ser os celebrantes do negócio que se pretende anular) ou facultativo (não há obrigatoriedade, ficando a critério da parte (ex.: ação em que um condômino ingressa para pleitear a inobservância, pelo síndico, de cláusula da convenção do condomínio. A ação poderá ser proposta por um ou vários condôminos em litisconsórcio ativo); d) unitário (o juiz deverá decidir de maneira



uniforme para todos os litisconsortes. Ex: oposição) ou simples (a decisão pode ser diferente para cada litisconsórcio. Ex: familiares das vítimas ingressam com ação contra companhia aérea). Nesse sentido, denota-se que tanto o litisconsórcio necessário (decorre de lei ou da relação jurídica – art. 114, do NCPC) quanto o facultativo (a lei não impõe a sua formação. Há discricionariedade) podem ser unitários (necessidade de decisão uniforme para todos) ou simples (decisão não uniforme).

b) INCORRETA. Art. 119, parágrafo único, do NCPC: “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.

c) CORRETA. O NCPC, ao contrário do que previa o CPC/73, conferiu à oposição a natureza de processo incidente, não mas a prevendo como hipótese de intervenção de terceiros. Assim, a oposição (art. 682 e ss., do NCPC) passa a figurar ao lado de outros processos incidentes, como os embargos de terceiros (arts. 674 e ss., do NCPC), reclamação (arts. 988 e ss., do NCPC), dentre outros. Os chamados processos incidentes não se confundem com os incidentes do processo. Segundo DIDIER, processo incidente é processo novo, instaurado em razão de um processo existente, que dele se desgarra, mas nele produz efeitos. Já o incidente do processo é processo novo, que de modo não necessário surge de um processo já existente, e a ele se incorpora, tornando-o mais complexo”. A intervenção de terceiro não é um processo incidente (*Vide*: DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil – introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 476-477).

d) INCORRETA. Trata-se de hipótese de denunciação da lide (art. 125, inciso I, do NCPC), e não de chamamento ao processo.

e) INCORRETA. O NCPC não mais tratou da “nomeação à autoria”, que no CPC/73 (art. 62) era espécie de intervenção de terceiros. A hipótese prevista na assertiva deverá, pelo NCPC, ser tratada como ilegitimidade passiva, a ser arguida em preliminar de mérito, na contestação (art. 338 do NCPC).

2. Gabarito: D

a) CORRETA. “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

b) CORRETA.

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

c) CORRETA. “Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.”

d) INCORRETA. “Art. 113, § 1º, CPC. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.”

e) CORRETA. “Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.”

3. Gabarito: C

- a) INCORRETA. Nos termos do § 2º do art. 133 do NCPC, “Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”.
- b) INCORRETA. Dispõe o art. 134, *caput*, do NCPC que “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”.
- c) CORRETA. É justamente esse o teor do § 2º do art. 134 do NCPC, segundo o qual “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.
- d) INCORRETA. A intervenção do *amicus curiae* é cabível, também, perante o juiz. Nesse sentido, dispõe o art. 138, *caput*, do NCPC que “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.
- e) INCORRETA. Segundo o § 3º do art. 138 do NCPC “O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas”.

4. Gabarito: B

Art. 130, CPC. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

- I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
- II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
- III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

5. Gabarito: D

a) INCORRETA.

“Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.”

OBS. O artigo refere-se ao chamamento ao processo.

b) INCORRETA. “Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.”

c) INCORRETA.

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

d) CORRETA. “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.”

e) INCORRETA.

Art. 138, § 1º, CPC. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.



CAPÍTULO 8 — TUTELA PROVISÓRIA

1. Tutela Provisória

1.1. INTRODUÇÃO

No campo da tipologia das tutelas jurisdicionais, viu-se, no Capítulo VI, a distinção entre tutela definitiva (de certificação ou de efetivação) e tutela provisória (antecipada ou cautelar).

A **tutela definitiva** é aquela obtida com base em uma cognição exauriente. O processo se desenvolve de forma ampla e profunda, a fim de que o juiz, a partir de um juízo de certeza jurídica, certifique, por meio de uma sentença condenatória, constitutiva ou declaratória, a existência do direito, ou realize um direito previamente reconhecido mediante cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. O traço característico da tutela definitiva é a sua aptidão para tornar-se imutável pelo manto da coisa julgada.

A **tutela provisória**, por sua vez, é aquela obtida com base em cognição sumária e juízo de probabilidade. Pode ter natureza satisfativa (tutela antecipada) ou assecuratória (tutela cautelar), e em ambos os casos pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental.

A tutela provisória tem por objetivo redistribuir, de forma mais justa e equitativa, do ônus do tempo do processo. O ônus do tempo do processo não pode ser suportado apenas por uma parte, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

1.2. CARACTERÍSTICAS DA TUTELA PROVISÓRIA

As principais características da tutela provisória são:

- **Cognição sumária:** a concessão de tutela provisória se realiza mediante cognição não exauriente, ou seja, por meio de um juízo de probabilidade do direito invocado;
- **Inaptidão para coisa julgada:** a tutela provisória não transita em julgado, porém pode se estabilizar, conforme o caso;
- **Precariedade:** uma vez deferida, pode ser revogada posteriormente. Nesse sentido, prevê o art. 296 do CPC, “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.
- **Produção dos efeitos durante o período de suspensão do processo:** nos termos do parágrafo único do art. 296 do CPC, “salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”;
- **Poder-dever geral de efetivação:** o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória (art. 297, *caput*, do CPC). A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (art. 297, parágrafo único, do CPC).
- **Responsabilidade:** a parte beneficiada pela tutela responderá objetivamente por eventuais prejuízos causados à parte contrária. Assim, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: a) a sentença lhe for desfavorável; b) obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; d) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; e) o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302 do CPC). Nesse caso, a



indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível (art. 302, parágrafo único, do CPC);

- **Fungibilidade:** há uma fungibilidade entre as tutelas provisórias. Assim, requerida uma tutela antecipada, se o juiz entender que o pleito tem natureza de tutela cautelar, o receberá como tal. A recíproca também é verdadeira (fungibilidade de mão dupla). A fungibilidade pode ser extraída o parágrafo único do art. 305 do CPC (“Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303).

1.3. MOMENTO PARA REQUERER

Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar podem ser requeridas em caráter antecedente (a petição inicial se limitará ao requerimento da tutela provisória) ou em caráter incidental (no curso do processo) (art. 294, parágrafo único, do CPC).

1.4. COMPETÊNCIA

A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito (art. 299 do CPC).

1.5. TUTELA DE URGÊNCIA

Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar podem ter por fundamento uma situação de urgência. Fala-se, assim, em tutela de urgência.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*).

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (*inaudita altera parte*) ou após justificação prévia.

Nos termos do § 3º do art. 300 do CPC “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Apesar de o código expressamente prever a não concessão em caso de irreversibilidade, o magistrado, no caso concreto, mesmo diante de uma irreversibilidade, poderá fazer um juízo de **ponderação** e conceder a tutela provisória. Há casos em que há uma dupla irreversibilidade (o deferimento é irreversível para o réu e o indeferimento é irreversível para o autor). A análise do risco de irreversibilidade deve ser feita à luz do princípio da proporcionalidade. Deparando-se com risco de irreversibilidade de mão dupla, deve o juiz verificar qual o bem jurídico mais relevante. Diante de dois bens jurídicos que podem sofrer os impactos da irreversibilidade dos efeitos da decisão, cabe ao juiz proteger o de maior relevância.

Acerca dessa temática, o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil dispõe que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.

1.5.1. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Pressupõe uma situação de urgência. Logo, a tutela da evidência não pode ser requerida em caráter antecedente.

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A petição inicial se limitará a requerer o pedido de tutela antecipada. Deverá o autor indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Isso porque

Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. O autor poderá interpor agravo de instrumento. Esse aditamento serve para o autor formular os pedidos principais, a fim de dar início ao procedimento comum.

Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, dois cenários se apresentam:

- **Incumbência do autor:** o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Esse aditamento será realizado nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. O réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do CPC. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito.
- **Incumbência para o réu:** o réu deverá recorrer da decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, sob pena de estabilização.

A) ESTABILIZAÇÃO

No Brasil, a estabilização dos efeitos da tutela antecipada está prevista no art. 304, *caput*, do CPC, segundo o qual “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”.

Da análise do referido dispositivo, extrai-se que **a técnica de estabilização somente ocorrerá na tutela antecipada requerida em caráter antecedente**. Portanto, o art. 304 do CPC não se aplica às hipóteses de tutela antecipada requerida em caráter incidental e muito menos à tutela cautelar, seja ela antecedente ou incidental. Nesse sentido é o entendimento firmado no enunciado 420 do FPPC (“Não cabe estabilização de tutela cautelar”).

A estabilização tem a sua razão de existir na necessidade de se buscar uma rápida solução ao conflito, possibilitando que o autor obtenha uma tutela provisória satisfativa cujos efeitos se perpetuam no tempo até que o autor ou o réu ajuíze uma ação autônoma específica para discutir a estabilização que se operou ou para pleitear a tutela satisfativa definitiva. E como a tutela cautelar tem natureza meramente assecratória, a estabilização não cumpriria o seu objetivo de satisfazer, provisoriamente e de forma estável, a pretensão do autor.

Não há nada que impeça o requerimento de uma tutela antecipada antecedente para fins de ação rescisória. Basta imaginar que após o trânsito em julgado, a parte prejudicada pretenda obter, o mais rápido possível, a suspensão dos efeitos da decisão de mérito. Poderá, nesse caso, requerer ao

órgão do tribunal competente uma tutela antecipada em caráter antecedente consistente na suspensão dos efeitos da decisão que transitou em julgado. Contudo, caso haja deferimento da tutela antecipada pretendida e o réu não interponha recurso contra essa decisão, não haverá estabilização, sob pena de se permitir que a estabilização de uma decisão precária se sobreponha a uma coisa julgada já formada. Nesse sentido, é o entendimento firmado no enunciado 43 da I Jornada de Direito Processual Civil (“Não ocorre a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, quando deferida em ação rescisória”).

Viu-se que a estabilização da tutela antecipada nasce em razão da não interposição de recurso, por parte do réu, contra a decisão concessiva. Contra decisão que defere a tutela antecipada cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC) ou agravo interno (art. 1.021 do CPC), a depender do órgão jurisdicional prolator da decisão. Em outras palavras, a insurgência por parte do réu à decisão antecipatória da tutela obsta a estabilização dos seus efeitos. Contudo, **será que o agravo de instrumento e o agravo interno são os únicos instrumentos demonstrativos da insurgência do réu? E se o réu não agravar, mas apresentar simples petição demonstrando o seu inconformismo? E se o réu não agravar, mas apresentar espontaneamente a sua contestação? Seria possível obstar, nessas outras hipóteses, a estabilização?**

No âmbito do STJ, há, atualmente, dois entendimentos antagônicos:

- **1º)** Qualquer forma de impugnação, ainda que por simples petição, é suficiente para evitar a estabilização. Nesse sentido, a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 do CPC/2015, torna-se estável somente se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. (STJ: INF 639 - REsp 1.760.966-SP – TERCEIRA TURMA);
- **2º)** Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a estabilização, nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil. (STJ: INF 658 - REsp 1.797.365-RS – PRIMEIRA TURMA)

Estabilizada a tutela antecipada, o processo será extinto. Não obstante, qualquer das partes poderá, no prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida nessa nova ação, a tutela antecipada conservará seus efeitos.

A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes.

1.5.2. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Se a tutela provisória a ser requerida em caráter antecedente tiver natureza cautelar, o procedimento será diferente do estudado anteriormente. O CPC criou um verdadeiro procedimento cautelar.

A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 do CPC (princípio da fungibilidade).

O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 306 do CPC). Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor

presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias (art. 307, *caput*, do CPC). Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Concedida a tutela cautelar, ela deverá ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias. Efetivada a cautelar, o autor deverá formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 do CPC, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do CPC.

B) CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR

Deferida a tutela cautelar, é possível que algum fato superveniente gere a cessação dos seus efeitos. O art. 309 do CPC elenca as hipóteses, quais sejam: a) o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; b) não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; c) o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Deveria o legislador ter invertido a ordem do supracitado dispositivo, a fim de que a primeira hipótese fosse a do inciso II. Isso porque somente há de se falar em dedução do pedido principal (inciso I) se, antes, a tutela cautelar for efetivada (inciso II).

Vejamos cada uma das hipóteses:

- **Não efetivação da tutela cautelar no prazo de 30 (trinta) dias:** deferida a tutela cautelar, esta deverá ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias. A ausência de efetivação da tutela cautelar no referido prazo faz cessar os seus efeitos, nos termos do art. 309, II, do CPC. Contudo, a cessão com base na não efetivação da tutela cautelar somente ocorrerá se essa não efetivação decorrer de culpa do autor. Se a não observância do prazo para a efetivação decorre, por exemplo, da inércia ou demora do Poder Judiciário, o autor não pode ser prejudicado. Nesse sentido, é o entendimento firmado no enunciado 46 da I Jornada de Direito Processual Civil (“A cessação da eficácia da tutela cautelar, antecedente ou incidental, pela não efetivação no prazo de 30 dias, só ocorre se caracterizada omissão do requerente”).
- **Não apresentação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias:** dispõe o art. 308, *caput*, do CPC que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. Sendo omissa o autor na apresentação do pedido principal, haverá a cessação dos efeitos da tutela cautelar deferida;
- **Improcedência do pedido principal ou extinção do processo sem resolução do mérito:** é possível que a tutela cautelar seja efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, que o pedido principal seja apresentado também no prazo de 30 (trinta) dias, mas que, ao final do processo, o juiz julgue improcedente o pedido principal do autor. A improcedência do pedido do autor afasta a razão de ser da tutela cautelar, qual seja, a de assegurar o direito vindicado. Ora, a improcedência do pedido nada mais é do que o reconhecimento, pelo juiz, da ausência do direito invocado. E se o direito do autor não foi reconhecido, não há porque ser assegurado. Logo, é caso de cessação da eficácia da tutela cautelar. Da mesma forma ocorrerá quando o processo, por alguma razão, for extinto sem resolução do mérito. A extinção prematura do feito fulmina a possibilidade

de o juiz, naquele mesmo processo, resolver o mérito, cessando, por conseguinte, a eficácia da tutela cautelar anteriormente deferida.

C) RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR

A cessação da eficácia da tutela cautelar não impede que o autor formule novo pedido cautelar. Contudo, haverá preclusão no tocante aos fundamentos. Em outras palavras, a renovação do pedido de tutela cautelar não pode ter o mesmo fundamento do pedido anteriormente deferido e cuja eficácia tenha sido cessada.

É o que dispõe o parágrafo único do art. 309 do CPC (“Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento”).

1.6. TUTELA DA EVIDÊNCIA

A tutela da evidência está prevista no art. 311 do CPC. Trata-se de tutela provisória que independe da demonstração de urgência. É predominantemente satisfativa (antecipada) e somente pode ser requerida em caráter incidental.

É possível identificar duas grandes modalidades de tutela da evidência: i – tutela da evidência punitiva; ii – tutela da evidência documentada. A primeira encontra-se prevista no inciso I do art. 311 do CPC, apresentando-se como uma espécie de “sanção” à parte que viola o princípio da boa-fé processual, notadamente mediante abuso do direito. A segunda, por sua vez, encontra-se prevista nos três incisos seguintes (II, III e IV) do art. 311 do CPC, os quais exigem, dentre outros pressupostos, a prova documentada das alegações da parte.

O art. 311, *caput*, do CPC, dispõe que “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”, o que permite inferir, de antemão, que a “tutela da evidência” não pressupõe a demonstração de qualquer situação de urgência. Em outras palavras, basta que a parte demonstre a evidência do seu direito mediante uma das hipóteses contidas no supracitado dispositivo para que a tutela provisória lhe seja concedida.

Vejamos as hipóteses:

- **Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte:** o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório podem ser praticados tanto pelo autor quanto pelo réu. Daí a utilização do termo “parte” pelo inciso I do art. 311 do CPC, o que significa dizer que a tutela da evidência, nesta hipótese, pode ser concedida tanto ao autor quanto ao réu. Não se pode perder de vista, contudo, que a concessão da tutela da evidência, a despeito de dispensar a demonstração de qualquer situação de urgência, não afasta a necessidade de se demonstrar a probabilidade do direito. Nesse sentido é o entendimento firmado no enunciado 47 da I Jornada de Direito Processual Civil, segundo o qual “a probabilidade do direito constitui requisito para concessão da tutela da evidência fundada em abuso do direito de defesa ou em manifesto propósito protelatório da parte contrária”;
- **As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante:** para a obtenção da tutela da evidência, a parte deve comprovar, de plano e documentalmente, os fatos constitutivos do seu direito, bem como demonstrar que a sua pretensão está amparada por precedente judicial vinculante. Buscando ampliar a hipótese do inciso II do art. 311 do CPC, estabelece o enunciado 48 da I

Jornada de Direito Processual Civil que “é admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores”;

- **Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa:** se refere ao direito da parte de perseguir o bem que foi objeto de contrato de depósito. A prova documental exigida pelo inciso III do art. 311 do CPC deve receber interpretada ampliativa, admitindo-se a demonstração da relação jurídica de direito material (depósito do bem) por qualquer prova documental e não apenas por contrato de depósito. Além disso, é preciso que esteja configurada a mora do réu, quer seja pelo advento do prazo contratual, nos casos de mora *ex re*, quer seja pela existência de notificação/interpelação, nos casos de mora *ex persona*. Em qualquer hipótese, contudo, caso o pedido de tutela da evidência seja formulado após a citação do réu, eventual ausência de notificação/interpelação fica suprida pelo ato citatório, pois segundo o art. 240 do CPC/2015, a citação “constitui em mora o devedor”;
- **A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável:** a prova exigida do réu é a documental. Caso o réu não oponha prova documental capaz de gerar dúvida razoável, mas seja possível e/ou necessária a produção de outras provas (ex.: prova oral ou pericial), a tutela da evidência será deferida ao autor. Caso, por outro lado, o réu não oponha prova documental capaz de gerar dúvida razoável e também não tenha interesse na produção de qualquer outra prova ou não haja necessidade de sua produção, não será caso de simples concessão da tutela da evidência, mas sim de julgamento antecipado dos pedidos (art. 355 do CPC) ou julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC). O julgamento antecipado, contudo, não impede que o juiz, na sentença (ou decisão interlocutória de mérito), também defira a tutela da evidência, situação que projeta relevantes efeitos processuais, como, por exemplo, impedir a produção do efeito suspensivo da apelação (art. 1.012, *caput*, do CPC).

A irrelevância da existência de qualquer situação de urgência para o deferimento da tutela da evidência não impede a sua concessão em caráter liminar, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Dispõe o parágrafo único do art. 311 do CPC que “nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. A razão de ser desse dispositivo é muito simples: as hipóteses previstas nos incisos I e IV do art. 311 do CPC pressupõem a participação do réu no processo, o que as torna incompatível com o pedido liminar da tutela provisória.

O inciso I, como visto, trata da tutela da evidência quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”. Exige-se, aqui, um prévio comportamento da parte contra quem será deferida a tutela da evidência, razão pela qual não tem cabimento o seu deferimento liminar.

O inciso IV, por sua vez, trata da tutela da evidência quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Note que, assim como ocorre no inciso I, exige-se o prévio comportamento do réu, qual seja, não oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável.

Por outro lado, as hipóteses dos incisos II e III não pressupõem a prévia manifestação do réu no processo, razão pela qual poderá o juiz concedê-las liminarmente.

1.7. ENUNCIADOS DAS JORNADAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL SOBRE TUTELA PROVISÓRIA

ENUNCIADO 38 – “As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória independem do trânsito em julgado, inclusive contra o Poder Público (art. 297 do CPC).”

ENUNCIADO 39 – “Cassada ou modificada a tutela de urgência na sentença, a parte poderá, além de interpor recurso, pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior, na petição de recurso ou em via autônoma.”

ENUNCIADO 40 – “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.”

ENUNCIADO 41 – “Nos processos sobrestados por força do regime repetitivo, é possível a apreciação e a efetivação de tutela provisória de urgência, cuja competência será do órgão jurisdicional onde estiverem os autos.”

ENUNCIADO 42 – “É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

ENUNCIADO 43 – “Não ocorre a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, quando deferida em ação rescisória.”

ENUNCIADO 44 – “É requisito da petição inicial da tutela cautelar requerida em caráter antecedente a indicação do valor da causa.”

ENUNCIADO 45 – “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado.”

ENUNCIADO 46 – “A cessação da eficácia da tutela cautelar, antecedente ou incidental, pela não efetivação no prazo de 30 dias, só ocorre se caracterizada omissão do requerente.”

ENUNCIADO 47 – “A probabilidade do direito constitui requisito para concessão da tutela da evidência fundada em abuso do direito de defesa ou em manifesto propósito protelatório da parte contrária.”

ENUNCIADO 48 – “É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores.”

ENUNCIADO 49 – “A tutela da evidência pode ser concedida em mandado de segurança.”

ENUNCIADO 64 – “Ao despachar a reclamação, deferida a suspensão do ato impugnado, o relator pode conceder tutela provisória satisfativa correspondente à decisão originária cuja autoridade foi violada.”

ENUNCIADO 70 – “É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência.”

Enunciado 129 – “É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.”

Enunciado 130 – “É possível a estabilização de tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública.”

QUESTÕES

1-Acerca da tutela provisória, assinale a assertiva correta.

a) O NCPC manteve a distinção existente no CPC/73 em relação à tutela antecipada e as ações cautelares.

- b) A tutela antecipada, fundada na urgência, poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como nos casos de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte.
- c) A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes.
- d) A tutela antecipada deverá ser requerida no bojo da ação principal.
- e) Somente em caso de urgência será possível a concessão de tutela antecipada.

2- A respeito da tutela provisória assinale a alternativa CORRETA

- a) A tutela provisória de urgência, apenas quando antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente.
- b) A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, podendo ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, mas durante o período de suspensão do processo não conservará sua eficácia senão mediante de decisão judicial.
- c) O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, observando as normas ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.
- d) Na decisão que conceder ou negar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso, não sendo necessária motivação no caso de modificação ou revogação por fato novo.

3- Assinale a alternativa INCORRETA com relação a tutela provisória.

- a) A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.
- b) Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado
- c) É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
- d) É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência.
- e) As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória independem do trânsito em julgado, salvo contra o Poder Público.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C

- a) INCORRETA. O NCPC, diferentemente do sistema adotado no CPC/73, passou a conceber a tutela provisória como gênero, da qual são espécies a tutela antecipada e a tutela cautelar. Nos termos do parágrafo único do art. 294 do NCPC, “A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Não há mais as chamadas ações cautelares típicas.

b) INCORRETA. A tutela antecipada, baseada no abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, não é tutela de urgência (art. 300, do NCPC), mas sim tutela de evidência (art. 311, inciso I, do NCPC).

c) CORRETA. Redação do § 6º do art. 304 do NCPC.

d) INCORRETA. A tutela antecipada pode ser requerida no bojo da ação principal. Porém, nos termos do art. 303, do NCPC, “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

e) INCORRETA. O NCPC, diferentemente do CPC/73, diferenciou a tutela antecipada fundada na urgência, daquela fundada na evidência. O art. 311 do NCPC, estabelece que “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando [...]”.

2. Gabarito: C

a) INCORRETA. Art. 294, CPC. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

b) INCORRETA. Art. 296, CPC. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

c) CORRETA. Art. 297, CPC. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

d) INCORRETA. Art. 298, CPC. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

3. Gabarito: E

a) ENUNCIADO 40 – A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.

b) ENUNCIADO 45 – Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado

c) ENUNCIADO 42 – É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica

d) ENUNCIADO 70 – É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência.

e) ENUNCIADO 38, CFJ– As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória independem do trânsito em julgado, inclusive contra o Poder Público (art. 297 do CPC).

CAPÍTULO 9 — ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS

1. ATOS E NEGÓCIOS PROCESSUAIS

1.1. INTRODUÇÃO

Para a doutrina, ato processual consiste na conduta humana voluntária que tem relevância para o processo e não se confunde com os fatos processuais (que são acontecimentos naturais, que podem ter grande relevância ou repercussão no processo, mas não dependem de condutas humanas)²⁸.

Estão disciplinados nos artigos 188 e seguintes do CPC, e podem ser categorizados em “atos jurídicos processuais *stricto sensu*” e em “negócios processuais”.

José Miguel Garcia Medina leciona que, no ato jurídico processual *stricto sensu*, o ato é praticado para a produção de efeitos jurídicos predeterminados pela lei, enquanto nos negócios jurídicos prepondera a autonomia das partes, inclusive quanto aos efeitos²⁹.

1.2. PRINCÍPIOS

Ao analisar os atos e negócios processuais, é necessário ter uma íntima relação com os seguintes princípios:

- Princípio da liberdade de forma dos atos processuais
- Princípio da documentação
- Princípio da publicidade

1.2.1. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS

De acordo com esse princípio, os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. Desse modo, salvo disposição legal ou negocial em contrário a forma processual não será rígida.

Veja, portanto, que **a forma processual é livre**, desde que respeitados os princípios constitucionais e não haja forma prescrita em lei.

1.2.2. PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO

Segundo o princípio da documentação, todos os atos processuais devem ser documentados, ou reduzidos a termo, ainda que seja oralmente.

Nessa documentação, é necessária que seja empregada a **língua portuguesa**, caso contrário, deverá estar acompanhada da respectiva tradução, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

²⁸ GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 9ª edição, São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 295.

²⁹ MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno (livro eletrônico). 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 128.

1.2.3. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Segundo o princípio da publicidade, todos os atos processuais devem ser públicos.

O art. 189 do CPC estabelece que tramita em **segredo de justiça** os processos que o **interesse público exigir**. A regra é que o processo seja público e o segredo de justiça exceção, como é o caso em que haja dado protegido pelo **direito constitucional à intimidade**, processos que versem sobre **casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda**, entre outros.

Nos processos em que há segredo de justiça, a publicidade **fica restrita ao juiz, às partes e aos seus procuradores, podendo, ainda, o terceiro que demonstrar interesse jurídico requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação**.

1.3. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

De acordo com o CPC, os atos processuais podem ser classificados em: a) **atos das partes** (são aqueles praticados pelo autor/réu, por terceiros intervenientes e pelo Ministério Público); b) **atos do juiz** (sentença, decisões interlocutórias, despachos, acórdão, decisão monocrática de relator); c) **atos do escrivão ou chefe de secretaria** (citações, intimações, autuação de processos, atos de documentação, laudo pericial, entre outros).

1.4. TEMPO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS

De acordo com o artigo 212 do CPC, os atos processuais devem ser praticados em **dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas**.

Em caráter excepcional, alguns atos podem ser praticados fora desses dias, tais como a **citação, intimação e penhora**, independentemente de autorização do juiz, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.

Durante as férias forenses e feriados não se praticarão atos processuais, salvo **citação, intimação e penhora**, bem como a **tutela de urgência**. Para a lei processual civil, são feriados os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense, além dos declarados em lei.

Processam-se durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas:

- **Procedimentos de jurisdição voluntária** e os **necessários à conservação de direitos**, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento;
- **Ação de alimentos** e os processos de **nomeação ou remoção de tutor e curador**;
- **Processos que a lei determinar**.

1.5. LUGAR PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS

O art. 217 estabelece que os atos processuais devem ser praticados na sede do juízo. Este mesmo dispositivo autoriza que estes atos sejam praticados em outro local, em caso de:

- Deferência;
- Interesse da justiça;
- Natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.



Trata-se de um rol meramente exemplificativo, haja vista a existência de outros atos que podem ser praticados fora da sede do juízo, tais como, aqueles realizados mediante a expedição de carta precatória.

No que diz respeito à hipótese de obstáculo arguido pelo interessado, ressalte-se que, caso ele tenha sido criado por uma das partes, suspende-se o curso do prazo. Superado o motivo que deu causa à suspensão, este será restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. A mesma regra se aplica às hipóteses de suspensão do processo elencadas no art. 313 do CPC.

1.6. PRAZO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS

Os prazos processuais podem ser: a) legais; b) judiciais; ou c) convencionais.

A princípio, os **prazos legais** são aqueles prescritos na lei.

Ocorre de a lei ser omissa, caso em que caberá ao magistrado estabelecer o prazo (**prazos judiciais**). Caso o magistrado tenha sido omissor, a parte terá o **prazo de 5 dias** para praticar o ato. Este é o prazo geral (art. 218, §3º, CPC).

Já os **prazos convencionais** são aqueles ajustados pelas partes.

Vale lembrar que se a parte praticar um ato antes da abertura do prazo, ele deverá ser considerado como tempestivo.

1.7. CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PERDA DE UM PRAZO

Quando a parte deixa de praticar um ato processual por inércia, este estado de inércia é denominado contumácia. Esta contumácia, na maioria das vezes, gera preclusão.

A preclusão é a perda da possibilidade ou do direito de subjetivo da prática de um ato processual impedindo que as partes discutam questões já decididas no curso do processo. Esta perda da faculdade de praticar um ato pode ser classificada em:

- **Preclusão temporal:** a parte deixa escoar o prazo previsto em lei ou fixado pelo magistrado e não se manifesta. Segundo o art. 223 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa (evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário).
- **Preclusão lógica:** é a perda da faculdade de praticar um ato em razão da parte já ter praticado outro ato incompatível com o ato que pretende praticar. Ex.: condenado é obrigado a pagar mil reais em sentença. O condenado paga a condenação sem qualquer ressalva. Em seguida, o condenado interpõe recurso de apelação. Houve uma preclusão lógica, pois o primeiro ato é incompatível com o segundo ato, não cabendo agora recurso.
- **Preclusão consumativa:** é a perda da faculdade de praticar um ato em razão da parte já tê-lo praticado. Verifica-se em duas situações: i) quando um ato é praticado de forma incompleta e a parte pretende completá-lo; ou ii) quando dois ou mais atos devem ser praticados em um prazo comum e apenas um deles é manejado pelas partes. Ex.: houve uma sentença de parcial procedência em face de João para pagar mil reais. João interpõe recurso de apelação 5 (cinco) dias após a publicação da decisão, sendo o prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, após a interposição do recurso, o recorrente apresenta novo recurso de apelação no 14º dia, inserindo uma nova tese jurídica. Nesse caso, a interposição de novo recurso não será mais possível, pois houve a preclusão consumativa.



- **Preclusão *pro judicato*:** parte da doutrina considera essa preclusão como uma nomenclatura equivocada. O consenso é no sentido de que se trata da impossibilidade de que o juiz se submeta de não mais poder decidir a respeito de uma questão já decidida, salvo exceções, como por exemplo, a possibilidade de reavaliação de questões de ordem pública.

Quando se fala em **revelia**, essa nada mais é do que uma **espécie de contumácia específica** para o demandado, eis que se opera quando o sujeito deixa de apresentar contestação, a qual gera como efeitos a **presunção de veracidade dos fatos** e a **desnecessidade de intimação do réu para ciência e participação dos atos posteriores do processo** (atente-se as exceções previstas no artigo 345 do CPC – o tema será estudado adiante).

1.8. Classificação dos prazos

Os prazos processuais podem ser classificados em prazos próprios, impróprios, dilatórios ou peremptórios.

Prazos próprios são destinados às partes principais ou acessórias, de forma que sua inobservância gera consequências como, por exemplo, a revelia e a preclusão.

Prazos impróprios são destinados, geralmente, ao magistrado ou ao serventuário da justiça. A lei não prevê consequências processuais caso ele não seja observado, ainda que possa haver consequências administrativas. Deve-se ressaltar, no entanto, que todos os sujeitos do processuais devem cooperar para a razoável duração do processo.

Prazos dilatórios são aqueles que podem ser reduzidos ou prorrogados por vontade das partes. Ex.: prazo para juntada de documentos.

Prazos peremptórios são aqueles prazos que não podem ser reduzidos ou prorrogados por vontade das partes. Ex.: prazo para contestar e prazo para recorrer.

Esta classificação dos prazos dilatórios e peremptórios passa a ser desnecessária, pois mesmo o prazo peremptório poderá ser prorrogado (art. 222, CPC), como nos casos em que seja difícil o transporte para a base territorial do juízo, **podendo o juiz prorrogar os prazos por até 2 meses**. Em se tratando de **calamidade pública**, o juiz **podará exceder esse período**.

O CPC prevê que ao juiz é **vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes**.

1.9. CONTAGEM DOS PRAZOS

Definido o termo inicial, o primeiro dia da contagem processual **será imediatamente o primeiro dia útil seguinte**, e na sequência **serão apenas contados os dias úteis** até que se alcance ao termo final.

Apenas a título de informação, uma vez que o tema será abordado em capítulo próprio, a contagem de prazos para a prática de qualquer ato processual nos Juizados Especiais também passou a ser realizado em dias úteis (Lei n. 13.728/2018).

Destaque-se que no período compreendido entre o dia **20 de dezembro** ao dia **20 de janeiro** haverá a **suspensão** de todos os prazos processuais. Tal regra se aplica ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública. Durante esse lapso temporal haverá expediente forense, salvo feriados, férias coletivas nos tribunais superiores ou recesso forense, mas não serão realizadas audiências, nem sessões de julgamento.

Em relação à contagem dos prazos em dias úteis, esta norma deverá ser interpretada restritivamente, devendo apenas se referir às hipóteses em que o CPC **fizer remissão a dias**. Isso porque em determinados dispositivos a lei processual faz remissão a prazo em meses ou em anos. **Se**



o prazo está previsto em meses ou em anos (como, por exemplo, o prazo de dois anos para ajuizamento de ação rescisória), **a contagem será realizada em dias corridos**.

Essa contagem em dias úteis **somente se aplica aos atos praticados intraprocessualmente**. Ex.: o mandado de segurança poderá ser impetrado em até 120 dias, devendo ser contado de forma contínua, visto que não é um prazo intraprocessual, mas sim um **prazo pré-processual**.

1.10. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR MEIO ELETRÔNICO

O tema possui previsão nos arts. 193 a 199 do CPC.

Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, como, por exemplo, nos processos híbridos, que possuem atos físicos e outros digitais.

De acordo com o art. 194, CPC, os atos processuais efetivados por meio eletrônico devem ser praticados observando algumas **garantias**, quais sejam:

- **Disponibilidade:** a informação deverá estar disponível.
- **Independência da plataforma computacional:** não se pode priorizar a utilização exclusiva de bens de determinada empresa. Ex.: acessar só por computador da Apple. É necessário que, independentemente do computador, seja possível acessar o sistema.
- **Acessibilidade:** as informações devem ser acessíveis, principalmente às pessoas com deficiência.
- **Interoperabilidade entre sistemas, serviços e dados:** quer permitir que o sistema se comunique adequadamente entre si e não apenas com um Tribunal específico.

A **competência** para regulamentar a lei em relação à prática de **atos processuais eletrônicos** é do **Conselho Nacional de Justiça** e **apenas supletivamente dos Tribunais**.

1.11. NEGÓCIOS PROCESSUAIS

Negócios processuais são aqueles pontos afetos ao direito processual que podem ser flexibilizados por convenção entre as partes, visando ajustar o procedimento às especificidades da causa. Trata-se de uma **cláusula geral de negociação** que pode ser celebrada, inclusive, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública.

O CPC regulamenta o tema em seu artigo 190 e permite a existência de negócios jurídicos **típicos** e **atípicos**, contanto que respeitem os princípios constitucionais e não afetem poderes e deveres do juiz. No plano da validade, devem ser observados os requisitos elencados no artigo 104 do Código Civil – agente capaz (essa capacidade é a processual e não propriamente a civil), objeto lícito, possível e determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

De acordo com o enunciado 37 da ENFAM “são nulas, por ilicitude do objeto, as convenções processuais que violem as garantias constitucionais do processo, tais como as que: a) autorizem o uso de prova ilícita; b) limitem a publicidade do processo para além das hipóteses expressamente previstas em lei; c) modifiquem o regime de competência absoluta; e d) dispensem o dever de motivação”.

Vale ressaltar que a indisponibilidade do direito material não impede, por si só, que as partes celebrem um negócio jurídico processual, como, por exemplo, nas questões relacionadas ao direito à alimentos.

O juiz, **de ofício** ou **a requerimento**, controlará a validade das convenções processuais, recusando-lhes aplicação somente nos casos:

- De nulidade;
- De inserção abusiva em contrato de adesão; ou
- Em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade processual é a suscetibilidade do litigante que o impede de praticar atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária.

São exemplos de negócios processuais que podem ser pactuados pelas partes:

- **Modificação do procedimento;**
- **Instauração de calendário processual;**
- **Saneamento do processo;**
- **Inversão do ônus da prova;**
- **Renúncia de impenhorabilidade de bens formalizada pelas próprias partes;**
- **Renúncia à força executiva de título extrajudicial por convenção processual;**
- **Dispensa de caução para cumprimento provisório de sentença;**
- **Efeitos do recurso;**
- **Permissão de sustentação oral, ainda que não previstas em lei, ou aumentar o prazo para sustentação.**

1.11.1 NEGÓCIO PROCESSUAL PARA A MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Segundo o mesmo art. 190, CPC, versando sobre **direitos que admitam autocomposição**, é lícito às **partes plenamente capazes** estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e **convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo**.

1.11.2. NEGÓCIO PROCESSUAL PARA A CRIAÇÃO DE CALENDÁRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS

O art. 191, CPC, por sua vez, estabelece que é possível as partes convencionarem e criarem um calendário para a prática dos atos processuais.

Nesse caso, é **dispensável eventuais intimações** para a prática das providências convencionadas ou para realização de audiência cuja data esteja pré-fixada no calendário.

A calendarização **vincula as partes e o juiz**, e os prazos **somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados**.

1.11.3. NEGÓCIO PROCESSUAL PARA QUE O SANEAMENTO DO PROCESSO POSSA SER EFETUADO PELAS PRÓPRIAS PARTES

O saneamento do processo é uma atividade desempenhada pelo magistrado e tem por finalidade resolver questões pendentes, solucionar pontos controvertidos e determinar quais provas ainda devem ser produzidas.

O art. 357, §2º, CPC, **permitirá que as próprias partes apresentem ao juiz uma delimitação consensual das questões de fato e de direito**, apresentando o saneamento do processo que elas mesmo fizeram, ao qual, se homologada, vincula os sujeitos processuais.



É necessário lembrar que isto não vai subtrair do juiz a possibilidade de solucionar outros pontos controvertidos, pois caberá a ele o julgamento da causa, ou ainda os meios de prova que entender adequado, visto que cabe a ele julgar.

Veja, é possível que as partes convençionem sobre o saneamento do processo, cabendo ao juiz homologar o aludido negócio processual, mas esta homologação não lhe retira a iniciativa probatória.

1.11.4. NEGÓCIO PROCESSUAL PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O art. 373, §4º, CPC, autoriza que o ônus da prova seja convençionado pelas partes, **exceto** nas seguintes situações:

- Recair sobre **direito indisponível da parte**;
- Tornar **excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito**.

Isso somente será possível se o contrato apresentar manifestações de vontade paritárias quando da sua formulação, do contrário, poderá ser revestido de abusividade.

O dispositivo **permite que esta inversão de ônus seja realizada extrajudicialmente**, devendo estar prevista em contrato.

1.11.5. NEGÓCIO PROCESSUAL VISANDO À RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE DE BENS POR CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES

Ao dispor sobre os bens impenhoráveis, o CPC não fala mais em bens absolutamente impenhoráveis (art. 833), isso porque existe a possibilidade de a parte renunciar à impenhorabilidade dos bens previstos no aludido dispositivo, com exceção dos bens inalienáveis e do bem de família.

Ressalte-se que o pacto de impenhorabilidade produz efeitos entre as partes, não alcançando terceiros, conforme dispõe o enunciado 152 da II Jornada de Direito Processual Civil (CJF).

1.11.6. NEGÓCIO PROCESSUAL VISANDO À RENÚNCIA À FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR CONVENÇÃO PROCESSUAL

Segundo o art. 785 do CPC, a **existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento**, a fim de obter título executivo judicial.

Trata-se de negócio processual, feito no bojo do processo, por convenção processual, em que a parte renuncia à força executiva de um título executivo extrajudicial que ela tem, devendo discutir em processo de conhecimento.

Nota-se, portanto, que a existência de um título executivo extrajudicial não é óbice ao ajuizamento de ação condenatória, podendo ainda o credor optar pelo ajuizamento de ação monitória, a despeito da possibilidade de utilização da via executória.

1.11.7. NEGÓCIO PROCESSUAL PARA RENÚNCIA PRÉVIA AO DIREITO DE RECORRER OU DE PRODUZIR PROVAS

Não há óbice legal para que a parte renuncie ao direito de recorrer ou de produzir provas.

1.11.8. NEGÓCIO PROCESSUAL PARA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS PEREMPTÓRIOS

Ao magistrado é vedado reduzir prazos peremptórios, sem que haja anuência das partes. Assim, se as partes anuírem, o juiz poderá promover, mediante negociação processual, a redução e a alteração do prazo peremptório.

1.11.9. MEIOS PARA NULIFICAR OS NEGÓCIOS PROCESSUAIS

Na verdade, quando se fala de nulidade, fala-se de um vício do negócio processual.

Há normas na lei processual que autorizam o juiz reconhecer de ofício as nulidades em convenções processuais, como é o caso da eleição de foro.

Há quem entenda na doutrina, ainda, que a regra acima deve ser expandida para todos os negócios processuais. Deste modo, se houver uma nulidade ou abusividade, o juiz deverá reconhecer de ofício, sem permitir que produza efeitos no processo.

Cumpra salientar que o negócio jurídico processual não pode afrontar o devido processo legal (por exemplo, as partes não podem firmar negócio jurídico para excluir o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica) e os direitos e garantias fundamentais (tais como o contraditório e o juiz natural). Além disso, não pode afastar os deveres inerentes aos princípios da boa-fé e da cooperação, nem alterar normas cogentes ou versar sobre matéria de reserva legal.

Além do mais, as partes não podem estabelecer, em convenção processual, a vedação da participação do *amicus curiae*, visto que tal sujeito processual figura como auxiliar do juízo.

QUESTÕES

1- (TJRO/VUNESP) Com relação à forma, ao tempo e ao lugar dos atos processuais, assinale a alternativa correta.

- a) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.
- b) Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade só podem modificar ou extinguir direitos processuais após a homologação judicial.
- c) Salvo autorização judicial, as citações, intimações e penhoras não poderão ser realizadas no período de férias forenses e nos feriados.
- d) Em caso de obstáculo criado por uma das partes, superado o motivo que deu causa à suspensão do curso do prazo, este será restituído integralmente à outra parte.
- e) O documento redigido em língua estrangeira poderá ser juntado aos autos desacompanhado de versão para a língua portuguesa se as partes assim acordarem.

2- (TJ-AL/FCC) Quanto aos prazos,

- a) sendo a lei omissa, o prazo para a parte praticar o ato processual será sempre o de dez dias.
- b) a parte pode renunciar àqueles estabelecidos exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.
- c) quando contados em dias, estabelecidos legal ou judicialmente, computar-se-ão os dias corridos.



d) se processuais, interrompem-se nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

e) será considerado intempestivo o ato praticado antes de seu termo inicial, por ainda não existir, processualmente.

3- (DPE-SP/FCC) Os negócios processuais

a) típicos são, por exemplo, a eleição do foro, a desistência da ação após a apresentação de resposta do réu, a distribuição convencional do ônus da prova e a calendarização do processo.

b) autorizam que as partes possam estabelecer consensualmente a proibição da intervenção de terceiro na condição de *amicus curiae* e do Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica, a fim de assegurar a celeridade do processo.

c) somente são permitidos caso o direito material em discussão naquele processo seja disponível, de maneira que são vedados quaisquer negócios processuais em processos que tenham por objeto algum direito substancial indisponível.

d) dependem somente da vontade das partes envolvidas, de modo que se mostra desnecessária a participação ou a homologação judicial das convenções processuais estabelecidas pela livre manifestação das partes.

e) são um instituto novo no sistema processual civil brasileiro, inaugurado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual ainda pairam diversas controvérsias na doutrina e jurisprudência a seu respeito.

4- (TJ-CE/CESPE) A fixação de calendário para a prática de atos processuais

a) vincula as partes, mas não o juiz.

b) torna dispensável intimação para a audiência cuja data esteja designada no calendário.

c) é uma convenção processual e, portanto, não pode ser firmada pela fazenda pública.

d) deve assumir a forma determinada em lei para evitar falha que gere nulidade.

e) é uma convenção processual que, se estipular confidencialidade, permitirá que o processo tramite em segredo de justiça.

5- (DPE-PE/ CESPE) Regra geral prevista no Código de Processo Civil determina que os atos processuais sejam realizados em dias úteis, das seis às vinte horas. Com relação aos tempos dos atos processuais, assinale a opção correta, conforme a legislação pertinente.

a) A prática eletrônica de ato processual poderá ocorrer até as vinte e quatro horas do último dia do prazo.

b) Em se tratando de prática eletrônica de ato processual, o horário a ser considerado será aquele vigente no juízo que emitiu o ato.

c) Durante as férias forenses, atos processuais de tutela de evidência podem ser praticados.

d) Ato processual iniciado antes das vinte horas não poderá ser concluído após esse horário, independentemente de o adiamento causar grave dano aos envolvidos no processo.

e) Apenas com autorização judicial as citações poderão ser realizadas durante as férias forenses.



6- (DPE-PR/FCC) Vulnerabilidade processual é a suscetibilidade do litigante que o impede de praticar atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária. Deste modo,

- a) para dirimir a suscetibilidade daquele que foi vulnerável na relação de direito material, o magistrado poderá em qualquer momento processual afastar de ofício a cláusula de eleição de foro.
- b) reconhecendo a vulnerabilidade da mulher em face do homem na relação conjugal, sendo ainda uma realidade brasileira a sua submissão a práticas familiares patriarcais, o novo CPC manteve a prerrogativa do foro da esposa para ações de divórcio.
- c) apesar de o novo CPC não conceituar o termo vulnerabilidade, tal vocábulo aparece no diploma em dispositivo que versa sobre a possibilidade de o juiz controlar a convenção das partes acerca de alteração em procedimento.
- d) verificada a suscetibilidade de umas das partes em face da outra, não poderá o magistrado dilatar os prazos processuais em benefício dela, pois deve assegurar às partes igualdade de tratamento.
- e) há regra específica para a superação da vulnerabilidade geográfica a qual prevê que na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até um mês.

7- (MPE-PR/MPE-PR) Sobre a disciplina dos atos processuais no Código de Processo Civil de 2015, assinale a alternativa correta:

- a) Os atos processuais podem ser parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;
- b) Os negócios jurídicos processuais e o calendário processual são faculdades que decorrem da negociação exclusiva das partes, devendo o magistrado apenas controlar a validade das convenções previstas;
- c) Como a movimentação processual é exclusiva de advogado, não há no Código de Processo Civil preocupação com a acessibilidade aos sítios das unidades do Poder Judiciário na rede mundial de computadores;
- d) A distinção entre sentença e decisão interlocutória é de conteúdo material, sendo irrelevante o momento e a situação processual em que o ato do juiz foi praticado e seus efeitos para o andamento do processo;
- e) Toda decisão oriunda dos tribunais é considerada, pelo Código de Processo Civil, como um acórdão.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: A.

- a) Art. 225 do CPC: A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.
- b) Art. 200, *caput*, do CPC: Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.
- c) Art. 212, §2º, CPC: Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



d) Art. 221 do CPC: Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

e) Art. 191, parágrafo único, CPC: O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

2. Gabarito: B.

a) Art. 218, §3º, CPC: Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

b) Art. 225 do CPC: A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.

c) Art. 219 do CPC: Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

d) Art. 220 do CPC: Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

e) Art. 218, §4º, CPC: Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

3. Gabarito: A.

a) O Código de Processo Civil prevê em seus artigos algumas espécies de negócios jurídicos típicos, dentre elas estão a eleição do foro (artigo 63, CPC), a desistência da ação após a apresentação de resposta do réu (artigo 485, §4º, CPC), a distribuição convencional do ônus da prova (artigo 373, §§3º e 4º, CPC) e a calendarização do processo (artigo 191).

b) De acordo com o enunciado n. 254 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), “é inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica”. Por sua vez, o enunciado n. 392 do FPPC estabelece que “as partes não podem estabelecer, em convenção processual, a vedação da participação do *amicus curiae*”.

c) Nos termos do enunciado n. 135 do FPPC, “a indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual”.

d) Embora as partes tenham ampla liberdade para negociar, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, controlar a validade dessa negociação, conforme preceitua o artigo 190, parágrafo único, do CPC: “de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”.

e) Não existem controvérsias quanto a aplicação do negócio jurídico processual, pois, embora ele tenha sido positivado no Código de Processo Civil de 2015, desde o Código Buzaid (CPC/73) já haviam exemplos de sua aplicação na prática, como, por exemplo, a cláusula de eleição de foro (artigo 111, CPC/73).

4. Gabarito: B.

a) Art. 191, §1º, do CPC: O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.

b) Art. 191, §2º, do CPC: Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

c) Nos termos do enunciado n. 256 do FPPC, “a Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual”.

d) De acordo com Fredie Didier Jr.,

a forma do negócio processual atípico é livre. A consagração da atipicidade da negociação processual liberta a forma com o que o negócio jurídico se apresenta. Assim, é possível negócio processual oral ou escrito, expresso ou tácito, apresentado por documento formado extrajudicialmente ou em mesa de audiência etc.³⁰.

e) A regra é que os atos processuais sejam públicos. No entanto, o artigo 189 do CPC estabelece as hipóteses em que o processo deverá tramitar em segredo de justiça. De acordo com o enunciado n. 37 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM),

são nulas, por ilicitude do objeto, as convenções processuais que violem as garantias constitucionais do processo, tais como as que: a) autorizem o uso de prova ilícita; b) limitem a publicidade do processo para além das hipóteses expressamente previstas em lei; c) modifiquem o regime de competência absoluta; e d) dispensem o dever de motivação.

Desta forma, o negócio jurídico processual não pode estipular confidencialidade fora das situações elencadas na lei.

5. Gabarito: A.

a) Art. 213 do CPC: A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

b) Art. 213, parágrafo único, do CPC: Em se tratando de prática eletrônica de ato processual, o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.

c) A lei processual preconiza em seu artigo 214 que, durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, exceto as citações, intimações, penhoras e os atos relacionados à tutela de urgência e não de evidência.

d) Art. 212, §1º, CPC: Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.

e) Art. 212, §2º, CPC: Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

6. Gabarito: C.

a) A cláusula de eleição de foro só poderá ser afastada de ofício pelo juiz caso seja abusiva, antes da citação, conforme determina o artigo 63, §3º, do CPC, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.

³⁰ DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. —18 ed.— Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, página 394.

b) O CPC/15 não manteve a prerrogativa de foro da mulher para as ações de divórcio, determinado em seu texto (art. 53, I) que as ações de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável serão propostas no foro de domicílio do guardião de filho de incapaz; no foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; no foro de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; ou no foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar.

c) O CPC não conceitua o termo “vulnerabilidade”, contudo, faz alusão ao referido termo em seu artigo 190, parágrafo único, segundo o qual “de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”.

d) A dilação de prazo pelo magistrado em favor de uma das partes encontra respaldo no artigo 437, §2º, do CPC, que disciplina que “poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação”.

e) A regra para superação da vulnerabilidade geográfica está prevista no art. 222 do CPC e se refere a possibilidade de o juiz prorrogar os prazos, por até 02 (dois) meses, para a prática de atos processuais nas comarcas, seções ou subseções judiciárias onde for difícil o transporte.

7. Gabarito: A.

a) Art. 193 do CPC: Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.

b) Os negócios jurídicos processuais e o calendário processual são faculdades que decorrem de negociação entre as partes e o juiz, conforme previsão do artigo 191, *caput*, do CPC.

c) Diferentemente do disposto na alternativa, o Código de Processo Civil se preocupou com a acessibilidade aos sistemas informacionais das pessoas com deficiência, tanto é que disciplinou em seu artigo 199 que “as unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica”.

d) São relevantes para distinguir uma sentença e uma decisão interlocutória o momento processual e a situação em que foram proferidas, visto que a sentença é o pronunciamento judicial que, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por sua vez, a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença.

e) Nem toda decisão oriunda dos tribunais pode ser considerada com um acórdão, como, por exemplo, as decisões monocráticas ou singulares.

2. VÍCIOS DOS ATOS PROCESSUAIS

2.1. PRINCÍPIOS REITORES

No plano dos vícios processuais, deve-se salientar que os atos praticados no processo, assim como os atos jurídicos, devem observar as seguintes premissas: agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei.

Considerando que a finalidade do processo é a construção de uma norma jurídica individualizada – **princípio da primazia do julgamento de mérito**, o Código de Processo Civil criou o

sistema de invalidade, visando, assim, evitar a decretação da nulidade/invalidade de um ato processual, sem que tenha se buscado primeiro corrigir o defeito.

Em consonância com esse sistema, uma invalidade só pode ser decretada como medida excepcional, ou seja, após a oportunidade de corrigir o erro.

Tem como princípios reitores:

- Princípio da instrumentalidade das formas;
- Princípio do prejuízo;
- Princípio da causalidade;
- Princípio do interesse.

2.1.1. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS

O princípio da instrumentalidade das formas está disciplinado no art. 277 do CPC e traz como essência a ideia de que, quando a lei prescrever determinada forma, inexistindo prejuízo para a parte contrária e para o próprio andamento do feito, e tendo atingido sua finalidade, aproveita-se o ato viciado, seja absolutamente ou relativamente nulo.

Desse modo, o princípio da instrumentalidade das formas torna irrelevante o vício, desde que o ato tenha atingido sua finalidade.

2.1.2. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO (ART. 282, §1º, CPC)

Está intimamente ligado ao princípio da instrumentalidade das formas e estabelece que será dado aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

2.1.3. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 281, CPC)

De acordo com esse princípio, **anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam**, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Na esfera dos vícios processuais, tal postulado se aproxima muito da teoria dos frutos da árvore envenenada. Isto é, se for declarada a nulidade de um ato, os atos que dele decorrerem também serão nulos.

É necessário que se faça uma análise de dependência/independência entre o ato nulo e os outros atos a serem considerados, de modo que, os atos processuais que mantenham dependência com o ato nulo serão considerados nulos (nulidade derivada ou decorrente) e os atos processuais que mantenham independência com ele, não serão atingidos.

2.1.4. PRINCÍPIO DO INTERESSE (ART. 276, CPC)

O princípio do interesse tutela o princípio da confiança e da boa-fé processual ao prescrever que **a decretação do vício não poderá ser requerida pela parte que o tiver ocasionado**. Após ter praticado o ato, a parte não pode alegar sua nulidade, operando-se a preclusão lógica da alegação.

2.2. ESPÉCIES DE VÍCIOS PROCESSUAIS

Inicialmente, convém esclarecer a distinção existente entre defeito e invalidade. O **defeito** é um vício, ou seja, o ato processual está inquinado de alguma falha relacionada a validade do

processo. Por exemplo, se uma ação é proposta perante um juízo absolutamente incompetente, o defeito está na tramitação do próprio processo perante o juízo incompetente.

A sanção para um ato processual defeituoso é a **decretação da invalidade dos atos processuais**. Deste modo, para a doutrina, o defeito é o vício e a invalidade é a sanção.

Há defeitos que não geram qualquer invalidade do ato processual ou do processo, como, por exemplo, um erro meramente material em uma certidão do Cartório da secretária. Existem, também, defeitos que geram nulidades, mas que não podem ser reconhecidos de ofício, como a ausência de alegação de incompetência relativa ou de convenção de arbitragem.

Por outro lado, há defeitos que geram nulidade do ato processual e podem ser reconhecidos de ofício (como a incompetência absoluta), e defeitos que podem ser reconhecidos de ofício, mas se não forem suscitados na primeira oportunidade gera preclusão (vício na citação).

São espécies de vícios processuais:

2.2.1. INEXISTÊNCIA

O vício da inexistência não se sujeita à preclusão, pois, em tese, é um nada jurídico. Caso chegue à justiça, **o juiz pode pronunciar de ofício a inexistência**. Ex.: sentença assinada pelo oficial de gabinete ou pelo escrivão. Esta sentença inexistente.

2.2.2. NULIDADE ABSOLUTA E NULIDADE RELATIVA

Na **nulidade absoluta**, também conhecida como nulidade insanável ou cominada, há a inobservância de uma norma de ordem pública, podendo ser pronunciada de ofício, ou seja, sem qualquer provocação e a qualquer tempo.

O que se discute é que, se o ato inquinado por nulidade absoluta deve ser invalidado ou se este ato pode ser convalidado.

Há posições em ambos os sentidos.

A ausência de intimação do Ministério Público nas ações em que sua intervenção é obrigatória constitui causa de nulidade processual, cabendo ao órgão se manifestar sobre eventual prejuízo. A invalidação será efetivada a partir do momento em que o órgão deveria ter sido intimado.

A **nulidade relativa** decorre da inobservância de uma norma de ordem privada e não pode ser decretada de ofício, sendo necessário que haja provocação pela parte na primeira oportunidade que couber a ela falar nos autos.

No CPC, o art. 73 exige o consentimento de um dos cônjuges para que o outro possa ingressar com certas demandas, quando se tratar, como regra, de bens imóveis, a depender do regime de bens do casal.

Essa ausência de consentimento é um vício sanável. Inclusive este vício poderá ser suprido judicialmente. No caso de ausência de consentimento, apesar de ser relativa, poderá ser pronunciado de ofício pelo magistrado.

Ressalte-se que, independentemente da nulidade, a invalidação do ato processual dependerá de decisão judicial nesse sentido.

2.2.3. RESCINDIBILIDADE

A rescindibilidade é um vício processual que justifica a propositura de uma ação rescisória. Trata-se de um vício que produz coisa julgada material, mas só pode ser pronunciado e reconhecido



no bojo de uma ação rescisória. **As rescindibilidades são aquelas situações que autorizam a propositura de uma ação rescisória.** Ex.: sentença transitada em julgado proferida por juiz absolutamente incompetente, cabendo ação rescisória e havendo coisa julgada material.

Por isso, este vício processual será um vício rescindível. Após os 2 (dois) anos do trânsito em julgado, haverá coisa soberanamente julgada.

2.2.4. IRREGULARIDADE

Irregularidade é uma categoria de vícios dos atos processuais que não macula a existência, validade ou mesmo a eficácia dos atos.

O ato está em desconformidade pela maneira pretendida pela lei, mas esta inconformidade não gera qualquer consequência. Ex.: a lei diz que as peças processuais devem ser redigidas em língua portuguesa. O sujeito atravessa uma petição parcialmente redigida em língua inglesa. Trata-se de mera irregularidade.

2.3. CONVALIDAÇÃO DO ATO PROCESSUAL

No sistema processual brasileiro predomina a ideia do **princípio da fungibilidade dos atos processuais**, permitindo, assim, a convalidação de um ato processual inicialmente defeituoso.

São quatro as possíveis situações de convalidação do ato:

- Primeira situação: nulidade relativa – haverá a convalidação de um ato processual com o fenômeno da preclusão (caso não alegada em um primeiro momento);
- Segunda situação: nulidade absoluta – em regra, o ato se convalida com o trânsito em julgado. O artigo 508 do CPC disciplina a chamada **eficácia preclusiva da coisa julgada**, ou seja, consideram-se alegadas e repelidas todas aquelas questões que poderiam ter sido suscitadas pelas partes e não o foram;
- Terceira situação: há vícios/defeitos que mesmo após o trânsito em julgado podem ser arguidos. Por exemplo, os vícios que fundamentam as hipóteses de uma ação rescisória – art. 966 do CPC;
- Quarta situação: vícios transrescisórios, ou seja, mesmo após o prazo de dois anos da ação rescisória (chamada de coisa soberanamente julgada), é possível que eventuais vícios sejam arguidos. Por exemplo, quando houver um vício de citação, a parte deve ajuizar uma ação autônoma de impugnação, denominada de *querela nullitatis insanabilis*, a qual tem por finalidade reconhecer um vício de citação e, consequentemente, reconhecer a invalidade de todo o processo.

QUESTÕES

1- (TJ-AL/FCC) O erro de forma do processo

- a) acarreta a ineficácia de todos os atos processuais, que deverão ser repetidos de acordo com a forma prescrita ou não defesa em lei.
- b) acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.
- c) não acarreta consequência processual alguma, devendo prevalecer os atos praticados em nome do exercício pleno e efetivo da atividade jurisdicional.



- d) acarreta a inexistência dos atos processuais cujo aproveitamento não seja possível, a serem novamente praticados em tempo razoável.
- e) é mera irregularidade, que só necessitará de ratificação ou convalidação se alguma das partes for menor ou incapaz.

2- (DPE-BA/FCC) Sobre a nulidade dos atos processuais, é correto afirmar que

- a) sua decretação pode ser requerida pela parte que lhe der causa, quando a lei prescrever determinada forma para o ato.
- b) se verifica independentemente da existência de prejuízo.
- c) o juiz não a pronunciará quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite.
- d) pode ser alegada, em regra, em qualquer momento, não estando sujeita a preclusão.
- e) o erro de forma invalida o ato ainda que possa ser aproveitado sem prejuízo à defesa das partes.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: B.

Comentários: A questão exige conhecimento acerca do art. 283 do CPC, que assim dispõe: “o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais”. Observa-se do aludido dispositivo que o erro de forma não tem o condão de anular todo o processo, mas apenas os atos procedimentais que não possam ser aproveitados. Nota-se, contudo, que acarreta consequência processual, visto que os atos eivados de erro de forma que ocasionem prejuízos ao direito de defesa das partes não devem ser aproveitados, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

2. Gabarito: C.

- a) Art. 276 do CPC: Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
- b) Art. 283, parágrafo único, do CPC: Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
- c) Art. 282, §2º, do CPC: Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
- d) Art. 278 do CPC: A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
- e) Art. 283, parágrafo único, do CPC: Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.



CAPÍTULO 10 — PROCESSO DE CONHECIMENTO

1. PROCESSO DE CONHECIMENTO E O PROCEDIMENTO COMUM

1.1. DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO E PROCEDIMENTO

Processo, em síntese, é um conjunto de atos que estabelecem uma **relação jurídica processual**.

Procedimento é o modo como o processo se exterioriza, consistindo em uma **sucessão de atos processuais** concatenados que visam garantir a prestação da tutela jurisdicional.

Há quem defina processo como o procedimento estruturado em contraditório.

1.2. INDISPONIBILIDADE DO PROCEDIMENTO

O procedimento, em regra, não pode ser objeto de escolha pelos litigantes, mas esta máxima de indisponibilidade sofreu mitigação no art. 190 do CPC, dispositivo que permite a alteração do procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Ex.: demandante pode optar, em uma ação cujo conteúdo econômico não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, entre propor uma ação perante a vara cível ou perante o juízo do juizado especial cível. Veja, é possível escolher o procedimento em certas hipóteses.

Outro exemplo é aquele em que o autor pode optar por usar o mandado de segurança ou por instaurar uma demanda, observando o rito comum.

Conforme já mencionado em linhas volvidas, via de regra, a alteração procedimental só pode ser realizada quando a causa versar sobre direitos que admitam autocomposição e as partes forem plenamente capazes.

1.3. PROCEDIMENTO COMUM

O procedimento comum é o que deve ser observado quando não houver rito especial e é dividido em quatro fases: postulatória, ordinatória, instrutória e decisória.

A fase **postulatória** é composta pela petição inicial e resposta do réu. Já a fase **ordinatória** possui início após a apresentação da contestação e é constituída pelo saneamento e organização do processo, isto é, o juiz verifica se é necessária a adoção de alguma providência preliminar e, posteriormente, se é caso de julgamento conforme o estado do processo ou de instrução processual.

Havendo necessidade de instrução processual, ingressa-se na fase **instrutória** de produção de provas. Por fim, na fase **decisória**, oportunidade em que o juiz profere uma decisão de mérito.

O procedimento comum, basicamente, deve observar a seguinte ordem:

- Petição inicial;
- Deferimento da petição inicial e a consequente determinação de citação do demandado;
- Audiência, em tese, obrigatória de conciliação e mediação;
- O réu apresenta defesa, podendo apresentar sua contestação e uma reconvenção (na própria contestação);
- Providência preliminares;

- Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, seja parcial (decisão interlocutória) ou total (sentença);
- Saneamento do processo, pode ser feito em gabinete, em audiência ou pelas partes e submetido à homologação;
- Audiência de instrução e julgamento, se necessária;
- Sentença.

O CPC prevê em seu artigo 318, parágrafo único, a aplicação subsidiária do procedimento comum aos procedimentos especiais (artigos 539 e seguintes) e ao processo de execução (artigos 771 e seguintes).

2. PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial é a peça que inaugura o processo, sendo o primeiro ato da fase postulatória. Deve ser direcionada ao juízo competente e instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Para a doutrina, “documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido”³¹.

2.1. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

O art. 319 do CPC traz os seguintes **requisitos** da petição inicial:

- **Indicação do juízo ou Tribunal;**
- **Identificação e qualificação das partes;**
- **Fato e fundamentos jurídicos do pedido;**
- **Pedido com as suas especificações;**
- **Valor da causa;**
- **Provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;**
- **Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.**

O juiz, se verificar que a petição inicial não preenche tais requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, **no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.** Caso o autor não cumpra essa diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.1.1. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

São elementos identificadores e qualificadores das partes: nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu).

³¹ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 12 ed.– Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, página 597.

O nome poderá ser dispensado se for possível delimitar a pessoa ou as pessoas que ocuparão o polo passivo (ex.: ocupação pelo MST).

Caso o demandante não disponha de todos estes elementos, ou ao menos suficientes para delimitar o polo passivo, **podrá requerer auxílio do poder judiciário para obter as informações faltantes**, conforme disposto no §1º do art. 319, que diz que, caso não disponha das informações relativas à identificação e qualificação, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção.

O demandante ficará dispensado dessas informações se for excessivamente difícil de se obtê-las.

2.1.2. CAUSA DE PEDIR

A causa de pedir é o fundamento da demanda, ou seja, o que leva o autor a pleitear a tutela jurisdicional. É dividida pela doutrina em **causa de pedir próxima** (constituída pelos fatos) e **causa de pedir remota** (constituída pelos fundamentos jurídicos). No entanto, deve-se ter atenção a essa divisão, pois há quem entenda exatamente o contrário, ou seja, que a causa de pedir próxima corresponde à fundamentação de direito e a causa de pedir remota corresponde à fundamentação de fato.

A causa de pedir pode ser dividida, ainda, em **ativa** (corresponde ao fato constitutivo do direito do autor) ou **passiva** (corresponde ao fato violador do direito do autor). Ex.: em uma execução fiscal, o fato gerador do tributo devido pode ser identificado como a causa de pedir ativa, enquanto que o seu inadimplemento seria a causa de pedir passiva.

A doutrina elenca duas teorias relacionadas a causa de pedir: **i) teoria da substanciação/substancialização**: a causa de pedir será composta pelos fundamentos de fato e de direito, devendo o autor expor de forma mais ampla possível o fato jurídico e a relação jurídica decorrente, o que não impede, contudo, que o juiz, ainda que de ofício, leve em consideração algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, ocorrido após a propositura da demanda, no momento de proferir a sentença; **ii) teoria da individuação/individualização**: basta que o autor exponha a relação jurídica em que está inserido, sendo composta apenas pela fundamentação de direito.

Embora exista posicionamento em sentido contrário, prepondera o entendimento de que o **Direito Processual Civil adotou a teoria da substanciação**.

Convém destacar que, para o STJ, o nome atribuído a ação é irrelevante para a aferição de sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir³².

2.1.3. PEDIDO

O pedido é o núcleo essencial de toda e qualquer petição inicial. **É o pedido que limita a atuação do juiz**, pois, com base no princípio da congruência, não pode o juiz decidir nem aquém e nem além do pedido.

É importante diferenciar o objeto imediato do pedido do objeto mediato.

- **Objeto imediato**: é aquele dirigido ao Estado-Juiz, em que há o pedido para que haja um provimento jurisdicional da tutela que o demandante pretende obter ao final do processo.

³² AResp 778.247/RJ.

- **Objeto mediato:** é o bem da vida, ou seja, a providência de cunho material que o autor efetivamente quer obter.

O pedido deve ser certo e determinado. Pedido **certo** é pedido expresso, isto é, o autor deve indicar de forma clara qual é a tutela jurisdicional que ele busca. E pedido **determinado** se refere a delimitação do bem da vida pretendido (em que consiste e em quanto).

Para o STJ é pacífico o entendimento de que “**não** configura julgamento *ultra petita* ou *extra petita*, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial”³³.

Convém destacar, também, que, para o STJ, o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. A obrigatoria adstrição do julgamento ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da *mihi factum dabo tibi ius* (dá-me os fatos que te darei o direito) e *iura novit curia* (o juiz é quem conhece o direito)³⁴.

i. Pedido implícito

De acordo com o §2º do artigo 322, na interpretação do pedido deve ser considerado o conjunto da postulação, observando-se o princípio da boa-fé. Desta feita, a mera ausência ou imprecisão terminológica dos pedidos não impede o julgamento de todas as questões discutidas.

Por vezes, é possível o reconhecimento de pedido implícito, visto que não está no corpo da petição, mas decorre de expressa previsão normativa. Ex.: condenação ao pagamento de juros.

Outro exemplo é a condenação de prestações periódicas. Neste caso, segundo o art. 323, há a possibilidade de considerar procedente o pleito e condenar o pagamento das prestações periódicas que forem vencendo ao longo do processo, pois o caráter é implícito.

Tem-se como mais um exemplo, a ausência de pedido para que a parte pague as custas processuais e honorários.

Embora a legislação autorize pedido implícito, **a decisão do juiz que o reconhece deve ser expressa no que toca ao reconhecimento desse pedido implícito**, pois, **do contrário, o advogado deverá opor embargos de declaração para suprir a omissão**. É o teor da Súmula 453 do STJ³⁵.

A jurisprudência, no que diz respeito aos juros e correção monetária, poderão ser exigidos mesmo nos casos em que a decisão transitada em julgado tiver sido omissa, sendo o fundamento a vedação do enriquecimento sem causa.

ii. Pedido genérico

O pedido genérico é aquele que, embora seja expresso, não é delimitado.

Não é delimitado porque o autor não tem condições de individualizar a abrangência do bem da vida que pretende obter.

As **hipóteses pedido genérico**, dentre outras, são:

- **Ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados**

Ações universais são aquelas demandas em que se discutem, por exemplo, a propriedade de determinado bem, sem que se possa indicar, de início, quais são os bens exatamente.

³³ A tese pode ser conferida em 339 acórdãos disponibilizados na página Pesquisa Pronta do STJ. REsp 1537996/DF.

³⁴ AgRg no REsp 1455713/SC.

³⁵ **Súmula 453, STJ:** Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

Refere-se a universalidade de fato ou de direito e, como não dá para delimitar, o pedido será genérico. Tem-se como exemplo de universalidade de fato o rebanho e a biblioteca, e como universalidade de direito, a herança.

- **Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato praticado**

É o caso do acidente, sendo necessário primeiro verificar os gastos com hospital, veículo, cirurgia, entre outros, para somente depois verificar, ainda, se precisará de uma pensão vitalícia, ou mesmo qual será a extensão da sequela. Neste caso, percebe claramente que não é possível delimitar, inicialmente, o pedido, autorizando que o autor formule pedido genérico.

- **Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu**

Somente com um ato praticado pelo demandado é que se saberá qual é a delimitação exata do pedido. Ex.: ação de exigir contas. Neste caso, como o sujeito não presta contas, não é possível saber o montante devido pelo administrador. Esse caso autoriza que o pedido seja genérico.

O CPC **proibiu** expressamente o **pedido genérico de danos morais**. Então, o valor da causa deverá ser exatamente o que o sujeito pretende receber.

iii. Pedido certo e determinado de danos morais: valor inferior ao postulado

Como dito, o valor dos danos morais deve ser determinado pela parte autora.

Caso na sentença o juiz fixe um valor inferior aquele que foi postulado, como será avaliada a sucumbência? Ex.: sujeito pediu 10 mil reais, mas o juiz fixou em 2 mil reais os danos morais. **A jurisprudência entende que, mesmo nesta hipótese, será o demandado quem arcará exclusivamente com as custas e honorários.** O fundamento é de que o pedido do autor foi integralmente acolhido, eis que o arbitramento do dano moral é um desdobramento da procedência do pedido. O juiz realmente reconheceu que houve o dano moral.

O outro fundamento é de que não seria razoável que quem fosse vitorioso no pleito tivesse que arcar com as despesas processuais, eis que atingiria até mesmo o valor da indenização.

A **súmula 326 do STJ** vai dizer que **na ação de indenização por dano moral, a condenação por montante inferior de danos morais não implica sucumbência recíproca**. Neste caso, o demandado vai ter de pagar as custas processuais e honorários.

iv. Cumulação de pedidos

Cumulação de pedidos é a **formulação de mais de um pedido dentro do mesmo processo**. Ex.: sujeito pede indenização por danos morais e materiais.

O art. 327 do CPC estabelece que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

São **requisitos** para a cumulação de pedidos:

- Pedidos sejam compatíveis entre si;
- Juízo competente para ambos os pleitos;
- Seja adequado o mesmo tipo de procedimento para ambos.

São modalidades de cumulação de pedidos:

- Cumulação comum ou simples



Há cumulação comum ou simples quando o demandante formula mais de um pedido no mesmo processo, e entre estes pedidos há independência, podendo um ser acolhido e o outro não. Ex.: indenização por danos morais e materiais. Poderá tanto um quanto o outro ou os dois serem acolhidos. O valor da causa, no caso de cumulação simples, será a soma de ambos os pedidos.

- **Cumulação sucessiva**

Na cumulação sucessiva há uma relação de dependência entre os pedidos, de modo que o acolhimento do pedido principal pressupõe o do pedido sucessivo. Ex.: autor pleiteia o reconhecimento de inexistência de uma dívida, e sucessivamente que a instituição seja condenada ao pagamento de danos morais em razão de um protesto realizado com base neste suposto débito indevido. Se o juiz declarar que o débito inexistente, cabe a indenização por danos morais, razão pela qual, acolhendo um acolherá o outro.

Por outro lado, se disse que o débito existia, não é possível acolher o dano moral.

Com isso, verifica-se que há uma relação de prejudicialidade, ou seja, há uma ordem hierárquica entre o pedido principal e o pedido sucessivo.

- **Cumulação eventual ou subsidiária**

Na cumulação eventual ou subsidiária, o autor/reconvinte apresenta um pedido primário e outro subsidiário, estabelecendo uma ordem de preferência entre eles, de modo que, se o pedido primário for acolhido, o pedido subsidiário não será apreciado. Vê-se, portanto, que apenas um será acolhido.

O valor da causa será o do conteúdo econômico do pedido principal.

Não existe a necessidade de se aplicar a exigência de que os pedidos sejam compatíveis entre si. Isso porque, quando falamos de cumulação eventual ou subsidiária, só haverá a apreciação de um se o outro for julgado improcedente.

- **Cumulação alternativa**

Na cumulação alternativa, o demandante apresenta dois pedidos com a pretensão de que o juiz acolha apenas um deles. Nesse caso, não haverá uma ordem de preferência, ficando a escolha a cargo do julgador.

O valor da causa será o do conteúdo econômico do maior pedido.

Não confunda pedido alternativo com cumulação alternativa. No **pedido alternativo**, previsto no art. 325 do CPC, há um pedido único que pode ser prestado de diversas formas. Há a possibilidade de a obrigação de direito material ser satisfeita por mais de uma maneira. Nesse caso há o pedido alternativo e não cumulação alternativa. Por exemplo, se “A” ingressar com o feito pedindo a anulação do contrato ou a redução da vantagem da outra parte, haverá cumulação alternativa.

No caso de pedido alternativo, “A” contrata uma pessoa para pintar a casa, mas o sujeito não foi. Logo, ele ingressa com o feito, pedindo que o juiz fixe multa, ou mande outro indivíduo para pintar a casa, às custas do demandado, ou transferindo dinheiro para pagar, etc. Veja, a pretensão de direito material pode ser cumprida de diversas formas.

2.1.4. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

A indicação do valor da causa **deve corresponder ao proveito econômico que o demandante pretende obter** e deve ser fixada ainda que a demanda não tenha conteúdo patrimonial.

O artigo 292 do CPC estabelece as regras de fixação do valor da causa, que devem ser observadas pelo autor no momento da propositura da demanda.

Nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se determinará o recolhimento das custas correspondentes.

O réu poderá impugnar o valor atribuído à causa em sede de preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Caso seja acolhido pelo juiz, o autor deverá complementar as custas.

2.1.5. INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE SE PRETENDE PRODUZIR

O autor deve indicar, ainda, na petição inicial as provas que pretende produzir no decorrer da instrução processual. Para a doutrina, basta a indicação genérica de todos os meios de prova em direito admitidos para que esse requisito seja atendido. Detalhe, em se tratando de processo de execução, não se faz necessária tal indicação, visto que não há produção de provas nessa fase.

2.1.6. INDICAÇÃO DA OPÇÃO PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO

Em regra, a audiência de conciliação e mediação será obrigatória. Cabe ao demandante informar expressamente ao juízo se tem ou não interesse na realização de tais atos processuais.

Lembrando que **na conciliação alguém conduz a autocomposição e na mediação são as partes que se autocompõem**.

Atente-se que esta audiência, seja de conciliação ou de mediação, só não se concretizará quando **ambas as partes (autor e réu) tiverem peticionado afirmando expressamente seu desinteresse**, ou quando o direito litigioso não permitir esta solução consensual. Desta feita, havendo na petição inicial o requerimento de sua realização, a manifestação do réu em sentido contrário não surtirá qualquer efeito.

2.1.7. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PATRONO E ASSINATURA

A petição inicial deverá conter, ainda, o endereço do patrono (físico e eletrônico) e assinatura. Lembrando que deverá ser instruída com a procuração.

De acordo com o art. 287, parágrafo único, do CPC, a procuração poderá ser dispensada nos seguintes casos: **i) para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente**, hipóteses em que o advogado deverá exibir o referido instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz; **ii) se a parte estiver representada pela Defensoria Pública; iii) se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei**.

2.1.8. FORMA DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial poderá ser escrita ou oral, no caso desta última, deverá ser reduzida a termo, como é o caso dos Juizados Especiais Cíveis.

2.2. PROPOSITURA DA AÇÃO E SEU JUÍZO INICIAL

A petição inicial será **registrada**, se for num juízo único, ou será **distribuída**, quando houver mais de um órgão jurisdicional competente.

2.2.1. DISTRIBUIÇÃO

A distribuição ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, o qual **deverá ser alternado e aleatório**, a fim de permitir a observância e obediência ao princípio do juízo natural.

O modo de distribuição poderá ser **livre** ou **dirigido**, sendo esse último denominado de distribuição por dependência.

Na **distribuição livre** poderá cair em **qualquer juízo**.

Na **distribuição por dependência**, não. Isso porque já há uma distribuição vinculada, sendo direcionada a determinado juízo.

São **hipóteses de distribuição por dependência**:

- **Quando entre os processos existir vínculo de conexão ou continência**

Se entre o novo feito e o feito antigo há conexão ou continência, será distribuído por dependência ao juízo que já está prevento.

- **Quando o processo primitivo tiver sido extinto sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda**

Do contrário, poderia haver violação ao juízo natural.

- **Quando houver ajuizamento de ações idênticas, sendo prevento o juiz que tramita a ação anterior.**

Este juízo extinguirá a nova demanda por litispendência ou coisa julgada.

O art. 290 do CPC vai dizer que a petição inicial, para ser distribuída, **deverá vir acompanhada do recolhimento das custas**. Se ausente o recolhimento, deverá a parte ser intimada (na pessoa de seu advogado) para que, em 15 (quinze) dias, regularize esta situação. Do contrário, haverá o **cancelamento da distribuição**.

Apesar da expressão “cancelamento da distribuição”, há uma sentença terminativa, isto é, sem resolução do mérito. Neste caso, caberá recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, admitindo-se juízo de retratação.

Caso o sujeito proponha um novo feito, deverá ser distribuído ao mesmo órgão, pois ele está prevento.

A parte, seu procurador, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão fiscalizar a distribuição. Caso haja algum erro ou, até mesmo, a falta de distribuição, o juiz corrigirá de ofício ou a requerimento do interessado.

Cumprе salientar, por fim, que nas demandas em que houver intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

2.2.2. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL

Emendar é corrigir. Em atenção ao aproveitamento dos atos processuais e aos princípios da efetividade e economia processual, o art. 321 do CPC autoriza que o magistrado determine a emenda da petição inicial no **prazo de 15 (quinze) dias, quando constatar que ela não observa os requisitos do art. 319**, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Trata-se de um direito subjetivo do autor, e não mera faculdade do juiz. Deste modo, é nula a sentença que indefere a petição inicial sem que o juiz permita a correção do vício sanável.

A autoridade judiciária, na sua decisão para que seja emendada a petição inicial, já **deve indicar o ponto que deve ser corrigido**, em consonância com os deveres da prevenção e de esclarecimento decorrentes do princípio da cooperação. Isso ocorrerá quando o vício encontrado comportar emenda. Do contrário, se for **vício extremamente grave, poderá, desde logo, indeferir a petição inicial**, devendo, neste caso, ouvir o autor previamente (art. 330).

Se, mesmo após dar ao autor a oportunidade de emendar a petição inicial, persistir vício que determinou a emenda, o juiz indeferirá a petição inicial sem determinar a citação do réu.

2.2.3. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

O indeferimento da petição inicial poderá ocorrer de forma **total**, hipótese em que a parte poderá interpor o recurso de apelação (art. 331 do CPC), ou **parcial**, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento (art. 354 do CPC).

São **hipóteses de indeferimento da petição inicial** enumeradas exemplificativamente no art. 330 do CPC:

- **Petição inicial for inepta;**

São várias as formas em que a petição poderá ser considerada inepta ou não apta para provocar a jurisdição, como, por exemplo, quando não tiver pedido; não tiver causa de pedir; contiver pedido indeterminado fora das hipóteses admitidas; quando dos fatos narrados não decorrer da conclusão; pedido juridicamente impossível ou incompatíveis entre si; quando o autor não discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter.

- **Ilegitimidade das partes;**

- **Ausência de interesse processual;**

- **Não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.**

Frise-se que as situações acima mencionadas são **matérias de ordem pública**, portanto, podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Indeferida a petição inicial ou julgado liminarmente improcedente o pedido, pode o juiz se retratar, no prazo de 05 (cinco) dias, se interposta apelação contra a sentença. Ressalte-se, contudo, que o órgão judicial não exercerá o juízo de retratação, ainda que reconheça erro em sua sentença, na hipótese de recurso interposto intempestivamente.

Cuidado para não confundir **inépcia** da petição inicial com **indeferimento**, pois as hipóteses de inépcia estão relacionadas a defeitos estruturais da petição inicial (art. 330, §1º), o que pode resultar no indeferimento da peça exordial (art. 330, *caput*). Conforme se extrai do art. 330 do CPC, toda hipótese de inépcia é uma hipótese de indeferimento, mas nem toda hipótese de indeferimento é uma hipótese de inépcia.



2.2.3. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR

O art. 332 autoriza que o magistrado sentencie liminarmente o processo, resolvendo o mérito, **antes mesmo de citar o requerido**, mas desde que se trate de uma **sentença de improcedência** e que se dispense a etapa instrutória (produção de provas).

Na verdade, essa improcedência liminar **é um caso de tutela de evidência**, prestada em caráter definitivo, fazendo coisa julgada material, visto que **é evidente a falta do direito alegado pelo demandante**.

O indeferimento da inicial se dará por sentença processual ou terminativa (art. 485, I, do CPC) e poderá ocorrer nos seguintes casos:

- Quando o **pedido contrariar enunciado de Súmula do Supremo Tribunal Federal ou Súmula do Superior Tribunal de Justiça**;
- Quando o **pedido contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos**;
- Quando o **pedido contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência**;
- Quando o **pedido contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local**;
- Quando o pedido **estiver prescrito ou já estiver operado a decadência do direito do autor**;

Veja que, nos casos de julgamento total, será cabível o **recurso de apelação**, no prazo de 15 (quinze) dias, admitindo o juízo de retratação pelo juiz, no prazo de 05 (cinco) dias. Todavia, o indeferimento poderá ser parcial, hipótese em que a parte deverá interpor agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC).

2.4. DESPACHO LIMINAR DE CONTEÚDO POSITIVO

Não sendo caso de improcedência liminar do pedido, de indeferimento da petição inicial ou de saneamento da inicial, o juiz irá proferir **despacho liminar de conteúdo positivo**, ocasião em que determinará a citação do demandado.

No entanto, pode ser que este despacho liminar de conteúdo positivo tenha **natureza de decisão interlocutória**.

Caso, no momento em que o juiz defere a inicial, também analise um requerimento, como, por exemplo, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em caráter provisório, haverá uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento.

O art. 240, §1º, do CPC, em conjunto com o art. 208, I, do CC, estabelecem que este ato proferido pelo magistrado (despacho liminar de conteúdo positivo) tem o condão de **interromper a prescrição**.

3. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Esse estudo é dividido em dois grupos:

- **Citação e intimação**;



- **Cartas.**

3.1. CITAÇÃO

O art. 238 do CPC diz que citação é o ato pelo qual são convocados o **réu**, o **executado** ou o **interessado** para integrar a relação processual.

Trata-se de um **pressuposto de validade do processo**, conforme estabelece o art. 239 do CPC. O processo não deixa de ser instrumento. Por conta disso, tal dispositivo afirma que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, **ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido**.

E o § 1º do aludido dispositivo dispõe que **o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação**, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

3.1.1. TEORIA DA APARÊNCIA

O art. 242 do CPC diz que **a citação será feita pessoalmente ao réu**, podendo ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

A teoria da aparência ganha relevância nos casos de réu pessoa jurídica. O que vem sendo admitido é a realização da citação na pessoa do funcionário que exteriorize poder de gestão ou de decisão no dia a dia das atividades empresariais.

A teoria da aparência traz a ideia de que, **ainda que este funcionário, no estatuto, não detenha poderes para receber uma citação, se ele age e se exterioriza como tal, então é considerada válida a citação daquela pessoa jurídica.**

No caso da citação via postal o CPC admite expressamente que seja assinado pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. **Se quem recebe a citação é pessoa que aparentemente tem poder para recebê-la, em caso de pessoa jurídica, ainda que formalmente não tenha esse poder, valerá a citação.** Visa coibir a fraude.

3.1.2. SITUAÇÕES EM QUE A CITAÇÃO NÃO PODE SER REALIZADA

Em regra, a citação pode ser realizada em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Não precisa, necessariamente, ser cumprida no endereço indicado na petição inicial, o importante é que o citando tome ciência do ato.

O militar em serviço ativo será citado **na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado**.

São **hipóteses em que não poderá ser realizada a citação**, salvo para evitar o perecimento do direito:

- A quem estiver participando de ato de **culto religioso**;
- Ao cônjuge, companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em 2º grau, **no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes**;
- Aos **noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento**;
- Os **doentes, enquanto grave o seu estado**.



A legislação prevê, ainda, que a citação não será feita quando se verificar que o citando é **mentalmente incapaz** ou está impossibilitado de recebê-la, oportunidade em que o oficial de justiça deverá certificar minuciosamente a ocorrência. Nesse caso, o juiz nomeará um médico para examinar o citando, devendo o aludido profissional apresentar um laudo no prazo de 05 (cinco) dias. Tal providência será dispensada se a família de quem deve receber a citação apresentar declaração do médico que o acompanha atestando sua incapacidade.

Devidamente reconhecida a impossibilidade de a pessoa mentalmente incapaz receber a citação, será nomeado curador especial, a quem incumbirá a defesa de seus interesses. Essa nomeação deve observar a preferência estabelecida em lei.

Se o citando já tiver sido interditado, a citação será feita na pessoa de seu curador.

3.1.3. MODALIDADES DE CITAÇÃO

É preciso diferenciar dois grupos de citação, a citação pessoal/real e a citação ficta. A diferença está no fato de que na **citação pessoal** o réu é efetivamente citado, enquanto na **citação ficta**, presume-se que ele tenha sido citado.

Outra diferença reside na ausência da manifestação do demandado após ele ter sido citado. **Se a citação é pessoal, é gerado o efeito da revelia, restando autorizado o julgamento antecipado do mérito**, conforme previsto no art. 355, II, CPC, caso em que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, desde que não haja requerimento de prova.

Quando há a citação ficta, há a presunção de que o réu/executado/interessado tenha sido citado, situação que **não vai motivar o julgamento antecipado do mérito** e sim **a nomeação de um curador especial, o qual apresentará defesa, sem ônus da impugnação especificada**. Nesse caso, o curador especial poderá apresentar **contestação por negativa geral**, hipótese em que os fatos alegados pelo autor não serão considerados presumidamente verdadeiros.

i. Citação pelo correio

A citação pela via postal é uma citação pessoal e é a modalidade preferencial. Será utilizada sempre a parte não requeira ou a lei não exija outra forma.

O artigo 247 do CPC enumera exceções à citação pelo correio, quais sejam:

- Ações de estado (são aquelas que envolvem discussão de direitos indisponíveis do estado da pessoa);
- Quando o citando por incapaz (tanto o incapaz civil – absoluto ou relativo – quanto aquele que não tem discernimento para compreender o conteúdo escrito da correspondência – como o analfabeto);
- Quando o citando for pessoa de direito público (as empresas públicas e as sociedades de economia mista não são abrangidas em tal conceito por possuírem personalidade jurídica de direito privado);
- Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência.

Nas hipóteses acima descritas, a citação se concretizará por intermédio de oficial de justiça.

A citação também não ocorrerá pelo correio quando o autor, de forma justificada, requerer que seja feita de outro modo.

O art. 248 vai dizer que, **determinada a citação postal, cabe ao serventuário remetê-la com cópia reprográfica da petição inicial e do despacho do juiz que autorizou esta citação**. Nesta

remessa feita pelo serventuário, já vai comunicar o **prazo de resposta**, bem como o **endereço do juízo**.

No caso do **procedimento comum**, o mandado de citação indicará a **data e o horário da audiência de conciliação ou mediação**.

A **Súmula 429** do STJ vai dizer que a **citação postal, quando determinada por lei, exige o aviso de recebimento**.

Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário está ausente.

De acordo com o enunciado n. 85 da Jornada de Direito Processual Civil do CJF, “na execução de título extrajudicial ou judicial (artigo 515, §1º, do CPC) é cabível a citação postal”.

ii. Citação por oficial de justiça

A citação pode se dar por oficial de justiça **nas hipóteses em que é proibida a citação postal**, conforme mencionado em linhas volvidas. Também poderá ser feita a citação por oficial de justiça quando a citação postal **tiver sido frustrada** ou **mesmo quando houver dúvida se foi o próprio demandado quem assinou o AR, ou se foi outra pessoa**.

Nesse caso, o cartório emitirá um mandado de citação e o oficial cumprirá este mandado.

Ao chegar no local, o oficial promoverá a leitura do mandado de citação e a entrega ao demandado de uma contrafé (cópia da petição inicial), sendo a partir de então considerada realizada a citação. Nas ações de família, o mandado de citação deverá estar desacompanhado da contrafé, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

A citação por oficial de justiça será realizada em **dias úteis, entre 6 horas e 20 horas**, podendo ocorrer no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário acima, independentemente de autorização judicial.

iii. Citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório

A citação poderá ser feita pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório.

É uma modalidade de citação pessoal.

iv. Citação por meio eletrônico

A citação, inclusive da Fazenda Pública, será realizada por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Busca-se aprimorar a economia processual.

Nos termos do artigo 246, §1º, do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

v. Citação por edital

A citação por edital é espécie de **citação ficta**, não sendo citação real/pessoal. Exige o esgotamento dos outros meios de citação.

A citação por edital poderá ser realizada nas hipóteses autorizadas por lei, quais sejam:

- **Desconhecido ou incerto o demandado;**
- **Incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que o demandado se encontra;**
- **Nos demais casos previstos e autorizados em lei.**



No primeiro caso, o demandado é realmente desconhecido pelo demandante. Ex.: ações possessórias derivadas de invasões de terra.

No segundo caso, sabe-se quem é o demandado, mas não se sabe o lugar em que ele está, ou se tal lugar é inacessível. A doutrina enumera duas espécies de inacessibilidade: **a) jurídica/política** – quando o réu está em país que não cumpre ou se recusa a cumprir carta rogatória; **b) física/geográfica** – o réu se encontra em local fisicamente inacessível, ocasião em que a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Lembre-se que no **Juizado Especial não cabe citação por edital**.

A terceira hipótese pode se dar, por exemplo, no caso da lei de execução fiscal, que prevê que **o executado, quando residente no exterior, deve ser citado por edital**. Esta interpretação legal vem sendo mitigada, ao ponto de o STJ ter sumulado tal entendimento através do **enunciado n. 414**, em que estabelece **ser a citação por edital cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades**.

O STJ diz que é preciso homenagear a ampla defesa e o contraditório, de maneira que se sabe onde está e quem é o executado, deve-se citá-lo de modo pessoal. Apenas quando frustradas estas tentativas é que se fará a citação por edital.

É permitido ao autor requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos com o intuito de obter informações sobre o endereço do demandado, podendo responder ao pagamento de multa, equivalente a cinco vezes o valor do salário mínimo vigente, quando agir dolosamente, sendo esta revertida em benefício do citando.

A citação por edital se dará por meio da publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos.

Pode, ainda, ser determinada a publicação de editais em jornal local de ampla circulação. **O prazo dos editais vai variar entre 20 e 60 dias**, depois de escoado tal prazo é que terá início o prazo para que, o agora citado, apresente a sua resposta.

Caso não apresente resposta nesse lapso temporal, a citação, que é considerada ficta, **não gerará o efeito da revelia, devendo o juiz nomear um curador para apresentar resposta sem o ônus da impugnação especificada**.

vi. Citação por hora certa

A citação também poderá ser por hora certa, sendo também **espécie de citação ficta**.

Caberá citação por hora certa quando o oficial tiver comparecido ao endereço do demandado em **2 (duas) oportunidades**, não o encontrando e tendo uma suspeita de que ele está se ocultando para não ser citado. Nesses casos, caberá ao oficial retornar no dia seguinte, ou marcar uma data, a fim de voltar pela terceira vez, situação na qual irá intimar alguém da família ou vizinho, deixando lá a cópia da petição inicial.

Nota-se, portanto, que a citação com hora certa pressupõe dois requisitos: **1º)** ter o oficial já procurado o citando e não o encontrado por duas vezes (**requisito objetivo**) e **2º)** suspeitar que o citando esteja se ocultando, maliciosamente, para não ser citado (**requisito subjetivo**).

O oficial deverá anotar na certidão os dias e os horários em que esteve presente no local indicado no mandado, sob pena de nulidade do ato citatório.

No caso da citação por hora certa, há ainda a necessidade de que o servidor do judiciário expeça uma carta registrada, com destino ao citando, para informar tudo o que aconteceu.

O prazo para o sujeito apresentar a resposta será o primeiro dia útil seguinte à juntada do mandado cumprido pelo oficial de justiça, e não o da expedição da carta ou da juntada do aviso de recebimento desta.

Sendo certo que o demandado foi citado por hora certa, situação em que não apresentou resposta, neste caso, como se trata de citação ficta, **o juiz irá nomear curador especial para apresentar resposta sem o ônus da impugnação especificada.**

3.1.4. EFEITOS DA CITAÇÃO

A citação pode apresentar **efeito processual** (litispendência) e também **efeitos materiais** (tornar a coisa litigiosa, constituir o devedor em mora e interromper a prescrição), que podem ser gerados mesmo que o juízo que a tenha determinado seja incompetente.

A **litispendência** diz respeito à impossibilidade de que coexistam processos com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, de modo que, havendo citação válida em um deles, não poderão prosseguir os demais em juízos diferentes.

Para a doutrina, **a coisa ou direito sobre o qual se litiga torna-se litigioso** com a citação válida do réu, considerando que para o autor a coisa já possui essa característica desde a propositura da demanda.

Em regra, **a citação constitui o devedor em mora**, contudo, há exceções, como, por exemplo, nas obrigações positivas e líquidas (artigo 397, *caput*, do CC) e nas obrigações provenientes de ato ilícito (artigo 398 do CC).

A citação válida produz, ainda, a interrupção da prescrição, cuja eficácia interruptiva do despacho que a determina retroage ao momento da propositura da ação.

Com a citação ocorre, também, a estabilização subjetiva da demanda, restando formada a relação autor-juiz-réu. A partir de então, o autor só poderá modificar a causa de pedir e o pedido caso o réu consinta com o aditamento, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de quinze dias.

3.1.5. CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE CITAÇÃO OU NULIDADE DA CITAÇÃO

Inicialmente, convém destacar a distinção existente entre falta de citação e nulidade da citação. A **falta de citação** é o caso em que o sujeito não foi citado, enquanto na **nulidade da citação** ele foi citado, mas o ato não foi válido. O processo em que a citação for inexistente ou nula está maculado de um vício.

O vício consubstanciado na falta de citação ou em sua nulidade poderá ser arguido na fase de conhecimento, contestação, impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, inclusive de ofício.

Ainda que a sentença tenha sido proferida ou tenha transitado em julgado formando, assim, a coisa julgada material soberana (ou coisa soberanamente julgada) é possível que a validade do processo seja questionada, visto que há uma mácula insanável. Nesse caso, eventual ausência de citação poderá ser discutida no bojo de uma ação declaratória de nulidade (**querela nullitatis**).

3.2. INTIMAÇÃO

O art. 269 do CPC diz que intimação é o **ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo** para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Para alguns, a intimação é a ciência de um ato que já aconteceu e notificação é a ciência de um ato que irá ocorrer. Porém, a legislação não traz essa diferenciação.

Pode ser dirigida tanto à parte como a um terceiro (perito, testemunha, etc.).

A regra é que a intimação se dê pela publicação no diário oficial, mas pode ocorrer por meio eletrônico, pelo correio, por oficial de justiça, inclusive com hora certa, por edital, por termo nos autos ou **pelo próprio magistrado**, caso se dê na presença das partes e dos respectivos advogados, considerando que foram intimados desde já.

Em determinados casos, a legislação autoriza que a intimação se materialize com o encaminhamento dos próprios autos, como ocorre quando o órgão intimado é o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Nesses casos, há **intimação pessoal**.

O art. 272, §1º, do CPC, prevê a possibilidade de os advogados requererem que a intimação a eles dirigida seja feita em nome da sociedade a que pertençam, **desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil**.

As **intimações devem conter os nomes das partes e de seus advogados**, sendo vedada abreviaturas ou que seja dirigida tão somente ao advogado/sociedade sem fazer referência às partes.

3.3. CARTAS

São meios de comunicação de atos processuais que se estabelecem entre os órgãos do Judiciário. Podem ser de quatro espécies, conforme o órgão para a qual for dirigida a solicitação: carta precatória, carta de ordem, carta arbitral e carta rogatória.

3.3.1. CARTA PRECATÓRIA

A carta precatória se faz presente quando **um juízo requer a outro juízo de igual hierarquia que seja cumprida uma decisão**. Isso ocorre pelo fato de que o primeiro juízo (deprecante) não tem competência territorial para atuar naquela localidade (deprecado). É uma forma de **cooperação nacional**, dentre diversas outras formas.

A comunicação via carta precatória se dará por meio físico ou por meio eletrônico, sendo imprescindível que ela seja instruída com as peças processuais necessárias para o atendimento da diligência requerida.

As questões decididas pelo juízo deprecado serão bem limitadas, visto que a competência é do juízo deprecante. No entanto, apesar da limitação, o juízo deprecado poderá decidir certas questões relativas ao cumprimento da carta precatória.

Se o objeto da carta precatória for a produção de prova e esta for imprescindível à resolução do mérito, o juízo deprecante não poderá julgar a causa sem que o instrumento tenha retornado, devendo, nesse caso, determinar o sobrestamento do processo até a sua devolução.

Este sobrestamento poderá se dar pelo prazo de **até 1 (um) ano**, a fim de que seja cumprida a carta precatória no juízo deprecado.

Atente-se que há uma **suspensão imprópria** do processo, pois ele continua em trâmite. Isto é, a carta precatória faz parte do processo e ela está sendo cumprida, ou seja, parte dos autos continua em andamento.

A carta precatória **poderá ser dispensada**, quando se tratar de um ato que será praticado numa **localidade contígua** ou **naquelas que compõem a mesma região metropolitana**.

3.3.2. CARTA DE ORDEM

A carta de ordem **decorre da hierarquia entre o órgão que determina a prática do ato e aquele que vai cumpri-la**. O juízo deprecado não poderá recusar cumprimento à carta. Isso porque a carta é de ordem. Ex.: juiz determina ao órgão de primeira instância que cumpra a medida.

3.3.3. CARTA ARBITRAL

A carta arbitral é a carta do árbitro.

O objetivo é dar cumprimento à decisão proferida pelo árbitro, pois este não possui poder de efetivação de suas decisões, podendo buscar o poder judiciário para adoção dos meios executivos, com o objetivo de satisfazer determinada obrigação.

3.3.4. PEDIDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: AUXÍLIO DIRETO E CARTA ROGATÓRIA

O pedido de cooperação internacional pode ser realizado de duas formas:

- **Auxílio direto:** modalidade adequada para atos que não necessitam de prestação jurisdicional.
- **Carta rogatória:** é o pedido de cooperação oriunda de um país, com destino a outro país. Neste caso, serve para o cumprimento de medida judicial. Seria uma espécie de carta precatória entre países diferentes.

O art. 27 irá enumerar de forma exemplificativa as medidas que podem ser objeto de cooperação jurídica internacional:

- Citação
- Intimação
- Notificação (judicial ou extrajudicial)
- Colheita de provas
- Homologação de decisão
- Cumprimento de decisão
- Concessão de medida judicial de urgência
- Assistência jurídica internacional
- Qualquer ato judicial ou extrajudicial, desde que não vedado pela legislação brasileira

i. Auxílio direto

Auxílio direto ocorre quando o pedido de cooperação **não tenha por objeto uma decisão judicial estrangeira que esteja sujeita a um juízo de delibação** feita pela autoridade brasileira. O auxílio direto é típico de medidas de cunho administrativo/extrajudicial.

O art. 29 do CPC diz que a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. A autoridade central é o Ministério da Justiça.

Caso não esteja claro, poderá a autoridade central pedir esclarecimentos antes de decidir.

O art. 30 da lei processual traz um **rol das hipóteses que poderão ser caso de auxílio direto**:

- Auxílio direto para obtenção e prestação de **informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso**;
- Auxílio direto para **colheita de provas**, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira;
- **Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.**

ii. Carta rogatória

A carta rogatória necessita passar por um filtro **feito pelo Superior Tribunal de Justiça**, situação na qual concede o *exequatur*. Nesta situação **será necessário um juízo de delibação**.

Neste caso, um juiz federal dará cumprimento a esta carta rogatória na primeira instância. Após, encaminhará ao STJ, o qual emitirá o envio à autoridade central (Ministério da Justiça).

4. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

4.1. INTRODUÇÃO

De acordo com o artigo 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

O réu será intimado para comparecer à audiência no mesmo ato que se der a citação. **Somente após a frustração de tentativa de solução consensual do conflito é que se inicia o prazo para que ele apresente a sua resposta.** Por sua vez, o autor será intimado na pessoa de seu advogado.

Tanto a conciliação como a mediação demandam a presença de um terceiro.

Caso o terceiro conduza o diálogo, haverá uma **conciliação**. Se a postura do terceiro se limita apenas a apartear o diálogo entre os envolvidos, será apenas um **mediador**.

O pagamento do conciliador ou do mediador é, inicialmente, suportado pelo demandante.

O art. 165 do CPC estabelece que os Tribunais criarão centros judiciários para solução de conflitos responsáveis por realizar audiência de conciliação e de mediação.

O art. 166 traz a regra que impõe a **confidencialidade de todas as informações produzidas no procedimento, não podendo ser utilizada para outros fins**, impondo sigilo ao conciliador, mediador e para equipe envolvida.

O CPC ainda proíbe que conciliadores e mediadores exerçam advocacia no juízo que desempenhem suas atividades. Isso por conta de impedimento e moralidade. Além dessa restrição, **conciliadores e mediadores não podem assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes que tenham participado de uma audiência que tiver conciliado ou mediado.** Este impedimento **perdura por 1 (um) ano.**

O mediador não pode ser advogado no mesmo juízo que atuou como conciliador ou mediador, nem **mesmo ser advogado de uma parte que ele tenha feito a conciliação ou mediação, em qualquer juízo, dentro do prazo de 1 (um) ano.** A ideia é se buscar a imparcialidade do conciliador e do mediador.

É possível que as partes, de comum acordo, escolham o conciliador ou o mediador. O trabalho desenvolvido por eles poderá ser remunerado por meio de uma tabela fixada pelo Tribunal, sendo possível, também, o trabalho voluntário.



O art. 174 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos **no âmbito administrativo**. Trata-se de **desjudicialização do direito administrativo**. É a possibilidade de autocomposição dos conflitos no âmbito da administração pública.

4.2. PROCEDIMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

O art. 334 estabelece que a audiência de conciliação e mediação só **não ocorrerá se as partes (autor e réu) manifestarem expressamente seu desinteresse**. Deste modo, o autor informará na petição inicial que não possui interesse na solução consensual do conflito, assim como o demandado também o fará, por simples petição, até 10 (dez) dias antes da data fixada para a audiência, caso contrário, o ato será realizado. Havendo litisconsórcio, a não realização da audiência depende da manifestação de desinteresse de todos os litisconsortes.

Dispensa-se, ainda, a audiência de conciliação e mediação nas hipóteses em que o **direito material não admita autocomposição**.

Se uma das partes deixar de comparecer, injustificadamente, à audiência de conciliação ou mediação, tal comportamento será considerado um **ato atentatório à dignidade da justiça**, passível de sanção processual, representada por multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, cujo credor será a União ou o Estado.

O CPC permite que a parte constitua um representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir, para comparecer ao ato em seu lugar.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Obtida a solução consensual, o processo será encaminhado ao juiz para que prolate uma sentença definitiva, estando encerrado o processo, fazendo, inclusive, coisa julgada material.

Se, por outro lado, não houver composição, **começará a correr o prazo, de 15 (quinze) dias, para que o demandado apresente resposta**.

4.3. CASUÍSTICA ENVOLVENDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA

João propõe uma ação perante o juízo incompetente. O réu é devidamente intimado para comparecer ao ato. Nesse caso, seu comparecimento é obrigatório? Caso não compareça estará sujeito a multa por ato atentatório à dignidade da justiça?

Nos termos do art. 340 do CPC, alegada a incompetência do juízo, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, oportunidade em que será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação.

5. RECONHECIMENTO DO PEDIDO OU INÉRCIA

5.1. INTRODUÇÃO

Realizada a citação do demandado, poderá ele realizar diferentes comportamentos, tais como, apresentar resposta ou reconhecimento de procedência do pedido, ou até mesmo ficar inerte, podendo gerar revelia.



5.2. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Uma vez citado, o demandado poderá constituir advogado e peticionar nos autos pelo reconhecimento de procedência do pedido.

Nesse caso, o juiz deverá julgar conforme o estado do processo, prolatando sentença resolvendo o mérito, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido.

No caso de reconhecimento parcial de procedência do pedido, o magistrado poderá desde logo proferir um julgamento antecipado parcial do mérito, sendo constituído imediatamente um título executivo judicial, **permitindo ao credor executar o devedor daquela parcela incontroversa.**

5.3. AUSÊNCIA DE RESPOSTA (REVELIA)

Citado o demandado, caso não responda à demanda ou responda intempestivamente, poderá ser considerado revel. Nota-se, portanto, que revelia nada mais é do que a ausência jurídica da contestação na forma e tempo devidos. Tal comportamento gera três efeitos, quais sejam:

a) presunção de veracidade ou confissão ficta: os fatos alegados pelo autor serão reputados verdadeiros, não vinculando, contudo, a fundamentação jurídica exposta na petição inicial, ou seja, a presunção de veracidade é relativa, pois não incide sobre o direito da parte, mas sobre a matéria de fato;

b) julgamento antecipado do pedido, caso o réu não se faça representar nos autos a tempo;

c) desnecessidade de intimação, hipótese em que os prazos contra o revel fluirão a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial.

Conforme o art. 345 do CPC, não haverá o efeito material da revelia quando houver **pluralidade de réus e algum deles contestar a ação;** quando o **litígio versar sobre direitos indisponíveis;** quando a **petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato,** a despeito da resposta do réu; quando **as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.**

Vale destacar que o demandado revel poderá intervir no feito em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar.

5.4. DIFERENÇA ENTRE CONTUMÁCIA, REVELIA E ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DA PROVA

A **contumácia** é estado de inércia de qualquer das partes. Equivale a contumácia à uma desobediência deliberada, ou em estar presente ou atender a uma deliberação judicial.

A **revelia** é uma espécie de contumácia, ou seja, é a inércia do demandado, que não apresenta sua contestação no prazo legal.

Quanto ao **ônus da impugnação especificada da prova** diz respeito ao dever de o demandado rebater, por ocasião da sua contestação, todos os fatos afirmados pelo demandante, pontualmente, de modo que, os fatos não impugnados, serão tidos como verdadeiros.

O ônus da impugnação especificada é aplicado a qualquer das partes do processo e não só ao demandado. Não se aplica, todavia, ao advogado dativo, curador especial e ao defensor público, pois estes podem apresentar contestação por negativa geral.



Pode acontecer de a peça de defesa do réu levantar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nesse caso, o juiz deverá abrir vista ao demandante para que ele apresente réplica. Neste momento, o autor deverá impugnar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos trazidos pelo réu.

5.5. REVELIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA

Via de regra, não há revelia em desfavor da Fazenda Pública, pois atua em juízo na defesa de direito indisponível. Portanto, o efeito material não seria gerado na Fazenda Pública.

5.6. REVELIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Como se sabe, o sujeito promove uma execução por título extrajudicial. Os embargos à execução permitem que haja um novo processo, sendo processo de conhecimento.

Porém, se o embargado, que é o demandado nos embargos à execução, não apresentar resposta, não haverá revelia. **O fundamento é que o embargado já tem presunção que lhe favorece, visto que tem um título executivo extrajudicial.**

6. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA

6.1. CONTESTAÇÃO

6.1.1. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Contestação é a modalidade de resposta por excelência, permitindo a apresentação tanto de defesa de cunho processual como defesas de cunho material.

O **prazo** para apresentação da contestação é de **15 (quinze) dias**, cujo termo inicial será contado da seguinte forma:

- Da audiência de conciliação/mediação quando não houver composição;
- A partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação/mediação, que deverá ser apresentado até dez dias antes da data designada, se houver litisconsórcio passivo, o prazo para apresentação da contestação de cada um terá início na data do respectivo protocolo da petição (lembrando que todos devem se manifestar pela não realização do ato);
- Quando **não** for o caso de audiência de conciliação, a contagem do prazo será realizada conforme as regras previstas no artigo 231 do CPC, se houver litisconsórcio, o prazo terá início a partir da data da última juntada do mandado de citação ou do aviso de recebimento.

Caso o autor desista de um litisconsorte que ainda não foi citado, não sendo caso de audiência de conciliação/mediação, o prazo para apresentação de resposta terá início na data da intimação da decisão que homologar a desistência (art. 335, §2º, CPC).

Nos casos em que houver **requerimento de tutela provisória de urgência cautelar**, a **contestação deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação.**

6.1.2. QUESTÕES PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Questões preliminares são **matérias defensivas que são apresentadas pelo demandado no início da sua contestação**. Estão previstas no artigo 337 do CPC.

Preliminar é uma **defesa de cunho processual** e pode trazer uma **matéria de cunho dilatório ou de cunho peremptório**.

A defesa será **dilatatória** quando o seu acolhimento não acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, se o demandado alegar falta ou nulidade da citação, incompetência do juízo, incorreção do valor da causa, incapacidade da parte, defeito de representação, indevida concessão da gratuidade da justiça, tudo isso será matéria de cunho processual **dilatatório**, pois em qualquer dessas o processo continuará a sua tramitação. Atente-se que estas matérias poderão perder o cunho dilatório se o problema não for solucionado.

Por conseguinte, a defesa processual será peremptória quando puder acarretar a extinção do processo sem a resolução do mérito. São matérias de defesa de cunho **peremptório** a alegação de inépcia da inicial, perempção, litispendência ou coisa julgada material, existência de convenção de arbitragem, ilegitimidade da parte ou falta de interesse processual.

Todas estas matérias processuais serão consideradas como **objeções**, ou seja, que podem ser conhecidas de ofício, **com exceção da convenção de arbitragem e incompetência relativa, eis que não podem ser conhecidas de ofício**.

O CPC permite que o réu alegue a sua ilegitimidade passiva e, se o demandante concordar com a alegação do réu, a petição inicial será emendada para a exclusão do demandado primitivo e para inclusão do demandado que se mostrou adequado. **Nesse caso, a ilegitimidade da parte não implicará a extinção do processo**.

O demandado que alega a sua ilegitimidade, deverá declinar na sua contestação, apresentando quem deveria ter sido citado para figurar no polo passivo em seu lugar, sob pena de o próprio demandado arcar com as custas processuais e indenização ao autor.

No que diz respeito às questões prejudiciais, tratam-se de **qualquer matéria ou tema que o magistrado deverá enfrentar antes da resolução do mérito da causa**. Podem ocorrer no mesmo processo (homogênea) ou em processo distinto (heterogênea).

A **questão prejudicial homogênea** é **analisada nos próprios autos**, situação em que o próprio juiz faz a análise da questão (ex.: prescrição).

A **questão prejudicial heterogênea** (externa) é **analisada em outro processo**, sendo necessário aguardar este outro processo para que então o primeiro possa ser decidido. Por exemplo, “A” ingressa com uma ação de alimentos, enquanto “B” ingressa com uma ação negatória de paternidade. Se ficar provado que “B” não era o pai, esta ação vai determinar o destino da ação de alimentos. Veja, é uma questão prejudicial heterogênea (externa).

6.1.3. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE

Segundo o princípio da eventualidade, também denominado de princípio da concentração de defesa (art. 336 do CPC), **o demandado deverá alegar na contestação todas as matérias de defesa**.

Esta regra comporta exceções, ou seja, situações em que o réu poderá apresentar matéria defensiva mesmo após sua contestação:

- Quando se tratar de uma **matéria de ordem pública**, podendo o juiz conhecê-la de ofício;
- Quando se tratar de **direito superveniente**;

- Quando houver **expressa autorização legal** no sentido de que o sujeito poderá apresentar a tese defensiva após a contestação.

6.1.4. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS

Possui previsão no artigo 341 do CPC e consiste no ônus que o réu tem de rebater pontualmente todos os fatos narrados na petição inicial, não podendo apresentar sua resposta de forma genérica, sob pena de os fatos não impugnados serem presumidos verdadeiros, com **exceção** do defensor público, advogado dativo e curador especial, que podem apresentar defesa por negativa geral.

Embora essa seja a regra, a lei prevê hipóteses em que não se aplica a presunção de veracidade ainda que os fatos não tenham sido impugnados de forma individual, quais sejam:

- Fatos a cujo respeito não se admite a confissão (direitos indisponíveis);
- Petição inicial desacompanhada de instrumento público que a lei considere da substância do ato (por exemplo, certidão de casamento, certidão de óbito);
- Fatos que estejam em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

6.2. RECONVENÇÃO

A reconvenção corporifica o exercício do direito de ação. **Um novo direito de ação é exercido.**

A reconvenção **inaugura uma nova relação jurídica processual dentro dos mesmos autos**, trazendo novos fatos e uma nova pretensão. Todavia, estes fatos trazidos são conexos aos fatos constantes na petição inicial ou na contestação.

A reconvenção não é acessória, de forma que, ainda que o demandante primitivo desista da ação originária, a reconvenção continua e será julgada.

Não impede os efeitos primários (materiais) e secundários (processuais) da revelia, mas **excepcionalmente** será possível que a causa de pedir da reconvenção seja um fato, que se alegado na contestação, constituiria uma **defesa de mérito indireta**.

A reconvenção se baseia num fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. E, nesse caso, o sujeito se vale desse fato conexo da petição inicial, a fim de promover uma cobrança na reconvenção.

6.2.1. DISTINÇÃO ENTRE RECONVENÇÃO, PEDIDO CONTRAPOSTO E AS AÇÕES DÚPLICES

A **reconvenção** decorre do exercício do direito de ação. Cria uma nova relação jurídico-processual nos mesmos autos. O reconvinte pode trazer novos fatos, desde que conexos àqueles constantes da petição inicial ou contestação.

Por sua vez, o **pedido contraposto**, embora seja uma forma de exercício do direito de ação, só é deduzido nas hipóteses autorizadas em lei e no próprio corpo da contestação. Também deverá ser com base nos mesmos fatos alegados pelo autor. Isto é, o pedido contraposto não autoriza a inserção ou a introdução dos novos fatos conexos à contestação ou à petição inicial. Ele se baseia nos mesmos fatos. Também é autônomo em relação à demanda primitiva, de modo que se for extinta a demanda originária não impede a análise do pedido contraposto. A Lei n. 9.099/95 veda a reconvenção e permite o pedido contraposto.

Já as ações dúplices são ações em que, se o pedido for julgado improcedente, há um benefício ao réu. Em outras palavras, o demandado poderá ter o reconhecimento do seu direito a partir da improcedência da ação exercida pelo demandante, sem exercer o direito de ação. Demandas declaratórias são essencialmente ações de caráter dúplice, se não é reconhecido o que o autor pleiteia ser declarado, é forçoso convir que há uma declaração em benefício do réu.

6.2.2. PROCESSOS E PROCEDIMENTO QUE ADMITEM A RECONVENÇÃO

Reconvenção é o instrumento utilizado **apenas em processo de conhecimento** que observa o procedimento comum.

A reconvenção não é cabível na execução.

Só haverá procedimento especial admitindo reconvenção quando eles possam ser convertidos em processos que obedecem ao rito comum. Ex.: na **ação monitória**, se o sujeito apresenta contestação, se tornará rito comum.

A **Súmula 292 do STJ** diz que “a reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário”. E esse é o sentido do art. 700, §6º, do CPC.

Outro procedimento que admite reconvenção é o da **ação rescisória**. Isso porque se trata de procedimento especial que admite conversão em procedimento comum.

Em suma, caberá reconvenção quando:

- houver uma ação pendente;
- o juízo da causa principal for competente para julgar a reconvenção;
- entre a ação principal e a reconvenção houver compatibilidade entre os procedimentos.

6.2.3. PROCEDIMENTO NA RECONVENÇÃO

A reconvenção **deve ser apresentada na mesma peça da contestação**. Recomenda-se que venha num capítulo próprio da peça. É possível, todavia, que o réu apresente tão somente a reconvenção, hipótese em que será considerado revel.

Nesta petição da reconvenção **deverá constar o valor da causa**, por se tratar de um direito de ação, sendo o prazo para seu oferecimento de **15 (quinze) dias**, que é o prazo coincidente da contestação, **devendo ser exercida no mesmo momento da peça contestatória**.

Quanto à **legitimidade** da reconvenção, **só poderá ser apresentada pelo demandado originário em face do demandante primitivo**.

Excepcionalmente, vem sendo admitido que outra pessoa figure num dos polos da reconvenção, como é o caso do litisconsórcio necessário, permitindo que haja o alargamento de um dos polos, subjetivamente falando.

Quando uma das partes primitivas estiver sendo substituída processualmente (substituto processual), a reconvenção é possível?

SIM, desde que na reconvenção também seja possível a substituição processual. Neste caso, claramente é possível apresentar a reconvenção em substituição processual, contanto que a reconvenção revele uma pretensão contra o substituído e não contra o substituto. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.

Ao analisar a peça da reconvenção, o juiz deverá apreciar se deve ser indeferida de plano ou não. Caso indefira de plano, haverá decisão interlocutória, cabendo **agravo de instrumento**.

Se o juiz entender que deve ser deferida a reconvenção, o reconvindo **será intimado na pessoa de seu advogado (demandante da ação originária)**.

Intimado o reconvindo, apresentará a sua resposta também no prazo de 15 (quinze) dias.

Existe uma **discussão** se seria possível que o reconvindo pudesse oferecer a **reconvenção da reconvenção**. Há quem defenda que não, pois se fosse autorizado, por via oblíqua, estaria admitindo uma emenda à inicial, visto que inseriria novos pedidos não incluídos na inicial. Além disso, causa enorme prejuízo à marcha processual.

Vale dizer que o CPC, quando disciplina o procedimento monitório, veda expressamente a reconvenção da reconvenção.

Uma vez apresentada a defesa do reconvindo, o juiz determinará o prosseguimento do processo e, ao final, prolatará uma sentença para a demanda originária juntamente com a reconvenção.

Destaca-se que a extinção/desistência da ação principal não obsta o julgamento da reconvenção, pois não há autonomia entre elas.

7. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Apresentada a contestação, dá-se início à fase ordinatória, oportunidade em que o juiz deve verificar se é necessária a adoção de alguma providência preliminar. Há quatro hipóteses de providências preliminares:

a) réu revel nos casos de não aplicação do efeito material da revelia: o juiz deve intimar o autor para que ele especifique as provas que pretende produzir. Lembrando que, ainda que o réu seja revel, ele também poderá requerer a produção de provas, desde que ingresse no processo antes da instrução;

b) réu apresenta contestação com alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor: há, nessa situação, uma alegação de defesa indireta de mérito, devendo o autor ser intimado para que se manifeste/apresente réplica no prazo de 15 (quinze) dias;

c) réu alega preliminar de mérito disposta no artigo 337 do CPC: ocorrerá a mesma providência acima elucidada, devendo o autor ser intimado para que se manifeste/apresente réplica no prazo de 15 (quinze) dias;

d) juiz verifica a existência de vícios sanáveis: a parte deve ser intimada para que corrija o vício em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

Adotadas tais providências ou não sendo o caso de qualquer delas, o juiz verifica se o processo comporta julgamento.

7.1. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO NO SENTIDO DA EXTINÇÃO

Após a fase de apresentação da petição inicial e resposta do réu, o juiz deverá analisar se é possível **sentenciar o processo no estado em que se encontra, julgando-o nos termos dos artigos 485 e 487, incisos II e III, ambos do CPC**. Trata-se de consagração ao princípio da economia processual.

7.2. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DO PROCESSO

Não confundir o julgamento conforme o estado do processo com o julgamento antecipado do mérito do processo. **Para o julgamento antecipado do mérito é necessário que antes tenha havido a citação do demandado.**

E isso vai diferenciar o julgamento antecipado do mérito da denominada improcedência liminar (art. 332 do CPC). No julgamento antecipado do mérito há a possibilidade de, inclusive, se julgar procedente o pedido, e na improcedência liminar dispensa-se a citação, visto que o pedido será julgado improcedente.

Será cabível o julgamento antecipado do mérito do processo nas seguintes hipóteses:

- Quando não houver necessidade de produção de outras provas;
- Quando houver revelia, produzindo o seu efeito material, e não houver requerimento de prova.

De acordo com o enunciado n. 297 do FPPC, “o juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”.

7.3. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO

O art. 356 do CPC admite que o julgamento antecipado seja parcial do mérito **através de uma decisão interlocutória**, sendo possível nos casos de pedidos contrapostos e nos casos em que é permitido o julgamento por ter havido parcela incontroversa (não houve impugnação especificada dos fatos) ou que parte daqueles fatos não demanda produção de provas. Trata-se de hipótese de julgamento fracionado de mérito.

Em suma, segundo o art. 356 do CPC, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

- Mostrar-se incontroverso (a decisão pode reconhecer a existência de obrigação ilíquida);
- Estiver em condições de imediato julgamento, quando não houver necessidade de produção de outras provas e quando houver revelia, produzindo o seu efeito material, e não houver requerimento de prova.

O credor fica autorizado a promover a liquidação ou execução da parcela que já foi julgada em autos apartados, desde logo, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. O processo seguirá com relação à parcela litigiosa do pedido.

Ainda se reconhece no CPC que **esta decisão do julgamento antecipado parcial do mérito, apesar de ser uma decisão interlocutória, produz coisa julgada material**. Isso porque enfrenta o mérito com cognição exauriente, ainda que seja parcial.

Nos termos do enunciado n. 125 da Jornada de Direito Processual Civil do CJF, “a decisão parcial de mérito não pode ser modificada senão em decorrência do recurso que a impugna”.

A despeito de formar coisa julgada material em virtude de uma análise de cognição exauriente, da decisão interlocutória parcial do mérito caberá **agravo de instrumento**.

7.4. SANEAMENTO DO PROCESSO

O saneamento do processo se materializa mediante uma decisão interlocutória.

O objetivo do saneamento é:



- Resolver as questões processuais que estão pendentes;
- Fixar os pontos controvertidos;
- Definir a distribuição do ônus da prova;
- Determinar quais as provas a serem produzidas;
- Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Lembrando que a legislação permite que haja **convenção entre as partes para fins de saneamento do processo**, levando ao juiz para que homologue este saneamento.

Outra regra pontual é a previsão da **possibilidade de audiência de saneamento em conjunto**, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito.

CAPÍTULO 11 — PROVAS

1. PROVAS

Prova é todo elemento ou todo instrumento previsto ou não em lei, capaz de demonstrar a veracidade de algum fato ou de alguma situação jurídica que interessa a solução do litígio. É como se convence alguém de como o fato ocorreu.

Tem como finalidade influenciar eficazmente na convicção do juiz.

1.1. CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS

As provas podem ser classificadas em:

1.1.1. PROVAS TÍPICAS E ATÍPICAS

- **Provas típicas:** são aquelas expressamente previstas no CPC. Ex.: depoimento pessoal das partes, prova pericial, etc.
- **Provas atípicas:** são provas não positivadas no CPC. Podem ser empregadas por não serem ilícitas. Ex.: exibição de um vídeo em audiência, inspeção *in loco* realizada pelo oficial de justiça, etc.

1.1.2. PROVAS ILÍCITAS

Provas ilícitas são as **provas produzidas em violação ao ordenamento jurídico, em desconformidade às normas constitucionais ou infraconstitucionais**. A vedação das provas ilícitas está prevista na Constituição, não se podendo admitir no processo qualquer prova obtida por meio ilícito.

Lembrando que **não apenas a prova ilícita deve ser desconsiderada, mas também a prova que surgiu** como decorrência dela. É a aplicação da **teoria dos frutos da árvore envenenada**. Apesar da não previsão legal no CPC, surge da decorrência lógica da vedação constitucional das provas ilícitas.

1.1.3. PROVAS INDICIÁRIAS/INDIRETA

São provas que **não têm expressa previsão no CPC**. Trata-se de uma **prova que é obtida através de indícios**. Por vezes, a prova vai recair sobre fatos que não são os que o magistrado tem que analisar.

A prova vai recair sobre outros fatos, os quais irão permitir que o juiz faça um raciocínio indutivo, a fim de chegar à conclusão de que uma das partes está afirmando. Não é regulada pelo CPC.

1.1.4. PROVA EMPRESTADA

É possível que uma prova produzida em um processo seja aproveitada em outro, mas, para tanto, é necessário que tenha sido observado o contraditório tanto na origem quanto no destino.

O art. 372 do CPC passa a admitir expressamente o uso da prova emprestada, que é uma prova que se junta no processo judicial, podendo ter sido produzida num processo judicial ou mesmo num processo administrativo.

Para o STJ, não é necessário que as partes do processo de destino sejam as mesmas do processo de origem.

A prova emprestada receberá do direito processual civil o tratamento de uma **prova documental**.

1.1.5. PROVA DE FORA DA TERRA

A prova de fora da terra, apesar do nome, é a prova produzida num juízo de outra base territorial, distinta da base em que tramita o processo.

Quando uma prova é produzida por meio de carta precatória, por exemplo é ouvida uma testemunha em outra comarca, há uma prova de fora da terra (da terra do juízo).

1.1.6. PROVA DIABÓLICA

Prova diabólica é aquela que **se faz presente nos casos em que a produção da prova é impossível**, ou então é **extremamente difícil para a parte que alegou aquele fato**.

Isto é típico de fato negativo. Por exemplo, João não apareceu no escritório no dia X. Como comprovar que João não compareceu nesse dia, se o escritório não tem câmera?

Neste caso, o próprio João poderá comprovar que não compareceu ao escritório, pois é mais fácil para ele comprovar o fato positivo do que para a outra parte comprovar o fato negativo.

1.2. OBJETO DA PROVA

A prova vai recair sobre **fatos relevantes**, os quais normalmente são pretéritos. A parte tem o objetivo de demonstrar ao magistrado que aquele fato efetivamente ocorreu.

Se a **tutela é inibitória**, que é aquela que visa impedir que alguém venha a fazer algo, o objeto da prova deverá recair sobre os **atos preparatórios ou fatos que indicam que há uma intenção de praticar o ilícito**.

O objeto da prova também pode recair sobre atos normativos, apesar de isso ser pouco comum. O CPC autoriza que o juiz possa exigir prova da existência e da vigência de lei municipal, lei estadual, lei estrangeira ou mesmo de normas decorrentes de costumes.

1.3. FATOS QUE INDEPENDEM DE PROVA

Existem alguns fatos que não precisam ser provados:

- **Fatos notórios** (ex.: dia 7 de setembro era feriado);
- **Fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;**
- **Fatos admitidos no processo como incontroversos;**
- **Fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.**

No caso de fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, a parte tem uma postura ativa, enquanto no caso de fatos admitidos no processo como incontroversos a parte tem uma postura passiva.



Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as chamadas máximas de experiência, salvo quanto à experiência técnica, o exame pericial.

1.4. ETAPAS PARA A PRODUÇÃO DA PROVA

As provas podem ser determinadas **de ofício** pelo magistrado. E isso não retira a sua imparcialidade.

São etapas para a produção da prova:

- **Requerimento da prova;**
- **Deferimento da prova;**
- **Produção da prova.**

Nem sempre será necessário passar por cada uma dessas fases, como é o caso da prova documental. A parte requer a produção de prova documental, mas caso deferida é produzida num único momento.

Em relação ao **requerimento para produção de prova**, via de regra **deverá constar da petição inicial e já da contestação**. O juiz deferirá as provas, via de regra, na decisão de saneamento. Sendo deferidas, as provas serão produzidas.

Sendo uma prova oral, ela será realizada numa audiência de instrução e julgamento.

Sendo uma prova pericial, será realizada, provavelmente, no local do evento, mas pouco provável em juízo.

1.5. CRITÉRIOS PARA A VALORAÇÃO DA PROVA

Existem três grandes sistemas de valoração da prova, sendo eles: sistema legal, sistema da íntima convicção e sistema da persuasão racional.

Para o **sistema legal**, também conhecido como **sistema da prova tarifada**, as provas possuem um valor predeterminado, ou seja, a carga probatória é estabelecida pelo próprio legislador, cabendo ao juiz tão somente aplicá-la. Via de regra, não é adotado, mas encontra respaldo em alguns pontos do CPC, como, por exemplo, o artigo 406, que diz que quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.

Para o **sistema da íntima convicção**, o juiz possui ampla liberdade, sendo desnecessário motivar sua decisão. É possível nesse sistema que o juiz se valha de situação extra-autos para formar sua convicção. Não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro por violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual impõe a fundamentação das decisões judiciais.

Como se sabe, o sistema adotado no Brasil é o da **persuasão racional** ou do **livre convencimento motivado**, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Nota-se, portanto, que a prova não pertence à parte que a produziu e sim ao processo, é o **princípio da comunhão das provas**.

1.6. ÔNUS DA PROVA

O ônus da prova é a incumbência de provar. **Via de regra, é estático**, conforme o art. 373.



Isso porque **competete ao demandante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo** de seu direito e **incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo** do direito do autor.

Todavia, o CPC adota expressamente a **possibilidade de o ônus da prova ter caráter dinâmico** quando prevê que a prova deverá ser produzida pela parte que tem maiores condições de produzi-la, independentemente de ter sido esta parte requerente ou não da medida.

Existem três espécies de inversão do ônus da prova: i) **convencional** – decorre de um acordo de vontades entre as partes, que poderá ocorrer antes ou durante o processo; ii) **legal** – prevista em lei; iii) **judicial** – o juiz inverterá o ônus da prova no caso concreto.

1.6.1. DISTINÇÃO ENTRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DISPENSA DO ÔNUS DA PROVA

Na **inversão do ônus da prova**, o juiz determina que uma das partes produza a prova do fato alegado pela outra parte.

Na **dispensa do ônus da prova**, o juiz dispensa o demandante de produzir a prova dos fatos alegados. Se o demandado quiser produzir prova em contrário, poderá fazê-lo. É o que ocorre no artigo 12, §3º, c/c art. 14, §3º, ambos do CDC, quando diz que o fabricante ou fornecedor somente não serão responsabilizados quando demonstrarem que não colocaram o produto no mercado.

1.6.2. MOMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Até que momento é possível que o magistrado promova ou defira a inversão do ônus da prova? Até o saneamento do feito? Até o momento da sentença?

É possível a inversão do ônus da prova **até o saneamento do processo**, com base no contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o art. 373, §2º, CPC (**regra de procedimento**). A decisão de inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, ou seja, ao magistrado é vedado realizar a inversão do ônus na própria sentença, pois tornaria impossível a incumbência do encargo pela parte.

1.6.3. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ

No caso de prova determinada de ofício pelo juiz, terá o ônus de arcar com os custos o **demandante**.

1.7. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Produção antecipada de provas é a **prova produzida antes do momento em que ela normalmente seria produzida**. Materializa-se pela propositura de uma **ação probatória autônoma**.

A **competência** para produção antecipada de provas é concorrente, sendo, via de regra, do **juízo do foro em que a prova deva ser produzida** ou do **juízo do foro do domicílio do réu**, conforme art. 381, §1º, do CPC.

O órgão jurisdicional onde esta produção antecipada de provas tramitar **não fica prevento** para eventual demanda posterior (art. 381, §2º, CPC).

O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

São **hipóteses** em que se admite a produção antecipada de provas:



- Quando houver **fundado receio de que essa prova venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação** (ex.: testemunha com 99 anos e internada).
- Quando a **prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição** ou outro meio adequado de solução de conflito;
- Quando o **prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação**.

O processamento da produção antecipada de provas seguirá o CPC com a **possibilidade de requerer outras provas não discriminadas na petição inicial**.

O magistrado **não se pronuncia sobre fatos que não sejam objetos de prova e nem sobre as consequências jurídicas do fato**. Ele apenas preside a instrução para que a prova seja produzida.

Tanto é que é vedado o oferecimento de defesa ou de recurso neste procedimento, salvo se o juiz indeferir a produção antecipada de provas. Para a doutrina, a vedação a interposição de recurso, em especial, a vedação a interposição de apresentação de defesa, não se aplica a questões cognoscíveis de ofício – matérias de ordem pública, que podem ser alegadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Produzida a prova, **os autos da produção antecipada de provas são entregues ao requerente**.

1.8. PROVAS EM ESPÉCIE

1.8.1. ATA NOTARIAL

Ata notarial é uma ata ou certidão lavrada pelo tabelião. Pode estar representada por uma imagem ou som que ateste a existência ou modo de existir de determinado fato. Tem **peso relativo**.

1.8.2. DEPOIMENTO PESSOAL

Depoimento pessoal é a colheita em juízo das declarações de uma das partes principais do processo (demandante ou demandado).

O depoimento pessoal é **realizado na audiência de instrução e julgamento**. Se houver urgência poderá ser prestado em sede de produção antecipada de prova.

A parte poderá se recusar a depor em juízo. Neste caso, o juiz deverá interpretar a recusa como confissão. O mesmo vai acontecer se a parte deixar de comparecer à audiência de instrução em julgamento, ou se o depoente deixou de apresentar respostas ou foi evasivo. **Nestes casos, o juiz entenderá que houve confissão** (art. 386).

O depoimento pessoal da parte que residir em outra comarca ou seção judiciária, **poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real**, podendo ocorrer durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

A parte deverá responder pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo utilizar de escritos preparados, **permitindo-se a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos**.

O depoente **não é obrigado a depor sobre:**

- **Fatos criminosos ou torpes que lhe sejam imputados** (direito a não autoincriminação);

- Fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo;
- Fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível;
- Fatos que coloquem em perigo a vida do depoente ou de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível.

Cabe ressaltar que estes casos **não se aplicam às ações de estado e de família.**

1.8.3. CONFISSÃO

Confessar é admitir a ocorrência de um fato contrário ao interesse próprio em favor à outra parte.

A confissão, que será **judicial** ou **extrajudicial**, ocorre quando **a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.**

A confissão judicial pode ser **espontânea** ou **provocada**:

- **Confissão espontânea:** pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial.
- **Confissão provocada:** constará do termo de depoimento pessoal.
- **Confissão judicial:** ocorrida nos próprios autos. Faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.
- **Confissão extrajudicial:** ocorre fora do processo. Quando feita **oralmente**, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal.
- **Confissão simples:** é a confissão comum.
- **Confissão qualificada:** é aquela em que o réu confessa o fato, mas apresenta a defesa de mérito direta. Isto é, ele confessa os fatos, mas nega os efeitos pretendidos pelo demandante.
- **Confissão complexa:** é aquela confissão em que o réu reconhece os fatos, mas argui um outro fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Há uma defesa de mérito indireta.

No caso de confissão na seara judicial ou na seara extrajudicial, deverá ser realizada **pela própria parte** ou **por mandatário com poderes especiais**.

Nas ações que versarem sobre **bens imóveis** ou **direitos reais sobre imóveis alheios**, a **confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro**. A confissão valerá se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens.

A confissão **não pode prejudicar os demais litisconsortes**, independentemente da natureza do litisconsórcio, seja unitário, simples, necessário ou facultativo.

A confissão também **não pode ser admitida quando ela se referir a fatos relacionados a direitos indisponíveis**, conforme art. 392 do CPC.

A confissão será **ineficaz** se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. **A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.**

A confissão é **irrevogável**, mas pode ser anulada se decorreu de **erro de fato** ou de **coação**.



A legitimidade para a ação é **exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura**.

O art. 395 do CPC diz que **a confissão é, em regra, indivisível**. Isto é, a parte não pode invocar a confissão como meio de prova num tópico que a beneficia e rejeitá-la num tópico que a prejudica. Entretanto, é possível que a confissão aborde mais de um fato, sendo possível que em relação a um dos fatos seja verdadeiro e em relação a outro não admita.

1.8.4. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Qualquer parte pode requerer ou o juiz pode determinar a exibição, de ofício, de um documento ou uma coisa que se encontre com qualquer um dos litigantes ou que estejam em poder de uma terceira pessoa.

Na hipótese de **requerimento** cabe ao demandante demonstrar:

- **Individuação** do documento ou da coisa;
- **Finalidade da prova**, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
- **Circunstâncias em que se fundamentam a afirmação de que o documento ou a coisa se ache em poder da parte contrária**.

Nada impede que a exibição de documento seja requerida pelo réu, ou seja, **tanto o autor como o réu podem requerer a exibição**.

Feito o requerimento, o juiz determinará que a parte contrária apresente a coisa ou documento, bem como se manifeste no prazo de **5 (cinco) dias**. Isso porque, **por vezes, a legislação autoriza que haja uma recusa**, situação na qual a parte irá se manifestar nesse sentido.

Após a apresentação da resposta, caberá ao magistrado determinar a intimação do requerente a fim de, em seguida, decidir.

O juiz **não admitirá a recusa** se o:

- Requerido tiver **obrigação legal de exhibir**;
- Requerido tiver **aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova**;
- **Documento for comum às partes**.

Supondo que a parte recuse apresentar o documento e o juiz entenda pela sua necessidade de exibição, bem como pela falta de justa causa na recusa, **o CPC autoriza que os fatos que o documento ou a coisa atestariam sejam considerados como verdadeiros**.

Desse modo, serão presumidos como verdadeiros os fatos quando:

- Requerido não exhibir e nem fizer nenhuma declaração no prazo de **5 (cinco) dias** da intimação;
- Recusar ilegitimamente a exibição.

Caso a coisa **não esteja em poder das partes**, mas sim em **poder de terceiros**, deverá haver a **emenda da inicial para que este terceiro seja incluído no polo passivo no prazo de 15 (quinze) dias**. Haverá um **litisconsórcio passivo necessário**.

Estando em **poder de terceiro**, e se o juiz entender que a recusa não é legítima, não tem como o juiz considerar legítima as alegações do autor contra o réu, visto que foi o **terceiro que se**

recusou. Nesta situação, o juiz determinará um mandado de apreensão, a fim de consolidar a medida.

A parte e o terceiro podem deixar de exhibir, em juízo, se o documento ou a coisa:

- For relacionado a **negócios da própria vida da família**;
- Puder **violar dever de honra**;
- **A publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro**, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, ou lhes representar perigo de ação penal;
- Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, **devam guardar segredo**;
- **Houver outros motivos graves** que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição;
- **Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição.**

Se os motivos da recusa disserem respeito a apenas uma parcela do documento, **a parte ou o terceiro exhibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado auto circunstanciado.**

1.8.5. PROVA DOCUMENTAL

Documento é toda e qualquer coisa, não necessariamente escrita, que representa um fato, podendo ser **público** (elaborado por oficial público sem o intuito de servir de prova, mas podendo, eventualmente, assim ser utilizado) ou **particular** (que não foi elaborado por oficial público, ou o foi, mas de forma irregular).

A prova documental **deve acompanhar a petição inicial ou a contestação**.

É lícito que o interessado traga aos autos, **em qualquer momento antes da sentença**, a prova documental.

i. Força probante dos documentos

O documento público faz prova:

- Da **sua formação** e;
- Dos **fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.**

Se a lei exigir **instrumento público** como da substância do ato, **nenhuma outra prova poderá suprir sua falta**. Vigora o princípio da prova tarifada nesse ponto.

O documento feito por **oficial público incompetente** ou **sem a observância das formalidades legais**, sendo subscrito pelas partes, terá a mesma eficácia probatória do documento particular.

As declarações de documento particular escrito e assinado ou somente assinado **presumem-se verdadeiras em relação ao signatário**. Todavia, **se contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si**, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

A **data do documento particular**, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, **poderá ser provado por todos os meios de direito.**

Em relação a terceiros, **será considerado datado** o documento particular:

- No dia em que foi registrado;

- Desde a morte de algum dos signatários;
- A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários;
- Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;
- Do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento.

Será considerado **autor do documento particular**:

- Quem o fez e o assinou;
- Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
- Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos.

Será considerado **autêntico o documento** quando:

- Tabelião reconhecer a firma do signatário;
- Autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico;
- Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

O documento de cuja autenticidade não se tem dúvida prova que o seu autor fez a declaração que a ele é atribuída.

O documento particular admitido expressa ou tacitamente é **indivisível**, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.

O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a **mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente**.

A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora.

O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário.

As **cartas** e os **registros domésticos** provam contra quem os escreveu quando:

- Enunciam o recebimento de um crédito;
- Contêm anotação que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor;
- Expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova.

O escrito pelo credor em qualquer parte de documento que expresse uma obrigação, ainda que não assinada, **faz prova em benefício do devedor**.

Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Se eles preencherem os requisitos exigidos por lei **provam a favor de seu autor no litígio entre empresários**.

A **escrituração contábil é indivisível** e, se dos fatos que resultam dos lançamentos uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.



O juiz pode ordenar, a **requerimento da parte**, a **exibição integral dos livros empresariais** e dos documentos do arquivo:

- Na liquidação de sociedade;
- Na sucessão por morte de sócio;
- Quando e como determinar a lei.

Neste caso, **o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos**, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.

Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem. Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.

As **reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões** sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original.

Terão o mesmo valor do original a **cópia de documento particular**, desde que **o escrivão**, intimadas as partes, **conferir e certificar** a conformidade entre a cópia e o original.

Fazem a **mesma prova que os originais**:

- **Certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria**, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;
- **Traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos** ou documentos lançados em suas notas;
- **Reproduções dos documentos públicos**, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais;
- **Cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado**, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;
- **Extratos digitais de bancos de dados públicos e privados**, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;
- **Reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular**, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Os originais dos **documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.**

Tratando-se de **cópia digital de título executivo extrajudicial** ou de documento relevante à instrução do processo, **o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.**

Sendo declarado falso, cessará a fé do documento público ou particular.

A falsidade consiste em:

- **Formar documento não verdadeiro;**
- **Alterar documento verdadeiro.**

Cessa a fé do documento particular quando:

- **Impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;**
- **Assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.**

Haverá abuso quando quem recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte completá-lo, violando o pacto feito com o signatário.

Incumbe o **ônus da prova**:

- **Falsidade de documento ou de preenchimento abusivo:** caberá à parte que a arguir a falsidade o ônus da prova;
- **Impugnação da autenticidade:** caberá à parte que produziu o documento alegar a falsidade.

ii. Arguição de falsidade

A falsidade **deve ser suscitada**:

- **Na contestação**
- **Na réplica**
- **No prazo de 15 (quinze) dias da intimação da juntada do documento aos autos.**

Arguida a falsidade, será resolvida como **questão incidental**, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. Nesse caso, a parte deverá expor os motivos que fundamentam a falsidade e os meios com que provará o alegado.

Após a oitiva da parte contrária no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o **exame pericial**. Não haverá perícia se a parte concordar em retirar o documento falso.

A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada.

iii. Produção da prova documental

Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Se o documento for produzido como **reprodução cinematográfica** ou **fonográfica**, a parte deverá trazer nos autos a sua exposição, a qual **será realizada em audiência**, intimando-se previamente as partes.

É **lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos**, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o princípio da boa-fé.

A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

- Impugnar a admissibilidade da prova documental;

- Impugnar sua autenticidade;
- Suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;
- Manifestar-se sobre seu conteúdo.

O réu se manifestará na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor se manifestará na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para impugnação.

Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

O juiz **requisitará às repartições públicas**, em qualquer tempo ou grau de jurisdição:

- Certidões necessárias à prova das alegações das partes;
- Procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou entidades da administração indireta.

Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 1 (um) mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes, e, em seguida, devolverá os autos à repartição de origem.

As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado.

1.8.6. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DO DOCUMENTO

A arguição de falsidade do documento deve ser apresentada na contestação (caso tenha sido apresentado na petição inicial), na réplica (caso tenha sido apresentado na contestação), ou mesmo em qualquer outra petição (caso tenha sido apresentado posteriormente), **desde que tenha sido apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do documento.**

O ônus da prova quanto à falsidade compete à parte que arguir a falsidade do documento, salvo quando a impugnação se referir à autenticidade do documento. Neste caso, competirá à parte que produziu o documento.

Após as manifestações das partes, haverá o exame pericial para averiguar a falsidade, salvo se a parte que está sendo acusada da falsificação concordar em retirar o documento dos autos.

Essa questão é decidida por **decisão interlocutória**, pois, via de regra, a decisão que encerra a arguição de falsidade de documento é interlocutória.

Todavia, **é possível que qualquer das partes requeira** que não seja analisada a questão da falsidade do documento sob o viés de uma questão prejudicial, mas sim **sob o viés de uma questão principal**, conforme previsão do art. 430, parágrafo único, do CPC. **Nesses casos, a declaração de falsidade passará a constar da parte dispositiva da sentença**, situação na qual será cabível **recurso de apelação**.

1.8.7. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Os documentos eletrônicos são disciplinados pelo CPC.

Impõe que seja necessária a forma impressa dos documentos eletrônicos, bem como a necessária certificação de sua autenticidade. Somente serão admitidos os que forem produzidos e conservados conforme a legislação específica (Lei n. 11.419/06).

1.8.8. PROVA TESTEMUNHAL

A prova testemunhal consiste na tomada do depoimento prestado por alguém que não é parte principal no processo.

A atuação da testemunha deve se limitar a informar se o fato ocorreu, como ocorreu, se ele não ocorreu, em que circunstâncias ocorreu.

A testemunha **não pode realizar um juízo de valor** dos fatos. Deve narrar os fatos.

Cada parte poderá arrolar até 10 (dez) testemunhas no processo. Se esta espécie de prova for deferida no saneamento do processo, as partes terão mais 15 (quinze) dias para que o rol seja apresentado, caso ele não tenha sido indicado anteriormente.

A lei processual civil permite que a **intimação de testemunha seja realizada diretamente pelo patrono da parte** (advogado), visando, assim, dar maior agilidade à intimação. No entanto, **a própria parte pode se comprometer a levar a testemunha em audiência, independentemente de intimação.**

Se a **parte se comprometeu** em levá-la, mas a **testemunha não compareceu ao ato**, essa ausência será interpretada como **desistência**.

Caso a testemunha tenha sido intimada, mas não compareceu, não haverá desistência, autorizando a expedição de um mandado de condução coercitiva.

O art. 447 do CPC **proíbe que sejam arroladas testemunhas incapazes** (interditadas, menores de 16 anos, etc.), bem como as **testemunhas impedidas** (ascendentes e descendentes das partes, etc.). Também não se permite a inquirição de **testemunhas suspeitas** (aquelas que têm algum interesse no litígio, amigo íntimo ou inimigo das partes, etc.).

Apresentado o rol de testemunhas, só é possível a substituição nos seguintes casos: i) quando a testemunha **falecer**; ii) quando **não estiver em condições de depor em razão de enfermidade**; iii) quando **não for encontrada em virtude de ter mudado de residência ou de local de trabalho**.

Durante a **audiência de instrução e julgamento**, o juiz seguirá a seguinte ordem:

- **Oitiva das testemunhas arroladas pelo autor;**
- **Oitiva das testemunhas arroladas pelo réu.**

Esta é a ordem, podendo ser alterada se as partes de comum acordo não se opuserem a isso.

Não sendo caso de impedimento, suspeição ou incapacidade da pessoa, o juiz vai exigir que a **testemunha preste o compromisso**, ou ainda na qualidade de informante, bem como advertirá à testemunha no sentido de que poderá incorrer no crime de falso testemunho.

São **hipóteses em que a testemunha poderá se silenciar**:

- Quando o seu depoimento puder gerar grave dano pessoal ou material a sua pessoa;
- Quando o seu depoimento puder gerar grave dano patrimonial ao seu companheiro, cônjuge ou a parente até 3º grau;
- Quando o fato a cujo respeito deva guardar sigilo ou por estado ou por profissão.

A oitiva da testemunha se dá através do **sistema *cross examination***. O advogado efetua pergunta diretamente à testemunha.

i. Incidente de recusa de prova testemunhal

O art. 457, §1º, CPC, autoriza que **qualquer das partes contradite a testemunha arrolada pela outra parte, arguindo incapacidade, impedimento ou suspeição**, por meio de petição ou oralmente, no momento imediatamente anterior à tomada de compromisso daquela testemunha.

Caberá ao juiz indagar a testemunha a respeito dessa condição. Se a testemunha concordar será dispensada ou ouvida na qualidade de informante.

Se a testemunha discordar da contradita, é possível que pessoa prove a contradita, seja por meio de **prova documental** ou **por meio de oitiva de até 3 (três) testemunhas** que tenham sido apresentadas no ato.

Finda a instrução, o juiz irá proferir uma **decisão interlocutória** para resolver a contradita.

1.8.9. PROVA PERICIAL

Prova pericial é a prova do perito, sendo uma prova essencialmente técnica, visto que exige conhecimento específico sobre o assunto em questão.

A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

No procedimento comum, cabe às partes requerer a produção da prova pericial, no momento oportuno, isto é, **até o momento do saneamento do feito**.

Deferida a produção da prova, as partes serão intimadas para indicar assistente técnico e arguir o impedimento ou suspeição do perito nomeado, podendo apresentar os **quesitos no prazo de 15 (quinze) dias**, os quais serão direcionados ao aludido profissional.

O perito não precisa prestar compromisso, mas a sua função e o seu encargo deve ser prestado escrupulosamente (art. 466 do CPC).

As partes serão **previamente intimadas** da data e do local em que será realizada a diligência para que possam acompanhá-la.

Feita a diligência, o perito deverá apresentar um laudo no prazo em que o juiz determinar, admitindo a prorrogação motivada.

Na hipótese de já ter sido designada uma audiência de instrução e julgamento, **o laudo deverá ser apresentado pelo perito com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência**.

Os **assistentes técnicos** irão apresentar os seus **pareceres no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do laudo** juntado aos autos.

Se for necessário algum esclarecimento, o perito será intimado para realizar o esclarecimento por escrito. Não sendo suficiente, será prestado em sede de instrução e julgamento.

O art. 478 do CPC disciplina que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, deixando claro que o sistema de provas adotado é o do livre convencimento motivado.

O art. 464, §§3º e 4º, do CPC, **consagram a possibilidade de o juiz determinar uma prova técnica simplificada**, para os pontos controvertidos que tiver deixado no saneamento do processo. Esta prova técnica simplificada consiste na **inquirição de um especialista em audiência**.

1.8.10. INSPEÇÃO JUDICIAL

A inspeção é judicial, ou seja, do juiz. Pode ser realizada de **ofício** ou a **requerimento da parte**, em qualquer fase do processo.

Sempre que for necessário, o magistrado deve fazer esta inspeção, deslocando-se para onde está a pessoa ou a coisa, quando não for possível apresentá-las em juízo sem grandes dificuldades, ou quando for ordenada a reconstituição dos fatos.

Muito comum é a inspeção realizada pelo oficial de justiça, quando o magistrado não puder comparecer. Trata-se de prova atípica, porém válida.

1.8.11. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS E USO DESTA PROVA NO PROCESSO CIVIL

Segundo a Constituição da República, o afastamento do sigilo, e, portanto, da interceptação dos dados telemáticos, só pode recair sobre comunicações telefônicas se estiverem presentes 3 (três) requisitos:

- Ordem judicial;
- Investigação penal ou instrução processual penal;
- Nas hipóteses em que a lei estabelece. A lei que regulamenta é a Lei 9.296/96.

Como se sabe, **essa prova poderá ser utilizada no processo civil, desde que a interceptação seja determinada no processo penal**, situação em que será anexada ao processo civil ou a processo administrativo, **na qualidade de prova documental**(prova emprestada).

2. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

2.1. CONCEITO

É um **ato processual complexo**, pois tem início com a tentativa de conciliação, seguida pela produção de prova, podendo ter as alegações finais orais da parte, e findando-se com uma sentença, hipótese em que poderá haver interposição de recurso.

O CPC permite que a audiência de instrução e julgamento seja realizada **nos dias úteis entre 6 horas e 20 horas**, com a ressalva de que esta audiência possa terminar após esse horário, desde que sua interrupção gere prejuízo ao ato ou dano grave que justifique sua continuidade a despeito de passar do horário.

A audiência de instrução e julgamento **deve ser considerada uma audiência una e contínua**. Desta forma, se houver a necessidade de prosseguimento em outra data, esta circunstância não implica nova audiência e sim continuação daquela que se iniciou.

O juiz é o responsável por presidir a audiência de instrução, exercendo, assim, poder de polícia.

2.2. PRINCÍPIOS INFORMATIVOS

São princípios informativos da audiência de instrução e julgamento:

- **Princípio da publicidade (art. 368):** todos os atos processuais devem ser públicos. Não se trata de um princípio pleno, pois poderão tramitar em segredo de justiça os processos que assim exigir o interesse público ou interesse privado relevante (casamento, filiação, separação, divórcio, alimentos, guarda de menores, etc.).



- **Princípio da concentração:** como dito, a audiência é una, devendo ser praticados todos os atos. Só poderá ser cindida em casos excepcionais.
- **Princípio da oralidade:** permite que os atos praticados durante a audiência de instrução e julgamento sejam realizados oralmente, embora haja a necessidade de redução a termo ou sua gravação.
- **Princípio da imediatividade:** esse princípio recomenda que a sentença seja proferida pelo juiz que tiver contato direto com a prova, eis que conhece melhor o processo.

2.3. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

É possível que se adie a audiência de instrução e julgamento por convenção das partes ou por qualquer outro motivo (ex.: ausência de comparecimento de uma das partes de forma motivada).

Segundo o CPC, a audiência poderá ser adiada:

- Por convenção das partes;
- Se qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar não puder comparecer, por motivo justificado;
- Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado (esse atraso não diz respeito ao atraso do término da audiência anterior).

Poderá ainda adiar a audiência de instrução e julgamento se um dos advogados não puder estar presente. Neste caso, bastará apresentar justificativa antes do ato, pois, do contrário, irá se realizar com a dispensa das provas requeridas pelas partes cujo advogado não se encontre presente no ato (art. 362, §2º, CPC).

2.4. ESTRUTURA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A audiência de instrução e julgamento tem início com o **pregão**, que é a chamada das partes, advogados e testemunhas, normalmente feito por oficiais de justiça.

Antes de iniciar a instrução, **o juiz tentará conciliar as partes.**

Não havendo a conciliação, passa-se diretamente à instrução.

Com relação à colheita de provas, o art. 361 do CPC diz que as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, **preferencialmente:**

- Esclarecimento do perito e dos assistentes técnicos, caso não respondidos anteriormente por escrito;
- Depoimento do autor e, em seguida, depoimento do réu;
- Oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.

Adota-se, como já frisado, o **sistema do cross examination**, que autoriza que as perguntas sejam realizadas diretamente pelos advogados das partes.

Após a instrução, as partes realizarão suas **alegações finais orais**, as quais serão reduzidas a termo. O prazo é de **20 (vinte) minutos** para cada parte, sendo possível **prorrogação por mais 10 (dez) minutos**, a critério do juiz.

Sendo caso de **litisconsórcio** ou **intervenção de terceiros**, o prazo para alegações finais orais será de **30 (trinta) minutos**, sendo **divididos igualmente** entre os litisconsortes ou entre os intervenientes e partes, salvo se dispuserem de forma diferente.

Pode ocorrer de a situação de fato ou de direito se mostrar de maior complexidade, hipótese em que o art. 364, §2º, do CPC, autoriza que as alegações finais orais sejam substituídas por memoriais escritos, fixando o juiz o **prazo de 15 (quinze) dias**, contados sucessivamente.

Em seguida, o juiz irá prolatar a sentença, que poderá ocorrer **imediatamente** (de forma oral) ou no **prazo de 30 (trinta) dias** (prazo impróprio).

Existem duas normas nos §5º e §6º do art. 367, CPC, que autorizam a gravação da audiência, seja por áudio seja por imagem, por meio digital, analógico ou análogo. Porém, é a previsão do §6º que causa certo receio na doutrina, pois **traz uma previsão que permite a gravação da audiência de instrução e julgamento por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial**.

Prolatada a sentença, é possível que a parte interponha o **recurso de apelação**.

Quanto às **decisões interlocutórias**, é possível que apresente **agravo de instrumento**, desde que se trate de hipótese prevista em lei.

3. SENTENÇA

3.1. CONCEITO

Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Diz respeito ao encerramento da fase de conhecimento ou do processo de execução, quer seja por uma decisão sem resolução de mérito (art. 485, CPC) ou com resolução de mérito (art. 487, CPC). Para um ou mais réus, a despeito de o juiz ter se pronunciado com base no art. 485, CPC, não há que se falar em sentença quando o processo não for encerrado como um todo. Tem-se, nesse caso, uma decisão parcial de mérito.

Nos procedimentos especiais é possível que haja uma sentença que não põe fim ao processo/fase de conhecimento, sendo possível, inclusive, que em um mesmo processo haja mais de uma sentença, é o que ocorre na ação de demarcação de terras particulares (art. 581 – 1ª sentença: traçado da área; e art. 587 – 2ª sentença: homologa a demarcação, ambos do CPC).

Estudado o conceito de sentença, o de decisão interlocutória dá-se por exclusão. Aquilo que tiver carga decisória, mas que não for sentença, ou seja, que não pôr fim à fase de conhecimento e nem extinguir a execução é uma **decisão interlocutória**, independentemente de resolver parte do mérito ou extinguir uma parte do processo sem resolução de mérito.

3.2. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

O CPC pontua qual é o conteúdo constante na sentença em seus artigos 485 e 487.

3.2.1. FUNDAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (COISA JULGADA FORMAL)

Nas hipóteses arroladas no artigo 485 do CPC há uma **sentença terminativa**, em que **não** há resolução do mérito e que gera **coisa julgada formal**. De acordo com esse dispositivo, o juiz não resolverá o mérito nos seguintes casos:

- Indeferimento da petição inicial;

- Quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias por não promover os atos e as diligências que lhe cabia. Atente-se que, neste caso, a lei impõe que o juiz determine a intimação pessoal da parte para que ela dê andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito.
- Quando verificar a ausência de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
- Quando verificar presença de pressupostos processuais negativos, os quais autorizam a reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
- Quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (lembre-se que se tratam de condições da ação);
- Quando acolher a alegação de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência (nesse caso, o juiz não poderá reconhecer de ofício);
- Quando o juiz homologar pedido de desistência formulado pelo demandante da ação (não se confunde com a renúncia, visto que gera apenas coisa julgada formal, ao contrário do reconhecimento do pedido);
- Em caso de morte da parte e a ação for considerada intransmissível por disposição legal (exemplo disso ocorre com o credor de alimentos que no curso do processo vem a falecer);
- Nos demais casos prescritos pela lei processual (exemplo é o cancelamento da distribuição em razão de o demandante não ter efetuado o pagamento das custas após a sua intimação para recolhimento).

3.2.2. FUNDAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (COISA JULGADA MATERIAL)

Prevista no art. 487, a sentença, nestes casos, estará acobertada pelo manto da **coisa julgada formal e material**. Haverá resolução de mérito quando:

- O juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
- O juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
- O réu reconhecer a procedência do pedido formulado pelo autor na ação ou na reconvenção (não se confunde com a confissão, visto que esta poderá não gerar procedência do pedido do autor; no caso do reconhecimento, o réu entende que o autor deverá ganhar a ação);
- As partes transigirem, situação em que o juiz homologará;
- O demandante renuncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

O CPC adota o **princípio da primazia da resolução do mérito**, visto que o juiz deverá se esforçar para possibilitar efetivamente a análise da pretensão material.

Quanto aos fundamentos que justificam a extinção do processo, tem-se, em regra, **sentenças terminativas** ou **sentenças definitivas**.

Em caráter excepcional, uma mesma sentença poderá ter um conteúdo terminativo e um conteúdo definitivo, nos casos em que o ato decisório possuir mais de um capítulo, como, por exemplo, quando o autor postular dois pedidos e o juiz julgar procedente apenas um desses pedidos e em relação ao outro reconhecer a ilegitimidade ativa.

3.3. ESPÉCIES DE SENTENÇA

a) Quanto às suas consequências, as sentenças podem ser:

- **Terminativas** (artigo 485 do CPC) e
- **Definitivas** (artigo 487 do CPC).

O que é sentença falsamente terminativa? Para Cândido Rangel Dinamarco, sentenças falsamente terminativas são atos decisórios que têm conteúdo definitivo, mas que por um grave equívoco do juiz, neles constam conteúdos terminativos. Por exemplo, o juiz reconhece que a parte é ilegítima e, portanto, extingue o processo sem resolução do mérito analisando o acervo probatório. Na questão de ilegitimidade *ad causam* deve ser levado em conta a teoria da asserção. Se o juiz está analisando prova há análise do mérito, de modo que esta sentença será falsamente terminativa.

Outro exemplo de sentença falsamente terminativa é o caso de uma sentença terminativa numa demanda em que há o reconhecimento da usucapião, mas a sentença diz que o autor não conseguiu demonstrar o lapso temporal para obter o reconhecimento do seu pedido e que, portanto, deverá ser extinto sem resolução do mérito. Veja, se o autor não conseguiu provar, deverá ser julgado improcedente o pedido. É falsamente terminativa.

Uma sentença falsamente terminativa é apta a fazer coisa julgada material, já que o conteúdo já analisou a pretensão de direito material após uma cognição exauriente.

b) Quanto ao seu conteúdo, leva-se em conta a natureza da pretensão de direito material que foi posta em juízo. Nesse sentido, há duas correntes doutrinárias que merecem destaque:

- **Classificação ternária;**
- **Classificação quinária.**

i) **Classificação ternária:** para essa classificação a sentença poderá ser **declaratória**, **constitutiva** ou **condenatória**.

Sentença declaratória é a sentença que julga procedente um pedido de natureza declaratória, visando eliminar o estado de incerteza ou de dúvida, com a declaração da existência ou inexistência de um direito. O pleito declaratório não está sujeito a prazo prescricional e nem a prazo decadencial. Esta sentença, uma vez proferida, possui duas características peculiares: não há necessidade de executar este pronunciamento judicial e só produzirá efeitos após o trânsito em julgado, inclusive com efeitos retroativos, pois só reconhecerá a existência ou inexistência do direito. Isso porque, caso haja a possibilidade de recurso, é possível que exista alguma dúvida. Por isso, é indispensável o trânsito em julgado.

Toda a sentença de improcedência possui natureza declaratória, pois declarará que o demandante não tem o direito alegado.

Em relação a **sentença constitutiva** haverá a criação, alteração ou extinção de uma relação jurídica de direito material. Via de regra, só produzirá efeitos após o trânsito em julgado, dispensando o cumprimento da sentença.

A diferença da sentença constitutiva para a sentença declaratória é que os efeitos produzidos pela primeira são ex nunc, ou seja, não retroagem, por exemplo, sentença que decreta o divórcio não retroage.

Por vezes a sentença constitutiva também poderá gerar efeitos antes do trânsito em julgado, quando a lei assim autorizar, como é o caso de sentença de interdição. A sentença de interdição produz efeitos imediatamente, ainda que interposto o recurso de apelação. O recurso contra a decisão que decreta a sentença de interdição tem efeito apenas devolutivo, não tendo efeito suspensivo.

A **sentença condenatória** é aquela em que o juiz impõe ao demandado uma obrigação, seja de fazer, não fazer, dar ou entregar um bem. A sentença condenatória, portanto, se não for cumprida voluntariamente, deverá ser executada. Costuma ter efeitos retroativos.

Em relação à eficácia, a sentença condenatória deverá ter eficácia imediata, independentemente do trânsito em julgado, visto que já é possível promover a execução provisória, caso o recurso de apelação não seja recebido com efeito suspensivo.

ii) Classificação quinária: para essa classificação a sentença poderá ser **declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva lato sensu**. É a classificação adotada por Pontes de Miranda.

Na sentença **executiva lato sensu** o direito é real, busca-se a retomada de algo que está no patrimônio do executado injustamente. O juiz já fixa o meio que entender adequado para o cumprimento da condenação.

Por sua vez, na sentença **mandamental** o juiz ordena que pessoa ou órgão faça ou deixe de fazer algo, não se limitando à condenação do réu.

Veja-se que tanto a **sentença mandamental** quanto a **sentença executiva lato sensu** têm um conteúdo condenatório, mas já trazem ínsitas a elas um meio executivo. Este meio executivo poderá ser a sub-rogação ou coerção:

- **Sub-rogação:** o magistrado estabelece um meio de como dar o cumprimento direto da obrigação. O juiz promove a execução direta, permitindo que um terceiro cumpra a obrigação ao invés do executado. Quando um meio de sub-rogação já é fixado na sentença, há uma sentença executiva *lato sensu*. Ex.: ação de reintegração de posse ou ação de despejo, pois se o sujeito não sair, o oficial de justiça, com auxílio policial, retira o réu do local. Veja, é sub-rogação por execução direta.
- **Coerção:** é a sentença que traz em seu conteúdo meios de coerção, ou seja, são meios de execução indiretos. Estes meios de coerção são fixados com a finalidade de estimular o cumprimento da obrigação pelo próprio executado. Quando este meio for adotado na sentença, esta passará a ter um conteúdo, tendo natureza mandamental, pois traz uma coerção ínsita. É típico das ações de fazer ou não fazer, visto que o não cumprimento poderá ensejar a fixação de *astreintes*.

A doutrina majoritária adota a teoria ternária, sob o fundamento de que as sentenças mandamentais e executivas *lato sensu* são espécies de sentenças condenatórias.

c) Sentenças determinativas

Sentenças determinativas podem ser compreendidas como aquelas **sentenças que impõem obrigação ou condenação que perdurarão no tempo**. Neste caso, trata-se de uma **obrigação de trato sucessivo**. Exemplo disso ocorre nos casos de sentença que condena o demandado a pagar alimentos, benefício previdenciário, etc.

A discussão reside no fato de esta sentença fazer ou não coisa julgada material, mas isto será visto mais à frente.

3.4. ESTRUTURA DA SENTENÇA

Segundo CPC, a sentença deverá ter **relatório, fundamentação e dispositivo**.

3.4.1. RELATÓRIO

Relatório é narrativa dos acontecimentos do processo. Nele conterà os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo.

A ausência de relatório enseja nulidade da sentença. **Excepcionalmente poderá ser dispensado, como nos Juizados Especiais.**

3.4.2. FUNDAMENTAÇÃO

É a motivação dos atos decisórios. No CPC foi criada uma norma indicativa das hipóteses em que a decisão judicial não é considerada fundamentada. Decorre de uma imposição constitucional nos termos do art. 93, inciso IX, da CRFB.

O Código de Processo Civil se preocupa de tal forma com a fundamentação das decisões judiciais que, no art. 489, §1º, elencou algumas situações em que as decisões/sentenças não serão consideradas fundamentadas. Veja-se:

- **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida:** é preciso que o juiz faça o cotejo analítico entre a norma que está sendo utilizada para fundamentar a decisão e o caso concreto;
- **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso:** não adianta alegar que a conduta do réu viola a boa-fé objetiva ou o princípio da função social, por exemplo, sem fazer a ligação com o caso concreto;
- **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão:** não se pode, simplesmente, fazer uma decisão padrão (que poderia ser utilizada para qualquer questão) e sequer relacionar essa decisão com o caso concreto, o juiz tem que enfrentar cada uma das discussões apresentadas nas petições;
- **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador:** deve-se ter um cuidado redobrado com essa previsão, pois ela leva à falsa percepção de que todas as questões devem ser enfrentadas pelo juiz e isso não é verdade, visto que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses. Ex.1: o autor alega nulidade do contrato e requer a declaração de nulidade, sendo este contrato nulo por: (i) incapacidade do autor à época da celebração e por (ii) coação. O juiz julga procedente o pedido e reconhece a nulidade do contrato porque a parte era incapaz. Neste caso, o juiz não precisa, em tese, enfrentar a tese da coação, uma vez que já anulou, considerando o fato de que o conhecimento acerca da coação não poderia infirmar a conclusão já consolidada em razão da incapacidade da parte. Ex.2: Embargos de Declaração no MS 21.315/DF³⁶;

³⁶Nos termos do art. 1.022 do NCPC (Lei nº 13.105/15), cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III). O parágrafo único do citado dispositivo legal estabelece que se considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, parágrafo 1º. O questionamento acerca de violação ao disposto no art. 37, §6º e 144, II, §2º da CF c/c o art. 936 e 927 do Código Civil, art. 20 do CTB e art. 333, I do CPC de 1973 encontra-se apreciado no voto condutor, que se baseia na



- **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos:** à luz do art. 927 do CPC, têm-se os precedentes vinculantes, devendo o juiz, ao decidir, adotá-los. O que o juiz não pode fazer é, simplesmente, invocar um precedente ou uma súmula sem fazer o cotejo analítico com o caso concreto. Além de citar o precedente, é necessário demonstrar às partes que as balizas fáticas e jurídicas do precedente e do caso concreto são as mesmas;
- **Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento:** o juiz não pode deixar de aplicar o precedente sem demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente, ou que aquele precedente já foi superado.
 - **Técnicas de aplicação de distinção e superação dos precedentes:** o Código de Processo Civil adotou a teoria dos precedentes judiciais obrigatórios, consagrando os fenômenos da distinção (*distinguishing*) e da superação (*overruling*). No ***distinguishing*** a parte invoca um precedente, para que este seja aplicado as balizas fáticas e jurídicas do caso concreto devem ser idênticas àquelas que geraram o precedente. Se forem diferentes, tem-se um caso de **distinção**, isto é, o caso concreto é diferente do caso que gerou o precedente. Desta feita, trata-se de uma hipótese de não aplicação do precedente no caso concreto, sem que tenha havido a sua revogação. No ***overruling***, as balizas fáticas e jurídicas do precedente são as mesmas do caso concreto, no entanto, houve alteração do entendimento, restando ele superado. Com o intuito de se buscar maior segurança jurídica, ter-se-á: i) ***retrospective overruling***: ao superar um precedente, poderá atingir processos que já estão em curso, relacionados a fatos passados; ii) ***prospective overruling***: o tribunal, ao modificar o seu precedente, poderá conceder efeitos prospectivos, o que significa que este precedente modificado será aplicado apenas para casos futuros.

A) FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (ALIUNDE OU POR REFERÊNCIA)

É aquela na qual o juiz se vale de outra decisão proferida no processo ou do parecer do Ministério Público e adota como razão de decidir aqueles fundamentos. Essa fundamentação é admitida pelo STJ e STF casuisticamente, conforme a situação.

constatação de ato omissivo do ente público no seu dever de diligência quanto à fiscalização e manutenção de barreiras protetivas nas rodovias federais, a fim de se evitar a invasão de animais, o que, vale ressaltar, não reflete conduta isolada, mas, infelizmente, corriqueira nas estradas nacionais. Neste diapasão, subsiste responsabilidade ao DNIT, já que tem tal autarquia a atribuição legal de zelar pela adequada conservação da malha viária federal. O nexo causal, por sua vez, está patente, pois em face da negligência do DNIT, ocorreu o sinistro, que causou ao Autor a incapacidade temporária para o trabalho. Os pontos trazidos como omissos nos embargos foram devidamente analisados no julgado embargado, sendo que, na verdade, pretende o embargante rediscutir a matéria, sendo que, conforme amplamente sabido por todos, os mesmos não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria ou à correção de eventual *error in iudicando* (Processo: 08017867920144050000, Desembargador Federal Marcelo Navarro, Terceira Turma, julgamento: 13.11.2014). **Ressalte-se, por fim, que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada."** STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Faz-se necessário, dois **pressupostos** para a adoção da fundamentação *per relationem*:

- i) é preciso que a decisão/manifestação de referência esteja substancialmente fundamentada;
- ii) é preciso que não haja qualquer fato novo e nem alegação de fato novo que ainda não tenha sido enfrentado pelas partes e pelo juiz. Ex.: AgInt no AgInt no AREsp 903.995/SC³⁷.

3.4.3. DISPOSITIVO

Dispositivo é a conclusão da sentença, é nele que o juiz externa o ato, ou seja, se ela foi concluída com ou sem resolução do mérito.

A ausência de dispositivo implica inexistência do ato, vício que pode ser alegado mediante a oposição de embargos de declaração ou, até mesmo, por meio de ação meramente declaratória, após o trânsito em julgado da decisão.

Apenas a conclusão do dispositivo é acobertada pela coisa julgada, por isso, se a questão prejudicial é enfrentada como questão principal, ela deverá estar no dispositivo.

3.5. ASSINATURA

O juiz não poderá deixar de assinar a sentença, seja manualmente ou eletronicamente, **sob pena de o ato ser considerado inexistente**.

3.6. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS E CUSTAS

Nos termos do artigo 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e as custas processuais.

A sucumbência (honorários e custas) será fixada levando em consideração dois critérios, o da **causalidade** e o da **dupla sucumbência**.

De acordo com o critério da causalidade quem deu causa para a propositura da demanda é quem deve arcar com a sucumbência, e não necessariamente o vencido.

Por sua vez, o **critério da dupla sucumbência** diz respeito a dupla derrota da parte (na causa e o recurso). É o critério adotado pelos Juizados Especiais. Nessa situação, o demandante ingressa em juízo, independentemente do pagamento das custas. Após a sentença, o recorrente apresenta o seu recurso, acompanhado do preparo ou faz o pagamento em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição independentemente de uma nova intimação. Depois, somente se perder novamente na

³⁷ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ.1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a precisa demonstração de omissão (Súmula 284 do STF).2. "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).3. Não se mostra cabível, nesta via, perquirir acerca da inexistência de coisa julgada ante o óbice constante da Súmula 7/STJ, especialmente quando o Tribunal a quo concluiu que "é certo que houve reprodução de ação idêntica e já definitivamente julgada".4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 903.995/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017).

análise do seu recurso, é que será fixada uma verba honorária em prol do advogado da outra parte. É por isso que se diz que se adota o modelo da dupla sucumbência.

Havendo sucumbência parcial ou recíproca, o juiz deverá distribuir entre eles, proporcionalmente as despesas. Se, no entanto, a sucumbência for mínima, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários.

3.6.1. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA À LUZ DO ART. 85 DO CPC

O art. 85 do CPC elenca dezenove parágrafos, que buscam esclarecer os critérios em que os honorários advocatícios serão fixados.

O referido dispositivo estabelece que os honorários advocatícios serão fixados em percentuais entre **10% e 20% da condenação**. Não sendo possível mensurar o valor da condenação, serão fixados **entre 10% e 20% do valor da causa**.

Nas **causas em que for inestimável o proveito econômico ou que este for irrisório, ou sendo o valor da causa muito baixo**, o juiz fixará os honorários com **base na apreciação equitativa**.

O art. 85, §3º, do CPC, regulamenta os **honorários quando a Fazenda Pública for vencida**. Nestes casos, quanto maior for a condenação da Fazenda Pública, menor será o percentual dos honorários que cabem ao advogado do vencedor.

O Tribunal, quando for apreciar o recurso, irá majorar os honorários, levando em conta o trabalho adicional do advogado em grau recursal. É vedado ao tribunal, mesmo majorando, ultrapassar os limites fixados na legislação.

Cabe ressaltar que o STF entendeu que **é cabível os honorários para o recorrido, ainda que não tenha ofertado contrarrazões recursais**.

Quanto à Fazenda Pública, quando o CPC dispõe no art. 85, §7º, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios na execução de sentença contra a fazenda pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido embargada esta execução, o CPC apenas consagra aquilo que já estava previsto na Lei 9.494/97.

O art. 85, §14, consagra o entendimento de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e por isso gozam do mesmo privilégio oriundo da legislação do trabalho. Por essa razão, **fica vedada a compensação de honorários** em sucumbência parcial.

Atente-se que o STJ se pronunciou pela possibilidade de o advogado ser obrigado, em ação de cobrança, a devolver os valores que recebeu a título de honorários, no caso em que a decisão judicial que ensejou a fixação de honorários de sucumbência seja parcialmente rescindida por meio de ação rescisória, ainda que o causídico, de boa-fé, já tenha efetuado o levantamento.

O art. 85, §18, vai dizer que **é possível o ajuizamento de uma ação autônoma para definição e cobrança dos honorários**, quando estes não tiverem sido fixados na sentença.

O art. 85, §15, autoriza que o advogado faça um requerimento para que o pagamento dos honorários seja feito à sociedade a que ele pertence, trazendo um benefício de ordem tributária no tocante a incidência de imposto de renda da pessoa jurídica.

O art. 85, §19, passa a permitir que advogados públicos recebam honorários de sucumbência nos termos da lei. Haverá de vir uma lei para tratar do assunto.

3.6.2. SUCUMBÊNCIA NA CUMULAÇÃO SUBJETIVA DE AÇÕES (LITISCONSÓRCIO)

A cumulação é subjetiva, pois **há mais de um sujeito num dos polos da ação**. Há aqui um **litisconsórcio**.

O art. 87 do CPC diz que, **concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos irão responder pelas despesas e honorários em proporção**. Deve a sentença distribuir de forma expressa o montante a cada um dos vencidos.

Se a **sentença for omissa**, os vencidos irão **responder solidariamente** pelas despesas e honorários fixados ou existente.

3.6.3. SUCUMBÊNCIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, ela deverá ser condenada a arcar com a sucumbência.

O que acontece aqui é que o art. 98, §3º, do CPC, diz que esta condenação **fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos**, prazo esse prescricional. **Durante esse tempo, o credor poderá provar que superou a situação de hipossuficiência do devedor**, ou seja que é possível a cobrança das custas processuais, honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família do devedor.

3.6.4. SUCUMBÊNCIA NO MANDADO DE SEGURANÇA E *HABEAS DATA*

Mandado de segurança não permite que a parte vencida seja condenada a pagar **honorários**. **Admite-se, porém, a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais**.

A jurisprudência adota idêntico raciocínio no caso de *habeas data*.

3.6.5. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Segundo o art. 18 da Lei 7.347/85, nas ações civis públicas, **não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora**, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

O dispositivo em comento vem sendo interpretado de forma ampliativa, de maneira que outros legitimados não sejam condenados ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, **salvo se agir com má-fé**. Isso, contudo, só ocorre se a associação autora for a vencida. Se o réu perder a ação civil pública, deverá arcar, normalmente, com custas, despesas e honorários advocatícios.

3.6.6. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO POPULAR

Segundo o art. 5º, LXXIII, CF, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, **salvo comprovada má-fé**, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Perceba que, **se o autor vencer a ação, a parte ré deverá arcar com custas, despesas e honorários advocatícios**.

3.7. VÍCIOS NA SENTENÇA

O artigo 492, *caput*, CPC, disciplina que “é vedado ao juiz, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Tal dispositivo preceitua o **princípio da congruência**, também conhecido como **princípio da correlação** ou da **adstrição**.

A fundamentação da sentença deve se ater aos argumentos expendidos pelas partes, caso contrário, estará maculada de um vício. Nesse ponto, convém destacar algumas **exceções** mencionadas pela doutrina³⁸:

- i) nos chamados pedidos implícitos é admitido ao juiz conceder o que não tenha sido expressamente pedido pelo autor;
- ii) a fungibilidade permite ao juiz que conceda tutela diferente da que foi pedida pelo autor, verificando-se nas ações possessórias e nas ações cautelares;
- iii) nas demandas que tenham como objeto uma obrigação de fazer e/ou não fazer o juiz pode conceder tutela diversa da pedida pelo autor, desde que com isso gere um resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação.

3.7.1. SENTENÇA ULTRA, EXTRA E CITRA PETITA

Tratam-se de vícios na sentença que violam o princípio da congruência, ou seja, são **hipóteses em que o magistrado julga em desconformidade com aquilo pedido na petição inicial**.

Nesses casos, a sentença será:

- **Ultra petita:** quando o magistrado decidiu além dos limites da provocação. O seu ato decisório foi além daquilo que o autor deduziu na petição inicial. Neste caso, há uma nulidade na sentença. É necessário arguir esta nulidade, pois, caso não seja arguida, poderá formar coisa julgada material e o vício restar sanado. A parte pode arguir, por exemplo, em sede de embargos de declaração ou de apelação.
- **Extra petita:** quando o magistrado profere uma sentença distinta dos limites da provocação. A sentença *extra petita* deve ser considerada inexistente, pois não há sequer provocação. Há quem entenda que esta sentença *extra petita* seja apenas nula.
- **Citra petita:** quando o ato decisório não enfrenta todas as questões levantadas pela parte e que sejam relevantes para o mérito. Neste caso, por conta de uma omissão relevante, caberá embargos de declaração para sanar esta omissão, ou mesmo recurso de apelação, visando a anulação da sentença, no que toca ao fato de ter sido *citra petita*.

3.7.2. SENTENÇA CONDICIONAL

Sentença é um título executivo judicial. A obrigação constante num título deve ser **líquida, certa e exigível**.

A sentença condicional acaba sendo incerta, considerando o fato de que ela não decide conclusivamente sobre a existência ou não de um direito, ou obrigação, postergando essa decisão a um evento futuro. Por exemplo, o juiz julga procedente o pedido, resolvendo o mérito, a fim de declarar a paternidade do demandado se este se submeter a exame de DNA, e este for procedente. Veja, esta sentença é condicional, ficando a condição de ser pai sujeito a um evento futuro e incerto.

A sentença condicional equivale a dizer que é uma sentença incerta.

Pode ser que a sentença seja certa e líquida e, ainda assim, tenha a sua eficácia subordinada a um termo ou a uma condição. Nesse caso a sentença é válida, pois ela é certa.

Há sentença condicional quando a sentença é incerta, não dizendo se existe o débito, a obrigação ou o vínculo, ou seja, afirma apenas que poderá existir se o direito for afirmado.

³⁸NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 12 ed.— Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, página 829.



Isto não ocorre quando a sentença condena o vencido (beneficiário da justiça gratuita) ao pagamento das custas processuais, visto que, nesse caso, apesar de ficar suspensa a exigibilidade das custas, ela poderá ser exigida caso ele mude de situação econômica. Em que pese tratar de um evento futuro e incerto, ou seja, de ser uma condição, a sentença é certa, ou seja, ela traz a certeza, diferentemente do que ocorre com a sentença condicional.

3.7.3. CORREÇÃO DA SENTENÇA

A sentença quando é publicada não pode mais ser modificada (art. 494, CPC), salvo algumas exceções. Segundo o dispositivo, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

- Para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, **inexatidões materiais ou erros de cálculo;**
- Por meio de **embargos de declaração.**

Ex.: o juiz declarou na fundamentação que o dano moral seria de 3 mil reais, mas no dispositivo mencionou 30 mil reais. Nesse caso, há erro material, podendo ser corrigido de ofício.

Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, desde que o ato seja omissivo, contraditório, obscuro ou contenha erro material.

Eventualmente, o juiz poderá corrigir a sentença nos casos em que a lei autoriza juízo de retratação em sede de recurso de apelação. Neste caso, poderá exercer este direito, alterando a sentença, mesmo após a sua publicação.

3.8. EFEITOS DA SENTENÇA

São efeitos da sentença:

- **Principal:** diz respeito ao bem da vida pleiteado. Por exemplo, o principal efeito de uma sentença condenatória, é a condenação do réu;
- **Anexa:** é aquele efeito que a sentença produz independentemente de manifestação da parte ou de quem a prolatou, porque decorre da própria lei. Por exemplo, não é necessário mencionar na sentença que aquela decisão é um título executivo judicial, ou que a sentença vale como hipoteca judiciária;
- **Reflexa:** é possível que uma sentença atinja reflexamente quem não fez parte do processo. Por exemplo, ação de despejo promovida pelo locador contra o locatário, caso o pedido seja julgado procedente, atingirá o sublocatário de forma reflexa;
- **Probatória:** a sentença por ser um documento público, faz prova da sua própria existência; do seu conteúdo, ou seja, a sentença não faz prova do fato em si, mas prova que houve um litígio; que as partes estiveram em audiência, etc.

3.9. HIPOTECA JUDICIÁRIA (ART. 495, CPC)

O art. 495 do CPC disciplina que “a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária”. Trata-se de um efeito anexo da sentença.



- **Importante:** Hipoteca judiciária é sempre uma decisão que condena a uma prestação pecuniária ou que condena a uma obrigação de fazer; de não fazer ou de dar coisa que foi convertida em prestação pecuniária³⁹.

A sentença valerá como hipoteca judiciária e o credor, independentemente de requerimento, de homologação ou de autorização judicial poderá realizar sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis, gerando para o credor hipotecário o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores.

Perguntas:

1- E se a condenação for genérica?

R: Se genérica no sentido de precisar liquidar, ainda assim será admitida hipoteca judiciária.

2- E se a sentença ainda não transitou em julgado?

R: A sentença valerá como hipoteca judiciária, pouco importando se houve ou não trânsito em julgado.

3- E se o credor já constringiu bens do devedor?

R: Será possível.

4- E se houver recurso com efeito suspensivo?

R: Do mesmo modo a sentença valerá como hipoteca judiciária.

- **OBS. 1:** Se ocorreu a constrição dos bens ou; não houver trânsito em julgado, a sentença valerá como hipoteca judiciária, mas o credor se submete a aplicação **da teoria do risco-proveito**. Isso significa que, no futuro, se a sentença for cassada ou reformada, os danos causados à parte contrária em razão da hipoteca judiciária, deverão ser arcados pelo credor que averbou a sentença. Tem-se, portanto, que a responsabilidade do credor é objetiva – princípio da cooperação, dever de proteção.
- **OBS. 2:** O **direito de preferência** após a averbação da sentença diz respeito aos demais credores do devedor, mas cede lugar, para as preferências do direito material. Por exemplo, se o devedor tiver outro credor hipotecário constante na averbação do imóvel, a hipoteca gerada pelo direito processual, cede para as preferências decorrentes do direito material.

3.10. SENTENÇA E FATO SUPERVENIENTE

A sentença deve ter como base o estado de fato e de direito no momento da sua prolação. Dessa forma, os fatos supervenientes à propositura da ação, poderão ser levados em consideração ao proferir a decisão, conforme prescreve o artigo 493 do CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, **de ofício ou a requerimento da parte**, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

³⁹ATENÇÃO: Examinador tenta confundir o candidato, mencionando o seguinte: “A decisão que condena a prestação em dinheiro ou que condena a uma obrigação de fazer, valerão como hipoteca judiciária”→ Incorreta.

O parágrafo único do aludido dispositivo oportuniza o exercício do poder de influência (art. 10 do CPC). Por exemplo, em uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial ainda não vencido, inexistente inadimplemento. O juiz, ao receber a petição inicial, verifica que o vencimento da dívida ocorreu após a propositura da ação, mas antes da citação do réu. Neste caso, o magistrado poderá admitir o fato superveniente e manter intacta a ação.

O **STJ** possui entendimento nesse sentido: “é plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião – ação de conhecimento”⁴⁰.

Destaca-se, contudo, que são três os **pressupostos** para aplicação do artigo 493 do CPC:

- Fato superveniente a propositura da ação;
- Deve ter havido contraditório sobre o fato;
- Fato novo deve estar provado no processo, para que possa reconhecê-lo de ofício.

Pergunta:

1- A regra do art. 493 do CPC pode beneficiar o réu?

R: Pode beneficiar tanto o autor quanto o réu. Por exemplo, se no curso de uma ação de cobrança o réu passa a ser credor do autor em razão de uma compensação e tendo o crédito surgido após a propositura da ação, tem-se um fato superveniente que será levado em consideração pelo juiz no momento da prolação da sentença.

3.11. COISA JULGADA

Coisa julgada é um instituto valoroso, pois **prestigia a segurança jurídica**.

Para Chiovenda, coisa julgada é a eficácia que decorre da própria sentença. Apesar disso, o entendimento não prevalece.

Liebman dizia que coisa julgada é a **autoridade da sentença que a torna imutável quanto ao seu conteúdo e quanto aos seus efeitos**.

O conceito de coisa julgada material encontra-se disposto no artigo 502 do CPC, segundo o qual “denomina-se coisa julgada material a **autoridade** que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

A expressão “autoridade” significa dizer que coisa julgada não é efeito da sentença, mas sim autoridade da decisão de mérito que a torna indiscutível e imutável. Denota-se, portanto, que, enquanto houver recurso pendente, não haverá coisa julgada, pois, o recurso impede a sua formação.

De modo geral, os **recursos** previstos no nosso sistema produzem diversos efeitos, mas o principal deles é o **efeito obstativo da coisa julgada**.

Logo, coisa julgada trata-se de um direito fundamental previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Pergunta:

1- A coisa julgada é pressuposto para que a sentença produza efeitos?

R: Não, pois, ainda que não haja coisa julgada, a sentença produz seus efeitos normalmente. Tem-se,

⁴⁰ Agravo Regimental no Recurso Especial 1.163.175/PA, Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª turma.

como exemplo, a hipoteca judiciária que produz efeito anexo da sentença.

3.11.1. COGNIÇÃO E ATOS QUE PODEM GERAR COISA JULGADA

i. Cognição que pode gerar coisa julgada

Cognição é o grau de aprofundamento do juiz quanto às questões de fato e de direito submetidas a julgamento. Há uma cognição superficial ou sumária, e uma cognição exauriente, que é aprofundada.

- **Cognição exauriente:** significa que o ato decisório decorre de um juízo de certeza. Por conta disso, poderá transitar em julgado, ou seja, poderá haver coisa julgada material.
- **Cognição sumária:** o magistrado profere uma decisão não com base no juízo de certeza, mas sim em um juízo de probabilidade. Como a instrução não chegou ao fim, poderá ela ser alterada no decorrer do trâmite processual. Dessa forma, não fará coisa julgada. Ex.: tutela provisória de urgência antecipada.

ii. Atos que podem gerar coisa julgada

Existem atos proferidos pelo juiz que podem sofrer os efeitos decorrentes da coisa julgada material:

- **Acórdão;**
- **Decisões monocráticas do Relator,** quando decide questão conforme jurisprudência pacífica do Tribunal;
- **Sentenças,** desde que tenham julgamento decorrente de cognição exauriente ou que resolvam em caráter definitivo a pretensão de caráter material (reconhecendo prescrição ou decadência);
- **Decisão interlocutória, desde que não tenha sido interposto agravo de instrumento:** ocorrerá quando houver o julgamento antecipado do mérito. Ex.: João deve 100 mil a Pedro. Pedro ajuíza a ação, mas João contesta dizendo que deve 80 mil, e não 100 mil. Há uma parcela incontroversa de 80 mil. Em relação a este valor já haverá trânsito em julgado e poderá ser concedido por meio de tutela de evidência. Este valor será reconhecido em decisão interlocutória.

3.11.2. COISA JULGADA, PRECLUSÃO E ESTABILIDADE DA DECISÃO

Coisa julgada é uma qualidade que torna imutável o conteúdo de um ato decisório que não se sujeita mais a qualquer recurso. Depende, em regra, de cognição exauriente.

Preclusão é a imutabilidade de um ato decisório se não for interposto qualquer recurso. A preclusão atinge qualquer ato decisório, diferentemente da coisa julgada.

O termo **estabilidade da decisão** é utilizado para designar o regime da tutela provisória de urgência antecipada, quando a mesma é deferida e não é interposto qualquer recurso pela parte ré. O processo será extinto e os efeitos da liminar não mais serão passíveis de alteração nos próprios autos. Há, nesse caso, uma estabilidade da decisão judicial. A parte endereçada terá o prazo de 2 (dois) anos para reverter essa decisão por meio de uma ação própria de impugnação. Após esse lapso temporal não será mais possível.



3.11.3. CLASSIFICAÇÃO DA COISA JULGADA

A coisa julgada poderá ser:

- **Coisa julgada formal:** atua exclusivamente no processo em que a sentença foi proferida. Tem efeito endoprocessual. Todo processo possui coisa julgada formal. Caso não tenha havido recurso contra a decisão, ela transitará em julgado formalmente, não podendo mais ser discutido o que foi decidido naquele processo, mas poderá ser julgado em outro. Há uma sentença terminativa.
- **Coisa julgada material:** ocorre quando os efeitos da coisa julgada extrapolam aquele processo, não se permitindo uma nova discussão sobre aquele fato em qualquer outro processo. Típico de sentença definitiva.
- **Coisa soberanamente julgada:** após o trânsito em julgado de uma decisão, a parte possui o prazo de 2 (dois) anos para propor uma ação rescisória. Passado este período (2 anos), surge a denominada coisa soberanamente julgada, pois não será possível sequer o ajuizamento de uma ação rescisória.

3.11.4. COISA JULGADA *PRO ET CONTRA*

Basicamente, todas as decisões que possuem coisa julgada terão também a coisa julgada *pro et contra*.

Coisa julgada *pro et contra* quer dizer que **a coisa julgada se forma independentemente, via de regra, do resultado do processo ter sido ou não favorável aos intentos do autor**. A coisa julgada será tanto *pro* quanto *contra* o demandante.

3.11.5. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA

Em regra, a coisa julgada só vai vincular demandante e demandado no processo em que foi proferida, ou seja, só vincula as partes, não prejudicando terceiros.

Excepcionalmente, a coisa julgada poderá atingir terceiros que não participaram do processo, como por exemplo:

- **Substituto processual:** alguém age em nome próprio defendendo direito alheio. Logo, eventual sentença proferida, atingirá a esfera subjetiva de terceiro, a despeito de não ser parte no processo;
- **Litisconsórcio facultativo unitário:** dois ou mais acionistas tentam obter judicialmente a nulidade de uma assembleia, fundamentando na mesma causa de pedir (ausência de quórum para deliberação). Se é a mesma causa de pedir, o acionista poderá ingressar sozinho ou em litisconsórcio facultativo. Neste caso, há um litisconsórcio facultativo unitário, pois será a assembleia anulada ou não, seja para um seja para o outro. O teor da sentença, portanto, irá vincular não apenas o que participou do processo, mas todos aqueles que figuraram no processo como litisconsórcio facultativo unitário. Ada Pellegrini Grinover discorda desse entendimento.
- **Dissolução parcial da sociedade:** o CPC estabelece que nestas demandas deverão figurar todos os sócios e também a pessoa jurídica. O próprio CPC dispensa a citação da pessoa jurídica quando todos os sócios estiverem citados. Neste caso, a pessoa jurídica será atingida pela coisa julgada, apesar de não participar do processo.



3.11.6. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA

Coisa julgada alcança **objetivamente o dispositivo da sentença ou do ato decisório**.

Atente-se que o art. 503, §1º, do CPC, passou a prever que a coisa julgada também vai abranger, além da questão principal, a questão prejudicial interna, desde que o enfrentamento dela seja necessário para resolver o mérito. Nesse caso, tendo sido respeitado o contraditório prévio e a competência do juiz, tal decisão fará coisa julgada material.

São **requisitos para que haja a resolução de questão prejudicial**, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

- Dessa resolução depender o julgamento do mérito;
- A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
- O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal;
- Não houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

No sistema anterior, para isso acontecer, era necessário propor uma ação declaratória incidental.

Parcela da doutrina entende que deverá ser feita uma interpretação restritiva para formar a coisa julgada da questão prejudicial interna apenas se houver o requerimento da parte, a fim de não julgar em desconformidade com o pedido do demandante. No entanto, o próprio CPC não traz essa necessidade de requerimento da parte, motivo pelo qual haveria automaticamente essa possibilidade.

3.11.7. EFEITOS DA COISA JULGADA

A coisa julgada possui três efeitos:

- **Efeito vinculativo:** os limites subjetivos da coisa julgada material, alcançando a coisa julgada apenas as partes principais;
- **Efeito sanatório:** os vícios processuais são convalidados com o trânsito em julgado material. Ex.: incompetência absoluta após o trânsito em julgado, situação na qual haverá o efeito sanatório da coisa julgada material. Existem exceções como, por exemplo, a inexistência de citação e alguns casos de rescindibilidade (nulidades absolutas que permitem instauração de ação rescisória).
- **Efeito preclusivo:** no momento em que a coisa julgada se forma estarão repelidos todos os argumentos que a parte poderia invocar no processo, tenha ou não sido invocado. Ex.: João cobra de Samer 100 mil reais. Samer entende que João merece 80 mil reais, pois não prestou o serviço adequadamente. Na contestação, Samer alega apenas a prescrição, mas não fala nada sobre a má prestação do serviço. Neste caso, o juiz não acolheu a alegação da prescrição e julgou procedente o pedido. Transitando em julgado a decisão, não poderá Samer alegar mais a má prestação, visto que houve o efeito preclusivo da coisa julgada.

3.11.8. COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA

No mandado de segurança não há dilação probatória. A prova trazida pelo impetrante deverá ser uma prova pré-constituída. Denegada a segurança, é necessário verificar se a decisão foi com ou sem resolução de mérito.

A discussão reside na situação em que a segurança é denegada por ausência de direito líquido e certo, não havendo prova pré-constituída do direito.

O direito líquido e certo é considerado como uma condição específica da ação de mandado de segurança, situação na qual implicaria decisão terminativa, o que autorizaria a utilização do procedimento comum, já que não seria necessário direito líquido e certo. Veja, não haveria coisa julgada material.

Na linha de Cândido Dinamarco, a afirmação do juiz de que a segurança deverá ser denegada por ausência de direito líquido e certo configura o julgamento improcedente do pedido por falta de provas. Neste caso, haveria uma decisão definitiva, razão pela qual haveria coisa julgada material, não sendo possível ajuizar ação sequer pelo procedimento comum.

3.11.9. COISA JULGADA NAS SENTENÇAS DETERMINATIVAS

Sentença determinativa é a **sentença que o juiz impõe ao vencido uma obrigação de trato sucessivo**. É típica da ação de alimentos.

A grande dúvida é se essa sentença tem ou não aptidão para gerar coisa julgada material, já que o conteúdo poderá ser alterado numa demanda posterior.

A verdade é que sentença determinativa pode gerar coisa julgada formal e coisa julgada material. Isso porque, se o sujeito propõe posteriormente uma ação de revisão de alimentos, esta ação se fundará numa nova causa de pedir e há um novo pedido. Primeiro porque o pedido anterior era do reconhecimento de alimentos e o segundo é de revisão de alimentos, motivo pelo qual não há identidade de pedidos. E segundo, porque agora a causa de pedir está fundada na alteração do binômio necessidade x possibilidade, visto que já está reconhecida a paternidade.

Como se vê, não se está repetindo a ação, pois inexistente identidade de causa de pedir e pedido. Portanto, poderá dizer que a sentença anterior transitou em julgado.

3.11.10. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NAS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO

Esse tema ganhou relevância em razão de indenizações que foram sendo estabelecidas em ações de desapropriação que já haviam transitado em julgado, mas cujo valor da indenização fixado em sentença era absolutamente desproporcional e injusto. Era uma fonte de enriquecimento ilícito do particular em detrimento do erário.

O STJ decidiu que sentenças dessa natureza nem sempre transitam em julgado, visto que haveria um interesse público afeto à sociedade em corrigir estas distorções que causam grave prejuízo ao erário, autorizando ainda questionamentos no título no decorrer dessa sentença. Veja, nesses casos o interesse público desautorizaria a formação de coisa julgada.

3.11.11. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NAS AÇÕES DE ESTADO

Ações de estado são processos instaurados com o objetivo de criar, modificar, extinguir um estado. Ex.: ação de paternidade e divórcio.

A relativização da coisa julgada ganha importância nas **ações de reconhecimento de paternidade julgadas improcedentes por falta de provas, mas à época não havia e/ou não foi realizado o exame de DNA**. Se não foi realizado o exame de DNA e foi julgado improcedente o pedido, **o STJ entende que a coisa julgada, nesse caso, deverá ser relativizado. O STF adotou posicionamento na mesma linha.**

Deste modo, será possível o ajuizamento de uma nova ação de paternidade sem que a anterior tenha sido desconstituída. Não é preciso ação rescisória.

O argumento é de que, se a ação não tiver sido peremptoriamente negada, seria possível um novo processo, instruído com novas provas.

Apesar de o STJ não usar a expressão, **há uma coisa julgada *secundum eventum probationis***, ou seja, se o sujeito fez o exame de DNA e deu que ele não seria o pai, não há mais o que discutir. Por outro lado, se não fez o exame de DNA, mas a sentença disse que ele não era o pai. Caberá a relativização para submeter ao exame.

3.11.12. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL

Prolatada uma sentença que contraria frontalmente a Constituição e transitando em julgado, haverá uma coisa julgada inconstitucional.

O art. 525, §12, do CPC, traz que **é inexigível uma sentença fundada num ato normativo reputado inconstitucional pelo STF ou sentença tido como incompatível com a Constituição pela Suprema Corte**. Aqui há uma sentença já transitada em julgada.

O CPC vai dizer no §15 que, se a sentença for proferida **antes** da decisão do STF, que declarou o ato normativo inconstitucional ou a interpretação dada como incompatível com a Constituição, **cabará ação rescisória dessa decisão**, que deverá ser oferecida no **prazo de 2 (dois) anos, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão prolatada pela Suprema Corte.**

QUESTÕES

1. (MP-PI/CESPE) Com relação a procedimentos, posturas, condutas e mecanismos apropriados para a obtenção da solução conciliada de conflitos, assinale a opção correta, à luz da legislação pertinente.

- a) Os advogados podem estimular a conciliação e outros métodos de solução consensual de conflitos nos processos que atuem, desde que autorizados pelo juiz competente.
- b) A audiência de conciliação ou de mediação deverá ser necessariamente realizada de forma presencial.
- c) Incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.
- d) Para que a realização da audiência de conciliação ou de mediação seja dispensada, basta que uma das partes manifeste, expressamente, o desinteresse na composição consensual.
- e) É vedado às partes do processo judicial escolher livremente o conciliador ou o mediador: elas devem selecionar profissional inscrito no cadastro do tribunal pertinente.

2. (TJ-CE/CESPE) Com base no CPC, é correto afirmar que o valor da causa

- a) não servirá de base de cálculo para a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça caso seja irrisório ou demasiado elevado.



- b) é um requisito legal da petição inicial, mas não da reconvenção.
- c) não poderá ser corrigido de ofício pelo juiz, mesmo se verificado que a monta indicada não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.
- d) pode ser corrigido a qualquer tempo se comprovada alteração superveniente de fato ou de direito, oportunidade na qual será complementado o seu pagamento, se necessário.
- e) corresponderá, em causa relativa a obrigação por tempo indeterminado, à soma das parcelas vencidas mais o valor de uma prestação anual relativa às parcelas vincendas.

3. (MPE/SP) Quanto à reconvenção, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Pode ser proposta contra o autor e terceiro.
- b) Não é cabível em ação monitória.
- c) Pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.
- d) Se o réu contestar a ação e não reconvir, poderá veicular sua pretensão em ação própria.
- e) O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

4. (TJ-RJ/VUNESP) No que diz respeito ao julgamento antecipado parcial de mérito, é correto afirmar que o respectivo pronunciamento judicial

- a) deve ser objeto de confirmação quando da prolação da futura sentença, por se tratar de decisão de natureza provisória.
- b) configura-se em sentença, sendo, portanto, apelável.
- c) é passível de cumprimento provisório, mesmo que tenha sido julgado em definitivo o recurso dele interposto.
- d) pode ser executado, independentemente de caução, ainda que esteja pendente de julgamento recurso contra ele interposto.
- e) deve reconhecer a existência de obrigação líquida, não sendo cabível sua prévia liquidação.

5. (TJ-PA/CESPE) Considera-se fundamentada a decisão interlocutória se o juiz apenas

- a) expuser as razões que lhe formaram o convencimento.
- b) indicar o dispositivo legal aplicável.
- c) invocar precedente jurisprudencial aplicável.
- d) reproduzir o ato normativo aplicável.
- e) empregar conceitos jurídicos, ainda que indeterminados.

6. (TJ-AL/ FCC) Quanto aos princípios gerais e às modalidades de provas no Processo Civil,

- a) a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados mediante ata lavrada por tabelião, salvo em relação a dados relativos a imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos.
- b) a produção antecipada da prova previne a competência do Juízo para a ação que venha a ser proposta.

- c) quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, somente prova pericial pode suprir-lhe a falta.
- d) a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada; se espontânea, só pode ser feita pela própria parte.
- e) o documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular.

7. (TJ-RJ/VUNESP) Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No que pertine ao instituto da coisa julgada, segundo o regime estabelecido pelo diploma processual vigente, assinale a alternativa correta.

- a) O regime da formação de coisa julgada sobre questões prejudiciais somente é aplicável aos processos iniciados após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.
- b) A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros.
- c) A tutela antecipada antecedente, se não for afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes no prazo de dois anos, faz coisa julgada, vez que se torna imutável e indiscutível.
- d) A coisa julgada aplica-se à resolução de questão preliminar, decidida expressa e incidentemente no processo, desde que a mesma conste do dispositivo da sentença.
- e) Fazem coisa julgada os motivos da sentença desde que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do pronunciamento judicial.

8. (TJ-RO/VUNESP) A hipoteca judiciária é um efeito secundário próprio da sentença, estando correto afirmar que

- a) sobrevindo a reforma ou invalidação da decisão condenatória, eventuais perdas e danos decorrentes da hipoteca deverão ser apurados em ação própria.
- b) deve ser realizada perante o cartório de registro imobiliário mediante ordem judicial e demonstração de urgência.
- c) a decisão não produz hipoteca judiciária se pendente arresto sobre o bem do devedor.
- d) decorre da sentença condenatória, sendo irrelevante a interposição ou não de recurso contra ela, ainda que este seja dotado de efeito suspensivo.
- e) decorre da decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação pecuniária, salvo se a condenação for genérica.

COMENTÁRIOS

1. C.

- a) Nos termos do artigo 3º, §3º, do CPC, a conciliação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados tanto por juízes quanto por advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, independentemente de autorização judicial.



- b) De acordo com o artigo 334, §7º, do CPC, a audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico.
- c) Conforme estabelece o artigo 139, inciso V, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições da lei adjetiva civil, incumbindo-lhe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.
- d) Para que a realização da audiência de conciliação ou de mediação seja dispensada, é necessário que ambas as partes manifestem, expressamente, o desinteresse na composição consensual, conforme disciplina o artigo 334, §4º, do CPC.
- e) As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador ou o mediador, ainda que eles não estejam cadastrado no tribunal (artigo 168, §1º, CPC).

2. Gabarito: E.

- a) O ato atentatório à dignidade da justiça deve ser punido com fixação de multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis; é o que dispõe o art. 77, §2º do CPC. Para as hipóteses em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável, o §5º do mesmo dispositivo prevê que a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Verifica-se, portanto, que o texto processual civil não traz exceção à regra prevista no art. 77, §2º do CPC para os casos em que o valor da causa seja demasiado elevado, o que torna a alternativa incorreta.
- b) A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é, normalmente, proposta pelo réu no bojo da contestação, devendo preencher os mesmos requisitos da petição inicial, inclusive o valor da causa, que deverá seguir os critérios disciplinados no art. 292 do CPC.
- c) O CPC, em seu artigo 292, §3º, permite que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, se majorado o valor primeiramente informado pelo autor.
- d) O valor da causa não poderá ser corrigido a qualquer tempo, mas até a fase de saneamento do processo, inteligência do art. 357 do CPC, ocasião em que, na hipótese de correção, haverá o recolhimento das custas correspondentes.
- e) Nas obrigações por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, o valor da causa será igual ao valor da soma das parcelas vencidas (até o momento da propositura da demanda) e uma prestação anual, quanto às prestações vincendas (que vencerão no decorrer da demanda), conforme prevê o artigo 292, §§1º e 2º do CPC.

3. Gabarito: B.

- a) Artigo 343, §3º, do CPC: A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
- b) Artigo 702, §6º, do CPC: Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.
- c) Art. 343, §4º, CPC: A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.
- d) Se o réu contestar a ação e não reconvir, poderá, perfeitamente, veicular sua pretensão em ação própria, visto que a reconvenção é uma mera faculdade processual, podendo o réu ingressar com uma ação autônoma para a prestação da tutela jurisdicional não manejada em sede de reconvenção.
- e) Art. 343, §6º, do CPC: O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.



4. Gabarito: D.

- a) A decisão do julgamento antecipado parcial do mérito, apesar de ser uma decisão interlocutória, produz coisa julgada material, razão pela qual não há necessidade de que seja confirmada quando da prolação da sentença, visto que enfrenta o mérito com cognição exauriente.
- b) Apesar de formar coisa julgada material em virtude de uma análise de cognição exauriente, o julgamento antecipado parcial de mérito é materializado por uma decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, o recurso de agravo de instrumento e não de apelação (art. 356, §5º, CPC).
- c) Caso tenha sido julgado em definitivo o recurso interposto contra decisão parcial de mérito, a execução será definitiva e não provisória, nos termos do artigo 356, §3º, CPC).
- d) Artigo 356, §2º, CPC: A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.
- d) pode ser executado, independentemente de caução, ainda que esteja pendente de julgamento recurso contra ele interposto.
- e) Artigo 356, §1º, CPC: A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

5. Gabarito: A.

- a) Dentre os elementos essenciais da sentença está a fundamentação, oportunidade em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, expondo as razões que lhe formaram o convencimento, conforme determina o artigo 489, inciso II, do CPC.
- b) Artigo 489, §1º, inciso I, do CPC: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
- c) Artigo 489, §1º, inciso I, do CPC: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
- d) Artigo 489, §1º, inciso I, do CPC: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
- e) Artigo 489, §1º, inciso II, do CPC: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

6. Gabarito: E.

- a) Nos termos do artigo 384 do CPC, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião, podendo dela constar, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos.
- b) Artigo 381, §3º, do CPC: A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.



- c) Artigo 406 do CPC: Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.
- d) Artigo 390, §1º, do CPC: A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial.
- e) Art. 407 do CPC: O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular.

7. Gabarito: A.

- a) De acordo com o art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, aplicando-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo, se dessa resolução depender o julgamento do mérito; se a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; e se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Nos termos do artigo 1.054 do CPC, tal regra somente se aplica aos processos iniciados após a sua vigência (2015).
- b) Art. 506 do CPC: A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
- c) Nos termos do artigo 304, §6º, do CPC, a decisão que concede a tutela antecipada requerida em caráter antecedente não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes.
- d) Consoante dispõe o artigo 503, do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, aplicando-se à resolução de questão prejudicial (e não de questão preliminar) decidida expressa e incidentalmente no processo.
- e) Art. 504, *caput*, do CPC: “Não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.

8. Gabarito: D.

- a) Artigo 495, §5º, do CPC: Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos.
- b) Artigo 495, §2º, do CPC: A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.
- c) Artigo 495, §1º, inciso II, do CPC: A decisão produz a hipoteca judiciária ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor.
- d) Artigo 495, §1º, inciso III, do CPC: A decisão produz a hipoteca judiciária mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.
- e) Artigo 495, §1º, inciso I, do CPC: A decisão produz a hipoteca judiciária embora a condenação seja genérica.



Informativos de Jurisprudência

- CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

DUPLICIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. SUBSIDIARIEDADE. ART. 272 DO CPC/2015. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações. (AgInt no AREsp 1.330.052-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019).

PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO DE FATO NO BRASIL. FILIAL OU AGÊNCIA NÃO FORMALMENTE CONSTITUÍDA. CITAÇÃO. REGULARIDADE. É regular a citação da pessoa jurídica estrangeira por meio de seu entreposto no Brasil, ainda que não seja formalmente aquela mesma pessoa jurídica ou agência ou filial. (HDE 410-EX, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).

INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA OU DE ORDEM. PRAZO RECURSAL. INÍCIO DO CÔMPUTO. DATA DA JUNTADA AOS AUTOS. Nos casos de intimação/citação realizadas por correio, oficial de justiça, ou por carta de ordem, precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta. (REsp 1.632.777-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. (Tema 379)).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. A apresentação de procuração e a retirada dos autos efetuada por advogado destituído de poderes para receber a citação não configura comparecimento espontâneo do réu (art. 214, § 1º, do CPC). Precedentes citados: REsp 648.202-RJ, Segunda Turma, DJe 11/4/2005; e REsp 1.246.098-PE, Segunda Turma, DJe 5/5/2011. AgRg no REsp 1.468.906-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/8/2014.

CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. A pessoa jurídica - ente evidentemente abstrato - faz-se representar por pessoas físicas que compõem seus quadros dirigentes. Se a própria diretora geral, mesmo não sendo a pessoa indicada pelo estatuto para falar judicialmente em nome da associação, recebe a citação e, na ocasião, não levanta nenhum óbice ao oficial de justiça, há de se considerar válido o ato de chamamento, sob pena de, consagrando exacerbado formalismo, erigir inaceitável entrave ao andamento do processo. Precedente citado: AgRg nos EREsp 205.275-PR, DJ 28/10/2002. EREsp 864.947-SC, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, julgados em 6/6/2012.

- PETIÇÃO INICIAL

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. FACULDADE. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESPÓLIO. ARTS. 43, 265 E 1.055 DO CPC/1973. É admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição de executado pelo seu espólio, em execução ajuizada em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação. (REsp 1.559.791-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).

AÇÃO DE INVENTÁRIO. CITAÇÃO DE HERDEIROS QUE RESIDEM EM COMARCA DISTINTA DA QUE TRAMITA A AÇÃO. ART. 999, § 1º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE CITAÇÃO POR OFICIAL



DE JUSTIÇA. HERDEIROS CONHECIDOS E QUE ESTÃO EM LOCAL SABIDO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. Tendo sido declinados na petição inicial todos os dados pessoais indispensáveis à correta identificação dos herdeiros, inclusive os seus respectivos endereços, devem ser eles citados pessoalmente por carta com aviso de recebimento, vedada a citação por oficial de justiça. (REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

- RESPOSTA DO RÉU E REVELIA

AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO ADOTADO PELA CÔNJUGE POR OCASIÃO DO CASAMENTO. REVELIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VONTADE. NECESSIDADE. DIREITO DA PERSONALIDADE. INDISPONIBILIDADE. A revelia em ação de divórcio na qual se pretende, também, a exclusão do patronímico adotado por ocasião do casamento não significa concordância tácita com a modificação do nome civil. (REsp 1.732.807-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital. (REsp 1.088.068-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, por unanimidade, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017).

RECONHECIDA A REVELIA, A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO AOS DANOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO ALCANÇA A DEFINIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO INDICADO PELO AUTOR. Como assentado na doutrina, a revelia não viola o processo justo, o devido processo legal, porque não significa a formação de um contraditório virtual ou presumido, muito menos a existência de uma confissão ficta. A própria existência da ação atesta a inconformação entre a pretensão do autor e a resistência do réu. Por isso, os efeitos da revelia não são absolutos, conduzindo à automática procedência dos pedidos. A revelia produz efeitos relativos, apenas autorizando o julgador, como destinatário do comando inserto no art. 319 do CPC, a considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Caberá ao juiz a análise conjunta das alegações e das provas produzidas (REsp 1.128.646-SP, Terceira Turma, DJe de 14/9/2011; e EDcl no Ag 1.344.460-DF, Quarta Turma, DJe de 21/8/2013). A par disso, a revelia permite ao juiz considerar verdadeiros os fatos relacionados à ocorrência de dano suportado pelo autor em razão da conduta do réu. Assim, o que deve ser considerado "verdadeiro" é a ocorrência do dano. Importa destacar que não se pode confundir a existência do dano com a sua correta quantificação feita pelo autor na petição inicial. O quantum é decorrência do dano, e seu valor deve corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, a ser ressarcido pelo causador, não sendo permitido o enriquecimento sem causa. Precedentes citados: AgRg no AREsp 450.729-MG, Quarta Turma, DJe de 28/5/2014; e AgRg no REsp 1.414.864-PE, Segunda Turma, DJe de 11/2/2014. REsp 1.520.659-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1º/10/2015, DJe 30/11/2015.

- PROVAS

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. APLICABILIDADE. É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, na vigência do Código de Processo Civil de 2015. (REsp 1.803.251-SC, Rel. Min.



Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII, DO CPC/2015. PROVA NOVA. CONCEITO. INCLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória. (REsp 1.770.123-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE. O magistrado pode negar a realização de perícia requerida pela parte sem que isso importe, necessariamente, cerceamento de defesa. De fato, o magistrado não está obrigado a realizar todas as perícias requeridas pelas partes. Ao revés, dentro do livre convencimento motivado, pode dispensar exames que reputa desnecessários ou protelatórios. Precedente citado: AgRg no AREsp 336.893-SC, Primeira Turma, DJe 25/9/2013. REsp 1.352.497-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 4/2/2014.

É ADMISSÍVEL, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO, PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPARAM AS PARTES DO PROCESSO PARA O QUAL A PROVA SERÁ TRASLADADA. A grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo. Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na CF pela EC 45/2004. Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso. Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 4/6/2014.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. Desde que observado o devido processo legal, é possível a utilização de provas colhidas em processo criminal como fundamento para reconhecer, no âmbito de ação de conhecimento no juízo cível, a obrigação de reparação dos danos causados, ainda que a sentença penal condenatória não tenha transitado em julgado. Com efeito, a utilização de provas colhidas no processo criminal como fundamentação para condenação à reparação do dano causado não constitui violação ao art. 935 do CC/2002 (1.525 do CC/16). Ademais, conforme o art. 63 do CPP, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente é pressuposto para a sua execução no juízo cível, não sendo, portanto, impedimento para que o ofendido proponha ação de conhecimento com o fim de obter a reparação dos danos causados, nos termos do art. 64 do CPP. AgRg no AREsp 24.940-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014.

- SENTENÇA E COISA JULGADA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (EAREsp

1.255.986-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUESTIONADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO WRIT. CONHECIMENTO. O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo *mandamus*. (EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por maioria, julgado em 14/03/2019, DJe 11/06/2019).

DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO SOBRE PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. POSTERIOR AJUSTE CONSENSUAL ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS BENS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONVENÇÃO SOBRE PARTILHA DE BENS PRIVADOS E DISPONÍVEIS. PARTES MAIORES E CAPAZES. POSSIBILIDADE. A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, não impede que haja um novo acordo sobre o destino dos referidos bens. (REsp 1.623.475-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

CAPÍTULO 12 — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

1. LIQUIDAÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em regra, **a sentença ou a decisão parcial de mérito devem ser líquidas**, ainda que decidam pedido genérico, de modo a permitir que a parte possa iniciar, desde logo, a fase de cumprimento em que buscará a implementação da tutela satisfativa.

Ocorre que, em determinadas hipóteses, poderá haver a prolação de **sentença ou de decisão parcial de mérito que, conquanto obrigue o réu a pagar quantia, não possa imediatamente ser executada porque dependa de liquidação**, isto é, de atividade de apuração de valor que não seja apenas cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC).

Com efeito, dispõe o art. 491, *caput* e incisos, CPC, que a decisão que resolver ação cujo pedido seja uma obrigação de pagar quantia deverá, desde logo, definir a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, salvo se: (i) não for possível determinar, definitivamente, o montante devido; (ii) a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa.

Não se trata, sublinhe-se, de uma nova ação, procedimento ou incidente, mas, sim, de uma **fase do processo de conhecimento ulterior à sentença ou decisão parcial**, de natureza **cognitiva**, em que se pretende a apuração da quantia devida (*quantum debeatur*) sobre obrigação já reconhecida anteriormente (*an debeatur*)⁴¹.

É inadmissível que haja nova discussão acerca da lide e modificação da decisão de mérito transitada em julgado (art. 509, §4º, CPC) na liquidação de sentença, mas a simples modificação do critério de liquidação inicialmente fixado na decisão de mérito – por exemplo, por não ter se vislumbrado, naquela ocasião, a necessidade de produção de prova sobre fato novo – não ofende a coisa julgada que se formou anteriormente⁴².

A liquidação, que poderá ser **iniciada pelo credor ou também pelo devedor** (art. 509, *caput*, CPC), poderá ser **definitiva**, se fundada em título judicial transitado em julgado, ou **provisória**, quando baseada em título judicial ainda suscetível de modificação por recurso, caso em que caberá ao liquidante **instruir o pedido** com cópia das peças processuais pertinentes (art. 512, CPC), dispensada a prestação de **caução** (art. 356, §2º, CPC).

Se a sentença ou a decisão parcial de mérito reconhecerem a existência de obrigação que seja **parte líquida e parte ilíquida**, é admissível a **tramitação simultânea** das fases de cumprimento da parte líquida e de liquidação da parte ilíquida (art. 509, §1º, CPC), formando-se, se o caso, autos suplementares para que não haja prejuízo ao processo principal (art. 356, §4º, CPC).

A decisão que colocar fim à fase, liquidando a sentença para estabelecer o valor devido, terá natureza **interlocutória** e, como todas as demais proferidas nessa fase processual, será impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC)⁴³, salvo se, excepcionalmente, **da liquidação resultar a extinção da própria execução**, caso em que possuirá natureza de sentença e, assim, será impugnável por apelação⁴⁴.

⁴¹ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 931.

⁴² Súmula 344/STJ: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

⁴³ Enunciado 145 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento”.

⁴⁴ Nesse sentido: AgInt no REsp 1.776.299/AM, 4ª Turma, DJe 27/11/2019, rel. Ministro Marco Buzzi.



Na forma do art. 509, I e II, CPC, há duas espécies de liquidação: por **arbitramento** ou pelo **procedimento comum** (anteriormente chamada de liquidação por artigos).

1.2. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

A **liquidação por arbitramento** será cabível “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação” (art. 509, I, CPC).

Essa modalidade de apuração incidirá, pois, quando a decisão que reconhecer a existência do dano (*an debeatur*) estabelecer que o valor do dano (*quantum debeatur*) será apurado por arbitramento, quando as partes, por meio de negócio jurídico processual, estabelecerem que o valor do dano será apurado por arbitramento ou, ainda, quando a natureza do objeto da liquidação exigir que a apuração se dê na forma de arbitramento. Todas as hipóteses estão assentadas na **impossibilidade de fixação do valor na fase de conhecimento** em razão de complexidade fática justificadora da postergação da fixação do *quantum debeatur*, inclusive mediante realização de prova pericial, se necessário.

Na liquidação por arbitramento, as partes serão intimadas a apresentar **pareceres** ou **documentos elucidativos**, a fim de viabilizar a **tomada de decisão judicial de plano** acerca do valor devido (ou seja, sem a necessidade de prova pericial, que não é mais obrigatória) ou, ao menos, para **municar o perito** que vier a ser designado para a apuração do valor devido (art. 510, CPC), que deverá desenvolver o seu mister em observância das regras que disciplinam a prova pericial (art. 464, CPC).

1.3. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM

A principal característica dessa espécie de liquidação é a **necessidade de alegação e de produção de prova sobre fato novo**, o que significa dizer, pois, que nem todos os elementos fático-probatórios indispensáveis para a apuração do *quantum debeatur* estavam presentes por ocasião do julgamento do mérito da causa.

O **fato novo** a que se refere o art. 509, II, CPC, é aquele “*ocorrido antes ou depois da propositura da ação, mas que tenha íntima relação com a determinação do valor ou da extensão da obrigação declarada pela sentença ilíquida, se o fato for preexistente, deve ter sido desconsiderado, devendo ser objeto, nesse momento, de cognição judicial, exclusivamente destinada a precisar o valor ou extensão da obrigação*”⁴⁵.

É o caso, por exemplo, de ação indenizatória ajuizada em decorrência de acidente de trânsito, na qual não se podem precisar, desde logo, todas as consequências que permitirão a precificação integral da obrigação (danos no veículo que era utilizado em atividade laborativa, danos à pessoa que terá de se submeter a diversas cirurgias e tratamentos estéticos, etc.), hipótese em que será estabelecida, na fase de conhecimento, a **obrigação de reparar os danos** (*an debeatur*), mas somente poderá ser fixada, na fase de liquidação, a exata **dimensão dos danos** (*quantum debeatur*) **mediante prova de novos fatos** (qual era o lucro líquido obtido com o uso comercial do veículo abalroado, quantos e quais tratamentos serão necessários para o pleno restabelecimento da vítima do acidente, etc.).

Na liquidação pelo procedimento comum, admite-se a ocorrência da denominada **liquidação zero**, cabível quando a parte não consegue provar o valor do prejuízo ou quando se encontra, realmente, o valor zero. A **liquidação zero**, de incidência rara, justifica-se porque a conclusão contida

⁴⁵ ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 925.

na decisão de mérito, porque genérica, é também hipotética, podendo vir a ser apurado, apenas posteriormente, que embora fosse provável a ocorrência de dano decorrente do ato ilícito, concretamente não houve dano (ou não foi ele comprovado)⁴⁶.

Em síntese, como destaca a doutrina:

Somente a liquidação pelo procedimento comum pode resultar negativa, dado que nela se tem de provar fato novo, porque o an debeatur foi fixado na sentença sem grau de extensão (a caracterizar-se pela prova do que deve ser liquidado). A liquidação por arbitramento, porque já se fixou o an debeatur, em extensão máxima indiscutível, por decisão transitada em julgado (CPC 509 §4º), é impossível resultar negativa: o perito terá de, forçosamente, atribuir um valor à condenação já determinada pela sentença de conhecimento transitada em julgado, sob pena de ofender-se a coisa julgada, negando-se vigência ao CPC 509 §4º⁴⁷.

Procedimentalmente, a única particularidade dessa espécie de liquidação é que o requerido será intimado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, contestar em 15 dias, seguindo-se, a partir daí, o procedimento comum (arts. 318 e seguintes, CPC).

2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Proferida decisão de mérito transitada em julgado ou contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo, poderá o vencedor dar início à fase de cumprimento do julgado. Trata-se de mera fase procedimental e de não de nova ação, desde a reforma realizada no CPC/73 pela Lei 11.232/2005 que estabeleceu o **sincetismo** entre as fases de conhecimento e cumprimento do julgado.

Embora prevista na parte geral do cumprimento de sentença, a regra do art. 513, §1º, CPC, diz respeito apenas ao **cumprimento de julgado que reconheça a obrigação de pagar quantia**, na medida em que, para as demais obrigações (fazer, não fazer ou dar coisa distinta de dinheiro), o desenvolvimento da fase de cumprimento **poderá se dar independentemente de requerimento da parte vencedora** (art. 536, *caput*, CPC), por se entender que, no pedido deduzido na petição inicial, estão compreendidas as medidas necessárias à implementação do julgado, que poderão ser adotadas, inclusive, de ofício⁴⁸.

Há **determinados títulos judiciais** que, por serem formados fora do juízo cível, **somente poderão ser objeto de cumprimento mediante requerimento da parte**, independentemente da natureza da obrigação (se de pagar quantia, fazer, não fazer ou dar coisa distinta de dinheiro). Tais hipóteses estão elencadas no art. 515, VI a IX, CPC, a saber: sentença penal condenatória transitada em julgado; sentença arbitral; sentença estrangeira homologada pelo STJ; decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do *exequatur* à carta rogatória pelo STJ, havendo, nesses casos, inclusive a necessidade de citação de quem deva cumprir o julgado (art. 515, §1º, CPC).

Também na forma do art. 513, §1º, CPC, o cumprimento poderá ser **provisório** (cumprimento de decisão contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo) ou **definitivo** (cumprimento de

⁴⁶ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 923.

⁴⁷NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.354.

⁴⁸NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.023/1.024.



decisão transitada em julgado). O **cumprimento provisório do julgado deverá, obrigatoriamente, ser iniciado a requerimento da parte vencedora**, independentemente da natureza da obrigação (se de pagar quantia, fazer, não fazer ou dar coisa distinta de dinheiro), na medida em que eventual reversão do julgado em grau recursal implicará em obrigação de reparar os danos causados ao executado (art. 520, I, CPC).

Iniciado o cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou da decisão parcial de mérito, deverá o executado ser **intimado**, na forma do art. 513, §2º, I a VI, CPC, para cumpri-la. A **intimação** ocorrerá: (i) pelo **Diário da Justiça**, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; (ii) por **carta com AR**, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, **ressalvada a hipótese de citação por edital seguida de revelia na fase de conhecimento**, caso em que o executado deverá novamente ser intimado por edital na fase de cumprimento; (iii) **por meio eletrônico**, quando se tratar de empresa pública ou privada (exceto microempresa ou empresa de pequeno porte) que não tenha procurador constituído nos autos.

Não se pode olvidar que, na vigência do CPC/73, havia entendimento no sentido de que “a parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes”⁴⁹, que fora posteriormente cristalizado na Súmula 410/STJ⁵⁰.

Ocorre que, a despeito da literalidade da norma que dispensa a intimação pessoal da parte como regra, fixou-se o entendimento, no novo CPC, de que “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, **nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil**”⁵¹.

Em síntese, para as **obrigações de quantia**, o executado deverá, em regra, ser **intimado para pagar na pessoa de seu advogado** (art. 513, §2º, I, CPC), salvo se o requerimento de cumprimento do julgado ocorrer **após 01 ano do trânsito em julgado**, caso em que a intimação deverá ser **pessoal** (art. 513, §4º, CPC). De outro lado, para as **obrigações de fazer e não fazer**, o executado deverá ser **pessoalmente intimado para cumprir** o julgado.

Nas hipóteses em que necessária a intimação pessoal do executado, será válida a **intimação entregue no endereço que havia sido por ele declinado** no processo, inclusive na hipótese em que tenha ele mudado de endereço sem comunicação prévia ao juízo (art. 513, §3º, CPC).

Na forma do art. 513, §5º, CPC, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que **não tiver participado da fase de conhecimento**. Com esse dispositivo, pretende-se reafirmar que o executado é aquele que consta como tal no título executivo (art. 779, I, CPC) e, além disso, generalizar antigo entendimento materializado na Súmula 268/STJ⁵², de modo a confirmar que, conquanto fiador, coobrigado ou corresponsável possam responder pela dívida, a eles deve ser assegurado o contraditório ainda na fase de conhecimento, ressalvadas as hipóteses de sucessão processual do executado.

Os **títulos executivos judiciais suscetíveis de cumprimento** pelo rito estipulado nos arts. 513 e seguintes, CPC, são aqueles enumerados nos incisos do art. 515, CPC, quais sejam: (i) as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; (ii) a decisão homologatória de autocomposição judicial, que poderá envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido

⁴⁹ Nesse sentido: AgRg no Ag 774.196/RJ, 3ª Turma, DJ 09/10/2006, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros.

⁵⁰ Súmula 410/STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

⁵¹ Nesse sentido: EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 07/03/2019, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

⁵² Súmula 268/STJ: “O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado”.

deduzida em juízo (art. 515, 2º, CPC); (iii) a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; (iv) o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal; (v) o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; (vi) a sentença penal condenatória transitada em julgado; (vii) a sentença arbitral; (viii) a sentença estrangeira homologada pelo STJ; e (ix) a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ.

No que se refere à **competência** para a fase de cumprimento da sentença, anote-se que o art. 516, I, CPC, contém regra de **competência de natureza absoluta** (pois cabe aos Tribunais, sem exceção, cumprir os julgados proferidos nas causas de sua competência originária), ao passo que o art. 516, II e III, CPC, prevê regras de **competência de natureza relativa**⁵³, pois o juízo cível que proferiu a decisão de mérito em 1º grau e o juízo competente para o cumprimento de sentença penal condenatória, de sentença arbitral e de sentença estrangeira, poderão ser **modificados mediante requerimento do exequente**.

Com efeito, em tais hipóteses, *“o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”* (art. 516, parágrafo único, CPC).

Sublinhe-se, ainda, que especificamente nas **execuções de alimentos**, a regra do art. 528, §9º, CPC, também acrescenta a possibilidade de o cumprimento ocorrer no juízo de domicílio do credor dos alimentos.

Esse requerimento poderá, inclusive, ser realizado **após o início** do cumprimento de sentença no foro em que proferida a sentença, não se submetendo à regra da *perpetuatio jurisdictionis* (art. 43, CPC), razão pela qual é correto afirmar que o art. 516, parágrafo único, CPC, prevê a possibilidade de um **cumprimento de sentença itinerante**⁵⁴⁻⁵⁵.

Ademais, sublinhe-se que o art. 517, *caput*, CPC, prevê, expressamente, a possibilidade de **protesto da decisão judicial de mérito que contenha obrigação de pagar quantia certa transitada em julgado**, o que poderá ser requerido após o prazo para pagamento voluntário da condenação pelo executado, bastando que o exequente forneça ao cartório certidão de teor da decisão que será fornecida, em 03 dias, pelo juízo em que tramita o cumprimento (art. 517, §1º e 2º, CPC), podendo o executado que houver ajuizado ação rescisória contra a decisão que se pretende cumprir requerer a anotação deste fato à margem do título protestado (art. 517, §3º, CPC). O **cancelamento do protesto**, que ocorrerá mediante requerimento do executado após a satisfação integral da obrigação, será determinado pelo juiz em ofício para o cartório, que deverá ser expedido em até 03 dias contados do requerimento pelo executado (art. 517, §4º, CPC).

Finalmente, observe-se que o art. 518, CPC, estabelece que *“todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz”*.

Além de se tratar de dispositivo que simplifica o procedimento na fase de cumprimento, não se pode olvidar que se extrai, da referida regra, a **positivação da exceção de pré-executividade**, defesa atípica do executado que, conquanto não existente na lei, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência na vigência do CPC/73, cabível *“em qualquer tempo e grau de*

⁵³ NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil comentado*. 16ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.379; ASSIS, Araken. *Manual da execução*. 20ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 528/530.

⁵⁴ DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de direito processual civil: execução*. 9ª edição. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 488/489.

⁵⁵ Nesse sentido: REsp 1.776.382/MT, 3ª Turma, DJe 05/12/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

*jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória*⁵⁶.

3. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

De início, é preciso destacar que o **cumprimento provisório** será regido, em princípio, pelas mesmas regras aplicáveis ao **cumprimento definitivo** da decisão de mérito (art. 527, CPC), salvo, como bem se destaca na doutrina, nas hipóteses em que **há regra especial** do cumprimento provisório que afaste a incidência da regra geral do cumprimento definitivo e nas quais **não há compatibilidade** entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo⁵⁷.

Fixada essa premissa, sublinhe-se que o art. 520, I a IV, CPC, fixa **regras que se aplicam especificamente ao cumprimento provisório** da decisão judicial e que se justificam pela precariedade do título executivo em que se funda a execução, eis que poderá ser modificado por ocasião do julgamento de recurso.

Assim, o **cumprimento provisório**: (i) correrá por **iniciativa e responsabilidade** do exequente, que se **obriga**, se a decisão for reformada, a **reparar os danos** causados ao executado, independentemente da aferição de culpa ou dolo (responsabilidade objetiva); (ii) ficará **sem efeito**, total ou parcialmente, se sobrevier **decisão que modifique ou anule** a decisão exequenda, no todo ou em parte, restituindo-se as partes ao estado anterior (salvo se já houver sido implementada a transferência ou alienação – art. 520, §4º, CPC) e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; (iii) dependerá de **caução suficiente e idônea**, arbitrada de plano e prestada no próprio cumprimento, quando se pretender o **levantamento de dinheiro** ou a **prática de atos que importem em transferência de posse** ou em **alienação de propriedade** ou de **outro direito real** ou dos quais possa resultar **grave dano** ao executado.

Especificamente no que se refere à **caução**, dispõe o art. 521, I a IV, CPC, que poderá ser ela **dispensada** quando: (i) o crédito for de **natureza alimentar**, independentemente de sua origem; (ii) o credor demonstrar **situação de necessidade**; (iii) **pender de julgamento o agravo** em recurso especial ou extraordinário (art. 1.042, CPC); (iv) a **decisão que se pretende cumprir estiver em consonância** com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ, em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos (recursos especial e extraordinário repetitivo e IRDR) e, ainda, em IAC⁵⁸. Em todas essas hipóteses, todavia, a **caução**, ainda assim, **poderá ser mantida**, se de sua dispensa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, CPC).

Ao mesmo tempo em que prevê hipóteses em que o regime do cumprimento definitivo não se aplicará ou sofrerá modificações de modo a amoldá-lo às especificidades do cumprimento provisório, o novo CPC também disciplina algumas **situações em que poderia haver dúvida sobre a aplicabilidade, ou não, de determinada regra**, prevista apenas para o cumprimento definitivo, ao cumprimento provisório.

Daí porque o art. 520, §1º, CPC, destaca ser **cabível a impugnação** ao cumprimento de decisão provisória (art. 525, caput, CPC), bem como o art. 520, §2º, CPC, estabelece também serem cabíveis a **multa** e os **honorários advocatícios**, no cumprimento provisório do julgado, na hipótese de não cumprimento voluntário pelo devedor (art. 523, §1º, CPC), superando-se consolidada

⁵⁶Nesse sentido: EREsp 905.416/PR, 2ª Seção, DJe 20/11/2013, rel. Ministro Marco Buzzi.

⁵⁷GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 713.

⁵⁸Enunciado 136 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A **caução exigível em cumprimento provisório de sentença poderá ser dispensada se o julgado a ser cumprido estiver em consonância com tese firmada em incidente de assunção de competência**”.

jurisprudência do STJ⁵⁹. Justamente por isso é que o art. 520, §3º, CPC, estabelece que o depósito tempestivo do valor, apenas com a finalidade de se isentar da multa, **não configura ato incompatível com o recurso** do devedor.

Do ponto de vista **procedimental**, sublinhe-se que o cumprimento será requerido pelo exequente por petição e, se os autos não forem eletrônicos, o requerimento deverá ser instruído com cópia da decisão exequenda, da certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, das procurações outorgadas pelas partes, da decisão de habilitação (se houve falecimento após o ajuizamento da ação) e, facultativamente, de outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito (art. 522, parágrafo único, I a V, CPC).

Finalmente, registre-se que essa disciplina se aplicará ao cumprimento provisório de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e, ainda, no que couber, igualmente à decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa (art. 520, §5º, CPC).

4. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

No que se refere ao **cumprimento definitivo** da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, deverá haver requerimento do exequente para regular início da fase de cumprimento, caso em que o executado será intimado, em regra na pessoa de seu advogado (art. 513, §2º, I, CPC), para **pagar o débito no prazo de 15 dias**, acrescido de custas, se houver (art. 523, *caput*, CPC).

Embora haja sólida divergência doutrinária sobre a **natureza jurídica** do prazo previsto no art. 523, *caput*, CPC (se **processual**, pois seria ato executivo de natureza mandamental⁶⁰; ou se **material**, pois seria ato a ser cumprido especificamente pela parte, independentemente de seu advogado⁶¹) e, conseqüentemente, se deveria ser ele **contado em dias em dias úteis ou corridos** (a teor do art. 219, *caput*, CPC), fato é que já se decidiu no STJ se tratar de **prazo processual que deve ser contado em dias úteis**⁶². No mesmo sentido, sublinhe-se que há enunciado da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF⁶³.

Como anteriormente destacado, o **não pagamento voluntário** no prazo de **15 dias úteis** acarretará o acréscimo de **multa de 10%** e, ainda, de **honorários advocatícios também de 10%**, ambos calculados sobre o valor do débito (art. 523, §1º, CPC), deflagrando ainda a expedição de mandado de penhora e avaliação e os subsequentes atos de expropriação (art. 523, §3º, CPC). Na hipótese de pagamento **tempestivo**, mas **parcial**, sobre o restante do valor incidirão a multa e os honorários advocatícios (art. 523, §2º, CPC).

Como já se decidiu no STJ, *“a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito”*⁶⁴, mas, ao revés, a referida multa não incidirá na

⁵⁹ Nesse sentido: REsp 979.922/SP, 4ª Turma, DJe 12/04/2010, rel. Ministro Aldir Passarinho Junior; REsp 1.209.422/SP, 2ª Turma, DJe 10/12/2010, rel. Ministro Castro Meira.

⁶⁰ ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 955.

⁶¹ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 979/980.

⁶² Nesse sentido: REsp 1.708.348/RJ, 3ª Turma, DJe 01/08/2019, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; REsp 1.693.784/DF, 4ª Turma, DJe 05/02/2018, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

⁶³ Enunciado 89 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: *“Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC”*.

⁶⁴ Nesse sentido: REsp 1.803.985/SE, 3ª Turma, DJe 21/11/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.



hipótese em que o devedor faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e, conquanto informe que se trata de medida visando obter futuro efeito suspensivo e garantir o juízo, efetivamente **não apresenta a impugnação**⁶⁵.

Na forma do art. 524, *caput*, I a VII, CPC, o **requerimento de início da fase de cumprimento deverá ser instruído** com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a **petição conter**: (i) nome completo, o CPF ou CPJ do exequente e do executado, facultada a localização desses dados mediante diligência judicial (art. 319, §1º a §3º, CPC); (ii) índice de correção monetária adotado; (iii) juros aplicados e as respectivas taxas; (iv) os termos inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados; (v) periodicidade da capitalização dos juros, se o caso; (vi) especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; (viii) indicação dos bens passíveis de penhora, quando possível.

É lícito ao juiz, se verificar que o valor apontado pelo exequente no cumprimento é, aparentemente, superior à condenação, **limitar a penhora ao valor que reputar como adequado** (art. 524, §1º, CPC).

Se houver **dúvida acerca dos cálculos**, poderá o juiz se valer de contabilista do juízo, que deverá verificar os cálculos em 30 dias ou no prazo que lhe for fixado (art. 524, §2º, CPC). Se os **documentos** necessários para a **elaboração do demonstrativo** estiverem em poder de **terceiros** ou do **executado**, poderá o juiz requisitá-los, sob pena de incidirem em **crime de desobediência** (art. 524, §3º, CPC). Se a **complementação do demonstrativo** depender de **dados** que se encontrem em poder do executado, o juiz poderá requisitá-los, a requerimento do exequente, para apresentação em até 30 dias, sob pena de a recusa injustificada acarretar a **presunção de correção dos cálculos** apresentados pelo exequente com base nos dados que dispunha (art. 524, §4º e §5º, CPC).

Transcorrido o prazo de 15 dias úteis sem pagamento do executado, terá início, automaticamente após (inclusive dispensando-se nova intimação se da anterior constarem ambos os prazos para o executado, para pagar e para impugnar⁶⁶), o prazo de **15 dias úteis para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença** (art. 525, *caput*, CPC), cuja natureza jurídica é, segundo a doutrina majoritária, de **incidente processual de defesa**⁶⁷. Esse prazo deverá ser contado **em dobro** na hipótese de executados com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, em processos físicos (art. 525, §3º, CPC).

Na referida defesa, cujo exercício **não depende de penhora ou garantia do juízo**, poderá o executado alegar **apenas**: (i) falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; (ii) ilegitimidade de parte; (iii) inexecutabilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (iv) penhora incorreta ou avaliação errônea; (v) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (vi) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; (vii) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 525, §1º, I a VII, CPC).

Também poderá o executado alegar o **impedimento** ou a **suspeição** do juiz (art. 525, §2º, CPC), mas, nesses casos, não deverá fazê-lo na impugnação ao cumprimento de sentença e, sim, por meio do **incidente** previsto nos arts. 146 e 148, CPC.

No conceito de **obrigação inexigível** apta a justificar a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, III, CPC), também está compreendida a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado **inconstitucional** pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como **incompatível com a CF/88**, em controle **concentrado** ou **difuso** (art. 525, §12, CPC), desde que o julgado do STF

⁶⁵ Nesse sentido: REsp 1.834.337/SP, 3ª Turma, DJe 05/12/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁶⁶ Enunciado 92 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: "A intimação prevista no caput do art. 523 do CPC deve contemplar, expressamente, o prazo sucessivo para impugnar o cumprimento de sentença".

⁶⁷ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 992.



seja **anterior ao trânsito em julgado** da decisão exequenda (art. 525, §14, CPC), pois, se posterior, será ele **rescindível** (art. 525, §15, CPC). Exatamente a **mesma regra se aplica ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública** (art. 535, §5º a 8º, CPC).

Se porventura alegar **excesso de execução**, deverá o executado declarar desde logo o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de, não apontando ou não apresentando o demonstrativo, ser liminarmente rejeitada a impugnação (se o excesso for o seu único fundamento) ou, se houver outro fundamento, será a impugnação processada, mas sem que seja examinado o excesso (art. 525, §4º e §5º, CPC).

De regra, a impugnação **não impedirá que a decisão exequenda produza efeitos** (inclusive mediante a prática de atos expropriatórios), ou seja, é correto afirmar que a impugnação **não tem efeito suspensivo ope legis**, podendo-lhe atribuir esse efeito o juiz, **ope judicis**, desde que, **cumulativamente**: (i) haja requerimento do executado; (ii) haja garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes; (iii) a fundamentação seja relevante; (iii) o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, §6º, CPC).

Ainda assim, o efeito suspensivo suscetível de deferimento na impugnação **não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens** (art. 525, §7º, CPC), partindo o legislador da premissa de que tais atos, **em nenhuma hipótese**, resultarão em situação que justifique a concessão de efeito suspensivo *ope judicis*⁶⁸. Se o efeito suspensivo atribuído à impugnação versar apenas sobre **parte do objeto** da execução, esta **prosseguirá quanto à parte restante** (art. 525, §8º, CPC). Em regra, **não haverá ampliação subjetiva do efeito suspensivo concedido a um dos executados**, salvo quando se tratar de fundamento que a todos aproveita (art. 525, §9º, CPC).

Finalmente, **mesmo quando atribuído efeito suspensivo** à impugnação, poderá o exequente requerer o prosseguimento da execução, desde que **prestada caução suficiente e idônea** a ser arbitrada pelo juiz (art. 525, §10, CPC).

Sublinhe-se, ademais, que o art. 525, §11, CPC, prevê que, havendo a necessidade de debater fato superveniente ocorrido após o término do prazo para apresentação da impugnação, bem como matérias relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, deverá o executado suscitá-las, por simples petição, no prazo de **15 dias contados da ciência do fato ou da intimação do ato**, conforme o caso.

Da decisão que resolver a impugnação ao cumprimento do julgado caberá **agravo de instrumento** (art. 1.015, parágrafo único, CPC), salvo se, do acolhimento da impugnação, resultar a **extinção do cumprimento de sentença**, caso em que o recurso cabível será a **apelação**⁶⁹.

Finalmente, sublinhe-se que o novo CPC prevê, no art. 526, *caput* e parágrafos, a possibilidade de a **parte vencida cumprir espontaneamente a obrigação antes mesmo de ser intimada** para fazê-lo em cumprimento iniciado pela parte vencedora.

Nesse caso, o devedor ofertará o pagamento do valor que entender devido e apresentará demonstrativo de cálculo, intimando-se o credor que, em **05 dias**, poderá: (i) **impugnar o valor depositado**, caso em que poderá desde logo levantar a parte incontroversa; (ii) **não se opor**, caso em que o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

Anote-se, ademais, que se o juiz entender que o depósito realizado pelo vencido foi **insuficiente**, sobre a diferença apurada incidirão multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,

⁶⁸ GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 753.

⁶⁹ Enunciado 93 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: "Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não o fizer".

podendo prosseguir a fase de cumprimento com a penhora e os atos subsequentes para a satisfação da diferença.

5. CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS

Conquanto se trate de obrigação de pagar quantia certa, a execução de **alimentos** possui procedimento diferenciado, claramente mais protetivo ao exequente, em virtude das peculiares necessidades do direito material em debate, com ênfase, sobretudo, na possibilidade de prisão civil do devedor como técnica coercitiva para evitar o inadimplemento.

Em primeiro lugar, registre-se que se submete ao rito especial do art. 528 e seguintes, CPC, o cumprimento **provisório** (alimentos provisionais ou provisórios) ou **definitivo** (alimentos definitivos) (art. 531, *caput*, CPC) de decisão judicial que fixe **alimentos legítimos** (isto é, decorrentes de vínculo familiar). A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de **não se aplicar o rito especial** de execução sob pena de prisão aos **alimentos devidos em razão de ato ilícito** (também chamados de indenizatórios)⁷⁰.

Iniciado o cumprimento a pedido do exequente, o juiz determinará a intimação do executado para, em **03 dias úteis contados na forma do art. 231, I a VIII, CPC**⁷¹, a **pagar, provar que pagou** ou justificar a **absoluta impossibilidade de pagar** (art. 528, *caput* e §2º, CPC). A jurisprudência do STJ se consolidou, por exemplo, no sentido de que a existência de outra prole e o desemprego do alimentante não são justificativas aceitáveis para o inadimplemento da obrigação de natureza alimentar⁷².

Não havendo pagamento, prova de pagamento ou justificativa de absoluta impossibilidade de pagar, o juiz mandará **protestar** decisão judicial (art. 528, §1º, CPC) e **decretará a prisão civil** do devedor, pelo **período de 01 a 03 meses** (art. 528, §3º, CPC), a ser cumprida em **regime fechado** e devendo o **preso ficar separado** dos presos comuns (art. 528, §4º, CPC), **sem que isso signifique perdão ou inexigibilidade do pagamento** das prestações vencidas e vincendas (art. 528, §5º, CPC).

Especificamente quanto ao **prazo da prisão civil**, sublinhe-se que há julgado do STJ no sentido de que *“não há óbice legal para que a prisão civil, técnica de coerção típica disponível para assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações de conteúdo alimentar, seja modulada ou ajustada, quanto à forma ou ao prazo, para atender às suas finalidades essenciais”*, razão pela qual *“nada impede que, decretada inicialmente no prazo mínimo legal, seja posteriormente objeto de prorrogação, observando-se o prazo máximo fixado em lei, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos”*⁷³.

Ainda a esse respeito, saliente-se haver divergência doutrinária quanto ao prazo da prisão civil, tendo em vista que o novo CPC não revogou expressamente o art. 19 da Lei 5.478/1968: (i) nos alimentos provisionais, o prazo seria de 1 a 3 meses, mas nos alimentos definitivos o prazo seria, no máximo, de 60 dias; (ii) o prazo seria sempre de 1 a 3 meses, independentemente de se tratar de alimentos provisionais ou definitivos; (iii) o prazo seria sempre de até 60 dias, independentemente de se tratar de alimentos provisionais ou definitivos⁷⁴.

⁷⁰ Nesse sentido: HC 182.228/SP, 4ª Turma, DJe 11/03/2011, rel. Ministro João Otávio de Noronha; HC 35.408/SC, 3ª Turma, DJe 29/11/2004, rel. Ministro Castro Filho.

⁷¹ Enunciado 146 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: *“O prazo de 3 (três) dias previsto pelo art. 528 do CPC conta-se em dias úteis e na forma dos incisos do art. 231 do CPC, não se aplicando seu § 3º”*.

⁷² Nesse sentido: RHC 92.211/SP, 3ª Turma, DJe 02/03/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁷³ Nesse sentido: RHC 92.211/SP, 3ª Turma, DJe 02/03/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁷⁴ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.008.



De outro lado, destaque-se que, na forma do art. 528, §7º, CPC, o débito de natureza alimentar que autoriza a prisão civil é aquele que compreende **até as 03 prestações anteriores ao ajuizamento** da execução e **as que vencerem no curso do processo**. Trata-se de regra que reproduz fielmente o teor da Súmula 309/STJ⁷⁵, bastando, para a decretação da prisão, que haja o inadimplemento de apenas uma parcela, ainda que parcialmente⁷⁶.

Há precedentes relativizando, em **circunstâncias excepcionais**, a obrigatoriedade de decretação da prisão civil do devedor de alimentos, como, por exemplo, na hipótese que envolva **obrigação alimentar entre ex-cônjuges em que o alimentado, maior e capaz, já havia se recolocado profissionalmente**, ocasião em que se entendeu que a prisão civil só se justificaria se: (i) fosse indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; (ii) fosse atingido o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil – garantir a sobrevivência do alimentado; (iii) fosse a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor⁷⁷.

Em situações semelhantes, afastou-se a prisão civil do devedor de alimentos quando o **credor já havia atingido a maioridade civil e já possuía formação em curso superior ou exercia atividade profissional remunerada**, facultando-se ao credor a possibilidade de se valer de “*quaisquer outras medidas típicas e atípicas de coerção ou de sub-rogação, como autoriza o art. 139, IV, do CPC/15*” em substituição à técnica executiva típica⁷⁸, inclusive se se tratar de obrigação alimentar avoenga⁷⁹.

É certo, contudo, que a questão ainda é polêmica no âmbito do STJ e há precedente que **expressamente não acolhe a possibilidade de flexibilização**⁸⁰, inclusive porque o art. 528, §8º, CPC, estabelece ser um **direito do credor optar** pela execução sob o rito da prisão ou sob o rito da expropriação, que somente se tornará o regime a ser observado se a técnica coercitiva da prisão civil e a técnica sub-rogatória do desconto em folha de pagamento não forem suficientemente eficazes para vencer a renitência do devedor (art. 530, CPC).

Quanto à técnica de **desconto em folha de pagamento do valor da prestação alimentícia**, é correto afirmar que será ela admissível quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho (art. 529, *caput*, CPC), sendo certo que a medida será implementada mediante **ofício judicial** à autoridade, empresa ou empregador (art. 529, §1º, CPC) que **conterá** nome, número do CPF do exequente e do executado, importância a ser descontada mensalmente, tempo de sua duração e conta na qual deve ser feito o depósito (art. 529, §2º, CPC).

O desconto pela autoridade, empresa ou empregador é **obrigatório** desde a primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício, sob pena de **crime de desobediência** (art. 529, §1º, CPC).

Ademais, o art. 529, §3º, CPC, prevê a possibilidade de desconto de parcelas **vincendas e também vencidas** mediante a técnica de desconto em folha de pagamento, parceladamente, desde que, somadas, **não ultrapassem 50% do ganho líquido** do devedor. Trata-se de regra que incorpora, ao direito positivo, a jurisprudência do STJ que já admitia essa possibilidade⁸¹. Ainda nesse contexto, sublinhe-se que há precedente do STJ no sentido de ser admissível a combinação entre a técnica sub-

⁷⁵ Súmula 309/STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

⁷⁶ Enunciado 147 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “Basta o inadimplemento de uma parcela, no todo ou em parte, para decretação da prisão civil prevista no art. 528, § 7º, do CPC”.

⁷⁷ Nesse sentido: HC 392.521/SP, 3ª Turma, DJe 01/08/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁷⁸ Nesse sentido: RHC 91.642/MG, 3ª Turma, DJe 09/03/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi; HC 437.560/MS, 3ª Turma, DJe 29/06/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi; HC 422.699/SP, 3ª Turma, DJe 29/06/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁷⁹ Nesse sentido: HC 416.886/SP, 3ª Turma, DJe 18/12/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁸⁰ Nesse sentido: HC 413.344/SP, 4ª Turma, DJe 07/06/2018, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

⁸¹ Nesse sentido: AgRg no AREsp 333.925/MS, 3ª Turma, DJe 12/12/2014, rel. Ministro João Otávio de Noronha.



rogatória do desconto em folha e a expropriação de bens do devedor, sempre com vistas ao princípio da máxima efetividade da execução⁸².

Do ponto de vista **procedimental**, anote-se que a execução de alimentos fixados em sentença **não transitada em julgado** serão processados em autos apartados (art. 531, §1º, CPC), ao passo que o cumprimento definitivo de decisão **transitada em julgado** ocorrerá no próprio processo em que proferida (art. 532 §2º, CPC).

Conquanto seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao executado, não se pode olvidar que a sua conduta **procrastinatória** na execução de alimentos gerará, se constatada pelo juiz, do executado, a ciência ao Ministério Público diante dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 532, CPC).

Finalmente, o novo CPC estabelece que, quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos (que poderá ser fixada com base no salário-mínimo, art. 533, §4º, CPC), poderá o requerente pleitear que o **executado constitua capital garantidor que assegure o pagamento do valor mensal da pensão** (art. 533, *caput*, CPC), cabendo ao juiz deferir o pedido independentemente de o executado ter, ou não, patrimônio suficiente ao tempo do requerimento⁸³.

O capital constituído, que poderá ser formado por imóveis, direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras, será **inalienável e impenhorável** enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação (art. 533, §1º e §5º, CPC), permitindo-se, todavia, a sua substituição pelo **desconto em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica** ou, ainda, a requerimento do executado, por **fiança bancária ou garantia real**, em valor a ser arbitrado pelo juiz (art. 533, §2º, CPC).

Se os **ativos que compõem o capital** (e não as partes)⁸⁴ tiverem suas condições econômicas modificadas (como, por ex., excesso de valorização ou de desvalorização), poderá ser pleiteada a redução ou aumento da prestação, conforme o caso (art. 533, §3º, CPC). O processamento desse requerimento se realizará incidentalmente, não sendo necessário o ajuizamento de ação própria⁸⁵.

6. CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA

Ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se aplicam, em larga escala, os mesmos requisitos estabelecidos formais para o cumprimento de sentença contra particulares.

Desse modo, o exequente deverá apresentar petição contendo demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, especificando ainda: (i) o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; (ii) o índice de correção monetária adotado; (iii) os juros aplicados e as respectivas taxas; (iv) o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; (v) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (vi) a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados (art. 534, I a VI, CPC).

⁸²Nesse sentido: REsp 1.733.697/RS, 3ª Turma, DJe 13/12/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

⁸³Súmula 313/STJ: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

⁸⁴GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 789.

⁸⁵ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 976.



Se houver **pluralidade de exequentes**, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, podendo haver, nessa fase, **limitação de litisconsórcio facultativo** (arts. 524, §1º, e art. 113, §1º e 2º, CPC).

Obviamente, não há que se falar, na impugnação apresentada pela Fazenda Pública, em indicação de bens à penhora (art. 524, VII, CPC) e nem tampouco em incidência das multas previstas no art. 523, §1º, CPC, na medida em que a Fazenda Pública **não é intimada para pagar**, mas, sim, para **impugnar**.

A Fazenda Pública possui, como é cediço, forma específica de comunicação dos atos processuais, razão pela qual prevê o art. 535, *caput*, CPC, que será ela “*intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico*”, para, querendo, no **prazo de 30 dias** e nos próprios autos, apresentar **impugnação à execução**, em que poderá arguir: (i) falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; (ii) ilegitimidade de parte; (iii) inexecutibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (iv) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; (vi) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Também poderá a Fazenda Pública alegar o **impedimento** ou a **suspeição** do juiz (art. 535, §1º, CPC), mas, nesses casos, não deverá fazê-lo na impugnação e, sim, por meio do **incidente** previsto nos arts. 146 e 148, CPC.

No conceito de **obrigação inexigível** apta a justificar a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, III, CPC), também está compreendida a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado **inconstitucional** pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como **incompatível com a CF/88**, em controle **concentrado** ou **difuso** (art. 535, §5º, CPC), desde que o julgado do STF seja **anterior ao trânsito em julgado** da decisão exequenda (art. 535, §7º, CPC), pois, se posterior, será ele **rescindível** (art. 535, §8º, CPC).

Se porventura alegar **excesso de execução**, deverá a Fazenda Pública declarar desde logo o valor que entende correto, sob pena não conhecimento da arguição (art. 535, §2º, CPC).

Finalmente, **se não impugnada a execução ou se for rejeitada a impugnação** ofertada pela Fazenda Pública: (i) será expedido, pelo Presidente do Tribunal, **precatório** em favor do exequente, observando-se o disposto na CF/88; (ii) por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de **obrigação de pequeno valor** será realizado no prazo de **2 meses contado da entrega da requisição**, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

7. CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER.

De início, é correto afirmar que o modo de cumprimento das obrigações de fazer e não fazer (também denominado de cumprimento de **tutelas específicas**), inclusive dos deveres legais de fazer e não fazer (art. 536, §5º, CPC), possui algumas **importantes especificidades** em relação ao modo de cumprimento das demais decisões judiciais.

Com efeito, como já assentado anteriormente, a fase de cumprimento dessas obrigações se **iniciará independentemente de requerimento da parte vencedora** (art. 536, *caput*, CPC), pois se

entende que, no pedido deduzido na petição inicial, estão compreendidas as medidas necessárias à implementação do julgado, que poderão ser adotadas, inclusive, de ofício⁸⁶.

Para a implementação do conteúdo da decisão judicial (efetivação da **tutela específica** ou a **obtenção do resultado prático equivalente**), poderá o juiz, também com fundamento no art. 536, *caput*, CPC, **determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente**, indicando o art. 536, §1º, CPC, um **rol exemplificativo de medidas aplicáveis** para que seja cumprida a decisão judicial (imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, entre outras medidas), permitindo-se, inclusive, a aplicação de **multa por litigância de má-fé** por injustificado descumprimento de ordem judicial e, até mesmo, responsabilização do executado por **crime de desobediência** (art. 536, §3º, CPC).

Desse modo, conclui-se que, desse conjunto de dispositivos, resulta uma amplíssima gama de **poderes gerais de efetivação** atribuídos ao juiz, que disporá de um sólido ferramental de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Especificamente quanto à **busca e apreensão**, estabelece o art. 536, §2º, CPC, que o mandado será cumprido por **2 oficiais de justiça**, observando-se as regras do art. 846, §1º a 4º, CPC, se houver necessidade de arrombamento.

Na forma do art. 536, §4º, CPC, o meio apropriado para a defesa do executado, assim como nos demais modelos de cumprimento de decisões judiciais, é a **impugnação** (art. 525, CPC).

Finalmente, o novo CPC procurou disciplinar, de modo mais detalhado, aquela que era a medida de apoio sobre a qual pendiam inesgotáveis controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais: a **multa coercitiva**, também chamada de *astreintes*.

O art. 537, *caput*, CPC, estabelece que a **multa poderá ser aplicada de ofício ou a requerimento**, em **qualquer fase** procedimental, bastando ao juiz apurar a sua **suficiência e proporcionalidade** (o que indica quantificação sempre casuística⁸⁷), bem como a fixação de **prazo razoável** para cumprimento da medida.

Justamente por se tratar de uma técnica **coercitiva**, cujo propósito **não é promover o enriquecimento ilícito** do exequente (a quem caberá recebê-la na hipótese de inadimplemento, art. 537, §2º, CPC), mas, ao revés, somente servir de instrumento apropriado para **dobrar a eventual renitência do devedor**, prevê o art. 537, §1º, I e II, CPC, que o juiz poderá, também de ofício ou a requerimento, **modificar o valor** ou a **periodicidade da multa vincenda** (mas **não da multa vencida**) ou, até mesmo, **excluí-la**, caso verifique que ela se tornou **insuficiente** ou **excessiva** ou, ainda, que o devedor demonstrou **cumprimento parcial superveniente da obrigação** ou **justa causa** para o descumprimento.

Por derradeiro, sublinhe-se que o **momento em que a multa se torna exigível** também é matéria que se pretende disciplinar, motivo pelo qual o art. 537, §3º e 4º, CPC, prevê que a multa coercitiva, embora **devida desde o dia em que configurado o descumprimento**, incidente **enquanto não for adimplida** a obrigação e suscetível de **cumprimento provisório**, podendo, inclusive, o seu **depósito em juízo** ser imediatamente exigido pelo credor, estará, em última análise, sempre **condicionada ao desfecho definitivo da causa**, na medida em que se permite o seu levantamento somente **após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte**, o que sugere que a eventual

⁸⁶ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.023/1.024.

⁸⁷ ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 984.

improcedência do pedido deverá acarretar o cancelamento da multa aplicada ao renitente, como se fixou em julgado do STJ ao tempo do CPC/73⁸⁸.

8. CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA.

Ao cumprimento da decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de entregar coisa se aplica, em regra, o mesmo modo de cumprimento aplicável às obrigações de fazer ou de não fazer (art. 538, §3º, CPC).

Na forma do art. 538, *caput*, CPC, o inadimplemento da obrigação de entregar coisa (igualmente denominada obrigação de dar coisa distinta de dinheiro) gerará a **expedição de mandado de busca e apreensão** (se se tratar de coisa móvel) ou de **imissão na posse em favor do credor** (se se tratar de coisa imóvel).

Estabelece o novo CPC, ademais, que a **retenção** e a **indenização** por benfeitorias feitas na coisa que deverá ser entregue é matéria a ser suscitada em **contestação**, na **fase de conhecimento**, de modo que se pretende, no art. 538, §1º e 2º, CPC, **impedir o debate acerca dessas matérias no âmbito do cumprimento de sentença** (sem prejuízo, evidentemente, de eventual discussão dessas questões em ação autônoma).

QUESTÕES

1- Quanto à fase de liquidação de sentença, assinale a alternativa correta:

- a) É inadmissível a tramitação conjunta de liquidação da sentença na parte ilíquida e de cumprimento de sentença na parte líquida.
- b) Na liquidação por arbitramento, a perícia é sempre indispensável.
- c) Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a citação pessoal do requerido para, querendo, contestar em 15 dias.
- d) A iniciativa para a liquidação da sentença é do credor e do devedor.

2- Quanto à fase de cumprimento de sentença, assinale a alternativa correta:

- a) O cumprimento definitivo de sentença proferida pelo juízo cível que reconheça obrigação de pagar quantia certa deve sempre ser iniciado mediante requerimento da parte e a intimação do vencido para pagamento deve sempre ocorrer mediante intimação pela imprensa oficial, na pessoa de seu advogado constituído.
- b) O cumprimento definitivo de sentença proferida pelo juízo arbitral que reconheça obrigação de fazer deve sempre ser iniciado mediante requerimento da parte e a intimação do vencido para cumprimento poderá ocorrer mediante intimação pela imprensa oficial, na pessoa de seu advogado constituído no processo arbitral.

⁸⁸ Nesse sentido: AgRg no AREsp 333.925/MS, 3ª Turma, DJe 12/12/2014, rel. Ministro João Otávio de Noronha.



c) O cumprimento provisório de sentença proferida pelo juízo cível que reconheça obrigação de não fazer não pode ser iniciado de ofício e a intimação do vencido para cumprimento deve sempre ocorrer mediante intimação pela imprensa oficial, na pessoa de seu advogado constituído.

d) O cumprimento definitivo de sentença proferida pelo juízo cível que reconheça obrigação de fazer pode ser iniciado mediante requerimento da parte e exige a intimação pessoal da parte para cumprimento.

3- João Carlos, advogado, deu início à fase de cumprimento provisório de sentença que condenou José Maria ao pagamento de R\$ 10.000,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Nessa hipótese:

a) Se houver reforma ou anulação da decisão executada, João Carlos será obrigado a reparar os danos causados a José Maria, se agiu com dolo ou culpa.

b) João Carlos deverá prestar caução, que somente não dispensável na hipótese de crédito de natureza alimentar decorrente de alimentos legítimos (isto é, de vínculo familiar).

c) João Carlos deverá prestar caução se pretender o levantamento do depósito realizado por José Maria.

d) É sempre dispensável a caução na hipótese de execução de honorários, ainda que de sua dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.

4- São matérias suscetíveis de impugnação ao cumprimento de sentença:

a) Falta ou nulidade de citação, em qualquer hipótese.

b) Prescrição, inclusive àquela não examinada por ocasião da fase de conhecimento.

c) Excesso de execução, caso em que a impugnação será sumariamente rejeitada se, em se tratando de único fundamento da impugnação, o devedor não apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

d) Somente a incompetência absoluta do juízo da execução, mas não a incompetência relativa do juízo da execução.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: D

Letra A (incorreta). É admissível a tramitação conjunta da liquidação e do cumprimento, conforme autoriza o art. 509, §1º, CPC.

Letra B (incorreta). Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, conforme art. 510, CPC.

Letra C (incorreta). Na liquidação pelo procedimento comum, o requerido será intimado na pessoa de seu advogado para, querendo, contestar em 15 dias, nos termos do art. 511, CPC.

Letra D (correta). Nos termos do art. 509, *caput*, CPC.

2. Gabarito: D



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



Letra A (incorreta). Nem sempre a intimação ocorrerá pela imprensa na pessoa de seu advogado constituído, conforme art. 513, §2º, II, III e IV, e §4º, CPC.

Letra B (incorreta). Em se tratando de cumprimento de sentença arbitral, deverá haver a citação do devedor (art. 515, §1º, CPC).

Letra C (incorreta). O cumprimento pode ser iniciado de ofício (art. 536, caput, CPC) e a intimação deverá ser pessoal (Súmula 410/STJ e EREsp 1.360.577/MG).

Letra D (correta). Nos termos do art. 536, caput, CPC, da Súmula 410/STJ e do EREsp 1.360.577/MG.

3. Gabarito: C

Letra A (incorreta). A responsabilização civil pela execução provisória é objetiva, independentemente de dolo ou culpa, nos termos do art. 520, I e II, CPC.

Letra B (incorreta). A dispensa da caução é dispensável quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, nos termos do art. 521, I, CPC.

Letra C (correta). Nos termos do art. 520, IV, CPC.

Letra D (incorreta). A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, na forma do art. 521, parágrafo único, CPC.

4. Gabarito: D

Letra A (incorreta). Apenas a falta ou nulidade de citação da qual decorreu revelia na fase de conhecimento é suscetível de impugnação, nos termos do art. 525, §1º, I, CPC.

Letra B (incorreta). Somente a prescrição superveniente à sentença é suscetível de impugnação, conforme art. 525, §1º, VII, CPC.

Letra C (correta). Nos termos do art. 525, §4º e 5º, CPC.

Letra D (incorreta). Ambas as incompetências, absoluta e relativas, são arguíveis em impugnação, conforme determina o art. 525, VI, CPC.

CAPÍTULO 13 — PROCESSO DE EXECUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O presente capítulo é dedicado ao estudo da execução fundada em título executivo extrajudicial, cujas normas se aplicam, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva (art. 771, *caput* do CPC). Aplicam-se à execução, também, de forma subsidiária, as disposições previstas no CPC para o processo de conhecimento (art. 771, parágrafo único do CPC).

2. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

Processo de execução nada mais é do que o instrumento vocacionado à satisfação de uma prestação líquida, certa, exigível e exequível, por meio do qual o Estado constringe bens do devedor para a satisfação do credor.

Com efeito, considera-se execução o conjunto de atos jurisdicionais praticados para satisfazer, no plano concreto, o direito do credor reconhecido em um título executivo.

A execução pode ser classificada da seguinte forma:

2.1. EXECUÇÃO COMUM E EXECUÇÃO ESPECIAL

Execução comum é aquela cujo procedimento previsto na lei serve como *procedimento padrão* a títulos executivos diversos. Não há discriminação entre sujeitos ou títulos. É o que ocorre na execução por quantia certa (art. 824 e seguintes do CPC).

Por sua vez, a execução especial é aquela cujo procedimento é específico, em razão do sujeito (ex. execução contra a Fazenda Pública – arts. 911 a 913 do CPC) ou do próprio crédito (ex.: execução de alimentos – arts. 911 a 913 do CPC).

2.2. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

A execução fundada em título executivo judicial (art. 515 do CPC) será realizada por meio do cumprimento de sentença, que pode corresponder a uma fase dentro do mesmo processo em que o título foi constituído (ex.: cumprimento da sentença prolatada nos autos) ou a um processo autônomo (ex.: cumprimento de uma sentença arbitral). O procedimento a ser seguido será o previsto no art. 513 e seguintes do CPC.

A execução fundada em título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC) será realizada sempre por meio de um processo autônomo, unicamente executivo e pode seguir um dos procedimentos previstos no Livro II da Parte Especial.

2.3. EXECUÇÃO DIREITA E EXECUÇÃO INDIRETA

Fala-se em execução direta quando o Estado-juiz adota medidas coercitivas em substituição a qualquer ato que possa ser praticado pelo devedor. Trata-se, portanto, de *execução por sub-rogação* (ex.: busca e apreensão, expropriação de bens etc.).

A execução indireta, por outro lado, ocorrerá quando o cumprimento da obrigação depender da colaboração do devedor. Diz-se *indireta* porque diante da natureza da obrigação, não se mostra

possível a sub-rogação. O Estado, nesse caso, valer-se-á de medidas *indutivas ou coercitivas* (ex.: *astreintes*, na execução para entrega de coisa).

2.4. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E EXECUÇÃO DEFINITIVA

O cumprimento de sentença, por outro lado, pode ser provisório (arts. 520 a 522 do CPC) ou definitivo (arts. 523 e seguintes do CPC). A execução fundada em título extrajudicial, por outro lado, é sempre definitiva.

3. PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO

3.1. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE (OU REALIDADE)

A responsabilidade do devedor é sempre patrimonial. Segundo dispõe o art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. A execução, portanto, não recai sobre a pessoa do executado, mas apenas sobre o seu patrimônio. Daí se dizer, também, que a execução é sempre real.

No tocante à possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos (art. 528, § 3º), não se pode perder de vista que tal medida não é forma de responsabilização pessoal – pois o cumprimento da pena não exige o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º do CPC) –, mas sim meio de coerção para forçar o cumprimento da obrigação. Em outras palavras, a prisão civil do devedor de alimentos é forma de *execução indireta*.

3.2. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO

A execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC). Isso, contudo, não confere ao credor o direito de fazer da execução um mecanismo de vingança ou de agravamento da situação jurídica do devedor.

O princípio da menor onerosidade é extraído do art. 805, *caput* do CPC, segundo o qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

3.3. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO

Como a execução tem por objetivo a satisfação do direito do exequente, o processo executivo é disponível. Isso significa dizer que o credor tem o direito de não executar o devedor, assim como o de desistir da ação já proposta.

A desistência pode se referir a todo o processo executivo (desistência total) ou a apenas a algumas medidas executivas (desistência parcial), conforme prevê o art. 775, *caput* do CPC. Como regra, a desistência da execução ou cumprimento de sentença não depende de consentimento do executado. Contudo, se o executado já tiver oposto embargos à execução ou apresentado impugnação ao cumprimento de sentença – e a depender da matéria suscitada –, a desistência dependerá do consentimento do executado, nos termos do art. 775 do CPC.

Vejamos os possíveis cenários:



- **se o executado não opôs embargos à execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença):** a desistência será homologada independentemente de consentimento do executado e o processo será extinto;
- **se o executado opôs embargos à execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença), mas se limitou a discutir questões processuais:** a desistência será homologada independentemente de consentimento do executado, extinguindo-se a execução e os embargos (ou impugnação ao cumprimento de sentença). Nesse caso, o exequente pagará as custas processuais e os honorários advocatícios;
- **se o executado opôs embargos à execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença), discutindo a relação jurídica material:** a extinção do processo dependerá do consentimento do executado (embargante/impugnante).

3.4. PRINCÍPIO DO EXATO ADIMPLEMENTO (OU ESPECIFICIDADE DA EXECUÇÃO)

A execução deve permitir ao credor obter a tutela específica, ou seja, aquela que seria obtida caso o devedor adimplisse a obrigação de forma voluntária.

Tratando-se de execução que tenha por objeto uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, será possível a sua conversão em perdas e danos quando: a) o credor optar pela conversão; b) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 499 do CPC).

3.5. PRINCÍPIO DO DESFECHO ÚNICO

O processo de execução tem por finalidade única a satisfação do crédito do exequente. Esse é o fim normal que se espera. A extinção do processo executivo somente ocorrerá nas estritas hipóteses previstas no art. 924 do CPC.

Pelo princípio do desfecho único, o processo executivo admite uma única forma de prestação de mérito, qual seja, a satisfação do exequente.

Tal princípio parece ter perdido sua força ao longo dos anos, especialmente a partir do momento em que os tribunais passaram a admitir a alegação de matérias defensivas pelo executado nos próprios autos da execução, por meio da denominada *exceção de pré-executividade*.

Se o executado, por exemplo, no curso da execução, peticiona nos próprios autos para arguir a prescrição intercorrente e o juiz a acolhe, haverá, decerto, uma sentença de mérito, com base no art. 924, V do CPC, favorável ao executado.

4. CONCENTRAÇÃO DOS PODERES DE EXECUÇÃO DO JUIZ

O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva exige que o processo civil municie os atores processuais com instrumentos e técnicas processuais de efetivação da tutela do direito. No âmbito do processo de execução, o princípio da tipicidade – que restringia a atuação do juiz aos meios executivos expressamente previstos na lei – cedeu lugar ao princípio da concentração dos poderes do juiz.

Nos termos do art. 782, *caput* do CPC, “não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá”. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana (art. 782, § 1º do CPC). Ademais, sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará (art. 782, § 2º do CPC).



O juiz pode, ainda, em qualquer momento do processo: a) ordenar o comparecimento das partes; b) advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; c) determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.

5. PARTES NO PROCESSO DE EXECUÇÃO

5.1. LEGITIMIDADE ATIVA

A legitimidade ativa para o processo de execução será, como regra, daquele que detém a qualidade de credor, ou seja, aquele a quem a lei confere título executivo (art. 778, *caput* do CPC). Trata-se de *legitimidade ativa ordinária originária*, pois há coincidência entre as figuras do credor previsto no título e do exequente no processo de execução.

Também terá legitimidade ordinária originária o Ministério Público, nos casos previstos em lei (art. 778, § 1º, I, CPC).

Há casos em que a pessoa autorizada pela lei a propor a ação de execução não coincide com aquela constante como credora no título. Tal legitimidade decorre da transmissão do direito por ato entre vivos ou *causa mortis* (ex.: morte do credor originário, cessão ou sub-rogação).

As hipóteses estão previstas nos incisos II, III e IV do § 1º do art. 778 do CPC. Não há necessidade de consentimento do devedor, ainda que a ação executiva já esteja em curso. Vejamos:

- **o Ministério Público, nos casos previstos em lei;**
- **o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo:** vale lembrar que após a partilha do patrimônio deixado pelo *de cujus*, a ser realizada no juízo do inventário, a legitimidade passará aos herdeiros e sucessores;
- **o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos:** vale lembrar que a cessão de crédito independe do consentimento do devedor. Contudo, enquanto o devedor não for notificado acerca da cessão, poderá pagar ao seu credor originário, hipótese em que o cessionário não poderá exigir-lhe a obrigação. Nesse sentido, prevê o art. 209 do CC que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”;
- **o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional:** a sub-rogação pode ser legal ou convencional. A sub-rogação legal se opera de pleno direito em favor: a) do credor que paga a dívida do devedor comum; b) do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; c) do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (art. 346 do CC). Por sua vez, a sub-rogação convencional decorre da manifestação de vontade das partes. Ocorrerá quando: a) o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos; b) terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito (art. 347 do CC).

5.2. LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva está prevista no art. 779 do CPC. Vejamos:

- **o devedor, reconhecido como tal no título executivo:** trata-se do devedor originário;
- **o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor:** vale lembrar que, nos termos do art. 796 do CPC, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”
- **o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo:** a presente hipótese diz respeito à sucessão por ato *entre vivos*. Nos termos do art. 299 do CC, “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”;
- **o fiador do débito constante em título extrajudicial:** vale lembrar que o fiador, convencional ou judicial, quer seja na ação de conhecimento, quer seja na ação de execução, pode se valer do benefício de ordem. Nos termos do art. 827 do CC, “o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor”. No processo de execução, o benefício de ordem garante ao executado o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembaraçados, indicando-os pormenorizadamente à penhora (art. 794, *caput* do CPC). Nesse caso, os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor (art. 794, § 1º do CPC). Se o fiador pagar a dívida, poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo;
- **o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito:** trata-se da responsabilidade daquele que presta uma garantia real, ou seja, oferece bem próprio como forma de garantir o adimplemento de obrigação alheia. Muito embora o garantidor não seja o devedor do negócio principal, é responsável pela dívida, já que ofereceu um bem como garantia do adimplemento da obrigação. Essa garantia, aliás, faz nascer um direito de preferência do credor hipotecário sobre o respectivo bem, conforme dispõe o art. 1.422 do CC (“O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro”);
- **o responsável tributário, assim definido em lei:** a responsabilidade tributária decorre de um vínculo jurídico obrigacional imposto pela lei. À luz do art. 121, parágrafo único, II do CTN, o responsável tributário é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. No mesmo sentido, dispõe o art. 128 do CTN que

sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.



6. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES

Nos termos do art. 780 do CPC que “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.

São requisitos para a cumulação:

- **identidade de partes:** o exequente deve ser credor de todos os títulos, assim como o executado deve ser o mesmo em todos eles;
- **mesmo juízo competente:** para que seja admitida a cumulação, é preciso que o mesmo juízo seja competente para todas as execuções;
- **identidade de procedimento:** é preciso que para cada execução que se pretenda cumular, a lei preveja o mesmo procedimento. Assim, não é possível, por exemplo, cumular execução de título executivo extrajudicial com cumprimento de sentença, ainda que as partes sejam as mesmas e seja competente o mesmo juízo.

7. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO

O art. 516 do CPC⁸⁹ trata das regras de competência para o cumprimento de sentença e o art. 781 do CPC trata das regras de competência para a execução fundada em título executivo extrajudicial.

As hipóteses previstas no art. 781 do CPC versam sobre competência territorial relativa, razão pela qual tais regras podem ser derogadas pela vontade das partes ou mesmo por conexão ou continência.

A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

- a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;
- tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;
- sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;
- havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer um deles, à escolha do exequente;
- a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

8. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO

Exige-se para o processo executivo a observância dos pressupostos processuais de existência e validade, os quais foram estudados no Capítulo 5 desta obra. Para além deles, o CPC exige dois requisitos específicos para a execução forçada: a) inadimplemento do devedor; b) título executivo.

⁸⁹ Sobre o tema, ver capítulo XXIX.



8.1. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR

Enquanto o inadimplemento não ocorrer, a obrigação, ainda que goze de certeza e de liquidez, não será exigível. Note, assim, que é a partir do inadimplemento do devedor que a obrigação se torna exigível.

Nesse sentido, dispõe o art. 788 do CPC que

o credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.

8.2. TÍTULO EXECUTIVO

Toda execução pressupõe a existência de um título executivo. (*nulla executio sine titulo*).

O título executivo é o documento escrito e representativo de uma obrigação líquida, certa e exigível, ao qual a lei confere uma qualidade especial, qual seja, eficácia executiva, tendo em vista a alta probabilidade do direito.

Os títulos executivos são apenas aqueles previstos em lei.

9. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO EXECUTIVO: CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

Nos termos do art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

9.1. CERTEZA

Inicialmente, é preciso ter em mente que a certeza não diz respeito ao título ou ao crédito, mas sim à obrigação. A certeza, nesse sentido, não recai sobre a existência do crédito em si, o qual poderá ser discutido pelo executado. A certeza exigida pela lei é meramente formal e abstrata.

Além disso, é preciso que o documento tenha qualidade de título executivo, ou seja, que observe os requisitos legais de sua formação.

9.2. LIQUIDEZ

O título executivo deve exprimir o valor devido, ou seja, o *quantum debeatur*. Não se admite execução fundada em título ilíquido.

Tratando-se de título ilíquido, poderá o credor ajuizar ação de conhecimento ou ação monitória, mas não ação de execução.

Impende destacar, entretanto, que caso a definição total do valor do débito dependa de meros cálculos aritméticos, isso, por si só, não torna a obrigação ilíquida (art. 786, parágrafo único do CPC)⁹⁰. É o que ocorre, por exemplo, na execução fundada em cédula de crédito bancário⁹¹ e cédula de crédito rural⁹².

⁹⁰ Nesse sentido: AgRg no AREsp 576.838/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016.



9.3. EXIGIBILIDADE

A obrigação será exigível quando o credor puder reclamá-la. Está relacionada com o próprio inadimplemento da obrigação. Nos termos do art. 786, *caput* do CPC, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Se a obrigação estiver sujeita a termo ou condição, o exequente deverá demonstrar o advento do termo ou a ocorrência da condição (art. 798, I, “c”, do CPC).

10. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS

O rol dos títulos executivos extrajudiciais consta do art. 784 do CPC. Tratando-se de título executivo extrajudicial oriundo de país estrangeiro, não é necessária sua prévia homologação para ser executado (art. 784, § 2º, do CPC). Contudo, o título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação (art. 784, § 3º do CPC).

Vejamos o rol do art. 784 do CPC:

10.1. LETRA DE CÂMBIO, A NOTA PROMISSÓRIA, A DUPLICATA, A DEBÊNTURE E O CHEQUE

Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque são títulos de crédito, ou seja, o “documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei” (art. 887 do CC).

A **letra de câmbio** é uma ordem de pagamento, emitida por uma pessoa (sacadora) à outra (sacado) em favor de outrem (beneficiário). Deverá a letra de câmbio ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento, ou, sendo esse dia feriado por lei, no primeiro dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossantes e avalistas.

A ação executiva, relativa à letra de câmbio, poderá ser proposta contra um, alguns ou todos os coobrigados, sem estar o credor adstrito à observância da ordem dos endossos.

A **nota promissória** é uma promessa de pagamento. Nos termos do art. 77 da Lei Uniforme de Genebra, “são aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias a natureza deste título, as disposições relativas as letras e concernentes”.

A **duplicata** é o título de crédito que decorre de um contrato de compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Assim, ao ser extraída a fatura relativa à compra e venda mercantil, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador (ver arts. 1º e 2º da Lei nº 5.474/68).

Quanto à duplicata, vejamos algumas orientações firmadas pelo STJ:

⁹¹ “[...] A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa [...]” (AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 19/11/2010).

⁹² “[...] O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor[...]” (REsp n. 784.422/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008).

- a) Ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução (AgRg no AREsp 389.488/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016).
- b) O aceite lançado em separado à duplicata não possui nenhuma eficácia cambiária, mas o documento que o contém poderá servir como prova da existência do vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou ordinária (art. 16 da Lei nº 5.474/1968). A duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, é documento hábil à instrução do procedimento monitório (REsp 1334464/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
- c) A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução (AgRg no AREsp 745.067/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016).
- d) As duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.492/1997. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. (REsp 1.024.691-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/8/2012).

Debêntures são valores mobiliários que conferem direito de crédito perante a sociedade anônima emissora, nas condições constantes do certificado (se houver) e da escritura de emissão⁹³.

Por fim, **cheque** é uma ordem de pagamento à vista emitida pelo sacador em favor de alguém (beneficiário) para que este, de posse do documento, apresente-o ao sacado (instituição bancária) para pagamento.

O STJ, no julgamento do REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou as seguintes teses:

- a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula;
- sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.

10.2. ESCRITURA PÚBLICA OU OUTRO DOCUMENTO PÚBLICO ASSINADO PELO DEVEDOR

Por se tratar de documento público, cujo conteúdo goza de fé-pública, a escritura é, por si só, independentemente da assinatura de duas testemunhas, título executivo extrajudicial. Assim, basta que a escritura preveja a obrigação assumida pelo devedor, que pode consistir em pagamento de quantia, entrega coisa, obrigação de fazer ou não fazer.

⁹³ COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, v. II, p. 141.

Note que, pela redação do inciso II do art. 784 do CPC, a assinatura do devedor somente é exigida para *outro documento público*, o que significa dizer que, em se tratando de escritura pública – até mesmo em razão da fé pública do notário –, a falta de assinatura do devedor não retira a sua qualidade de título executivo extrajudicial.

10.3. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS

Para que o documento particular seja considerado título executivo, mostra-se indispensável a assinatura de duas testemunhas, ainda que essas não tenham presenciado a realização de negócio.

Ademais, para o ajuizamento da ação de execução, basta que as assinaturas constem apenas no documento do credor⁹⁴, sendo, ainda, irrelevante a ausência do reconhecimento de firma da testemunha.

10.4. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PELA ADVOCACIA PÚBLICA, PELOS ADVOGADOS DOS TRANSATORES OU POR CONCILIADOR OU MEDIADOR CREDENCIADO POR TRIBUNAL

O CPC confere exequibilidade ao documento ao Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal.

Em primeiro lugar, no tocante ao documento de transação referendado pelos advogados dos transatores, nada impede que apenas um advogado, escolhido pelas partes, formalize a transação e a referende.

Em relação ao instrumento referendado por conciliador ou mediador, o código exige que tais profissionais sejam **credenciados pelo tribunal**, alinhando-se, assim, ao comando do art. 165, SS, do CPC⁹⁵. Vê-se, assim, a importância dos mecanismos não jurisdicionais de solução de conflitos.

Por fim, impende destacar que nada impede que, mesmo que referendado por um dos profissionais mencionados no inciso IV, o instrumento seja submetido à autoridade judiciária para ser homologado, cuja decisão homologatória terá natureza de título executivo judicial (art. 515, III, do CPC)⁹⁶.

10.5. CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA, PENHOR, ANTICRESE OU OUTRO DIREITO REAL DE GARANTIA E AQUELE GARANTIDO POR CAUÇÃO

A relação constante do inciso V é meramente exemplificativa, o que significa dizer que todo direito real de garantia vinculado a um negócio jurídico pode ser executado.

Não é por outra razão que a ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia pode ser convertida em ação executiva.

⁹⁴ Nesse sentido: AgRg no REsp 1456893/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014.

⁹⁵ Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

⁹⁶ Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...);

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

(...)



Nos termos do art. 1.419 do CC, “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. Portanto, vencida a obrigação, o credor poderá promover a ação executiva, objetivando a constrição do bem para o pagamento da dívida.

Ainda que o bem/direito dado em garantia seja superior ao valor do débito, ficará sujeito ao cumprimento da obrigação, devendo, se for o caso, ser alienado para satisfazer o crédito do exequente.

Registre-se que é possível que outras ações executivas atinjam o bem objeto de garantia real. Nesse caso, deve-se verificar qual dos credores é o preferencial. Caso o credor com garantia real não tenha a preferência (ex.: execução hipotecária x execução fiscal)⁹⁷, somente receberá seu crédito após a satisfação do exequente que detenha a preferência.

10.6. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM CASO DE MORTE

Diferentemente da previsão constante no art. 585, III, do CPC/73, o CPC/2015 somente confere exequibilidade ao contrato de seguro de vida no caso de morte. Isto é, o evento *morte* é *conditio sine qua non* para que o título preencha seus requisitos de validade e fundamente a ação executiva.

No tocante aos demais contratos de seguro, os mesmos poderão subsidiar eventual ação executiva desde que estejam assinados por duas testemunhas e contenham uma dívida líquida, certa e exigível. Porém, o fundamento legal não será o inciso VI do art. 784 do CPC, mas sim o inciso III.

10.7. CRÉDITO DECORRENTE DE FORO E LAUDÊMIO

O foro e laudêmio estão relacionados à enfiteuse, que é o direito real por meio do qual o proprietário concede a outrem (enfiteuta) todos os direitos sobre a coisa, passando o enfiteuta a ter o domínio útil do bem. Para tanto, deverá pagar ao proprietário uma prestação certa e anual, denominada *foro*. Como o enfiteuta possui o domínio útil do bem, poderá aliená-lo a terceiros. Em tal caso, o proprietário terá direito de preferência. Caso não o exerça, terá direito a um percentual sobre o negócio, denominado de laudêmio.

Para o STJ, é válida cláusula inserta em contrato de promessa de compra e venda de imóvel situado em terreno de marinha que estipule ser da responsabilidade do promitente-adquirente o pagamento do laudêmio devido à União, embora a referida cláusula não seja oponível ao ente público⁹⁸.

Impende destacar que o art. 2.038 do CC proibiu a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, devendo ser aplicadas as ainda existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores.

⁹⁷ PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os bens gravados com hipoteca oriunda de cédula de crédito podem ser penhorados para satisfazer o débito fiscal. Isso porque a impenhorabilidade de que trata o art. 57 do Decreto-Lei 413/69 não é absoluta, cedendo à preferência concedida ao crédito tributário pelo art. 184 do CTN. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1327595/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).

⁹⁸ REsp 888.666-SE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/12/2015, DJe 1º/2/2016)



10.8. CRÉDITO, DOCUMENTALMENTE COMPROVADO, DECORRENTE DE ALUGUEL DE IMÓVEL, BEM COMO DE ENCARGOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO TAXAS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO

Celebrado o contrato de locação, além do valor dos aluguéis, os locatários, na maioria das vezes, se responsabilizam por outras obrigações, que via de regra, são de responsabilidade do proprietário do imóvel. Não há qualquer ilegalidade na transferência de algumas obrigações ao locatário, por exemplo, pagamento do IPTU, taxas condominiais, despesas decorrentes do consumo de água e energia elétrica etc.

Nos termos do art. 784, VIII, qualquer crédito, documentalmente comprovado, decorrente de contrato de aluguel (aluguel, taxas condominiais, consumo de energia elétrica etc.) pode ser exigido por meio da ação de execução.

Via de regra, o título executivo será o próprio contrato de locação, que, por sua vez, não precisa conter a assinatura de duas testemunhas, pois tal exigência somente se refere à hipótese do inciso III do art. 784 do CPC.

10.9. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AOS CRÉDITOS INSCRITOS NA FORMA DA LEI

Conforme previsão do § 2º do art. 39 da Lei nº 4.320/64, “dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas [...]”.

Esse crédito – decorrente do procedimento tributário denominado *lançamento* – será inscrito pelo órgão competente para apurar a sua liquidez e certeza e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo⁹⁹.

Com a inscrição do crédito, será lavrada a Certidão da Dívida Ativa – CDA, que é justamente o título que embasará o processo executivo fiscal e que goza de presunção de certeza e liquidez¹⁰⁰.

O processo de execução fiscal encontra-se disciplinado na Lei 6.830/80, aplicando-se, subsidiariamente, o CPC, conforme art. 1º da aludida lei.

10.10. CRÉDITO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO, PREVISTAS NA RESPECTIVA CONVENÇÃO OU APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL, DESDE QUE DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS

As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício podem ser exigidas por meio da ação de execução. Para tanto, tais encargos devem estar previstos na respectiva convenção ou na ata da assembleia geral que os aprovou.

Vê-se, assim, que o título executivo não é o crédito, mas sim o documento (convenção ou ata da assembleia geral) que o prevê, sendo irrelevante o fato de o devedor não ter participado da convenção ou assembleia.

⁹⁹ Art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

¹⁰⁰ Art. 3º da Lei nº 6.830/80.



10.11. CERTIDÃO EXPEDIDA POR SERVENTIA NOTARIAL OU DE REGISTRO RELATIVA A VALORES DE EMOLUMENTOS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS PELOS ATOS POR ELA PRATICADOS, FIXADOS NAS TABELAS ESTABELECIDAS EM LEI

Os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (art. 1º da Lei nº 8.935/94).

Os valores cobrados pelas serventias extrajudiciais são fixados em lei no âmbito de cada Estado da federação, sendo que, no caso do Distrito Federal, os valores são previstos em lei federal.

10.12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva

Além dos títulos executivos previstos no art. 784 do CPC, é possível que uma lei específica atribua força executiva a determinado documento. É o que ocorre, por exemplo, com as cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67), comercial (Lei nº 6.840/80), industrial (Decreto-lei nº 413/69) e bancária (Lei nº 10.931/04).

11. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO EXECUTADO

Conforme estudado, toda execução pressupõe a existência de um título que estampe uma obrigação líquida, certa e exigível. É importante ressaltar, entretanto, que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial, a teor do art. 785 do CPC.

Se a prestação que incumbe ao devedor depender da contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Promovendo a execução, poderá o executado eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar.

À luz do princípio da responsabilidade patrimonial, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC).

O código, porém, em seu art. 790, elege outras pessoas que, a despeito de não serem devedoras principais, também terão seu patrimônio sujeito à execução. São elas:

11.1. SUCESSOR A TÍTULO SINGULAR, TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL OU OBRIGAÇÃO REIPERSECUTÓRIA

Uma das características dos direitos reais é o direito de sequência, ou seja, a prerrogativa conferida ao seu titular de perseguir e executar os bens dados em garantia pelo devedor.

11.2. SÓCIO NOS TERMOS DA LEI

A despeito de a personalidade da pessoa jurídica não se confundir com a dos seus sócios, é possível que a pessoa dos sócios responda pelas obrigações assumidas pela sociedade, como ocorre na sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC)¹⁰¹.

Ademais, é possível que o véu da personalidade jurídica seja momentaneamente retirado para se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, em razão de obrigação contraída pela própria pessoa jurídica. Trata-se do instituto da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e arts. 133 a 137 do CPC)¹⁰².

11.3. DEVEDOR, AINDA QUE EM PODER DE TERCEIROS

Ainda que os bens do devedor estejam na posse ou administração de terceiros (Ex.: imóvel arrendado), será possível a sua constrição. Isso porque, o executado não deixa de ser o proprietário do bem.

11.4. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, NOS CASOS EM QUE SEUS BENS PRÓPRIOS OU DE SUA MEAÇÃO RESPONDEM PELA DÍVIDA

Em regra, sendo a obrigação contraída apenas em benefício de um dos cônjuges, somente os seus bens devem responder na execução. Entretanto, há casos que a própria lei prevê a sujeição dos bens de ambos os cônjuges, como ocorre, por exemplo, na obrigação assumida em benefício da família¹⁰³.

11.5. ALIENADOS OU GRAVADOS COM ÔNUS REAL EM FRAUDE À EXECUÇÃO

O art. 792 do CPC elenca as hipóteses configuradoras de fraude à execução. São elas: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.

Assim, se o devedor alienar bens ou gravá-los de ônus real nas hipóteses elencadas acima, tais bens continuarão sujeitos à execução, pois a alienação será **ineficaz** em relação ao exeqüente, conforme previsão do § 1º do art. 792 do CPC.

¹⁰¹ Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais.

¹⁰² Art. 50 do CC: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Art. 134 do CPC: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na **execução fundada em título executivo extrajudicial**”.

¹⁰³ Dispõe o art. 1.664 do CC que Art. 1.664. “Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”.

11.6. CUJA ALIENAÇÃO OU GRAVAÇÃO COM ÔNUS REAL TENHA SIDO ANULADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, EM AÇÃO AUTÔNOMA, DE FRAUDE CONTRA CREDORES

A fraude contra credores, instituto de direito material, configura-se na alienação fraudulenta de bens, a título oneroso ou gratuito, pelo qual o devedor-alienante objetiva prejudicar credor em tempo futuro. Há, portanto, dolo por parte do alienante/devedor.

A sua configuração pressupõe a ocorrência de dois requisitos: a) *consilium fraudis* (má-fé); b) *eventum damni* (insolvência).

Quando se está diante de uma fraude contra credores, o credor prejudicado deve intentar uma ação específica, denominada *ação pauliana* (o nome da ação homenageia o pretor romano Paulo).

Destarte, anulando-se a alienação fraudulenta, por meio da *ação pauliana*, os respectivos bens objeto voltarão a ficar sujeitos à execução.

11.7. DO RESPONSÁVEL, NOS CASOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Conforme estudado no item 8.2, é possível que o véu da personalidade jurídica seja momentaneamente retirado para se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, em razão de obrigação contraída pela própria pessoa jurídica. Trata-se do instituto da desconconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e arts. 133 a 137 do CPC)¹⁰⁴.

Assim, descon siderada a personalidade jurídica da sociedade, os bens dos sócios ou administradores ficarão sujeitos à execução. Note que a pessoa jurídica é a executada, porém os atos constitutivos, em caso de descon sideração da personalidade jurídica, recairão também sobre o patrimônio pessoal dos sócios e/ou administradores.

12. BENS NÃO SUJEITOS À EXECUÇÃO

Embora a execução recaia, como regra, sobre o patrimônio do devedor, alguns bens são protegidos pela lei, ou seja, não respondem pela dívida contraída pelo seu titular. Certos bens são considerados pelo ordenamento jurídico como impenhoráveis.

Os bens considerados absolutamente impenhoráveis estão previstos no art. 833 do CPC. Vejamos:

12.1. BENS INALIENÁVEIS E OS DECLARADOS, POR ATO VOLUNTÁRIO, NÃO SUJEITOS À EXECUÇÃO

Os bens inalienáveis são aqueles assim considerados pela própria lei, como o são os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar (art. 100 do CC). A inalienabilidade também pode

¹⁰⁴ Art. 50 do CC: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Art. 134 do CPC: “Art. 134. O incidente de descon sideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na **execução fundada em título executivo extrajudicial**”.

decorrer de ato voluntário, como, por exemplo, quando instituída na doação e testamento gravados com cláusula de inalienabilidade, ou, ainda, na instituição de bem de família convencional (art. 1.711 do CPC). No tocante ao testamento, a cláusula de inalienabilidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade.

12.2. BENS MÓVEIS, PERTENCES E AS UTILIDADES DOMÉSTICAS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO, SALVO OS DE ELEVADO VALOR OU OS QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS CORRESPONDENTES A UM MÉDIO PADRÃO DE VIDA

Trata-se de uma preocupação social do legislador, que impede que os bens necessários para o dia a dia do devedor – e de pouca importância para a satisfação do crédito do exequente – sejam constrictos (ex.: fogão, única geladeira, única televisão, aparelho telefônico, liquidificador etc.). Trata-se de norma que se alinha à ideia de humanização do direito civil.

A ressalva feita na parte final do dispositivo (*salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida*) é providencial. A impenhorabilidade deve referir-se a bens móveis suscetíveis de garantir a dignidade da pessoa humana, na perspectiva do direito ao *mínimo existencial*, não alcançando, pois, bens cujo valor é incompatível com a proteção buscada pela norma. A título de exemplo, se o devedor possui uma televisão de vinte polegadas e uma outra de cinquenta, esta última deve responder pela dívida.

12.3. VESTUÁRIOS, BEM COMO OS PERTENCES DE USO PESSOAL DO EXECUTADO, SALVO SE DE ELEVADO VALOR

A impenhorabilidade dos bens de uso pessoal também presta obséquio à tutela da dignidade da pessoa humana. Estão abrangidos neste dispositivo o anel nupcial, retratos de família, instrumento musical de uso pessoal do devedor, livros etc. Registre-se, porém, que se tais bens forem suntuosos (ex.: executada é proprietária de três bolsas, sendo cada uma avaliada em R\$ 10.000,00), perderão o caráter de impenhorabilidade.

12.4. VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, SOLDOS, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES, PECÚLIOS E OS MONTEPIOS, BEM COMO AS QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, OS GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO E OS HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL, RESSALVADO O § 2º

É impenhorável a remuneração, em sentido amplo, do devedor, pois possui natureza alimentar. Trata-se de rol meramente exemplificativo, devendo ser compreendido como todo valor recebido por alguém, de natureza alimentar, decorrente de uma relação de direito público ou privada, utilizada, destinada, como regra, para o sustento da pessoa e de sua família. A constrição de verbas destinadas ao sustento do executado e de sua família viola o princípio da dignidade humana.

Essa regra de impenhorabilidade, contudo, não é absoluta. Não se aplica, por exemplo, à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º, ambos do CPC. Para o Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, “quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba

remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"¹⁰⁵.

Conforme entendimento doutrinário, “as hipóteses de penhora do art. 833, § 2º, do CPC aplicam-se ao cumprimento da sentença ou à execução de título extrajudicial relativo a honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar” (enunciado nº 105 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJP).

12.5. LIVROS, AS MÁQUINAS, AS FERRAMENTAS, OS UTENSÍLIOS, OS INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO

O inciso V do art. 833 do CPC, à luz da tutela da dignidade da pessoa humana, considera como impenhorável os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Citem-se, a título de exemplo, livros, mesas, cadeiras, computador. Incluem-se, ainda, os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária (art. 833, § 3º, do CPC).

12.6. SEGURO DE VIDA

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC).

O seguro de vida não pode responder nem pelas dívidas do segurado nem pelas dívidas dos beneficiários. Não respondem pelas dívidas do segurado porque o valor garantido não o pertence. Logo, não é herança. É direito próprio de pessoas eleitas pelo segurado.

O objetivo do seguro de vida é a proteção do beneficiário, garantindo-lhe uma vida digna. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça vem interpretando a regra de impenhorabilidade do seguro de vida (art. 833, VI, do CPC) à luz do limite estabelecido para a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança (quarenta salários-mínimos), prevista no art. 833, X, do CPC (art. 649, X, do CPC/73). Assim, a impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida deve se limitar ao montante de 40 (quarenta) salários-mínimos¹⁰⁶.

12.7. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO, SALVO SE ESSAS FOREM PENHORADAS

A impenhorabilidade dos materiais necessários para obras em andamento permite com que a obra em curso possa ser terminada. Com isso, tutela-se o direito à moradia (se a obra for para fins de moradia) e, em qualquer caso, a manutenção do trabalho dos construtores (proteção da fonte de produção).

Embora os materiais já destinados a uma obra em andamento não sejam penhoráveis, a obra, em si, enquanto edifício em construção, pode sofrer penhora, conforme previsão do art. 862

¹⁰⁵REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019.

¹⁰⁶REsp 1361354/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018.

do CPC ("Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração").

12.8. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, ASSIM DEFINIDA EM LEI, DESDE QUE TRABALHADA PELA FAMÍLIA

O inciso VIII do art. 833 do CPC se harmoniza ao inciso XXVI do art. 5º da CRFB/88, segundo o qual "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

A pequena propriedade rural, segundo o art. 4º, I, da Lei nº 8.629/93, é o prédio rústico de área contínua de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva, pois a interpretação teleológica do art. 833, VIII, demonstra que a intenção do legislador foi proteger a atividade agropecuária de subsistência do trabalhador rural e de sua família, a par do enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural¹⁰⁷. Além disso, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família¹⁰⁸.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em razão da presunção *juris tantum* em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural"¹⁰⁹.

12.9. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL

A impenhorabilidade dos recursos referidos no inciso IX do art. 833 do CPC tem por objetivo proteger direitos fundamentais à educação, saúde e assistência social. De igual forma, confere às instituições privada que exercem tais atividades e ao próprio poder público maior tranquilidade para o desenvolvimento de políticas pública. A norma protege, evidentemente, um interesse público.

Para que o recurso goze de impenhorabilidade, é preciso que seja de aplicação compulsória na área da educação, saúde ou assistência social. Pouco importa se a atividade é desenvolvida antes ou após o recebimento do recurso público. Assim, o fato de o executado, por exemplo, ter prestado serviços de educação previamente ao recebimento dos créditos correspondentes do FIES não descaracteriza sua destinação; ao contrário, reforça a ideia de que se trata de recursos compulsoriamente aplicados em educação, sendo, portanto, impenhorável¹¹⁰.

A terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, ainda, que os valores vinculados à contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS - Sistema Único de

¹⁰⁷ REsp 1.368.404-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015.

¹⁰⁸ AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019

¹⁰⁹ REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017.

¹¹⁰ REsp 1840737/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019.

Saúde são absolutamente impenhoráveis¹¹¹. Por outro lado, as verbas recebidas por escola de samba a título de parceria público-privada com a administração pública não gozam da proteção da impenhorabilidade. Isso porque, a despeito do valor social, cultural, histórico e turístico do carnaval brasileiro, tais valores não estão vinculados, de forma compulsória, à educação ou à assistência social¹¹².

12.10. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS

A impenhorabilidade se limita ao valor correspondente a 40 (quarenta salários-mínimos), o que significa dizer que a quantia depositada for maior, a penhora incidirá sobre o excedente.

Tal impenhorabilidade também se aplica a outros investimentos, desde que seja observado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Para o Superior Tribunal de Justiça,

reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)¹¹³.

12.11. OS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDOS POR PARTIDO POLÍTICO, NOS TERMOS DA LEI

Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.096/95,

o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”. O § 3º do art. 17 da CF dispõe que “os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

A aplicação do fundo partidário encontra-se regulamentada no art. 44 da Lei nº 9.096/95. A impenhorabilidade decorre do fato de os recursos que compõem o fundo partidário ser originários de fontes públicas, sendo que, uma vez incorporados ao fundo, passam a ter destinação legal, revelando-se, com isso, a natureza jurídica de verba pública.

Impende registrar, entretanto, que os partidos políticos possuem outras fontes de recursos, como, por exemplo, contribuições dos filiados e doações em geral, recursos estes que não se encontram protegidos pelo manto da impenhorabilidade¹¹⁴.

¹¹¹ REsp 1324276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012.

¹¹² REsp 1816095/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019.

¹¹³ REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014.

¹¹⁴ REsp 1474605/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 26/05/2015.

12.11. CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, VINCULADOS À EXECUÇÃO DA OBRA

Segundo dispõe o art. 31-A da Lei nº 4.591/64,

a critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.

O inciso XII do art. 833 do CPC, objetivando proteger, a um só tempo, incorporador e adquirentes, conferiu aos créditos oriundos da venda das unidades imobiliárias e vinculados à própria execução da obra, o caráter de impenhorabilidade.

12.12. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA

A Lei nº 8.009/1990 versa sobre o chamado *bem de família legal*, conferindo a proteção jurídica da impenhorabilidade ao bem imóvel, em certos casos, independentemente da vontade da parte. Nos termos do art. 1º da supracitada lei, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90). Ademais, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza.

A proteção do bem de família não é absoluta. O art. 3º da Lei nº 8.009/90 elenca as exceções à impenhorabilidade. São elas: a) processo movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; b) processo movido pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; c) processo movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; d) processo movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; e) processo movido por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens; f) processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Além do bem de família legal, é possível que a pessoa, por ato voluntário, institua bem de família. Fala-se, nesse caso, em *bem de família convencional*. Nos termos do art. 1.711 do CC, “podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial”.

A impenhorabilidade convencional, evidentemente, pode decorrer de negócio jurídico processual atípico celebrado entre as partes (art. 190 do CPC), conforme entendimento firmado no enunciado nº 153 da II Jornada de Direito Processual Civil – CJF (“A penhorabilidade dos bens,

observados os critérios do art. 190 do CPC, pode ser objeto de convenção processual das partes”). Contudo, o pacto de impenhorabilidade (arts. 190, 200 e 833, I do CPC), evidentemente, produz efeitos apenas entre as partes, não alcançando terceiros (enunciado nº 152 da II Jornada de Direito Processual Civil – CJP).

É preciso fazer uma distinção importante entre o bem de família convencional e o bem de família legal. O bem de família convencional implica impenhorabilidade e inalienabilidade. Já o bem de família legal só implica impenhorabilidade. Isso significa dizer que é plenamente possível que o bem de família legal objeto, por exemplo, de alienação fiduciária em garantia, após o inadimplemento do devedor, sofra constrição em futuro processo de execução ou mesma seja levado a leilão nos termos da Lei nº 9.514/97¹¹⁵.

13. BENS SUBMETIDOS AO REGIME DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE

A superfície é o direito real por meio do qual o proprietário concede a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, a teor do art. 1.369 do CC. No processo executivo, os atos constitutivos poderão recair sobre a propriedade ou sobre a construção ou plantação, a depender de quem seja o executado.

Assim, se o executado for o proprietário, a penhora e os demais atos de constrição recairão exclusivamente sobre o terreno; por outro lado, sendo o executado o superficiário, a penhora ou os outros atos de constrição recairão sobre a construção ou a plantação (art. 791, *caput*, do CPC).

Os atos de constrição ora referidos deverão ser averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas (art. 792, § 1º, do CPC).

Por fim, registre-se que tal regra aplica-se, no que couber, à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso (art. 792, § 2º, do CPC).

14. FRAUDE À EXECUÇÃO

Fraude à execução é instituto de direito processual consistente na alienação ou oneração de bens no curso da fase de conhecimento do procedimento comum, cumprimento de sentença ou do processo de execução fundado em título executivo extrajudicial. Trata-se, portanto, da oneração ou alienação de bens, a título gratuito ou oneroso, na pendência de ação judicial.

A fraude à execução deve ser suscitada no processo de execução e gera a ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor.

Embora o reconhecimento da fraude à execução ocorra nos mesmos autos em que ela é suscitada, é preciso garantir o exercício do contraditório do terceiro que poderá vir a ser atingido pelo ato constitutivo. Nesse sentido, dispõe o § 4º do art. 792 do CPC que “antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”¹¹⁶.

As hipóteses configuradoras de fraude à execução encontram-se elencadas no art. 972, *caput*, do CPC. Vamos a elas.

¹¹⁵ REsp 1595832/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 04/02/2020.

¹¹⁶ Sobre os embargos de terceiros, ver Capítulo XXX.



- **Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver:** Para a configuração da fraude à execução, na hipótese em comento, é preciso que o exequente tenha averbado a pendência do processo no registro público em que o bem objeto da execução está inscrito. A averbação gera uma presunção absoluta de ciência perante terceiros e, conseqüentemente, de fraude à execução, em caso de alienação. Nos bens sujeitos a registro, uma vez promovida a averbação da pendência da ação, não há mais espaço para alegação de boa-fé por parte do terceiro adquirente;
- **Quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 do CPC:** uma vez promovida a averbação, haverá uma presunção absoluta de conhecimento da execução por parte de terceiros e, conseqüentemente, fraude à execução, em caso de alienação do bem (art. 828, § 4º, do CPC). Se quando da alienação não havia averbação da pendência da execução no respectivo registro público do bem alienado, haverá, nesse caso, presunção de boa-fé do adquirente, cabendo ao exequente o ônus da prova de que aquele agiu de má-fé. Tratando-se de bem não sujeito a registro, caberá ao terceiro adquirente provar a sua boa-fé, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem, nos termos do art. 792, § 2º, do CPC;
- **Quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude:** a hipoteca judiciária é direito real de garantia sobre coisa alheia (art. 495 do CPC). Uma vez constituída, a hipoteca judiciária sujeita o bem hipotecado, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Não é, contudo, qualquer decisão judicial que produzirá hipoteca judiciária, mas somente aquela que: a) condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro; ou b) que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária;
- **Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência:** Cumpre destacar que não basta a ciência do devedor quanto à ação em seu desfavor e a alienação do bem. É preciso que a ação seja capaz de reduzi-lo à insolvência. Conforme adverte Humberto Theodoro Junior, “não importa a natureza da ação em curso (pessoal ou real, de condenação ou de execução). O que importa é a aptidão do litígio para reconhecer uma obrigação de pagar quantia cuja satisfação se frustre em razão do desfalque patrimonial verificado”¹¹⁷;
- **Demais casos expressos em lei:** além das hipóteses previstas expressamente no art. 792 do CPC, em outras passagens no próprio CPC ou em leis extravagantes é possível a previsão de comportamento configurador de fraude à execução. É o que ocorre, por exemplo, no art. 856, § 3º, do CPC (penhora sobre crédito) e art. 828, § 4º, do CPC (alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação).

14.1. FRAUDE À EXECUÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Desconsiderada a personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios ficarão sujeitos à execução (art. 790, VII, do CPC). E quando reconhecida a ocorrência de fraude à execução, a alienação de bens será considerada ineficaz em relação ao exequente (art. 137 do CPC).

¹¹⁷ THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. 29ª ed. rev. e atual. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito. 2017, p. 240-241.



Nos termos do § 3º do art. 792 do CPC, “nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”.

Há duas formas de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica: 1ª) na própria petição inicial da ação de conhecimento ou da ação de execução; 2ª) no curso do processo, em momento posterior à apresentação da petição inicial.

Pela redação do § 3º do art. 792 do CPC, o marco temporal a partir do qual a alienação ou oneração de bens, realizada pelos sócios, será considerada como fraude à execução, será a data da citação da pessoa jurídica ré (“citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”).

15. EXECUÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO

Nos termos do art. 793 do CPC, “exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder”. Tem-se, nesse caso, um verdadeiro direito de preferência, na medida em que primeiro devem ser excutidos os bens que já se encontram em poder do exequente em razão do direito de retenção. Somente se a excussão desses bens não for suficiente para a satisfação do crédito, é que será possível a constrição de outros bens do executado.

16. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EXEQUENTE

Nos termos do art. 776 do CPC, “o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”. A *sentença* referida no dispositivo é a proferida nos embargos à execução. Diferentemente da redação contida no art. 520, I, do CPC, o art. 776 do CPC prevê a responsabilidade do exequente tão somente na hipótese de a sentença dos embargos reconhecer *inexistente, no todo ou em parte, a obrigação*. Assim, se a execução for extinta, por exemplo, em razão do reconhecimento de prescrição, o executado não fará jus a qualquer reparação de danos.

17. MULTAS OU DE INDENIZAÇÕES DECORRENTES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU DE PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

Se, no curso da execução, uma das partes for condenada por litigância de má-fé ou pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a cobrança da multa ou de eventuais indenizações delas decorrentes será promovida nos próprios autos do processo (art. 777 do CPC). Busca-se, com isso, maior economia processual, aproveitando-se a relação jurídico-processual já formada.

Embora o código seja omissivo, se o condenado pela litigância de má-fé ou pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça for o próprio exequente, é plenamente possível o valor da multa ou indenização por ele devida seja compensado com o valor da execução.



CAPÍTULO 14 — DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A execução fundada em título executivo extrajudicial observará, a depender do seu objeto, um dos seguintes procedimentos: a) execução para entrega de coisa; b) execução das obrigações de fazer ou de não fazer; c) execução por quantia certa; d) execução contra a Fazenda Pública; e) execução de alimentos.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS PERTINENTES ÀS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

2.1. PETIÇÃO INICIAL

O processo de execução terá início com a apresentação da petição inicial, a qual deve observar, além dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, haja vista que as regras previstas para o processo de conhecimento aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC).

O art. 798 do CPC estabelece os requisitos para a propositura da ação de execução. Vejamos:

- **A petição inicial deverá ser instruída com:** a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;
- **A petição inicial deverá indicar:** a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

O demonstrativo do débito pode ser apresentado em planilha anexa à petição inicial ou em planilha apresentada no próprio corpo da petição. Seja como for, o demonstrativo conterá: a) o índice de correção monetária adotado; b) a taxa de juros aplicada; c) os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; d) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; e) a especificação de desconto obrigatório realizado (art. 798, parágrafo único, do CPC).

O valor da causa deve corresponder à expressão econômica do objeto da execução.

2.2. INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

Além dos requisitos formais citados, o exequente deverá, ao indicar determinado bem à penhora, requerer a intimação de terceiros que possuam alguma relação com o bem indicado. As hipóteses estão previstas no art. 799, I a VI, X e XI, do CPC. A ausência de intimação gera importantes consequências para o processo de execução, conforme art. 804 e parágrafos do CPC.



Assim, incumbe ao exequente requer a intimação:

- Do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária (art. 799, I, do CPC). A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou ao proprietário fiduciário não intimado (art. 804, *caput* e § 3º, do CPC);
- Do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação (art. 799, II, do CPC). A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado (art. 804, § 6º, do CPC);
- Do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada (art. 799, III, do CPC). A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado (art. 804, § 1º, do CPC);
- Do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda ou de promessa de cessão será ineficaz em relação ao promitente vendedor ou ao promitente cedente não intimado (art. 804, § 3º, do CPC);
- Do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, assim como concessão especial para fins de moradia, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário do respectivo imóvel não intimado (art. 804, § 2º, do CPC);
- Do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário. A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado (art. 804, § 5º, do CPC);
- Do titular da construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. A despeito da omissão do art. 804 do CPC, a alienação do direito de laje será ineficaz em relação ao titular da construção-base não intimado;
- Do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base (art. 799, I a VI, X e XI, do CPC). A despeito da omissão do art. 804 do CPC, a alienação da construção-base será ineficaz em relação ao titular das lajes não intimado;

Se o exequente, na petição inicial, não indicar um bem específico, não precisará requerer a intimação de terceiros. Contudo, se, no curso do processo, requerer a penhora de algum bem sujeito a um dos direitos acima elencados, deverá o exequente requerer a intimação do terceiro.



2.3. MEDIDAS URGENTES

O exequente poderá, na petição inicial, requer medidas urgentes, como, por exemplo, tutela provisória de natureza antecipada ou cautelar (art. 799, VIII, do CPC).

2.4. AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DA EXECUÇÃO

Incumbe ao exequente, ainda, proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros (art. 799, IX, do CPC).

O art. 799, IX, do CPC deve, ainda, ser lido à luz do art. 828 do CPC, o qual prevê que “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Para fins de averbação, não basta a simples propositura da ação de execução, é preciso que a execução tenha sido admitida pelo juiz, nos termos do art. 828, *caput*, do CPC.

No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, § 1º, do CPC). Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados (art. 828, § 2º, do CPC), sem prejuízo de o juiz determinar o cancelamento de ofício (art. 828, § 3º, do CPC).

2.5. OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

É possível que o título executivo contenha uma obrigação alternativa. Segundo o art. 252 do CC, “nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 326 do CPC dispõe que “quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo”.

Com efeito, nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato (art. 800 do CPC). Se o executado não exercer o direito de escolha dentro de 10 (dez) dias, a escolha caberá ao credor (art. 800, § 1º, do CPC). Se, desde o início, a escolha cabia ao credor, ela deverá ser indicada na petição inicial (art. 800, § 2º, do CPC).

2.6. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL

Caso a petição inicial não preencha os requisitos exigidos pela lei, o juiz deve oportunizar ao exequente a correção dos vícios. Nesse sentido, prevê o art. 801 do CPC que “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”.

O art. 801 do CPC deve ser interpretado à luz do art. 321 do CPC, de modo que, ao determinar a emenda da petição inicial, deverá o juiz indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado, providência, aliás, que se alinha ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

2.7. DESPACHO INICIAL

Assim como ocorre no processo de conhecimento, no processo de execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 do CPC, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente (art. 802, *caput*, do CPC). A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação (art. 802, parágrafo único, do CPC).

Ao propor a ação de execução, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art. 240, § 2º, do CPC). Não se exige que a citação ocorra no prazo de 10 (dez) dias, mas que o autor diligencie no sentido de viabilizar a citação, ou seja, apresentando ao juízo todas as informações necessárias para a citação. Não diligenciando o exequente, não haverá interrupção da prescrição.

2.8. NULIDADE DA EXECUÇÃO

O art. 803 do CPC apresenta um rol de situações geradoras de nulidade do processo executivo. São elas: a) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; b) o executado não for regularmente citado; c) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

A nulidade será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução (art. 803, parágrafo único, do CPC).

3. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA

Coisa certa é a coisa individualizada, móvel ou imóvel. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso (art. 233 do CC).

O procedimento da execução para entrega de coisa certa fundada em título executivo extrajudicial está previsto nos arts. 806 a 810 do CPC.

Ao juiz, ao receber a petição inicial, deverá determinar a citação do executado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação (art. 806, *caput*, do CPC). No mesmo despacho, o juiz poderá fixar, desde já, multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação (*astreinte*), ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1º, do CPC).

Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado (art. 803, § 2º, do CPC).

Independentemente do prazo para entrega da coisa, o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à execução (art. 915 do CPC). A oposição de embargos não está condicionada ao depósito da coisa ou qualquer outra forma de garantia do juízo. Os embargos, por outro lado, não gozam de efeito suspensivo, de tal sorte que, ainda que opostos, será imitado o mandado de imissão de posse ou busca e apreensão, conforme o caso, sem prejuízo da adoção de outras técnicas processuais executivas, como, por exemplo, a fixação de *astreinte* ou majoração, caso já fixada.

O executado poderá obter efeito suspensivo, quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC).

Se a coisa objeto da execução for alienada no curso do processo (alienação de coisa litigiosa), será expedido mandado contra o terceiro adquirente. A alienação do objeto da execução é ineficaz em relação ao exequente. Há, aqui, fraude à execução. O terceiro adquirente, nesse caso, somente será ouvido após depositar a coisa em juízo (art. 808 do CPC).

Se a coisa não for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro, o exequente terá direito de receber, além das perdas e danos, o seu respectivo valor (art. 809 do CPC). Se o valor da coisa não constar do título executivo e se for impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial (art. 809, § 1º, do CPC). Os prejuízos serão apurados em liquidação (art. 809, § 2º, do CPC). A execução que, até então, tinha por objeto obrigação de entregar coisa certa, será convertida em execução por quantia certa.

Se o executado ou terceiro tiver realizado benfeitorias indenizáveis na coisa, poderão exercer o direito de retenção¹¹⁸. Boa parte da doutrina entende que caberá ao exequente, nesse caso, promover a liquidação das benfeitorias antes mesmo do início da execução, conforme exigência do art. 810 do CPC (“Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória”). Tratando-se de título executivo judicial, será necessária a instauração da fase de liquidação (art. 509 do CPC). Tratando-se de título executivo extrajudicial, a doutrina vem exigindo que a liquidação das benfeitorias ocorra por meio de prévia ação de conhecimento.

Após a liquidação, é possível que o saldo apurado seja em favor do executado ou de terceiros, ou em favor do próprio exequente. Havendo saldo em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Havendo o saldo em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo (art. 810, parágrafo único, do CPC).

4. Execução para entrega de coisa certa

Coisa incerta é aquela definida ao menos pelo gênero e pela quantidade. Nos termos do art. 244 do CC, “nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor”.

Ao receber a petição inicial o juiz determinará a citação do executado para entregar a coisa individualizada, se lhe couber a escolha (art. 811 do CPC). Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial (art. 810, parágrafo único, do CPC).

Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação (art. 812 do CPC).

A escolha feita pela parte (exequente ou executado, conforme o caso) poderá ser impugnada pela parte contrária no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo ao juiz decidir de plano ou, se necessário, ouvir perito de sua nomeação (art. 810 do CPC). O pronunciamento do juiz quanto à escolha tem natureza de decisão interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

Após, segue-se o mesmo procedimento da execução para entrega de coisa certa (art. 813 do CPC).

¹¹⁸ Nos termos do art. 1.219 do CC, Art. 1.219. “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.



5. EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER

A obrigação de fazer é uma prestação positiva consistente na prática de uma determinada conduta ou tarefa pelo devedor. Tal prestação pode ser infungível (somente o devedor pode cumpri-la, pois tem caráter personalíssimo) ou fungível (pode ser cumprida por outra pessoa).

A obrigação de não fazer, por sua vez, é uma prestação negativa consistente na abstenção, pelo devedor, da prática de determinado ato.

Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida (art. 814, *caput*, do CPC). Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo (art. 814, parágrafo único, do CPC).

5.1. PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNGÍVEL

Recebida a petição inicial, o executado será citado para satisfazer a obrigação no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo (art. 815 do CPC).

Se o executado satisfizer a obrigação no prazo designado, a execução será extinta. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, o exequente terá duas opções:

- **Requerer, nos próprios autos, a satisfação da obrigação por terceiro à custa do executado:** o juiz ouvirá o executado e, em seguida decidirá. Deferido o pedido, o exequente adiantará as quantias previstas na proposta (art. 817 do CPC). Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 (dez) dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação e extinguirá a execução. Havendo impugnação, o juiz, após ouvir a parte contrária, decidirá (art. 818 do CPC). Caso o terceiro contratado não realize a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 (quinze) dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante (art. 819, *caput*, do CPC). Ouvido o contratante no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo (art. 819, parágrafo único, do CPC);
- **Requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos:** optando o exequente pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deverá requerer, nos mesmos autos, a apuração do valor das perdas e danos em liquidação, a qual seguirá o rito do art. 509 do CPC. Apurado o valor, o processo seguirá o procedimento da execução por quantia certa (art. 816, parágrafo único, do CPC).

5.2. PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INFUNGÍVEL

Tratando-se de obrigação infungível, o exequente poderá requerer ao juiz assine ao executado prazo para cumpri-la (art. 821, *caput*, do CPC). Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa (art. 821, parágrafo único, do CPC). A liquidação observará o art. 509 do CPC.



5.3. PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

O título executivo pode prever uma obrigação de abstenção do devedor, ou seja, um não fazer. Proposta a execução, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo (art. 822 do CPC). Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos (art. 823, *caput*, do CPC).

Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa (art. 823, parágrafo único, do CPC).

6. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

Segundo dispõe o art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

A execução por quantia certa realiza-se por meio da expropriação de bens do executado para a satisfação do crédito do exequente. A expropriação consiste em: a) adjudicação; b) alienação; c) apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (art. 825 do CPC). Não obstante, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC).

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797, *caput*, do CPC). Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência (art. 797, parágrafo único, do CPC).

6.1. PETIÇÃO INICIAL

O processo de execução terá início com a apresentação da petição inicial, a qual deve observar, além dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, os do art. 798 do CPC.

A petição inicial deverá indicar: a) a espécie de execução (quantia certa); b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Indicando bens suscetíveis de penhora, deverá o exequente, se for o caso, requerer a intimação dos terceiros referidos no art. 799 do CPC (ex.: credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando sobre o bem indicado à penhora incidir uma dessas garantias) (art. 798, II, do CPC).

A petição inicial deverá ser instruída com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (art. 798, I, do CPC).

6.2. CITAÇÃO DO DEVEDOR

Recebida a petição inicial, o juiz determinará a citação do executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três dias), fixando, ainda, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado (art. 827 do CPC).

É importante registrar que a contagem do prazo de 3 (três) dias para o pagamento corre a partir da citação do executado, pouco importando a data da juntada da segunda via do mandado aos autos (art. 829, *caput*, do CPC). A contagem do prazo, nesse caso, se amolda à regra prevista no § 3º do art. 231 do CPC (“Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação”).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º, do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º, do CPC).

Se o executado cumprir integralmente a obrigação no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 828, § 1º, do CPC).

6.3. MANDADO DE CITAÇÃO E ARRESTO PRÉVIO (OU PRÉ-PENHORA)

Ao ser admitida a execução, será expedido mandado de citação, penhora e avaliação. O executado não é citado para se defender, mas para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias.

O prazo para pagar começa a fluir a partir da efetiva citação, pouco importando a data da juntada da segunda via do mandado aos autos (art. 829, *caput*, do CPC). Além do prazo de 3 (três) dias para pagar, o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à execução, o qual, por sua vez, começará a fluir somente a partir da juntada da segunda via do mandado aos autos, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, *caput*, do CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, *caput*, do CPC).

Se o executado não for encontrado, o oficial de justiça promoverá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 do CPC). Tal arresto também é conhecido como *pré-penhora*, pois, após a citação e transcorrido o prazo de pagamento, ele se converterá em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º, do CPC).

Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º, do CPC). Frustradas as tentativas de localização do executado, e não sendo o caso de citação por hora certa, o exequente requererá a citação por edital (art. 830, § 2º, do CPC).

Se o executado for citado por edital e deixar transcorrer o prazo para a oposição de embargos à execução, o juiz nomeará curador especial (art. 72 do CPC). A atuação do curador especial não se limitará ao acompanhamento da execução em si. Tem ele legitimidade para opor embargos à execução, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 196 (“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”).

Citado o executado (pessoalmente, por hora certa ou por edital), o arresto será convertido em penhora, independentemente de termo específico.

6.4. PENHORA

Penhora é o ato executivo que afeta determinado bem à execução, servindo como garantia do crédito do exequente. É ato de constrição por excelência e concretizadora do princípio da patrimonialidade.

A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. (art. 831 do CPC).

Conforme já mencionado, do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º, do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º, do CPC). Trata-se de regra que se encontra em harmonia com o princípio da menor onerosidade da execução.

6.4.1. BENS NÃO SUJEITOS À PENHORA

Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 832 do CPC). O tema já foi estudado.

Há bens que, embora sujeitos à penhora, sua expressão econômica é irrisória frente ao custo do processo. Nesse sentido, dispõe o art. 836, *caput*, do CPC que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.

A aferição será feita pelo oficial de justiça, a quem caberá, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica (art. 836, § 1º, do CPC). Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz (art. 836, § 2º, do CPC).

6.4.2. BENS PENHORÁVEIS E ORDEM PREFERENCIAL

O CPC, no art. 835, estabelece um rol meramente exemplificativo de bens penhoráveis. A ordem do art. 835, evidentemente, será observada sempre que o patrimônio do executado for composto por uma diversidade de bens.

A ordem é a seguinte:

- **Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira:** dispõe o § 1º do art. 835 do CPC que “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no *caput* de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Isso significa dizer que em toda execução por quantia certa, a primeira tentativa de penhora de bens do devedor deve recair sobre dinheiro. O § 2º do art. 835 do CPC, para fins de substituição da penhora, equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Assim, caso a penhora recaia sobre algum outro bem que não dinheiro, se o executado oferecer fiança bancária ou seguro garantia judicial, será possível a substituição, na medida em que se equiparam a dinheiro e, portanto, gozam de prioridade;

- **Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado:** para que a penhora sobre títulos da dívida pública seja admitida, é preciso que o título tenha cotação em mercado mobiliário. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “independente de se tratar de título da dívida pública externa ou interna, somente garantem a execução fiscal ou são hábeis à compensação tributária os títulos ofertados à penhora com cotação em bolsa”¹¹⁹;
- **Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado:** os títulos de valores mobiliários são emitidos, em geral, por sociedades anônimas de capital aberto e negociados no mercado valores mobiliários. A lei nº 6.385/76, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, elenca os valores mobiliários a ela sujeitos;
- **Veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves:** os bens, móveis e imóveis, possuem, de uma forma geral, expressão econômica e, por conseguinte, admitem comercialização. Além dos bens imóveis, alguns bens móveis são sujeitos a registro, como é o caso, por exemplo, dos veículos de via terrestre, navios e aeronaves, podendo o exequente, antes mesmo da penhora, promover a averbação da pendência da execução no respectivo registro público do bem;
- **Ações e quotas de sociedades simples e empresárias:** ações e quotas de sociedades representam a participação de uma pessoa em determinada sociedade empresária. Possuem valor econômico, pois representam o capital da sociedade;
- **Percentual do faturamento de empresa devedora:** embora a penhora sobre o faturamento da empresa executada seja possível, não pode, por outro lado, gerar a inviabilidade de continuação da atividade empresarial. Daí por que deve ser admitida em caráter excepcional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça exige a observância dos seguintes requisitos para que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial;
- **Pedras e metais preciosos:** para o Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a recusa por parte do credor de bens indicados à penhora quando de difícil alienação externada, na espécie, por dúvida acerca da sua autenticidade¹²⁰;
- **Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia:** não se pode perder de vista que, ao indicar à penhora direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, o exequente deverá requerer, ainda, a intimação do promitente vendedor (art. 799, IV, do CPC) e do credor fiduciário (art. 799, I, do CPC), conforme o caso;
- **Outros direitos:** o rol do art. 354 do CPC é meramente exemplificativo, admitindo que outros bens ou direitos sejam objeto de penhora. É o que ocorre, por exemplo, com as *criptomoedas*, que por terem valor econômico, podem ser penhoradas.

¹¹⁹ AgRg no AREsp 380.735/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

¹²⁰ REsp 953.977/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007, p. 208.



7. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA: BENS IMÓVEIS E MÓVEIS EM GERAL

7.1. AUTO OU TERMO DE PENHORA

Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais (art. 839 do CPC).

O auto ou termo de penhora devem observar os seguintes requisitos formais: a) indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; nomes do exequente e do executado; descrição dos bens penhorados, com as suas características; nomeação do depositário dos bens (art. 838 do CPC).

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

7.2 FORMALIZAÇÃO DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS AUTOMOTORES

A penhora será realizada onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Pretendendo o exequente penhorar bem imóvel do executado, independentemente do local onde estiver localizado, deverá juntar aos autos certidão da respectiva matrícula, caso em que a penhora será formalizada por termo nos autos. No tocante aos veículos automotores, a penhora também será realizada por termo nos autos, quando apresentada certidão que ateste a sua existência (art. 845, § 1º, do CPC).

Formalizada a penhora, será, no mesmo ato, nomeado depositário.

Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora por termo nos autos, na forma prevista no art. 845, § 1º, do CPC, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação (art. 845, § 2º, do CPC).

A averbação de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico, obedecendo as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837 do CPC). Para tanto, é preciso que o bem seja sujeito a registro e haja sistema eletrônico que permita a averbação *on-line* no registro público. É o que ocorre, por exemplo, no sistema Renajud (sistema *on-line* de restrição judicial de veículos), criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

7.3. RESISTÊNCIA DO EXECUTADO E ORDEM DE ARROMBAMENTO

Quando a penhora é realizada por oficial de justiça, evidentemente que será necessário o comparecimento deste no local onde está localizada a coisa, a fim de realizar o ato. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento (art. 846, *caput*, do CPC). Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presume estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência, devendo. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação (art. 846, §§ 1º e 4º, do CPC).

Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens (art. 846, § 2º, do CPC).

Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência (art. 846, § 3º, do CPC).

7.4. DEPÓSITO

A penhora é ato complexo, pois realizada mediante a apreensão e o depósito dos bens (art. 839 do CPC). Independentemente da forma de realização da penhora (*on-line*, termo, auto ou termo nos autos), deve ser nomeado, no ato, depositário para o bem constrito.

O art. 840 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto à nomeação do depositário, a saber:

- **Quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos:** serão depositados em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;
- **Bens móveis, semoventes, imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos:** serão depositados em poder do depositário judicial. Não havendo depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente;
- **Imóveis rurais, direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola:** serão depositados em poder do executado, mediante caução idônea.

Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (art. 840, § 2º, do CPC). As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate (art. 840, § 3º, do CPC). O registro do valor estimado de resgate é importante, porque, em caso de extravio ou danificação do bem pela instituição financeira depositária, caberá a ela o pagamento do valor respectivo.

7.5. INTIMAÇÕES

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado (art. 841, *caput*, do CPC).

Se a penhora for realizada na presença do executado, será considerado intimado. Se a penhora não for realizada na presença do executado, a intimação será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença (art. 841, § 1º, do CPC). Se o executado ainda não houver constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente, de preferência por via postal (art. 845, § 2º, do CPC).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC). O art. 842 do CPC refere-se à hipótese em que apenas um dos cônjuges é executado, mas a penhora recai sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel.

Além do cônjuge, também serão intimados da penhora as pessoas referidas no art. 799 do CPC, quais sejam: a) credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; b) titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação; c) promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja

promessa de compra e venda registrada; d) promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; e) superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão; f) proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário; g) da sociedade, no caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, para o fim previsto no art. 876, § 7º do CPC; h) titular da construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje; i) titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base.

8. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA: ESPECIALIDADES

8.1. PENHORA DE DINHEIRO EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA

A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira é feita de forma eletrônica, através do sistema *Bacenjud*, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. Esse sistema foi criado por meio de convênio entre o Banco Central do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O art. 854 do CPC estabelece o procedimento da formalização da penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

A requerimento da parte, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art. 854 do CPC).

No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz tornará indisponíveis os ativos financeiros do executado e determinará a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo (art. 854, §§ 1º e 2º, do CPC).

Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º, do CPC).

Se o juiz reconhecer a impenhorabilidade ou o excesso, determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas (art. 854, § 4º, do CPC).

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, a indisponibilidade será convertida em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, § 5º, do CPC).

Se o executado pagar a dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente e de forma eletrônica, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade (art. 854, § 6º, do CPC).

A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz (art. 854, § 8º, do CPC).

8.2. PENHORA DE CRÉDITOS

A penhora que recai sobre créditos pertencentes ao executado (ex.: títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários etc.) considera-se realizada com a intimação do terceiro (devedor do executado) e do executado, da seguinte forma:

- Ao terceiro (devedor), para que não pague ao executado (credor);
- Ao executado (credor), para que não pratique ato de disposição do crédito.

Se o crédito estiver representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, a penhora será realizada mediante apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado (art. 856, *caput*, do CPC). Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância (art. 856, § 1º, do CPC), o qual só será exonerado da obrigação se depositar em juízo a importância da dívida (art. 856, § 2º, do CPC).

Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução (art. 856, § 3º, do CPC).

A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos (art. 856, § 4º, do CPC).

Realizada a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Nesse caso, o exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que deverá declarar sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora. A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens (art. 857 do CPC).

Se a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento (art. 858 do CPC).

Recaindo a penhora sobre direito a prestação ou a restituição de coisa determinada, o art. 859 do CPC diz que “o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução” (art. 859 do CPC).

Por fim, quando o executado estiver pleiteando em juízo algum direito, a penhora pode recair sobre esse direito litigioso, caso em que ela será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (art. 860 do CPC). Trata-se do que se convencionou chamar de *penhora no rosto dos autos*.

8.3. PENHORA DE QUOTAS OU AÇÕES DE SOCIEDADES PERSONIFICADAS

Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: a) apresente balanço especial, na forma da lei; b) ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; c) proceda à liquidação das quotas ou das ações, caso não haja interesse dos sócios na aquisição das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro (art. 861 do CPC). Nessa última hipótese, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação (art. 861, § 3º, do CPC).

Para evitar a liquidação das quotas ou das ações e buscando manter a estrutura da societária, a própria sociedade poderá adquirir as quotas ou ações penhoradas, sem redução do capital social, mediante utilização de suas reservas (art. 681, § 1º, do CPC), hipótese que não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso (art. 681, § 2º, do CPC).

O prazo de até 3 (três) meses, previsto no art. 861, *caput*, do CPC, poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: a) superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou b) colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária (art. 681, § 4º, do CPC).

Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do art. 861 do CPC seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações (art. 681, § 5º, do CPC).

8.4. PENHORA DE EMPRESA, OUTROS ESTABELECIMENTOS E SEMOVENTES

Nos termos do art. 862, *caput*, do CPC, “quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração”. O juiz ouvirá as partes e, em seguida, decidirá.

A penhora de empresa, a qual é tratada nos arts. 862 a 865 do CPC não se confunde com a penhora sobre faturamento de empresa, tratada no art. 866 do CPC.

Tratando-se de penhora sobre edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador (art. 862, § 3º, do CPC). Com isso, resguardam-se os direitos dos adquirentes das demais unidades imobiliárias.

Caso seja necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, os adquirentes formarão uma comissão de representantes que exercerá a administração provisória da incorporação. Se a construção for financiada, a administração será exercida por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes (art. 862, § 4º, do CPC).

A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores (art. 863, *caput*, do CPC).

Se a penhora recair sobre renda ou sobre determinados bens, o administrador-depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel, previsto nos arts. 867 a 869 do CPC (art. 863, § 1º, do CPC). Por outro lado, se a penhora recair sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão (art. 863, § 2º, do CPC).

A penhora sobre navio e aeronave não impede esses bens continuem navegando ou operando até a alienação, porém o juiz, ao conceder a autorização a navegação ou operação, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto sem que o executado faça o seguro usual contra riscos (art. 864 do CPC).

8.5. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA

Também de caráter excepcional, o faturamento da empresa pode sofrer penhora. Evidentemente, será preciso compatibilizar o direito do exequente ao crédito com os princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa.

Nesse sentido, dispõe o art. 866 do CPC que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.

Ao deferir a penhora sobre o faturamento da empresa, o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866, § 1º, do CPC). O juiz nomeará, ainda, administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (art. 866, § 2º, do CPC).

Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel (art. 866, § 3º, do CPC).

8.6. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE COISA MÓVEL OU IMÓVEL:

A penhora sobre frutos e rendimentos de bens móveis e imóveis deve se mostrar, no caso concreto, eficiente para a satisfação do crédito do exequente, além de atender ao princípio da menor onerosidade da execução, conforme prevê o art. 867 do CPC.

Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 868, *caput*, do CPC). A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis (art. 868, § 1º, do CPC). Incumbirá ao exequente providenciar a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial (art. 868, § 2º, do CPC).

O juiz poderá nomear como administrador-depositário o próprio exequente ou executado, ouvida previamente a parte contrária. A nomeação, aliás, depende do consentimento da parte contrária. Não havendo acordo, o juiz nomeará profissional qualificado para o desempenho da função (art. 869, *caput*, do CPC).

O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente (art. 869, § 1º, do CPC). Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem (art. 869, § 2º, do CPC).

Tratando-se de imóvel arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador (art. 869, § 3º, do CPC). O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado (art. 869, § 4º, do CPC).

As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida (art. 869, § 5º, do CPC), cabendo ao exequente dar ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas (art. 869, § 6º, do CPC).

9. MODIFICAÇÕES DA PENHORA

Como regra, a penhora é irretratável. Contudo, é possível que, após a formalização da penhora, haja necessidade de substituição, redução, ampliação ou renovação da penhora.

9.1. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA

No prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, o executado poderá requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 847, *caput*, do CPC).

Caberá ao executado demonstrar que a substituição, além de lhe ser menos onerosa, não frustra o direito do exequente. Por isso, ao indicar bem à penhora em substituição ao já penhorado, deverá o executado: a) comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; b) descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; c) descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; d) identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e) atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos (art. 847, § 1º, do CPC).

Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora (art. 847, § 2º, do CPC). Tratando-se de indicação de bem imóvel, o executado deverá apresentar expressa anuência do seu cônjuge, salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens (art. 847, § 3º, do CPC).

Além das hipóteses de substituição por iniciativa exclusiva do executado (art. 847 do CPC), há, ainda, situações outras que permitem que qualquer das partes requeira a substituição do bem penhorado. São elas: a) quando a penhora não obedecer à ordem legal; b) quando a penhora não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; c) quando, havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; d) quando, havendo bens livres, a penhora tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; e) quando a penhora incidir sobre bens de baixa liquidez; f) quando fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; g) quando o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (art. 848 do CPC).

Para fins de substituição da penhora, equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, § 2º, do CPC). Assim, independentemente do bem objeto da penhora, será possível a sua substituição por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 848, parágrafo único, do CPC).

Substituído o bem inicialmente penhorado, será lavrado novo termo (art. 849 do CPC).

9.2. REDUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA PENHORA

Se, após a realização da penhora, sobrevier alteração significativa do valor de mercado dos bens penhorados, será admitida a redução, a ampliação ou a transferência da penhora (art. 850 do CPC).

9.3. RENOVAÇÃO DA PENHORA

Após a realização da primeira penhora, pode sobrevir causa que imponha a renovação do ato. Não se trata de substituição ou transferência da penhora, mas de realização de uma segunda penhora, a qual pode ou não recair sobre o mesmo bem. O art. 851 do CPC elenca as causas que ensejarão a renovação da penhora. São elas: a) quando a primeira for anulada; b) quando, executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; c) quando o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

9.4. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS PENHORADOS

Efetuada a penhora e decidida eventual impugnação, ingressa-se na fase de expropriação, a qual se dará por adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (art. 825 do CPC).

Não obstante, o código admite, em situações excepcionais, a alienação antecipada dos bens penhorados nos seguintes casos:

- Quando se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração (art. 852, I, do CPC);
- Quando houver manifesta vantagem (art. 852, II, do CPC).

Na primeira hipótese autorizadora da alienação antecipada (inciso I), a vantagem decorre, evidentemente, do fato de se evitar a depreciação ou deterioração do bem. Na segunda hipótese (inciso II), basta que haja manifesta vantagem na alienação, independentemente de se tratar de bem sujeito a depreciação ou deterioração.

Requerida a alienação antecipada por uma das partes, o juiz ouvirá a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir (art. 853, *caput*, do CPC)

Além das hipóteses previstas no art. 852, a alienação antecipada pode ser objeto de negócio jurídico processual (art. 190 do CPC).

10. AVALIAÇÃO

Sempre que necessário, o bem penhorado deverá ser avaliado antes de ser expropriado. Tal avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 870, *caput*, do CPC). Contudo, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo (art. 870, parágrafo único, do CPC).

A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: a) os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; b) o valor dos bens (art. 872 do CPC).

Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação (art. 872, § 1º, do CPC). Nesse caso, realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias, decidindo o juiz em seguida.

A avaliação será dispensada nas seguintes hipóteses: a) quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, salvo se houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem, caso em que a avaliação poderá ser realizada; b) quando se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; c) quando se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; d) quando se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Será admitida nova avaliação quando: a) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; b) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; c) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Realizada a nova avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: a) reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; b) ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

11. EXPROPRIAÇÃO

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem (art. 875 do CPC).

A expropriação consiste em: a) adjudicação; b) alienação; c) apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (art. 825 do CPC).

11.1. ADJUDICAÇÃO

A adjudicação é modalidade de expropriação por meio da qual o próprio bem penhorado é dado em pagamento ao exequente como forma de extinção, total ou parcial, da execução, ou transferido a determinadas pessoas legitimadas.

A adjudicação é medida expropriatória preferencial (art. 880, *caput*, do CPC), pois, além de ser mais célere e menos burocrática, é também menos onerosa. Pode ser realizada enquanto o bem penhorado não for alienado por iniciativa particular ou em leilão judicial.

Além do exequente, têm legitimidade para requerer a adjudicação:

- Credor com garantia real (art. 876, § 5º, do CPC);
- Credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem (art. 876, § 5º, do CPC);
- Cônjuge, companheiro, descendentes e ascendentes do executado (art. 876, § 5º, do CPC);
- Demais sócios, quando a penhora recair sobre quota social ou ação de sociedade anônima fechada, de titularidade do executado (art. 876, § 7º, do CPC).

Cumpre registrar que o exequente não necessariamente terá preferência na adjudicação. Sua preferência é de ordem processual, pois decorre do art. 876, *caput*, do CPC, não se sobrepondo,



contudo, às preferências de direito material, como é o caso, por exemplo do credor com garantia real sobre o bem (ex.: credor hipotecário).

Formulado o pedido de adjudicação, o executado será intimado: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; c) por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246 do CPC¹²¹, não tiver procurador constituído nos autos (art. 876, § 1º, do CPC).

Havendo mais de um pretendente na adjudicação – e não havendo crédito preferencial –, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem (art. 876, § 6º, do CPC).

Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação (art. 877, *caput*, do CPC).

A adjudicação se considera perfeita e com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado. Na oportunidade, serão, desde logo, expedidos:

- Carta de adjudicação e mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel (art. 877, § 1º, do CPC). A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão (art. 877, § 2º, do CPC);
- Ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel (art. 877, § 1º, do CPC).

11.1.1. REMIÇÃO

Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC).

Tratando-se de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido (art. 877, § 3º, do CPC).

Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel (art. 877, § 4º, do CPC).

11.2. ALIENAÇÃO

A alienação é a segunda forma de expropriação de bens prevista no CPC. Pode se dar por iniciativa particular ou por leilão judicial (eletrônico ou presencial).

¹²¹ § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

11.2.1. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR

Nos termos do art. 880 do CPC, “não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário”.

A alienação por iniciativa particular deve observar os requisitos formais estabelecidos pelo juiz, quais sejam, o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem (art. 880, § 1º, do CPC). No tocante ao preço mínimo, o CPC não o vincula ao valor da avaliação, o qual servirá apenas como um norte. Caberá ao juiz, conforme o caso concreto, estabelecer, com proporcionalidade, o preço mínimo do bem para fins de alienação, sendo vedado, obviamente, a fixação de preço vil (art. 891 do CPC).

O exequente poderá optar por promover a alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Dispõe o § 3º do art. 880 que “os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos”. Ademais, nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3º, a indicação será de livre escolha do exequente (art. 880, § 4º, do CPC).

Realizada a alienação, sua formalização ocorrerá por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: a) a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; b) a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (art. 880, §2º, do CPC).

11.2.2. ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL

A) CARACTERÍSTICAS DO LEILÃO JUDICIAL

Não efetivada a adjudicação e não requerida a alienação por iniciativa particular, proceder-se-á à alienação em leilão judicial. As principais características dessa modalidade de alienação são:

- Será realizada quando não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular (art. 881, *caput*, do CPC);
- Será realizada por leiloeiro público (art. 881, § 1º, do CPC);
- Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente (art. 883 do CPC);
- Somente se não for possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial (art. 882, *caput*, do CPC);
- Sendo presencial, o leilão ocorrerá em local designado pelo juiz (art. 882, § 3º, do CPC);
- Todos os bens devem ser alienados em leilão público, salvo aqueles a cargo de corretores de bolsa de valores (art. 881, § 2º, do CPC);
- A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça (art. 882, § 1º, do CPC);

- A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital (art. 882, § 3º, do CPC);
- O preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante serão estabelecidas pelo juiz (art. 885 do CPC).

B) LEILOEIRO

Designado o leiloeiro, a ele incumbirá: a) publicar o edital, anunciando a alienação; b) realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz; c) expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias; d) receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação; e) prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito (art. 884 do CPC).

O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo a publicação do edital ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão (art. 887, § 1º, do CPC).

A comissão do leiloeiro, estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz, será paga pelo arrematante (art. 884, parágrafo único, do CPC).

C) EDITAL DO LEILÃO

O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: a) a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; b) o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; c) o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; d) o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; e) a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; f) menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados; g) no caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação (art. 886 do CPC).

O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local (art. 887, §§ 2º e 3º, do CPC).

Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em outros sítios eletrônicos (art. 887, § 4º, do CPC).

Tratando-se de leilão de imóveis e de veículos automotores, os editais serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios (art. 887, § 5º, do CPC).

O juiz poderá, ainda, determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução (art. 887, § 6º, do CPC).

D) INTIMAÇÕES

Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: a) o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; b) o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; c) o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; d) o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; e) o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; f) o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; g) o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; h) a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado (art. 889 do CPC).

Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único, do CPC).

E) NÃO REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, cabendo ao leiloeiro providenciar a ampla divulgação do novo leilão, nos termos do art. 887 do CPC (art. 888 do CPC). Se a transferência do leilão for causada por culpa do escrivão, do chefe de secretaria ou do leiloeiro, responderá o culpado pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 (cinco) dias a 3 (três) meses, em procedimento administrativo regular (art. 888, parágrafo único, do CPC).

F) ARREMATAÇÃO

Todo aquele que estiver no pleno gozo da administração de seus bens pode oferecer lances, objetivando a arrematação do bem objeto da alienação.

Há certas pessoas, porém, que, em razão do vínculo existente entre ela e o processo, as partes ou o bem objeto da alienação, são impedidas de oferecer lances e, consequentemente, arrematar o bem. São elas: a) os tutores, os curadores, os testamenteiros, os administradores ou os liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade; b) os mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados; c) o juiz, o membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, o escrivão, o chefe de secretaria e os demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade; d) os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta; e) os leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados; f) os advogados de qualquer das partes (art. 890 do CPC).

Serão impedidos de lançar no novo leilão, ainda, o arrematante e seu fiador remissos, ou seja, quando, no primeiro leilão, não pagaram o preço no prazo estabelecido (art. 897 do CPC).

Não será aceito lance que ofereça preço vil, ou seja, preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. Caso não tenha sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891 do CPC).

G) PAGAMENTO

A arrematação, como regra, é feita mediante pagamento à vista, em dinheiro, mediante depósito judicial ou por meio eletrônico, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso (art. 892, *caput*, do CPC).

Se o exequente participar do leilão e arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço. Porém, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, o exequente-arrematante depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC).

Havendo mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem (art. 892, § 2º, do CPC).

Tratando-se de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os Municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta (art. 892, § 3º, do CPC).

Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um pretendente (lançador), terá preferência aquele que se propuser a arrematar todos os bens, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles (art. 893 do CPC).

Se o bem penhorado for imóvel, caso seja possível a sua cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução (art. 894, *caput*, do CPC). A alienação por partes, entretanto, deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado (art. 894, § 1º, do CPC). Não havendo lançador interessado na arrematação de parte do imóvel, far-se-á a alienação do bem em sua integridade (art. 894, § 1º, do CPC).

O código permite, ainda, o pagamento de forma parcelada, ou seja, em prestações. Nesse caso, o interessado deverá apresentar proposta por escrito, observando as seguintes regras:

- Até o início do primeiro leilão, a proposta de aquisição do bem deve ser feita por valor não inferior ao da avaliação (art. 895, I, do CPC);
- Até o início do segundo leilão, a proposta de aquisição do bem pode ser feita por valor inferior ao da avaliação, desde que não seja considerado vil (art. 895, II, do CPC).

A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, § 1º, do CPC). Deverá o interessado proponente, ainda, indicar o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo (art. 895, § 2º, do CPC).

Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC).

Se o fiador do arrematante pagar o valor do lance e a multa, poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida (art. 898 do CPC).

No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado (art. 895, § 9º, do CPC).

Caso o arrematante atrase o pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Nesse caso, o exequente ficará autorizado a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos próprios autos da execução em que se deu a arrematação (art. 895, §§ 4º e 5º, do CPC).

A apresentação de proposta de pagamento em prestações não suspende o leilão, sendo certo que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, §§ 6º e 7º, do CPC).

Se houver mais de uma proposta de pagamento parcelado, o juiz decidirá da seguinte forma: a) se as propostas estipularem condições diferentes, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; b) se as propostas estipularem as mesmas condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

Objetivando proteger os interesses de incapaz, estabelece o art. 896 do CPC que “quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano”. Se, durante esse prazo, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão (art. 896, § 1º, do CPC). Contudo, se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo (art. 896, § 2º, do CPC). Em ambos os casos, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel durante o prazo de adiamento, findo o qual o imóvel será submetido a novo leilão (art. 896, §§ 3º e 4º, do CPC).

H) SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO E DO LEILÃO

Nos termos do art. 889 do CPC, “será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução”. Esse dispositivo disciplina a hipótese em que, havendo mais de um bem penhorado, antes da arrematação do último, o valor alcançado é suficiente para a satisfação do exequente e das despesas da execução. A rigor, não se trata de “suspensão”, mas de verdadeiro encerramento antecipado da arrematação.

O art. 900 do CPC determina a suspensão do leilão, quando for ultrapassado o horário de expediente forense, caso em que o leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital.

I) AUTO DE ARREMATAÇÃO

Arrematado o bem, será lavrado pelo agente responsável pelo leilão, de imediato, o respectivo auto, assinado pelo leiloeiro, pelo juiz e pelo arrematante. O auto de arrematação poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem (art. 901 do CPC). Após, o auto será juntado ao processo.

A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, do CPC).

A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (art. 901, § 2º, do CPC).

Tratando-se de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel (art. 902 do CPC).

Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º do art. 903 do CPC¹²², assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

11.2.3. INVALIDAÇÃO, INEFICÁCIA E RESOLUÇÃO DA ARREMATAÇÃO

Ressalvadas outras situações previstas no CPC, a arrematação poderá ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida nas seguintes hipóteses, conforme previsão do art. 903, § 1º, do CPC:

- **Arrematação inválida:** quando realizada por preço vil ou com outro vício;
- **Arrematação ineficaz:** quando não intimado o credor com garantia real, conforme determina o art. 804 do CPC (“A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado”);
- **Resolução da arrematação:** quando não for pago o preço ou não for prestada a caução.

O pedido de invalidação, ineficácia ou resolução deverá ser formulado no prazo decadencial de 10 (dez) dias, contado do aperfeiçoamento da arrematação. Ultrapassado esse prazo sem que tenha havido requerimento, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse (art. 903, §§ 2º e 3º, do CPC).

11.2.4. AÇÃO ANULATÓRIA AUTÔNOMA

Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (art. 903, § 4º, do CPC).

Todos os envolvidos no processo de execução (exequente, executado e arrematante) deverão compor essa nova relação processual. Quem propuser a ação deverá requerer a citação dos demais em litisconsórcio passivo necessário. Se a ação for proposta por terceiro, todos aqueles sujeitos formarão um litisconsórcio passivo necessário. A sentença, ao final, terá natureza constitutiva negativa.

¹²²§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

11.2.5. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO

O arrematante poderá desistir da arrematação nas seguintes hipóteses, conforme § 5º do art. 903 do CPC:

- Se provar, nos 10 (dez) dias seguintes à arrematação, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;
- Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º do art. 903 do CPC;
- Se o arrematante for citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º do art. 903 do CPC. Nesse caso, o arrematante deve apresentar desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.

Homologada a desistência, será imediatamente devolvido ao arrematante o depósito que tiver feito.

11.2.6. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

No âmbito do processo de execução, não se admite a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante. Trata-se, evidentemente, de ato violador à boa-fé processual, razão pela qual o § 6º do art. 903 do CPC o considera como ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

11.3. PAGAMENTO AO CREDOR

A satisfação do crédito do exequente será feita da seguinte forma: a) pela entrega do dinheiro; b) pela adjudicação dos bens penhorados (art. 904 do CPC).

O exequente, nos termos do art. 905 do CPC, poderá levantar, mediante autorização judicial, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando:

- A execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados;
- Não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.

Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências (art. 908, *caput*, do CPC).

É terminantemente proibida a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos durante o plantão judiciário (art. 905, parágrafo único, do CPC).

Recebido o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. A expedição do mandado de levantamento, contudo, poderá ser substituída por transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente (art. 906 do CPC).

Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado (art. 907 do CPC).

Tratando-se de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza *propter rem*, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência (art. 908, § 1º, do CPC). Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora (art. 908, § 2º, do CPC).

12. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

12.1. INTRODUÇÃO

Entende-se por Fazenda Pública as seguintes pessoas jurídicas de direito público: União, estados, municípios e suas respectivas autarquias e fundações. As pessoas jurídicas integrantes da administração indireta que ostentem personalidade jurídica de direito privado (empresas públicas e sociedades de economia mista) não integram o conceito de Fazenda Pública e, portanto, a elas não se aplicam, como regra, as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, assim como os regimes especiais de execução.

O débito da Fazenda Pública pode constar em título executivo judicial (ex.: condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida na dívida ativa) ou título executivo extrajudicial (ex.: contrato para a construção de uma escola)¹²³. No primeiro caso, a execução ocorrerá, como regra, nos mesmos autos em que o título foi constituído, mediante a instauração da fase de cumprimento de sentença (art. 534 do CPC). No segundo caso, mediante execução de título executivo extrajudicial (art. 910 do CPC).

As linhas seguintes serão dedicadas à execução contra a Fazenda Pública fundada em título executivo extrajudicial.

12.2. PROCEDIMENTO

Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. Por se tratar de prazo próprio, não se aplica a contagem em dobro (art. 182, § 2º, do CPC).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal¹²⁴.

Opondo embargos à execução, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

No mais, aplica-se à execução contra a Fazenda Pública o procedimento previsto para o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (arts. 534 e 535 do CPC).

13. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

A execução de alimentos fundada em título executivo judicial se desenvolve mediante cumprimento de sentença, na forma dos arts. 528 a 533 do CPC.

¹²³ Nos termos da súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

¹²⁴ Sobre o procedimento de expedição e pagamento dos precatórios e requisição de pequeno valor, ver Capítulo XXIX, item 10.6.



O procedimento da execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial é, basicamente, o mesmo daquele previsto para o cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 911, parágrafo único, do CPC.

Recebida a petição inicial, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, *caput*, do CPC).

Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (art. 528, § 2º, do CPC).

Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, do CPC).

A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns (art. 528, § 4º, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, o executado deverá ser posto imediatamente em liberdade, sem prejuízo de nova decretação da prisão relativamente às parcelas que se vencerem no curso do processo. As parcelas pretéritas, incluindo-se as que geraram a decretação da prisão, não serão consideradas como pagas. Isso porque a prisão civil é meio de coerção pessoal para o adimplemento da obrigação, sendo que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, do CPC).

Se o executado pagar a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão (art. 528, § 6º, do CPC).

Não se pode perder de vista que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do CPC).

Se o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia (art. 912, *caput*, do CPC). Nesse caso, ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (art. 912, § 1º, do CPC). O ofício conterá os nomes e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração (art. 912, § 2º, do CPC).

A execução pelo rito da prisão civil é faculdade do credor. Assim, ao propor a execução, deverá manifestar-se sobre o procedimento que pretende seguir. Caso não requeira a execução pelo rito da prisão, será observado o procedimento da execução por quantia certa, previsto no art. 824 e seguintes do CPC, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação (art. 913 do CPC).

14. EMBARGOS À EXECUÇÃO

14.1. INTRODUÇÃO

Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento incidental e conexa (em sentido amplo)¹²⁵ à execução. Trata-se de instrumento de contra-ataque do executado, cujo objetivo é a extinção ou a modificação da relação jurídica que fundamenta a execução.

Nos embargos à execução, o executado passa a ocupar o polo ativo, enquanto o exequente o polo passivo. Por conseguinte, é do executado (embargante) o ônus da prova quanto à insubsistência ou o excesso da execução.

Assim como execução de título executivo extrajudicial não se confunde com o a fase ou a ação de cumprimento de sentença, há distinção quanto aos instrumentos de que dispõe o devedor. Na execução, o devedor deve se insurgir à pretensão do exequente por meio de uma ação de conhecimento incidental, qual seja, os embargos à execução. Por outro lado, na fase ou ação de cumprimento de sentença, o devedor poderá se insurgir por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual tem natureza de incidente processual de defesa e é apresentada nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Assim como há afinidade entre o processo de execução e o cumprimento de sentença (ambos são formas de execução), há também grande similitude entre os embargos e a impugnação, notadamente no que toca às questões que podem ser suscitadas (ex.: inexecutibilidade do título, penhora incorreta, excesso de execução etc.). Não obstante, por opção legislativa, o CPC conferiu aos embargos e à impugnação natureza jurídica e estrutura procedimental particulares que as distinguem, sobretudo no âmbito recursal.

14.2. COMPETÊNCIA

Como regra, os embargos serão opostos perante o juízo competente para a execução (art. 914, § 1º, do CPC). Trata-se de competência funcional, portanto absoluta.

Quando a execução for realizada por carta precatória (ex.: penhora realizada em foro diverso da execução), os embargos poderão ser oferecidos tanto no juízo deprecado quanto no juízo deprecante, mas a competência para julgá-los poderá ser diferente. Vejamos:

- Na execução por carta, ainda que os embargos sejam opostos no juízo deprecado, a competência para o seu julgamento será do juízo deprecante, ou seja, onde tramita o processo de execução;
- Se os embargos versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas, a competência para julgamento dos embargos será do juízo deprecado (art. 914, § 2º, do CPC).

14.3. PRAZO

Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, *caput*, do CPC).

¹²⁵ Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 18ª edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 336.



Havendo mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último (art. 915, § 1º, do CPC).

Tratando-se de execução por carta, deverão ser observadas as seguintes regras:

- Versando os embargos unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, o prazo será contado da avaliação ou da alienação dos bens;
- Versando sobre questões diversas da anterior, o prazo será contado da juntada, nos autos de origem, do comunicado de cumprimento da citação pelo juízo deprecado ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida.

Dispõe o § 4º do art. 915 do CPC que “nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante”.

Por fim, ainda que haja um litisconsórcio passivo na execução e os executados possuam advogados distintos de escritórios de advocacia distintos, não se aplicará a regra do art. 229 do CPC (“Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”). Isso porque os embargos não são contestação, impugnação ou manifestação. Embargos são ação autônoma.

14.4. PARCELAMENTO

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, *caput*, do CPC).

A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC).

Efetuada o depósito de trinta por cento do valor requerido pelo exequente, e requerido o parcelamento, o exequente será intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos para o parcelamento e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias (art. 916, § 1º, do CPC). O parcelamento a que se refere o art. 916 do CPC tem natureza de moratória legal. Logo, o seu deferimento não depende do consentimento do exequente. Este apenas deverá se manifestar previamente quanto ao preenchimento, pelo executado, dos requisitos formais previstos no *caput* do art. 916 do CPC.

Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento (art. 916, § 2º, do CPC).

Deferido o pedido de parcelamento, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPC).

O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: a) o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; b) a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.

Por fim, o parcelamento de que trata o art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença (art. 916, § 7º, do CPC). Isso porque, no cumprimento de sentença, o credor teve que

passar por toda uma fase de conhecimento para a obtenção do título executivo judicial. Nesse sentido, admitir o parcelamento seria prestigiar a demora na satisfação do crédito.

14.5. OBJETO DOS EMBARGOS

O leque de matérias que podem ser suscitadas em sede de embargos à execução é bastante amplo. Basta atentar-se para o inciso VI do art. 917, o qual permite ao embargante alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”. O referido dispositivo revela um ponto importante: o rol do art. 917 do CPC é meramente exemplificativo.

Vejamos as matérias que podem ser alegadas nos embargos:

14.5.1. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO

Inexequível é o título que não atende aos requisitos formais para a sua constituição ou que não goza de liquidez. Assim, o documento particular não assinado pelo devedor ou por 2 (duas) testemunhas, por exemplo, não possui exequibilidade. Da mesma forma, se a obrigação não for líquida, não há exequibilidade do título.

A exigibilidade, por sua vez, está relacionada à possibilidade de a obrigação constante no título produzir os seus efeitos imediatamente. Nesse sentido, será inexigível a obrigação quando a produção dos efeitos encontra algum óbice, fático ou jurídico. A título de exemplo, será inexigível o título: a) enquanto não ocorrer o vencimento da dívida; b) enquanto não realizada a condição; c) enquanto o exequente não adimplir a contraprestação que lhe corresponde.

14.5.2. PENHORA INCORRETA OU AVALIAÇÃO ERRÔNEA

Fala-se em penhora incorreta quando há algum vício formal em sua constituição, quando ela recai sobre bem impenhorável ou quando não observa a ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC. Por sua vez, fala-se em avaliação errônea quando o valor declarado pelo oficial de justiça avaliador (ou outro avaliador) no laudo não espelha o valor do bem objeto da penhora.

Se a penhora ou avaliação for realizada após a apresentação dos embargos, não serão cabíveis novos embargos à execução, tendo em vista a preclusão. Contudo, por se tratar de fato superveniente, a alegação de incorreção na penhora ou na avaliação poderá ser feita por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Nesse sentido, dispõe o § 1º do art. 917 do CPC prevê que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”.

14.5.3. EXCESSO DE EXECUÇÃO OU CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES

Haverá excesso de execução quando: a) o exequente pleiteia quantia superior à do título; b) a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; c) a execução se processa de modo diferente do que foi determinado no título; d) o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; e) o exequente não prova que a condição se realizou (art. 917, § 2º, do CPC).

Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, § 3º, do CPC).

Também haverá excesso no caso de cumulação indevida de execuções. Nos termos do art. 780 do CPC, “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,



quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.

14.5.4. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS OU ÚTEIS, NOS CASOS DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA

Trata-se de matéria que somente pode ser alegada na execução que tenha por objeto obrigação de entrega de coisa certa. Nos termos do art. 1.219 do CC, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

Se o exequente (embargado), reconhecendo o direito do executado (embargante) à indenização das benfeitorias, depositar o valor, o juiz deverá determinar a entrega da coisa e, uma vez cumprida a obrigação, extinguir os embargos e a execução e autorizar o levantamento, pelo executado, da quantia depositada.

14.5.5. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA OU RELATIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

Assim como ocorre na fase de conhecimento (art. 337, II, do CPC), é possível que o executado alegue a incompetência, absoluta ou relativa, do juízo (ex.: executado alega a inobservância da cláusula de eleição de foro constante no título).

Não se pode perder de vista que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz (art. 337, § 5º, do CPC).

14.5.6. QUALQUER MATÉRIA QUE LHE SERIA LÍCITO DEDUZIR COMO DEFESA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO

O executado também poderá alegar qualquer outra matéria que a ele seria permitido deduzir como defesa em processo de conhecimento. Tanto questões processuais (ex.: ausência de pressupostos processuais) quanto de mérito (inexistência da obrigação, pagamento, compensação, novação etc.) são admitidas.

14.6. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DO JUIZ

Na execução de título executivo extrajudicial, o executado também poderá arguir a suspeição ou o impedimento do juiz (art. 525, § 2º, do CPC). Não se trata de matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, mas de verdadeira exceção que deverá seguir o procedimento previsto nos arts. 146 e 148 do CPC (art. 917, § 7º, do CPC).

14.7. PROCEDIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Os embargos são opostos mediante apresentação da petição inicial e distribuídos por dependência ao juízo onde se processa a execução. A petição inicial deverá observar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Para oposição de embargos à execução, não se exige prévia garantia do juízo, a qual somente é exigida para fins de concessão de efeito suspensivo.

O juiz rejeitará liminarmente os embargos nas seguintes hipóteses: a) intempestividade; b) quando presente alguma causa de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido; c) embargos manifestamente protelatórios.

A apresentação de embargos meramente protelatórios configura conduta atentatória à dignidade da justiça, podendo o juiz, conforme a gravidade da conduta, aplicar ao executado (embargante) multa não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente (embargado), exigível nos próprios autos do processo (art. 774, parágrafo único, do CPC).

Não sendo o caso de rejeição liminar, os embargos serão admitidos, determinando o juiz a intimação do exequente (embargado), por seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Se o exequente (embargado) não apresentar resposta, será decretada a sua revelia. Contudo, não será aplicado o seu efeito material, qual seja, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, haja vista que a execução é fundada em título executivo líquido, certo e exigível.

Apresentada resposta pelo exequente (embargado), o juiz julgará imediatamente o pedido, caso esteja pronto para julgamento, ou designará audiência. Encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

O julgamento dos embargos ocorre por sentença, da qual caberá apelação. Nada impede, porém, que no curso do procedimento, o juiz profira decisão parcial de mérito.

14.8. EFEITO SUSPENSIVO

Como regra, os embargos à execução não gozam de efeito suspensivo (art. 919, *caput*, do CPC). Contudo, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC).

O pedido de efeito suspensivo pode ser formulado na petição inicial ou, a qualquer momento, no curso dos embargos. Da decisão que defere ou indefere o pedido, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, X, do CPC).

O efeito suspensivo pode abranger toda a execução ou apenas uma parte desta (ex.: limitação do valor da execução ou dos bens do executado que podem sofrer constrição). Se o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante (art. 919, § 3º, do CPC). Seja como for, a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens (art. 919, § 5º, do CPC).

A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante (art. 919, § 4º, do CPC).

Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada (art. 919, § 3º, do CPC). Contra essa decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, X, do CPC).

Em caso rejeição liminar ou improcedência dos embargos à execução, as verbas de sucumbência arbitradas serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais (art. 85, § 13º do CPC). Ademais, os honorários advocatícios de 10% fixados pelo juiz ao despachar a petição inicial da ação de execução (art. 827, *caput*, do CPC) poderão ser elevados até vinte por cento, em caso de rejeição ou improcedência dos embargos à execução, podendo a majoração. Se o executado não opuser os embargos, tal majoração poderá ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, § 2º, do CPC).

15. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Embora o processo executivo não seja, a rigor, dialético, pois não admite apresentação de defesa pelo executado, a quem cabe discutir questões atinentes ao título somente por meio de ação de conhecimento (embargos à execução), doutrina e jurisprudência, sob forte influência de Pontes de Miranda, passaram a admitir uma defesa atípica nos próprios autos do processo de execução. Trata-se da exceção de pré-executividade (ou objeção de pré-executividade).

A exceção de pré-executividade será cabível no processo de execução de título executivo extrajudicial, inclusive execução fiscal¹²⁶, e no cumprimento de sentença.

Por meio da exceção de pré-executividade, o executado pode alegar, por exemplo, iliquidez, inexigibilidade e inexecutabilidade do título, ilegitimidade, prescrição etc. Não obstante, a jurisprudência vem afrouxando os requisitos para o manejo da exceção de pré-executividade, já chegando a admiti-la mesmo quando a questão não seja conhecível de ofício pelo juiz, mas desde haja prova pré-constituída (ex.: alegação de pagamento da dívida)¹²⁷.

Por ser criação doutrinária e jurisprudencial, a lei não disciplina o procedimento da exceção de pré-executividade. Contudo, é evidente que o juiz deve garantir ao exequente (*excepto*) o exercício do contraditório. Assim, apresentada a exceção, caberá ao juiz, inicialmente, analisar se os requisitos de admissibilidade estão presentes (matéria conhecível de ofício e desnecessidade de dilação probatória). Recebida a exceção, o *excepto* será intimado para manifestar no prazo designado pelo juiz. Após, o juiz decidirá.

A natureza do pronunciamento judicial que julga a exceção de pré-executividade varia conforme as consequências processuais geradas pelo julgamento. Se o acolhimento da exceção gerar a extinção do processo de execução, o julgamento será feito por sentença, contra a qual cabe recurso de apelação. Tratando-se de acolhimento parcial (sem extinção da execução) ou rejeição, o pronunciamento será uma decisão interlocutória, a qual desafiará o recurso de agravo de instrumento.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na exceção de pré-executividade, somente serão cabíveis honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial, da exceção¹²⁸. Em caso de rejeição, não haverá condenação ao pagamento dos honorários¹²⁹.

16. SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

16.1. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

Assim como ocorre no processo de conhecimento, há situações, fáticas ou jurídicas, que ensejam a suspensão da execução ou do cumprimento de sentença. Além das hipóteses previstas nos arts. 313 e 315 do CPC, a execução será suspensa:

- No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

¹²⁶ “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (súmula 393 do STJ).

¹²⁷ AgInt nos EDcl no REsp 1671306/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018.

¹²⁸ AgInt no AREsp 1164658/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020.

¹²⁹ REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.

- Quando o executado não possuir bens penhoráveis;
- Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
- Quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 do CPC;
- Quando houver negócio jurídico processual, inclusive durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação (arts. 190 e 922 do CPC). Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 921, parágrafo único, do CPC).

Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes (art. 923 do CPC).

16.1.1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Prescrição intercorrente é o nome dado à prescrição da pretensão que se perfaz no curso de um processo judicial. Como se sabe, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeito retroativo à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (súmula 150 do STF). O grande problema está em saber a partir de que momento o prazo prescricional interrompido começará a correr.

No curso do processo, é evidente que o credor não pode ser penalizado com a demora natural e inerente ao rito processual ou à estrutura, muitas vezes precária, do juízo. Nesse sentido, o novo CPC, acertadamente, tratou a questão nos parágrafos do art. 921.

Não localizando bens do devedor penhoráveis o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1º, do CPC). Esse prazo tem por objetivo permitir que o credor possa diligenciar, com mais tempo, à procura de bens do devedor. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2º, do CPC). Se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução (art. 921, § 3º, do CPC). Contudo, se decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, terá início o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC). O início da contagem do prazo da prescrição intercorrente é uma decorrência automática do decurso do prazo de suspensão da execução. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, o juiz intimará o exequente para se manifestar (art. 921, § 5º, do CPC) e, após, pronunciará a prescrição intercorrente e extinguirá a execução na forma do art. 924, V, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1604412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, fixou as seguintes teses:

- Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
- O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980);

- O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
- O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

16.2. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução encerra-se por sentença. Não se trata, a rigor, de sentença de mérito, na medida em que não há julgamento de uma demanda. Trata-se de simples sentença declaratória do encerramento da execução, conforme prevê o art. 925 do CPC (“A extinção só produz efeito quando declarada por sentença”).

Extingue-se a execução quando:

- **A petição inicial for indeferida;**
- **A obrigação for satisfeita;**
- **Quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;**
- **Quando o exequente renunciar ao crédito;**
- **Quando ocorrer a prescrição intercorrente.**

Por se tratar de sentença, será cabível o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).

QUESTÕES

1- Acerca da execução em geral, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato.
- b) Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.
- c) É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, desde que fundadas em títulos iguais e que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo.
- d) O contrato de locação, ainda quando não acompanhado da assinatura de duas testemunhas, é título executivo extrajudicial.
- e) A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2- No tocante à execução em geral, cumprimento de sentença e penhora, assinale a alternativa correta.



- a) Na execução de dívida relativa a taxas condominiais, a penhora deve recair necessariamente sobre o imóvel que deu ensejo à cobrança, haja vista a natureza *propter rem* das taxas condominiais.
- b) O STJ não admite que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa.
- c) a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, desde que nele o executado tenha domicílio.
- d) A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.
- e) Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro dependem de homologação para serem executados no Brasil.

3- São títulos executivos extrajudiciais, exceto.

- a) O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito.
- b) Contrato de locação de imóvel não assinado por duas testemunhas.
- c) Contrato de seguro de vida.
- d) Sentença arbitral.
- e) Certidão da Dívida Ativa dos municípios.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C

- a) CORRETA. Redação do art. 800 do NCPC. Vale lembrar que as obrigações alternativas, à luz do Direito Civil, são aquelas que possuem mais de um objeto, de modo que ao devedor caberá a escolha da prestação. Nos termos do art. 252 do CC, "nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou". É importante destacar, ainda, o que dispõe os §§ 1º e 2º do art. 800 do NCPC: "§ 1º Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. § 2º A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la".
- b) CORRETA. Redação do art. 514 do NCPC. É importante registrar que a decisão sobre uma relação jurídica sujeita a condição é plenamente possível. O que não se admite é sentença condicional, ou seja, aquela cujo reconhecimento da procedência ou improcedência de uma pretensão submeta a parte ao cumprimento de uma condição. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 492 do NCPC estabelece que "A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional".
- c) INCORRETA. É plenamente possível cumular, contra o mesmo devedor, várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, conforme permissão do art. 780 do NCPC.
- d) CORRETA. Diferentemente do que pode parecer em uma leitura apressada, o contrato de locação é considerado título executivo independentemente da assinatura de duas testemunhas. Isso porque, a exigência da assinatura de duas testemunhas para configurar o documento como título executivo encontra prevista no inciso III do art. 784 do NCPC ("o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas"). Ocorre que o contrato de locação encontra-se previsto, como título executivo extrajudicial, em inciso autônomo (inciso VIII do art. 784, do NCPC), no qual não há qualquer exigência de assinatura de duas testemunhas.

2. Gabarito: D



- a) INCORRETA. Não é por que a obrigação é *propter rem* que a penhora deve recair, necessariamente, sobre o bem. Até porque, vige em nosso ordenamento o princípio da menor onerosidade ao devedor. Conforme entendimento do STJ, na execução de dívida relativa a taxas condominiais, ainda que se trate de obrigação *propter rem*, a penhora não deve necessariamente recair sobre o imóvel que deu ensejo à cobrança, na hipótese em que se afigura viável a penhora *on line* (REsp 1.275.320-PR).
- b) INCORRETA. Para o STJ, é plenamente possível que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Não há violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 805 do NCPC (AgRg no AREsp 242.970-PR).
- c) INCORRETA. Segundo o inciso V do art. 781 do NCPC “a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”.
- d) CORRETA. Trata-se da redação da súmula nº 449, do STJ.
- e) INCORRETA. Não dependem de homologação (art. 784, § 2º, do NCPC).

3. Gabarito: D

- a) INCORRETA. Segundo a súmula 300 do STJ, “O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.
- b) INCORRETA. Conforme já visto, o contrato de locação, ainda que não assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial (REsp 578.355/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 25/10/2004, p. 378)
- c) INCORRETA. O contrato de seguro de vida é título executivo extrajudicial, a teor do art. 784, inciso VI, do NCPC.
- d) CORRETA. A sentença arbitral não é título executivo extrajudicial, mas sim JUDICIAL (art. 515, inciso VII, do NCPC). Lembre-se: a questão pede a exceção, ou seja, aquele que não é título executivo extrajudicial.
- e) INCORRETA. A Certidão da Dívida Ativa é título executivo extrajudicial (art. 784, inciso IX, do NCPC).



CAPÍTULO 15 — PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA E VOLUNTÁRIA

1. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA

1. 1. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

A consignação em pagamento é um instituto de direito civil que diz respeito ao adimplemento e extinção das obrigações, sendo que o procedimento especial correspondente disciplina o meio pelo qual se realiza o **depósito do valor ou da coisa devida**, a fim de que, se julgado procedente o pedido, seja **considerado o pagamento e extinta a obrigação por meio de decisão judicial**.

A consignação é **cabível**, na forma do art. 335 do CC, nas **hipóteses de mora** (se o credor não puder receber ou, em justa causa, recusar o recebimento do pagamento ou recusar dar a quitação na forma devida; se o credor não for e nem mandar receber a coisa no julgar, tempo e condição devido; ou se o credor for incapaz de receber, se for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil) e nas **hipóteses de dúvida** (se ocorrer dúvida sobre quem deva receber o pagamento; e se se pender litígio sobre o objeto do pagamento).

O **efeito** do ajuizamento da consignatória é evitar o devedor, desde a data do depósito, dos juros e dos riscos, salvo se a demanda for ao final julgada improcedente (art. 540, CPC).

É admissível a **cumulação** da consignação com pretensão de natureza distinta (como, por ex., com revisional de contrato), desde que observada a especialidade do rito e a provável necessidade de tramitação pelo procedimento comum (art. 327, §2º, CPC)¹³⁰⁻¹³¹.

A consignação pode ser realizada **extrajudicialmente** (ou de modo pré-processual). Nesse caso, o procedimento se realizará da seguinte forma (art. 539, §§1º e 2º, CPC): (i) o **devedor depositará** o dinheiro em estabelecimento bancário oficial no local do pagamento; (ii) o **credor será notificado** por carta com AR, concedendo-lhe prazo de 10 dias contados do retorno do AR para manifestar recusa; (iii) **não manifestada a recusa**, considera-se o dever liberado da obrigação e o dinheiro fica à disposição do credor (a resolução nº 2814/CMN disciplina mais detalhadamente a questão, especialmente no tocante às tarifas, despesas, prazos, formas de notificação, etc.).

Se, todavia, o **credor se recusar**, deverá ser ajuizada, no **prazo de 1 mês**, a ação de consignação em pagamento, que deverá ser instruída com a prova do depósito e da recusa (art. 539, §3º, CPC). Esse prazo é de natureza **decadencial** e implica na impossibilidade de uso da via especial (procedimento diferenciado) mediante o emprego daquele mesmo depósito já realizado, sem prejuízo de consignar mediante um novo depósito, bem como a discussão da matéria na respectiva ação de conhecimento ou de execução, conforme o caso.

Além da hipótese de recusa, a consignação judicial, dispensando-se a fase pré-processual, poderá ocorrer também quando não for possível a consignação extrajudicial (por ex., se não houver estabelecimento oficial no local do pagamento), quando se tratar de consignação de coisa ou por opção do autor.

Na **petição inicial**, o autor requererá o **depósito** da quantia ou da coisa em **5 dias**, sob pena, não depositando, acarretar a extinção sem resolução de mérito (art. 542, I e parágrafo único, CPC), ressalvada a eventual existência de depósito na forma do art. 539, §3º, CPC, bem como requererá a **citação** do Réu, para levantar o depósito ou contestar (art. 542, II, CPC).

¹³⁰GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 881/882.

¹³¹Nesse sentido: REsp 464.439/GO, 3ª Turma, DJ 23/06/2003, rel. Ministra Nancy Andrighi.



Se o objeto da prestação for **coisa indeterminada** (por ex., 10 sacas de soja, 20 sacas de feijão, sem prévia especificação da qualidade) e a escolha couber ao **credor**, este será citado para o exercício deste direito em **5 dias** (ou no prazo que constar da lei ou do contrato, se existente) ou para aceitar que o devedor faça a escolha. Nesse caso, deve o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito (art. 543, CPC).

A ação deverá ser ajuizada no lugar do pagamento (art. 540, CPC), ressalvada a possibilidade de se tratar de coisa imóvel ou corpo que deva ser entregue no local em que está, caso em que a competência será do local da coisa¹³².

Na hipótese de **prestações sucessivas**, consignada a primeira, poderá o devedor continuar depositando as demais, no mesmo processo e sem formalidades, desde que em até **5 dias** da data do respectivo vencimento (art. 541, CPC). Se as prestações se prolongarem no tempo, é admissível a **consignação sucessiva enquanto o processo estiver pendente**¹³³, ou seja, **até o trânsito em julgado**¹³⁴.

Na **contestação**, poderá o réu, na forma do art. 544, I a IV e parágrafo único, CPC, alegar que: (i) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; (ii) a recusa foi justa; (iii) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; (iv) o depósito não é integral, caso em que a alegação está subordinada à indicação do montante que reputa devido.

Conquanto se entenda, majoritariamente, que o rol de matérias suscetíveis de arguição na contestação seja **taxativo quanto ao mérito**, nada obsta que o réu suscite **objeções de natureza processual** (ilegitimidade de parte, ausência de interesse processual, inépcia da petição inicial, etc.)¹³⁵.

Se, na defesa, alegar-se **insuficiência do depósito** (art. 545, *caput*, CPC), será facultado ao autor completá-lo em **10 dias**, salvo nas hipóteses em que a complementação for impossível por já ter havido, no curso do processo, a rescisão contratual (por ex., se a obrigação envolvia a entrega de móveis para um evento já ocorrido).

De todo modo, poderá o Réu levantar desde logo o valor ou a coisa depositada (**parcela incontroversa**), prosseguindo o feito sobre a parcela controvertida (art. 545, §1º, CPC). Se houver complexidade da matéria acerca da completude, ou não, do depósito realizado, **poderá haver dilação probatória** neste rito especial, inclusive com a produção de prova pericial¹³⁶.

A sentença que concluir pela insuficiência, determinará o montante devido (se possível) e servirá como título executivo, facultando-se ao credor promover o cumprimento nos próprios autos ou liquidá-la, se necessário, também nos próprios autos (art. 545, §2º). Anote-se, contudo, que, em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos (tema 967), concluiu-se que “*em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de*

¹³²Enunciado 59 do FPPC: “(art. 540). Em ação de consignação e pagamento, quando a coisa devida for corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a consignação no foro em que ela se encontra. A supressão do parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil de 1973 é inócua, tendo em vista o art. 341 do Código Civil. (Grupo: Procedimentos Especiais; redação revista no III FPPC-Rio)”.

¹³³Enunciado 60 do FPPC: “(art. 541) Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo. (Grupo: Procedimentos Especiais)”.

¹³⁴Nesse sentido: REsp 439.489/SP, 2ª Seção, DJ 19/04/2004, rel. Ministra Nancy Andrighi.

¹³⁵ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 995.

¹³⁶Nesse sentido: REsp 15.391/RJ, 4ª Turma, DJ 28/09/1992, rel. Ministro Athos Gusmão Carneiro.

improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional¹³⁷.

A sentença de **procedência** declarará a extinção da obrigação e condenará o réu ao pagamento das custas e honorários (art. 546, *caput*, CPC); a de **improcedência**, declarará a manutenção do vínculo obrigacional e condenará o autor ao pagamento das custas e honorários, além da mora pelo período de inadimplência.

Na hipótese de haver **dúvida subjetiva**, isto é, dúvida sobre **quem deve receber** legitimamente o crédito (por ex., na hipótese de cessão de crédito com posterior judicialização), deverá o autor requerer a citação de **todos os possíveis titulares do crédito** para que provem o seu direito (art. 547, CPC).

Nesse caso, na forma do art. 548, I a III, CPC: **se ninguém comparecer**, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas (art. 746, CPC); **se um comparecer**, o juiz decidirá de plano; ou, **se mais de um comparecer**, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo **apenas em relação aos presuntivos credores**, pelo procedimento comum, salvo se houver controvérsia acerca da suficiência do depósito, hipótese em que prosseguirá também em relação ao autor¹³⁸.

1.2. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Por meio da prestação de contas se pretende o acerto dos números de uma determinada relação jurídica em que o devedor de contas geriu o patrimônio de um credor de contas. Tem por finalidade a **apuração dos valores decorrentes de uma relação**, decorrente de lei ou de contrato, que **envolva a administração de recursos** (por ex., tutela, curatela, administração judicial da falência, inventário, mandato, etc.).

A ação de exigir contas possui, como **legitimado ativo**, aquele que pretende exigir as contas, não sendo mais possível o ajuizamento da ação **por quem tenha o dever de prestar as contas**, que somente poderá figurar no **polo passivo**. De todo modo, quem pretender **dar contas**, conquanto não possua mais a ação de procedimento especial prevista no CPC/73, poderá, ainda, valer-se de ação de dar contas pelo procedimento comum¹³⁹.

Já se decidiu no STJ, por exemplo, que a prestação de contas por quem exerce a administração por **mandato eletivo** (síndico de condomínio, diretor de associação, etc.) ocorre na **assembleia geral**, de modo que a ação judicial somente será cabível se não forem elas prestadas ou se forem prestadas inadequadamente¹⁴⁰.

Ademais, também já se decidiu que é **incabível a ação de prestação de contas em decorrência da prestação de alimentos**, pois a fiscalização de gastos nessa relação não é meramente aritmética, não há proveito ao autor diante da irrepetibilidade dos alimentos, a obrigação é fixada judicialmente e naquele processo poderá ser revista, sendo que a eventual má aplicação do valor se reverterá ao menor (e não ao autor)¹⁴¹.

¹³⁷ Nesse sentido: REsp 1.108.058/DF, 2ª Seção, DJ 23/10/2008, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

¹³⁸ Enunciado 62 do FPPC: "(art. 548, III) A regra prevista no art. 548, III, que dispõe que, em ação de consignação em pagamento, o juiz declarará efetuado o depósito extinguindo a obrigação em relação ao devedor, prosseguindo o processo unicamente entre os presuntivos credores, só se aplicará se o valor do depósito não for controvertido, ou seja, não terá aplicação caso o montante depositado seja impugnado por qualquer dos presuntivos credores. (Grupo: Procedimentos Especiais)".

¹³⁹ GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 901/902.

¹⁴⁰ Nesse sentido: REsp 1.046.652/RJ, 3ª Turma, DJe 30/09/2014, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

¹⁴¹ Nesse sentido: REsp 985.061/DF, 3ª Turma, DJe 16/06/2008, rel. Ministra Nancy Andrighi.



De igual modo, também se decidiu no STJ, por ocasião do julgamento do tema repetitivo 528, que “**nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas**”¹⁴², diante da ausência de típica movimentação de créditos e débitos.

A **competência** para a ação de exigir contas é do lugar em que ocorre a administração do patrimônio (art. 53, IV, “b”, CPC).

No que se refere à petição inicial, além de observar os requisitos do art. 319, CPC, deverá o autor **especificar detalhadamente as razões pelas quais exige** as contas, os **períodos** e as **especificações** (art. 550, §1º, CPC), ou seja, a causa de pedir e o pedido devem ser precisos, com datas, movimentações, etc., não se admitindo pretensão genérica e vazia, que é reputada inepta pelo STJ¹⁴³.

A ação de exigir contas poderá se desenvolver em um **procedimento bifásico**. Na **primeira fase**, deve-se decidir somente se há o dever de prestar contas e, apenas **se julgado procedente** este pedido, será iniciada a **segunda fase**, em que será examinada a exatidão das contas apresentadas, julgando-as.

Na **primeira fase**, o réu será citado para apresentar as contas ou contestar, sempre em **15 dias**. Serão três os possíveis desdobramentos: (i) **inércia do réu**, caso em que haverá a presunção relativa de reconhecimento tácito do dever de prestar, julgando-se esta fase antecipadamente, mas não necessariamente procedente; (ii) **apresentação das contas pelo réu**, que deverão ser prestadas de forma adequada, especificando-se receitas, despesas e investimentos (art. 551, *caput*, CPC) e, ato contínuo, passar-se-á à segunda fase, isto é, ao julgamento das contas, diante da incontrovérsia sobre o dever de prestar; (iii) **contestação e negativa do dever de prestar**, caso em que será aberta a fase instrutória, se necessário, para ulterior decisão judicial acerca da procedência, ou não, do pedido formulado na primeira fase.

A **decisão que põe fim à primeira fase** (art. 550, §5º, CPC), reconhecendo, ou não, o dever de prestar contas, pode ter diferentes naturezas e regimes recursais. Se **procedente o pedido**, será decisão com conteúdo de mérito (reconhece a existência de uma obrigação), pois não põe fim à fase cognitiva (apenas deflagrará a segunda fase da ação), sendo recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Se **julgado improcedente o pedido** ou se **extinto o processo sem resolução de mérito**, será sentença, pois põe fim à fase cognitiva (não haverá segunda fase da ação), de modo que será recorrível por apelação (art. 1.009, CPC). Diante da **dúvida objetiva** acerca do recurso cabível e da divergência doutrinária acerca da matéria, aplica-se a **fungibilidade recursal**¹⁴⁴.

A **segunda fase** da ação de exigir contas, quando cabível, iniciar-se-á de modos distintos, a depender da conduta do réu na fase antecedente: (i) **se o réu prestou as contas**, será dada vista ao autor para eventual impugnação (que deverá ser específica e fundamentada, art. 551, §1º, CPC), abrindo-se contraditório para o réu apresentar documentos que justifiquem as contas e, então, passar-se-á ao exame e julgamento das contas, acaso a demanda prescindir de novas provas; (ii) **se o réu foi inerte ou contestou**, será ele intimado para, em 15 dias, apresentá-las, sob pena de se considerar como corretas as contas que vierem a ser apresentadas, demonstradas e comprovadas pelo autor (com demonstrativo das receitas, despesas, investimentos e saldo, se houver), sem possibilidade de ulterior impugnação.

Se o **autor falecer**, os herdeiros ou sucessores poderão ajuizar ou prosseguir na ação de exigir contas já ajuizada. Todavia, se o **réu falecer**, não haverá, em regra, como se falar em sucessão processual, na medida em que os herdeiros e sucessores não são obrigados ou não terão capacidade ou responsabilidade pela prestação de contas do administrador falecido, impondo-se a extinção sem

¹⁴² Nesse sentido: REsp 1.293.558/PR, 2ª Seção, DJe 25/03/2015, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

¹⁴³ Nesse sentido: REsp 1.318.826/SP, 3ª Turma, DJe 26/02/2013, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

¹⁴⁴ Nesse sentido: REsp 1.746.337/RS, 3ª Turma, DJe 09/04/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi; REsp 1.680.168/SP, 4ª Turma, DJe 10/06/2019, rel. Ministro Raul Araújo.

resolução de mérito (art. 485, IX, CPC)¹⁴⁵, ressalvada a hipótese em que a atividade cognitiva e instrutória exercida na primeira fase tenha adentrado também às próprias contas que deverão ser prestadas, caso em que a ação poderá prosseguir¹⁴⁶.

Finalmente, anote-se que há um **regime jurídico distinto para a prestação de contas em hipóteses previstas em lei** (inventário, falência, tutela e curatela, art. 553, *caput*, CPC), que dispensa o ajuizamento da ação.

Nesses casos, as contas serão prestadas em um **incidente apensado ao processo principal em que se discute a questão de fundo** (inventário, falência, tutela, curatela), de ofício ou a requerimento do administrado ou de qualquer interessado, sendo que, nesses casos, **se o responsável legal for condenado a pagar saldo e não o fizer, poderá sofrer as seguintes sanções**: destituição do cargo, sequestro de bens sob sua guarda, glosar (suspender) o prêmio ou a gratificação a que teria direito e, ainda, determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo (art. 553, parágrafo único, CPC).

1.3. AÇÕES POSSESSÓRIAS

1.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE TODAS AS AÇÕES POSSESSÓRIAS

É possível que a **posse**, que é um dos atributos da propriedade, venha a sofrer alguma espécie de **moléstia** de um terceiro, como o **esbulho** (em que o possuidor legítimo perde **totalmente** a posse), a **turbação** (em que o possuidor tem comprometida **parcialmente** a posse) e a **ameaça** (em que há um temor fundado e iminente de que a **posse venha a sofrer** um esbulho ou turbacão).

Nas hipóteses de esbulho e turbacão, admite-se uma espécie de **autotutela** do possuidor, denominada **desforço imediato** (art. 1.210, §1º, CC). Se, todavia, não for o caso de desforço imediato (ou se for ele insuficiente para o restabelecimento do *status quo* ante), será necessário o ajuizamento de uma **ação possessória**, que poderá ser de **reintegração da posse** (na hipótese de esbulho), de **manutenção da posse** (na hipótese de turbacão) ou de **interdito proibitório** (na hipótese de ameaça).

Considerando que as circunstâncias justificadoras da tutela possessória podem se alterar muito rapidamente no curso do processo (por ex., a ação inicialmente era contra a ameaça, mas, concedida a liminar, tornou-se esbulho), há uma regra legal de **fungibilidade da tutela possessória** (art. 554, CPC).

Essa regra legal, além de se aplicar em razão da modificação da dinâmica fática, também se aplica mediante a mitigação das regras de adstrição, correlação e congruência, de modo que, se o autor pleiteia tutela com *nomen juris* de ameaça (interdito), mas a narrativa (causa de pedir) é de turbacão (manutenção), poderá o juiz realizar este ajuste para melhor amoldar a tutela jurisdicional ao caso concreto.

Entretanto, a **fungibilidade da tutela possessória não é absoluta**, na medida em que são **inadmissíveis a alteração da causa de pedir** (por ex., ação de possuidor direto em face de indireto – art. 1.197, CC – não pode ser julgada ao fundamento de que há composses – art. 1.199, CC) ou a **alteração, modificação ou acréscimo do pedido quanto à sua natureza** (por ex., o pedido é de reintegração de posse e, no curso da ação, considerando a existência de danos, condena-se o réu a

¹⁴⁵ Nesse sentido: REsp 1.055.819/SP, 3ª Turma, DJe 07/04/2010, rel. Ministro Massami Uyeda.

¹⁴⁶ Nesse sentido: REsp 1.480.810/ES, 3ª Turma, DJe 20/03/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

repará-los)¹⁴⁷, o que **não se confunde** com a conversão da tutela específica em perdas e danos na hipótese de ser impossível obtê-la (art. 499, CPC).

A **competência** para a ação possessória imobiliária é a do foro de situação da coisa. Não se trata de competência territorial e relativa, na medida em que as partes não podem escolher o local do imóvel. Trata-se, pois, de competência funcional e absoluta (art. 47, §2º, CPC).

Como se sabe, em se tratando de ação que verse sobre direito real imobiliário, a participação de ambos os cônjuges é, em regra, indispensável (art. 73, *caput* e §1º, CPC). Nas ações possessórias, a participação do cônjuge somente será necessária se houver composses ou ato praticado por ambos, aplicando-se o mesmo regramento à união estável (art. 73, §§2º e 3º, CPC).

Ainda no que se refere à legitimação processual, anote-se que o novo CPC tratou de melhor disciplinar os **litígios coletivos envolvendo a posse** e que, a despeito de tão comuns no cotidiano, somente tinham as balizas procedimentais traçadas pela jurisprudência.

Assim, nos **litígios coletivos**, a ciência da ação pelos litigantes (formação do **litisconsórcio passivo multitudinário**) observará, na forma do art. 554, §1º a 3º, CPC, que: (i) serão citados pessoalmente apenas aqueles que forem encontrados no local (basta uma única visita); (ii) todos os demais serão citados por edital; (iii) haverá a intimação do Ministério Público (art. 178, III, CPC); (iv) se houver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, haverá a intimação da Defensoria Pública; (v) deverá ser dada ampla publicidade acerca da existência do litígio (anúncios, jornais, rádios, cartazes) e, inclusive, registro de protesto para consignar a informação do litígio possessória na respectiva matrícula imobiliária¹⁴⁸.

É **admissível a cumulação** de outros pedidos com a proteção possessória, mas há limitações, especialmente em decorrência dos critérios estabelecidos para a cumulação (art. 327, §1º, CPC). Desse modo, é possível, cumulativamente ao pedido possessório, pleitear **perdas e danos** (danos emergentes, lucros cessantes, danos morais, etc.), **indenização dos frutos** (colhidos e percebidos), bem como a **imposição de medidas adequadas para evitar nova vulneração à posse** e a **efetividade da tutela provisória ou final** (art. 555, I, II e parágrafo único, CPC). Conquanto haja divergência doutrinária, deve-se admitir também a cumulação com pedido de **desfazimento de construção** ou de **plantação** realizadas mediante violação da posse, sob pena de a restituição ao *status quo ante* não ser integral¹⁴⁹.

De outro lado, anote-se que, na forma do art. 556, CPC, é admissível a **formulação de pedido contraposto possessório pelo réu em desfavor do autor**, no bojo da própria defesa (por ex., além de pedir a manutenção da posse questionada pelo autor, poderá o réu pleitear a reintegração da posse e, se o caso, indenizações, medidas protetivas, etc.).

Não é correto afirmar, entretanto, que essa possibilidade implicaria no reconhecimento de que as ações possessórias possuiriam natureza dúplice, na medida em que esse caráter derivaria, na verdade, da **desnecessidade** de o réu formular pedido contra o autor, já que, pela natureza da relação de direito material, a improcedência do pedido do autor levaria naturalmente o réu a obter a posse, o que **não ocorre na hipótese**¹⁵⁰.

¹⁴⁷GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 921/922.

¹⁴⁸Enunciado 63 do FPPC: "(art. 554) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, a ampla divulgação prevista no §3º do art. 554 contempla a inteligência do art. 301, com a possibilidade de determinação de registro de protesto para consignar a informação do litígio possessório na matrícula imobiliária respectiva. (Grupo: Procedimentos Especiais)".

¹⁴⁹ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.013.

¹⁵⁰NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.065/1.066.



Não se pode olvidar, ademais, que **há vedação legal para que as partes debatam a propriedade na pendência de ação possessória**. A regra do art. 557, caput, CPC, há muito existente no sistema processual, reconhece a existência de um **direito autônomo à posse**, dissociado do direito à propriedade, que é suscetível de tutela jurisdicional independente, de modo a impedir que os litigantes ajuízem entre si ações petitórias, de caráter dominial (como a reivindicatória e a de usucapião), na pendência de litígio possessório que tenha por objeto, especificamente, um bem cuja posse é disputada.

A propriedade, quando muito, poderá ser enfrentada **incidentalmente** como argumento tendente à posse (por ex., o autor da ação possessória, mostrando-se proprietário do bem imóvel, comprova também ter a posse dele). A **restrição se aplica tão somente às partes**, de modo que é admissível o ajuizamento de **ação petitória em face de terceiros**.

Em síntese, o objeto das ações possessórias não é outro senão, fundamentalmente, a própria posse, que pode, inclusive, ser **legitimamente exercida em face do proprietário** do bem imóvel que, por alguma circunstância legal ou contratual, não seja o legítimo possuidor.

Finalmente, na forma do art. 559, CPC, **se o réu provar** que o autor que fez jus à tutela possessória liminar não possui idoneidade financeira para, na hipótese de improcedência, responder pelos prejuízos causados pela privação da posse, **poderá ele requerer a prestação de caução**, sob pena de depósito da coisa litigiosa (ressalvada a impossibilidade da parte hipossuficiente). A mesma regra deverá ser aplicada na hipótese em que **o réu obtiver uma liminar possessória** por pedido contraposto¹⁵¹.

1.3.2. CONSIDERAÇÕES PROCEDIMENTAIS SOBRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS

Nas **ações de manutenção da posse** (que é cabível em caso de **turbação**) e de **reintegração de posse** (que é cabível na hipótese de **esbulho**), deverá a parte, na forma do art. 561, I a IV, CPC, comprovar, mediante a juntada de documentos, fotografias, vídeos, atas notariais ou prova oral (testemunhal ou depoimento) em audiência de justificação: (i) a **posse**; (ii) o **ato ilícito** (turbação ou esbulho); (iii) a **data da turbação ou esbulho**, aspecto da mais alta relevância para definir se se trata da chamada **ação possessória de força nova** (em que o ato ilícito ocorreu até ano e dia) ou de **ação possessória de força velha** (em que o ilícito ocorreu há mais de ano e dia) e, assim, **se será observado o procedimento especial** (com liminar possessória específica) ou o **procedimento comum** (com a possibilidade de tutela de urgência ou evidência, desde que preenchidos os requisitos processuais próprios da antecipação de tutela genérica); e, finalmente (iv) a **continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração**, pois, embora fungíveis entre si, é preciso delimitar, na petição inicial, este requisito visa identificar se a ação proposta é a mais adequada para o ato ilícito narrado.

A concessão da **liminar possessória inaudita altera parte** (art. 562, caput, CPC) é, sem dúvida, o maior benefício da tutela possessória pelo rito especial, pois, se comprovados os requisitos acima mencionados, a liminar será deferida sem a oitiva do réu, a quem restará debater a matéria, após citado e em contraditório diferido.

Se, todavia, os **requisitos não estiverem suficientemente demonstrados**, deverá ser designada **audiência de justificação prévia** com o propósito de produzir prova oral em relação às questões de fato úteis para a concessão da tutela possessória¹⁵², citando-se o réu para comparecimento.

¹⁵¹Enunciado 180 do FPPC: "(art. 559) A prestação de caução prevista no art. 559 poderá ser determinada pelo juiz, caso o réu obtenha a proteção possessória, nos termos no art. 556. (Grupo: Procedimentos Especiais)".

¹⁵²Nesse sentido: REsp 900.534/RS, 4ª Turma, DJe 14/12/2009, rel. Ministro João Otávio de Noronha.



Na referida audiência, diverge a doutrina sobre a possibilidade de o réu produzir provas¹⁵³ ou se a sua atuação estaria restrita à contradita e indagação das testemunhas arroladas pelo autor¹⁵⁴. Tencionando adotar a segunda tese, já se decidiu que a **ausência de citação do réu** não resultará, por si só, em nulidade da audiência de justificação prévia realizada sem a sua presença¹⁵⁵.

Anote-se, quanto ao ponto, que visando a preservação do interesse público e tendo em vista a presunção de legalidade das atividades administrativas, o art. 562, parágrafo único, CPC, **veda a concessão da tutela possessória em desfavor das pessoas jurídicas de direito público em caráter inaudita altera parte**, condicionando-a à audiência prévia dos representantes do ente público.

Independentemente da concessão da liminar possessória, caberá ao autor promover, em **05 dias**, os atos necessários para a citação do réu, cujo prazo para contestar, de **15 dias**, possuirá dois diferentes marcos: se a citação se der por mandado, edital, etc., o prazo será contado na forma do art. 231, CPC; se a citação se der na audiência de justificação prévia, o prazo será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, *caput* e parágrafo único, CPC).

Nas **ações possessórias de natureza coletiva** (art. 565, *caput*, CPC), em se tratando de **ação possessória de força velha** (ilícito ocorrido há mais de ano e dia), deverá o juiz, antes do exame da liminar, designar audiência de mediação ou conciliação, a realizar em 30 dias.

Da leitura do referido dispositivo, pode-se extrair, como **primeira conclusão**, que se se tratar de **ação possessória coletiva de força nova**, não haverá a necessidade de designação da referida audiência, podendo ser deferida a liminar possessória *inaudita altera parte*; a **segunda conclusão** é de que o referido dispositivo é **absolutamente inócuo**, na medida em que a ação possessória de força velha tramitará pelo procedimento comum e, nele, a audiência de tentativa de conciliação e mediação é mandatória por força do art. 334, CPC.

Também se afirma ser necessária a **realização de audiência de mediação ou conciliação na hipótese de, se concedida a liminar, não for ela executada em 01 ano** (art. 565, §1º, CPC), para a qual deverão ser intimados o Ministério Público e a Defensoria Pública (para preservação dos direitos dos economicamente hipossuficientes (art. 565, §2º, CPC), facultando-se, ainda, a intimação dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Município onde se situe a área que é objeto do conflito, a fim de que se manifestem sobre eventual interesse na causa e sobre possíveis formas de solução do litígio (art. 565, §4º, CPC), estendendo-se o mesmo microsistema aos conflitos que versem sobre propriedade de imóveis (art. 565, §5º, CPC).

Nas **ações de interdito proibitório** (cabíveis contra ameaça de turbação ou esbulho iminente, arts. 567 e 568, CPC), aplica-se, em linhas gerais, o **mesmo procedimento** utilizado para as ações de manutenção ou de reintegração de posse, ressaltando-se que a **tutela possessória a ser deferida liminarmente será de natureza inibitória ou preventiva** (ou seja, trata-se de tutela que atua no campo do **risco** de existir uma conduta ilícita), de modo que a **prova do justo receio** (a ameaça e o risco iminente de ato ilícito) é de **ainda mais difícil produção**, devendo os indícios apresentados servirem para embasar tanto a existência de **interesse processual** quanto a **concessão da tutela possessória**.

De igual modo, no interdito proibitório há a **fixação da multa como técnica de apoio** para a hipótese de descumprimento da liminar, que, contudo, deve ser interpretada como mera opção, cabendo ao magistrado adotar a medida mais adequada para essa finalidade, na forma dos arts. 139, IV, e 297, *caput*, CPC.

¹⁵³GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 946.

¹⁵⁴NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.500.

¹⁵⁵Nesse sentido: REsp 1.232.904/SP, 3ª Turma, DJe 23/05/2013, rel. Ministra Nancy Andrighi.



1.4. AÇÃO DE DIVISÃO E DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES

1.4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AMBAS AS AÇÕES

Inicialmente, anote-se que a ação de divisão e a ação de demarcação de terras particulares **possuem natureza dúplice**, pois será prestada tutela jurisdicional ao autor e também ao réu, dispensando-se pedido deste, que terão as suas terras divididas ou demarcadas.

Também é importante destacar que ambas as ações **não se sujeitam a prazo**, na medida em que o direito à divisão ou à demarcação, de natureza **potestativa**, se submeteria à **decadência**, não havendo, entretanto, prazo estipulado em lei para o exercício dos referidos direitos¹⁵⁶.

A ação **demarcatória cabe ao proprietário** que pretenda obter certeza acerca das linhas divisórias e limitadoras entre duas propriedades, seja para criá-las, seja para aviventá-las (art. 569, I, CPC; arts. 1.297 e 1.298, CC), ao passo que a **ação divisória cabe ao condômino** que pretenda o desfazimento do condomínio, seja por meio de divisão *in natura* da própria coisa, seja para a apuração do valor da coisa mediante transformação em quinhões, se se tratar de bem indivisível (art. 569, II, CPC; arts. 1320 a 1322, CC).

Admite-se a **cumulação dos pedidos divisório e demarcatório**, mas, como orienta o art. 570, CPC, trata-se de uma cumulação bastante singular, que se opera de modo **sucessivo** e que é **ajuizada em face de diferentes réus**, uma vez que se processará, em primeiro lugar, a ação de demarcação (determinando-se qual é exatamente a área) e, somente após, terá início a ação de divisão (partindo daquilo que for decidido na demarcação e desfazendo-se o condomínio internamente).

Ainda em caráter preliminar, sublinhe-se que, em se tratando de **imóvel georreferenciado**, isto é, com mapeamento de acordo com o **Sistema Geodésico Brasileiro** (que é obrigatório em imóveis rurais, conforme Lei 10.267/2001, sem o qual não se insere o imóvel no CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e, assim, não se faz nenhuma alteração cartorial da propriedade) e se o mapeamento **estiver averbado no registro do imóvel**, poderá ser dispensada a realização de prova pericial na ação divisória ou demarcatória (art. 573, CPC).

1.4.2. AÇÃO DEMARCATÓRIA

A **petição inicial** da ação demarcatória deverá ser instruída com o título de propriedade, indicar todos os confinantes da linha (que formarão um litisconsórcio necessário), designar o imóvel pela situação e pela denominação e, ainda, descrever os limites por constituir ou aviventar (art. 574, CPC).

Qualquer condômino possui **legitimidade** para promover a demarcação do imóvel comum. Trata-se de hipótese de **legitimação extraordinária**, em que qualquer deles pode agir em nome dos demais, que serão intimados para intervir (art. 575, CPC). É admissível a formação de litisconsórcio no polo ativo, que será facultativo e unitário.

Na forma do art. 576, CPC, a **citação dos réus** deverá, em regra, ser realizada pelo correio, ressalvada a hipótese do art. 247, CPC, que prevê as hipóteses em que a citação deverá ocorrer por oficial de justiça. Também é cabível a **citação por edital** (arts. 576, parágrafo único, e 259, III, CPC), na medida em que se trata de ação em que é necessária, por lei, a provocação de interessados incertos ou desconhecidos para participação do processo.

¹⁵⁶ ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.029.



O prazo para resposta dos réus será **comum de 15 dias** (art. 577, CPC), havendo divergência doutrinária acerca da incidência, ou não, da regra do art. 229, CPC (dobra de prazo para litisconsortes com diferentes procuradores em processo físico), entendendo-se, majoritariamente, pela possibilidade de dobra¹⁵⁷.

Antes de proferir a sentença, o juiz **nomeará um ou mais peritos** para traçar a linha demarcada (art. 579, CPC). A realização da prova técnica é **obrigatória**¹⁵⁸, ressalvada a hipótese de imóvel georreferenciado (art. 573, CPC), em que é dispensável.

A **sentença** que determinar o traçado terá natureza **declaratória** (se apenas afastar as dúvidas acerca dos limites) ou **constitutiva** (se fixar limites onde antes não havia); será de **procedência** se acolher a pretensão de demarcação nos limites estabelecidos pelo autor na petição inicial ou de **improcedência** se consignar como corretos os limites tracejados pelo réu na contestação. Também, se o caso, determinará a restituição de área invadida e declarará o domínio e/ou a posse do prejudicado (art. 581, CPC). Da sentença, que **encerrará essa fase da ação demarcatória**, caberá apelação **com efeito suspensivo**.

Após o trânsito em julgado da fase acima mencionada, terá início a fase de **cumprimento de sentença** (ou a **segunda fase da demarcatória**) (art. 582, CPC), ocasião em que caberá ao perito dar efetivo cumprimento ao comando judicial, efetuando a demarcação e colocando os marcos necessários (art. 584, CPC), consignando tudo em planta e em memorial descritivo cujos requisitos estão no art. 583, CPC, com as referências para a identificação dos pontos assinalados.

Há a necessidade de emissão de um relatório pelos peritos (art. 585, CPC), denominado **auto de demarcação**, sobre o qual as partes poderão se manifestar no prazo comum de 15 dias (art. 586, CPC), antes da homologação do relatório do perito pelo juiz (art. 587, CPC). Essa fase, que se assemelha ao cumprimento de sentença ou à execução do julgado (tanto que ocorre somente após o trânsito em julgado), encerra-se por sentença impugnável por apelação **sem efeito suspensivo** (art. 1.012, §1º, I, CPC).

1.4.3. AÇÃO DIVISÓRIA

A **petição inicial** da ação divisória deverá ser instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel; a qualificação completa dos condôminos, indicando-se aqueles estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas; e, finalmente, quais são as benfeitorias comuns (art. 588, I a III, CPC).

No que se refere à **citação e resposta** dos réus, o procedimento será **idêntico à ação demarcatória** (citação dos réus em regra pelo correio, ressalvada a hipótese do art. 247, CPC, em que a citação deverá ocorrer por oficial de justiça; admissibilidade da citação por edital; prazo para resposta **comum de 15 dias**, com possibilidade de dobra na hipótese do art. 229, CPC).

De igual modo, a produção de prova pericial na ação divisória é **obrigatória** (art. 590, *caput*, CPC), ressalvada a hipótese de imóvel georreferenciado. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, devendo ser **rigorosamente respeitados** os requisitos do art. 590, parágrafo único, CPC, na medida em que a existência ou não de vias de comunicação, construções, benfeitorias, águas e outros impactará na formação e no valor dos quinhões em futura partilha.

¹⁵⁷ ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.036; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 973.

¹⁵⁸ Nesse sentido: REsp 790.206/ES, 4ª Turma, DJe 12/04/2010, rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro.

Embora a **apresentação de títulos** ocorra, na perspectiva dos réus, com a defesa, o art. 591, CPC, faculta a eles a **oportunidade de apresentá-los logo após o laudo pericial**. Também nesse momento, ambas as partes poderão formular **pedidos sobre a constituição dos quinhões**, levando em consideração aspectos como maior comodidade, existência de benfeitorias particulares ou servidões, por exemplo.

Cumprida a regra do art. 591, CPC, será aberto o **contraditório (15 dias** para manifestações, art. 592, *caput*, CPC). Se **não houver impugnação**, determinar-se-á a **divisão geodésica** do imóvel (que é uma espécie de **divisão provisória**, a ser confirmada por perícia e sentença homologatória) (art. 592, §1º, CPC).

Se, todavia, houver impugnação, o juiz decidirá sobre os pedidos e os títulos que deverão ser atendidos na formação dos quinhões (art. 592, §2º, CPC). Considerando que a decisão que delibera sobre a impugnação **põe fim à primeira fase da ação divisória**, trata-se de decisão interlocutória que versa sobre mérito e que é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, CPC¹⁵⁹.

Realizada a divisão geodésica do imóvel, terá início a **segunda fase da ação de divisão**, ocasião em que os peritos proporão a **forma definitiva de divisão**, consultando as partes sobre a forma que lhe for mais cômoda, respeitando, nas adjudicações, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e as suas benfeitorias e evitando o retalhamento dos quinhões em glebas separadas (art. 595, CPC).

Apresentado o laudo pericial sobre o cálculo e o plano de divisão e ouvidas as partes no prazo comum de **15 dias**, deverá o juiz deliberar sobre a partilha (art. 596, *caput*, CPC) por intermédio de **sentença homologatória** que poderá ser impugnada por apelação **sem efeito suspensivo** (art. 1.012, §1º, I, CPC).

Ato contínuo, terá **início a fase de cumprimento da sentença homologatória**, momento em que se ocorrerá a efetiva demarcação dos quinhões (observado os requisitos dos arts. 584 e 585, CPC) e, ainda, que: (i) benfeitorias comuns que não comportem divisão adequada serão adjudicadas a um mediante compensação; (ii) serão providenciadas as servidões necessárias, incluindo o valor no preço para que o condômino que a suportar seja compensado; (iii) as benfeitorias particulares dos condôminos que excederem à sua área serão adjudicadas pelo vizinho mediante reposição; (iv) as compensações e reposições serão feitas em dinheiro, salvo estipulação em sentido contrário; (v) serão desenhados em planta os quinhões e as servidões aparentes, organizando-se em seguida o memorial descritivo (arts. 596, parágrafo único, I a IV, e 597, CPC).

Finalmente, sublinhe-se que se, na divisão, uma linha de perímetro **atingir benfeitoria permanente de confinante feita há mais de 01 ano**, ela deverá ser respeitada, bem como os terrenos onde estiverem, que **não serão levadas em consideração** na área a ser dividida (art. 593, CPC), bem como que, se houver usurpação de terreno pelo imóvel dividendo, os confinantes poderão demandar a restituição dos terrenos invadidos (art. 594, CPC).

1.5. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE

Por intermédio da ação de dissolução parcial de sociedade, pretende-se a **resolução** da sociedade em relação a sócio falecido, excluído ou que exerceu direito de retirada ou recesso e/ou a **apuração de haveres** de sócio nas mesmas circunstâncias acima mencionadas (art. 599, I a III, CPC).

¹⁵⁹ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.036; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 973.

Significa dizer que a pretensão deduzida na ação poderá ser de resolução, de apuração de haveres ou ambas cumulativamente.

Conquanto a referida ação tenha por objeto, essencialmente, a **sociedade simples** e a **sociedade empresária**, admite-se também o ajuizamento da ação para dissolver parcialmente a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista(s) que representem 5% ou mais do capital social, que não pode ela preencher seu fim (art. 599, §2º, CPC).

A **petição inicial** deverá obrigatoriamente ser instruída com o **contrato social consolidado** da sociedade (art. 599, §1º, CPC), ressalvada a possibilidade de, não havendo, ser instruída com o contrato originário e as subsequentes alterações¹⁶⁰.

O rol de **legitimados ativos** para propor a ação está previsto no art. 600, I a V, CPC, a saber: (i) o espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, sendo admissível o ajuizamento por coerdeiro, antes da partilha, apenas na hipótese de proteção dos interesses do espólio¹⁶¹; (ii) pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido; (iii) pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, na hipótese em que esse direito decorrer do contrato; (iv) pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais, a alteração consensual do contrato social após 10 dias do exercício do direito; (v) pela sociedade, nos casos em que a lei não autorizar a exclusão extrajudicial; ou (vi) pelo sócio excluído.

Finalmente, estabelece o art. 600, parágrafo único, CPC, que o cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por esse sócio. Entende-se que, nessa hipótese, o reconhecimento da união estável deverá ser precedente, inadmitindo-se o reconhecimento incidental no bojo dessa ação¹⁶².

A **legitimação passiva** para responder a ação está prevista no art. 601, *caput*, CPC: deverão compor o polo passivo (e, conseqüentemente, ser citados) os demais **sócios** e a **sociedade**, em litisconsórcio passivo necessário, sendo que a ausência de um deles acarretará nulidade absoluta¹⁶³ (ressalvada a dispensa da sociedade no polo passivo se todos os sócios participarem prevista no art. 601, parágrafo único, CPC), ocasião em que se poderá reconhecer a procedência do pedido, contestá-lo e/ou, em tese, reconvir¹⁶⁴, bem como formular pedido contraposto indenizatório a ser compensado com os haveres (art. 602, CPC).

Havendo **concordância com a dissolução**, o juiz a decretará e, logo após, terá início a fase de liquidação, não havendo condenação em honorários e rateio das custas segundo a participação das partes no capital (art. 603, *caput* e §1º, CPC). A decisão que põe fim à primeira fase é de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, CPC¹⁶⁵.

Todavia, se houver **contestação**, a ação passará a tramitar pelo procedimento comum até o acerto definitivo da relação jurídica de direito material, devendo o juiz, na forma do art. 604, I a III, CPC, fixar a data da resolução da sociedade, definir o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social e nomear perito especialista em avaliação de sociedades (art. 606, parágrafo único, CPC), cabendo a antecipação dos honorários a quem requereu a prova (não se

¹⁶⁰GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.004.

¹⁶¹Nesse sentido: REsp 1.645.672/SP, 3ª Turma, DJe 29/08/2017, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

¹⁶²NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.102.

¹⁶³Nesse sentido: AgRg no REsp 947.545/MG, 3ª Turma, DJe 22/02/2011, rel. Ministro Sidnei Beneti.

¹⁶⁴Nesse sentido: REsp 1.128.431/SP, 3ª Turma, DJe 25/10/2011, rel. Ministra Nancy Andrighi.

¹⁶⁵NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.105.

aplicando a regra de rateio do art. 603, §1º, CPC¹⁶⁶), bem como determinar que seja depositada em juízo a parcela incontroversa dos haveres (art. 604, §1º, CPC), que poderá desde logo ser levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

A **decisão que dissolver a sociedade fixará a data de sua resolução**, a saber: (i) no caso de falecimento do sócio, a do óbito; (ii) na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; (iii) no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; (iv) na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e (v) na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado (art. 605, I a V, CPC).

Também nesse momento, deverá o juiz, se omisso o contrato social, determinar que a eventual **apuração de haveres seja realizada mediante balanço de determinação**, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (art. 606, CPC).

Finalmente, anote-se que a data da resolução e o critério de apuração de haveres poderão ser revistos pelo juiz, mediante requerimento da parte, **a qualquer tempo antes do início da perícia** (art. 607, CPC). Após o início da produção da prova técnica, operar-se-á a **preclusão**.

1.6. INVENTÁRIO E PARTILHA

De início, anote-se ser possível a realização de inventário e partilha de bens por **escritura pública**, desde que todos os herdeiros sejam capazes, estejam de acordo e forem assistidos por advogado ou defensor público, caso em que a escritura servirá como documento apto a efetuar qualquer registro ou levantamento de valor (art. 610, §1º e §2º, CPC).

Entretanto, ausente as circunstâncias ensejadoras do inventário extrajudicial, proceder-se-á, necessariamente, ao **inventário judicial**, de que se tratará daqui em diante.

1.6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O INVENTÁRIO JUDICIAL

O inventário deverá ser instaurado dentro de **02 meses**, contados da abertura da sucessão (data da morte), devendo ser finalizado nos **12 meses seguintes**. Tais prazos são suscetíveis de prorrogação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 611, CPC.

Na ação de inventário, caberá ao juiz decidir todas as questões de direito relacionadas à sucessão de bens e direitos do falecido, desde que estejam elas documentalmente provadas. Todavia, se sobre a questão controvertida houver a **necessidade de extensa atividade instrutória** (por ex., produção de prova pericial ou oral) ou **incompatibilidade de procedimento** (por ex., necessidade de reconhecimento prévio de filiação ou união estável), estará configurada a chamada **questão de alta indagação**, casos em que o juiz remeterá o exame de tais questões às vias ordinárias (art. 612, CPC).

Quanto ao ponto, anote-se, inicialmente, que o fato de haver previsão de que o juiz remeterá as partes às vias ordinárias se verificar a existência de questão de alta indagação **não significa dizer que a parte esteja proibida de ajuizar ação autônoma** se constatar, desde logo, a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário¹⁶⁷.

De outro lado, também já se decidiu que a remessa às vias ordinárias **não afasta o juízo do inventário** de debate a respeito de tema relacionado com a herança, mas, sim, que a questão não

¹⁶⁶ Nesse sentido: REsp 1.821.048/GO, 3ª Turma, DJe 29/08/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

¹⁶⁷ Nesse sentido: REsp 1.480.810/ES, 3ª Turma, DJe 20/03/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.



poderá ser examinada na ação de inventário em razão de suas restrições cognitivas, de modo que não há óbice para que a ação de procedimento comum que se relacione com a herança tenha seu curso regular perante o juízo do inventário¹⁶⁸.

Ainda em caráter propedêutico, sublinhe-se que prevê o Código a figura do **administrador provisório**, a ser escolhido a partir do rol do art. 1.797 do CC, que atuará como representante ativo e passivo do espólio até que o inventariante preste compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, que deverá fazer em até **05 dias** após a sua intimação (arts. 613, 614 e 617, parágrafo único, CPC).

1.6.2. JURISDIÇÃO, COMPETÊNCIA, LEGITIMIDADE E CUMULAÇÃO

De início, sublinhe-se que há regra específica que prevê caber à **jurisdição** brasileira processar e julgar o **inventário de bens situados no Brasil**, ainda que o falecido seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do Brasil (art. 23, II, CPC).

Estabelecida a jurisdição, registre-se que a **competência territorial** está definida no art. 48, *caput*, CPC, que prevê que a ação de inventário deverá ser processada e julgada no **foro de domicílio do falecido**, ainda que o óbito tenha ocorrido no exterior. Se, contudo, **não houver domicílio certo** do falecido, será competente: (i) o foro de situação dos bens imóveis; (ii) havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; (iii) não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. (art. 48, parágrafo único, I a III, CPC).

No que se refere à **legitimidade**, sublinhe-se que o requerimento de inventário e partilha caberá a quem estiver na posse e na administração do espólio, devendo ser instruído com a certidão de óbito do falecido (art. 615, *caput* e parágrafo único, CPC).

São igualmente **legitimados, concorrente e disjuntivamente**, o cônjuge ou companheiro sobrevivente; o herdeiro; o legatário; o testamenteiro; o cessionário do herdeiro ou do legatário; o credor do herdeiro, do legatário ou do falecido; o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz; a Fazenda Pública, quando houver interesse; e, finalmente, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do falecido ou do cônjuge ou companheiro sobrevivente. (art. 616, CPC).

É admissível a **cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas**, quando houver: (i) identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; (ii) heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, caso em que prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens; (iii) dependência de uma das partilhas em relação à outra, caso em que, se a dependência for parcial diante da existência de outros bens, poderá haver a tramitação em separado (arts. 672, I a III e parágrafo único, e 673, CPC).

1.6.3. INVENTARIANTE E PRIMEIRAS DECLARAÇÕES

Requerido o inventário, caberá ao juiz **nomear o inventariante, observada a seguinte ordem sucessiva**: cônjuge ou companheiro sobrevivente, se convivia com o falecido no momento da morte; herdeiro que estiver na posse e administração do espólio, se as pessoas mencionadas no item anterior não forem mais vivas ou se estão impossibilitadas de assumir o encargo; qualquer herdeiro, se nenhum estiver na posse ou administração; herdeiro menor, por seu representante legal; testamenteiro, se a ele couber a administração do espólio ou se herança estiver distribuído em legados; cessionário do herdeiro ou do legatário; inventariante judicial, se houver; pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial (art. 617, CPC).

¹⁶⁸ Nesse sentido: REsp 1.558.007/MA, 3ª Turma, DJe 02/02/2016, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Após a prestação do compromisso, **cabará ao inventariante, independentemente de anuência dos interessados ou de autorização judicial**: representar ativa e passivamente o espólio, em juízo ou fora dele; administrar o espólio, velando os bens diligentemente; prestar as primeiras ou últimas declarações pessoalmente ou procurador com poderes especiais; exhibir em cartório, a qualquer tempo, os documentos do espólio para exame das partes; juntar ao processo a certidão do testamento; colacionar os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que determinado pelo juiz; requerer a declaração de insolvência (art. 618, CPC).

Além das atribuições acima mencionadas, **também incumbirá ao inventariante, desde que ouvidos os interessados e mediante autorização judicial**: alienar bens; transigir em juízo ou fora dele; quitar dívidas do espólio e fazer despesas necessárias para conservação ou melhorias de bens (art. 619, CPC).

Especificamente quanto ao **pagamento de condenações judiciais em 15 dias** (art. 523, *caput* e §1º, CPC), há precedente no sentido de que **não se aplica a multa** pelo inadimplemento ao espólio se houver ele requerido, no prazo, a autorização judicial para pagamento¹⁶⁹.

Em **até 20 dias contados do compromisso**, o inventariante deverá fazer as **primeiras declarações**, por meio de petição autônoma e que poderá ser firmada por procurador com poderes especiais, que deverão ser assinadas pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante e na qual constarão: dados pessoais relacionados ao falecido e ao evento ensejador do inventário; dados pessoais relacionados aos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro sobrevivente, o regime de bens do casamento ou da união estável; qualidade dos herdeiros e grau de parentesco com o falecido; relação completa e individualizada dos bens do espólio, inclusive aqueles colacionados, e dos bens alheios que nele forem encontrados (art. 620, CPC).

Somente poderá ser arguida, em **ação de sonegados**, a **sonegação promovida por algum herdeiro ou pelo inventariante** após o encerramento da descrição dos bens, com a declaração de não há outros a inventariar (art. 621, CPC). A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, para a caracterização da sonegação, é imprescindível a demonstração do **elemento anímico** (malícia, má-fé, desejo de ocultar o bem antecipadamente recebido)¹⁷⁰.

Há hipóteses em que se admite a **remoção do inventariante**, de ofício ou a requerimento. São elas: (i) se não prestar as primeiras ou as últimas declarações no prazo; (ii) se não der andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou praticar atos protelatórios; (iii) se, por sua culpa, bens se deteriorarem, forem dilapidados ou danificados; (iv) se não defender o espólio nas ações em que for citado, não cobrar dívidas ou não promover medidas para evitar perecimento de direitos; (v) se não prestar contas ou as prestar incorretamente; (vi) se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. (art. 622, CPC).

Presente alguma dessas hipóteses, será instaurado **incidente de remoção**, a ser processado em apartado, ocasião em que o inventariante será intimado para se defender e produzir provas em **15 dias**, findo o qual o juiz decidirá o incidente. Se acolhida a arguição, será o inventariante removido, nomeando-se outro, devendo entregar os bens do espólio ao substituto sob pena de busca e apreensão ou imissão na posse, sem prejuízo da multa de até 3% sobre o valor dos bens inventariados. (arts. 623, 624 e 625, CPC).

¹⁶⁹ Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.021.416/AM, 4ª Turma, DJe 10/12/2013, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

¹⁷⁰ Nesse sentido: REsp 1.267.264/RJ, 3ª Turma, DJe 25/05/2015, rel. Ministro João Otávio de Noronha; REsp 1.567.276/CE, 4ª Turma, DJe 01/07/2019, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

1.6.4. CITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Apresentadas as primeiras declarações, o juiz mandará **citar, por correio**, cônjuge, companheiro, herdeiros e legatários, **publicando-se ainda edital**. Mandará, ademais, **intimar** a Fazenda Pública, o Ministério Público (se houver herdeiro incapaz ou ausente) e o testamenteiro (se houver testamento), conforme determina o art. 626, CPC.

Feitas as citações, será dada **vista às partes**, pelo prazo comum de **15 dias**, para se manifestarem sobre as primeiras declarações, cabendo-lhes impugnar, conforme art. 627, CPC: (i) **erros, omissões e sonegação de bens**, tratando-se de impugnação que, se acolhida, acarretará a correção das primeiras declarações pelo inventariante; (ii) **reclamar contra a nomeação do inventariante**, impugnação que, se acolhida, acarretará a nomeação de outro inventariante, observada a preferência legal; (iii) **contestar a qualidade de quem foi incluído como herdeiro**, impugnação que poderá ser acolhida de plano e acarretará a exclusão do herdeiro ou, se depender de instrução probatória, deverá ser apurada em ação pelo procedimento comum, suspendendo-se a entrega do quinhão que caberia ao herdeiro até julgamento da ação.

No mesmo prazo mencionado no parágrafo anterior, o **herdeiro obrigado a colacionar bens** indicará aqueles que recebeu do falecido em vida ou, se não mais os possuir, indicará o seu respectivo valor (art. 639, *caput*, CPC). Se **negar o recebimento ou a obrigação de colacionar**, será aberto contraditório (**15 dias**) e o juiz decidirá o incidente diante das alegações e das provas produzidas (art. 641, *caput*, CPC). Se **rejeitada a objeção do herdeiro**, o juiz mandará que colacione, sob pena de sequestro para que sejam inventariados e partilhados ou abaterá do quinhão o referido valor, se os bens já não forem mais do herdeiro (art. 641, §1º).

Finalmente, se não for possível decidir a questão de plano por ser necessária a dilação probatória, deverá a matéria ser elucidada em ação pelo procedimento comum, suspendendo-se a entrega do quinhão que caberia ao referido herdeiro e impedindo-se o levantamento, sem caução, até julgamento da referida ação, conforme determina o art. 641, §2º, CPC.

Antes da partilha, quem se **julgar preterido poderá requerer a sua admissão no inventário** (art. 628, *caput*, CPC). Instalado o contraditório (prazo para manifestação de **15 dias**), o juiz decidirá a questão incidente de plano ou, se necessária a instrução probatória, deverá ser apurada em ação pelo procedimento comum, reservando-se com o inventariante o quinhão que caberia ao referido herdeiro até julgamento da ação (art. 628, §1º e §2º, CPC).

1.6.5. AVALIAÇÃO DE BENS E PAGAMENTO DAS DÍVIDAS

Findo o prazo para impugnação dos herdeiros (ou decidida a impugnação), o juiz nomeará, se necessário, **perícia para avaliação de bens do espólio**, se não houver avaliador judicial na comarca, na forma do art. 630, *caput*, CPC. Não será expedida carta precatória para avaliação de bens fora da comarca se forem de pequeno valor ou se forem conhecidos pelo perito (art. 632, CPC), assim como não se fará a avaliação se, capazes as partes, a Fazenda Pública concordar com o valor atribuído aos bens nas primeiras declarações (art. 633, CPC).

Se o caso de perícia, entregue o laudo de avaliação, deverão as partes se manifestar no prazo comum de **15 dias**. Havendo impugnação e versando ela sobre o valor atribuído pelo perito, o juiz decidirá de plano e, julgando-a procedente, determinará que se retifique a avaliação (art. 635, §1º e §2º, CPC).

Aceito o laudo pericial ou decididas as impugnações, lavrar-se-á **termo de últimas declarações**, cabendo ao inventariante, se o caso, emendar, aditar ou completar as primeiras (art. 636, CPC), abrindo-se **nova vista às partes**, pelo prazo de **15 dias** (art. 637, CPC), findo o qual serão **calculados os tributos** incidentes. Após os cálculos dos tributos, haverá **novo contraditório** (prazo

comum de **5 dias**) e, em seguida, falará nos autos a Fazenda Pública (art. 638, *caput*, CPC). Se porventura acolhida eventual impugnação, os autos serão remetidos ao contador para ajustes e, ao final, serão calculados os tributos (art. 638, §1º e §2º, CPC).

Também antes da partilha, os credores do falecido poderão requerer ao juízo do inventário o **pagamento das dívidas vencidas e exigíveis**, conforme art. 642, CPC. Já o credor de **dívida líquida e certa**, mas ainda **não vencida**, poderá requerer a **habilitação** no inventário e, havendo concordância, o juiz mandará que se reserve o valor para futuro pagamento (art. 644, *caput* e parágrafo único, CPC).

O credor deverá protocolar petição com a prova da dívida, que será distribuída ao juízo do inventário e autuada em apenso. Se **houver concordância das partes com a dívida**, o juiz determinará a reserva do valor ou, não havendo, de bens suficientes para o pagamento para alienação, podendo o credor requerer, ainda, a adjudicação dos bens reservados, que está sujeita a concordância de todas as partes (art. 642, §2º a 4º, CPC).

Todavia, **se não houver concordância das partes com a dívida**, a questão será remetida às vias ordinárias, ressalvado o dever do juiz de reservar, com o inventariante, bens suficientes quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação (art. 643, parágrafo único, CPC).

1.6.6. PARTILHA

Finalizado o inventário, separados os bens necessários para o pagamento dos credores habilitados e após o juiz mandar aliená-los, será facultado às partes que, no prazo de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, ato contínuo, proferirá **decisão de deliberação da partilha**. Trata-se de pronunciamento jurisdicional de mérito por meio do qual o juiz resolverá os pedidos formulados pelas partes (tentando-se, ao máximo, atender aos interesses de cada quinhoeiro) e que indicará os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro ou legatário (art. 647, *caput*, CPC).

Por ocasião da **decisão de deliberação da partilha**, deverá o juiz buscar e observar: (i) a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; (ii) a prevenção de litígios futuros; (iii) a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro (art. 648, NCPC). Se houver **bens insuscetíveis de divisão cômoda** (que não caibam na parte do cônjuge ou companheiro sobrevivente ou não caibam no quinhão de um só herdeiro), serão licitados entre os interessados, vendidos judicialmente (e partilhando-se o valor) ou adjudicados por todos, conforme art. 649, CPC. Se houver **interessado nascituro**, o quinhão que lhe cabe será reservado em poder do inventariante até o nascimento (art. 650, CPC) e, se porventura não nascer, será objeto de **sobrepartilha** entre os demais sucessores.

Embora este seja o momento em que os herdeiros efetivamente usar e fruir dos bens anteriormente pertencentes ao falecido, não se pode olvidar que é admissível, durante o curso da ação de inventário, a **concessão de tutela antecipatória que permita o imediato uso e fruição dos bens a quaisquer herdeiros** antes do encerramento da partilha (art. 647, parágrafo único, CPC), havendo entendimento no sentido de que a **antecipação também se aplica aos legatários**¹⁷¹⁻¹⁷².

¹⁷¹Enunciado 181 do FPPC: “(arts. 645, I, 647, parágrafo único, 651) A previsão do parágrafo único do art. 647 é aplicável aos legatários na hipótese do inciso I do art. 645, desde que reservado patrimônio que garanta o pagamento do espólio. (Grupo: Procedimentos Especiais)”.

¹⁷²Enunciado 182 do FPPC: “(arts. 647 e 651) Aplica-se aos legatários o disposto no parágrafo único do art. 647, quando ficar evidenciado que os pagamentos do espólio não irão reduzir os legados. (Grupo: Procedimentos Especiais)”.



Trata-se de hipótese típica de **tutela provisória da evidência** (pois independe de urgência)¹⁷³, condicionada apenas a inexistência de controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação e que **não exclui a possibilidade de ser concedida tutela provisória de urgência**, com base nos arts. 300 e seguintes, CPC, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, mas desde que presentes os respectivos pressupostos legais¹⁷⁴.

Proferida a decisão de deliberação da partilha, caberá ao **partidor**, usualmente um servidor da contadoria forense, **esboçar a partilha** observando a decisão judicial e os critérios de pagamento elencados no art. 651, CPC: (i) as dívidas exigíveis; (ii) a meaço do cônjuge; (iii) a meaço disponível; (iv) os quinhões hereditários, iniciando pelo herdeiro mais velho.

Após o esboço, será facultado às partes se manifestarem sobre o tema em **15 dias** e, resolvidas as eventuais impugnações, a partilha será formalizada nos autos (art. 652, CPC), gerando o denominado **auto de partilha**, que é o documento que servirá de base para a **futura sentença de partilha** e que deverá mencionar: (i) qualificação do falecido, inventariante, cônjuge ou companheiro sobrevivente, herdeiros, legatários e credores; (ii) ativo, passivo e líquido partível, com as devidas especificações; (iii) valor de cada quinhão; (iv) pagamentos a serem feitos a cada quinhoeiro, especificando-se a motivação do pagamento e a individualização e descrição dos bens (art. 653, I e II< CPC).

Somente após o pagamento do ITCMD (imposto sobre transmissão *causa mortis* e doação) ou garantia de pagamento do tributo será proferida a sentença de partilha (art. 654, *caput*, CPC; art. 192, CTN), ressalvada a hipótese em que a parte hipossuficiente não puder oferecer a referida garantia¹⁷⁵.

Transitada em julgado a partilha, o **herdeiro receberá os bens** e o **formal de partilha**, do qual constarão as seguintes peças: (i) termo de inventariante e título de herdeiros; (ii) avaliação dos bens que constituíram o quinhão; (iii) pagamento do quinhão; (iv) quitação dos impostos; (v) sentença (art. 655, *caput*, CPC), que poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão se esse **não exceder 05 salários mínimos**, caso em que se transcreverá na certidão a sentença de partilha transitada em julgado (art. 655, parágrafo único, CPC).

Sublinhe-se que, **mesmo após o trânsito em julgado**, a partilha poderá ser **emendada** nos próprios autos, desde que haja concordância entre as partes e que o vício se refira a um erro de fato na descrição de bens partilhados (art. 656, CPC).

Fora da hipótese de **saneamento** acima mencionada, **somente poderá haver sobrepartilha**, desde que existam bens: (i) sonegados; (ii) descobertos após a partilha; (iii) litigiosos, bem como aqueles de difícil ou morosa liquidação; (iv) situados em lugar remoto da sede do juízo do inventário. A **sobrepartilha observará o procedimento do inventário e da partilha** e que correrá no mesmo processo (que será desarquivado, se necessário) (arts. 669, I a IV, e 670, *caput* e parágrafo único, CPC).

A **partilha consensual por escritura pública**(art. 610, §1º, CPC) pode ser **anulada** por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, sujeitando-se à **ação anulatória** (art. 966, §4º, CPC). O prazo, que é **decadencial**, conta-se: (i) se coação, do dia em que cessou; (ii) se erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato; (iii) se incapaz, do dia em que se tornar capaz (art. 657, *caput* e parágrafo único, CPC).

¹⁷³GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.097/1.098; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.145.

¹⁷⁴Nesse sentido: REsp 1.738.656/RJ, 3ª Turma, DJe 05/12/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

¹⁷⁵Enunciado 71 do FPPC: "(art. 654; art. 300, §1º) Poderá ser dispensada a garantia mencionada no parágrafo único do art. 654, para efeito de julgamento da partilha, se a parte hipossuficiente não puder oferecê-la, aplicando-se por analogia o disposto no art. 300, § 1º. (Grupo: Procedimentos Especiais; redação revista no III FPPC-Rio)".

Por sua vez, a **partilha sentenciada com trânsito em julgado é rescindível** também por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, bem como se feita com inobservância de formalidades legais, se preteriu herdeiro ou se incluiu quem não era (art. 658, I a III, CPC).

1.6.7. ARROLAMENTO COMUM E SUMÁRIO

Além do inventário e partilha ordinário, completo e solene, também há uma espécie de procedimento mais simples, denominado **arrolamento**, que poderá ser **sumário** ou **comum**.

Na hipótese de **arrolamento sumário**, é **indispensável que haja consenso** e que **existam partes capazes**, devendo ser homologada pelo juiz (art. 659, *caput*, CPC), sendo que, na **petição inicial**, os herdeiros requererão a nomeação do inventariante que escolherem; declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio; e atribuirão valor aos bens do espólio (somente haverá a avaliação judicial se um credor impugnar a estimativa feita pelos herdeiros) (art. 660, I a III, e 661, CPC).

Do ponto de vista **procedimental**, sublinhe-se que caberá ao Fisco, na forma do art. 659, §2º, CPC, realizar os lançamentos administrativos dos tributos incidentes e apurar, administrativamente, eventuais divergências de valor estimado e real (ou seja, a **homologação e expedição do formal não depende do recolhimento prévio de ITCMD**¹⁷⁶). Ademais, a **existência de credores não impede a homologação**, desde que sejam reservados bens suficientes ao pagamento da dívida, conforme valores estimados pelas partes (art. 663).

Finalmente, anote-se que o **arrolamento comum** será cabível quando o valor dos bens do espólio for **igual ou inferior a 1.000 salários mínimos**, independentemente de **consensualidade** ou de **plena capacidade** (se houver incapaz, bastará a anuência de todos e do Ministério Público (arts. 664, *caput*, e 665, CPC).

Nesse caso, o **processamento se iniciará** quando o inventariante nomeado, independentemente de termo de compromisso, apresentar as suas declarações, a avaliação dos bens e o plano de partilha, sendo que somente será nomeado avaliador se as partes ou Ministério Público impugnar a estimativa (art. 664, *caput* e §1º, CPC). Apresentado o laudo, será designada **audiência** em que o **juiz deliberará sobre todas as impugnações** e mandará pagar as dívidas não impugnadas, lavrando-se termo por todos subscrito (juiz, inventariante, partes e advogados). Quitados os tributos, será julgada a partilha (art. 664, §2º a 5º, CPC).

1.7. EMBARGOS DE TERCEIRO

A ação de embargos de terceiro visa desfazer ou inibir uma **construção judicial indevida** por ter atingido bens ou direitos de quem não é parte no processo em que o ato foi realizado (art. 674, *caput*, CPC). A **construção judicial** é o ato pelo qual o bem ou direito é apreendido ou submetido por decisão a uma finalidade de que resulte limitação ou ônus (por ex., penhora, arresto, sequestro, , etc.) e a tutela a ser dada nesta ação abrange a **posse** e a **propriedade** sobre o bem (art. 674, §1º, CPC).

O **legitimado a ajuizar** a ação é o **proprietário** do bem constrito (inclusive o **fiduciário**), assim como também o **possuidor**, direto ou indireto, desde que não seja ele parte do processo em que determinada a medida constritiva, isto é, que **seja terceiro**. São exemplos de terceiros (art. 674, §2º, CPC): (i) **cônjuge ou companheiro**, na defesa da posse de bens próprios ou de sua meação¹⁷⁷⁻¹⁷⁸,

¹⁷⁶Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.497.714/DF, 1ª Turma, DJe 04/12/2019, rel. Ministro Gurgel de Faria.

¹⁷⁷Súmula 134/STJ: “Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação”.

¹⁷⁸Súmula 251/STJ: “A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fi scal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal”.

salvo se bem indivisível (art. 843, CPC), caso em que a meação recairá sobre o produto da arrematação; (ii) o **adquirente de bem** constrito por decisão que reconhece a ocorrência de fraude à execução; (iii) os **sócios de pessoa jurídica** que sofram constrição pessoal em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica; (iv) o **credor com garantia real** (hipoteca, penhor e anticrese), a fim de impedir a expropriação do bem ou direito sobre o qual recai a garantia; (v) o **confinante**, nas ações de demarcação ou de divisão, se houver avanço sobre seu imóvel; (vi) o **promitente comprador**, ainda que o contrato não tenha sido registrado¹⁷⁹.

Anote-se que há regra no sentido de que o juiz, se identificar a existência de terceiro titular de interesse em embargar, **deverá intimá-lo** pessoalmente para, querendo, embargar do ato judicial constitutivo (art. 675, parágrafo único, CPC).

O **legitimado passivo** será a parte a quem a constrição aproveita no processo de origem e, ainda, seu adversário, se foi ele quem indicou o bem para constrição (art. 677, §4º, CPC). Nesse caso, haverá a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, que poderá ser subjetivamente ampliado, se, por exemplo, um dos réus for casado ou viver em união estável e os embargos envolverem direitos reais imobiliários¹⁸⁰.

Os embargos de terceiro poderão ser ajuizados: (i) no processo de conhecimento, a qualquer momento **até o trânsito em julgado da decisão de mérito** que diga respeito ao tema; (ii) na fase de cumprimento de sentença ou na execução, a qualquer momento **até 5 dias após a adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação**, mas desde que sempre antes da assinatura da respectiva carta (art. 675, *caput*, CPC).

Sublinhe-se, quanto ao ponto, que se o **terceiro não tinha conhecimento do ato executivo**, o prazo para embargar será contado da turbacão ou do esbulho de sua posse, ainda que a arrematação já tenha ocorrido¹⁸¹; e, na hipótese de **intimação diante de possível reconhecimento de fraude à execução**, haverá prazo de 15 dias contados da decisão judicial que tenciona declarar a fraude (art. 792, §4º, CPC).

A **competência** para o processamento e julgamento dos embargos será do **juízo que ordenou a constrição** (art. 676, *caput*, CPC), tratando-se de hipótese de **conexão por acessoriedade** (art. 61, CPC). Se, porventura, a constrição se realizar por carta precatória ou de ordem, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se a carta já houver sido devolvida ou se o bem específico objeto de constrição houver sido indicado pelo juízo deprecante (art. 676, parágrafo único, CPC).

Além dos requisitos do art. 319, CPC, deverá o embargante, na **petição inicial**, fazer prova sumária da posse, domínio ou direito e da qualidade de terceiro, juntando documentos e indicando testemunhas (art. 677, *caput*, CPC), havendo precedente no sentido de que a não apresentação do rol de testemunhas com a petição inicial acarreta **preclusão**¹⁸².

Poderá, se necessário, ser **designada audiência para a colheita de prova da posse pelo terceiro** (art. 677, §1º, CPC). Conquanto denominada de preliminar, a referida audiência em tudo se assemelha à audiência de justificação prévia em ação possessória (art. 562, *caput*, CPC).

O réu dos embargos de terceiro será **intimado para responder na pessoa de seu advogado**, independentemente de existência de poderes para receber citação, salvo se não houver procurador constituído na ação principal, caso em que deverá haver citação pessoal (art. 677, §3º, CPC).

¹⁷⁹Súmula 84/STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

¹⁸⁰GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.151/1.152.

¹⁸¹Nesse sentido: REsp 974.249/SP, 4ª Turma, DJe 19/05/2008, rel. Ministro João Otávio de Noronha.

¹⁸²Nesse sentido: REsp 362.504/RS, 2ª Turma, DJe 23/05/2006, rel. Ministro João Otávio de Noronha.

Se entender que está suficientemente provada a indevida constrição, o juiz concederá, mediante requerimento da parte, **tutela provisória** para suspender a constrição, manter ou reintegrar a posse ao terceiro, inclusive *inaudita altera parte*, podendo, se necessário, exigir a **prestação de caução** (art. 678, *caput* e parágrafo único, CPC).

Regularmente citado ou intimado, o réu poderá **responder em 15 dias** (art. 679, CPC) e, a partir daí, seguir-se-á o procedimento comum.

A matéria dedutível em **contestação** é **ilimitada**, salvo na hipótese dos embargos do credor com garantia real (hipoteca, penhor e anticrese), em que se aplicarão as restrições constantes no art. 680, I a III, CPC, somente se podendo alegar que o devedor comum é insolvente, que o título é nulo ou não obriga terceiro e que outra é a coisa dada em garantia. Quanto ao ponto, já se decidiu que

o credor com garantia real tem o direito de impedir, por meio de embargos de terceiro, a alienação judicial do objeto da hipoteca; entretanto, para o acolhimento dos embargos, é necessária a demonstração pelo credor da existência de outros bens sobre os quais poderá recair a penhora¹⁸³.

Na vigência do CPC/73, não se admitia a reconvenção em embargos de terceiro por incompatibilidade procedimental, tendo em vista que, após a defesa, o rito seguido era o de ação cautelar. Entende-se na doutrina que, seguindo-se o procedimento comum após a resposta, **não mais há impedimento para que haja reconvenção**¹⁸⁴.

Proferida sentença julgando **procedente** o pedido, a constrição será cancelada e o bem, se necessário, será entregue ao autor (art. 681, CPC). Se **improcedente** o pedido, mantém-se a constrição e revoga-se, se o caso, eventual tutela provisória concedida. Em ambos os casos, será cabível o recurso de apelação, recebido com efeito suspensivo.

Por ocasião do julgamento dos embargos, haverá a **condenação em honorários**, que, nos termos da Súmula 303/STJ¹⁸⁵ e da tese repetitiva 872 do STJ¹⁸⁶, deverá ser fixada em observância ao **princípio da causalidade**.

Finalmente, anote-se que poderá o terceiro prejudicado interpor recurso em vez de embargos de terceiro. Como já se decidiu,

em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado, exegese conforme a instrumentalidade do processo e o escopo de economia processual¹⁸⁷.

1.8. OPOSIÇÃO

Prevista como **intervenção de terceiro** no CPC/73, a **oposição passa a ser uma ação autônoma de procedimento especial** no novo CPC. A mudança não é meramente topológica, mas,

¹⁸³ Nesse sentido: REsp 578.960/SC, 3ª Turma, DJ 08/11/2004, rel. Ministra Nancy Andrihgi.

¹⁸⁴ GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.155; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.177.

¹⁸⁵ Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

¹⁸⁶ Tese repetitiva 872: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

¹⁸⁷ Nesse sentido: REsp 329.513/SP, 3ª Turma, DJ 11/03/2002, rel. Ministra Nancy Andrihgi.

ao revés, **conceitual**, diante de todas as repercussões advindas da mudança (petição inicial, ônus de impugnação específica, coisa julgada, etc.)

A ação de oposição deverá ser proposta por quem **pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre o qual controvertem o autor e o réu** de uma ação originária, que serão, ambos, réus na oposição (art. 682, CPC). Trata-se de uma ação em que se busca **excluir o bem dos litigantes originários**.

Embora seja muito comum nas ações reivindicatórias de propriedade, a oposição é cabível em **quaisquer ações que envolvam discussão sobre a titularidade** de algum bem, direito ou coisa. É cabível, inclusive, oposição em ação possessória, mas desde que o fundamento igualmente seja a posse¹⁸⁸.

A ação de oposição deve ser ajuizada em face de autor e réu da ação originária (art. 682, CPC), observando-se os requisitos comuns da petição inicial (arts. 319 e 683, CPC). Forma-se entre os réus da oposição um **litisconsórcio passivo necessário simples** (é necessário porque o CPC indica ser imprescindível a presença de ambos; é simples porque se admite solução jurídica distinta entre os litisconsortes).

Além de ser **dirigida simultaneamente às partes** da ação originária e de **haver coincidência total ou parcial de objeto**, a admissibilidade da oposição está condicionada a ser o **juiz competente** para conhecer e julgar também a oposição e ao **ajuizamento da oposição antes da prolação da sentença ou da decisão parcial de mérito** que tenha se pronunciado sobre a titularidade do bem, coisa ou direito sobre o qual controvertem as partes.

Distribuída a ação por dependência da ação originária, os réus, denominados **opostos**, serão citados, na pessoa de seus advogados, para contestar no **prazo comum de 15 dias** (art. 683, parágrafo único, CPC). Diverge a doutrina se a citação da parte na pessoa de seu advogado deverá ocorrer por publicação na imprensa oficial¹⁸⁹ ou por mandado¹⁹⁰.

Conquanto o dispositivo diga ser o prazo para contestar, é admissível a reconvenção na oposição (por ex., se um dos réus tiver fundamento para pretender uma indenização em face do autor da oposição se perder o bem em disputa).

Se um dos réus **reconhecer a procedência do pedido** deduzido na oposição, a demanda prosseguirá em relação ao outro (art. 684, CPC).

Admitida a oposição, as ações – a originária e a oposição – tramitarão simultaneamente, devendo ambas serem julgadas na mesma sentença (art. 685, CPC). Anote-se que, **se a oposição for proposta antes do início da audiência de instrução e julgamento**, não haverá suspensão e ambas correrão em paralelo, mas, **se proposta após**, em regra haverá a suspensão, podendo o juiz, contudo, suspender a audiência para a instrução conjunta das ações (art. 685, parágrafo único, CPC).

Finalmente, anote-se que há **relação de prejudicialidade** entre a oposição e a ação originária. A tramitação e sentenciamento conjunto de ambas as ações, aliás, decorre de **conexão por prejudicialidade impeditiva**, pois, se procedente a oposição, a ação originária perde o objeto, ao passo que somente a improcedência da oposição autorizará o julgamento da lide originária.

Por esse motivo é que existe a regra do art. 686, CPC, segundo a qual a **oposição deverá ser julgada em primeiro lugar**, destacando-se, todavia, que já se decidiu que a inobservância da ordem não acarreta nulidade da sentença se dela não decorreu prejuízo às partes¹⁹¹.

¹⁸⁸ Nesse sentido: REsp 780.401/DF, 3ª Turma, DJe 21/09/2009, rel. Ministra Nancy Andrihgi.

¹⁸⁹ GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.162.

¹⁹⁰ NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.619.

¹⁹¹ Nesse sentido: REsp 1.221.369/RS, 3ª Turma, DJe 30/08/2013, rel. Ministra Nancy Andrihgi.



1.9. AÇÕES DE FAMÍLIA

1.9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Prevê o art. 693, *caput*, CPC, que o procedimento previsto naquele capítulo se aplicará, regra geral, a todas as **ações de família** de natureza contenciosa (litígios sobre divórcio, separação, reconhecimento ou extinção de união estável, guarda, visitação ou filiação), ressalvada as ações de alimentos ou que envolvam interesse de menores, que observarão observam o procedimento previsto na lei especial de regência e nas quais o CPC apenas será aplicável subsidiariamente (art. 693, parágrafo único, CPC).

Conquanto parcela significativa da doutrina sustente não mais haver a ação de separação judicial após a EC 66/2010, que modificou o art. 226, §6º, CF/88, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que **a separação judicial subsiste** no ordenamento jurídico pátrio¹⁹².

As denominadas ações de família **deverão tramitar sob segredo de justiça** (art. 189, II, CPC), a fim de que seja preservada a intimidade das relações familiares.

Sublinhe-se que há regra específica que prevê caber à **jurisdição** brasileira proceder à partilha de bens situados no Brasil em divórcios, separações ou dissoluções de união estável, ainda que o titular seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do Brasil (art. 23, III, CPC).

Estabelecida a jurisdição, registre-se que a **competência territorial** está definida no art. 53, I, CPC, estabelecendo-se que será competente o foro: (i) do domicílio do guardião do filho incapaz; (ii) não havendo, do último domicílio do casal; (iii) se nenhuma das partes residir no último domicílio, no domicílio do réu; (iv) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Quanto ao ponto, anote-se não se tratar de foros concorrentes, mas, sim, de **foros subsidiários**¹⁹³.

Nas ações de família, a intervenção do Ministério Público como **fiscal da ordem jurídica (custos legis)**, ocorrerá quando houver interesse de incapaz, caso em que, inclusive, deverá ser ouvido previamente à homologação de qualquer acordo (arts. 178, II, e 698, *caput*, CPC), bem como nas hipóteses em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha (art. 698, parágrafo único, CPC).

Ainda em caráter propedêutico, anote-se que as ações de família são regidas por um **princípio de primazia da solução consensual**¹⁹⁴, de modo que, em razão das peculiaridades do direito material envolvido, as iniciativas de solução consensual do conflito são francamente incentivadas (art. 694, *caput*, CPC).

Daí porque: (i) a audiência de mediação ou conciliação **deverá ser realizada com o apoio de profissionais de outras áreas** do conhecimento (psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas, etc.); (ii) há **preferência pela mediação** em relação à conciliação (art. 694, *caput* e parágrafo único, 695, *caput* e 696, CPC); (iii) admite-se **multiplicidade de sessões** de mediação para viabilizar a solução consensual (art. 696, CPC); (iv) admite-se a **suspensão convencional do processo por período maior** do que o previsto para as demais hipóteses (art. 694, parágrafo único, e 313, II e §4º, CPC).

¹⁹²Nesse sentido: REsp 1.431.370/SP, 3ª Turma, DJe 22/08/2017, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp 1.247.098/MS, 4ª Turma, DJe 16/05/2017, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

¹⁹³Enunciado 108 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A competência prevista nas alíneas do art. 53, I, do CPC não é de foros concorrentes, mas de foros subsidiários”.

¹⁹⁴GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.178.



Há especificidades, ademais, nas **citações** das ações de família. Com o objetivo de inibir a animosidade entre as partes, admitida a petição inicial e decidido eventual pedido de tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação ou conciliação **sem que tenha ele ciência do conteúdo da petição inicial**, ou seja, o mandado conterà apenas os dados necessários para o seu comparecimento à audiência, mas sem o envio da contrafé, a despeito de se assegurar o exame de seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, *caput* e §1º, CPC).

Ainda no que concerne à citação, anote-se que o réu deverá ser cientificado, **pessoalmente**, com **pelo menos 15 dias de antecedência** à audiência (art. 695, §2º, CPC, que é regra especial em relação ao art. 334, *caput*, CPC, que prevê antecedência mínima de 20 dias), sendo obrigatória a **presença das partes e de seus respectivos advogados ou defensores** (art. 695, §4º, CPC). Não realizado o acordo, a ação se processará pelo **procedimento comum** (art. 697, CPC).

1.9.2. AÇÃO DE SEPARAÇÃO OU DIVÓRCIO

As ações de dissolução litigiosa do vínculo matrimonial pela separação judicial ou pelo divórcio possuem previsões legais específicas na Lei 6.515/1977, de natureza material e processual, que precisam ser examinadas em conjunto com o Código Civil e com o Código de Processo Civil.

Dentre os dispositivos legais que merecem ser destacados, sublinhe-se, em primeiro lugar, o art. 24, parágrafo único, da Lei 6.515/1977, que confere legitimidade ativa para o ajuizamento dessas ações apenas aos cônjuges, ressalvadas as hipóteses de incapacidade, em que igualmente serão legitimados, por substituição processual, o curador, o ascendente ou o irmão.

Também merece destaque o art. 7º, §1º, da Lei nº 6.515/1977, que prevê a denominada **separação de corpos** como medida cautelar. Registre-se que não há, no novo CPC, regra semelhante ao art. 888, VI, do CPC/73 (que previa a possibilidade de afastamento temporário de um dos cônjuges como medida provisional), nem tampouco ação cautelar propriamente dita.

Diante desse cenário, a **separação de corpos**, que é **antecipação de parte dos efeitos da tutela final** (dissolução do vínculo conjugal) e que, por isso mesmo, tem natureza satisfativa e não meramente acautelatória, poderá ser **requerida incidentalmente**, no bojo da petição inicial da ação de separação ou divórcio, bem como em **caráter antecedente**, caso em que deverá ser seguido o rito dos arts. 303 e seguintes, CPC, inclusive no que se refere à estabilização da tutela.

1.9.3. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL

Nas ações que versam sobre o **reconhecimento de união estável**, dois aspectos processuais são merecedores de atenção.

No que se refere à **prova**, embora já seja comum a realização de declaração conjunta ou escritura pública de união estável, não se pode olvidar que, em se tratando de situação de fato, a ampla e profunda instrução probatória é essencial à resolução da matéria, de modo que o acervo probatório apto a comprovação da união pode reunir, por ex., declaração de imposto de renda, certidão de nascimento de filho em comum, procurações, conta conjunta, apólice de seguro de um em favor do outro, etc., além, logicamente, da prova oral.

Especificamente no que se refere ao **reconhecimento e dissolução da união estável post mortem**, esclareça-se que a ação deverá ser proposta em face do espólio, se antes da partilha (e, mesmo não havendo litisconsórcio com os herdeiros, poderão eles intervir), sendo que, após a partilha, a legitimidade passiva será dos herdeiros¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Nesse sentido: REsp 1.080.614/SP, 3ª Turma, DJe 21/09/2009, rel. Ministra Nancy Andrighi.

1.9.4. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS

Na forma do art. 2º, *caput*, da Lei 11.804/2008, os alimentos gravídicos contemplam o valor destinado à gestante para atender as despesas relacionadas a gravidez e que sejam a ela correspondentes, compreendidas no período da concepção ao parto, incluindo alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames, internações, parto, medicamentos, profilaxia e medidas terapêuticas, de modo que se afigure apropriado que o **pedido seja instruído com laudos médicos** que indiquem e detalhem as necessidades da gestante, a fim de municiar o juiz no momento do **arbitramento do valor**.

O **deferimento de tutela concessiva de alimentos gravídicos** pressupõe a existência de **indícios de paternidade** (art. 6º da Lei 11.804/2008). Não há, pois, a necessidade de prova cabal e irrefutável da paternidade, mas, sim, de prova indiciária (oral, documental, etc.), sem prejuízo, evidentemente, da possibilidade de realização de prova técnica (exame de DNA fetal) se não houver risco ou prejuízo ao nascituro.

Na ação de alimentos gravídicos, o réu será citado para responder em **05 dias** (art. 7º da Lei 11.804/2008) e o posterior nascimento com vida implica em conversa dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia. A esse respeito, já se decidiu que *“em regra, a ação de alimentos gravídicos não se extingue ou perde seu objeto com o nascimento da criança, pois os referidos alimentos ficam convertidos em pensão alimentícia até eventual ação revisional em que se solicite a exoneração, redução ou majoração do valor dos alimentos ou até mesmo eventual resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade”*¹⁹⁶.

1.9.5. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE

No que se refere à investigação de paternidade, friza-se, inicialmente, que prevê o art. 2º, §1º a 6º, da Lei 8.560/1992 a denominada **averiguação oficiosa de paternidade**, cabível quando constar do registro de nascimento do menor apenas o nome da mãe e houver alegação de que o suposto pai se nega a reconhecê-lo, caso em que o oficial de registro enviará ao juiz a **certidão integral e dados do suposto pai**, a fim de que seja averiguada oficiosamente a procedência da alegação de negativa.

Nesse caso, o juiz ouvirá a mãe e, ato contínuo, notificará o suposto pai, independentemente de seu estado civil, para manifestação. Se reconhecer a paternidade, averba-se no registro do menor. Se, todavia, o **pretense pai negar a paternidade ou não responder a notificação, o juiz remeterá o procedimento ao Ministério Público para eventual ajuizamento de ação** de investigação de paternidade, dispensando-se o ajuizamento se, após o não comparecimento ou a recusa do pai, a criança for encaminhada para adoção.

Especificamente quanto à **ação investigatória**, sublinhe-se ser **legitimado** para ajuizá-la não apenas o Ministério Público, mas também quem tenha legítimo interesse em fazê-lo, tratando-se de conceito amplo que abrange os cônjuges, o próprio filho, avós, irmãos, etc., inclusive em virtude dos reflexos sucessórios que daí poderão advir.

A **competência** observará a regra geral do art. 46, *caput*, CPC (foro do domicílio do réu), salvo se **cumulada com pedido de alimentos**, caso em que se aplicará a regra do art. 53, II, CPC (foro de domicílio ou residência do alimentando)¹⁹⁷.

Como é cediço, na ação investigatória a **prova pericial consubstanciada no exame de DNA**, pela sua precisão científica, é aquela de maior relevância, a despeito da necessidade de seu

¹⁹⁶ Nesse sentido: REsp 1.629.423/SP, 3ª Turma, DJe 22/06/2017, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

¹⁹⁷ Súmula 1/STJ: “O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos”.

sopesamento com todas as demais provas que deverão ser produzidas (art. 2º-A, *caput*, da Lei 8.560/1992).

O maior peso dado à prova técnica, aliás, é corroborado pelo teor do art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 8.560/1992, que, em linha com a Súmula 301/STJ¹⁹⁸, prevê que “a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório”.

Finalmente, anote-se, quanto ao ponto, que se já se decidiu ser possível a **relativização da coisa julgada** que se formou em primeira ação investigatória de paternidade na hipótese de **dúvida razoável sobre eventual fraude** no exame anteriormente realizado¹⁹⁹, mas desde que essa seja a **causa de pedir** da nova ação investigatória²⁰⁰.

1.9.6. AÇÃO DE ALIMENTOS

Também para a ação de alimentos há que se compatibilizar o CPC com legislação especial (Lei 5.478/1968).

A **petição inicial**, na forma dos arts. 2º e 3º da Lei 5.478/1968, poderá ser realizada de forma simplificada, expondo sucintamente os fatos, as necessidades do alimentando e provando o parentesco e a obrigação de alimentar do devedor, qualificando-o, bem como informando ganhos e recursos de que dispõe. Há a possibilidade, inclusive, de dispensa de apresentação de documentos públicos em relação aos quais haja impedimento ou demora em obter ou extrair certidões.

Na forma do art. 292, III, CPC, o **valor da causa** na ação de alimentos será a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor.

Recebida a petição inicial, o juiz **fixará desde logo os alimentos provisórios**, salvo se o credor a eles renunciar (art. 4º, *caput*, da Lei 5.478/1968). A audiência de conciliação e julgamento deverá ser designada com tempo hábil para que possa o réu responder ao pedido, citando-o da ação e intimando-o da audiência no mesmo ato. Caso haja impedimento ou embaraço, possibilita-se ainda citação por edital (art. 5º, §1º, da Lei 5.478/1968).

O não comparecimento do **autor** à audiência, acarretará o **arquivamento** do processo, ao passo que o não comparecimento do **réu** implicará em **revelia** e em **confissão quanto à matéria de fato** (art. 7º da Lei 5.478/1968).

Para a audiência de conciliação e julgamento, deverá o juiz **oficiar ao empregador do réu**, solicitando o envio, até a audiência, de informações sobre salário ou vencimentos (art. 5º, §7º, da Lei 5.478/1968). De outro lado, **as partes deverão comparecer** à audiência com, no máximo, **03 testemunhas** cada e, se não houver conciliação, o juiz tomará o depoimento pessoal e ouvirá as testemunhas.

Ato contínuo, será concedida às partes e o Ministério Público a possibilidade de aduzir **razões finais**, oralmente e em **10 minutos cada** (art. 11, *caput*, da Lei 5.478/1968, regra especial em relação ao art. 364, *caput*, CPC, que prevê o prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10).

Da **sentença** que julgar a ação de alimentos caberá **apelação**, que **não possuirá efeito suspensivo** (arts. 14 da Lei 5.478/1968 e 1.012, §1º, II, CPC).

Finalmente, anote-se que a sentença de alimentos **não transita em julgado**, podendo ser revista, a qualquer tempo, diante da modificação de situação financeira dos interessados (art. 15 da

¹⁹⁸Súmula 1/STJ: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade”.

¹⁹⁹Nesse sentido: REsp 1.632.750/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁰⁰Nesse sentido: REsp 1.816.042/MG, 3ª Turma, DJe 03/12/2019, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.



Lei 5.478/1968). É a chamada **coisa julgada rebus sic stantibus**, ou seja, que se mantém imutável enquanto perdurar a situação fática que lhe serviu de suporte.

1.10. AÇÃO MONITÓRIA

A **ação monitoria** é àquela colocada à disposição do autor que pretende, em um **procedimento mais célere** do que o comum, a satisfação de obrigações de qualquer natureza (pagamento de valor, entrega de coisa fungível ou infungível, entrega de bem móvel ou imóvel e prestações de fazer ou de não fazer – art. 700, I a III, CPC) por **devedor capaz**.

Trata-se de medida ainda útil no sistema, na medida em que dispensa a realização da audiência do art. 334, CPC, tem aptidão para a formação de título executivo simplesmente pela não oposição de embargos pelo réu e, finalmente, retira automaticamente o efeito suspensivo de futura apelação²⁰¹.

Para que possa se valer da monitoria, é indispensável que **haja prova escrita sem eficácia de título executivo**. Trata-se de requisito de admissibilidade da ação monitoria e de concessão da tutela da evidência na hipótese de não oposição de embargos pelo réu, materializado na apresentação de **prova documental** ou de **prova oral documentada em ação probatória autônoma** (arts. 700, §1º, e 381, CPC). São exemplos de provas que viabilizam a abertura via monitoria, por ex., o contrato de abertura de crédito e demonstrativo do débito²⁰² e o cheque prescrito²⁰³.

De outro lado, também se exige que a prova escrita seja representativa de obrigação que não se enquadre no rol do art. 515, CPC (títulos executivos judiciais) ou no rol do art. 784, CPC (títulos executivos extrajudiciais), ou seja, **prova escrita que não possua força de título**.

Além dos requisitos do art. 319, CPC, o autor da ação monitoria deverá observar também os **seguintes requisitos específicos para a petição inicial** (art. 700, §2º, CPC): (i) se a obrigação for de pagar quantia, deve instruí-la com memória de cálculo, nos moldes do art. 524, II a VI, CPC; (ii) se a obrigação for de dar coisa, o valor atual do bem; (iii) se a obrigação for de fazer ou não fazer, o conteúdo econômico pretendido ou proveito econômico buscado. Tais valores, ainda que estimativos, corresponderão ao **valor a ser atribuído à causa**.

Conquanto o art. 701, *caput*, CPC, refira-se à **mandado de pagamento**, não se pode olvidar que todas as formas de citação são admissíveis na ação monitoria (art. 700, §7º, CPC), inclusive a **editância**²⁰⁴. A expedição de mandado de pagamento não significa que a citação somente poderá ocorrer por mandado.

O mandado de pagamento (ou **mandado monitorio**) será expedido sem oitiva do réu, desde que seja evidente o direito do autor materializado na prova escrita produzida (art. 701, *caput*, CPC). Trata-se, pois, de modalidade específica de tutela de evidência, suscetível de deferimento *inaudita altera parte* por expressa autorização legal (art. 9º, III, CPC).

Nessa hipótese, deverá o réu pagar, entregar ou fazer/não fazer em **15 dias** e, no mesmo prazo, deverá **depositar honorários de 5% sobre o valor da causa**, caso em que será **isento** de custas processuais. Por se tratar de prazo para satisfação de direito material com repercussão processual (deflagração do prazo para oposição de embargos), deverá ser aplicado, por analogia, o

²⁰¹GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 1.188/1.199.

²⁰²Súmula 247/STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitoria”.

²⁰³Súmula 299/STJ: “É admissível a ação monitoria fundada em cheque prescrito”.

²⁰⁴Súmula 282/STJ: “Cabe a citação por edital em ação monitoria”.

entendimento consolidado para o art. 523, *caput*, CPC, computando-se o referido prazo em **dias úteis**²⁰⁵.

Citado, poderá o réu, na forma dos arts. 701, §1º, 2º e 5º, e 702, CPC): (i) **cumprir tempestivamente a obrigação**, o que resultará na isenção do pagamento das custas e no benefício da redução de honorários (sanções premiais); (ii) **quedar-se inerte**, o que acarretará a formação imediata do título executivo judicial (com força de coisa julgada, pois rescindível – art. 701, §3º), viabilizando o cumprimento definitivo de sentença pelo autor, em que poderá o réu apresentar impugnação (com limitação cognitiva, todavia); (iii) **oferecer embargos monitórios**, o que resultará na suspensão da eficácia do mandado monitório e na conversão da monitória em procedimento comum; (iv) **requerer o parcelamento da dívida**, nas obrigações pecuniárias, na forma do art. 916, CPC, sem isenção de custas processuais.

Os **embargos monitórios** possuem natureza de **defesa e contestação** do réu na ação monitória, a ser ofertado em **15 dias** (isto é, no prazo de pagamento). Trata-se de uma inversão da lógica do contraditório, pois se exige conduta ativa do réu para que o procedimento comum seja deflagrado e para evitar que haja a formação do título executivo.

A atividade exercida na ação monitória e nos respectivos embargos é **cognitiva**, razão pela qual é **dispensado o oferecimento de garantia** (que sequer é exigível para os embargos à execução ou para a impugnação ao cumprimento de sentença). Daí porque, inclusive, é lícito deduzir nos embargos monitórios **quaisquer matérias que seriam dedutíveis em contestação no procedimento comum** (art. 702, §1º, CPC).

A despeito disso, na ação monitória possui singularidades procedimentais que a aproximam da execução ou fase de cumprimento, como, por exemplo, **a obrigatoriedade de o réu que alegar excesso de cobrança igualmente indicar o valor correto**, apresentando a competente memória de cálculo, sob pena de não conhecimento de alegação (art. 702, §2º, CPC).

Juntamente com o oferecimento dos embargos monitórios, **podará o réu reconvir**, positivando o art. 702, §6º, CPC, o teor da Súmula 292/STJ²⁰⁶. Veda-se, contudo, a reconvenção à reconvenção.

Admitidos os embargos, é imprescindível a **intimação do autor para sobre ele se manifestar** (art. 702, §5º, CPC) ainda que não haja defesa indireta (art. 350 e 351, CPC), na medida em que os embargos podem alargar ou aprofundar o âmbito delineado pelo autor na inicial da monitória (que, relembre-se, somente pretendia a conversão da prova escrita em título executivo).

Ao final da ação monitória embargada, será proferida sentença impugnável por apelação. Embora não esteja no rol do art. 1.012, §1º, CPC, o **recurso não terá efeito suspensivo**, uma vez que: (i) a formação do título, após a rejeição dos embargos, se dará imediatamente, conforme art. 702, §8º, CPC; (ii) a oposição dos embargos suspende a eficácia do mandado monitório até julgamento em 1º grau, conforme art. 702, §4º, CPC; (iii) a decisão que julga procedente a monitória restabelece a eficácia do mandado monitório, espécie de tutela da evidência, sendo certo que a confirmação de tutela provisória em sentença impede o recebimento do recurso no efeito suspensivo²⁰⁷.

Anote-se que há, na ação monitória, regra específica acerca da litigância de má-fé (art. 702, §10 e 11, CPC): se o autor for o litigante de má-fé, deverá pagar multa ao réu de até 10% sobre o valor da causa, ao passo que, se o réu for o embargante de má-fé, multa de igual forma revertida em favor do autor.

²⁰⁵ Nesse sentido: REsp 1.708.348/RJ, 3ª Turma, DJe 01/08/2019, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; REsp 1.693.784/DF, 4ª Turma, DJe 05/02/2018, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

²⁰⁶ Súmula 292/STJ: “A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário”.

²⁰⁷ Enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4º, e 1.012, § 1º, V, CPC)”.

Finalmente, sublinhe-se que a ação monitória já era admissível contra a Fazenda Pública no CPC/73²⁰⁸, sendo que o novo CPC apenas positivou o referido entendimento (art. 700, §6º). As peculiaridades, na hipótese, são, em suma, a necessidade de se observar: (i) após a formação do título judicial, as regras de cumprimento previstas nos arts. 534 e 535, CPC; (ii) as hipóteses de reexame necessário (arts. 496 e 701, §4º, CPC).

1.11. RESTAURAÇÃO DE AUTOS

A ação de restauração de autos tem por finalidade a restauração um processo judicial cível, eletrônico ou físico, que se extraviou, danificou ou desapareceu (art. 712, CPC). Esse procedimento não precisará ser observado em processos administrativos, que são regidos por legislação especial (Leis 8.112/90 e 9.784/99)²⁰⁹.

A **legitimação ativa** para a instauração dessa ação de procedimento especial é de qualquer das partes, do Ministério Público ou, ainda, pelo juiz, de ofício. Se instaurado por uma das partes, a outra será a **legitimada passiva**; se instaurado de ofício ou pelo Ministério Público, ambas as partes serão **legitimadas passivas**.

A **competência** para processar a ação é do juízo em que ocorreu o extravio do processo original (art. 61, CPC) e, se no Tribunal, deverá preferencialmente ser distribuído ao relator do recurso original (art. 717, CPC). Anote-se **haver regramento específico para a hipótese de desaparecimento no Tribunal**, em que caberá ao juízo de 1º grau do processo originário promover a restauração até as apelações (art. 717, §1º, CPC), prosseguindo-se daí em diante no próprio Tribunal (art. 717, §2º, CPC).

Na **petição inicial**, caberá ao requerente informar o estado do processo ao tempo do sumiço e, além disso, instruir a petição inicial com: (i) certidões; (ii) cópias de peças; (iii) quaisquer outros documentos úteis a restauração (art. 713, CPC), providência que igualmente caberá à(s) parte(s) que estiver(em) no polo passivo (deverá(ão) **contestar em 5 dias**, juntando cópias, contraféis, certidões, reproduções ou documentos que contribuam com a restauração (art. 714, *caput*, CPC).

Na **contestação**, o requerido poderá **concordar de plano com a restauração** realizada pelo requerente, caso em que será lavrado auto que, assinado pelas partes e juiz, suprirá o processo desaparecido (art. 714, §1º, CPC). Todavia, a **concordância poderá ocorrer após a contestação**, mediante a eventual complementação de documentos apresentados pelo requerido. Finalmente, poderão as partes **indicar a existência de peças que não foram juntadas por nenhuma delas** ou, ainda, **noticiar a juntada de documentos estranhos ao processo**, casos em que se converterá o procedimento especial em comum (art. 714, §2º, CPC).

Se a necessidade de restauração ocorrer após a instrução, deverá o juiz, se necessário, mandar refazer a prova (art. 715, *caput*, CPC), que observará: (i) na **prova oral**, haverá nova inquirição das mesmas testemunhas, podendo ser substituídas, de ofício ou a requerimento, se não for mais possível ouvi-las (art. 715, §1º, CPC); (ii) na **prova pericial**, se não for possível recuperar o laudo e nem tampouco a essencialidade da prova técnica (transcrição de seus elementos mais relevantes – quesitação e respostas – na sentença)²¹⁰, deverá ser refeita a perícia, preferencialmente pelo mesmo perito (art. 715, §2º, CPC); (iii) na **prova documental**, se não houver certidão dos documentos que instruíram o processo original, serão admissíveis cópias e, se não houver, os fatos que com os documentos se comprovavam deverão ser submetidos aos demais meios de prova (art. 715, §3º, CPC).

²⁰⁸ Súmula 339/STJ: “É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

²⁰⁹ Nesse sentido: MS 22.575/PA, 1ª Seção, DJE 30/08/2016, rel. Ministro Humberto Martins.

²¹⁰ Nesse sentido: REsp 302.527/RJ, 4ª Turma, DJ 12/02/2007, rel. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ademais, anote-se que os serventuários ou auxiliares serão **obrigados a depor sobre fatos** que tenham presenciado ou **atos** que tenham praticado (art. 715, §4º, CPC) e que caberá ao juiz ou ao escrivão colacionar cópias das decisões proferidas, especialmente da sentença, que possuirão o mesmo valor da origem (art. 715, §5º, CPC).

Se, após o ajuizamento da ação de restauração de atos, **o processo original for localizado ou recuperado**, nele prosseguirá a tramitação processual, apensando-se a restauração (art. 716, parágrafo único, CPC)

A ação de restauração será encerrada por **sentença**, contra a qual caberá **apelação** com efeito suspensivo. Quem **der causa ao desaparecimento arcará com as custas e honorários** (art. 718, CPC), ainda que não tenha havido contestação por quem deu causa²¹¹, ressalvada a hipótese em que o desaparecimento ocorreu por culpa do Poder Judiciário²¹².

1.12. REGULAÇÃO DE AVARIA GROSSA

A ação de regulação de avaria grossa visa a **apuração dos danos e das despesas** que não foram previstas antes da partida embarcação e que foram **intencionalmente causadas pelo comandante com o objetivo de se evitar danos maiores** durante o transporte, devendo tais eventos serem pormenorizadamente registrados no diário de bordo. Se a avaria grossa for comprovada, **haverá a repartição proporcional das despesas e dos danos entre transportador, fretador, proprietário da carga e segurador**, exonerando-se assim a responsabilidade exclusiva do transportador.

Realizada a avaria grossa pelo capitão e não havendo consenso entre os possíveis interessados sobre a forma do rateio (o que poderá decorrer, por ex., da própria tipificação ou não como avaria grossa ou sobre o regulador que será nomeado), a ação de regulação **poderá ser proposta por qualquer interessado no transporte**, isto é, fretadores, transportadores, proprietário da carga ou do navio, segurador, etc.

Consequentemente, quem **não for o autor da ação de regulação**, deverá necessariamente **figurar no polo passivo** em litisconsórcio unitário e necessário.

A **competência** será do lugar do primeiro porto a que a embarcação chegar após a ocorrência da avaria grossa, cabendo ao juiz, logo após o ajuizamento da ação, nomear um **regulador** na hipótese de não existir consenso entre as partes sobre o nome (art. 707, CPC). Entende-se que neste momento deverá ser ordenada a citação dos demais interessados²¹³.

O **regulador** é uma **espécie de perito** (tanto que se sujeita às regras de impedimento e suspeição – arts. 711 c/c 156 a 158, CPC), que deve ser altamente especializado no tema e que deve ter capacidade de não apenas definir se se trata de avaria grossa, como também de apurar a extensão dos danos causados.

O primeiro ato do regulador, na forma do art. 708, *caput*, CPC, será declarar, de modo justificado e imediato, inclusive mediante vistoria na embarcação, se os danos caracterizam avaria grossa, bem como exigir garantias das partes para liberação das cargas.

Havendo concordância dos interessados, e tendo sido prestadas as garantias por ele exigidas, serão liberadas as cargas; **se houver justificada impugnação** (seja quanto a tipificação como avaria grossa, seja quanto a extensão dos danos, seja ainda quanto as garantias exigidas pelo regulador para liberação), caberá ao juiz deliberar sobre a questão em 10 dias (art. 708, §1º, CPC).

²¹¹ Nesse sentido: Pet 3.753/SC, 1ª Turma, DJe 17/09/2009, rel. Ministro Luiz Fux.

²¹² Nesse sentido: EDcl no REsp 10.883/SP, 2ª Turma, DJ 04/04/2005, rel. Ministro Franciulli Netto.

²¹³ Enunciado 75 do FPPC: “(art. 707) No mesmo ato em que nomear o regulador da avaria grossa, o juiz deverá determinar a citação das partes interessadas. (Grupo: Procedimentos Especiais)”.

Em regra, a liberação das cargas somente ocorrerá após a **apresentação de garantias idôneas** (reais, fidejussórias, etc.) por **todas as partes potencialmente formadoras do rateio** para reparação da avaria grossa.

Não havendo a apresentação das garantias exigidas, o regular fixará o valor da **contribuição provisória** para o prosseguimento dos trabalhos, a ser **caucionada** por depósito judicial ou garantia bancária (art. 708, §2º, CPC) e, se não houver o caucionamento, o regulador requererá ao juiz a alienação judicial da carga para dar prosseguimento à regulação da avaria (arts. 708, §3º, e 879 a 903, CPC).

Poderá o regulador, mediante alvará, levantar as quantias necessárias às despesas de alienação, mantendo-se o saldo em depósito judicial até finalização da regulação (art. 708, §4º, CPC).

Em sequência, serão as partes intimadas para, em prazo razoável a ser fixado pelo regulador, apresentar aos autos **todos os documentos** aptos a comprovação, extensão e quantificação dos danos (tais como: diário de bordo; protesto marítimo ou formado a bordo na forma do art. 766, CPC; ata de deliberação; conhecimento de embarque marítimo; contrato de transporte e demais documentos relacionados à carga), o que somado a vistoria na embarcação, permitirão a continuidade dos trabalhos pelo regulador (art. 709, CPC).

Instruída a ação de regulação, terá o regulador o prazo de **12 meses**, contados da entrega dos documentos pelas partes, para apresentar o **regulamento**, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz (art. 710, *caput*, CPC).

Oferecido o regulamento, as partes terão o **prazo comum de 15 dias para manifestações** e, havendo impugnação, os autos serão remetidos ao regulador para esclarecimentos adicionais. Sem impugnação, ou após a decisão sobre ela, o juiz proferirá **sentença homologando o regulamento** (arts. 710, §1º e 2º, CPC), da qual caberá **apelação** com efeito suspensivo. A sentença tem natureza **condenatória**, na medida em que impõe aos interessados a obrigação de contribuir pecuniariamente para a reparação dos danos, na proporção de suas participações e responsabilidades.

1.13. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA

A ação de homologação de decisão estrangeira, de competência exclusiva do STJ, tem por finalidade conferir eficácia total ou parcial a uma decisão proferida em outro país, a fim de que possa ela ser executada no Brasil (art. 961, *caput* e §2º, CPC).

São **homologáveis** as seguintes decisões estrangeiras: (i) as **sentenças** e as **decisões parciais de mérito**, sejam elas declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais ou executivas; (ii) as **decisões não judiciais**, desde que, no Brasil, o conteúdo tenha natureza jurisdicional (art. 961, §1º, CPC); (iii) as **decisões arbitrais**, observados, nesse aspecto, os ditames da lei específica de regência (no Brasil, a Lei 9.307/96), conforme art. 960, §3º, CPC.

Ademais, anote-se que são **exequíveis no Brasil as tutelas de urgência concedidas no estrangeiro**, que deverão ser efetivadas por meio de carta rogatória (art. 962, §1º, CPC), desde que: (i) tenha sido garantido o **contraditório**, prévio ou diferido (art. 962, §2º, CPC); (ii) tenha sido examinada a urgência pelo **juízo de origem** (art. 962, §3º, CPC); (iii) se se tratar de sentença cuja homologação é dispensada no Brasil (por lei ou tratado), a executoriedade sobre a decisão de medida de urgência **dependerá de exame de validade**, a ser promovido pelo juiz competente para lhe dar cumprimento (art. 962, §4º, CPC).

Anote-se que há **previsão legal específica de dispensa de homologação**, que se soma às dispensas eventualmente fixadas em tratados: a **sentença estrangeira de divórcio consensual** (art. 961, §5º, CPC) dispensa a homologação, mas se sujeita ao controle jurisdicional, exercido *principaliter* ou *incidenter tantum* por qualquer juiz, quando suscitada a questão em processo de sua competência (art. 961, §6º, CPC).

Na ação de homologação de decisão estrangeira, descabe ao STJ examinar os fundamentos de fato e de direito adotados pelo prolator da decisão estrangeira. **A cognição, pois, é diferenciada e restrita, na medida em que o STJ apenas verificará, em juízo de delibação,** se: (i) a decisão foi proferida por autoridade competente; (ii) houve citação válida na origem, ainda que tenha havido revelia; (iii) a decisão é eficaz no país em que foi proferida, não mais se exigindo que tenha havido o trânsito em julgado na origem²¹⁴; (iv) não há ofensa à coisa julgada brasileira; (v) está acompanhada de tradução oficial, salvo dispensa em texto convencional; (vi) não contenha ofensa à ordem pública, à soberania nacional e/ou à dignidade da pessoa humana (arts. 963, I a VI, CPC).

Do ponto de vista **procedimental**, é absolutamente imprescindível a observância do Regimento Interno do STJ – RISTJ.

Nesse contexto, sublinhe-se que é **atribuição** da Presidência do STJ homologar a decisão estrangeira, **salvo na hipótese de haver contestação**, caso em que será distribuída a um relator (a quem caberá instruir o feito) e decidida pela Corte Especial (art. 216-A e 216-K, RISTJ). Se já houver jurisprudência consolidada sobre o tema, será admitida a resolução por decisão monocrática do relator (art. 216-K, parágrafo único, RISTJ).

A petição inicial deverá observar os requisitos do art. 319, CPC, e ser instruída com original ou cópia da decisão e outros documentos indispensáveis, traduzidos oficialmente ou por tradutor juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira, conforme art. 216-C, RISTJ, admitindo-se emendas ou aditamentos (art. 216-E, *caput*, RISTJ) que, se não realizados, acarretarão a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 216-E, parágrafo único, RISTJ).

É admissível a concessão de tutela provisória na ação de homologação de decisão estrangeira (art. 216-G, RISTJ), que **não se confunde com a tutela de urgência concedida no exterior e que deverá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória**. Esse dispositivo permite a concessão, pelo STJ, de tutela provisória no âmbito da própria ação de homologação de decisão estrangeira.

O réu será citado e poderá contestar em **15 dias** (art. 216-H, *caput*, RISTJ), limitando a sua defesa ao eventual **não preenchimento dos requisitos legais** para homologação, a serem aferidos em **juízo de delibação**. Na hipótese de revelia ou de incapacidade do réu, será nomeado **curador especial**, na forma do art. 216-I, RISTJ.

É admissível, na ação de homologação de decisão estrangeira, a concessão de prazos para **réplica e tréplica** (art. 216-J, RISTJ), sendo que, após, deverá ser dada vista ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 dias, ocasião em que poderá o *Parquet* impugnar o pedido (art. 216-L, RISTJ).

Das **decisões unipessoais** proferidas na ação de homologação de decisão estrangeira, será cabível **agravo interno** (art. 1.021, CPC, e art. 216-M, RISTJ). Do **acórdão que julgar o mérito da ação**, caberão **embargos de declaração** (art. 1.022, I a II, CPC) ou **recurso extraordinário** (art. 102, III, “a”, CF/88), se porventura presentes os pressupostos desses recursos.

Finalmente, anote-se que os atos de execução e de cumprimento da decisão estrangeira homologada pelo STJ serão **efetivados pelo juízo federal competente**, pelo mesmo rito do cumprimento da decisão brasileira, devendo o requerimento ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória, conforme o caso (art. 965, *caput* e parágrafo único, CPC). Todavia, todas as demais providências relacionadas ao cumprimento do julgado, como, por exemplo, o pagamento da condenação em honorários, que é cabível, deverá ser processado pela Presidência do STJ (art. 301, I, RISTJ).

²¹⁴ Nesse sentido: SEC 14.812/EX, Corte Especial, DJe 23/05/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

1.14. HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR LEGAL

O penhor é uma das modalidades que compõem o rol dos direitos reais de garantia (juntamente com a hipoteca e a anticrese), que recai sobre bens móveis e que pode decorrer de acordo entre as partes (penhor consensual) ou da própria lei (penhor legal).

No **penhor legal** (arts. 1.467, I e II, CC, e 31, Lei 6.533/78), o credor toma *sponte propria* a posse de bens móveis do devedor (hipóteses específicas de **autotutela** autorizadas pela lei), quantos forem necessários para a satisfação da dívida, levando, apenas posteriormente, à homologação judicial (arts. 1.470 e 1.471, CC), admitindo-se a possibilidade de o penhor não se constituir se o devedor prestar caução idônea (art. 1.472, CC).

De início, há a **possibilidade de homologação extrajudicial do penhor legal** (art. 703, §2º a 4º, CPC), mediante **requerimento do credor** ao cartório de notas de sua escolha, instruindo o requerimento com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, tabela de preços e relação de objetos retidos.

Nessa hipótese, recebido o requerimento, o devedor será notificado para **pagar** ou **impugnar** a dívida em **05 dias**. Se **impugnada** a dívida, o procedimento será encaminhado para **deliberação judicial**; se não houver manifestação do devedor, o próprio **notário homologará o penhor** por escritura pública.

Essa possibilidade não impede que seja desde logo requerida a **homologação judicial do penhor legal** (art. 703, §1º, CPC), caso em que o credor, por **petição inicial** que, além dos requisitos do art. 319, CPC, deverá ser instruída, conforme o caso, com o contrato de locação ou com a conta pormenorizada das despesas, tabela de preços e relação de objetos retidos, requererá a citação do devedor para **pagar em 05 dias** ou **contestar em audiência preliminar que será designada** (não se trata da audiência de mediação ou conciliação do art. 334, CPC, mas de audiência específica deste rito especial).

Na **homologação extrajudicial ou judicial do penhor legal**, a defesa do devedor é limitada às matérias indicadas no art. 704, I a IV, CPC (pois se discute apenas a validade do ato de apossamento e não a inexistência da obrigação de forma exauriente). As matérias dedutíveis são as seguintes: (i) **nulidade do processo**, como, por exemplo, se o credor não colacionou a documentação essencial exigida; (ii) **extinção da obrigação**, como, por exemplo, pelo pagamento; (iii) **que a dívida ou os bens são insuscetíveis de penhor legal**, como, por exemplo, se o fornecedor não inseriu a tabela impressa, prévia e ostensivamente, no estabelecimento; (iv) **que há caução idônea rejeitada pelo credor**. O rol é **exemplificativo**, pois se admite a cognição de **questões de ordem pública** que deva o juiz conhecer de ofício²¹⁵.

Após a realização da audiência preliminar, converter-se-á o procedimento em comum (art. 705, CPC).

A **sentença homologatória** do penhor legal, se de **procedência**, consolidará a posse do credor sobre o objeto, facultando-se a sua posterior alienação, sem, contudo, formar título judicial ou extrajudicial acerca da existência da dívida; se de **improcedência**, implicará na determinação de devolução do objeto ao devedor, sem prejuízo de o credor cobrar a dívida pelas vias ordinárias ou pela monitória, salvo se se reconhecer a existência de extinção da obrigação (art. 706, *caput* e §1º, CPC).

²¹⁵ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.213/1.214; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.647.



Embora a apelação que eventualmente se interporá contra a sentença **não possua efeito suspensivo**, é admissível que o relator determine que a coisa permaneça depositada judicialmente ou em poder do credor durante a tramitação do recurso (art. 706, §2º, CPC).

2. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A jurisdição voluntária é atividade jurisdicional que, **pressupondo a inexistência de lide e a existência de interesses convergentes**, visa a criação, modificação ou extinção de situações e de relações jurídicas. Embora a ausência de litigiosidade seja pressuposta, não se pode olvidar que o conflito de interesses poderá ocorrer no âmbito desses procedimentos, como, por exemplo, na hipótese de interdição promovida por genitora contra os interesses do interditando.

Em todos esses procedimentos, vige o **princípio dispositivo**, de modo que há a necessidade de provocação dos interessados (não há, a rigor, autor e réu), do Ministério Público ou da Defensoria Pública, a quem caberá formular o pedido e instruir o requerimento com a documentação necessária (art. 720, CPC). O conceito de **interessados** é vago, podendo ser tido como interessado todo aquele **cujas esferas jurídica poderá ser atingida pela decisão** ou, ainda, aquele que **precisa ser cientificado do procedimento sob pena de invalidade** da medida pleiteada.

Todos os interessados deverão ser **citados**, ao passo que o Ministério Público deverá ser **intimado** nas hipóteses do art. 178, CPC (interesse público ou social; interesse de incapaz; litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana), para se manifestarem em **15 dias** (art. 721, CPC). A Fazenda Pública será sempre ouvida quando for interessada (art. 722, CPC).

Inexistindo, em regra, lide e conflito de interesses, **não há que se falar em revelia**, inclusive porque inexistente contestação nos procedimentos. Pelo mesmo motivo, **não se cogita de reconvenção**.

Ato contínuo, deverá ser proferida **sentença** sobre o pedido no prazo de 10 dias (art. 723, *caput*, CPC), sendo que há previsão legal específica (art. 723, parágrafo único, CPC) no sentido de que o juiz está autorizado a **não observar o critério de legalidade estrita**, podendo adotar solução equitativa com base em conveniência ou oportunidade (critérios discricionários para o atingimento da decisão mais justa). Da sentença caberá apelação (art. 724, CPC).

Finalmente, elenca o art. 725, CPC, em **rol exemplificativo**, hipóteses de pedidos que se processarão sob procedimentos de jurisdição voluntária: (i) **emancipação** do menor de 16 anos, necessária quando houver divergência entre os pais que impeça a emancipação voluntária ou quando o menor estiver sob tutela; (ii) **sub-rogação**, por meio do qual se transfere a cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade de um bem, dado a alguém em doação, testamento ou instituição do bem de família, para outro de igual valor, para não desrespeitar a vontade do doador, falecido ou instituidor; (iii) **alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças, adolescentes, órfãos ou interditos**, pois a prévia autorização judicial é requisito de validade do negócio jurídico que envolva tais pessoas, devendo ser demonstrado que o negócio é benéfico ou, ainda, que se trata de situação de necessidade; (iv) **alienação, locação e administração de coisa comum e alienação de quinhão em coisa comum**, embora tais atos, a rigor, dispensem a manifestação do Poder Judiciário se todos estiverem de acordo (de modo que não há que se falar em jurisdição voluntária) e, se houver discordância, haverá lide e igualmente não haverá jurisdição voluntária; (v) **extinção de usufruto** quando não se der por falecimento do usufrutuário, por termo da sua duração ou pela consolidação e **extinção do fideicomisso** (estipulação em que o testador constitui alguém como legatário ou herdeiro, impondo, todavia, que uma vez verificada uma determinada condição, o legado ou herança deverá ser transmitida a outra pessoa por ele indicada), desde que decorrente de renúncia ou quando ocorrer antes do evento causador da condição resolutória; (vi) **alvará judicial**, que é o requerimento de expedição de quaisquer alvarás (permissão



para que determinados atos aconteçam); (vii) **homologação de autocomposição extrajudicial**, independentemente do valor ou da natureza, que ocorrerá de plano se feita por todos os subscritores e *a posteriori*, se requerida por apenas algum deles, caso em que os demais deverão ser citados e aquiescerem.

2.2. NOTIFICAÇÃO, INTERPELAÇÃO E PROTESTO

São meras manifestações de vontade sobre assuntos juridicamente relevantes, atuando o juiz, nessa situação, como mero intermediador desta comunicação. Não há ordem judicial alguma, não há prova em regra e, também como regra, não há sentença (art. 726, *caput*, CPC).

O **protesto** é a mera documentação de um fato; a **notificação** é a documentação de um fato associada a um ato de comunicação; a **interpelação** é a documentação de um fato com a intenção de gerar um ato da outra parte (fazer ou não fazer).

Do ponto de vista **procedimental**, anote-se que, salvo na hipótese de requerimento de edital (cientificação pública e geral da manifestação de vontade), em que se faz um juízo de admissibilidade sobre as razões apresentadas e sobre a efetiva necessidade da medida (podendo-se, nessa hipótese, produzir-se prova desses fatos), a regra é de que, requerida a interpelação, protesto ou notificação, o **juiz determinará a imediata intimação da pessoa indicada na petição** (art. 726, §1º, CPC).

Apenas se houver suspeita de que a medida se presta a fim ilícito ou se a medida tiver sido requerida para fim de averbação em registro público, deverá o juiz instalar o contraditório e permitir que a pessoa a ser intimada se pronuncie, a fim de evitar prejuízo (art. 728, I e II, CPC).

Deferida a intimação da pessoa indicada e sendo ela regularmente intimada, os autos serão devolvidos ao promovente da medida (art. 729, CPC).

Em regra, **não haverá sentença e tampouco recurso nesses procedimentos**. Contudo, será admissível recurso nas hipóteses em que deveria ter havido contraditório (mas não houve), bem como na hipótese em que o requerimento é de plano indeferido. Nesse caso, será cabível apelação, pois, conquanto não haja conteúdo de mérito na decisão, o pronunciamento jurisdicional coloca fim ao procedimento em 1º grau²¹⁶.

2.3. ALIENAÇÃO JUDICIAL

Não havendo acordo entre os interessados sobre o modo pelo qual um determinado bem deverá ser alienado, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, incidentalmente ou em procedimento autônomo, mandará alienar o referido bem em leilão, na forma dos arts. 879 a 903, CPC.

O único pressuposto é de que haja **discordância entre os interessados**, não havendo juízo de valor sobre a conveniência ou não da alienação.

A alienação ocorrerá por **iniciativa particular** (preferível em relação ao leilão judicial, art. 881, CPC) ou, se não for possível, por intermédio de **leilão judicial eletrônico** (preferível em relação ao leilão presencial, art. 882, CPC), por corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

Caberá ao juiz fixar o prazo para alienar, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e comissões, se o caso. De igual modo, a ele caberá a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.

²¹⁶ Nesse sentido: REsp 35.631/CE, 3ª Turma, DJ 13/09/1993, rel. Ministro Eduardo Ribeiro.



O leilão deverá ser precedido de publicação de edital, em que constará o detalhamento preciso do bem (características, valor de avaliação e preço mínimo, lugar onde estão, *website* ou local do leilão, eventuais ônus ou processos pendentes, etc.).

2.4. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO CONSENSUAL, EXTINÇÃO CONSENSUAL DA UNIÃO ESTÁVEL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO MATRIMÔNIO

A homologação judicial de divórcio, de separação ou de dissolução da união estável (art. 731, I a IV, CPC) poderá ser requerida por ambos os cônjuges, em petição conjunta, que deverá indicar as disposições relativas à descrição e a partilha dos bens comuns, pensão alimentícia entre os cônjuges, guarda dos filhos incapazes e regime de visitas e contribuição destinada a criação e educação dos filhos. Se porventura **não houver acordo sobre a partilha**, é possível que esta questão seja decidida posteriormente ao divórcio, separação ou dissolução (art. 731, parágrafo único, CPC), observando-se as regras dos arts. 647 a 658, CPC.

É possível a **homologação extrajudicial** mediante a lavratura de escritura pública de divórcio, separação ou dissolução, que indicará as mesmas disposições referidas no procedimento judicial, se não houver nascituros ou filhos incapazes (art. 733, *caput*, CPC) e desde que as partes estejam representadas por advogados ou defensores (art. 733, §2º, CPC), sendo a escritura suficiente para qualquer ato de registro ou de levantamento de valores depositados, independentemente de homologação judicial (art. 733, §1º, CPC).

No que se refere ao pedido de **alteração do regime de bens do casamento**, anote-se ser cabível **mediante autorização judicial** em pedido motivado por ambos os cônjuges, submetido a procedimento de jurisdição voluntária em que se apurará a credibilidade e a procedência dos motivos apresentados pelas partes, resguardando-se os direitos de terceiros (art. 1.639, §2º, CC e art. 734, *caput*, CPC)²¹⁷.

Do ponto de vista **procedimental**, recebida a petição inicial, será determinada a oitiva do Ministério Público e a publicação de edital para divulgação do requerimento de alteração de bens, com validade de 30 dias, findo o qual poderá o juiz decidir (art. 734, §1º, CPC). É admissível que as partes proponham, na inicial ou em petição incidental, outro meio de divulgação da alteração do regime de bens (*internet*, por exemplo), a fim de resguardar direitos de terceiros (art. 734, §2º, CPC).

Transitada em julgado a sentença homologatória, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, se necessário, ao registro público de empresas (art. 734, §3º, CPC). Para preservar direitos de terceiros, a alteração do regime produzirá efeitos *ex nunc*, ou seja, apenas a partir da sentença²¹⁸.

2.5. TESTAMENTOS E CODICILOS

Ao receber um **testamento cerrado**, que é aquele secreto, escrito pelo próprio testador ou por alguém a pedido dele, aprovado por tabelião que deverá costurá-lo e ainda lacrá-lo com cera quente, devolvendo-o ao testador para guarda, deverá o juiz, se não identificar vício que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, abri-lo e mandar que o escrivão o leia na presença do apresentante (art. 735, *caput*, CPC).

Ato contínuo, será lavrado **termo de abertura** contendo, essencialmente, o nome do apresentante, como obteve o testamento, a data e local do falecimento do testador, acompanhado das respectivas provas (art. 735, §1º, CPC) e, após a oitiva do Ministério Público, mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento se não houver dúvidas (art. 735, §2º, CPC).

²¹⁷ Nesse sentido: REsp 1.446.330/SP, 3ª Turma, DJe 27/03/2015, rel. Ministro Moura Ribeiro.

²¹⁸ Nesse sentido: REsp 1.533.179/RS, 3ª Turma, DJe 23/09/2015, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Após o registro, será intimado o **testamenteiro**, que é a pessoa indicada pelo testador para o cumprimento de suas disposições de última vontade e prestar contas em juízo. Se não houver, será nomeado testamenteiro dativo na ordem legal – cônjuge ou herdeiro a ser nomeado pelo juiz (art. 1.984, CC).

As regras do **testamento cerrado** também se aplicam ao **testamento público** (art. 736, CPC).

No **testamento particular** (elaborado pelo próprio testador para leitura de 3 testemunhas, na forma do art. 1.876 e seguintes do CC, no **marítimo** (em navio brasileiro, de guerra ou mercante, perante o comandante), no **aeronáutico** (militar ou comercial, perante quem for indicado pelo comandante), no **militar** (feito em campanha, no país ou fora dele, ante 2 ou 3 testemunhas) e no **nuncupativo** (militar e oral, em combate ou ferido), bem como no **codicilo** (escrito de última vontade que dispõe sobre o enterro do testador, doação de esmolas, móveis, roupas ou joias de uso particular e de pequeno valor), deverá, na forma do art. 737, *caput*, CPC, haver a publicação do testamento, que poderá ser requerida pelo herdeiro, legatário, testamenteiro ou terceiro detentor do testamento, se impossível a entrega a algum dos demais legitimados.

Ato contínuo, os herdeiros que não requereram a publicação deverão ser **intimados** (art. 737, §1º, CPC) e, após a oitiva do Ministério Público, deverá o juiz **confirmar o testamento** de presentes os requisitos legais (art. 737, §2º, CPC), a ser cumprido tal qual o testamento cerrado (art. 735, CPC).

2.6. HERANÇA JACENTE

A herança jacente é um **ente despersonalizado** consistente em um acervo de bens, administrado por um curador sob fiscalização do juiz, que existirá até que se habilitem os herdeiros, incertos ou desconhecidos, ou até que se reconheça, por intermédio de sentença, a vacância da herança.

Considera-se jacente a herança quando não há testamento e nem tampouco herdeiro conhecido (art. 1819, CC), caso em que o juiz da comarca do domicílio do falecido procederá imediatamente às diligências de **arrecadação dos bens**, que ficarão sob a guarda, conservação e administração de um **curador**, a quem incumbirá: (i) representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público; (ii) guardar e conservar adequadamente os bens e direitos arrecadados e promover a arrecadação de outros eventualmente existentes; (iii) prestar contas mensalmente ao juiz, mediante apresentação de balancete de receitas e despesas, e também ao final da sua gestão (art. 739, *caput* e §1º, CPC).

Anote-se que ao **curador** se aplicam as mesmas regras relacionados ao **administrador** e ao **depositário de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados** (arts. 159 a 161, CPC), ou seja, há remuneração pelos serviços prestados, possibilidade de indicação de prepostos e a responsabilidade civil pelos danos causados por culpa ou dolo que causar aos bens da herança jacente (sem prejuízo da responsabilização penal e da imposição de pena por ato atentatório), inclusive com possibilidade de perda da remuneração arbitrada, ressalvado o direito de ter reembolsadas as despesas efetuadas.

Caberá ao **oficial de justiça**, acompanhado do **escrivão** e do **curador**, **arrolar os bens** que compõem a herança jacente e descrevê-los em auto circunstanciado, podendo o oficial ser **substituído por autoridade policial** na impossibilidade daquele, desde que acompanhado por **2 testemunhas** (art. 740, *caput* e §1º, CPC).

Durante as diligências de arrecadação de bens, deverá o juiz **perquirir sobre dados e informações** do falecido, dos seus sucessores ou eventuais outros bens, lavrando-se tudo em auto de inquirição e informação.

Deverão ser examinados pelo juiz os **documentos** e, se porventura não houver nada que indiquem informações ou dados interessantes para a localização de herdeiros e destino dos bens, deverão eles ser empacotados para entrega aos sucessores ou queimados, se vacantes (art. 740, §4º, CPC). Os bens eventualmente existentes em **outras comarcas serão arrecadados por meio de carta precatória** (art. 740, §5º, CPC).

A arrecadação não será realizada ou será suspensa, se iniciada, quando comparecerem o cônjuge ou companheiro, herdeiro ou testamenteiro e se não houver oposição fundamentada do Ministério Público, da Fazenda Pública, do curador ou de qualquer interessado (art. 740, §6º, CPC).

Finda a arrecadação, será expedido **edital**, a ser publicado na *internet*, no *website* do Tribunal a que estiver vinculado o juízo e em página do CNJ (na forma da Resolução 234/2016), onde permanecerá por **3 meses**, facultando-se a **habilitação dos sucessores** no prazo de **6 meses** contado da primeira publicação (art. 741, *caput*, CPC). Havendo habilitação de herdeiro, reconhecida a existência de testamenteiro ou provado haver cônjuge ou companheiro, a **arrecadação será convertida em inventário**.

Nesse período, **poderá o juiz autorizar a alienação** de: (i) **bens móveis**, se a conservação for difícil ou custosa; (ii) **semoventes**, se não empregados em alguma indústria; (iii) **títulos e créditos**, se houver risco de depreciação; (iv) **ações**, se reclamada a integralização e não houver dinheiro para pagamento na herança; (v) **imóveis**, se existente risco de ruína e inviável a reparação; se hipotecados e, vencendo-se a dívida, não houver dinheiro para pagamento (art. 742, I a V, CPC). A alienação de retratos, objetos de uso pessoal, livros, obras de arte e objetos de afeição somente será possível após a vacância (art. 742, §2º, CPC).

A **vacância** ocorrerá se, **1 ano após a primeira publicação** do edital, não houver herdeiro habilitado ou habilitação pendente (art. 743, *caput*, CPC). Transitada em julgado a sentença que **declarar a vacância**, o bem será transferido ao Estado²¹⁹, momento a partir do qual eventual cônjuge, companheiro, herdeiro ou credor apenas poderá reavê-lo por meio de ação de conhecimento a ser ajuizada em face do Estado (art. 743, §2º, CPC).

2.7. BENS DOS AUSENTES

Havendo o desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio sem que dela se tenha notícia, sem representante ou procurador (ou, havendo, o recuse ou possua poderes insuficientes), o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, nomeando curador (art. 22, CC, e art. 744, CPC).

Nessa hipótese, observar-se-á, em princípio, o **mesmo procedimento da herança jacente** (art. 745, *caput*, CPC), ressalvando-se que, em vez de vacância, o esgotamento do prazo de 1 ano da primeira publicação do edital **acarretará a possibilidade de abertura da sucessão provisória por qualquer interessado**, a quem caberá requerer a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos herdeiros ausentes para habilitação (art. 745, §1º e 2º, CPC).

Sentenciada a sucessão provisória e passado o prazo de **10 anos após o trânsito** (ou, tendo o ausente **mais de 80 anos** e há **5 anos houve a última notícia** dele ou, ainda, se **confirmada a sua morte**), poderá haver a **conversão em sucessão definitiva** (art. 37 e 38, CC).

Havendo o **regresso** do ausente ou de algum ascendente ou descendente, reclamando a entrega dos bens, serão **citados para contestar** os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e a Fazenda Pública, seguindo-se, a partir daí, o procedimento comum (art. 745, §4º, CPC).

²¹⁹ Nesse sentido: REsp 36.873/SP. 3ª Turma, DJ 28/05/2001, rel. Ministro Ari Parglender.



2.8. COISAS VAGAS

Se receber do descobridor coisa alheia perdida, o juiz lavrará auto descrevendo o bem e as declarações do descobridor (art. 746, *caput*, CPC) e, se recebido por autoridade policial, a ela caberá a remessa ao juízo competente (art. 746, §1º, CPC).

Será publicado nos moldes do art. 741, *caput*, CPC, para o fim de que o dono ou possuidor a reclame, salvo se se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do Tribunal, caso em que o edital apenas será fixado no átrio do edifício do fórum (art. 746, §2º, CPC).

2.9. INTERDIÇÃO

Estão sujeitos à **interdição** aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos e os pródigos. Tais pessoas precisam ser **curateladas** pelo Estado.

O cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante da entidade em que o interditando está albergado e o Ministério Público possuem **legitimidade ativa** para o ajuizamento da ação de interdição (art. 747, I a IV, CPC). Anote-se que a legitimidade do Ministério Público é **residual**, na medida em que somente promoverá a medida em caso de **doença mental grave** e **se os legitimados ordinários não existirem ou não a promoverem** ou se cônjuge, companheiro, parente ou tutores **também forem incapazes** (art. 748, I e II, CPC).

Na **petição inicial**, deverá o autor especificar os fatos relacionados à incapacidade do interditando para administrar e/ou para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se verificou (art. 749, *caput*, CPC), juntando laudo médico para provar as suas alegações ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo (art. 750, CPC). É admissível que, em situações de **urgência**, seja nomeado **curador provisório** para a prática de determinados atos da vida civil (art. 749, parágrafo único, CPC).

Na forma do art. 751, *caput*, CPC, o interditando será citado para, em data a ser designada, ser **entrevistado pelo juiz** (antigamente, este ato se chamava **interrogatório do interditando**), a quem caberá indagar sobre sua vida, negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos e sobre tudo mais que for útil para a aferição da capacidade, podendo ser acompanhado por especialista, serem utilizados recursos tecnológicos que auxiliem as manifestações de vontade e respostas e, ainda, ouvidos parentes e pessoas próximas do interditando (art. 751, §2º a 4º, CPC). Já se decidiu que a **ausência de entrevista acarreta a nulidade do processo**²²⁰.

Após a entrevista, abre-se o prazo de **15 dias** para eventual **impugnação** do interditando (art. 752, *caput*, CPC), que poderá ser representado por advogado e, em sua ausência, será nomeado **curador especial**. Anote-se que já se decidiu que o **curador especial não poderá ser o Ministério Público**, tendo em vista o risco de conflito entre a atuação como *custos legis* e como parte²²¹.

Ato contínuo, será determinada a realização de perícia para avaliação da capacidade, que poderá ser realizada por equipe multidisciplinar, cujo laudo deverá, se o caso, identificar para quais atos haverá a necessidade de curatela (art. 753, *caput* e §§1º e 2º, CPC).

É possível dispensar o laudo pericial judicial **se outro houver sido feito na fase extrajudicial** e se estiver em **consonância com os demais elementos de prova**²²², mas a prova pericial **não pode ser**

²²⁰Nesse sentido: REsp 1.686.161/SP, 3ª Turma, DJe 15/09/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²²¹Nesse sentido: REsp 1.824.208/BA, 3ª Turma, DJe 13/12/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²²²Nesse sentido: REsp 253.733/MG, 4ª Turma, DJ 05/04/2004, rel. Ministro Fernando Gonçalves.

substituída por mero relatório médico, especialmente se houver **divergência com os demais elementos de prova** ou quando **não forem especificados para quais atos há incapacidade**²²³.

Produzido o laudo e colhidas as demais provas, será proferida **sentença** (art. 754, CPC), que, se for pela **decretação da interdição**, também demandará: (i) a **nomeação do curador**, atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado; (ii) a fixação dos **limites da curatela**; (iii) a **observância das características pessoais** do interdito (potencialidades, habilidades, vontades e preferências); (iv) a **inscrição no registro de pessoas naturais e publicação de edital** na *internet*, no site do Tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma do CNJ, em que constará o nome do curatelado e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e os eventuais atos que poderão ser praticados com autonomia (art. 755, I e II, §1º a 3º, CPC).

Se cessada a causa que deu origem à interdição, admite-se o **levantamento da curatela**, total ou parcialmente, em pedido a ser realizado pelo próprio **curatelado**, pelo **curador** ou pelo **Ministério Público**, que será autuado em apenso ao processo de interdição e observará o mesmo procedimento dela (art. 756, *caput*, §1º a 4º, CPC). Já se decidiu que o **rol de legitimados para levantamento não é exaustivo**, conferindo-se legitimidade também aos **terceiros juridicamente interessados**, como, por exemplo, àquele que fora condenado a pensionar vitaliciamente o interdito em razão de acidente automobilístico do qual gerou a interdição²²⁴.

2.10. TUTELA E CURATELA

O tutor ou o curador será intimado a **prestar compromisso** em **5 dias**, contados da nomeação, da intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído, após o qual assumirá a administração dos bens do incapaz (art. 759, I e II, e §2º, CPC).

Poderá o tutor ou o curador **rejeitar o encargo**, no prazo de **5 dias** contados da **intimação para compromissar-se** (se antes de aceitar o encargo) ou do **motivo da escusa** (se posterior ao encargo), sob pena de **renúncia ao direito de escusar-se**. O juiz julgará o pedido e, rejeitando-o, o nomeado deverá exercer a tutela ou curatela até que haja eventual reforma da decisão com trânsito em julgado (art. 760, I e II, §1º e 2º, CPC).

Ademais, o tutor ou o curador pode ser **removido** a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Nesse caso, o tutor ou curador será citado para **contestar em 5 dias**, findo o qual o processo seguirá pelo procedimento comum (art. 761, *caput* e parágrafo único, CPC), podendo o juiz, de todo, suspender cautelarmente a tutoria ou a curadoria, nomeando substituto (art. 762, CPC).

Finalmente, a **exoneração do encargo** poderá ser requerida após o término do prazo para o qual fora nomeado (em regra, **2 anos**, art. 1765, CC), devendo requerer a exoneração no prazo de **10 dias contados da expiração do prazo**, sob pena de recondução (salvo se houver dispensa do juiz) (art. 763, *caput* e §1º, CPC). Cessada a tutela ou a curatela, deverá haver a **prestação de contas** pelo tutor ou curador (art. 763, §2º, CPC).

2.11. ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

Considerando os fins a que se propõe (éticos, religiosos, morais, culturais, de assistência, etc.), as **fundações** se revestem de notável interesse público, o que justifica a prévia deliberação do Ministério Público sobre o tema.

²²³ Nesse sentido: REsp 1.685.826/BA, 3ª Turma, DJe 26/09/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²²⁴ Nesse sentido: REsp 1.735.668/MT, 3ª Turma, DJe 14/12/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.



Desse modo, havendo conflito entre instituidor e o Ministério Público, caberá ao juiz deliberar, especialmente sobre os seguintes aspectos: (i) **aprovação**, se o interessado não concordar com a deliberação ou a exigência do Ministério Público por ocasião da aprovação ou de alteração do estatuto pelo *Parquet* (seja no sentido de negar a aprovação, de exigir modificações, de discordar do estatuto elaborado pelo próprio Ministério Público), caberá ao juiz decidir sobre o assunto, podendo, ele próprio, mandar fazer ajustes para adaptá-lo ao objetivo do instituidor (art. 764, I e II, e §2º, CPC); (ii) **extinção**, pois, além do Ministério Público, qualquer interessado pode promover em juízo um pedido de extinção da fundação quando seu objeto se tornar ilícito, quando impossível a sua manutenção ou quando vencido o prazo de sua existência (art. 765, I e III, CPC).

2.12. RATIFICAÇÃO DOS PROTESTOS MARÍTIMOS E DOS PROCESSOS TESTEMUNHÁVEIS FORMADOS A BORDO

No **diário de bordo** devem ser anotados **todas as ocorrências relevantes** relacionadas à viagem (avarias, incidentes, etc.). Havendo risco de danos a terceiros, o comandante lavrará um termo de ressalva de responsabilidade (chamado de protesto ou processo testemunhável a bordo).

O prazo para apresentação do protesto ou do processo testemunhável para posterior **ratificação judicial** é de **24 horas** contadas do atracamento no primeiro porto após a ocorrência, na forma do art. 766, CPC, salvo hipóteses excepcionais (como, por ex., quarentena decorrente de doença contagiosa). O **propósito da ratificação e homologação judicial** é prevenir responsabilidades, salvaguardar direitos, etc.

Em **petição inicial**, deverá o comandante narrar os fatos tal como lançados no diário e ser instruída com cópia deste, de documentos do comandante e das testemunhas, dos tripulantes, do registro da embarcação e, se o caso, da descrição das cargas sinistradas e a qualificação dos seus consignatários para citação (art. 767, CPC).

A medida deverá ser distribuída com urgência, devendo o juiz ouvir, **no mesmo dia**, o comandante e as testemunhas (entre 2 e 4), que comparecerão independentemente de intimação. Se estrangeiros, haverá tradutor levado pelo autor ou, ainda, nomeado pelo juiz (art. 768, *caput*, §1º e 2º, CPC).

Ato contínuo, será realizada audiência para a oitiva de todos os envolvidos (consignatários, comandante, interessados, testemunhas, etc.), finda a qual o juiz, convencido da veracidade do diário, **ratificará por sentença o protesto ou processo testemunhável**, entregando-o ao autor independentemente do trânsito em julgado, mas desde que se apresente cópia (arts 769 e 770, *caput* e parágrafo único, CPC).

QUESTÕES

1- Acerca das ações possessórias, é correto afirmar que:

- a) Nos litígios possessórios coletivos, a citação de todos os ocupantes será sempre pessoal, nomeando-se curador especial para aqueles que eventualmente não apresentem contestação tempestivamente.
- b) Se o réu da ação possessória pretender alegar que foi ofendido em sua posse, deve necessariamente ajuizar reconvenção em face do autor.
- c) É admissível a cumulação do pedido possessório com o pedido de indenização dos frutos.
- d) É inadmissível a concessão da liminar possessória sem a realização de audiência de justificação.

2- Sobre as ações de divisão e de demarcação de terras particulares, é incorreto afirmar que:

- a) É lícita a cumulação dessas ações, caso em que deverá ser processada em primeiro lugar a ação de divisão da coisa comum.
- b) Na hipótese de imóvel georreferenciado com averbação no respectivo registro de imóveis, é admissível a dispensa da prova pericial.
- c) A decisão de mérito que põe fim à primeira fase da ação de demarcação possui natureza de sentença e será impugnável por apelação com efeito suspensivo.
- d) A decisão de mérito que põe fim à segunda fase da ação de demarcação possui natureza de sentença e será impugnável por apelação sem efeito suspensivo.

3- Cabe ao inventariante:

- a) Representar o espólio ativa e passivamente em juízo, desde que autorizado pelo juiz.
- b) Alienar bens de qualquer espécie, independentemente de autorização judicial.
- c) Prestar as primeiras e as últimas declarações, sempre pessoalmente.
- d) Pagar dívidas do espólio, após a oitiva dos interessados e mediante autorização judicial.

4- Sobre a condenação em honorários de sucumbência nos embargos de terceiro, é correto afirmar que:

- a) É inadmissível a condenação em honorários sucumbenciais nos embargos de terceiro, pois se trata de incidente processual.
- b) Os honorários serão sempre fixados de acordo com o princípio da sucumbência.
- c) O embargado deverá ser sempre condenado em honorários, inclusive quando o embargante não atualizou seus dados cadastrais.
- d) O embargado deverá ser condenado em honorários quando, ciente da transmissão do bem, insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

5- Ajuizada ação monitória e sendo evidente o direito do autor, deve o juiz:

- a) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de urgência, concedendo-se ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu opor embargos em igual prazo.
- b) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de evidência, concedendo-se ao réu o prazo de 5 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu apresentar contestação em igual prazo.
- c) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de evidência, concedendo-se ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu opor embargos em igual prazo.
- d) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de urgência, concedendo-se ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu apresentar contestação em igual prazo.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C

Letra A (incorreta). Nos litígios possessórios, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais (art. 554, §1º, CPC).

Letra B (incorreta). Poderá o réu, nessa hipótese, deduzir a pretensão possessória na própria contestação (art. 556, CPC).

Letra C (correta). Nos termos do art. 555, II, CPC.

Letra D (incorreta). A audiência somente será designada se ausentes os requisitos legais para concessão da liminar sem a oitiva do réu (art. 562, caput, CPC).



2. Gabarito: A

Letra A (incorreta). Conquanto a cumulação seja lícita, diz o art. 570, CPC, que, nesse caso, a ação de demarcação da coisa comum deverá tramitar em primeiro lugar.

Letra B (correta). Na forma do art. 573, CPC.

Letra C (correta). Nos termos dos arts. 581, *caput*, e 1.012, *caput*, CPC.

Letra D (correta). Consoante arts. 587 e 1.012, §1º, I, CPC.

3. Gabarito: D

Letra A (incorreta). Nesse caso, dispensa-se a autorização judicial (art. 618, I, CPC).

Letra B (incorreta). Nesse caso, exige-se a autorização judicial (art. 619, I, CPC).

Letra C (incorreta). Nesse caso, admite-se a prestação das declarações por procurador com poderes especiais (art. 618, III, CPC).

Letra D (correta). Consoante art. 619, III, CPC.

4. Gabarito: D

Letra A (incorreta). A natureza jurídica dos embargos de terceiro é de ação de procedimento especial (art. 677, *caput*, CPC).

Letra B (incorreta). Os honorários serão regidos pelo princípio da causalidade e não da sucumbência (Súmula 303/STJ e Tese Repetitiva 872/STJ).

Letra C (incorreta). Na hipótese em que o embargante não atualizou seus dados cadastrais, a ele deve ser imposta a condenação em honorários advocatícios (Tese Repetitiva 872/STJ).

Letra D (correta). Nos termos da Tese Repetitiva 872/STJ.

5. Ajuizada ação monitória e sendo evidente o direito do autor, deve o juiz:

a) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de urgência, concedendo-se ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu opor embargos em igual prazo.

b) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de evidência, concedendo-se ao réu o prazo de 5 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu apresentar contestação em igual prazo.

c) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de evidência, concedendo-se ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu opor embargos em igual prazo.

d) Expedir mandado de pagamento, que possui natureza de tutela provisória de urgência, concedendo-se ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, facultado ao réu apresentar contestação em igual prazo.

5. Gabarito: C

Letra A (incorreta). A natureza jurídica da tutela é de evidência e os honorários são de 5% (art. 701, *caput*, CPC).

Letra B (incorreta). O prazo é de 15 dias e a manifestação do réu se dá por embargos (arts. 701, *caput*, e 702, *caput*, CPC).

Letra C (correta). Nos termos dos arts. 701, *caput*, e 702, *caput*, CPC.

Letra D (incorreta). A natureza jurídica da tutela é de evidência e a manifestação do réu se dá por embargos (art. 701, *caput*, CPC).

CAPÍTULO 16 — PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

1. TEORIA GERAL DOS RECURSOS

1.1. CONCEITO DE RECURSO

Na clássica lição de José Carlos Barbosa Moreira, “*pode-se conceituar recurso, no direito processual civil brasileiro, como o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna*”²²⁵.

Por se tratar de remédio marcado pela **voluntariedade** é que se afirma, majoritariamente, que a **remessa necessária** (art. 496, CPC) **não é recurso**, na medida em que, preenchidos os pressupostos e requisitos previstos em lei, o reexame da questão pelo Tribunal ocorrerá de modo automático e involuntário.

Por outro lado, dado que esse remédio pretende promover a correção do erro contido na decisão judicial no **mesmo processo**, afirma-se que o **mandado de segurança**, o **habeas corpus**, o **mandado de injunção**, o **habeas data** e a reclamação, dentre outros, não são recursos, mas, sim, **ações autônomas de impugnação**, uma vez que, nessas hipóteses, a eventual correção ocorrerá em **outro processo**.

Ademais, considerando que os recursos se orientam pelo princípio da **taxatividade**, segundo o qual somente será recurso aquilo que a lei disser textualmente que é, conclui-se que o **pedido de reconsideração de uma decisão judicial não é recurso**, pois essa medida não está prevista no rol do art. 994, CPC, e nem tampouco se encontra expressamente prevista em legislação extravagante.

São recorríveis os pronunciamentos jurisdicionais que possuam **conteúdo decisório**, a saber, as sentenças, as decisões interlocutórias, as decisões unipessoais e os acórdãos.

Embora os **despachos** sejam **irrecorríveis** (art. 1.001, CPC), já entendeu o STJ que “*independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes*”²²⁶.

Há hipóteses em que um **pronunciamento jurisdicional de conteúdo decisório será irrecorrível por força de lei** (por ex., art. 138, *caput*; art. 950, §3º; art. 1.007, §6º; art. 1.031, §§2º e 3º; e art. 1.035, *caput*, CPC) e, ainda, por **construção jurisprudencial** (por ex., a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos²²⁷).

Enquanto mecanismo apto a promover a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do pronunciamento jurisdicional, o recurso pretende corrigir **determinados vícios** de que padeceria a decisão judicial, a saber, o **error in iudicando** e o **error in procedendo**.

O **error in iudicando** (ou **erro de julgamento**) se verifica quando o alegado vício se relaciona com o **conteúdo substancial** da decisão (por ex., a decisão não valorou a prova corretamente ou a decisão é injusta), ao passo que o **error in procedendo** (ou **erro de procedimento**) se caracteriza quando o vício está relacionado ao desrespeito de normas procedimentais que tenham causado prejuízo às partes (por ex., a sentença não examinou uma questão relevante ou a perícia foi realizada sem a intimação dos assistentes técnicos).

²²⁵ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. 5 – Arts. 476 a 565. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 233.

²²⁶ Nesse sentido: REsp1.219.082/GO, 3ª Turma, DJe 10/04/2013, rel. Ministra Nancy Andriighi.

²²⁷ Nesse sentido: AgInt no AREsp411.892/RJ, 4ª Turma, DJe 20/10/2017, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

2. PRINCÍPIOS RECURSAIS

2.1. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Segundo o princípio do duplo grau de jurisdição, deve ser facultado às partes o **reexame, por um órgão hierarquicamente superior**, da decisão judicial proferida em seu desfavor.

Embora ainda se discuta, na doutrina, se seria o duplo grau de jurisdição um princípio de natureza constitucional ou não, fato é que o STF já decidiu, há quase duas décadas, que a CF/88 não contempla expressamente, no art. 5º, LV, o duplo grau como garantia de índole constitucional no Brasil, prevalecendo a CF até mesmo sobre o art. 8º, 2, h do Pacto de São José da Costa Rica, que garante o duplo grau apenas aos processos penais²²⁸.

Destaque-se que há, no sistema, hipóteses claras de **limitação da incidência do princípio do duplo grau de jurisdição**, por exemplo, nas causas de competência originárias do STF (art. 102, I, CF/88) e no cabimento de embargos infringentes em execuções fiscais de valor igual ou menor a 50 ORTNs, que serão julgados pelo mesmo juiz que proferir a sentença (art. 34 da Lei 6.830/80).

2.2. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE

Segundo o princípio da taxatividade, somente poderá ser considerado como recurso **aquilo que a lei federal expressamente disser que é**, não sendo admissível a criação, a modificação ou a extinção de recursos por outras modalidades normativas ou por convenção entre as partes.

Desse modo, outros meios de impugnação das decisões judiciais que não tenham sido indicados como tal pelo legislador (seja no CPC, art. 994; seja na legislação extravagante, como o art. 34 da Lei 6.830/80 acima mencionado) não poderão ser qualificados como recurso propriamente dito, mas, sim, como **outras espécies de impugnação** (como ações autônomas ou sucedâneos recursais).

2.3. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE, OU UNIRRECORRIBILIDADE

A partir do princípio da unicidade, é correto afirmar que **apenas se admite um recurso contra uma mesma decisão**, ou seja, há no sistema **apenas um recurso adequado para cada espécie de pronunciamento jurisdicional**.

Anote-se que o referido princípio pode ser objeto de **exceções** criadas pelo próprio sistema processual, como, por exemplo, na hipótese de cabimento de recursos especial e extraordinário contra o mesmo acórdão que possua fundamentação legal e constitucional, bem como na hipótese em que, sendo omissa a sentença quanto ao julgamento de um dos pedidos, faculta-se à parte opor embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC) ou interpor diretamente o recurso de apelação (art. 1.013, §3º, III, CPC).

2.4. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

De acordo com o princípio da fungibilidade, que deriva do princípio da instrumentalidade das formas, é admissível um determinado recurso, **ainda que entenda o órgão judiciário não ser ele o adequado** para impugnar aquela decisão judicial, quando houver **dúvida objetiva** acerca de qual é o recurso apropriado para a situação, o que **afasta a ocorrência de erro grosseiro** da parte.

²²⁸ Nesse sentido: RHC 79.785/RJ, Pleno, DJ 22/11/2002, rel. Ministro Sepúlveda Pertence.



A existência de dúvida objetiva (e, consequentemente, a inexistência de erro grosseiro) normalmente se caracteriza pela existência de **divergência doutrinária** acerca do recurso cabível que **não tenha sido pacificada pela jurisprudência**.

Nesse contexto, já decidiu o STJ que *“a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento”*, não se aplicando o princípio da fungibilidade por já ter sido estabelecida a interpretação a ser dada pela jurisprudência²²⁹.

Todavia, recentemente, o STJ entendeu por bem aplicar o princípio da fungibilidade em razão da divergência sobre o recurso cabível da decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas (art. 550, §5º, CPC), fixando a tese de que

se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação²³⁰.

2.5. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

A partir do princípio da *non reformatio in pejus*, pretende-se conferir segurança à parte recorrente de que não haverá a piora de sua situação por ocasião do julgamento de seu próprio recurso, podendo haver, em regra, tão somente a manutenção ou a melhora da situação do recorrente.

Anote-se que há, no sistema, ao menos uma hipótese em que o recorrente poderá ter a sua situação piorada em recurso exclusivamente por ele interposto, a saber, quando o Tribunal, ao desprover o recurso, majorar automaticamente os honorários fixados anteriormente em desfavor do recorrente e que deverão ser pagos ao advogado do vencedor (art. 85, §11, CPC).

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS

3.1. QUANTO À EXTENSÃO

No que se refere à extensão, o recurso pode ser classificado como **total**, em que há a impugnação de toda a decisão judicial (ou de todos os capítulos decisórios) ou **parcial**, em que o recorrente, voluntariamente, delimita o conteúdo impugnável e decide não impugnar todo o conteúdo que, em tese, seria suscetível de imediata irrisignação.

3.2. QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO

No que se refere à fundamentação, o recurso pode ser classificado como de **fundamentação livre**, caracterizado como aquele em que o recorrente poderá impugnar amplamente a decisão judicial, sem limitações quanto à causa de pedir recursal, inclusive no que tange ao profundo reexame da matéria fático-probatória. É o que ocorre, por exemplo, no recurso de apelação.

O recurso de **fundamentação vinculada**, por sua vez, é aquele que possui cabimento e feições previamente delineadas em lei, que condicionam a sua admissibilidade e o seu exame e exigem o perfeito enquadramento entre o vício alegado e o vício tipificado na norma. É o caso, por

²²⁹ Nesse sentido: REsp1.804.906/SP, 2ª Turma, DJe 30/05/2019, rel. Ministro Herman Benjamin.

²³⁰ Nesse sentido: REsp1.746.337/RS, 3ª Turma, DJe 12/04/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.



exemplo, do recurso especial (cujo fundamento deve ser extraído do art. 105, III, CF/88, como a contrariedade à lei federal) e do recurso de embargos de declaração (cujo fundamento deve ser extraído do art. 1.022, CPC, como a omissão judicial).

3.3. QUANTO À FORMA DE INTERPOSIÇÃO

No que se refere à forma de interposição, o recurso pode ser classificado como **autônomo** (ou de **interposição incondicionada**), situação em que não há nenhum óbice ao exercício do direito de recorrer pela parte e não há nenhuma relação entre o comportamento do recorrente e o do adotado pelo seu adversário.

O recurso **adesivo** (ou de **interposição subordinada**) é aquele que, em princípio, não seria sequer interposto pela parte que fora **parcialmente sucumbente** e que tenderia a se conformar com o resultado, mas que opta por interpor após ter ciência de que o seu adversário, também sucumbente em parte, impugnou a decisão judicial, estabelecendo-se, a partir desse momento, uma relação de vinculação subordinativa entre os recursos (principal e adesivo).

Para que a parte possa se valer do recurso na modalidade adesiva, é indispensável que tenha havido **sucumbência recíproca** (e, conseqüentemente, **interesse** em interpor o recurso apenas adesivamente), que haja **legitimidade** para recorrer (em regra, apenas das partes, art. 997, §1º, CPC²³¹), que seja observado o **prazo** (15 dias contados da intimação para responder ao recurso principal, art. 997, §2º, II, CPC) e as **modalidades recursais** em que se admite a interposição adesivamente (apelação, recurso especial e recurso extraordinário, art. 997, §2º, I, CPC, e recurso ordinário, arts. 1.027, II, “b” e 1.028, CPC) e, finalmente, que **não tenha havido recurso anterior** sobre a mesma matéria (ainda que inadmissível²³²).

O recurso interposto apenas na modalidade adesiva, justamente porque desprovido de autonomia, sempre terá o seu destino condicionado ao recurso principal, de modo que a **inadmissibilidade** ou **desistência** do recurso principal acarretará o **não conhecimento** do recurso adesivo (art. 997, §2º, I, CPC).

Finalmente, destaca a doutrina uma situação bastante peculiar e que excepciona a regra segundo a qual o **recurso adesivo será sempre da mesma espécie do recurso principal**, que é aquela em que o acórdão proferido em 2º grau, a despeito de dever enfrentar as questões constitucional e legal suscitadas pela parte, apenas decide com base em uma delas.

Nessa hipótese, a parte vencida poderá interpor um dos recursos cabíveis (especial ou extraordinário, conforme o caso), mas a parte vencedora, em princípio, não poderia interpor o recurso cabível para discutir a questão não examinada (na medida em que foi vencedora e não haveria interesse recursal), mas poderá sofrer prejuízo se porventura o recurso do vencido for provido (diante da impossibilidade de discussão da questão não decidida pelo acórdão).

Essencialmente para essa situação, defende-se na doutrina a possibilidade de interposição, pelo vencedor, de **recurso extraordinário ou especial cruzado**, cuja característica marcante será aderir ao recurso principal **distinto daquele que fora interposto pelo vencido** e que somente será examinado se porventura o recurso principal for provido.

²³¹Contra, por entender ser cabível o recurso na modalidade adesiva por terceiro, especialmente por aquele que poderia ter sido assistente litisconsorcial, mas não foi, diante de sua potencial sujeição à coisa julgada: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 183.

²³²Nesse sentido: REsp1.197.761/RJ, 2ª Turma, DJe 27/06/2012, rel. Ministro Mauro Campbell Marques.



4. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DE MÉRITO DOS RECURSOS

Interposto o recurso, será ele submetido a análise de **duas diferentes naturezas**: um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito.

A primeira análise concerne à admissibilidade, que sempre precederá ao mérito. Isso significa dizer que somente se adentrará ao mérito da pretensão recursal se superada a admissibilidade, isto é, se estiverem preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

4.1. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE

4.1.1. CABIMENTO

O exame do cabimento recursal está relacionado com a recorribilidade ou não daquela decisão judicial, isto é, se se trata de decisão efetivamente recorrível e, em caso positivo, se a impugnação é imediata ou diferida, especialmente diante do regime de preclusões instituído pelo CPC, e, ainda, sobre qual é o recurso adequado para impugnar aquela espécie de pronunciamento jurisdicional.

4.1.2. LEGITIMIDADE PARA RECORRER

A **legitimidade para recorrer** se materializa em um rol de pessoas indicadas pelo legislador como habilitadas a impugnar as decisões judiciais. Na legislação vigente, esse rol está circunscrito à **parte vencida**, ao **terceiro prejudicado** e ao **Ministério Público**, seja como parte, seja como fiscal da ordem jurídica (art. 996, *caput*, CPC).

No conceito de **parte vencida** devem ser incluídas tanto as partes originárias (indicadas pelo autor) como também aquelas que se tornaram partes, no curso do processo, por força de alguma espécie de intervenção de terceiro (por ex., assistente, litisdenunciado ou chamado – arts. 119 e seguintes, CPC). Não há óbice para que a lei restrinja a legitimidade recursal de alguma das partes posteriormente incorporadas ao processo, como é o caso do *amicus curiae*, que apenas está legitimado a opor embargos de declaração e a recorrer da decisão que julgar o IRDR (art. 138, §§1º e 3º, CPC).

Por sua vez, o conceito de **terceiro prejudicado** compreende àqueles que poderiam ou que deveriam ter participado do processo, como parte ou terceiro interveniente, mas não participaram, incluindo-se os litisconsortes necessários ou unitários (que são titulares ou co-titulares do direito discutido em juízo ou de direito com ele conexo).

No que se refere à legitimidade para recorrer do **Ministério Público**, é preciso esclarecer que a lei confere ao *Parquet* legitimação primária e autônoma, de modo que poderá ele recorrer independentemente do comportamento das partes, nos termos da Súmula 99/STJ²³³.

Finalmente, questão interessante se coloca quanto à legitimação para recorrer em busca apenas de **majoração de honorários advocatícios** fixados por ocasião da condenação. Questiona-se: A legitimidade recursal é da parte, do advogado ou de ambos? Quanto ao ponto, decidiu o STJ, ainda na vigência do CPC/73, que *“a verba relativa à sucumbência, a despeito de constituir direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade concorrente da parte para discuti-la, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94”*²³⁴.

²³³Súmula 99/STJ: “O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”.

²³⁴Nesse sentido: REsp828.300/SC, 1ª Turma, DJe 24/04/2008, rel. Ministro Luiz Fux.



4.1.3. INTERESSE PARA RECORRER

O interesse recursal está historicamente ligado ao conceito de **sucumbência formal**, isto é, à existência de derrota e de prejuízo à parte que é vencida no mérito do processo (pedido).

Fazendo-se um paralelo entre o interesse recursal e seu correspondente próximo, o interesse de agir, pode-se concluir que haverá interesse em impugnar uma decisão judicial quando houver **utilidade** (perspectiva de uma situação mais vantajosa que a atual) e **necessidade** (seja essa via a correta para obtenção dessa vantagem).

Nesse contexto é que se passou a reconhecer que, para além da sucumbência formal, o interesse de recorrer deve ser examinado sob a perspectiva da **sucumbência material**, isto é, o processo deve dar à parte, também no **mundo dos fatos**, tudo aquilo que poderia ela obter.

Como destaca José Carlos Barbosa Moreira, *“também se considera vencida a parte quando a decisão não lhe tenta proporcionado, pelo prisma prático, tudo que ela poderia esperar, pressuposta a existência do feito”*²³⁵, destacando-se, justamente, a hipótese de ação popular julgada improcedente em virtude de **insuficiência de prova** (e que não impedirá a repropositura, se fundada em prova nova) e a existência de interesse recursal do réu para a obtenção de sentença, igualmente de mérito, que se funde na **licitude da conduta** (caso em que se formará coisa julgada).

Além da hipótese de **coisa julgada secundum eventum probationis** que fora acima mencionada (e que também se verifica, por ex., no mandado de segurança e nas ações coletivas), destacam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que há interesse recursal para a modificação da fundamentação adotada na decisão judicial quando se busca a sanção de vícios justificadores dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC), em razão da possibilidade de formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial (art. 503, §1º, CPC) e para qualificar a fundamentação da *ratio decidendi* do precedente²³⁶.

4.2. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE

4.2.1. TEMPESTIVIDADE

O requisito de admissibilidade da tempestividade recursal significa dizer, em síntese, que o recurso deverá, obrigatoriamente, ser interposto dentro do prazo estabelecido em lei.

No que se refere aos prazos regidos pelo CPC, anote-se ter havido a **unificação dos prazos** recursais em **15 dias**, ressalvados expressamente os embargos de declaração (oponíveis em **5 dias**, art. 1.003, §5º, CPC) e os demais recursos submetidos à legislação extravagante que não tenham sido expressamente revogados pelo CPC, como o recurso ordinário em *habeas corpus* cível, que deverá ser interposto em **5 dias** (arts. 30 a 32 da Lei 8.038/90)²³⁷ e os recursos nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, que deverão ser interpostos em **10 dias**, salvo embargos de declaração, que serão opostos em 5 dias²³⁸.

É também preciso observar que o **Ministério Público**, os **entes públicos** e a **Defensoria Pública** possuem **prazo em dobro** (arts. 180, 183 e 186, CPC, respectivamente), assim como os **litisconsortes** com procuradores distintos de diferentes escritórios de advocacia, apenas se se tratar

²³⁵ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. 5 – Arts. 476 a 565. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 299.

²³⁶ DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 144/147.

²³⁷ Nesse sentido: RHC 109.330/MG, 3ª Turma, DJe 12/04/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²³⁸ Nesse sentido: REsp1.697.508/RS, 4ª Turma, DJe 04/06/2018, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.



de processo físico, não se aplicando a referida regra aos processos eletrônicos (art. 229, *caput* e §2º, CPC).

É importante destacar, ademais, que cessa a contagem do prazo recursal em dobro quando apenas um dos litisconsortes houver sucumbido²³⁹, bem como na hipótese de desfazimento do litisconsórcio pela interposição de recurso por apenas uma das partes sucumbentes²⁴⁰ ou, ainda, quando houver a exclusão do litisconsorte²⁴¹.

Anote-se que o prazo para interposição do recurso se iniciará com a intimação da decisão agravada (art. 1.003, *caput*, CPC, ressalvada a hipótese de a decisão ter sido proferida em face de parte não citada, caso em que, na forma do art. 1.003, §2º, CPC, o modo de contagem do prazo observará as regras do art. 231, I a VI, CPC).

O novo CPC, em seus arts. 218, §4º e 1.024, §5º, extinguiu a **figura do recurso intempestivo por prematuridade**, que era aquele interposto antes do início da fluência do prazo e que não era posteriormente ratificado pela parte, independentemente de ter havido ou não alteração no julgado em decorrência de embargos de declaração. Foi cancelada, então, a Súmula 418/STJ²⁴², substituída posteriormente pela Súmula 579/STJ²⁴³.

Finalmente, anote-se que a existência de feriado local (aquele que não é previsto em lei federal, mas somente em normativos estaduais ou regionais) que dilate o prazo de recurso dirigido ao STJ deverá, na forma do art. 1.003, §6º, CPC, ser obrigatoriamente comprovado no ato de interposição do respectivo referido, não havendo a possibilidade de juntada posterior de documento idôneo comprobatório²⁴⁴, ressalvada tão somente a hipótese do feriado de segunda-feira de carnaval, em que se admitiu a comprovação posterior nos recursos interpostos até o dia 18/11/2019²⁴⁵.

4.2.2. PREPARO

O requisito de admissibilidade do preparo consiste na obrigatoriedade de a parte recolher, quando cabível, o valor devido e previamente fixado para o exercício do direito de recorrer de uma decisão judicial, compreendendo as custas processuais (remuneração pelos serviços judiciários) e o porte de remessa e retorno dos autos.

Em regra, o preparo deverá ser integralmente recolhido no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, *caput*, CPC, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de **recolhimento complementar em 5 dias** na hipótese de **insuficiência** (isto é, quando houver recolhimento parcial, art. 1.007, §2º, CPC) e, ainda, a possibilidade de **recolhimento integral diferido** (na hipótese de ausência de recolhimento ou de ausência de comprovação do recolhimento, art. 1.007, §4º, CPC), também em **5 dias**²⁴⁶, mas, nesse caso, o valor recolhido deverá ser o **dobro** do valor estipulado para o recolhimento ordinário.

²³⁹Súmula 641/STF: “Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido”.

²⁴⁰Nesse sentido: AgRg no Ag 661.149/RS, 4ª Turma, DJe 21/10/2011, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

²⁴¹Nesse sentido: REsp155.964/RO, 2ª Turma, DJ 01/08/2000, rel. Ministro Francisco Peçanha Martins.

²⁴²Súmula 418/STJ: “É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”.

²⁴³Súmula 579/STJ: “Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior”.

²⁴⁴Nesse sentido: AgInt no AREsp957.821/MS, Corte Especial, DJe19/12/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁴⁵Nesse sentido: REsp1.813.684/SP, Corte Especial, DJe18/11/2019, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, com abrangência reduzida na QO no REsp 1.813.684/SP, Corte Especial, DJe 28/02/2020, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁴⁶Enunciado 97 do FPPC: “(art. 1.007, § 4º) Nos casos previstos no §4º do art. 1.007 do CPC, é de cinco dias o prazo para efetuar o preparo. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo; redação revista no IX FPPC-Recife)”.

Para todas as hipóteses acima mencionadas, a consequência jurídica do não recolhimento adequado do preparo recursal será a **deserção**, o que significa dizer que o recurso não será conhecido.

Pode ocorrer a dispensa do preparo **em razão da pessoa** (por ex., não recolhem preparo o Ministério Público, a União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, e respectivas autarquias, bem como quem goza de isenção legal e os beneficiários da gratuidade da justiça) ou em **razão da espécie recursal** (por ex., não há preparo no recurso de embargos de declaração – art. 1.023, *caput*, CPC– e no agravo em recurso especial ou extraordinário – art. 1.042, §2º, CPC).

4.2.3. REGULARIDADE FORMAL

O pressuposto da regularidade formal consiste na possibilidade de a lei estabelecer algum requisito específico para determinada espécie de recurso, cuja inobservância poderá acarretar a sua inadmissibilidade.

Enquadra-se nessa categoria, por exemplo, a **obrigatoriedade de juntada de peças no agravo de instrumento** quando se tratar de processo físico (art. 1.017, I, CPC), sendo que, nesse caso, o vício decorrente do descumprimento dessa regra poderá ser sanado pela parte (art. 1.017, §3º, CPC). Todavia, entendeu o STJ que o descumprimento da regra do art. 1.043, §4º, CPC, que exige a **juntada de cópia do acórdão paradigma** que justifica a interposição de embargos de divergência, não é vício sanável e a inobservância da referida regra de regularidade formal implica, de plano, na inadmissibilidade do recurso²⁴⁷.

4.3. COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em regra, caberá ao **órgão jurisdicional ad quem, ou seja, ao Tribunal, realizar o juízo de admissibilidade** do recurso, isto é, verificar se estão presentes os pressupostos anteriormente mencionados. Assim é, por exemplo, com o agravo de instrumento (que é interposto diretamente no Tribunal) e também com a apelação (que, embora seja interposta em 1º grau, não mais se submeterá a juízo de admissibilidade pelo juiz sentenciante, como ocorria no CPC/73).

É bem verdade que existe julgado do STJ no sentido de que *“embora, sob a égide do CPC/2015, a competência para o recebimento da apelação seja dos órgãos jurisdicionais de segundo grau, não se mostra razoável anular a decisão do magistrado de primeiro grau quando o recurso é manifestamente inadmissível”*²⁴⁸, mas fato é que a realização de juízo de admissibilidade por quem não possua autorização legal para tanto configura **usurpação de competência** suscetível de correção, inclusive, pela via da reclamação constitucional²⁴⁹.

Todavia, no que se refere aos recursos especial e extraordinário, há uma **bipartição do juízo de admissibilidade**, que é realizado, em primeiro lugar, pela Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido (2º grau, art. 1.030, V, CPC) e, após, poderá a admissibilidade ser novamente examinada pelo próprio Tribunal Superior, inclusive de modo unipessoal pelo relator (art. 932, III, CPC), de modo que não há vinculação do STJ ou do STF ao juízo realizado anteriormente pelo Tribunal Estadual ou Regional Federal que a exerceu **por delegação**.

4.4. JUÍZO DE MÉRITO

²⁴⁷ Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EREsp 1.455.459/SC, Corte Especial, DJe 09/12/2019, rel. Ministro Francisco Falcão.

²⁴⁸ Nesse sentido: AgInt no RMS 54.812/MG, 1ª Turma, DJe 15/02/2018, rel. Ministro Gurgel de Faria.

²⁴⁹ Nesse sentido: Rcl 35.958/CE, 2ª Seção, DJe 12/04/2019, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.



Se porventura houver juízo positivo de admissibilidade para o recurso, passa-se ao juízo de mérito, isto é, à verificação da efetiva ocorrência de *error in procedendo* ou de *error in iudicando* propriamente ditos.

Nesse ponto, é importante destacar que o **juízo de mérito do recurso não necessariamente coincidirá com o juízo de mérito da ação**. Por exemplo, em um agravo de instrumento em que se discuta o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC), o mérito do recurso consistirá em saber apenas se a pessoa faz ou não jus ao benefício, o que não se relaciona com o bem da vida que estiver em discussão (por ex., a reparação de danos morais e materiais). Porém, se o agravo de instrumento impugnar a decisão que julgou procedente um dos pedidos (decisão parcial de mérito, art. 1.015, II, CPC), o mérito do recurso coincidirá com o mérito da ação (a resolução da própria pretensão deduzida em juízo).

5. EFEITOS DOS RECURSOS

5.1. EFEITO SUSPENSIVO E EFEITO ATIVO

O efeito suspensivo dos recursos se relaciona com a possibilidade de da decisão judicial que se pretende impugnar **produzir efeitos imediatamente**. Em verdade, a suspensividade está na decisão e não propriamente no recurso, na medida em que é a decisão que nasce sem a aptidão para ser imediatamente executada.

Como regra, a **apelação possuirá efeito suspensivo**, pois a lei estabelece que a interposição desse recurso manterá a impossibilidade de produção de efeitos imediatos da sentença (efeito suspensivo *ope legis*, art. 1.012, *caput*, CPC). A própria lei, todavia, excepciona as hipóteses em que o recurso de apelação não possuirá efeito suspensivo (art. 1.012, §1º, I a VI, CPC).

Nos **demaís recursos, não haverá efeito suspensivo como regra** (art. 995, *caput*, CPC), de modo que todas as demais decisões judiciais, em princípio, produzirão efeitos imediatamente e poderão ser desde logo executadas. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de o relator conceder a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo “*se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso*” (efeito suspensivo *ope judicis*, art. 995, parágrafo único, CPC).

Não se deve confundir o efeito suspensivo com o **efeito ativo** (também denominado **efeito suspensivo-ativo** por parte da doutrina), que ocorre na hipótese em que a pretensão da parte não é de impedir a produção de efeitos, mas, sim, de uma providência essencialmente ativa (isto é, a parte quer uma decisão que produza efeitos imediatamente).

Por exemplo, quando a decisão interlocutória negar a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, não fará nenhum sentido pleitear, em agravo de instrumento, que seja concedido efeito suspensivo, pois a parte recorrente nada obteve na decisão recorrida. Nessa hipótese, o requerimento é de concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferida, pelo relator, a antecipação da tutela recursal, concedendo-se a providência de urgência que fora inicialmente negada em 1º grau.

5.2. EFEITO DEVOLUTIVO

A partir do efeito devolutivo, comum a todos os recursos, permite-se a devolução da matéria decidida a outro órgão jurisdicional de maior hierarquia ou, em algumas hipóteses, até mesmo ao próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão impugnada.



O ponto deve ser examinado sob **duas diferentes perspectivas**: a **devolutividade horizontal** (extensão) e a **vertical** (profundidade).

No que se refere à **extensão**, é correto afirmar que o efeito devolutivo é **definido pelo próprio recorrente**, que poderá optar, na hipótese de decisões objetivamente complexas, pela impugnação de um ou de todos os capítulos decisórios, aplicando-se a máxima latina do *tantum devolutum quantum appellatum*.

Isso significa dizer, por exemplo, que se o autor deduz, em cumulação simples, pedidos de reparação de dano moral e material, e a sentença julga improcedentes os dois pedidos, poderá ele, em apelação, devolver ao Tribunal apenas o dano moral, somente o dano material ou, ainda, ambos. Nessa hipótese, se devolvido apenas o dano moral, formar-se-á coisa julgada sobre o capítulo decidido e não impugnado (dano material).

Por outro lado, no que se refere à **profundidade**, é preciso observar que **a lei definirá quais questões ou fundamentos** poderão ser examinados pelo Tribunal por ocasião do julgamento daquela espécie recursal.

Nesse contexto, a **apelação** é o recurso que reconhecidamente possui, no sistema processual, a **maior devolutividade na perspectiva da profundidade**, pois nela poderão ser examinadas, na forma do art. 1.013, *caput*, §§1º e 2º, CPC, e com ampla liberdade de exame dos fatos e das provas, as questões decididas na origem e impugnadas pela parte dentro do capítulo impugnado, as questões suscitadas, mas que não foram decididas na origem, desde que relacionadas ao capítulo impugnado e, ainda, as questões de ordem pública, independentemente de suscitação ou de decisão, mas desde que relacionadas ao capítulo impugnado (esse exame, em particular, também decorre do denominado **efeito translativo** do recurso²⁵⁰).

Por outro lado, há recursos de **devolutividade mais restrita** no que se refere à profundidade, como o que ocorre nos embargos de declaração (em que somente são examináveis os vícios tipificados no art. 1.022, I a III, CPC) e nos recursos especial e extraordinário (em que somente são examináveis as questões de direito prequestionadas).

5.3. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO E OBJETIVO

Como a própria nomenclatura sugere, o efeito expansivo diz respeito a possibilidade de o órgão *ad quem*, por ocasião do julgamento do recurso, proferir decisão mais abrangente do que a matéria efetivamente impugnada pela parte.

Sob a ótica **subjettiva**, a decisão judicial a ser proferida no julgamento do recurso abrangerá **mais pessoas** do que somente aquela que impugnou a decisão, como na hipótese do art. 1.005, *caput*, CPC, segundo o qual “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”. No caso do **litisconsórcio unitário**, por exemplo, o provimento da apelação interposta por um aproveitará aos demais diante da necessidade de julgamento igualitário para todas as partes.

De igual modo ocorrerá na hipótese do art. 1.005, parágrafo único, CPC, que prevê que “havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”. Nesse caso, o **acolhimento da prescrição** suscitada por um dos devedores, por exemplo, poderá igualmente ser aproveitada pelo outro que se encontre nas mesmas condições.

²⁵⁰ NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.222.



Por outro lado, sob a perspectiva objetiva, a decisão judicial a ser proferida no julgamento do recurso abrangerá **mais decisões** do que apenas aquela impugnada pela parte. Se, por exemplo, houver o indeferimento de produção de prova pericial em decisão interlocutória que somente vem a ser impugnada, posteriormente, em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, CPC), o Tribunal, ao dar provimento ao recurso para reconhecer a necessidade de produzir a referida prova, não apenas anulará a sentença que fora proferida, como também todas as decisões eventualmente proferidas que lhe sejam antecedentes.

5.4. EFEITO IMPEDITIVO

O efeito impeditivo do recurso é aquele que obsta a ocorrência da preclusão ou da coisa julgada, prolongando o estado de litispendência até que o recurso seja definitivamente julgado.

5.5. EFEITO SUBSTITUTIVO

Diz-se que o recurso possui efeito substitutivo porque a decisão do Tribunal (monocrática ou colegiada) substitui, para todos os fins, a decisão proferida em 1º grau, ainda que o pronunciamento jurisdicional determine o retorno dos autos para nova decisão ou a anulação parcial ou total do processo. O mesmo raciocínio se aplica às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores em relação aos Tribunais de 2º grau.

5.6. EFEITO REGRESSIVO

O efeito regressivo do recurso é aquele que proporciona ao próprio juiz que proferiu a decisão recorrida a possibilidade de se retratar. Possuem efeito regressivo, por exemplo, a apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial (art. 331, CPC), contra sentença que resolve a controvérsia sem exame do mérito (art. 485, §7º, CPC) ou contra sentença que julga liminarmente improcedente o pedido (art. 332, §3º, CPC), bem como o agravo de instrumento (art. 1.018, §1º, CPC) e o agravo interno (art. 1.021, §2º, CPC).

6. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO RECURSO

A **desistência do recurso**, que somente poderá ocorrer **após a sua interposição**, é ato unilateral do recorrente (art. 200, CPC), que independe de anuência da parte adversa ou de litisconsortes e, inclusive, de deferimento ou homologação judicial (art. 998, *caput*, CPC), podendo ser formulada por escrito ou, até mesmo, oralmente, por ocasião da sustentação oral.

Embora a lei diga ser admissível a desistência a **qualquer tempo**, entende-se a jurisprudência do STJ que o limitador temporal para que ocorra a desistência válida do recurso é **até o fim do julgamento**, sendo irrelevante, nesse contexto, que o recurso já tenha sido incluído em pauta²⁵¹ ou que, iniciado o julgamento, tenha sido ele interrompido por pedido de vista de Ministro²⁵².

A despeito disso, verifica-se que esse **marco temporal tem sido flexibilizado** em determinadas hipóteses, pela lei ou pela jurisprudência, diante do caráter objetivo que possuem os recursos especial e extraordinário e da importância dos mecanismos de uniformização da jurisprudência e de formação de precedentes, criando-se impedimentos à desistência do recurso ou à sua utilização como formador de precedente.

²⁵¹ Nesse sentido: DESIS no REsp 882.690/SP, 3ª Turma, DJe 22/02/2010, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁵² Nesse sentido: QO nos EREsp 1.159.042/PR, Corte Especial DJe 20/02/2018, rel. Ministra Napoleão Nunes Maia Filho.



Por isso, ainda na vigência do CPC/73, decidiu-se ser **incabível a desistência de recurso especial após a sua submissão ao regime dos repetitivos**²⁵³, motivo pelo qual, procurando compatibilizar esse entendimento com o direito de desistir que assiste à parte, o novo CPC, em seu art. 998, parágrafo único, criou a regra segundo a qual *“a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”*, que se aplica, por interpretação extensiva, também ao incidente de assunção de competência, que igualmente compõe o microsistema de precedentes vinculantes²⁵⁴.

Além disso, colhe-se da jurisprudência do STJ entendimentos no sentido de que a desistência é inadmissível em **hipótese de má-fé**, quando o recorrente pretende impedir que seja fixada tese contrária aos seus interesses em julgamento que se encontre em estágio avançado²⁵⁵ e, ainda, quando a controvérsia envolver **interesse público**, não podendo a parte impor óbice à fixação de tese jurídica aplicável a outros processos sobre idêntica questão, ainda que o recurso não tenha sido submetido ao rito dos repetitivos²⁵⁶.

Por outro lado, a **renúncia ao recurso**, diferentemente da desistência, precede ao exercício do direito de recorrer, pois significa a manifestação da parte de que não interporá o recurso de que poderia se valer para impugnar a decisão judicial. De igual modo, a renúncia independe da aceitação da parte adversa (art. 999, CPC).

É interessante observar que, de acordo com a doutrina clássica, **a renúncia ao direito de recorrer somente poderia ocorrer quando esse direito pudesse ser efetivamente exercitável**, de modo que não seria admissível a renúncia a recurso que não pudesse ser interposto ao tempo da manifestação de vontade²⁵⁷.

Esse entendimento, todavia, merece nova reflexão diante da ampla possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais pelas partes (art. 190, CPC), inclusive o denominado **pacto de instância única**.

7. ORDEM DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS

7.1. INGRESSO DO PROCESSO OU RECURSO NO TRIBUNAL

O primeiro ato praticado por ocasião da entrada do processo ou do recurso no Tribunal é o seu **protocolo** (art. 929, *caput*, CPC), que conterà a data do protocolo da peça e que viabilizará não apenas a aferição de tempestividade da medida e a emissão de certidões, mas também mensurar dados históricos e estatísticos, auxiliando o Tribunal no desenvolvimento de políticas públicas de gestão processual.

Ato contínuo, haverá a **distribuição** (art. 930, *caput*, CPC), ato pelo qual o processo ou recurso é atribuído a um relator, de acordo com as regras delineadas no regimento interno do respectivo Tribunal, observando-se as regras de **alternatividade** (isto é, não pode um magistrado receber seguidamente processos), de **sorteio eletrônico** (que permite a atribuição de modo aleatório e sem violação ao princípio do juiz natural) e de **publicidade** (permitindo-se às partes a fiscalização da distribuição).

²⁵³ Nesse sentido: QO nos REsp 1.063.343/RS, Corte Especial, DJe 04/06/2009, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁵⁴ Enunciado 65 da I Jornada de Direito Processual do CJF: *“A desistência do recurso pela parte não impede a análise da questão objeto do incidente de assunção de competência”*.

²⁵⁵ Nesse sentido: QO nos EREsp 218.426/SP, Corte Especial, DJ 19/04/2004, rel. Ministro Vicente Leal.

²⁵⁶ Nesse sentido: QO no REsp 1.308.830/RS, 3ª Turma, DJe 19/06/2012, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁵⁷ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. 5 – Arts. 476 a 565. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 340.

Embora a distribuição deva, em regra, ocorrer livremente entre os julgadores que compõem órgãos fracionários com competência para a matéria versada no processo ou recurso (em observância ao **princípio do juiz natural**), o art. 930, parágrafo único, CPC, estabelece uma regra de **prevenção recursal**, segundo a qual *“o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”*.

A referida regra da **prevenção** prevê que o julgador que primeiro receber um recurso ou processo estará **prevento** para os demais recursos ou processos relacionados a mesma causa, ou seja, **os demais** processos, recursos ou incidentes relacionados ao **mesmo processo originário** (ou, ainda, a processo conexo) deverão necessariamente ser atribuídos ao mesmo relator (**distribuição por prevenção**).

Trata-se, pois, de uma exceção à regra geral de distribuição, justificável por motivos de **racionalidade** (o julgador que primeiro conheceu a matéria, em tese, já conhecerá melhor a causa por ocasião dos julgamentos subsequentes que dela sejam desdobramento) e de **segurança jurídica** (evita-se a prolatação de decisões potencialmente conflitantes).

Conquanto a figura da distribuição por prevenção fosse há muito tempo prevista nos regimentos internos dos Tribunais, fato é que o CPC disciplinou a matéria e, inclusive, inovou ao prever hipótese de **distribuição por prevenção para processos que são conexos na origem**, exigindo que o art. 930, parágrafo único, CPC, seja examinado sempre em conjunto com o art. 55, caput e §§, CPC²⁵⁸.

Anote-se que, no âmbito recursal, é irrelevante, para as subsequentes distribuições de recursos ou processos, que o primeiro recurso ou ação (aquele que deu origem à prevenção) já tenha sido definitivamente julgado. A conexão permanece, de modo que os demais incidentes deverão ser decididos pelo relator prevento.

7.2. PODERES DO RELATOR

A concessão de poderes ao relator, especialmente os decisórios, subverte a ordem do julgamento colegiado e, como tal, deve ser vista como uma medida **excepcional**.

Destaque-se que a ampliação dos poderes do relator no âmbito do processo civil se deu a partir das reformas de 1995 e de 1998 do CPC/73 que, acompanhando o movimento iniciado pela Lei 8.038/90, modificou a redação do art. 557, *caput* e §1º, do Código revogado, para que novos e maiores poderes fossem atribuídos ao relator, como forma de racionalização da prestação jurisdicional.

Atualmente, pode-se afirmar que o relator, nos termos do art. 932, CPC, possui poderes **diretivos, instrutórios e decisórios**.

7.2.1 PODERES DIRETIVOS

²⁵⁸ Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2º Aplica-se o disposto ncaput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolatação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.



Identificam-se os poderes diretivos do relator a partir do exame conjunto dos arts. 932, I e VI, e 139, CPC, cabendo-lhe, por exemplo, velar pela igualdade de tratamento das partes e pela razoável duração do processo, prevenir ou reprimir manobras processuais ou medidas meramente protelatórias, conceder ou dilatar prazos, determinar intimações, promover a autocomposição, etc.

7.2.2 PODERES INSTRUTÓRIOS

Embora não seja usual a realização de atividades instrutórias no Tribunal, não se pode olvidar que o art. 932, I, CPC, também confere ao relator o poder de determinar a realização das provas que porventura se revelem necessárias para o julgamento da causa, aplicáveis, com maior ênfase, nas causas de competência originária do Tribunal.

Todavia, mesmo no âmbito recursal, é admissível a produção de prova documental (art. 435, CPC), especialmente sobre fatos novos (arts. 342, I; 493 e 1.014, CPC), sem prejuízo da possibilidade de cognição de fato superveniente à decisão recorrida ou de questão de ordem pública não examinada (art. 933, *caput*, CPC).

7.2.3 PODERES DECISÓRIOS

A atividade decisória é aquela que, indiscutivelmente, demanda maior tempo e atenção do julgador nos Tribunais, especialmente diante da amplificação de seu poder para decidir, de modo unipessoal, não apenas as questões incidentes, mas também a admissibilidade e, por vezes, o próprio mérito do recurso ou da ação.

Nesse contexto, caberá ao relator, por exemplo, deliberar sobre pedido de **antecipação de tutela** originária ou recursal e sobre **pedido de gratuidade de justiça**, homologar **autocomposição** das partes (art. 932, I, CPC) e **não conhecer** de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão (art. 932, III, CPC, observada, se o caso, a regra que permite a sanção de vícios no âmbito dos recursos – art. 932, parágrafo único, CPC).

De igual modo, está compreendido no âmbito dos poderes do relator **desprover** recurso contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão do STF ou STJ sob o rito dos repetitivos e à tese firmada em IRDR e IAC (art. 932, IV, CPC), **dar provimento**, após o contraditório, se necessário, a recurso em face de decisão contrária à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão do STF ou STJ sob o rito dos repetitivos, à tese firmada em IRDR e IAC (art. 932, V, CPC) e, finalmente, decidir o mérito de **incidente de desconconsideração da personalidade jurídica** instaurado no Tribunal (art. 932, VI, CPC).

Finalmente, sublinhe-se que, na vigência do CPC/73, o relator poderia não conhecer, negar ou dar provimento também ao recurso que fosse contrário à **jurisprudência dominante** do STF, STJ ou do respectivo Tribunal (art. 557, *caput* e §1º-A, do Código revogado) e, na vigência dos referidos dispositivos legais, aprovou-se a Súmula 83/STJ²⁵⁹.

Observe-se, porém, que o art. 932, incisos, do novo CPC não mais confere (ao menos não textualmente) ao relator o poder de decidir o recurso, de modo unipessoal, com base em jurisprudência dominante, de modo que, em princípio, o julgamento nessa hipótese somente poderia ocorrer colegiadamente.

²⁵⁹Súmula 83/STJ: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

De todo modo, é importante destacar que o STJ aprovou em 16/03/2016 a Súmula 568 (publicada no DJe de 17/03/2016, um dia antes da entrada em vigor do novo CPC), que, em última análise, repristina o conteúdo do revogado art. 557, *caput* e §1º-A, do CPC/73²⁶⁰.

7.3. JULGAMENTO COLEGIADO

Admitindo-se não se tratar de hipótese de decisão unipessoal (art. 932, CPC), o julgamento do recurso ou da ação de competência originária deverá ocorrer de modo colegiado, especialmente ao fundamento de que haveria uma maior chance de acerto da decisão se proferida por julgadores reunidos.

Na forma do art. 941, §2º, CPC, a decisão colegiada será tomada, no julgamento da apelação e do agravo de instrumento, pelo **voto de 3 julgadores**²⁶¹. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, que no início não admitia sequer a participação de 1 juiz convocado por ocasião do julgamento no Tribunal²⁶², modificou-se radicalmente ao longo dos anos, de modo que, hoje, é **admissível até mesmo o julgamento por 3 juízes convocados**, desde que o órgão colegiado seja presidido por um Desembargador²⁶³.

Distribuídos os autos, feito o relatório e a minuta de voto pelo relator, será **pedido dia para julgamento e publicada a pauta** (art. 934, CPC) com, pelo menos, **5 dias de antecedência** à data designada (art. 935, *caput*, CPC). A pauta conterá os processos novos e os adiados de sessões anteriores em relação aos quais não tenha sido expressamente determinada a inclusão na 1ª sessão seguinte (art. 935, *caput*, CPC), facultando-se vista às partes após a publicação da pauta (art. 935, §1º, CPC).

Ressalvadas as preferências legais ou regimentais, a **ordem da pauta** deverá, na forma do art. 936, *caput* e incisos, CPC, ser a seguinte: (i) sustentações orais, em ordem de requerimento; (ii) preferências simples; (iii) prosseguimento de julgamentos anteriores (voto-vista e processos retirados, por ex.); (iv) demais processos (recursos em lista, por ex.).

7.4. SUSTENTAÇÃO ORAL

Na forma do art. 937, *caput*, CPC, após a leitura do relatório, será dada a palavra ao recorrente, ao recorrido e ao MP, quando o caso, para a **sustentação oral das razões recursais**, pelo prazo máximo de **15 minutos**.

A sustentação oral é **admissível**, conforme art. 937, incisos, CPC, no julgamento da apelação, do recurso ordinário, dos recursos especial e extraordinário, dos embargos de divergência, da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação, do agravo de instrumento que verse sobre tutelas provisórias e em outras hipóteses previstas em lei (art. 984, CPC) ou no regimento interno dos Tribunais (como, por exemplo, no agravo de instrumento que impugne decisão parcial de mérito²⁶⁴).

Nos termos do art. 937, §3º, CPC, **também será admissível a sustentação oral** em agravo interno interposto contra decisão unipessoal do relator que tenha extinguido alguma das ações de

²⁶⁰Súmula 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

²⁶¹No âmbito do STJ e do STF, o julgamento ordinariamente se dará em Turmas, que são constituídos por 05 Ministros (art. 2º, §4º, do RISTJ; art. 4º, *caput*, do RISTF).

²⁶²Nesse sentido: REsp 41.726/RS, 6ª Turma, DJ 03/11/1997, rel. Ministro Anselmo Santiago.

²⁶³Nesse sentido: HC 101.473/SP, 1ª Turma, DJe 08/06/2016, rel. Ministro Luis Roberto Barroso.

²⁶⁴Por exemplo, art. 187, I, do RITJBA e art. 226, §1º, do RITJPR. Vale dizer que a sustentação oral, nessa hipótese, é sustentada por parcela significativa da doutrina e se encontra consolidada no enunciado 61 da I Jornada de Direito Processual do CJF: “Deve ser franqueado às partes sustentar oralmente as suas razões, na forma e pelo prazo previsto no art. 937, *caput*, do CPC, no agravo de instrumento que impugne decisão de resolução parcial de mérito (art. 356, § 5º, do CPC)”.

competência originária mencionadas no art. 937, VI, CPC (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação).

Finalmente, anote-se que o requerimento de sustentação oral deverá ser formulado **até o início da sessão de julgamento**(art. 937, §2º, CPC), observada a ordem de requerimento e as preferências legais, admitindo-se, ademais, a realização de sustentações orais por **videoconferência** quando se tratar de **advogado com domicílio distinto** daquele em que sediado o Tribunal (art. 937, §4º, CPC).

7.5. VOTAÇÃO

Após a sustentação oral, terá início a votação com a leitura do voto pelo relator, seguido pela colheita de votos dos demais julgadores que comporem a turma ou câmara julgadora. É importante destacar que, no âmbito do STJ, o Ministro *“que não participou do início do julgamento, com sustentação oral, fica impossibilitado de participar posteriormente do julgamento”*²⁶⁵.

Proferido o voto pelo relator, poderá haver pedido de vista do julgador que não se considerar habilitado a proferir seu voto imediatamente, devendo devolver o processo em 10 dias, prorrogáveis por mais 10, sob pena de re-inclusão em pauta e substituição na hipótese de não aptidão (art. 940, *caput* e §1º e §2º, CPC).

Se, porventura, houver agravo de instrumento e apelação interpostos a partir do mesmo processo, o agravo de instrumento deverá ser julgado antes, inclusive se ambos estiverem na mesma pauta (art. 946, *caput* e parágrafo único, CPC).

Se houver a suscitação ou a necessidade de exame de **questões prévias** (que antecedem ou podem prejudicar o exame de mérito), gênero do qual são espécie as **questões preliminares** e as **questões prejudiciais**(por ex., vício na admissibilidade do recurso, vício procedimental, questão de ordem, possibilidade de conversão do julgamento em diligência ou de cassação da decisão), o exame dessas matérias deverá ocorrer antes do exame de mérito do recurso.

Isso porque tais matérias possuem um **caráter potencialmente prejudicial ao mérito**, o que, inclusive, justifica que sejam os votos de **cada questão prévia colhidos de modo separado** (isto é, cada julgador vota, separadamente, em cada questão prévia, computando-se a maioria em cada uma delas), de modo que somente se procederá ao exame da questão subsequente ou do próprio mérito se a questão antecedente for superada por maioria de votos (art. 938, *caput* e §1º a §4º, CPC).

Finalmente, na hipótese de a questão prévia ter sido superada, o voto do julgador que eventualmente **ficou vencido** nesse juízo inicial (isto é, na questão antecedente) **deverá ser computado** por ocasião do julgamento da questão principal, nos termos do art. 939, CPC.

7.6. AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO

A técnica de ampliação de colegiado (também denominada técnica de julgamento estendido) prevista no art. 942, CPC, foi criada pelo legislador em **substituição ao recurso de embargos infringentes** (art. 530 do CPC/73), embora com esse recurso não se confunda, seja porque se trata de uma técnica que se opera **automaticamente** (isto é, que independe de manifestação da parte), seja porque suas **hipóteses de incidência são distintas** das hipóteses de cabimento daquele recurso previsto na legislação revogada.

Por intermédio dessa técnica, o julgamento, em determinadas hipóteses, terá prosseguimento, na mesma sessão ou em sessão a ser designada futuramente, com a **presença de mais julgadores**, de modo que seja possível a **inversão do resultado** inicial.

²⁶⁵ Nesse sentido: QO nos EREsp 1.447.624/SP, Corte Especial, DJe 11/10/2018, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

São três as hipóteses em que a referida técnica incidirá: (i) quando o **resultado da apelação for não unânime**, ainda que não tenha havido a reforma do julgado²⁶⁶ e independentemente do conteúdo do julgamento em que houve a divergência²⁶⁷, inclusive na hipótese de dissenso na admissibilidade recursal²⁶⁸ (art. 942, *caput*, CPC); (ii) quando o **resultado da ação rescisória for não unânime, desde que o resultado seja a rescisão** (art. 942, §3º, I, CPC); e (iii) quando o **resultado do agravo contra decisão parcial de mérito for não unânime, desde que o resultado seja a reforma da decisão** que julgou parcialmente o mérito (art. 942, §3º, II, CPC).

Além de apontar as hipóteses de incidência da técnica de ampliação de colegiado, anote-se que o art. 942, §4º, CPC, também elenca as **hipóteses em que o julgamento estendido não ocorrerá**, a saber, a ampliação do colegiado não é admissível no julgamento de IAC e de IRDR, na remessa necessária e nos julgamentos não unânimes proferidos pelo Pleno e pela Corte Especial dos Tribunais.

Constatada a hipótese de incidência, o julgamento terá seguimento, na própria sessão ou em sessão futura (art. 942, §1º, CPC), com a convocação de julgadores de modo a possibilitar a inversão, devendo ser assegurada a **possibilidade de as partes sustentarem oralmente perante os novos julgadores** (art. 942, *caput*, CPC), admitindo-se, ademais, que por ocasião do prosseguimento do julgamento os **julgadores que já votaram possam rever ou alterar** seus votos (art. 942, §2º, CPC).

Finalmente, conquanto exista divergência doutrinária a respeito, sublinhe-se que há posicionamento do STJ no sentido de que se o **julgamento não unânime se restringir a um capítulo decisório**, a ampliação do colegiado não se limitará apenas a esse capítulo, mas, ao revés, **haverá a possibilidade de apreciação de toda a matéria** referente ao recurso pelos novos julgadores²⁶⁹, especialmente diante da possibilidade de os novos julgadores influenciarem aqueles que já haviam proferido voto e que, como visto anteriormente, não estão vinculados ao seu posicionamento inicial.

Isso significa dizer, pois, que se o julgamento de uma apelação versar sobre danos materiais e danos morais e houver divergência apenas quanto aos danos materiais, poderá o colegiado estendido se pronunciar sobre a matéria objeto do dissenso (danos materiais) e também sobre a matéria sobre qual, inicialmente, havia unanimidade (danos morais).

7.7. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO

Concluída a votação, o presidente proclamará o resultado, cabendo ao **relator redigir o acórdão**, salvo se ficar vencido, caso em que o relator será o autor do primeiro voto divergente-vencedor (art. 941, *caput*, CPC). **Até o momento da proclamação, admite-se a alteração do voto**, salvo se quem já votou houver sido afastado ou substituído (art. 941, §1º, CPC).

Considerando que é na fundamentação do voto que se pode obter as razões de decidir do julgado e que sustentam a sua conclusão (*ratio decidendi*), exige-se a juntada de todos os votos declarados (vencedores, vencidos, vogais, vistas, etc.), de modo que se possa interpretar adequadamente o precedente e, inclusive, melhor delimitar as questões decididas e viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores (art. 941, §3º, CPC), dando-se origem ao **acórdão** (que conterá relatório, ementa, voto e certidão de julgamento) que deverá ser publicado no prazo de até 30 dias contados da data da sessão de julgamento (art. 944, *caput*, primeira parte, CPC).

²⁶⁶ Nesse sentido: REsp 1.733.820/SC, 4ª Turma, DJe 10/12/2018, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

²⁶⁷ Nesse sentido: REsp 1.762.236/SP, 3ª Turma, DJe 15/03/2019, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

²⁶⁸ Nesse sentido: REsp 1.798.705/SC, 3ª Turma, DJe 28/10/2019, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

²⁶⁹ Nesse sentido: REsp 1.771.815/SP, 3ª Turma, DJe 21/11/2018, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



8. RECURSOS EM ESPÉCIE

8.1. APELAÇÃO

8.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É cabível o recurso de apelação em face da **sentença processual** (art. 485, CPC) ou **de mérito** (art. 487, CPC), ressalvadas as hipóteses em que a lei prevê recurso distinto contra as sentenças (por ex., nos Juizados Especiais, em que caberá recurso inominado – art. 41, *caput* da Lei nº 9.099/95 – ou nas execuções fiscais de valor igual ou menor a 50 ORTNs, em que caberão embargos infringentes – art. 34 da Lei 6.830/80).

É interessante observar que o art. 488, CPC, estabelece que *“desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”*. Trata-se da hipótese em que o juiz, por exemplo, em vez de proferir sentença processual de abandono de causa pelo autor (art. 485, III, CPC), estará autorizado a proferir sentença de improcedência se se convencer de que, no mérito, não assiste razão ao autor (art. 487, I, CPC). Trata-se de técnica que está em sintonia com o princípio da primazia da resolução do mérito e que reconhece que também o réu tem direito à coisa julgada material quando demandado.

Como ambas as sentenças beneficiarão o réu, mas apenas a última se revestirá de coisa julgada material, é correto afirmar que o réu possuirá interesse para recorrer da sentença e obter em seu favor uma sentença de mérito em substituição à sentença processual.

Por outro lado, é preciso esclarecer que **a apelação poderá não impugnar somente a sentença** (ou, ademais, **poderá não impugnar sequer a sentença**), mas, ao revés, poderá ser o **recurso cabível contra as decisões interlocutórias** proferidas ao longo do processo em 1º grau e que **não eram impugnáveis de imediato** pelo recurso de agravo de instrumento.

Nesse contexto, a primeira possibilidade é de **a apelação impugnar a sentença e também uma decisão interlocutória irrecorrível de imediato**, como na hipótese em que houve o indeferimento de prova pericial requerida pelo autor e prolação de sentença de improcedência no mérito. Nessa hipótese, o autor poderá impugnar, em sua apelação, preliminarmente, o indeferimento da prova que havia sido objeto de decisão interlocutória (art. 1.009, §1º, CPC) e, ainda, o próprio conteúdo da sentença.

Todavia, também existe a possibilidade de **a apelação impugnar somente a decisão interlocutória irrecorrível de imediato**. Imagine-se que tenha havido a imposição de multa por litigância de má-fé ao autor e prolação de sentença de procedência no mérito. Nessa hipótese, não haverá interesse em impugnar o conteúdo da sentença (pois de procedência), de modo que poderá o autor recorrer, por intermédio da apelação, apenas contra a decisão interlocutória que lhe impôs a multa por litigância de má-fé.

8.1.2. EFEITOS

A) EFEITO SUSPENSIVO

Como já assinalado anteriormente, em regra, **a apelação terá efeito suspensivo** (art. 1.012, *caput*, CPC). Entretanto, é preciso destacar que, em determinados casos, **a lei retira o efeito suspensivo** desse recurso, de modo a permitir que o apelado promova o cumprimento provisório da sentença logo após a sua publicação.

Além de outras hipóteses previstas em lei, **produzirá efeitos imediatamente a sentença** que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e decreta a interdição (art. 1.012, I a VI, CPC). Entende o legislador, pois, que, nessas hipóteses, há urgência que justifica não ser possível aguardar o julgamento da apelação.

Nas hipóteses em que a apelação **não for recebida com efeito suspensivo**, o apelante poderá requerer a atribuição desse efeito ao recurso *ope judicis*, ou seja, mediante requerimento, desde que demonstre ser **provável o provimento** da apelação (tutela da evidência em grau recursal) ou que demonstre, cumulativamente, que o recurso possui **fundamentação relevante** e que há **risco de dano** grave ou de difícil reparação (tutela de urgência em grau recursal), consoante se depreende do art. 1.012, §4º, CPC.

A **competência** para apreciação do pedido de efeito suspensivo será do Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou do relator, se já distribuída a apelação (art. 1.012, §3º, I e II, CPC).

B) EFEITO DEVOLUTIVO

Como dito anteriormente, o efeito devolutivo deve ser examinado sob duas diferentes perspectivas (a devolutividade **horizontal**, que é a extensão, e a devolutividade **vertical**, que é a profundidade).

Na perspectiva da **extensão**, caberá ao apelante definir, na hipótese de decisões objetivamente complexas, se impugna um ou todos os capítulos decisórios, aplicando-se a máxima latina do *tantum devolutum quantum appellatum*.

Por outro lado, constata-se que a apelação é o recurso que dispõe de **maior devolutividade** sob a ótica da **profundidade**, uma vez que abrange, com ampla liberdade de exame dos fatos e das provas, as questões decididas na origem e impugnadas pela parte dentro do capítulo impugnado, as questões suscitadas, mas que não foram decididas na origem, desde que relacionadas ao capítulo impugnado e, finalmente, as questões de ordem pública, independentemente de suscitação ou de decisão, mas desde que relacionadas ao capítulo impugnado (como corolário do denominado **efeito translativo**).

Isso significa dizer, em síntese, que definido pela parte o capítulo decisório a ser devolvido ao Tribunal (devolutividade na perspectiva da extensão), poderá o Tribunal, no julgamento da apelação, examinar quaisquer questões de fato e de direito relacionadas ao capítulo devolvido (devolutividade na perspectiva da profundidade), inclusive questões de ordem pública (pressupostos de admissibilidade da petição inicial e do próprio recurso) que sequer tenham sido objeto de arguição e debate pelas partes.

8.1.3 FORMA E PROCEDIMENTO

O recurso de apelação deverá ser **endereçado** ao juízo de 1º grau, perante o qual, inclusive, deverá ser **interposto**, observando-se, quanto à **forma**, a necessidade de nomeação e qualificação das partes, de exposição dos fatos e do direito, da apresentação das razões pelas quais se pretende reformar ou anular a sentença e, finalmente, o requerimento de nova decisão (art. 1.010, I a IV, CPC).

Anote-se que eventuais **vícios formais são suscetíveis de correção** em virtude da regra geral de sanabilidade prevista no art. 932, parágrafo único, CPC, como quando houver equívoco da parte

da denominação da peça (recurso inominado em vez de apelação), desde que tenham sido preenchidos todos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso adequado²⁷⁰.

Interposta a apelação em **15 dias**, será concedido **igual prazo** à parte adversa para responder ao referido recurso (art. 1.010, §1º, CPC), oportunidade em que poderá o recorrido, inclusive, interpor **apelação adesiva** se presentes os seus pressupostos, caso em que será o apelante originário intimado para responder à apelação adesiva (art. 1.012, §2º, CPC) **também em 15 dias**.

Anote-se que **esse mesmo procedimento** ocorrerá na hipótese de o apelado impugnar, em contrarrazões, decisão interlocutória que lhe fora desfavorável, que era irrecurável de imediato por agravo de instrumento e para a qual não havia interesse para interpor recurso de apelação autonomamente. É o caso, por exemplo, do indeferimento de prova pericial requerida pelo réu conjugado com posterior prolação de sentença de improcedência no mérito.

Nessa hipótese, interposta a apelação pelo autor, poderá o réu-apelado, em contrarrazões, suscitar o indeferimento da prova que havia sido objeto de anterior decisão interlocutória irrecurável imediatamente, de modo que, nesse caso, será concedido prazo para que o apelante se manifeste especificamente sobre a matéria (art. 1.009, §2º, CPC).

Ato contínuo, o processo será encaminhado ao Tribunal, em regra, independentemente de juízo de admissibilidade. Anote-se, todavia, que a **sentença processual** (que não resolve o mérito, art. 485, I a X, CPC) poderá ser objeto de **retratação** pelo juiz após a interposição da apelação (efeito **regressivo**, art. 485, §7º, CPC), de modo que, nesse caso, deverá ser examinado ao menos se a apelação interposta é **tempestiva** (pressuposto de admissibilidade) e se, portanto, viabiliza a **retratação**²⁷¹.

Em não se tratando de caso de retratação, ou não tendo sido ela realizada, o recurso será remetido ao Tribunal, sorteando-se relator que poderá julgá-lo monocraticamente, se presente alguma das hipóteses do art. 932, CPC, ou encaminhar o julgamento na forma colegiada.

8.1.4. TEORIA DA CAUSA MADURA

Finalmente, ao julgar apelação interposta contra sentença que contenha determinados vícios, poderá o Tribunal superar os defeitos de que padece a sentença e, então, passar ao julgamento do próprio mérito do respectivo pedido. Essa possibilidade, que decorre da denominada teoria da causa madura (art. 1.013, §§3º e 4º, CPC), pressupõe que o Tribunal reúna elementos fático-probatórios suficientes para proceder ao imediato julgamento do mérito do pedido que, incorretamente, não foi objeto de adequado exame em 1º grau de jurisdição.

A aplicação da teoria da causa madura deverá ocorrer quando o Tribunal reformar sentença processual (art. 485, CPC), quando decretar a nulidade da sentença por incongruência dela em relação ao pedido ou à causa de pedir, quando constatar a ausência de julgamento de um pedido na sentença, quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e, finalmente, quando reformar a sentença que decretou incorretamente a prescrição ou a decadência.

Em todas essas hipóteses, não será necessário cassar ou anular a sentença, determinando o retorno do processo ao 1º grau para a prolação de nova sentença se se constatar a possibilidade de imediato julgamento do mérito da controvérsia, isto é, se os elementos de fato e de prova colhidos até então forem suficientes para o enfrentamento do mérito pelo próprio Tribunal.

²⁷⁰Nesse sentido: REsp 1.822.640/SC, 3ª Turma, DJe 19/11/2019, rel. Ministra Nancy Andriahi.

²⁷¹Enunciado 293 do FPPC: "(arts. 331, 332, § 3º, 485, §7º, 1.010, § 3º) O juízo de retratação, quando permitido, somente poderá ser exercido se a apelação for tempestiva. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento; redação revista no VIII FPPC-Florianópolis; redação revista no IX FPPC-Recife)".

8.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO

8.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O agravo de instrumento é o meio adequado para impugnar as **decisões interlocutórias** proferidas em primeira instância, viabilizando o imediato reexame da questão pelo Tribunal de segundo grau. Será cabível, em princípio, quando o conteúdo da decisão se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.015, CPC.

8.2.2. HIPÓTESES DE CABIMENTO

O inciso I trata do agravo contra a decisão interlocutória que versa sobre **tutela provisória**, ou seja, que modifica, defere ou indefere, total ou parcialmente, tutela de urgência ou de evidência e que trata de medidas de apoio para a implementação da tutela (multa coercitiva, por ex.), dentre outras²⁷².

O inciso II, por sua vez, diz respeito à recorribilidade da decisão interlocutória que versa **mérito do processo**, compreendendo não apenas as decisões parciais de mérito (art. 356, CPC), mas também, por exemplo, as decisões sobre prescrição, decadência e demais hipóteses do art. 487, CPC, e sobre impossibilidade jurídica do pedido²⁷³.

Os incisos III e IV tratam, respectivamente, do cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre **rejeição da alegação de convenção de arbitragem** (isto é, aquela que mantém o processo sob a jurisdição estatal) e sobre o **incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – IDPJ** (tanto a que resolve o incidente, na forma do art. 136, CPC, quanto àquelas proferidas no curso do IDPJ e cujo conteúdo se amolde às demais hipóteses do art. 1.015, CPC, por exemplo, a que indefere um pedido de tutela provisória no âmbito do incidente).

Por outro lado, o inciso V trata do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre **rejeição do pedido de gratuidade da justiça** ou sobre o **acolhimento do pedido de sua revogação**, a fim de viabilizar o acesso à justiça de quem precisa do benefício; não cabe agravo de instrumento, todavia, da decisão que defere a gratuidade.

O inciso VI, por seu turno, trata da recorribilidade da decisão interlocutória que versa sobre **exibição ou posse de documento ou coisa**, contemplando a decisão que resolve o incidente de exibição contra a parte adversária, que resolve a ação incidental de exibição contra terceiro e, ainda, requerimento de expedição de ofício para exibição sem instauração de incidente ou ação²⁷⁴.

Os incisos VII e VIII preveem, respectivamente, o cabimento do agravo contra a decisão interlocutória que versa sobre **exclusão de litisconsorte** (não abrangendo, contudo, a decisão que rejeita excluir o litisconsorte que alega ser parte ilegítima²⁷⁵) e contra a decisão interlocutória que versa sobre **rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio**.

O inciso IX diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre **admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros** (assistência simples ou litisconsorcial, denúncia da lide, chamamento ao processo, IDPJ e *amicus curiae*, observado, em relação ao último, as restrições de recorribilidade consolidadas na jurisprudência²⁷⁶).

²⁷² Nesse sentido: REsp 1.752.049/PR, 3ª Turma, DJe15/03/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁷³ Nesse sentido: REsp1.695.936/MG, 2ª Turma, DJe 19/12/2017, rel. Ministro Herman Benjamin; REsp 1.778.237/RS, 4ª Turma, DJe 28/03/2019, rel. Min. Luis Felipe Salomão e REsp 1.738.756/MG, 3ª Turma, DJe 22/02/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁷⁴ Nesse sentido: REsp 1.798.939/SP, 3ª Turma, DJe21/11/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁷⁵ Nesse sentido: REsp1.724.453/SP, 3ª Turma, DJe 22/03/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁷⁶ Nesse sentido: QO no REsp1.696.396/MT, Corte Especial, DJe 19/12/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

O inciso X diz respeito ao cabimento do agravo contra a decisão interlocutória que versa sobre **concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução**, compreendida a decisão que concede ou que indefere o efeito suspensivo, reputado, pela lei, como tutela provisória (art. 919, §1º, CPC), de modo que o recurso seria cabível somente pelo inciso I²⁷⁷.

O inciso XI trata do cabimento do agravo contra a decisão interlocutória que versa sobre **redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º, CPC**, sendo recorrível a decisão que defere ou indefere a redistribuição dinâmica do ônus da prova ou qualquer outra hipótese de distribuição judicial do ônus da prova autorizada por lei, como a do art. 6º, VIII, CDC²⁷⁸.

O inciso XIII afirma que cabe agravo contra as decisões interlocutórias em **outros casos expressamente referidos em lei**, por exemplo, na decisão interlocutória que resolve a impugnação de crédito (art. 17, *caput*, da Lei 11.101/2005) e naquelas proferidas em ações populares (art. 19, §1º, da Lei 4.717/1965)²⁷⁹.

Finalmente, o art. 1.015, parágrafo único, CPC, diz respeito à recorribilidade de **todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário**, em razão de ser improvável a existência de apelação nesses procedimentos ou ações ou, ainda, da inutilidade de rediscussão da matéria apenas em apelação diante da irreversibilidade dos efeitos produzidos pela decisão interlocutória²⁸⁰. Pelos mesmos motivos, entende a jurisprudência do STJ que a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em **processos recuperacionais e de falência** igualmente é regida pela regra do art. 1.015, parágrafo único, CPC²⁸¹.

É também importante destacar que o STJ, em julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos (tema 988), estabeleceu ser cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória fora do rol do art. 1.015, CPC, quando *“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”*. Trata-se da tese da **taxatividade mitigada**, aplicável, por exemplo, na hipótese de decisão interlocutória que indefere a decretação de segredo de justiça²⁸².

8.2.3. EFEITOS, INSTRUÇÃO E FORMA

O agravo de instrumento é recurso **de fundamentação livre**, que possui **amplo efeito devolutivo** e que, **em regra, não possui efeito suspensivo** (ou seja, o processo na origem continuará em tramitação), ressalvada a possibilidade de atribuição desse efeito (ou de concessão da própria tutela recursal – efeito ativo) diretamente pelo relator no Tribunal, na forma do art. 1.019, I, CPC.

O modo de instruir o recurso de agravo de instrumento dependerá de o processo ser físico ou eletrônico.

Na hipótese de se tratar de **processo eletrônico**, a juntada, no agravo de instrumento, das peças elencadas no art. 1.017, I e II, CPC (cópias da **petição inicial**, da **contestação**, da **petição que deu origem à decisão agravada**, da **própria decisão agravada**, da **certidão da respectiva intimação** ou outro **documento oficial que comprove a tempestividade** e das **procurações** outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; da **declaração de inexistência** de qualquer dos documentos acima referidos, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal) será

²⁷⁷ Nesse sentido: REsp1.694.667/PR, 2ª Turma, DJe 18/12/2017, rel. Ministro Herman Benjamin e REsp1.745.358/SP, 3ª Turma, DJe 01/03/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁷⁸ Nesse sentido: REsp 1.729.110/CE, 3ª Turma, DJe 04/04/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi e REsp 1.802.025/RJ, 3ª Turma, DJe 20/09/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁷⁹ Nesse sentido: AgInt no REsp1.733.540/DF, 1ª Turma, DJe 04/12/2019, rel. Ministro Gurgel de Faria.

²⁸⁰ Nesse sentido: REsp1.803.925/SP, Corte Especial, DJe 06/08/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁸¹ Nesse sentido: REsp1.722.866/MT, 4ª Turma, DJe 19/10/2018, rel. Ministro Luis Felipe Salomão e REsp 1.786.524/SE, 3ª Turma, DJe 29/04/2019, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

²⁸² Nesse sentido: REsp1.696.396/MT, Corte Especial, DJe 19/12/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

sempre facultativa, assim como será opcional a juntada de outras peças que o agravante reputar úteis (art. 1.017, III, CPC).

Entretanto, caso se trate de **processo físico**, a juntada das peças mencionadas no art. 1.017, I, e da declaração mencionada no art. 1.017, II, CPC, será **sempre obrigatória**, mantendo-se, contudo, a facultatividade da juntada de outras peças que o agravante entender úteis (art. 1.017, III, CPC).

Quando se tratar de **processo físico na origem** e de **processo eletrônico no Tribunal**, bem como na hipótese inversa (processo eletrônico na origem e processo físico no Tribunal), a juntada das peças mencionadas no art. 1.017, I, CPC, e da declaração mencionada no art. 1.017, II, CPC, será **sempre obrigatória**²⁸³.

O **prazo** para interposição do agravo de instrumento é de **15 dias**, contados da intimação da decisão agravada (art. 1.003, *caput*, CPC), ressalvada a hipótese de a decisão agravada ter sido proferida em face de réu não citado, caso em que, na forma do art. 1.003, §2º, CPC, o modo de contagem do prazo observará as regras do art. 231, I a VI, CPC.

A petição do recurso de agravo de instrumento deverá conter os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço dos advogados de todas as partes, viabilizando as intimações no âmbito recursal.

Na hipótese de **processo físico**, o agravante **deverá** juntar, no processo de origem e no **prazo de 3 dias** contados da interposição do recurso, cópia da petição do agravo, o protocolo de sua interposição e a relação de documentos que o instruíram, de modo a permitir que o juiz de primeiro grau exerça seu juízo de retratação, sendo que a inobservância dessa regra acarretará no não conhecimento do agravo se arguida e comprovada pelo agravado, na forma do art. 1.018, §2º e §3º, CPC. É importante destacar que **essa causa de inadmissibilidade do recurso não se aplica quando se tratar de processo eletrônico**.

8.2.4. JULGAMENTO

Interposto o recurso, será designado um relator no Tribunal, que poderá, desde logo e antes mesmo da formação do contraditório em segundo grau, não conhecer do recurso ou lhe negar provimento quando presentes as hipóteses do art. 932, III e IV, CPC.

Não se tratando dessas hipóteses, o relator deverá examinar o pedido de efeito suspensivo ou ativo, se houver (art. 1.019, I, CPC), determinar a intimação do agravado para, se quiser, responder ao recurso no prazo de 15 dias (art. 1.019, II, CPC) e dar vista ao Ministério Público para manifestação, se o caso, também em 15 dias.

Ato contínuo, será designada sessão de julgamento do recurso, ocasião em que poderão as partes, inclusive, **sustentar oralmente** as suas razões no agravo de instrumento que versa sobre **tutela provisória** (art. 937, VIII, CPC), sustentando-se ser cabível a sustentação oral também no agravo de instrumento que impugne **decisão parcial de mérito** (enunciado 61 do CJF²⁸⁴).

Por ocasião do julgamento de agravo de instrumento que tenha impugnado decisão parcial de mérito (art. 356, CPC), poderá haver a incidência da técnica de ampliação de colegiado se, havendo divergência entre os desembargadores, formar-se maioria no sentido de reformar a decisão (art. 942, §3º, II, CPC).

²⁸³ Nesse sentido: REsp1.708.609/PR, 3ª Turma, DJe 24/08/2018, rel. Ministro Moura Ribeiro e REsp 1.749.958/RS, 3ª Turma, DJe 21/09/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁸⁴ Enunciado 61 da I Jornada de Direito Processual do CJF: “Deve ser franqueado às partes sustentar oralmente as suas razões, na forma e pelo prazo previsto no art. 937, *caput*, do CPC, no agravo de instrumento que impugne decisão de resolução parcial de mérito (art. 356, § 5º, do CPC)”.



Divergem a doutrina e a jurisprudência acerca do destino que deve ser dado ao agravo de instrumento anteriormente interposto e ainda pendente de julgamento quando **sobrevém sentença irrecorrida**.

Para Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, nessa hipótese, “o trânsito em julgado da sentença não apelada fica sob condição suspensiva, à espera da decisão a ser proferida no agravo de instrumento”²⁸⁵, havendo precedente do STJ nesse mesmo sentido²⁸⁶.

Por outro lado, leciona José Carlos Barbosa Moreira que “não deve o colegiado julgar o agravo sem antes certificar-se de que a apelação merece ser conhecida”, pois, caso contrário, “a sentença terá transitado em julgado, e o agravo perdido o objeto, tal como ocorreria se ninguém apelasse, nem estivesse a sentença, ex vi legis, sujeita a reexame obrigatório em segundo grau”²⁸⁷, havendo, de igual modo, precedente do STJ nesse sentido²⁸⁸.

Se, contudo, a hipótese versar sobre o destino que deve ser dado ao agravo de instrumento anteriormente interposto e ainda pendente de julgamento quando **sobrevém sentença que é objeto de apelação**, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que deverá ser examinado, sempre casuisticamente, se há, ou não, interesse e utilidade em se examinar o objeto do agravo de instrumento.

A esse respeito, já se decidiu no STJ, por exemplo, que a superveniência de sentença de mérito recorrida acarreta a **perda de objeto de agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória**, eis que o conteúdo da decisão interlocutória é absorvido pelo pronunciamento de mérito em cognição exauriente²⁸⁹, da mesma forma que já se entendeu, por exemplo, que **não há perda de objeto de agravos de instrumentos que versem sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus**, na medida em que se trata de antecedentes lógicos ao mérito da causa²⁹⁰.

8.3. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – ROC

O recurso ordinário constitucional se assemelha bastante ao recurso de apelação quanto à fundamentação e à devolutividade.

Todavia, se a apelação é o recurso cabível em face das sentenças proferidas em 1º grau de jurisdição, o **recurso ordinário, em regra, cabe de acórdãos proferidos em processos de competência originária** dos Tribunais Superiores (caso em que o recurso ordinário será julgado pelo STF, art. 102, II, “a”, CF/88, e art. 1.027, I, CPC) e dos Tribunais Estaduais ou Regionais Federais (caso em que o recurso ordinário será julgado pelo STJ, art. 105, II, “a” e “b”, CF/88, e art. 1.027, II, “a”, CPC).

O recurso ordinário será cabível apenas contra as **decisões denegatórias** proferidas em **mandado de segurança, habeas corpus, habeas data** ou **mandado de injunção**. Na hipótese das **decisões concessivas** proferidas nesses processos, será **cabível recurso extraordinário e/ou recurso especial**, conforme o caso. Trata-se de hipótese de recurso *secundum eventum litis*.

Finalmente, há uma **específica hipótese de cabimento de recurso ordinário contra sentença** proferida em 1º grau de jurisdição (art. 105, II, “c”, CF/88, e art. 1.027, II, “b”, CPC).

²⁸⁵DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 291.

²⁸⁶Nesse sentido: REsp182.562/RJ, 1ª Turma, DJ 01/07/1999, rel. Ministro Demócrito Reinaldo.

²⁸⁷BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 657.

²⁸⁸Nesse sentido: REsp1.750.079/SP, 3ª Turma, DJe 15/08/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁸⁹Nesse sentido: EAREsp 488.188/SP, Corte Especial, DJe 19/11/2015, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

²⁹⁰Nesse sentido: REsp 1.831.257/SC, 3ª Turma, DJe 22/11/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.



Nos processos que envolvam, de um lado, **Estado estrangeiro ou organismo internacional** e, de outro, **Município ou pessoa residente ou domiciliada no País**, a competência para julgamento será da **Justiça Federal** (art. 109, II, CF/88) e será **proferida sentença** em 1º grau, mas **não será cabível apelação**.

Nesse caso, caberá **recurso ordinário diretamente ao STJ** (recurso *per saltum*), com ampla devolutividade, possibilidade de incidência da teoria da causa madura e exame dos pressupostos de admissibilidade aplicáveis à apelação. Anote-se, ademais, que **caberá também ao STJ julgar os agravos de instrumento** interpostos a partir desse processo (art. 1.027, §1º, CPC).

Interposto o recurso ordinário em **15 dias** (salvo se se tratar de recurso ordinário em *habeas corpus* em matéria cível, cujo prazo será de 5 dias²⁹¹), o recorrido será intimado para **responder em igual prazo** (art. 1.028, §2º, CPC), findo o qual o recurso será remetido ao Tribunal Superior **independentemente de juízo de admissibilidade** (art. 1.028, §3º), sob pena de, se o fizer, estar configurada **usurpação de competência** suscetível de correção por reclamação constitucional²⁹².

Finalmente, discute-se, na doutrina, se o recurso ordinário constitucional possui **efeito suspensivo**. Para Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, a resposta é positiva, pois o recurso ordinário em tudo se assemelha à apelação, que o possui²⁹³. Para Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, todavia, a regra é que os recursos não possuirão efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, CPC), de modo que a exceção de que goza a apelação, que o possui, deve ser interpretada restritivamente²⁹⁴.

8.4. REMESSA NECESSÁRIA

A remessa necessária será tratada neste tópico, destinado aos recursos em espécie, tendo em vista a divergência existente acerca de sua **natureza jurídica**. Uma parcela da doutrina sustenta que a remessa necessária é um **recurso de ofício**²⁹⁵, outra corrente doutrinária afirma que se trata de um **sucedâneo recursal**²⁹⁶ e, finalmente, outro segmento da doutrina se posiciona no sentido de ser a remessa necessária uma **condição de eficácia da sentença**²⁹⁷.

Independentemente da natureza jurídica da remessa necessária, fato é que esse instituto prevê que a **sentença proferida em determinadas circunstâncias** somente produzirá efeitos após a sua confirmação pelo Tribunal.

Nesse sentido, registre-se que a remessa necessária será cabível quando for proferida **sentença de mérito** (ou, por simetria, **decisão parcial de mérito**). Em regra, **descabe remessa das sentenças processuais** (art. 485, CPC)²⁹⁸, ressalvada a hipótese da **ação popular**, em que também caberá remessa da sentença que decreta a **carência de ação** (art. 19 da Lei 4.717/65).

Por outro lado, para que haja remessa, a referida sentença ou decisão parcial de mérito deve ter sido **proferida contra a União, Estados, o DF, os Municípios e a suas autarquias e fundações de direito público** (excluindo-se, pois, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são

²⁹¹ Nesse sentido: RHC 109.330/MG, 3ª Turma, DJe 12/04/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

²⁹² Nesse sentido: Rcl 35.958/CE, 2ª Seção, DJe 12/04/2019, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

²⁹³ ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.651.

²⁹⁴ DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 350/351.

²⁹⁵ DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 473/477.

²⁹⁶ ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.025/1.031.

²⁹⁷ NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.269.

²⁹⁸ Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.868/CE, 2ª Turma, DJe 09/12/2013, rel. Ministro Herman Benjamin.

peças jurídicas de direito privado), salvo na hipótese de mandado de segurança, em que a remessa se aplica mesmo às pessoas jurídicas de direito privado (art. 14, §1º, da Lei 12.016/09).

A sentença ou decisão parcial de mérito proferida contra os entes acima mencionados pode ter sido proferida em **ações de procedimento comum** ou **especial** (por ex., ação popular, ação civil pública, ação de improbidade e mandado de segurança), em **embargos à execução não fiscal** (art. 496, §1º, CPC) e, ainda, quando julgados procedentes, total ou parcialmente, os **embargos à execução fiscal** (art. 496, II, CPC).

A remessa necessária será **dispensável**, contudo, quando a condenação ou o proveito econômico, **certo e líquido**, for inferior a 1.000 salários mínimos (União, respectivas autarquias e fundações, art. 496, §3º, I, CPC), a 500 salários mínimos (Estados, DF, respectivas autarquias e fundações e Municípios que sejam capitais de Estados, art. 496, §3º, II, CPC) e a 100 salários mínimos (Municípios, respectivas autarquias e fundações).

Se a decisão for **ilíquida**, deverá haver remessa, na forma da Súmula 490/STJ²⁹⁹, ressalvado recente posicionamento do STJ no sentido de que as **sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS não se sujeitam à remessa**, eis que, em regra, as condenações na esfera previdenciária não superarão o limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, §3º, I, CPC)³⁰⁰.

Ademais, a remessa necessária **também será dispensável**, na forma do art. 496, §4º, I a IV, CPC, quando a decisão condenatória estiver fundada em **súmula** de Tribunal Superior, em **tese** firmada pelo STF ou STJ em recursos repetitivos, em **tese** firmada em IAC ou IRDR ou em **orientação vinculante administrativa** do próprio ente público (manifestação, parecer ou súmula administrativa).

Sublinhe-se, por oportuno, que **se houver apelação** da Fazenda Pública, a **remessa é vedada** (art. 496, §1º, CPC), razão pela qual, nessa hipótese, será o recurso interposto que ditará as regras da insurgência da Fazenda Pública, sujeitando-se, inclusive, às causas de inadmissibilidade.

A **devolutividade** na remessa necessária é **amplíssima**, tanto na perspectiva da extensão, como também sob a ótica da profundidade, de modo que poderá o Tribunal conhecer de todos os pedidos e capítulos da decisão; de todas as questões suscitadas e decididas; de todas as questões suscitadas, mas não decididas; de todas as questões de ordem pública, ainda que não suscitadas; de todas as questões incidentais decididas em decisões interlocutórias não impugnáveis de imediato por agravo de instrumento e de honorários advocatícios (Súmula 325/STJ³⁰¹), podendo, ainda, aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §§3º e 4º, CPC).

Por se tratar de instrumento que visa à proteção da Fazenda Pública, aplica-se a regra da **non reformatio in pejus**, razão pela qual é **vedado ao Tribunal agravar a condenação** por ocasião do julgamento da remessa necessária (Súmula 45/STJ³⁰²).

É **admissível o julgamento monocrático** da remessa necessária (Súmula 253/STJ³⁰³), desde que presentes as hipóteses do art. 932, CPC.

Finalmente, é **inadmissível a incidência da técnica de ampliação de colegiado por expressa vedação legal** (art. 942, §4º, II, CPC), na esteira da vedação, existente na vigência do CPC/73, ao cabimento do recurso de embargos infringentes em remessa necessária (Súmula 390/STJ³⁰⁴).

²⁹⁹ Súmula 490/STJ: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentença ilíquidas”.

³⁰⁰ Nesse sentido: REsp 1.735.097/RS, 1ª Turma, DJe 11/10/2019, rel. Ministro Gurgel de Faria.

³⁰¹ Súmula 325/STJ: “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”.

³⁰² Súmula 45/STJ: “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública”.

³⁰³ Súmula 253/STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”. O art. 557 do CPC/73 corresponde, em grande parte, ao art. 932 do novo CPC.

³⁰⁴ Súmula 390/STJ: “Nas decisões por maioria, em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes”.



8.5. AGRAVO INTERNO

O agravo interno é o recurso cabível para impugnar uma **decisão monocrática** (também chamada de **decisão unipessoal**), que é aquela proferida por um desembargador ou ministro relator, nos moldes do art. 932, CPC, resolvendo uma questão incidente ou, até mesmo, o próprio recurso interposto (seja no sentido de não o conhecer, seja no sentido de lhe julgar o mérito). O propósito é que a **matéria seja examinada pelo colegiado** competente no Tribunal.

Além disso, também é cabível agravo interno na hipótese de decisão do Presidente ou Vice-Presidente do TJ ou TRF que inadmite ou que versa sobre o sobrestamento de um recurso especial ou extraordinário em determinadas hipóteses (por ex., art. 1.030, I e III, c/c §2º e art. 1.036, §3º, CPC).

O prazo para interposição do agravo interno é de **15 dias** e o recorrente, em petição dirigida ao relator, **sempre deverá impugnar especificadamente todos os fundamentos** da decisão agravada, sob pena de não ser ele conhecido, inexistindo, pois, nesse recurso, a figura da impugnação parcial da decisão³⁰⁵.

Após a interposição do agravo interno, haverá, necessariamente, a intimação da parte adversa para oferecimento de sua resposta e, se o relator não se retratar, o recurso será incluído em pauta e decidido pelo órgão fracionário competente.

No agravo interno, **em regra não haverá sustentação oral**, ressalvada a hipótese do art. 937, §3º, CPC, a saber, em agravo interno interposto contra decisão unipessoal do relator que tenha extinguido ação rescisória, mandado de segurança e reclamação.

Por ocasião do julgamento do agravo interno, **não poderá o colegiado**, em princípio, **somente se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão agravada** para desprovê-lo (art. 1.021, §3º, CPC), tratando-se de vedação à denominada fundamentação *per relationem*³⁰⁶. Essa regra não se aplica, contudo, quando a parte apenas insiste em tese que já fora afastada pela decisão monocrática, hipótese em que não há nulidade do acórdão que reproduz os mesmos fundamentos anteriormente expendidos³⁰⁷.

Finalmente, na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, CPC, o agravo interno **manifestamente inadmissível ou improcedente**, assim declarado em decisão fundamentada e unânime, resultará em condenação do agravante a pagar ao agravado uma multa de **1% a 5% sobre o valor atualizado da causa**, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da referida multa (exceção feita à Fazenda Pública e aos beneficiários de gratuidade).

8.6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O recurso de embargos de declaração objetiva a integração e correção da decisão judicial, tratando-se de contribuição das partes para que o pronunciamento jurisdicional seja completo e correto. Não se trata de recurso que objetive a reforma, anulação ou cassação da decisão judicial, embora possa, excepcionalmente, atingir esse resultado.

8.6.1. CABIMENTO

Na forma do art. 1.022, I a III, CPC, os embargos de declaração serão cabíveis quando **qualquer decisão judicial** – interlocutória, sentença, decisão unipessoal ou acórdão – for **contraditória** (dotada de uma **incoerência interna**, de modo que as suas premissas, conclusões ou

³⁰⁵ Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.454.212/ES, 1ª Seção, DJe 02/02/2018, rel. Ministro Gurgel de Faria.

³⁰⁶ Nesse sentido: REsp 1.622.386/MT, 3ª Turma, DJe 25/10/2016, rel. Ministra Nancy Andrighi.

³⁰⁷ Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP, Corte Especial, DJe 10/12/2019, rel. Ministra Laurita Vaz.



fundamentos são incompatíveis ou inconciliáveis entre si), **omissa** (quando **não enfrenta ponto, questão ou pedido** sobre o qual deveria se manifestar, de ofício ou a requerimento), **obscura** (quando não é inteligível ou quando dá margens a interpretações equívocas, dúbias ou inconclusivas), possuir **erro material** (incorreções evidentes de cálculo, de grafia, de expressões, etc.) ou **erro de fato** (desde que comprometa a inteligibilidade e o alcance do pronunciamento judicial³⁰⁸).

Anote-se que o CPC, em seu art. 1.022, parágrafo único, I e II, prevê hipóteses em que se **presume a omissão** da decisão judicial, a saber, quando desrespeitado o dever de fundamentação analítica (art. 489, §1º, CPC) ou quando a decisão não se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável à hipótese.

8.6.2. PRAZO, ADMISSIBILIDADE, CONTRADITÓRIO E PROCEDIMENTO

Os embargos de declaração deverão ser opostos em **5 dias** e **não há preparo recursal** (art. 1.023, *caput*, CPC). Desde que **tempestivos**, os embargos de declaração deverão ser **conhecidos**, pois a efetiva existência do vício é o mérito desse recurso que, ademais, **possui efeito interruptivo** (ou seja, a mera oposição de embargos tempestivos interrompe o prazo para os demais recursos cabíveis)³⁰⁹.

Opostos os embargos, haverá contraditório, permitindo-se que a **parte adversa responda** ao recurso, sempre que o seu **eventual acolhimento** resulte em **modificação** da decisão embargada (art. 1.023, §2º).

Após, os embargos serão julgados colegiadamente, se opostos em face de acórdão, ou monocraticamente, se opostos em face de decisão proferidas em 1º grau ou decisões unipessoais do relator nos Tribunais (art. 1.024, §2º), admitindo-se o **julgamento em mesa** (isto é, independentemente da inclusão em pauta – art. 1.024, §1º).

Caso se entenda que o recurso cabível em face da decisão unipessoal no Tribunal **era agravo interno** e não embargos de declaração, **o órgão julgador pode receber os aclaratórios como agravo interno**, permitindo-se, todavia, que a parte complemente as razões de seu recurso no prazo de **5 dias** (art. 1.024, §3º).

Finalmente, se uma das partes opuser embargos de declaração e a outra interpuser o recurso cabível por excelência contra aquela decisão judicial (por ex., agravo de instrumento, apelação, recurso especial, etc.), poderá ocorrer de os **aclaratórios serem acolhidos com modificação** (caso em que terá a parte que já havia interposto o recurso cabível o direito de complementar ou alterar as razões, nos limites da modificação, no prazo de 15 dias contados do julgamento dos embargos – art. 1.024, §4º) ou de os **aclaratórios serem rejeitados ou acolhidos sem modificação** (caso em que não haverá a necessidade de nenhuma providência da parte que havia interposto o recurso competente, sendo desnecessária, inclusive, a sua ratificação – art. 1.024, §5º).

8.6.3. PREQUESTIONAMENTO

Considerando que os recursos excepcionais, a saber, o especial e o extraordinário, pressupõem a existência de enfrentamento, pelo acórdão, da questão federal ou constitucional que se pretende ver reexaminada no respectivo recurso (de modo a configurar o chamado **prequestionamento**), é certo afirmar que os embargos de declaração possuem um relevante papel na futura admissibilidade dos recursos excepcionais.

³⁰⁸ Nesse sentido: EDcl no REsp 1.501.640/SP, 3ª Turma, DJe 13/12/2019, rel. Ministro Moura Ribeiro.

³⁰⁹ Nesse sentido: REsp 1.522.347/ES, Corte Especial, DJe 16/09/2015, rel. Ministro Raul Araújo.



Com efeito, a omissão judicial decorrente do não enfrentamento de uma determinada questão federal ou constitucional pelo Tribunal em 2º grau deverá ser objeto de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento do recurso excepcional em virtude da falta de prequestionamento. Dito de outro modo, o recurso de embargos de declaração é instrumento hábil a satisfação do requisito constitucional da **causa decidida** (arts. 102, III, e 105, III, CF/88).

Pode ocorrer, contudo, que a questão federal ou constitucional não seja examinada pelo Tribunal em 2º grau **mesmo após** a oposição de embargos de declaração pela parte.

Nessa hipótese, incidirá a regra do art. 1.025, CPC, segundo a qual *“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”*. Esse dispositivo, que materializa a possibilidade do denominado **prequestionamento ficto**, alinha-se ao teor da Súmula 356/STF³¹⁰ e supera o conteúdo da Súmula 211/STJ³¹¹.

Sublinhe-se, finalmente, que

a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei³¹².

Isso significa dizer, pois, que no recurso especial em que se pretenda discutir negativa de prestação jurisdicional, deverá a parte, obrigatoriamente, alegar violação de ambos os dispositivos legais – art. 1.022 e 1.025, CPC.

8.6.4. EFEITOS

Embora houvesse divergência doutrinária, na vigência do CPC/73, se os embargos de declaração possuíam, ou não, **efeito suspensivo**, fato é que o novo CPC estabelece, textualmente, que os aclaratórios **não possuirão efeito suspensivo ope legis** (art. 1.026, *caput*), podendo lhes ser atribuído esse efeito *ope judicis* (art. 1.026, §1º, CPC), se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Por outro lado, os embargos de declaração poderão possuir **efeito regressivo** (por se tratar de recurso que será julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão e que, em hipóteses excepcionais, poderá rever parcial ou totalmente o conteúdo decidido) e **efeito interruptivo** (o que significa dizer que há a interrupção, para qualquer das partes, do prazo do recurso que seria cabível subsequentemente com a mera oposição dos aclaratórios, desde que tempestivos (art. 1.026, *caput*, CPC).

Finalmente, anote-se que os embargos de declaração poderão, excepcionalmente, ter **efeito modificativo ou infringente**, de modo a alterar o conteúdo da decisão embargada. É a hipótese, por exemplo, da decisão judicial que possui uma **omissão relevante** (preliminar de prescrição suscitada pelo réu e não examinada em sentença de procedência) que, quando sanada, poderá implicar em **modificação do resultado do julgamento** (no exemplo, o acolhimento da preliminar de prescrição modificará o resultado para improcedência).

³¹⁰Súmula 356/STF: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

³¹¹Súmula 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.

³¹²Nesse sentido: REsp 1.639.314/MG, 3ª Turma, DJe 10/04/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

8.6.5. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MULTAS

É **admissível a reiteração** de embargos de declaração, desde que o segundo recurso esteja fundado na manutenção do vício que justificou a oposição do primeiro ou, ainda, esteja fundado em vício que tenha surgido somente por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios.

Por outro lado, a reiteração dos embargos de declaração poderá gerar a imposição de multa, a ser paga pelo embargante ao embargado quando configurado o **caráter manifestamente protelatório** do recurso.

A referida multa será **inicialmente de até 2%** sobre o valor atualizado da causa (isto é, para o primeiro recurso reputado como protelatório – art. 1.026, §2º, CPC) e **poderá ser elevada para até 10%** se, reiterados os embargos de declaração, forem também eles considerados protelatórios, **condicionando-se a interposição de qualquer recurso ao prévio depósito do valor da multa**, salvo se se tratar da Fazenda Pública e de beneficiário da gratuidade da justiça, que a recolherão ao final (art. 1.026, §3º). Anote-se, ademais, que serão **inadmissíveis** novos embargos de declaração se os dois primeiros forem reputados como protelatórios (art. 1.026, §4º).

É importante destacar, todavia, que a oposição de embargos de declaração com notório propósito de suprir as deficiências de fundamentação do acórdão recorrido e, portanto, de cumprir o requisito do prequestionamento, não podem ser considerados como protelatórios, nos termos da Súmula 98/STJ³¹³.

8.7. RECURSO ESPECIAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SEUS RESPECTIVOS AGRAVOS DENEGATÓRIOS

Os recursos excepcionais, gênero do qual são espécies o especial e o extraordinário, cumprem um papel bastante singular e relevante no sistema de impugnação das decisões judiciais, pois esses recursos, diferentemente dos demais de natureza ordinária, não se preocupam diretamente com a justiça da decisão impugnada.

Com efeito, os objetivos buscados pelo legislador com a criação dos recursos de natureza excepcional estão essencialmente relacionados com o interesse público de que a norma seja corretamente aplicada, com a tutela da isonomia decorrente da uniformização do entendimento acerca da interpretação do direito federal ou constitucional e, ainda, com a formação de precedentes que proporcionem segurança jurídica e previsibilidade às condutas dos jurisdicionados.

Por serem de **fundamentação vinculada** e de **devolutividade restrita**, os recursos excepcionais não se prestam ao reexame de todo e qualquer vício, nem tampouco são cabíveis em quaisquer hipóteses, mas, ao revés, somente serão admissíveis quando houver **questão essencialmente de direito** que se **encaixe fielmente** em alguma das hipóteses de cabimento previstas nos arts. 102, III, e 105, III, da CF/88³¹⁴.

³¹³Súmula 98/STJ: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

³¹⁴Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

8.7.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE COMUNS A AMBOS OS RECURSOS EXCEPCIONAIS

No juízo de admissibilidade, que será realizado primeiramente pelo Tribunal de origem e posteriormente pelo próprio Tribunal Superior, serão examinados, além de todos os pressupostos de admissibilidade estudados na teoria geral dos recursos, mais alguns requisitos específicos dos recursos excepcionais.

Nesse contexto, exige-se, em primeiro lugar, que o recurso verse sobre uma **questão de direito** (federal ou constitucional, conforme o caso) que tenha sido efetivamente decidida pelo acórdão recorrido, satisfazendo-se, dessa forma, o requisito do **prequestionamento**, que poderá ocorrer de modo **explícito** ou **numérico** (quando o acórdão recorrido relaciona o tema objeto da decisão ao dispositivo legal ou constitucional correspondente) ou **implícito** (quando o Tribunal, a despeito de não se referir diretamente ao dispositivo aplicável, efetivamente aborda o conteúdo normativo na resolução da questão).

De igual modo, também se exige que o recurso especial debata uma **questão essencialmente de direito**, isto é, que não demande o simples reexame de fatos e de provas, inviável por força das Súmulas 7/STJ³¹⁵ e 279/STF³¹⁶.

Embora seja difícil distinguir questões de fato e questões de direito, entende-se que os Tribunais Superiores não poderão examinar **se e como** os fatos ocorreram, mas poderão, de outro lado, **atribuir valor jurídico aos fatos incontroversos**, examinando-se, por exemplo, qual regra jurídica será aplicável ou qual o valor deve ser dado a certas provas em determinadas hipóteses que partam de um conjunto imutável de fatos (situações denominadas de **requalificação jurídica dos fatos** ou de **reavaliação das provas**)³¹⁷.

Finalmente, também se examina, previamente ao mérito dos recursos excepcionais, se houve o **exaurimento das vias ordinárias** mediante a interposição de todos os recursos ordinariamente cabíveis, na medida em que os recursos excepcionais somente poderão impugnar decisões tomadas em única ou em última instância (ou seja, é preciso que haja decisão final sobre o tema naquela instância, não se admitindo recurso *per saltum*).

8.7.2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL

A **repercussão geral** é um pressuposto de admissibilidade específico do recurso extraordinário dirigido ao STF e que se aplica, em razão de sua matriz constitucional (art. 102, §3º, CF/88), inclusive aos recursos extraordinários que versem sobre matéria penal.

Para que se possa considerar como presente o referido requisito, é preciso que a questão vertida no recurso extraordinário seja singularmente **relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico**, de modo a ultrapassar os interesses subjetivos do processo (art. 1.035,

III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

³¹⁵Súmula 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

³¹⁶Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

³¹⁷Nesse sentido: REsp 1.628.618/MA, 3ª Turma, DJe 04/04/2017, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



§1º, CPC). Isso significa dizer, pois, que se pretende, a partir do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, **fixar uma tese que não apenas dirá respeito às partes, mas, sim, atingirá toda a sociedade.**

Em razão desse caráter transcendente é que o legislador elencou, nos arts. 987, §1º, e 1.035, §3º, I e III, CPC, hipóteses em que a **repercussão geral será presumida** em virtude do conteúdo decisório ou da espécie de ação ou incidente em que se formou a decisão impugnada, de modo que recursos extraordinários que **contrariem súmula ou jurisprudência** dominante do STF, que **reconheçam a inconstitucionalidade** de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da CF/88, ou que **impugnem acórdão de mérito proferido em IRDR** possuirão repercussão geral.

Deverá a parte, nas **razões recursais**, explicitar os motivos pelos quais a questão constitucional vertida no recurso possui repercussão geral nos termos da lei, cabendo exclusivamente ao STF apreciar se a questão constitucional efetivamente possui, ou não, repercussão geral. Essa questão é exclusiva do STF, que somente poderá **recusá-la pela manifestação de dois terços** de seus membros (arts. 102, §3º, CF/88 e 1.035, §2º, CPC).

Por ocasião do exame acerca da existência de repercussão geral, poderá o relator sorteado no STF admitir a **manifestação de terceiros**, subscrita por procurador habilitado (art. 1.035, §4º, CPC). Trata o referido dispositivo legal, pois, da possibilidade de **intervenção de amicus curiae** ainda na fase de admissibilidade do recurso extraordinário.

Se porventura reconhecida a repercussão geral, o que, em regra, caberá ao Pleno do STF, reunido em seu Plenário Virtual, deveria haver, pela regra do art. 1.035, §5º, CPC, *“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”*. Já se decidiu, todavia, que a referida suspensão não é automática e não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, mas, ao revés, é **ato discricionário do relator**³¹⁸.

Caso seja determinado o sobrestamento dos processos, poderá o recorrido pleitear, ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem, que o recurso interposto em seu processo seja **excluído da suspensão** para ser **imediatamente inadmitido** na hipótese de **intempestividade** do recurso extraordinário interposto (art. 1.035, §6º, CPC). Nessa hipótese, o recorrente será instado a se manifestar em 5 dias e, da decisão que resolver esse requerimento, caberá agravo interno (art. 1.035, §7º, CPC).

Finalmente, anote-se que a decisão que não conhece do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral pelo STF é **irrecorrível**.

Se negada a existência de repercussão geral, o recurso extraordinário já interposto e que estava sobrestado deverá ter **negado seu seguimento**, salvo se contiver **capítulo autônomo constitucional distinto** daquele examinado pelo STF, caso em que apenas a eventual repercussão geral daquele capítulo poderá ser objeto de exame no STF (art. 1.035, §8º, CPC).

8.7.3. EFEITOS

Os recursos excepcionais **não possuem efeito suspensivo** *ope legis* (art. 995, *caput*, CPC), mas a eles poderá ser atribuído efeito suspensivo, *ope judicis*, mediante requerimento da parte interessada, se satisfeitos determinados requisitos (tutela provisória em grau recursal).

A **competência** para concessão do referido efeito é regida pelo art. 1.029, §5º, CPC, que estabelece que o pedido será apreciado pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, no período entre a interposição do recurso e a sua admissibilidade; pelo Tribunal Superior, entre a

³¹⁸ Nesse sentido: QO no RE 966.177/RS, Pleno, DJe 01/02/2019, rel. Ministro Luiz Fux.



admissibilidade do recurso e sua distribuição, ficando prevento o relator designado para seu exame; e pelo relator, se já distribuído o recurso.

A esse respeito, já se decidiu que, indeferida a tutela provisória na origem (art. 1.029, §5º, III, CPC), não se inaugura a competência do STJ para examinar semelhante pedido, salvo na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia³¹⁹.

Por outro lado, também já se decidiu que o pedido poderá ser formulado diretamente ao STJ, em desrespeito à regra de competência acima mencionada, em hipóteses excepcionais, a fim de resguardar direito da parte que tenha sido atingida por decisão manifestamente contrária à orientação jurisprudencial do STJ³²⁰.

Quanto aos **requisitos** para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, aplica-se a regra do art. 995, parágrafo único, CPC, de modo que *“se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”*, a produção de efeitos do acórdão recorrido poderá ser suspensa.

Por outro lado, conforme destacado anteriormente, os recursos excepcionais possuem **devolutividade bastante restrita**, especialmente na perspectiva da **profundidade**, tendo em vista se tratar de recurso de fundamentação vinculada, com específicas hipóteses de cabimento e com outros pressupostos adicionais de admissibilidade (por exemplo, repercussão geral e exigência de causa decidida sobre questão essencialmente de direito).

Nesse contexto, é interessante observar o conteúdo do art. 1.034, *caput* e parágrafo único, CPC, e da Súmula 456/STF³²¹, que, segundo parcela significativa da doutrina, **flexibilizariam a exigência de prequestionamento**³²².

Em verdade, considerando que o prequestionamento seria matéria relacionada especificamente à **admissibilidade**, de modo que, ultrapassado o juízo de admissibilidade, a cognição dos Tribunais Superiores seria ampliada para todo o capítulo decisório impugnado, estendendo-se o efeito devolutivo para questões que, conquanto suscitadas, não tenham sido decididas.

É o caso, por exemplo, de sentença proferida em ação de reparação de danos morais procedente ao fundamento de dolo, mas que também tinha causa de pedir culpa. Se o acórdão mantiver a sentença sob o mesmo fundamento, o recurso especial interposto para discutir inicialmente o dolo poderia, se admitido sob esse fundamento, discutir também a culpa.

Embora a **jurisprudência majoritária do STJ não se filie a esse entendimento**, há precedente no sentido de que

alegados pela parte recorrida, perante a instância ordinária, dois fundamentos autônomos e suficientes para embasar sua pretensão, e tendo-lhe sido o acórdão recorrido integralmente favorável mediante a análise de apenas um dele, não se há de cogitar da oposição de embargos de declaração pelo vitorioso apenas para prequestionar o fundamento não examinado, a fim de preparar recurso especial do qual não necessita (falta de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face de eventual recurso especial da parte adversária,

³¹⁹Nesse sentido: AgInt na TP 2203/PR, 1ª Turma, DJe 18/12/2019, rel. Ministra Regina Helena Costa.

³²⁰Nesse sentido: AgInt na TP 12.712/SP, 3ª Turma, DJe 27/09/2019, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

³²¹Súmula 456/STF: *“O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”*.

³²²NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.890/1.891; ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.665/1.669.



de modo que “reagitado o fundamento nas contrarrazões ao recurso especial do vencido, caso seja este conhecido e afastado o fundamento ao qual se apegara o tribunal de origem, cabe ao STJ, no julgamento do caso (...) enfrentar as demais teses de defesa suscitadas na origem”³²³.

8.7.4. PROCEDIMENTO

Do ponto de vista **procedimental**, sublinhe-se, em primeiro lugar, que os recursos excepcionais são interpostos perante os Tribunais locais, instalando-se o contraditório no próprio TJ ou TRF com a possibilidade de resposta aos recursos interpostos (art. 1.030, *caput*, CPC) e eventualmente, até mesmo, com a possibilidade de interposição de recurso especial ou extraordinário adesivo (art. 997, §2º, II, CPC).

Considerando que o primeiro juízo de admissibilidade ocorrerá também nos Tribunais locais, os recursos excepcionais possuirão diferentes caminhos, a depender do resultado desse juízo, se positivo ou se negativo.

A) RECURSO EXCEPCIONAL ADMITIDO

Admitido o recurso especial ou extraordinário neste primeiro juízo de admissibilidade (no TJ ou TRF), será autuado no STJ ou no STF e designado um relator, que, monocraticamente, poderá **não conhecê-lo, não provê-lo** ou, ainda, **provê-lo**, como autoriza o art. 932, III, IV e V, CPC. Em todas essas hipóteses, **da decisão unipessoal caberá agravo interno**. Se não estiverem presentes as circunstâncias que autorizam o julgamento monocrático, caberá ao relator encaminhar o recurso oportunamente para **julgamento colegiado**.

B) RECURSO EXCEPCIONAL INADMITIDO

O trajeto do recurso especial ou extraordinário será bastante diferente, entretanto, se o primeiro **juízo de admissibilidade for negativo**.

Nesse contexto, é preciso esclarecer que **há diferentes causas** de inadmissibilidade de um recurso excepcional, que pode **não ser conhecido**, ter seu **seguimento negado** ou, ainda, **não ser conhecido em parte** e **ter seguimento negado em parte**, por diferentes fundamentos.

Os Tribunais locais estão autorizados a inadmitir um recurso excepcional em **três hipóteses**: (i) quando o recurso extraordinário pretender discutir questão constitucional que o STF já disse **não haver repercussão geral** ou quando o acórdão recorrido estiver **conforme** entendimento do STF firmado em **regime de repercussão geral** (art. 1.030, I, “a”, CPC); (ii) quando o recurso especial ou extraordinário impugnar acórdão **conforme** entendimento do STF ou STJ firmado em julgamento no regime de **repetitivo** (art. 1.030, I, “b”, CPC); (iii) quando os **requisitos de admissibilidade**, gerais ou específicos, **não estiverem presentes** (tempestividade, cabimento, preparo, prequestionamento, legitimidade, interesse, exaurimento, etc.) e não for caso das hipóteses anteriores (art. 1.030, V, CPC).

A razão pela qual se permite a realização do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais pelos Tribunais locais decorre de uma **delegação de competência** dos Tribunais Superiores, que **não estão vinculados** ao juízo, positivo ou negativo, realizado na origem, podendo o STJ ou o STF admitir recurso que havia sido inadmitido na origem e vice-versa.

Em regra, **não é cabível o recurso de embargos de declaração contra a decisão que inadmite um recurso excepcional**. A justificativa para o descabimento dos aclaratórios é, em suma, de que “*não há necessidade de aperfeiçoar decisão cujos fundamentos em nada vinculam a instância*”

³²³ Nesse sentido: EREsp 595.742/SC, 2ª Seção, DJe 13/04/2012, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.



superior; decisão que não é passível de execução, sequer precária (o que é passível de execução é o acórdão recorrido); decisão que não resolve questão incidental no curso do processo”³²⁴.

Esse entendimento se mantém, inclusive, na vigência do novo CPC³²⁵, de modo que é correto afirmar que, em princípio, os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmite um recurso excepcional **não serão conhecidos** e, consequentemente, não ocorrerá o denominado **efeito interruptivo** (ou seja, não haverá a interrupção do prazo para os recursos subsequentes), o que gera, em última análise, a **ocorrência de preclusão ou de coisa julgada**, conforme o caso.

Todavia, os embargos de declaração serão **admissíveis** (e, consequentemente, **haverá interrupção do prazo**), em caráter **excepcional**, na hipótese em que decisão que inadmite o recurso excepcional for tão **genérica** que sequer permita a interposição do respectivo agravo denegatório³²⁶.

Assim, em síntese, é correto afirmar que o recurso cabível contra a decisão que inadmite um recurso excepcional poderá ser o **agravo interno** (especificamente nas hipóteses do art. 1.030, I, “a” e “b”, e III, c/c com §2º, CPC) ou o **agravo em recurso especial e em recurso extraordinário** (também denominado agravo denegatório), previsto no art. 1.042, CPC.

8.7.5. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (AGRAVO DENEGATÓRIO)

A **finalidade** do agravo previsto no art. 1.042, CPC, é destrancar o recurso especial ou extraordinário que fora inadmitido, levando-o, conjuntamente com o próprio agravo, ao STJ ou ao STF.

Trata-se de recurso cabível, como dito, contra a decisão do TJ ou TRF que inadmite o recurso especial ou extraordinário, salvo se a inadmissão se fundar em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, caso em que, sublinhe-se, caberá agravo interno a ser julgado pelo próprio Tribunal de origem.

No agravo denegatório, **somente devem ser impugnados os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial ou extraordinário**, não sendo apropriado o debate de questões distintas, especialmente aquelas vertidas no próprio recurso excepcional. Assim, se, por exemplo, a decisão de inadmissibilidade se funda nas Súmulas 7/STJ e 211/STJ, deve a parte apresentar, **apenas e precisamente**, as razões pelas quais a pretensão recursal não demanda o reexame de fatos e provas e a matéria está devidamente prequestionada.

Quando a decisão que inadmite o mesmo recurso excepcional se assentar em mais de um fundamento (por ex., Súmulas 7³²⁷ e 211/STJ³²⁸ e Súmula 284/STF³²⁹), **deverá a parte impugnar todos os fundamentos adotados** pelo Tribunal, sob pena de não conhecimento do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ³³⁰.

Anote-se que, segundo a jurisprudência do STJ, **não há a possibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissão**, ainda que os fundamentos adotados por ocasião do juízo de admissibilidade sejam **autônomos**.

³²⁴ Nesse sentido: AgRg no Ag 1.341.818/RS, 4ª Turma, DJe 31/10/2012, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

³²⁵ Nesse sentido: AgInt no MS 25.013/DF, Corte Especial, DJe 07/10/2019, rel. Ministra Nancy Andrihgi.

³²⁶ Nesse sentido: EAREsp 275.615/SP, Corte Especial, DJe 24/03/2014, rel. Ministro Ari Pargendler.

³²⁷ Súmula 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

³²⁸ Súmula 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.

³²⁹ Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

³³⁰ Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

É o caso, por exemplo, de um recurso especial em que se aponta violação ao art. 1.022, CPC (omissão) e ao art. 186, CC/2002 (ato ilícito e fato danoso), sendo inadmitido, no Tribunal de origem, por ambos os fundamentos. Nessa hipótese, **deverá a parte impugnar ambos os fundamentos**, ainda que, por exemplo, concorde com a decisão no que toca ao art. 1.022, CPC, pois *“a decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incidível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade...”*³³¹.

Interposto o agravo denegatório, que está **dispensado de preparo** (art. 1.042, §2º, CPC), em **15 dias**, será a parte adversa intimada para **respondê-lo em igual prazo** (art. 1.042, §3º, CPC), findo o qual, não havendo **retratação**, será o recurso remetido ao Tribunal Superior (art. 1.042, §4º, CPC).

Finalmente, na forma do art. 1.042, §5º, CPC, *“o agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo”*, divergindo a jurisprudência do STJ, contudo, acerca da interpretação que deve ser dada ao mencionado dispositivo legal.

De fato, há precedente no sentido de que **todo e qualquer agravo em recurso especial é suscetível de julgamento colegiado** e, assim, de sustentação oral³³², ao passo que há precedente no sentido de que **o dispositivo é inócuo no âmbito do STJ**, pois não há previsão regimental para julgamento conjunto de agravo em recurso especial e do próprio recursal, de modo que o agravo poderá não ser conhecido, conhecido para julgar o próprio recurso especial nas hipóteses do art. 932, CPC, ou reautuado como recurso especial, caso em que haverá a possibilidade de sustentação oral no próprio recurso³³³.

8.7.6. PROCEDIMENTO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS APÓS O INGRESSO NO TRIBUNAL SUPERIOR

Ao ingressar no Tribunal Superior, o recurso especial ou extraordinário será autuado e será designado um relator, que, monocraticamente, poderá **não conhecê-lo** (se inadmissível, prejudicado ou não tiver impugnado os fundamentos da decisão recorrida – art. 932, III, CPC – o que demonstra não haver vinculação entre o juízo de admissibilidade feito na origem e aquele que deverá ser realizado, uma vez mais, pelo Tribunal Superior), **não provê-lo** (se a decisão recorrida estiver de acordo com tese fixada em casos repetitivos ou em repercussão geral, com tese fixada em IAC ou com súmula do STF ou STJ – art. 932, IV, CPC) ou, ainda, **provê-lo** (se a decisão recorrida for contrária à tese fixada em casos repetitivos ou em repercussão geral, à tese fixada em IAC ou à súmula do STF ou STJ – art. 932, IV). Em todas essas hipóteses, **da decisão unipessoal caberá agravo interno**.

Se, contudo, não estiverem presentes as circunstâncias que autorizam o julgamento monocrático, caberá ao relator encaminhar o recurso oportunamente para **julgamento colegiado**, quando poderá, pelo órgão fracionário competente, não ser conhecido, não ser provido ou ser provido, no todo ou em parte.

Caso seja constatado que houve a interposição de **ambos os recursos excepcionais** (especial e extraordinário), o que poderá ocorrer, por exemplo, quando o acórdão recorrido se assentar em **fundamentos constitucional e infraconstitucional autônomos**³³⁴, o julgamento se iniciará, em regra,

³³¹ Nesse sentido: EAREsp 746.775/PR, Corte Especial, DJe 30/11/2018, rel. Ministro Luís Felipe Salomão.

³³² Nesse sentido: AREsp 851.938/RS, 1ª Turma, DJe 09/08/2016, rel. Ministro Gurgel de Faria. Vide também a Portaria Primeira Turma/STJ nº 01, que, em seu art. 10, estabelece que *“É permitida a sustentação oral em ARES, consoante o disposto no art. 1042, §5º do CPC/2015. (QO deliberada no âmbito do julgamento do AREsp 851938/RS em 16.06.2016)”*.

³³³ Nesse sentido: AgInt no AREsp 735.697/RJ, 3ª Turma, DJe 24/04/2018, rel. Ministra Nancy Andrighi.

³³⁴ A esse respeito, Súmula 126/STJ: *“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”*.



pelo recurso especial no STJ (art. 1.031, *caput*, CPC), findo o qual os autos serão remetidos ao STF para julgamento do recurso extraordinário, se este não houver sido prejudicado pelo julgamento realizado pelo STJ (art. 1.031, §1º, CPC).

Anote-se que a mesma regra se aplica na hipótese de **inadmissão de ambos** os recursos excepcionais, que **deverão ser impugnados por dois agravos denegatórios** (art. 1.042, §6º, CPC), cujo julgamento se **iniciará pelo STJ** (art. 1.042, §7º, CPC) e, somente após, haverá o julgamento pelo STF (art. 1.042, §8º, CPC).

Contudo, se o relator no STJ entender que existe **relação de prejudicialidade** do recurso extraordinário em relação ao recurso especial, deverá, em decisão irrecorrível, **sobrestar o julgamento** no STJ e remeter os autos ao STF (art. 1.031, §2º), cabendo ao STF deliberar, em definitivo, sobre a matéria, devolvendo os autos ao STJ, por meio de decisão irrecorrível, se entender **inexistente a referida prejudicialidade** (art. 1.031, §3º).

É importante destacar, ademais, que o STJ poderá identificar a existência de uma **questão constitucional trazida em um recurso especial** a ele submetido, bem como o STF poderá, igualmente, identificar a existência de **questão de direito federal no bojo de um recurso extraordinário**. Essa situação ocorre, inclusive, com bastante frequência, em decorrência da **sobreposição de temas** disciplinados tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação ordinária, por exemplo, direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito de herança, direitos autorais, etc.

Para essa hipótese, criou-se um **mecanismo de redirecionamento** dos recursos excepcionais, por meio do qual o relator do recurso especial no STJ, se entender que a hipótese é de **matéria constitucional**, deverá conceder prazo de **15 dias** para que o recorrente **adite o recurso** (para demonstrar a existência de repercussão geral e se manifestar sobre a questão constitucional), findo o qual, se cumprida a diligência, o recurso será remetido ao STF para julgamento como recurso extraordinário (art. 1.032, *caput*, CPC). Anote-se que, nessa hipótese, poderá o STF devolvê-lo, em caráter definitivo, para julgamento como recurso especial pelo STJ. (art. 1.032, parágrafo único, CPC).

De igual modo, se o STF entender que a hipótese é de **ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional**, insuscetível de exame no âmbito do recurso extraordinário por exigir também a interpretação de legislação infraconstitucional ou tratado, poderá remeter o recurso ao STJ para julgamento como recurso especial (art. 1.033, CPC).

8.8. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

O recurso de embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário objetiva a **uniformização interna** da jurisprudência do STJ e do STF, evitando-se que órgãos fracionários dos Tribunais Superiores possuam posicionamentos díspares sobre questões de direito material e de direito processual.

O recurso será **cabível**, nos termos do art. 1.043, I, CPC, na hipótese em que um acórdão de órgão fracionário (Turma ou Seção do STJ; Turma do STF, denominado **acórdão embargável**), em julgamento de recurso especial ou extraordinário, divergir do julgamento de qualquer **outro órgão** do mesmo Tribunal Superior (Turma, Seção ou Corte Especial do STJ; Turma ou Pleno do STF, denominado **acórdão paradigma**), sendo **ambos de mérito**.

Quanto ao ponto, é importante destacar que o órgão prolator do acórdão paradigma **ainda deverá ter competência** para apreciar a matéria ao tempo da interposição dos embargos de

divergência, sob pena de não conhecimento do recurso pela incidência da Súmula 158/STJ³³⁵. A aplicabilidade do referido enunciado sumular não foi afetada pelo novo CPC³³⁶.

Por outro lado, o recurso também será **cabível**, na forma do art. 1.043, III, CPC, na hipótese em que um acórdão de órgão fracionário (Turma ou Seção do STJ; Turma do STF, denominado **acórdão embargável**), em julgamento de recurso especial ou extraordinário, divergir do julgamento de qualquer **outro órgão** do mesmo Tribunal Superior (Turma, Seção ou Corte Especial do STJ; Turma ou Pleno do STF, denominado **acórdão paradigma**), sendo **um dos acórdãos de mérito** e o outro de **não conhecimento do recurso**, embora tenha sido apreciada a controvérsia.

Essa hipótese de cabimento se justifica, especialmente, diante da existência de acórdãos dos Tribunais Superiores que, conquanto, no dispositivo, afirmem que o recurso **não é conhecido** (ou seja, não houve exame de mérito), pois efetivamente **examinaram a controvérsia** na fundamentação (de modo que, em verdade, são acórdãos de mérito).

Finalmente, o recurso igualmente será **cabível**, na forma do art. 1.043, §3º, CPC, na hipótese em que um acórdão de órgão fracionário (Turma do STJ; Turma do STF, denominado **acórdão embargável**), em julgamento de recurso especial ou extraordinário, divergir do julgamento do **mesmo órgão fracionário** do mesmo Tribunal Superior (Turma do STJ; Turma do STF, denominado **acórdão paradigma**), especificamente quando houver a **alteração de mais da metade dos membros** desta Turma julgadora.

Conquanto se afirme, no art. 1.043, §1º, CPC, que, nos embargos de divergência, poderão ser confrontadas teses contidas em julgamentos de recursos e também de ações de competência originária, já se decidiu que, mesmo na vigência do novo CPC, não podem *“funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção”*, aplicando-se o mesmo raciocínio *“ao paradigma oriundo de medida cautelar, cujos pressupostos e requisitos são totalmente distintos do recurso especial, sendo, pois, imprestável para a realização do cotejo analítico indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência”*³³⁷.

É importante destacar, ainda, que o cabimento do recurso de embargos de divergência pressupõe que o **dissenso entre os órgãos julgadores seja atual**, de modo que, se já houve a pacificação da jurisprudência anteriormente, descabe o referido recurso por força da Súmula 168/STJ³³⁸.

Deverá o recorrente, por ocasião da interposição do referido recurso, provar a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica em que foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte (art. 1.043, §4º, CPC). A inobservância dessa regra, entende o STJ, é **vício insanável** e **acarreta o não conhecimento** dos embargos de divergência, sem possibilidade de aplicação do art. 932, parágrafo único, CPC³³⁹.

Ademais, considerando que o recurso de embargos de divergência se preocupa com **questões idênticas ou muito semelhantes tratadas de maneira díspar por seus órgãos fracionários internos**, deverá o recorrente, nas razões recursais, mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados (art. 1.043, §4º, CPC). Trata-se do denominado **cotejo analítico** entre o acórdão embargável e o acórdão paradigma.

³³⁵ Súmula 158/STJ: “Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acórdão de Turma ou Seção que não mais tenha competência para a matéria neles versada”.

³³⁶ Nesse sentido: EREsp 1.394.902/MA, Corte Especial, DJe01/07/2019, rel. Ministra Laurita Vaz.

³³⁷ Nesse sentido: AgInt no EAREsp 1.186.570/RS, Corte Especial, DJe17/12/2019, rel. Ministra Laurita Vaz.

³³⁸ Súmula 168/STJ: “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”.

³³⁹ Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EREsp 1.455.459/SC, Corte Especial, DJe09/12/2019, rel. Ministro Francisco Falcão.

Justamente por tratar apenas de **questões idênticas** ou de **semelhança muito acentuada**, já se decidiu o não cabimento de embargos de divergência para discutir o valor de danos morais³⁴⁰ ou para a quantificação de honorários advocatícios³⁴¹.

Finalmente, anote-se que, tal qual ocorre com os embargos de declaração, a interposição de embargos de divergência **interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes** (art. 1.044, §1º, CPC), sendo inclusive **desnecessário reiterar** o recurso extraordinário que eventualmente já tenha sido interposto quando os embargos de divergência não forem providos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior (art. 1.044, §2º, CPC).

A esse respeito, sublinhe-se que já se decidiu que

a interposição simultânea de recurso extraordinário e de embargos de divergência, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso, em virtude não somente do princípio da unirrecorribilidade, o qual preceitua que, para cada decisão será interposto apenas um recurso, mas também em consequência da preclusão consumativa³⁴².

9. PRECEDENTES

9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É inegável que o novo CPC pretende promover a valorização dos julgamentos proferidos pelos Tribunais, atribuindo-lhes, em determinadas circunstâncias, um caráter de **vinculatividade** que exige que sejam respeitados pelo próprio Tribunal que os proferiu e, ainda, pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

De início, esclareça-se que os julgamentos proferidos no âmbito dos Tribunais sempre serviram, em certa medida, como orientação aos órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores. É correto afirmar que a **jurisprudência**, enquanto conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido, e a **súmula**, enquanto enunciado que consolida a jurisprudência do Tribunal, embora **persuasivas**, sempre foram objeto de exame e de consideração dos julgadores das instâncias hierarquicamente inferiores, ainda que fosse para delas discordar ou para traçar, em relação a esses entendimentos, hipóteses de distinção ou de superação.

Conquanto a divergência de teses jurídicas seja salutar ao amplo debate, à necessária maturação e, finalmente, à tomada da melhor decisão, fato é que, em algum momento, o entendimento do Tribunal acerca daquela questão deverá se **consolidar**, tornando-se um posicionamento **estável, íntegro e coerente**, não apenas no âmbito do próprio Tribunal, mas também para irradiar efeitos para todos os demais órgãos do Poder Judiciário, especialmente em uma sociedade marcada pela litigiosidade repetitiva e massificada, na qual é inadmissível que jurisdicionados colocados em **situações idênticas** possam receber **soluções jurídicas distintas**.

É por esse motivo que o art. 927, incisos, CPC, prevê que os juízes e os tribunais observarão: (i) as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade; (ii) os enunciados de súmula vinculante; (iii) os acórdãos proferidos em IAC, em IRDR e em recursos extraordinários ou especiais repetitivos; (iv) os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; e (v) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

³⁴⁰ Súmula 420/STJ: “Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais”.

³⁴¹ Nesse sentido: AgRg nos EREsp 1.043.976/PR, Corte Especial, DJe09/02/2009, rel. Ministro Fernando Gonçalves.

³⁴² Nesse sentido: AgRg nos EREsp 303.546/MT, 2ª Seção, DJe01/10/2013, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira.



Assim está estruturado, pois, o sistema de precedentes vinculantes brasileiro, com **duas características** bastante marcantes: a **hierarquização** (em que os Tribunais Superiores ditam os entendimentos que deverão ser observados pelos Tribunais Estaduais e Regionais Federais, que, por sua vez, ditam os entendimentos que deverão ser observados em 1º grau de jurisdição) e a **vinculatividade** (em que se sabe, previamente, que determinadas decisões, quando tomadas, serão precedentes que a todos vincularão).

Entretanto, para que se possa exigir, do juiz, que respeite e bem aplique os precedentes vinculantes emanados dos Tribunais, é indispensável que se consiga corretamente identificar o **elemento nuclear** apto a produzir o efeito vinculante, razão pela qual a interpretação do precedente deve levar em consideração o **enunciado** que sintetiza a tese jurídica, examinado à luz de seus **fundamentos determinantes** (*ratio decidendi*).

A partir desse exame é que se pode verificar a existência de eventual cumprimento ou desrespeito ao precedente, bem como verificar se se está diante de hipótese que, por suas peculiaridades, é de **distinção** daquela tratada no precedente (justificadora do fenômeno denominado **distinguishing**) ou, ainda, de hipótese em que se faça necessário, diante de uma nova realidade social, jurídica, política ou econômica, promover a **superação do precedente** (justificadora do fenômeno denominado **overruling**).

Registre-se que, em virtude dos deveres de **estabilidade, integridade e coerência** previstos no art. 926, *caput*, CPC, a **superação** do precedente, que é sempre excepcional, deverá ser precedida de **audiências públicas** e da participação de **amicus curiae** que possam contribuir para o debate, legitimando a modificação que se pretende realizar (art. 927, §2º, CPC), ser tomada em decisão que contenha **fundamentação adequada e específica** que justifique a modificação do entendimento até então consolidado (art. 927, §4º, CPC) e, finalmente, ser objeto de **modulação de efeitos** quando necessário para a preservação do interesse social e da segurança jurídica (art. 927, §3º, CPC).

Passa-se ao exame, adiante, de **três relevantes técnicas de formação de precedentes vinculantes**, a saber, os recursos extraordinários ou especiais repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR – e o incidente de assunção de competência – IAC.

9.2. TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES

9.2.1. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO REPETITIVOS

Inicialmente, é preciso esclarecer que os recursos especial e extraordinário repetitivos não são modalidades recursais distintas, mas, ao revés, são técnicas diferenciadas de processamento e de julgamento desses recursos, em que são selecionados casos representativos (amostragem) para a construção de um precedente vinculante sobre a questão que se repete de forma seriada.

A **natureza jurídica** desse procedimento é a de **caso piloto** (ou **causa piloto**), na medida em que não há cisão cognitiva no julgamento pelo Tribunal que não apenas fixa a tese jurídica que deverá ser aplicada aos demais processos que versem sobre a mesma questão, mas também julga os casos concretos (recursos selecionados como representativos da controvérsia) que deram origem ao procedimento.

Trata-se de procedimento instituído exclusivamente no âmbito do STF e do STJ e que pressupõe a existência de **multiplicidade de recursos** especiais ou extraordinários com fundamento na mesma **questão de direito** (art. 1.036, *caput*, CPC).

No que se refere ao modo de seleção dos recursos que servirão de base para o procedimento, sublinhe-se que a Presidência ou a Vice-Presidência do Tribunal Estadual ou Regional Federal selecionará **dois ou mais recursos** representativos da controvérsia e os encaminhará ao STF

ou ao STJ, **sobrestando todos os demais processos** pendentes que envolvam a mesma matéria **naquele Estado ou região** (art. 1.036, §1º, CPC).

A seleção realizada no TJ ou no TRF **não vinculará** o relator no STF ou STJ, que poderá, por isso mesmo, selecionar **outros recursos** representativos da controvérsia (art. 1.036, §4º, CPC), inclusive **independentemente de iniciativa** nesse sentido do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (art. 1.036, §5º, CPC), observando-se, em quaisquer das hipóteses, que os recursos selecionados devem ser **admissíveis** e devem conter **abrangente argumentação** e **discussão** sobre a questão a ser julgada (art. 1.036, §6º, CPC).

É interessante destacar que a determinação de sobrestamento dos processos pendentes (art. 1.036, §1º, CPC) poderá eventualmente abranger recurso especial ou extraordinário **intempestivo**. Nessa hipótese, o interessado (normalmente, o recorrido) poderá requerer a **exclusão da ordem de suspensão**, a fim de que esse recurso seja imediatamente não conhecido pela intempestividade, sendo obrigatória a vista à parte contrária para manifestação sobre o tema em **5 dias** (art. 1.036, §2º, CPC). Se porventura sobrevier decisão indeferindo o referido requerimento, somente caberá agravo interno (art. 1.036, §3º, CPC).

Conquanto se afirme que **caberá ao relator no STJ ou STF proferir decisão de afetação** em que **identificará com precisão a questão** a ser submetida a julgamento, determinará a **suspensão de todos os processos** pendentes que versem sobre a questão e que **tramitem no território nacional** e, eventualmente, requisitará aos Presidentes ou aos Vice-Presidentes dos demais Tribunais Estaduais ou Regionais Federais a remessa de mais um recurso representativo da controvérsia (art. 1.037, *caput* e incisos, CPC). Fato é que, ao menos no âmbito do STJ, **não há que se falar em decisão monocrática de afetação**, mas, sim, em **deliberação colegiada de afetação** pela Seção ou pela Corte Especial após proposição e indicação do relator (art. 256-E, II, RISTJ)³⁴³.

Na hipótese de **não haver a afetação** e submissão dos recursos selecionados ao rito dos repetitivos ou, ainda, na hipótese de haver posterior **decisão de desafetação** (até o início do julgamento), a Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal que os tiver selecionado deverá ser científica, a fim de fazer cessar a ordem de sobrestamento dos recursos que haviam sido retidos na origem (art. 1.037, §1º, CPC).

Todavia, proferida decisão de afetação e determinada a **suspensão de todos os processos pendentes em todo o território nacional**, poderão as partes de processo que tenha sido sobrestado, regularmente intimadas da decisão de suspensão que vier a ser proferida pelo juiz ou relator (art. 1.037, §8º, CPC), demonstrar a **existência de distinção** (*distinguishing*) entre a questão a ser decidida em seu processo e aquela que será julgada no recurso submetido ao rito dos repetitivos, requerendo, em razão disso, o **prosseguimento da tramitação** de seu processo (art. 1.037, §9º, CPC).

A **competência** para examinar o requerimento de distinção será do juiz, se o processo sobrestado estiver em 1º grau; do relator, se o processo sobrestado estiver no Tribunal de origem; do relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no Tribunal de origem; e, finalmente, do relator, no Tribunal Superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado (art. 1.037, §10, incisos, CPC).

Instalado o **contraditório** com a parte adversa, que deverá se manifestar sobre o requerimento de distinção em **5 dias** (art. 1.037, §11, CPC), será proferida decisão judicial acerca da questão suscitada pela parte e, **se reconhecida a distinção**, serão tomadas as seguintes providências:

³⁴³Art. 256-E. Compete ao relator do recurso especial representativo da controvérsia, no prazo máximo de sessenta dias úteis a contar da data de conclusão do processo, reexaminar a admissibilidade do recurso representativo da controvérsia a fim de:

(...)

II –propor à Corte Especial ou à Seção a afetação do recurso especial representativo da controvérsia para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do Código de Processo Civil e da Seção II deste Capítulo



(i) se o processo estiver em 1º grau, no Tribunal de origem antes da interposição de recurso especial ou extraordinário no STF ou no STJ, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; (ii) se o processo houver sido sobrestado após a interposição de recurso especial ou extraordinário, o relator comunicará a decisão ao Presidente ou ao Vice-Presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior (art. 1.037, §12, CPC).

Finalmente, da decisão que resolver o requerimento de distinção, caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; ou agravo interno, se a decisão for de relator (art. 1.037, §13, CPC). Anote-se, ademais, que a decisão impugnável, nessa hipótese, **não é a que determinou a suspensão** do processo (art. 1.037, §8º, CPC), mas, sim, **exclusivamente a decisão que resolveu o requerimento de distinção** formulado pela parte³⁴⁴.

Iniciada a tramitação dos recursos representativos da controvérsia sob o rito dos repetitivos, poderá o relator, na forma do art. 1.038, *caput* e incisos, CPC, solicitar ou admitir a manifestação de *amicus curiae*, realizar audiências públicas, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, requisitar informações aos Tribunais Estaduais ou Regionais Federais a respeito da controvérsia e dar vista ao Ministério Público para manifestação.

Essas medidas visam conferir **legitimidade ao precedente vinculante** que se formará por ocasião do julgamento do recurso repetitivo e objetivam **reduzir o déficit de contraditório** que inegavelmente existe na hipótese, uma vez que a **tese jurídica se aplicará a todos os processos** pendentes que versarem sobre a mesma questão de direito **sem que tenha havido a participação individual dos jurisdicionados** na construção do entendimento do Tribunal Superior. Tais medidas, em síntese, servem também para que o **jurisdicionado e a sociedade sejam efetivamente representados** na construção do precedente vinculante.

Tomadas as referidas providências, haverá a inclusão dos recursos selecionados na pauta de julgamento, ocasião em que poderão as partes e os *amici curiae* realizar sustentação oral e, após, será proferido acórdão que deverá abranger os **fundamentos relevantes** da tese jurídica discutida (art. 1.038, §3º, CPC).

Findo o julgamento, em que será **fixada a tese jurídica** e serão **decididos os recursos representativos da controvérsia** que haviam sido afetados, os órgãos fracionários do STJ e do STF declararão **prejudicados** os recursos especiais ou extraordinários cujos **acórdãos estiverem em conformidade com a tese firmada** ou os **reformularão**, se **desconformes**, a fim de **aplicar a tese fixada** (art. 1.039, *caput*, CPC).

Por outro lado, os Tribunais Estaduais ou Regionais Federais **negarão seguimento** aos recursos especiais ou extraordinários que haviam sido sobrestados cujos acórdãos recorridos estiverem **de acordo com a tese** firmada (art. 1.040, I, CPC).

Aos órgãos fracionários dos Tribunais Estaduais ou Regionais Federais que haviam proferido **acórdãos recorridos contrários à tese**, será dada a oportunidade de **reexaminar** os processos anteriormente julgados (art. 1.040, II, CPC, denominado de **juízo de retratação**), ocasião em que deverão, inclusive, decidir eventuais **demais questões** cujo enfrentamento apenas se tornou necessário em decorrência da alteração de posicionamento (art. 1.041, §1º, CPC).

Anote-se que, se os órgãos fracionários **não adotarem a tese fixada** (a despeito da possibilidade de retratação) ou se os recursos contiverem **outras questões que não foram impactadas** pela modificação de posicionamento do órgão fracionário ou pela tese firmada no recurso repetitivo, os recursos especiais ou extraordinários já interpostos serão **remetidos** ao STJ ou ao STF (art. 1.041, *caput* e §2º, CPC).

³⁴⁴ Nesse sentido: REsp 1.846.109/SP, 3ª Turma, DJe13/12/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.



Finalmente, sublinhe-se que os processos que **havião sido suspensos em 1º grau e em 2º grau** (antes da interposição dos recursos excepcionais) terão o seu curso retomado para julgamento e aplicação da tese fixada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, II, CPC), observada, quanto aos processos em 1º grau, a possibilidade de **a parte desistir da ação**, antes da sentença, se a questão discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia (art. 1.040, §1º, CPC), **independentemente de aquiescência do réu** que tenha sido citado e que tenha apresentado contestação (art. 1.040, §3º, CPC), conferindo-se à parte, ainda, a **isenção de custas e honorários de sucumbência se desistir antes do oferecimento da contestação** pelo réu (art. 1.040, §2º, CPC).

9.2.2. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR

O IRDR é um mecanismo criado pelo novo CPC para uniformizar o entendimento dos Tribunais Estaduais e Regionais Federais acerca de uma mesma questão de direito que se repete em múltiplos processos, formando-se um precedente de natureza vinculante que deverá ser observado pelos demais órgãos fracionários e pelos juízes em 1º grau de jurisdição.

Conquanto diversos dispositivos legais indiquem que o IRDR é um instituto criado para os Tribunais de 2º grau (e esse também é o entendimento de parcela bastante significativa da doutrina³⁴⁵), fato é que há entendimento no sentido de que **é cabível o IRDR no âmbito do STJ**, especificamente em casos de **competência recursal ordinária** (por ex., recursos ordinários constitucionais) e de **competência originária** da Corte (por ex., mandados de segurança e conflitos de competência)³⁴⁶.

Por outro lado, uma das mais acirradas divergências acerca do IRDR diz respeito à **natureza jurídica** desse instituto, se **procedimento-modelo** ou se **caso-piloto**, debate que se refletirá na análise de muitos aspectos estruturais e procedimentais do IRDR.

A esse respeito, anote-se que uma parcela da doutrina, fundando-se na declarada inspiração de nosso IRDR (que é o *Musterverfahren* da Alemanha) e em uma série de dispositivos legais espalhados no sistema (arts. 976, I, 987, §1º e 977, III, CPC), compreende se tratar de **procedimento-modelo**, em que **há cisão cognitiva**, o que significa dizer que, no IRDR, **apenas será definida a tese jurídica** acerca da questão repetitiva, cabendo a **cada órgão jurisdicional posteriormente aplicar o entendimento nos casos concretos**, bem como se entende que **não será necessária a existência de causa pendente no Tribunal** para que o IRDR seja validamente instaurado, ou seja, o incidente poderá ser instaurado apenas com processos em curso no 1º grau de jurisdição³⁴⁷⁻³⁴⁸.

Por outro lado, parcela igualmente significativa da doutrina, fundando-se especialmente na impossibilidade de o legislador ordinário criar competências originárias para os Tribunais e no art. 978, parágrafo único, CPC, compreende que o IRDR é um **caso-piloto** (tal qual o recurso especial ou extraordinário repetitivo), em que há **unidade cognitiva**, o que significa dizer que, no IRDR, **a tese jurídica** acerca da questão repetitiva será **definida e aplicada diretamente nos casos concretos selecionados e que lhe serviram de base**, razão pela qual, inclusive, **é indispensável a existência de causa pendente no Tribunal** para que o IRDR seja validamente instaurado, ou seja, o incidente não poderá ser instaurado apenas com processos em curso no 1º grau de jurisdição³⁴⁹⁻³⁵⁰.

³⁴⁵ Por exemplo: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.718/1.719.

³⁴⁶ Nesse sentido: AgInt na Pet 11.838/MS, Corte Especial, DJe10/09/2019, rel. Ministro João Otávio de Noronha.

³⁴⁷ Por exemplo: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2017. p. 838/848.

³⁴⁸ Enunciado 22 da ENFAM: “A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal”.

³⁴⁹ Por exemplo: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 731/732.



Para que haja a instauração do IRDR, deverão ser cumulativamente preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, CPC: (i) **efetiva repetição de processos**, ou seja, a multiplicidade seja efetiva (concreta) e não apenas potencial (não cabe IRDR preventivo) sobre a **mesma questão unicamente de direito material ou processual**, isto é, não deve haver **controvérsia sobre fatos**; (ii) **risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica**, isto é, o efetivo perigo de que haja decisões diferentes e conflitantes sobre a mesma questão.

A **existência de causa pendente** no Tribunal, enquanto **pressuposto de admissibilidade** do IRDR, dependerá da corrente doutrinária a que se filie (se procedimento-modelo, será dispensável; se caso-piloto, será imprescindível).

Por outro lado, pode-se afirmar que o art. 976, §4º, CPC, prevê um **pressuposto negativo de admissibilidade** do IRDR, pois estabelece ser inadmissível o incidente quando a **matéria já houver sido afetada por Tribunal Superior** para julgamento sob o rito de recursos repetitivos. De igual modo, já se decidiu ser inadmissível o IRDR se o caso que serviria de base para a instauração do incidente **já tiver sido julgado no mérito**, pendente somente o julgamento de aclaratórios opostos em face do acórdão³⁵¹.

Na forma do art. 977, I a III e parágrafo único, CPC, **são legitimados** para requerer a instauração do IRDR o **juiz** ou o **relator** de qualquer processo em que a questão esteja colocada (por ofício); as **partes**, o **Ministério Público** ou a **Defensoria Pública** (por petição). Anote-se que juiz e partes de processos em tramitação nos Juizados Especiais igualmente são legitimados³⁵². Em todos os casos, o pedido deverá ser instruído com os documentos necessários ao preenchimento dos pressupostos.

Se admitido o IRDR, deverá haver a **suspensão de todos os processos pendentes** que envolvam a mesma questão, no **mesmo Estado ou região** (art. 982, I, CPC), que deverá perdurar por **até 1 ano** (art. 980, *caput*, CPC), findo o qual os processos deverão retomar a sua tramitação, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário (art. 980, parágrafo único, CPC).

O procedimento de alegação de **distinção** (*distinguishing*), por meio do qual a parte poderá requerer a exclusão de seu processo da ordem de suspensão, ao fundamento de que a matéria nele debatida é diferente daquela objeto do IRDR, e que apenas está textualmente previsto para a hipótese de recursos repetitivos, **igualmente será aplicável ao IRDR**, inclusive no que se refere à recorribilidade da decisão que resolver o requerimento, tendo em vista que **ambos os mecanismos compõem o microsistema de solução de controvérsias repetitivas**³⁵³.

A admissibilidade do IRDR deverá ser sempre **colegiada** (art. 981, CPC), devendo ser admitida a realização de **sustentação oral**³⁵⁴. O acórdão que admite ou inadmite o IRDR é **irrecorrível**³⁵⁵, especialmente diante da **inexistência de preclusão** e da possibilidade de **novo requerimento de instauração do IRDR** quando **satisfeito o requisito que inicialmente não havia sido comprovado** (art. 976, §3º, CPC), bem como da previsão de **recorribilidade excepcional apenas do mérito** do IRDR (art. 987, *caput*, CPC).

³⁵⁰ Enunciado 344 do FPPC: "(art. 978, parágrafo único) A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. (Grupo: Precedentes; redação revista no V FPPC-Vitória)".

³⁵¹ Nesse sentido: AREsp 1.470.017/SP, 2ª Turma, DJe 18/10/2019, rel. Ministro Francisco Falcão.

³⁵² Enunciado 605 do FPPC: "(arts. 977; 985, I) Os juízes e as partes com processos no Juizado Especial podem suscitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)".

³⁵³ Nesse sentido: REsp 1.846.109/SP, 3ª Turma, DJe13/12/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

³⁵⁴ Enunciado 651 do FPPC: "(arts. 937, 947, 976 e 984). É admissível sustentação oral na sessão de julgamento designada para o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas ou do incidente de assunção de competência, sendo legitimados os mesmos sujeitos indicados nos arts. 984 e 947, §1º. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)".

³⁵⁵ Nesse sentido: REsp 1.631.846/DF, 3ª Turma, DJe22/11/2019, rel. Ministra Nancy Andrighi.

Se, admitido o IRDR, houver a **desistência do recurso** ou o **abandono de processo** que serviu de base para a instauração do incidente, não haverá óbice para o exame de seu mérito e fixação da tese jurídica (art. 976, §1º, CPC).

Após a admissibilidade do IRDR, poderão as partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública requerer, ao STJ ou ao STF, conforme o caso, a **suspensão nacional de processos** que versem sobre o mesmo tema objeto do IRDR, visando garantir a segurança jurídica (art. 982, §3º, CPC). A legitimação para requerimento da suspensão nacional também se estende às partes de processos em que se discuta a mesma questão, mas que **tramitam fora do Estado ou região** em que o IRDR foi instaurado (art. 982, §4º, CPC).

A competência para julgamento do IRDR será do **órgão colegiado indicado pelo regimento interno** dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência do Tribunal (art. 978, *caput*, CPC). O órgão julgará **apenas o incidente** (se se entender que o IRDR é **procedimento-modelo**, caso em que o art. 978, parágrafo único, CPC, deverá ser compreendido como uma mera regra de prevenção) ou **o incidente e os casos concretos que lhe servem de base** (se se entender que o IRDR é um **caso-piloto**).

Caberá ao relator ouvir as **partes e demais interessados**, inclusive pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, bem como promover a realização de audiência pública para a oitiva de pessoas com experiência e conhecimento na matéria (art. 983, §1º, CPC). Discute-se na doutrina se, na qualidade de interessado, seria **admissível a intervenção dos terceiros que tiveram seus processos sobrestados** em razão da instauração do IRDR, com o propósito de qualificar o processo de formação do precedente mediante o acréscimo de questões ou de argumentos novos que possam contribuir para o debate, especialmente para conferir **legitimidade** ao precedente vinculante que se formará por ocasião do julgamento do IRDR e de **reduzir o déficit de contraditório** existente na hipótese³⁵⁶.

Findas as providências preliminares anteriormente referidas, ocorrerá o julgamento do IRDR, ocasião em que o relator fará exposição sobre o objeto do incidente (art. 984, I, CPC), haverá sustentação oral de autor e réu do processo originário, bem como do Ministério Público, por 30 minutos cada (art. 984, II, CPC), assim como haverá a sustentação oral dos demais interessados, pelo prazo de 30 minutos divididos entre eles, exigindo-se inscrição com 2 dias de antecedência (art. 984, III, CPC), prazo este que poderá ser ampliado, a depender do número de inscritos (art. 984, §1º, CPC).

O acórdão que julgar o mérito do IRDR deverá observar a regra de fundamento específica prevista no art. 984, §2º, CPC, que exige, expressamente, o exame de todos os fundamentos relacionados à tese, sejam eles **favoráveis** ou **contrários**.

Do acórdão que julgar o mérito do IRDR **caberá recurso especial ou extraordinário**, conforme o caso (art. 987, *caput*, CPC), que terá **efeito suspensivo** e possuirá **presunção de repercussão geral** (se a matéria for de índole constitucional) (art. 987, §1º, CPC), bem como deverá ser **processado sob o rito dos repetitivos**³⁵⁷⁻³⁵⁸.

Discute-se na doutrina quem possuiria **legitimidade e interesse para recorrer** do acórdão de mérito do IRDR.

³⁵⁶Por exemplo: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2017. p. 874/875.

³⁵⁷Art. 256-H do RISTJ: “Os recursos especiais interpostos em julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas serão processados nos termos desta Seção, não se aplicando a presunção prevista no art. 256-G deste Regimento”.

³⁵⁸Enunciado 660 do FPPC:“(arts. 987 e 1.036) O recurso especial ou extraordinário interposto contra o julgamento do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, ainda que único, submete-se ao regime dos recursos repetitivos. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)”.

Nesse contexto, parece não haver dúvida: (i) de que o juiz ou o relator **não possuem legitimidade ou interesse para recorrer** da decisão que fixa a tese no IRDR, mas, tão somente, para provocar a sua instauração (art. 977, I, CPC); (ii) de que as demais pessoas mencionadas no art. 977, II e III, CPC, **possuem legitimidade e interesse para recorrer** do acórdão a decisão que fixa a tese no IRDR; (iii) que o *amicus curiae* **igualmente possui legitimidade e interesse para recorrer** do acórdão que fixa a tese no IRDR por **expressa disposição legal** (art. 138, §3º, CPC).

A questão se torna mais complexa quando se examina a existência de legitimidade e de interesse recursal dos **terceiros que tiveram seus processos sobrestados no Estado ou região em que tramitou o IRDR**³⁵⁹ e de **terceiros de outros Estados ou regiões**³⁶⁰, inclusive e especificamente para a **modificação dos fundamentos da tese** ou, ainda, para lhe conferir **abrangência nacional**³⁶¹.

Diante dessa possibilidade e de um potencial tumulto processual causado por centenas ou milhares de recursos, propõe-se na doutrina, por exemplo, que a legitimação nessa hipótese seja **concorrente-disjuntiva**, ou seja, exaurir-se-ia com a interposição do primeiro recurso por um dos terceiros³⁶².

A tese firmada no IRDR se aplicará a todos os **processos pendentes**, isto é, todos aqueles que ainda tramitem na área de jurisdição do respectivo Tribunal, inclusive nos Juizados Especiais (e, se objeto de recurso excepcional julgado no mérito, aplicar-se-á para todo o território nacional – art. 987, §2º, CPC), excluídos aqueles que já tenham transitado em julgado ou que já tenham sido objeto de recursos especial ou extraordinário (art. 985, I, CPC). A tese também se aplicará a todos os **processos futuros** que versem sobre a mesma questão e que venham a tramitar no território de competência do Tribunal (art. 985, II, CPC), sendo que a **inobservância do precedente ensejará a correção pela via da reclamação** constitucional (arts. 985, §1º, e 988, IV, CPC), a ser julgada pelo **próprio Tribunal que fixou a tese em IRDR**.

A **revisão da tese** fixada no IRDR será realizada no Tribunal em que transitou em julgado a tese do IRDR, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Conquanto o art. 986, CPC, não faça referência expressa à legitimação das **partes** para pedido de revisão da tese, sublinhe-se que, por ocasião da revisão de texto do novo CPC no Senado Federal, o art. 977 teve seus **incisos desdobrados** (o II virou II e III) **sem que tenha ocorrido o respectivo ajuste** no texto do art. 986, razão pela qual deve igualmente ser conferida às partes a possibilidade de propor a revisão da tese firmada no IRDR.

A revisão da tese se justificará quando houver um fundamento novo não examinado inicialmente ou na hipótese de modificação das condições jurídicas, políticas, sociais ou econômicas, devendo ser observado, no procedimento de revisão, a realização de **audiências públicas** e a participação de *amicus curiae* que possam contribuir para o debate, legitimando a modificação que se pretende realizar (art. 927, §2º, CPC), a observância da regra que prevê a necessidade de **fundamentação adequada e específica** que justifique a modificação do entendimento até então consolidado (art. 927, §4º, CPC) e, ainda, a possibilidade de **modulação de efeitos**, se porventura necessário para a preservação do interesse social e da segurança jurídica (art. 927, §3º, CPC).

³⁵⁹ Enunciado 94 do FPPC: “(art. 982, § 4º; art. 987) A parte que tiver o seu processo suspenso nos termos do inciso I do art. 982 poderá interpor recurso especial ou extraordinário contra o acórdão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. (Grupo: Recursos Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; redação revista no V FPPC-Vitória)”.

³⁶⁰ Admitindo, por exemplo: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2017. p. 889/891.

³⁶¹ Por exemplo: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.734/1.735.

³⁶² DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 758.



9.2.3. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC

Ainda no contexto de valorização dos precedentes emanados dos Tribunais, o novo CPC aperfeiçoou substancialmente um mecanismo que, conquanto existisse na vigência do CPC/73, ganhou uma nova roupagem e disciplina: o incidente de assunção de competência – IAC.

O propósito principal do IAC é a formação de precedentes de natureza vinculante nas hipóteses em que **não há questão repetitiva** que justifique a utilização das técnicas dos recursos repetitivos ou do IRDR. O pressuposto específico de instauração do IAC, pois, é de que **não haja repetição da matéria controvertida em múltiplos processos** (art. 947, *caput*, parte final, CPC).

Nesse particular, é importante destacar que parcela significativa da doutrina sustenta ser possível a **conversão de IAC para o IRDR (e vice-versa)** na hipótese em que se verifique que o incidente instaurado não é o mais adequado para a resolução da questão submetida ao exame do Tribunal, mas que estão presentes os requisitos para a instauração do outro incidente³⁶³.

É admissível a instauração do IAC quando o julgamento de **recurso**, de **remessa necessária** ou de processo de **competência originária** do Tribunal envolver uma **relevante questão de direito material ou processual**, com **grande repercussão social** (o que compreende, por ex., a repercussão jurídica, econômica ou política³⁶⁴), inclusive para **prevenir** ou **compor** divergência entre órgãos fracionários dos Tribunais.

Do ponto de vista procedimental, anote-se que, presentes os pressupostos, caberá ao relator propor, de **ofício** ou mediante requerimento das **partes**, do **Ministério Público** ou da **Defensoria Pública**, que o caso seja julgado por órgão colegiado de maior tamanho, a ser indicado pelo regimento interno de cada Tribunal (art. 947, §1º, CPC), a quem caberá **não apenas fixar a tese jurídica**, como também **julgar o próprio recurso, remessa necessária ou processo de competência originária** que servir de base ao IAC. É correto afirmar, pois, que no IAC há **unidade cognitiva** (art. 947, §2º, CPC).

A tese jurídica fixada em IAC vinculará a todos os juízes e órgãos fracionários do Tribunal Estadual ou Regional Federal em que tramitou o incidente ou, se instaurado em Tribunal Superior, deverá ser observada em todo o território nacional³⁶⁵, sendo que a **inobservância do precedente ensinará a correção pela via da reclamação** constitucional (art. 988, IV, CPC), a ser julgada pelo **Tribunal que fixou a tese em IAC**.

Considerando que a disciplina legal do IAC se limita ao art. 947, CPC, a doutrina e os regimentos internos dos Tribunais têm procurado integrar as lacunas normativas, especialmente porque o IAC compõe, juntamente com o IRDR e os recursos repetitivos, o denominado **microssistema de precedentes vinculantes**.

É por isso que se afirma que, tal qual no IRDR, deverá o Ministério Público ser intimado para intervir após a instauração do IAC, inclusive, poderão ser admitidos *amici curiae* para contribuir e acrescentar argumentos e questões relevantes ao debate, bem como poderão ser realizadas audiências públicas e deverá ser franqueada a sustentação oral às partes e terceiros interessados,

³⁶³ Enunciado 702 do FPPC: “(arts. 947 e 976, I) É possível a conversão de incidente de assunção de competência em incidente de resolução de demandas repetitivas e vice-versa, garantida a adequação do procedimento. (Grupo: Ordem do processo nos Tribunais, Regimento interno e Incidente de Assunção de Competência)”.

Enunciado 141 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É possível a conversão de Incidente de Assunção de Competência em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, se demonstrada a efetiva repetição de processos em que se discute a mesma questão de direito”.

³⁶⁴ Enunciado 469 do FPPC: “(Art. 947). A “grande repercussão social”, pressuposto para a instauração do incidente de assunção de competência, abrange, dentre outras, repercussão jurídica, econômica ou política. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)”.

³⁶⁵ Enunciado 472 do FPPC: “(art. 985, I) Aplica-se o inciso I do art. 985 ao julgamento de recursos repetitivos e ao incidente de assunção de competência. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)”.

sempre com a finalidade de conferir **legitimidade ao precedente vinculante** que se formará por ocasião do julgamento do IAC e **reduzir o déficit de contraditório** que inegavelmente existe na hipótese, uma vez que a **tese jurídica se aplicará a todos os processos** pendentes que versarem sobre a mesma questão de direito **sem que tenha havido a participação individual dos jurisdicionados** na construção do entendimento³⁶⁶⁻³⁶⁷.

De igual modo, entende-se que, embora apenas haja previsão específica para as hipóteses de repercussão geral reconhecida e para os recursos repetitivos, o art. 998, parágrafo único, CPC, que prevê que a **desistência do recurso não impede a formação do precedente, também se aplica ao IAC**³⁶⁸.

Anote-se, ainda no mesmo sentido, que, a despeito da ausência de previsão legal expressa, é admissível a **concessão de tutela da evidência** fundada em tese firmada em incidente de assunção de competência e, ainda, a **caução exigível em cumprimento provisório de sentença poderá ser dispensada** se o julgado a ser cumprido estiver em consonância com tese firmada em incidente de assunção de competência³⁶⁹.

É interessante observar, ademais, que **não haverá a incidência da técnica de ampliação de colegiado** (art. 942, *caput* e §3º, I, CPC) por ocasião do julgamento do recurso ou do processo de competência originária em que foi **instaurado o IAC**, tendo em vista a existência de regra legal proibitiva (art. 942, §4º, I, CPC) que se justifica porque o IAC será julgado em um órgão colegiado ampliado.

Anote-se, por fim, que a tese jurídica fixada em IAC possui diversas **repercussões em outras fases processuais**, como ao autorizar o julgamento de **improcedência liminar** se a pretensão contrariar a tese (art. 332, III, CPC), a **dispensa de remessa necessária** se a decisão de mérito estiver conforme a tese (art. 496, §4º, III, CPC), e o **julgamento unipessoal** pelo relator no Tribunal (art. 932, IV e V, CPC).

³⁶⁶ Enunciado 201 do FPPC: “(arts. 947, 983 e 984) Aplicam-se ao incidente de assunção de competência as regras previstas nos arts. 983 e 984. (Grupo: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Assunção de Competência)”.

Art. 271-D do RISTJ: “O relator ou o Presidente ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida; em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público Federal no mesmo prazo”.

³⁶⁷ Enunciado 467 do FPPC: “(arts. 947, 179, 976, §2º, 982, III, 983, *caput*, 984, II, “a”) O Ministério Público deve ser obrigatoriamente intimado no incidente de assunção de competência. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)”.

Art. 271-B, §3º, do RISTJ: “Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no processo e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono”.

³⁶⁸ Enunciado 65 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A desistência do recurso pela parte não impede a análise da questão objeto do incidente de assunção de competência”.

Art. 271-B, §2º, do RISTJ: “A desistência ou o abandono do processo não impedem o exame do mérito”.

³⁶⁹ Enunciado 135 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É admissível a concessão de tutela da evidência fundada em tese firmada em incidente de assunção de competência”.

Enunciado 136 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A caução exigível em cumprimento provisório de sentença poderá ser dispensada se o julgado a ser cumprido estiver em consonância com tese firmada em incidente de assunção de competência”.

10. AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO E INCIDENTES NOS TRIBUNAIS

10.1. AÇÃO RESCISÓRIA

10.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de ação autônoma de impugnação, pois inaugura uma nova relação processual, distinta daquela em que foi proferida a decisão judicial impugnada, por intermédio da qual se pretende rescindir, em caráter excepcional e diante de vícios de maior gravidade, a coisa julgada que se formou na ação judicial anteriormente transitada em julgado e, se o caso, promover o rejuízo da causa.

10.1.2. HIPÓTESES DE CABIMENTO – DECISÕES DE MÉRITO

A) PREVARICAÇÃO, CONCUSSÃO OU CORRUPÇÃO PASSIVA DO JUIZ (ART. 966, I, CPC)

Todas essas hipóteses estão relacionadas aos **conceitos penais de possíveis fraudes do juiz**, a saber: a **prevaricação** (deixa de praticar ou retardar ato ou praticar contra disposição legal para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, art. 319, CP), a **conculusão** (exigir vantagem para si ou outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, art. 316, CP) e a **corrupção passiva** (solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, art. 317, CP).

Dois aspectos de extrema relevância deverão ser considerados para a ação rescisória fundada nessa hipótese: (i) a **prova da conduta criminosa** deverá ser **cabal**³⁷⁰ e poderá ser produzida na **própria ação rescisória** ou em **processo-crime anterior**, sendo que, nesse último caso, a condenação criminal não mais poderá ser debatida no bojo da ação rescisória; (ii) é necessário que, em se tratando de julgamento colegiado, o voto do magistrado que praticou a conduta criminosa tenha **influenciado na formação da maioria**.

B) JUIZ IMPEDIDO OU JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE (ART. 966, II, CPC)

As causas de impedimento do juiz estão elencadas no art. 144, CPC, e a rescindibilidade da decisão de mérito por ele proferida se justifica em razão da quebra de **imparcialidade**, que é **pressuposto processual de validade**. É irrelevante, nesse contexto, que a questão tenha sido ou não arguida na ação anterior, em que se formou a coisa julgada.

Para fins de rescindibilidade, é indispensável que o juiz tenha proferido **decisão de mérito**, sendo insuficiente, por exemplo, que tenha ele proferido apenas decisões interlocutórias. Na hipótese de se pretender a rescisão de decisão colegiada, o voto do magistrado impedido deve ter **influenciado na formação da maioria**, isto é, que tenha sido **decisivo** para o resultado³⁷¹.

Por outro lado, a decisão de mérito proferida por juízo **absolutamente incompetente** (em razão da matéria, da função ou da hierarquia), também justifica o cabimento da ação rescisória porque a competência absoluta também é um **pressuposto processual de validade**.

³⁷⁰ Nesse sentido: AR 4.184/SE, 1ª Seção, DJe05/09/2016, rel. Ministro Humberto Martins.

³⁷¹ Nesse sentido: EREsp 1.008.792/RJ, 2ª Seção, DJe 29/04/2011, rel. Ministra Nancy Andriighi.



C) DOLO OU COAÇÃO DO VENCEDOR EM DETRIMENTO DO VENCIDO; SIMULAÇÃO OU COLUSÃO ENTRE AS PARTES (ART. 966, III, CPC)

Nos casos de **dolo** e de **coação** de uma parte a outra (ou, até mesmo, de advogado³⁷²), é preciso demonstrar a existência de **ato grave e intencional**³⁷³, a existência de **nexo de causalidade** entre o referido ato e a decisão de mérito a ser rescindida, de modo que o referido vício constituiu **causa determinante** para a obtenção do referido resultado. Em regra, o exame dessas circunstâncias ocorrerá na própria ação rescisória, sem prejuízo, evidentemente, de a apuração dos fatos ocorrer em outra esfera e a prova nela produzida servir de elemento de convicção a ser valorado pelo Tribunal por ocasião do julgamento da ação rescisória.

Nos casos de **simulação** ou de **colusão** entre as partes, é também necessária a demonstração de **nexo causal**, de modo a demonstrar que as partes, mediante prévio acordo, simularam um processo ou estabeleceram um conluio com o propósito de fraudar a lei para, em regra, causar prejuízo a **terceiros**.

D) OFENSA À COISA JULGADA (ART. 966, IV, CPC).

O pronunciamento judicial que decida pedido que já havia sido acobertado pela **coisa julgada material** formada em **ação anterior**, que é pressuposto processual negativo desta nova ação, é igualmente **rescindível**.

Na hipótese de **conflito de coisas julgadas** em que ainda exista prazo para a rescisão da segunda, não há dúvida de que, ajuizada a ação rescisória e sendo ela julgada procedente, prevalecerá a primeira, sendo a **segunda extirpada** do mundo jurídico. A questão ganha contornos mais problemáticos, entretanto, quando **não mais houver prazo para rescindir a coisa julgada que se formou em segundo lugar**.

A divergência doutrinária acerca da questão também se instalou no âmbito do STJ, havendo posicionamento no sentido de que, também nessa hipótese, deveria prevalecer a **primeira coisa julgada**,³⁷⁴ e entendimento em sentido oposto, consignando que, se **ultrapassado o prazo** para rescindir, é a **segunda coisa julgada que deverá prevalecer**³⁷⁵. A referida divergência, contudo, foi recentemente dirimida, estabelecendo-se que, na hipótese de **não mais haver prazo para rescisão**, **deverá prevalecer a segunda coisa julgada**³⁷⁶.

E) VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC).

Trata-se da hipótese de cabimento **mais frequentemente** utilizada para sustentar o ajuizamento de uma ação rescisória.

Na vigência do CPC/73, era cabível a ação rescisória somente quando a decisão de mérito violasse **literal disposição de lei**. Nesse contexto, por ex., vedava-se o uso da ação rescisória com base em violação de **súmula**³⁷⁷ e tampouco se admitia a ação rescisória quando a **interpretação dada pela decisão rescindenda fosse objeto de controvérsia** nos Tribunais³⁷⁸.

³⁷² NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.685.

³⁷³ Nesse sentido: REsp 1.590.902/SP, 3ª Turma, DJe12/05/2016, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

³⁷⁴ Nesse sentido: REsp 1.590.902/SP, 3ª Turma, DJe12/05/2016, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

³⁷⁵ Nesse sentido: REsp 1.524.123/SC, 2ª Turma, DJe26/05/2015, rel. Ministro Herman Benjamin.

³⁷⁶ Nesse sentido: EAREsp 600.811/SP, Corte Especial, DJe07/02/2020, rel. Ministro Og Fernandes.

³⁷⁷ Nesse sentido: AR 433/SP, 1ª Seção, DJ 11/12/1995, rel. Ministro Demócrito Reinaldo.

³⁷⁸ Súmula 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".



Considerando que o novo CPC passou a prever o cabimento por **violação à norma jurídica**, é correto afirmar que, hoje, a rescindibilidade das decisões de mérito sob esse fundamento é **substancialmente mais ampla**, razão pela qual, atendendo-se aos anseios da doutrina e à evolução da própria jurisprudência, deverão também ser admitidas as ações rescisórias fundadas em **princípios**³⁷⁹ e em **precedentes**, especialmente os de natureza **vinculante**³⁸⁰ que, atualmente, possuem até mesmo uma previsão legal específica (art. 966, §5º, CPC), que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito que não tenha observado a distinção entre o caso concreto e o padrão decisório estabelecido em súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos (IRDR e recursos especiais ou extraordinários repetitivos).

Sublinhe-se, finalmente, que a alegada violação à norma jurídica deve ser **manifesta**, ou seja, clara, evidente, demonstrável apenas pela prova juntada aos autos, que envolva interpretação absolutamente desarrazoada do texto normativo ou, ainda, incoerente ou sem integridade com o ordenamento jurídico³⁸¹.

F) PROVA FALSA APURADA NO PROCESSO-CRIME OU NA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VI, CPC)

Para que seja rescindível a decisão fundada em **prova falsa**, seja na hipótese de falsidade ideológica, seja na hipótese de falsidade material, é necessário que haja **nexo de causalidade** entre a prova e a decisão de mérito a ser rescindida, tendo sido ela **decisiva** para a obtenção de determinado **resultado**, bem como que inexistam **fundamento diverso independente apto a sustentar a conclusão** a que chegou o julgado³⁸². A falsidade pode ter sido reconhecida em **processo-crime** ou poderá ser **provada na própria ação rescisória**.

G) PROVA NOVA POSTERIOR AO TRÂNSITO, CUJA EXISTÊNCIA ERA IGNORADA PELO AUTOR OU DE QUE NÃO PODERIA ELE FAZER USO, CAPAZ DE LHE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL (ART. 966, VII, CPC)

A prova nova a que se refere o mencionado dispositivo legal é aquela que, conquanto existisse no momento da prolação da decisão rescindenda, era **ignorada** ou **insuscetível de uso** pelo autor, apenas vindo a sê-lo após o trânsito em julgado.

São os casos, por exemplo, da testemunha incapaz de narrar os fatos de que tem ciência por ocasião da fase instrutória, mas que recupera a consciência após o trânsito em julgado, bem como das ações investigatórias de paternidade julgadas antes da possibilidade de uso da prova pericial consubstanciada no exame de DNA.

A prova nova deve ser **suficiente** para, sozinha, **modificar o resultado** da causa, **infirmando as demais provas** que sustentam a decisão rescindenda.

Finalmente, anote-se que o conceito de prova nova é **mais amplo** do que o conceito de documento novo que havia sido adotado ao tempo do CPC/73. Em razão disso, já se consignou que, *“no novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo”*³⁸³.

³⁷⁹GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2017. p. 773/774.

³⁸⁰Nesse sentido: REsp 1.655.722/SC, 3ª Turma, DJe 22/03/2017, rel. Ministra Nancy Andrighi.

³⁸¹DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 580/581.

³⁸²Nesse sentido: AR 3.553/SP, 3ª Seção, DJe 06/04/2010, rel. Ministro Felix Fischer.

³⁸³Nesse sentido: REsp 1.770.123/SP, 3ª Turma, DJe 02/04/2019, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



H) ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (ART. 966, VIII E §1º, CPC)

Para que seja rescindível a decisão de mérito ao fundamento de erro de fato, é preciso que seja ele verificável a partir do mero exame dos autos, não sendo admissível, pois, a produção de prova para que se constate o erro.

Na forma do art. 966, §1º, CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda **admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido**”. Além, diz a regra legal que o fato **não pode ter sido objeto de controvérsia** (ou seja, não pode ter havido **debate** entre as partes sobre o fato).

Em síntese, a ação rescisória será admissível, nessa hipótese, quando: (i) o erro de fato for relevante para o julgamento da questão, ou seja, quando sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; (ii) o erro de fato for apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e (iii) não houver controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato na ação originária³⁸⁴.

10.1.3. HIPÓTESES DE CABIMENTO – DECISÕES SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

A possibilidade de **rescisão de decisões processuais**, isto é, que não tenham enfrentado o mérito, era timidamente admitida na jurisprudência ao tempo do CPC/73³⁸⁵, embora a doutrina, já naquela época, vislumbasse essa possibilidade nas hipóteses em que a decisão em resolução de mérito tornasse inviável a repropositura da ação em virtude da imutabilidade e da indiscutibilidade da questão.

Com efeito, embora a ação rescisória sirva, em regra, para impugnar as decisões de mérito, há situações em que decisões sem resolução de mérito devem ser rescindíveis porque **impedem a repropositura da mesma ação** (art. 966, §2º, I, CPC), como o que ocorre quando há reconhecimento de **ilegitimidade de parte** (art. 485, VI, CPC).

Nessa hipótese, se porventura houver a **substituição** da parte supostamente ilegítima pelo autor (corrigindo-se, pois, o vício apontado na decisão, como determina o art. 486, §1º, CPC), é correto afirmar que não mais se tratará de repropositura da mesma ação, mas, ao revés, de **propositura de uma nova ação**, – visto que modificado o sujeito da relação processual. Desse modo, deverá ser facultado ao autor a via da rescisória caso compreenda estar equivocada a decisão sem resolução de mérito que reconheceu a ilegitimidade de parte.

De igual modo, também deve ser suscetível de rescisão a decisão que **impede a admissibilidade de recurso** (art. 966, §2º, II, CPC). Essa decisão não é de mérito (art. 487, CPC), tampouco é decisão sem resolução de mérito (art. 485, CPC), mas, se porventura houver sido proferida em **contrariedade à regra legal**, de modo a impedir que seja admitido o respectivo recurso (por ex., se a transgressão da regra estiver em intempestividade de recurso especial pela inobservância de feriado local comprovado na interposição, art. 1.003, §6º, CPC), será rescindível, a fim de viabilizar o exame do mérito recursal.

Nessa hipótese, a causa de pedir da ação rescisória deverá ser a existência do vício na decisão que não conheceu do recurso especial anteriormente interposto e o pedido deverá ser a rescisão da decisão que o inadmitiu³⁸⁶.

³⁸⁴ Nesse sentido: AR 1.421/PB, 2ª Seção, DJe 08/10/2010, rel. Ministro Massami Uyeda.

³⁸⁵ Nesse sentido: REsp 1.217.321/SC, 2ª Turma, DJe 18/03/2013, rel. Ministro Mauro Campbell Marques.

³⁸⁶ Nesse sentido: AgInt na AR 6.278/RS, 1ª Seção, DJe 16/10/2019, rel. Ministro Herman Benjamin.

10.1.4. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

Os legitimados para ajuizar a ação rescisória estão elencados no art. 967, CPC, a saber: (i) aquele que foi **parte no processo originário** ou seu **sucessor**, a título universal ou singular, independentemente do polo ocupado na ação originária; (ii) o **terceiro juridicamente interessado**, como aquele que **poderia** ter sido, mas **não foi** parte, e aquele que **tem relação jurídica conexa** com a principal e que foi **atingido**, ainda que **reflexamente**, pela decisão (assistentes ou litisconsortes facultativos); (iii) o **Ministério Público**, em determinadas situações (se não foi ouvido quando obrigatória a intervenção; na hipótese de simulação ou de colusão das partes (art. 966, III, CPC); em outros casos em que se imponha a sua atuação, sendo que, fora dessas hipóteses, será intimado para atuar como fiscal do ordenamento jurídico se presentes as situações do art. 178, CPC); (iv) aquele que **deveria ter sido interveniente**, mas não foi, por exemplo, os litisconsortes necessários e o CADE, a CVM, o INPI, etc., nas ações que necessariamente demandavam a sua intervenção.

Por outro lado, conquanto não exista disciplina legal acerca do tema, é correto afirmar que **todos aqueles que foram partes no processo originário**, inclusive quem foi litisconsorte de qualquer natureza do autor da ação rescisória na ação originária e que teria, como ele, interesse para ajuizá-la, **deverão ser incluídos no polo passivo**. Forma-se no polo passivo, pois, um **litisconsórcio necessário unitário**.

Entendeu-se no STJ que os **advogados** das partes vencedoras na ação originária (em que proferida a decisão rescindenda), em regra, **não deverão ser réus da ação rescisória**, salvo na hipótese de a causa de pedir e o pedido da ação rescisória se voltarem especificamente contra a parcela de honorários, tendo em vista que o recebimento dos honorários ocorreu de boa-fé e, ademais, os honorários possuem caráter alimentar e irrepetível³⁸⁷.

10.1.5. PRAZO

Na forma do art. 975, *caput*, CPC, o prazo para rescindir a decisão inquinada de algum dos vícios anteriormente mencionados se escoa em **2 anos**. Trata-se de prazo de natureza **decadencial**, pois se trata de pedido **desconstitutivo** ou **constitutivo negativo**, na medida em que há um direito **potestativo** à rescisão da coisa julgada.

Embora se trate de prazo decadencial (que, como se sabe, não se prorroga), há expressa disposição legal (art. 975, §1º, CPC) no sentido de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória se **prorroga para o dia útil subsequente** se a expiração ocorrer durante férias forenses, recesso, feriados ou dia que não houver expediente forense.

Considerando a possibilidade de prolação de **decisões parciais de mérito** (art. 356, CPC) e de cabimento de **ação rescisória sobre apenas um capítulo da decisão** (art. 966, §3º, CPC), discute-se na doutrina sobre a possibilidade de **ajuizamento de mais de uma rescisória a partir do mesmo processo** e sobre a **forma de contagem** do biênio decadencial da ação rescisória, especialmente porque o art. 975, *caput*, CPC, disciplina apenas o **termo final**.

Acerca dessa questão controvertida, as posições doutrinárias são essencialmente as seguintes: (i) é irrelevante ter havido decisão parcial de mérito transitada em julgado anteriormente, de modo que **o prazo deverá ser computado, sempre, da última decisão proferida no processo**³⁸⁸, em linha com a Súmula 401/STJ, editada na vigência do CPC/73³⁸⁹; (ii) o **prazo** para rescindir a decisão parcial de mérito transitada em julgado anteriormente é **variável**, podendo a parte **optar**

³⁸⁷ Nesse sentido: AR 5.160/RJ, 2ª Seção, DJe 18/04/2018, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

³⁸⁸ NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.104.

³⁸⁹ Súmula 401/STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

pelo ajuizamento de mais de uma ação rescisória ou, se preferir, aguardar a prolação da última decisão proferida no processo, quando então poderá ajuizar uma ação rescisória contra todas as decisões de mérito proferidas³⁹⁰; (iii) a última decisão proferida no processo deve ser compreendida como a última decisão proferida a respeito do capítulo objeto da decisão parcial de mérito, razão pela qual a parte que pretender rescindir mais de uma decisão de mérito deverá, necessariamente, ajuizar mais de uma ação rescisória³⁹¹.

Ainda em relação aos prazos, anote-se que, para a ação rescisória fundada em **prova nova**, dispõe o art. 975, §2º, CPC, que o termo inicial do biênio será a data da descoberta da prova, observado o limite de **5 anos do trânsito da última decisão proferida no processo**.

Por outro lado, no que se refere ao prazo da ação rescisória fundada em **colusão** ou em **simulação**, prevê o art. 975, §3º, CPC, que o termo inicial do biênio para terceiro ou para o Ministério Público, que não participaram do processo originário, será a data da ciência da colusão ou simulação.

Finalmente, o prazo para ação rescisória fundada em **inconstitucionalidade superveniente** deverá observar o termo inicial estabelecido nos arts. 525, §15, e 535, §8º, de modo que, sendo a lei declarada inconstitucional pelo STF, em controle concentrado ou difuso, será rescindível a decisão nela fundada, se a declaração do STF for posterior ao trânsito, caso em que o termo inicial será deflagrado com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.

10.1.6. COMPETÊNCIA

A **competência** para processar e julgar a ação rescisória é definida **constitucionalmente**, de modo que cabe ao STF rescindir os seus julgados (art. 102, I, “j”, CF/88); ao STJ rescindir os seus (art. 105, I, “e”, CF/88); aos TRFs rescindir os seus (art. 108, I, “b”, CF/88); e, aos TJs rescindir os seus, nos moldes do que definir a Constituição Estadual (art. 125, §1º, CF/88). Se a decisão de mérito a ser rescindida for a sentença, a competência será do TRF ou TJ ao qual o juízo prolator estiver vinculado.

Para a correta definição da competência, é preciso identificar qual é a última decisão de mérito proferida no processo, pois deverá ser ela o objeto da rescisão e, conseqüentemente, será ela que definirá o órgão julgador em que se processará a ação rescisória. Em suma, a competência será do último Tribunal que examinou o mérito da causa.

Nesse sentido, se, por exemplo: (i) a decisão de mérito proferida em 1º grau for objeto de **recurso não conhecido**, a decisão rescindenda será a sentença ou a decisão parcial de mérito e a competência será do TJ ou TRF; (ii) a decisão de mérito proferida em 1º grau for objeto de **recurso provido ou desprovido**, a decisão rescindenda será a monocrática ou o acórdão e a competência serão do TJ ou TRF que a prolatou; (iii) se a decisão de mérito proferida em 2º grau for objeto de **recurso excepcional não conhecido**, a decisão rescindenda será a monocrática ou o acórdão local e a competência são do TJ ou TRF respectivo; e, finalmente (iv) se a decisão de mérito proferida em 2º grau for objeto de **recurso excepcional provido ou desprovido**, a decisão rescindenda será a monocrática ou o acórdão do STJ ou STF e a competência serão do Tribunal Superior que a prolatou.

A despeito de a regra parecer bastante simples, não se pode olvidar que há hipóteses em que os Tribunais, conquanto digam que **não conhecem** do recurso, adentram ao exame de seu mérito, de modo que seria correto dizer que estão **lhe negando provimento**, razão pela qual pode haver dúvida acerca da competência para processar a ação rescisória.

³⁹⁰ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.549.

³⁹¹NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.709/1.710.

Essa questão era extremamente problemática na vigência do CPC/73, na medida em que a constatação de que a ação rescisória fora ajuizada em Tribunal que não detinha competência para rescindir a última decisão de mérito resultava em extinção da ação sem resolução de mérito, sem que houvesse a remessa da rescisória ao Tribunal competente e, normalmente, somente após o biênio para o ajuizamento da ação, de modo que o direito de rescindir estava, em regra, fulminado pela decadência³⁹².

A partir do novo CPC, todavia, se a parte ajuizar a ação rescisória em Tribunal incompetente nas hipóteses do art. 968, §5º, I e II, CPC, não mais haverá a extinção sem resolução de mérito, mas, sim, ordem judicial para o autor **emendar a petição inicial e adequar o objeto da ação rescisória**, seguida de abertura de prazo para **complementação da defesa do réu** (se o caso), findo o qual os autos serão remetidos ao Tribunal competente.

10.1.7. PETIÇÃO INICIAL, TUTELA PROVISÓRIA, PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

Além dos requisitos do art. 319, CPC, deverá o autor, em razão das particularidades da ação rescisória, cumprir determinados requisitos adicionais de admissibilidade da petição inicial.

O primeiro será cumular pedidos **rescindente** (desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado) e **rescisório** (rejulgamento da causa, quando cabível), na forma do art. 968, I, CPC. Há hipóteses em que o pedido rescisório é **desnecessário**, como, por exemplo, na hipótese de conflito entre coisas julgadas (art. 966, IV, CPC), em que se pretende tão somente a extirpação da coisa julgada que se formou em segundo lugar.

Ademais, será necessário providenciar o **depósito de 5% sobre o valor da causa**, desde que **não superior a 1000 salários**, sob pena de **indeferimento da petição inicial**, que será convertido em **multa ao réu** se a ação rescisória for julgada **inadmissível** ou **improcedente** por votação unânime. O depósito será **dispensado** quando se tratar de União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público, Ministério Público, Defensoria Pública e beneficiários da gratuidade (art. 968, II, §1º, §2º e §3º, CPC).

Na hipótese de a ação rescisória se fundar em **distinção entre o caso concreto e padrão decisório fixado em precedente** (art. 966, §5º, CPC), deverá a parte demonstrar, fundamentadamente, e sob pena de inépcia da petição inicial, que se trata de situação particular – hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada – que imponha diversa solução jurídica (art. 966, §6º, CPC).

Ademais, já se decidiu que, na ação rescisória, **“o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer”**³⁹³.

É admissível, por expressa disposição legal (art. 968, §4º, CPC), que a ação rescisória seja **julgada liminarmente improcedente** nas hipóteses do art. 332, CPC, ou seja, quando a pretensão contrariar súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recursos repetitivos, entendimento fixado em IRDR ou em IAC ou súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.

Em regra, a propositura da ação rescisória não impedirá o cumprimento definitivo da decisão rescindenda, salvo se for concedida tutela provisória da sentença (art. 969, CPC).

Admitida a ação rescisória, o relator, escolhido preferencialmente entre quem não tenha participado do julgamento havido na ação originária (art. 971, parágrafo único, CPC), determinará que seja o réu citado para responder, assinalando-se **prazo entre 15 e 30 dias**, observando-se, a

³⁹² Nesse sentido: REsp 714.580/PR, 1ª Turma, DJ 27/06/2005, rel. Ministro José Delgado.

³⁹³ Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.745.942/RS, 4ª Turma, DJe 11/06/2019, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

partir daí, o procedimento comum (art. 970, CPC), inclusive no que se refere à **fase instrutória**, que poderá ser delegada pelo relator ao juízo que proferiu a decisão rescindenda, com prazo de **1 a 3 meses** para conclusão dos trabalhos (art. 972, CPC), findo o qual haverá a abertura de **prazo sucessivo para razões finais**, pelo autor e pelo réu, pelo prazo de **10 dias** para cada (art. 973, *caput*, CPC).

Finalmente, por ocasião do julgamento da ação rescisória, haverá a possibilidade de sustentação oral (art. 937, VI, CPC), e o Tribunal proferirá, inicialmente, **decisão sobre o pedido de rescisão do julgado** (juízo rescindente). Se o resultado, por maioria, for no sentido de rescindir o julgado, aplicar-se-á a técnica de julgamento estendido (art. 942, §3º, I, CPC), a fim de que o julgamento do pedido rescisório ocorra em órgão de maior composição previsto no regimento interno.

Anote-se, a propósito, que somente se for julgado procedente o pedido rescindente, por unanimidade ou por maioria, é que se procederá ao **rejulgamento da causa** (juízo rescisório), se necessário for, e que poderá ser julgado procedente ou improcedente (art. 974, *caput*, CPC).

10.2. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

10.2.1. CABIMENTO

A reclamação constitucional é **ação autônoma de impugnação** sem similar no direito comparado, que poderá ser ajuizada pela **parte interessada** ou pelo **Ministério Público**, a fim de **garantir o efetivo cumprimento das decisões** judiciais que reconheçam a existência de direitos – materiais ou processuais.

A **primeira hipótese** de cabimento da reclamação, que está prevista no art. 988, I, CPC, versa sobre a necessidade de **preservação da competência do Tribunal**. Pretende-se, dessa forma, impedir que um Juiz ou Tribunal invada a competência de outro Juiz ou Tribunal, por exemplo, na hipótese em que o Tribunal de Justiça ou Regional Federal realiza **juízo de admissibilidade** de recurso ordinário constitucional³⁹⁴.

É também cabível a reclamação para **garantir a autoridade das decisões do Tribunal** (art. 988, II, CPC). Pretende-se, pois, impedir que Juiz ou Tribunal se negue a cumprir decisão provisória ou definitiva proferido por Tribunal hierarquicamente superior, como na hipótese em que há, na fase recursal, a conversão de julgamento em diligência, mas não são produzidas as provas determinadas pelo Tribunal.

Ademais, é igualmente cabível a reclamação para **garantir a observância de alguns precedentes** enunciados pelo legislador (art. 988, III e IV, CPC). Isso significa dizer, pois, que se Juiz ou Tribunal **deixar de aplicar** ou **aplicar indevidamente** (art. 988, §4º, CPC) a tese firmada em **súmula vinculante**, em decisão do STF em **controle concentrado de constitucionalidade** ou acórdão proferido em **IRDR** ou em **IAC**, não se exigindo, nessa hipótese, sequer o esgotamento das instâncias ordinárias, de modo que poderá, na forma do art. 988, §6º, CPC, ser ajuizada a reclamação em paralelo com a interposição do recurso cabível contra a decisão que desrespeitou o precedente, devendo ser a reclamação julgada mesmo se o recurso interposto vier a ser inadmitido ou julgado no mérito.

Assim, é correto afirmar que, nos termos do art. 988, §6º, CPC, poderá ser ajuizada a reclamação **em paralelo** com a interposição do recurso cabível em face da decisão que desrespeitou o precedente, na medida em que se trata de instrumentos processuais distintos e autônomos. Nessa

³⁹⁴ Nesse sentido: Rcl 35.958/CE, 2ª Seção, DJe 12/04/2019, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.



hipótese, deverá a reclamação ser julgada mesmo quando o recurso interposto vier a ser inadmitido ou julgado no mérito.

Por fim, anote-se que entende a doutrina³⁹⁵⁻³⁹⁶, majoritariamente, e a partir de uma interpretação a *contrario sensu* do art. 988, §5º, II, CPC (que se encontra nas hipóteses de inadmissibilidade da reclamação), que também é cabível a reclamação para **garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida** ou de **acórdão proferido em recursos especial ou extraordinário repetitivos**, desde que tenha havido o esgotamento das instâncias ordinárias.

Isso significa dizer, por exemplo, que se a sentença **aplicar inadequadamente um precedente formado em recurso especial repetitivo**, deverá a parte: (i) interpor recurso de apelação; (ii) se o acórdão do TJ ou TRF mantiver a sentença, deverá interpor recurso especial; (iii) após a negativa de seguimento do recurso com base no art. 1.030, I, “b”, CPC, deverá interpor agravo interno (art. 1.030, §2º, CPC); (iv) após o desprovimento pelo próprio TJ ou TRF, será cabível a reclamação ao STJ.

A questão relacionada ao cabimento, ou não, da reclamação constitucional pela negativa ou má aplicação de precedente formado em recurso extraordinário com repercussão geral ou em recursos excepcionais repetitivos (art. 988, §5º, II, CPC), foi julgada pelo STJ, que entendeu não ser cabível a reclamação constitucional para controle de aplicação de precedentes³⁹⁷.

10. 2.2. RECLAMAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO

Nos termos do art. 988, §5º, I, CPC, é inadmissível a reclamação quando proposta **após o trânsito em julgado da decisão reclamada**. O dispositivo legal positiva o conteúdo da Súmula 734/STF³⁹⁸.

Conquanto não haja prazo legal ou regimental para o ajuizamento da reclamação, a referida regra estabelece um óbice intransponível para a propositura da medida, a saber, que seja ela ajuizada antes do trânsito em julgado. Anote-se, a esse respeito, que, *“quando a reclamação é proposta antes do trânsito em julgado, a mesma não será obstaculizada pela inadmissibilidade ou desprovimento do recurso interposto”*, na medida em que *“a reclamação apresentada antes do trânsito em julgado, impugnando determinada decisão, impede a formação da coisa julgada, pois mantém o estado de pendência quanto à decisão que subjaz como objeto”*³⁹⁹.

10.2.3. PROCEDIMENTO

Caso a reclamação receba juízo positivo de admissibilidade, será designado relator que, ao despachá-la, tomará as providências previstas no art. 989, I a III, CPC: (i) requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez)

³⁹⁵Por exemplo: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2017. p. 905/906; ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.575/1.576; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.748/1.749.

³⁹⁶**Enunciado 138 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF:** *“É cabível reclamação contra acórdão que aplicou indevidamente tese jurídica firmada em acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, após o esgotamento das instâncias ordinárias, por analogia ao quanto previsto no art. 988, § 4º, do CPC”*.

³⁹⁷Nesse sentido: Rcl 36.476/SP, Corte Especial, j. 05/02/2019 (acórdão pendente de publicação), rel. Ministra Nancy Andrighi.

³⁹⁸**Enunciado 734/STF:** *“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”*.

³⁹⁹GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2017. p. 909.



dias; (ii) se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (iii) determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá 15 dias para apresentar a sua contestação.

De igual modo, qualquer interessado poderá impugnar o pedido formulado pela parte na reclamação (art. 990, CPC). Na hipótese de o Ministério Público não ser o reclamante, a ele será dada vista após serem prestadas as informações e formado o contraditório (art. 991, CPC).

Finalmente, se julgada procedente a reclamação, o Tribunal cassará a decisão que exorbita a sua competência ou determinará medidas adequadas para a solução da controvérsia (art. 992, CPC), que deverão ser, inclusive, cumpridas de imediato e independentemente da lavratura do acórdão *a posteriori* (art. 993, CPC).

- Pedido de suspensão de segurança, suspensão de liminar ou suspensão do cumprimento de tutela

Trata-se de pedido formulado no âmbito dos Tribunais, por meio do qual se objetiva **suspender o cumprimento de determinada decisão** judicial proferida em desfavor da Fazenda Pública.

Embora tenha sido criado especificamente para o mandado de segurança – o que justifica, inclusive, a denominação inicial de suspensão de segurança, fato é que o mecanismo foi sendo, ao longo do tempo, incorporado por inúmeras legislações especiais (por ex., art. 12, §1º, Lei 7.347/1985; art. 4º, Lei 8.437/1992; art. 1º, Lei 9.494/1997; art. 16, Lei 9.507/1997; art. 15, Lei 12.016/2009; art. 1.059, CPC)⁴⁰⁰. Atualmente, não há dúvida de que é cabível o pedido em quaisquer processos judiciais nos quais seja proferida decisão contra a Fazenda Pública, criando-se, inclusive, uma espécie de **microssistema de suspensão de tutelas**.

A despeito da divergência acerca da **natureza jurídica** do pedido de suspensão (se natureza recursal, administrativa, incidental, de exceção em sentido estrito ou cautelar), fato é que o propósito do instituto é, mediante a **sustação da produção de efeitos do pronunciamento** jurisdicional, impedir que haja lesão à Fazenda Pública.

O pedido de suspensão **não é mecanismo apto a reformar ou invalidar** a decisão judicial. É por isso, inclusive, que a **decisão que defere o pedido não é rescindível**, pois não há a formação de coisa julgada material e tampouco se impede que o objeto controvertido seja rediscutido na ação principal⁴⁰¹.

O rol de **legitimados** a formular o pedido de suspensão é bastante amplo, compreendendo, por exemplo, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas autarquias e fundações públicas, as agências reguladoras, os entes públicos despersonalizados (como uma Câmara de Vereadores) e o Ministério Público⁴⁰².

A **competência** para apreciação do pedido de suspensão será do Presidente do Tribunal ao qual estiver vinculado o julgador que proferiu a decisão potencialmente lesiva à Fazenda Pública. Assim, se proferida por juiz estadual, caberá o exame ao Presidente do respectivo TJ e se proferida por juiz federal, caberá o exame ao Presidente do respectivo TRF. Se, entretanto, a decisão houver sido proferida por membro de TJ ou de TRF, o pedido deverá ser formulado ao Presidente do STJ ou do STF, a depender da matéria ser de índole infraconstitucional ou constitucional (art. 25, Lei 8.038/1990).

⁴⁰⁰DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 805/808.

⁴⁰¹Nesse sentido: AR 5.857/MA, Corte Especial, DJe 15/08/2019, rel. Ministro Mauro Campbell Marques.

⁴⁰²DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 810/811.

Do ponto de vista **procedimental**, anote-se que o ente público interessado deverá formular o pedido de suspensão com a demonstração das circunstâncias atinentes ao caso e das razões pelas quais a decisão deverá ser suspensa, especialmente sob a perspectiva do **risco de lesão à saúde, economia, segurança ou ordem pública** (art. 4º, *caput*, Lei 8.437/1992) e da **plausibilidade do direito invocado** (art. 4º, §7º, Lei 8.437/1992).

Recebido o pedido, poderá o Presidente do Tribunal determinar que seja **emendada a petição** do pedido de suspensão (com a prestação de informações adicionais, esclarecimentos, etc.), **indeferir o pedido** de suspensão por não vislumbrar o alegado risco de lesão, determinar a **prévia manifestação** da parte adversa e do Ministério Público em **72 horas** ou, ainda, **liminarmente deferir a suspensão**.

Da decisão que **deferre** ou **indeferre** o pedido de suspensão, caberá **agravo interno**, a ser julgado pelo Plenário ou Corte Especial. A despeito de o art. 4º, §3º da Lei 8.437/1992 prever que o recurso deverá ser interposto em 5 dias, é correto afirmar que a regra foi revogada pelo art. 1.070, CPC, que **uniformizou em 15 dias** o prazo para a interposição de quaisquer recursos de agravo.

A sustação dos efeitos da decisão, em regra, **vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na ação principal** (art. 4º, §9º, Lei 8.437/1992), ressalvada, contudo, a hipótese de pedido de suspensão de segurança, em que há disciplina própria trazida pela Súmula 626/STF⁴⁰³.

Reforçando a **autonomia** e a **distinção** de objetivos entre o pedido de suspensão e o recurso, sublinhe-se, ademais, que a **interposição de agravo de instrumento** contra liminar concedida em ação movida em face da Fazenda Pública **não prejudica e nem condiciona o julgamento** do pedido de suspensão (art. 4º, §6º, Lei 8.437/1992). Isso porque, no recurso, o debate se cingirá ao erro de procedimento ou de julgamento contido na decisão recorrida (há aptidão para invalidação ou reforma), ao passo que o pedido de suspensão, que se reveste de nítida natureza acautelatória, limita-se à suspensão da produção de efeitos da decisão.

Finalmente, em homenagem à celeridade e à segurança jurídica, existe a possibilidade de **extensão dos efeitos da decisão que deferre o pedido de suspensão**, mediante simples aditamento do pedido original, na hipótese de superveniência de liminares acerca do mesmo objeto (art. 4º, §8º, Lei 8.437/1992).

10.2.4. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, é correto afirmar que todo e qualquer julgador possui o poder-dever de examinar a constitucionalidade da norma em que se fundamenta a pretensão ou a defesa da causa que lhe é submetida, podendo afastá-la, se o caso, como questão prejudicial ao mérito.

Se, em 1º grau de jurisdição, não há procedimento específico para a declaração incidental de inconstitucionalidade de norma, fato é que, em 2º grau, estabeleceu-se modelo próprio para o exercício do controle difuso de constitucionalidade pelos Tribunais, que estão obrigados a respeitar a denominada **cláusula de reserva de plenário** (art. 97, CF/88) e o procedimento específico instituído pelos arts. 948 a 950, CPC.

No âmbito dos Tribunais, arguida a inconstitucionalidade, deverá o relator do processo ou recurso, após oitiva do Ministério Público e das partes, submeter a questão ao órgão fracionário

⁴⁰³Súmula 626/STF: “A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigora até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”.

competente para julgá-lo (art. 948, *caput*, CPC), a fim de que lá se proceda ao juízo de admissibilidade do incidente.

Se **rejeitada a arguição**, o julgamento da causa ou recurso terá prosseguimento (art. 949, I). Uma das hipóteses de inadmissão do incidente ocorre, justamente, quando **já houver pronunciamento** sobre a questão do **plenário ou órgão especial do Tribunal** ou, ainda, do **plenário do STF** (art. 949, parágrafo único, CPC).

Se, todavia, o **incidente receber juízo positivo de admissibilidade** (ou seja, se houver a conclusão do órgão fracionário de que, em tese, a lei poderá ser declarada inconstitucional), o processo será remetido ao pleno ou ao órgão especial para o efetivo exame da inconstitucionalidade arguida (art. 949, II, CPC).

Ato contínuo, o acórdão lavrado pelo órgão fracionário que admitiu o incidente será encaminhado a todos os julgadores que comporão o pleno ou órgão especial (art. 950, *caput*, CPC) e, ainda preparatoriamente ao julgamento, será **admitida**, na forma do art. 950, §1º a §3º, CPC, a **manifestação**: (i) da pessoa jurídica de direito público que editou o ato questionado; (ii) de todos os legitimados a ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade (art. 103, I a IX, CF/88), mediante manifestação escrita, memoriais e juntada de documentos; (iii) a manifestação de outros órgãos e entidades, na condição de *amicus curiae*.

No incidente de arguição de inconstitucionalidade, há **cisão de competência**, na medida em que o órgão especial ou pleno **somente se pronunciará sobre a inconstitucionalidade** da lei ou ato, declarando-a incompatível com o texto constitucional, se o caso, pela maioria absoluta.

Todas as **demais questões versadas na causa permanecem afetas ao órgão fracionário** e somente serão examinadas após a decisão do incidente, ocasião em que o processo retornará ao referido órgão fracionário, o que explica, inclusive, o conteúdo da Súmula 513/STF e o cabimento de recurso apenas quando houver a complementação do julgamento no órgão fracionário⁴⁰⁴, ressalvada a **possibilidade de oposição de embargos de declaração** em face do acórdão que resolver o incidente⁴⁰⁵.

Finalmente, registre-se que o recurso extraordinário em que se impugne o acórdão de órgão fracionário que complementou o acórdão que julgou o incidente no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da norma possuirá **presunção de repercussão geral**, na forma do art. 1.035, III, CPC.

QUESTÕES

1- No Superior Tribunal de Justiça, o relator está autorizado a negar provimento a recurso que contrarie:

- a) Súmula do STF ou STF e acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, apenas.
- b) Súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR e IAC e jurisprudência dominante do STJ.
- c) Súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em IRDR e IAC, apenas.
- d) Súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos e jurisprudência dominante do STJ, apenas.

⁴⁰⁴Súmula 513/STF: “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito”.

⁴⁰⁵NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.661.



2- É admissível a sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento dos recursos de:

- a) Apelação e agravo de instrumento, em qualquer hipótese.
- b) Apelação, rescisória, mandado de segurança e reclamação.
- c) Apelação, ordinário, especial e extraordinário.
- d) Apelação, embargos de declaração, embargos de divergência e ordinário.

3- Em julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito, obteve-se o seguinte resultado parcial: (i) por maioria, rejeitaram a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, vencido o relator, que a acolhia; (ii) por maioria, rejeitaram a preliminar de nulidade da decisão pelo indeferimento de prova testemunhal, vencido o 2º julgador, que a acolhia; (iii) por maioria, mantiveram a decisão quanto à improcedência do pedido, vencido o 2º julgador, que a reformava para julgar procedente o pedido. Diante desse cenário, é correto afirmar que incidirá a técnica de ampliação de colegiado criada pelo CPC/15 sobre:

- a) Todos os capítulos decisórios.
- b) Nenhum dos capítulos decisórios.
- c) Os capítulos decisórios preliminares (intempestividade e nulidade da decisão).
- d) O capítulo decisório de mérito (improcedência do pedido).

4- Em relação ao efeito suspensivo dos recursos, é correto afirmar que:

- a) A apelação sempre terá efeito suspensivo *ope legis*.
- b) O recurso especial nunca terá efeito suspensivo *ope legis*.
- c) O agravo de instrumento não admite a concessão de efeito suspensivo *ope judicis*.
- d) Os embargos de declaração admitem a concessão de efeito suspensivo *ope judicis*.

5- Em relação aos recursos cabíveis contra a decisão que inadmite um recurso excepcional, é correto afirmar que:

- a) Da decisão que inadmite o recurso extraordinário ao fundamento de que o STF já se pronunciou sobre a inexistência de repercussão geral da questão constitucional, cabe agravo em recurso extraordinário.
- b) Da decisão que inadmite o recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está conforme o entendimento do STF exarado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno.
- c) Da decisão que inadmite o recurso especial ao fundamento de que o acórdão recorrido está conforme o entendimento do STJ exarado em regime de julgamento de recurso especial repetitivo, cabe agravo em recurso especial.
- d) Da decisão que inadmite o recurso especial ao fundamento de que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ), cabe agravo interno.

6- Sobre a ação rescisória, é incorreto afirmar que:

- a) Apenas são rescindíveis as decisões de mérito.
- b) A cumulação do pedido rescindente e do pedido rescisório é desnecessária quando a ação rescisória se funda no art. 966, IV, CPC.
- c) É cabível a ação rescisória fundada em distinção entre a decisão rescindenda e o precedente que lhe serviu de fundamento.
- d) É admissível a ação rescisória fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: B

Letra A (incorreta). Alternativa não contempla entendimento firmado em IRDR e IAC (art. 932, IV, “c”, CPC), tampouco jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ).

Letra B (correta). Nos termos do art. 932, IV, CPC, e Súmula 568/STJ.

Letra C (incorreta). Alternativa não contempla jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ).

Letra D (incorreta). Alternativamente não contempla entendimento firmado em IRDR e IAC (art. 932, IV, “c”, CPC).



2. Gabarito: C

Letra A (incorreta). No agravo de instrumento, apenas é admissível a sustentação oral no agravo que verse sobre tutela provisória, nos termos do art. 937, VIII, CPC.

Letra B (incorreta). Rescisória, mandado de segurança e reclamação não são recursos, mas, sim, ações autônomas de impugnação (vide, respectivamente, art. 966, art. 988 e Lei 12.016/2009).

Letra C (correta). Nos termos do art. 937, I, II, III e IV, CPC.

Letra D (incorreta). É inadmissível a sustentação oral em embargos de declaração, não constante da lista do art. 937, CPC.

3. Gabarito: B

Letra A (incorreta). No agravo de instrumento que impugne decisão parcial de mérito, a técnica de julgamento apenas incidirá quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, nos termos do art. 942, §3º, II, CPC.

Letra B (correta). No agravo de instrumento que impugne decisão parcial de mérito, a técnica de julgamento apenas incidirá quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, nos termos do art. 942, §3º, II, CPC.

Letra C (incorreta). No agravo de instrumento que impugne decisão parcial de mérito, a técnica de julgamento apenas incidirá quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, nos termos do art. 942, §3º, II, CPC.

Letra D (incorreta). No agravo de instrumento que impugne decisão parcial de mérito, a técnica de julgamento apenas incidirá quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, nos termos do art. 942, §3º, II, CPC.

4. Gabarito: D

Letra A (incorreta). Há hipótese em que a apelação não possuirá efeito suspensivo *ope legis*, conforme art. 1.012, §1º, I a VI, CPC.

Letra B (incorreta). Há hipótese em que o recurso especial terá efeito suspensivo *ope legis*, conforme art. 987, §1º, CPC.

Letra C (incorreta). É admissível a concessão de efeito suspensivo *ope judicis* no agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, CPC.

Letra D (correta). É admissível a concessão de efeito suspensivo *ope judicis* nos embargos de declaração, na forma do art. 1.026, §1º, CPC.

5. Gabarito: B

Letra A (incorreta). Na hipótese, o recurso cabível é o agravo interno e não o agravo em recurso extraordinário (art. 1.030, I, “a”, 1ª parte e §2º, CPC).

Letra B (correta). Na hipótese, o recurso cabível é mesmo o agravo interno (art. 1.030, I, “a”, 2ª parte e §2º, CPC).

Letra C (incorreta). Na hipótese, o recurso cabível é o agravo interno e não o agravo em recurso extraordinário (art. 1.030, I, “b” e §2º, CPC).

Letra D (incorreta). Na hipótese, o recurso cabível é o agravo em recurso especial (arts. 1.030, §1º, e 1.042, *caput*, CPC).

6. Gabarito: A

Letra A (incorreta). Há hipóteses em que se admite a ação rescisória contra decisão transitada em julgado que não seja de mérito, desde que impeçam a repropositura da ação ou a admissibilidade do recurso correspondente (art. 966, §2º, I e II, CPC).

Letra B (correta). Na forma do art. 968, I, CPC, a cumulação ocorrerá “se for o caso” e, na hipótese de conflito de coisas julgadas, a rescisória apenas pretende extirpar a coisa julgada que se formou em segundo lugar.

Letra C (correta). Nos termos do art. 966, V e §5º, CPC.

Letra D (correta). Nos termos do art. 966, VI, CPC.

CAPÍTULO 17 — PROCESSO COLETIVO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para melhor compreensão da tutela coletiva de direitos e, consequentemente, do processo coletivo, é preciso destacar que, conquanto a tutela jurisdicional tenha sido historicamente pensada sob a perspectiva **individual**, uma nova realidade global, em que litígios seriados, repetitivos e massificados se tornaram absolutamente corriqueiros, passou a reunir pessoas ou segmentos da sociedade em torno de interesses comuns. Dessa forma, exigiu-se, por óbvio, que os direitos material e processual se conformassem para atender às lesões decorrentes dessa nova configuração.

Os interesses ou direitos tutelados a partir desse modelo podem ser classificados em **difusos**, **coletivos *stricto sensu*** e **individuais homogêneos** (art. 81, parágrafo único, I a III da Lei nº 8.078/1990 – CDC).

Os **direitos ou interesses difusos** são aqueles que dizem respeito a uma parcela indeterminada de pessoas, ligadas a uma mesma circunstância de fato, que são atingidas em seus direitos de natureza indivisível (aditem fruição e aproveitamento coletivo, mas com interessados dispersos). Essas características tornam impossível dizer quantos e quais são os interessados, motivo pelo qual são indetermináveis. São exemplos disso um meio-ambiente ecologicamente equilibrado e o patrimônio histórico de um povo.

Por outro lado, os **direitos ou interesses coletivos *stricto sensu*** também possuem como característica a indivisibilidade, mas possuem interessados determinados a partir de uma relação jurídica base (vínculo jurídico, não fático). Embora com dimensão metaindividual, é possível identificar a coletividade ou o grupo interessado. São exemplos disso lesões causadas especificamente aos médicos, aos colaboradores de uma fábrica, aos alunos de uma escola etc.

Finalmente, a característica marcante dos **direitos ou interesses individuais homogêneos** é a divisibilidade, ou seja, podem ser especificamente atribuídos e quantificados aos seus respectivos titulares. São interesses individuais unidos em virtude de uma origem comum — por exemplo, grandes acidentes aéreos ou náuticos.

Para tutelar essa gama de direitos e interesses, é preciso buscar soluções adequadas e especificamente delineadas pelo legislador para essa finalidade, como na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), na Lei nº 7.437/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e na Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), que compõem, em conjunto com outras normas (Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Mandado de Segurança, Estatuto da Criança e do Adolescente etc.), o microsistema processual coletivo brasileiro, norteado e interpretado a partir de alguns princípios específicos.

2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO COLETIVO

O **princípio do microsistema** orienta que o intérprete busque as soluções apropriadas ao litígio coletivo nas normas que compõem o microsistema de tutela coletiva, devendo recorrer ao CPC apenas residualmente, nas hipóteses em que aquele microsistema for omissor. Significa dizer, pois, que há uma relação de **prevalência**, e não de diálogo propriamente dito, entre as normas de tutela coletiva e a legislação processual geral.

De acordo com o **princípio da participação**, deve ser densificada, no processo coletivo, a participação da sociedade, justamente em razão da tutela de direitos que dizem respeito a uma gama de pessoas ou a segmentos sociais que, no processo, serão representados pelos **legitimados** a propor ações coletivas. Esses, por sua vez, deverão ser **representantes adequados** e **aptos ao**

exercício do contraditório em nome de todos os titulares de direitos ou interesses coletivos. Trata-se, pois, de um instrumento de realização da democracia participativa.

O **princípio da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo** possui umbilical ligação com o princípio da instrumentalidade das formas e com as regras de sanabilidade dos vícios processuais e de primazia da resolução de mérito, de modo que, **com muito mais razão**, deve ser superado, no processo coletivo, o apego ao formalismo ensimesmado, afastando-se a incidência de regras técnicas que não comprometam o exame do mérito da tutela veiculada na ação coletiva.

Finalmente, o **princípio da indisponibilidade da demanda coletiva** estabelece que, diferentemente do que ocorre no processo individual, regido pelo princípio da disponibilidade, no processo coletivo não há que se falar em prevalência da vontade individual e particular. Em vez disso, é preciso falar em supremacia do interesse público qualificada pela propositura da ação coletiva pelo legitimado (se assim entender viável), permitindo-se ao indivíduo, contudo e em respeito ao desejo particular, que eventualmente não exerça o direito coletivo tutelado a que faz jus e não execute a sentença coletiva que lhe é benéfica.

3. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE

Em regra, a **competência** para processamento da ação coletiva será do local onde ocorreu o dano, tendo o juízo competência **funcional** (logo, **absoluta**) para a causa e, a partir da propositura, atrai a **prevenção** (e, conseqüentemente, a reunião) de todos os demais feitos relacionados (art. 2º, *caput* e parágrafo único da Lei nº 7.347/1985).

Anote-se que, **em ação popular**, a jurisprudência do STJ se consolidou, no sentido de que são igualmente competentes o juízo do domicílio do autor popular e o do local onde houver ocorrido o dano (local do fato). Dessa forma, a competência para examinar o feito é daquele que apresentar menor dificuldade para o exercício da ação popular, **ressalvada a hipótese de ação popular concorrente à ação civil pública com objeto semelhante**, caso em que a competência será do **local do fato**⁴⁰⁶.

A legitimação ativa para ajuizamento de ações coletiva será: (i) do **Ministério Público**, inclusive em litisconsórcio ativo entre Ministério Público Estadual e Federal (se não for autor, o Ministério Público deverá atuar como fiscal do ordenamento jurídico); (ii) da **Defensoria Pública**; (iii) da **União, Estado, Distrito Federal e Município**, bem como **autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista**, podendo, se não forem autores, ser litisconsortes dos demais legitimados; (iv) de **associação constituída há 1 (um) ano** e que possua a proteção do bem jurídico tutelado em sua finalidade institucional, ressaltando-se, quanto ao prazo, a dispensa em razão do interesse social decorrente da dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser tutelado (art. 82, I a IV e §1º do CDC).

4. LITISPENDÊNCIA

A partir da leitura dos arts. 95 e 104, ambos do CDC, pode-se afirmar que **não haverá coisa julgada e litispendência entre ação coletiva e individual**, seja em razão das diferenças encontradas entre os sujeitos (coletividade a princípio não identificada vs. indivíduos identificados), seja em função dos pedidos (genérico x específico), seja porque é direito do indivíduo renunciar à jurisdição coletiva, manejando a sua pretensão pela via individual, de modo que a sentença coletiva não lhe beneficiará e tampouco lhe prejudicará (*right to opt out*).

Havendo **concorrência entre ações coletivas sobre o mesmo objeto**, não há que se falar em extinção dos processos posteriores sem resolução do mérito, seja diante da possibilidade de

⁴⁰⁶ Nesse sentido: CC 164.362/MG, 1ª Seção, DJe 19/12/2019, rel. Ministro Herman Benjamin.



figurarem partes diferentes nos polos, seja porque, em se tratando de demanda coletiva, devem ser aproveitados os fundamentos e provas colacionadas pelos autores das ações, razão pela qual a solução mais adequada é a reunião das ações coletivas para processamento simultâneo, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985.

5. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS

Entendendo haver previsão legal específica (art. 19, §1º da Lei nº 4.717/1965) e autorização legal de cabimento (art. 1.015, XIII, CPC), o STJ se posicionou no sentido de que **todas as decisões interlocutórias proferidas em ação popular são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento**. Isso se dá com o fundamento de que *“as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microsistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (...) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral”*⁴⁰⁷.

Justamente por pertencer ao mesmo microsistema, tendo de ser interpretado a partir da mesma *ratio*, o STJ se posicionou, ademais, no sentido de que a regra do art. 19, §1º da Lei nº 4.717/1965, conquanto prevista apenas para a hipótese de ação popular, também se aplica às ações civis públicas. Também, por essa razão **todas as decisões interlocutórias proferidas em ação popular são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento**⁴⁰⁸ nas ações civis públicas.

6. COISA JULGADA

A coisa julgada na ação coletiva possui uma série de especificidades em relação à coisa julgada que se forma nas ações individuais.

De início, é preciso ressaltar que, quando havia apenas a Lei da Ação Popular e a Lei da Ação Civil Pública (isto é, antes do advento do CDC em 1990), a coisa julgada nas ações coletivas se formava ***secundum eventum probationis***, de modo que, na hipótese de improcedência da ação por insuficiência probatória, não se operaria a coisa julgada material, viabilizando-se, pois, o ajuizamento de nova ação, desde que com base em nova prova.

Após o CDC, quis o legislador adotar uma fórmula para a coisa julgada que também tivesse aptidão para solucionar questões relacionadas aos efeitos da ação coletiva sobre as demandas individuais. Daí, então, a coisa julgada passou a se formar, na ação coletiva, ***secundum eventum litis***, ou seja, somente haverá coisa julgada, em relação às demandas individuais, quando a coletiva for **procedente**, sempre para beneficiar, mas nunca para prejudicar (chamada **coisa julgada in utillibus**, art. 103, §3º, CDC).

Desse modo, se a ação individual for anterior à coletiva, o autor, para se beneficiar da sentença a ser proferida na ação coletiva, deverá requerer expressamente a suspensão da ação individual, em **até 30 dias após a comunicação pelo réu sobre a existência da ação coletiva**, sob pena de não poder dela se utilizar (art. 104, CDC).

É importante examinar, ainda, a coisa julgada e os direitos e interesses em discussão nas **ações de consumo** (art. 103, I e III, CDC).

Na hipótese de **interesse difuso**, a coisa julgada é ***erga omnes***, salvo se a improcedência decorrer de insuficiência de prova, caso em que qualquer legitimado poderá propor outra ação com base em nova prova. Nesse caso, porém, os efeitos da coisa julgada não prejudicarão os interesses individuais dos integrantes da coletividade.

⁴⁰⁷ Nesse sentido: AgInt no REsp 1.733.540/DF, 1ª Turma, DJe 04/12/2019, rel. Ministro Gurgel de Faria.

⁴⁰⁸ Nesse sentido: REsp 1.828.295/MG, 1ª Turma, DJe 20/02/2020, rel. Ministro Sérgio Kukina.



Quando se tratar de **interesse coletivo**, a coisa julgada é **ultra partes**, limitada ao grupo, categoria ou classe, salvo se a improcedência decorrer de insuficiência de prova, caso em que qualquer legitimado poderá propor outra ação com base em nova prova; Porém, os efeitos da coisa julgada não prejudicarão os interesses individuais dos integrantes do grupo, categoria ou classe.

Por sua vez, na hipótese de **interesse individual homogêneo**, a coisa julgada é *erga omnes*, somente no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas. Se for improcedente o pedido, o interessado que não tiver participado do processo como litisconsorte poderá propor ação individual.

Finalmente, conquanto o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública estabeleça que a sentença proferida em ações civis públicas apenas terá eficácia nos limites do território em que proferida, de modo que apenas indivíduos daquela localidade poderiam dela se beneficiar, não se pode olvidar que há precedente do STJ em sentido contrário, *“porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo”*⁴⁰⁹.

7. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS COLETIVAS

Versando o processo coletivo sobre direito individual homogêneo, o titular a quem a sentença beneficie poderá promover a liquidação do julgado para quantificação de seus prejuízos, de modo a viabilizar futura execução (art. 97, *caput*, CDC).

Se, porventura, não for iniciada, no **prazo de 1 ano**, a liquidação ou a execução pelos titulares de direito individual homogêneo que experimentaram o prejuízo, poderão os legitimados do art. 82, CDC (Ministério Público; Defensoria Pública; União, Estado, Distrito Federal e Município, bem como suas respectivas autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista; associações constituídas há 1 ano) promover, subsidiariamente, a liquidação ou execução (***fluid recovery***), caso em que os valores serão revertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (art. 100, parágrafo único, CDC, e art. 2º, III, do Decreto 1.306/1994).

Em se tratando de ações coletivas, a execução deverá ser promovida pela associação autora e, subsidiariamente, caso essa não o faça em **60 dias contados do trânsito em julgado**, pelo Ministério Público ou pelos demais legitimados (art. 15 da Lei nº 7.347/1985).

⁴⁰⁹ Nesse sentido: REsp 1.243.887/PR, Corte Especial, DJe 12/12/2011, rel. Ministro Luis Felipe Salomão.



CAPÍTULO 18 — JUIZADOS ESPECIAIS

1. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1.1. INTRODUÇÃO

O art. 98, I, da Constituição Federal, prevê a possibilidade da União e dos Estados criarem Juizados Especiais, sendo estes compostos por juízes togados ou por juízes togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e de infrações de menor potencial ofensivo.

Regulamentando o mandado constitucional, foram publicadas as Leis n^{os}. 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09, que tratam, respectivamente, dos Juizados Especiais Estaduais, Federais e da Fazenda Pública.

1.2. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

Nos processos que tramitam perante o Juizado Especiais, apenas o rito sumaríssimo pode ser empregado, sendo excluído todos os demais, ainda que se trate de procedimento especial.

1.3. CRITÉRIOS ADOTADOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

O art. 2º prevê que os Juizados Especiais devem buscar, sempre que possível, a conciliação ou a transação, devendo observar os critérios da:

- **Oralidade:** visa assegurar a solução das demandas de uma forma mais ágil e mais equitativa;
- **Simplicidade:** o desenvolvimento do processo perante os Juizados Especiais deve se dar de maneira facilitada;
- **Informalidade:** busca tornar o procedimento especial mais simples;
- **Economia processual:** diz respeito a obtenção, em juízo, do máximo resultado com o mínimo de esforço;
- **Celeridade:** princípio constitucional que visa assegurar aos jurisdicionados a pronta tutela jurisdicional.

1.4. COMPETÊNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS

O art. 3º da Lei estabelece que será da competência dos **Juizados Especiais Estaduais** as causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

- As causas cujo conteúdo econômico não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos;
- As causas enumeradas no art. 275, inciso II, do CPC/73⁴¹⁰;

⁴¹⁰Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

(...)

II - nas causas, qualquer que seja o valor;

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio;

c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;

d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;



- Ação de despejo para uso próprio;
- Ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários mínimos.

A previsão relativa ao CPC/73 continua plenamente vigente, conforme disposto no artigo 1.063 do CPC/15⁴¹¹. Trata-se de uma hipótese de ultratividade da lei processual revogada.

A Lei 10.259/01, em seu art. 3º, diz que compete ao **Juizado Especial Federal Cível** processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal **até o valor de 60 salários mínimos**, bem como executar as suas sentenças.

Há ainda um rol de matérias (taxativo) que não podem ser abordadas nos **Juizados Especiais Federais**, tais como:

- As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
- As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
- A disputa sobre direitos indígenas;
- As ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
- Sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
- Anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;
- Que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Em relação ao **Juizado Especial da Fazenda Pública** estabelece-se que, a ele, compete julgar as demandas que **não ultrapassem 60 salários mínimos**, mas com restrição de algumas matérias.

Não serão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

- Ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
- As causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
- As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução;

f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;

g) que versem sobre revogação de doação;

h) nos demais casos previstos em lei.

⁴¹¹**Art. 1.063.** Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.



1.5. OPÇÃO ENTRE O JUÍZO CÍVEL ESTADUAL E O JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL

A Lei n. 9.099/95, em seu artigo 3º, §3º, prevê a possibilidade de o demandante optar pelo Juízo Cível ou Juizado Especial, desde que, optando por este último, renuncie ao crédito que ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos, excetuada a hipótese de conciliação.

Esta possibilidade só existe no âmbito estadual, pois no **Juizado Especial Federal** e no **Juizado Especial Fazendário** a competência é absoluta, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei 10.259/01 e do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/09.

1.6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL

Já houve muita divergência, mas hoje o tema é pacífico entre os tribunais superiores (STF e STJ), inclusive através do enunciado da súmula 428 do STJ, estabelecendo que “**competete ao Tribunal Regional Federal** decidir conflito de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária”.

Se for conflito entre Juízo da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência será do **Tribunal de Justiça**, visto que se trata de competência estadual.

1.7. LEGITIMAÇÃO ATIVA E CAPACIDADE POSTULATÓRIA

1.7.1. JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS

Nos Juizados Especiais Estaduais serão legitimados para a propositura da ação:

- Pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de crédito de pessoa jurídica;
- Microempresas e as organizações civis de interesse público (OSCIP'S);
- Sociedades de crédito ao microempreendedor.

Além disso, a lei permite que haja litisconsórcio.

Não poderão ser legitimados ativos nos juizados especiais estaduais:

- Incapaz;
- Preso;
- Pessoas jurídicas de direito público;
- Empresas públicas da União;
- Massa falida;
- Insolvente civil.

Em relação aos **Juizados Especiais Estaduais**, nas causas de até 20 (vinte) salários mínimos, as partes podem propor ação sem advogado. Contudo, caso a parte queria recorrer ou apresentar contrarrazões recursais, a presença de advogado é obrigatória, independentemente do valor.

1.7.2. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E DA FAZENDA PÚBLICA

Nos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública, a legitimidade ativa é praticamente a mesma:

- Pessoas físicas;



- Microempresas e empresas de pequeno porte.

Observe-se que não há, aqui, restrição a demandas ajuizadas por incapazes ou por presos, motivo pelo qual a doutrina entende que poderiam ser propostas por estes.

Ademais, não é necessário que a petição inicial seja subscrita por advogado independentemente do valor envolvido. Caso haja recurso, será obrigatória a capacidade postulatória, devendo, assim, ser constituído causídico.

1.8. LEGITIMAÇÃO PASSIVA

1.8.1. JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS

Não podem ser legitimados passivos as pessoas que não podem figurar no polo ativo dos Juizados Especiais (ex.: preso e incapaz).

1.8.2. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Poderão ser legitimados passivos, ou seja, podem ser demandados nos juizados especiais federais:

- União, autarquias e fundações públicas e empresas públicas federais;
- Outros legitimados passivos, que não sejam os acima especificados, desde que venham a ocupar o polo passivo em litisconsórcio com a União, autarquias e fundações públicas e empresas públicas federais.

1.8.3. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

Poderão figurar no polo passivo:

- Estados, DF e municípios;
- Autarquias e fundações públicas e empresas públicas estaduais, distritais ou municipais.

1.9. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Não há intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, salvo a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de expressa autorização legal (art. 1.062, CPC).

1.10. PETIÇÃO INICIAL E PROCEDIMENTO PADRÃO

A petição inicial pode ser apresentada de forma oral ou de forma escrita.

Admite-se, ainda, a formulação de pedido genérico, já que está tratando de sujeito que não detém conhecimento técnico.

Atente-se que é vedado, como regra, a prolação de sentença ilíquida.

O procedimento da Lei 9.099/95 se dá da seguinte forma: o autor apresenta sua petição inicial → o réu é citado → é realizada uma audiência conciliação → não obtendo composição, é realizada a audiência de instrução e julgamento (oportunidade em que o réu apresentará sua contestação → o juiz profere sentença.



Nos **Juizados Especiais da Fazenda** e nos **Juizados Especiais Federais** é observado o seguinte **procedimento**, ainda que não previsto em lei, pois quando se está litigando contra a fazenda pública são raros os casos em que será possível a conciliação.

Por conta disso, o procedimento ocorrerá da seguinte forma: autor apresenta sua petição inicial → a Fazenda Pública é citada para responder em 30 (trinta) dias → após a apresentação da resposta fazendária, é realizada audiência de instrução e julgamento, se houver a necessidade de instrução probatória (do contrário, ela não será realizada) → o juiz profere sentença.

Em 31 de outubro de 2018, a Lei n. 13.728/2018 inseriu o artigo 12-A à Lei n. 9.099/95 para estabelecer que, na contagem de prazo para a prática de qualquer ato processual perante os Juizados Especiais, inclusive para a interposição de recursos, serão computados somente os dias úteis.

1.11. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A Lei 9.099/95 não faz alusão quanto à possibilidade de provimentos antecipatórios.

Por sua vez, a Lei n. 10.259/01 e a Lei n. 12.153/09 preveem a possibilidade de requerimento de provimentos de urgência. **Nos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública, as tutelas de urgência podem ser concedidas e serão impugnadas eventualmente através de recursos.**

Em relação ao **Juizado Especial Estadual**, decisão interlocutória não admite recurso. Portanto, ainda que o magistrado entenda pelo cabimento da antecipação da tutela provisória de urgência seja concedida ou revogada. No entanto, se houver inconformismo da parte, **não caberá recurso.**

Há doutrina que defende que esta impugnação pode ser feita por meio de **mandado de segurança**. Todavia, há decisão do STF no sentido de que nem mesmo o mandado de segurança pode ser empregado, pois não seria competência da Turma Recursal, considerando o fato de que esta turma possui competência para recursos e não para ações autônomas de impugnação.

1.12. CITAÇÃO

A citação pode ser realizada por meio postal e por oficial de justiça. Existe, contudo, **proibição expressa de citação por edital**, visando manter a economia processual e a celeridade na prestação jurisdicional.

Cabe ressaltar que **a citação com hora certa é admissível**, em que pese também se trate de uma espécie de citação ficta.

1.13. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A parte é citada para comparecimento à audiência de conciliação. Caso não haja autocomposição, será designada audiência de instrução e julgamento. Lembre-se que, no início da audiência, o réu apresenta a sua resposta.

A audiência de conciliação será conduzida por um conciliador ou por um juiz leigo, tendo por objetivo que as partes cheguem a um consenso. Se o autor não comparecer ao ato, o processo será extinto. Se o réu não comparecer, será decretada sua revelia.

Ressalte-se que **é possível que a audiência de conciliação seja convertida imediatamente em audiência de instrução e julgamento**. Nesse caso, **é necessário que a conciliação não tenha sido obtida**, além de **ter constado do mandado de citação essa possibilidade**.



1.14. RESPOSTA DO RÉU

Não sendo frutífera a audiência de conciliação, o réu apresentará sua resposta no início da audiência de instrução e julgamento, podendo ela ser oral ou escrita.

De acordo com o enunciado n. 11 do FONAJE, “nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia”.

A legislação autoriza que o demandado faça **pedido contraposto** em sede de contestação, desde que fundado nos mesmos fatos firmados na petição inicial. Nesse caso, o réu estará exercendo o direito de ação. Dessa forma, é necessário verificar se o demandado possui ou não legitimidade ativa para atuar perante o Juizado Especial, pois do contrário o pedido contraposto não será cabível.

A **reconvenção não é cabível** nos Juizados Especiais, conforme previsão do art. 31 da Lei 9.099/95.

1.15. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Iniciada a audiência de instrução e julgamento, é apresentada a resposta pelo réu. Com isso, será iniciada a produção de prova, sendo admitida todas legítimas ou moralmente admissíveis nos Juizados Especiais.

Esse ato pode ser presidido por um **juiz togado** ou por um **juiz leigo** (desde que haja a supervisão de juiz togado). Nos Juizados Especiais Federais não existe a figura do juiz leigo, mas **a instrução pode ser realizada por um conciliador**.

Não existe obstáculo legal para que se produza prova pericial na Justiça Especializada, mas não se admite prova complexa. Caso haja necessidade de produção de prova que demande conhecimento técnico com o intuito de formar a convicção do juiz, ela não poderá ser formal, admitindo-se, via reflexa, somente a prova que esteja concentrada na realização de vistorias ou inspeções. A perícia informal é admissível, conforme enunciado n. 12 do FONAJE.

Em se tratando de matéria que envolva grande complexidade, sendo inviável, portanto, o prosseguimento do feito, deverá, o juiz, declará-lo extinto, sem enfrentamento do mérito.

Com relação à prova testemunhal, é possível que as partes arrolem **até 03 (três) testemunhas**, que deverão comparecer independentemente de intimação. Caso precise de intimação, deverá a parte requerer ao juiz tal providência. **Esse requerimento para intimação deve ser feito, no mínimo, com 5 (cinco) dias de antecedência da data da audiência de instrução e julgamento.**

A prova oral, em sede audiência de instrução e julgamento em Juizado Especial, **não precisa ser reduzida a termo.**

1.16. SENTENÇA

O relatório **pode ser dispensado** no Juizado Especial.

A sentença pode ser definitiva ou terminativa. Existem outras causas de extinção do feito previstas na própria Lei n. 9.099/95, como é o caso em que o autor deixa de comparecer à audiência de conciliação, situação em que o processo será extinto.

Também será extinto o feito quando for inadmissível o procedimento instituído ou quando for reconhecida a incompetência territorial. Veja, portanto, que há causas de extinção do processo que são próprias da Lei 9.099/95.

Destaca-se, ainda, que **são vedadas as sentenças ilíquidas**, ou seja, que não tragam o *quantum debeatur*.

1.17. RECURSO, AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO E INCIDENTES

1.17.1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No rito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, caberão embargos de declaração que poderão ser interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.

O CPC, em seu artigo 1.026, dispõe que o efeito deste meio de impugnação à decisão judicial é **interruptivo**, ou seja, interrompe o prazo recursal.

Deve-se destacar que os erros materiais podem ser corrigidos independentemente de provocação das partes ou da oposição de embargos de declaração.

1.17.2. RECURSO INOMINADO, AGRAVO INTERNO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

i. Recurso inominado

Da sentença proferida em Juizado Especial, qualquer que seja o seu teor, caberá o **recurso inominado**, no prazo de 10 (dez) dias.

No caso dos **Juizados Especiais Federais** há uma peculiaridade, pois o art. 5º da Lei n. 10.259/01 diz que, exceto nos casos do art. 4º, **somente será admitido o recurso inominado de sentença definitiva**. Isso quer dizer que em sede de Juizados Especiais Federais só será admitido o recurso inominado para impugnar a decisão interlocutória a respeito de tutela provisória ou para questionar sentença definitiva. **Se a sentença é terminativa em Juizados Especiais Federais não caberá recurso inominado**. Neste caso, o autor deverá propor uma nova ação.

Há um abrandamento dessa regra quando a decisão terminativa é de litispendência ou de coisa julgada. Nesse caso, a doutrina e jurisprudência admitem o recurso inominado.

O recurso inominado deverá ser proposto perante o próprio órgão prolator da decisão. Após, a parte recorrida é intimada para apresentar as contrarrazões. Na sequência o feito é remetido à Turma Recursal para julgamento.

O recurso inominado tem apenas efeito devolutivo.

ii. Agravo interno

Na Turma Recursal é admitido o julgamento. **Se este julgamento se dar através de decisão monocrática, será cabível agravo interno**.

iii. Recurso extraordinário

Da decisão da turma recursal, é possível a interposição de recurso extraordinário, tanto é possível que a súmula 640 do STF vai nesse sentido ao afirmar que “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”.

1.17.3. MANDADO DE SEGURANÇA, AÇÃO RESCISÓRIA E RECLAMAÇÃO

i. Mandado de segurança

O mandado de segurança é adotado com frequência perante turma recursal para impugnar decisão interlocutória. Há pelo menos três grandes óbices ao manejo desta ação constitucional:

- Proibição de utilizar perante o Juizado Especial procedimento diverso do sumaríssimo;
- A turma é recursal, razão pela qual deveria tratar de recurso e não de ação autônoma;
- O magistrado, quando é apontado como autoridade coatora, tem a prerrogativa de apresentar suas informações ao Tribunal, e não à turma recursal.

ii. Ação rescisória

Em relação à ação rescisória, existe vedação expressa ao seu manejo em qualquer processo que tramitar perante o Juizado Especial (art. 59 da Lei n. 9.099/95).

iii. Reclamação

Após, o advento do CPC/2015, a Resolução nº 12/2009, do STJ, foi revogada e substituída pela Resolução nº 03/2016 que, em seu art. 1º, restringiu o cabimento da reclamação dirigida ao STJ à hipótese de decisão de Turma Recursal Estadual (ou do DF) que contrariar jurisprudência do STJ consolidada em a) incidente de assunção de competência; b) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); c) julgamento de recurso especial repetitivo; d) enunciados das Súmulas do STJ; e) precedentes do STJ.

1.17.4. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

Esse tema é regulado pela lei dos Juizados Especiais Federais e pela lei que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública. O objetivo desse pedido de uniformização é **sanar divergência entre turmas recursais distintas, mas localizadas no mesmo âmbito de jurisdição**. Se nesse julgamento for contrariado um posicionamento sumulado ou dominante do próprio Tribunal (TRF ou TJ), cabe requerimento ao TRF ou TJ para que ele resolva essa controvérsia.

O outro caso ocorre quando há **turmas recursais divergentes, mas localizadas em territórios distintos**, situação na qual o incidente será dirimido por meio da **turma nacional de uniformização**. Se nesse julgamento for contrariado um **posicionamento sumulado ou dominante do STJ**, cabe **requerimento ao STJ para que ele resolva essa controvérsia**.

1.18. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL

Se estivermos diante de um cumprimento de sentença, o procedimento será o do art. 52 da Lei n. 9.099/95.

Para receber quantia certa em Juizado Especial, é imprescindível que haja **requerimento do interessado, que poderá ser verbal**, sendo dispensada a apresentação de planilha, com o valor atualizado e discriminado, podendo proceder desde logo à execução, sem que seja necessária nova citação.

Os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão realizados pelo próprio servidor do cartório dada a simplicidade.

Feito o requerimento pelo exequente, o executado é intimado para apresentar defesa. Embora o art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, faça referência aos “embargos”, estes devem ser vistos e tratados como “impugnação”. As matérias de defesa são restritas e o processamento se dá nos próprios autos, mediante simples intimação do executado.

Se a **execução por quantia certa for lastreada por título extrajudicial**, haverá um procedimento que passa a ser fixado pelo art. 53 da Lei 9.099/95. Neste procedimento, **a petição inicial deverá ser instruída com uma planilha** atualizada da dívida.

Após a realização da penhora, é designada uma audiência de conciliação, momento em que os embargos poderão ser oferecidos pelo executado.

Ressalte-se dois pontos em comuns entre a execução de título judicial e a execução de título extrajudicial, quando se está diante de uma obrigação de pagar:

- Caso o pedido formulado pelos embargos não seja acolhida, haverá o início da etapa de expropriação, conforme o CPC regula;
- Se não houver bens penhoráveis, haverá o fim da execução por extinção.

1.19. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E FAZENDÁRIO

1.19.1. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM TÍTULO JUDICIAL

Se a obrigação de pagar for reconhecida em título judicial, o art. 17 da Lei n. 10.259/01 e o art. 13 da Lei n. 12.153/09 **dispensa que haja requerimento da parte interessada pelo cumprimento da sentença**. Basta que aguarde o trânsito em julgado da decisão para que tenha início o seu cumprimento.

Se a devedora for a **União, autarquia ou a fundação na esfera federal**, será requisitado RPV (**requisição de pequeno valor**), que será encaminhado ao presidente do Tribunal. Todavia, se a devedora for **empresa pública federal**, o juiz, após transitar em julgado, expedirá um ofício para a empresa para que **efetue o depósito do valor devido em até 60 (sessenta) dias**.

Quando se tratar de Estado, Distrito Federal e Município, assim como as autarquias, fundações e empresas públicas estaduais, distritais e municipais, a forma como se dará a liquidação poderá ser regulada por outros atos normativos, a depender de cada Estado, visto que se trata de procedimento.

1.19.2. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Se a obrigação de pagar for reconhecida em título extrajudicial, lastreada em Juizado Especial Federal e Fazendário, deverá ser observado o mesmo art. 53 da Lei n. 9.099/95, naquilo que for compatível.

QUESTÕES

1. (TJ-RO/VUNESP) Com relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é correto afirmar:

- a) Caberá pedido de uniformização de interpretação quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito processual.
- b) É cabível reclamação ao Superior Tribunal de Justiça quando Turmas de diferentes estados interpretam de forma divergente preceitos de lei federal e quando a decisão recorrida estiver em contrariedade com súmula do citado tribunal superior.
- c) Tal qual a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, a Lei de regência proíbe expressamente o menor incapaz demandar como autor das demandas que lhe são submetidas.
- d) O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, será efetuado mediante intimação ao advogado público responsável pela representação jurídica do ente público.



e) Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência, a soma das 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

2. (TJ-AL/FCC) Nos Juizados Especiais Cíveis

- a) cabem recursos de suas sentenças a serem recebidos no efeito devolutivo e suspensivo como regra geral, não havendo assim execução provisória do julgado.
- b) não se admite, em seus processos, qualquer forma de intervenção de terceiro, assistência ou litisconsórcio.
- c) só se admitem ações possessórias sobre bens móveis, mas não sobre bens imóveis.
- d) em seus processos o mandato ao advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos poderes especiais.
- e) a prova oral será produzida na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requerida previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir o que considerar excessivo, impertinente ou protelatório.

3. (TJ-MT/VUNESP) Com relação aos Juizados Especiais, assinale a alternativa correta.

- a) Não poderão ser partes o incapaz, o preso, a massa falida, o insolvente civil e as sociedades de crédito ao microempreendedor.
- b) Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.
- c) É admissível a denúncia da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
- d) É cabível o incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência entre as decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito processual.
- e) No Juizado Especial Cível, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz.

4. (DPE-AL/CESPE) Caso não seja cumprida voluntariamente sentença transitada em julgado no âmbito do juizado especial cível,

- a) o interessado deverá solicitar, por escrito, a execução da sentença, sendo necessária nova citação.
- b) o juiz determinará ao vencido o imediato cumprimento da sentença, sob pena de aplicação de multa diária.
- c) o juiz procederá, de ofício, à execução da sentença.
- d) proceder-se-á desde logo à execução mediante solicitação do interessado, que poderá ser verbal, dispensada nova citação.
- e) não será admitida a execução da sentença no próprio juizado.

5. (TRF-4ª Região) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

Acerca dos Juizados Especiais Federais:

I. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.

II. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial, substitutivo de recurso.

III. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas e dos juizados especiais em geral.

- a) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
- b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
- c) Estão corretas todas as assertivas.
- d) Está incorreta apenas a assertiva II.
- e) Estão incorretas apenas as assertivas II e III.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito: E.

a) Art. 18, Lei n. 12.153/2009: Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

b) Não é cabível reclamação ao Superior Tribunal de Justiça apenas com base em divergência interpretativa. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil enumeram o rol de hipóteses em que será cabível a Reclamação, não estando presente entre elas a hipótese elencada na alternativa. Ademais, para a jurisprudência do STJ, não é cabível reclamação, tampouco pedido de uniformização de jurisprudência, ao Superior Tribunal contra acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública sob a alegação de que a decisão impugnada diverge de orientação fixada em precedentes do STJ (Rcl 22.033-SC).

c) A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não faz restrição a possibilidade de ajuizamento de demandas por incapazes ou presos, motivo pelo qual a doutrina entende que poderiam ser propostas por estes.

d) Art. 12, Lei n. 12.153/2009: O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo.

e) Art. 2º, *caput*, e §2º da Lei n. 12.153/2009: Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

2. Gabarito: E.

a) Como regra, o recurso no rito dos Juizados Especiais terá somente efeito devolutivo, sendo possível o cumprimento provisório do julgado. Contudo, o juiz poderá atribuir-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, conforme disposto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

b) Não obstante a previsão do art. 10 da Lei n. 9.099/95, dispondo a inadmissibilidade de intervenção de terceiros e de assistência nos Juizados Especiais, a lei adjetiva civil, em seu artigo 1.062, prescreve que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, modalidade de intervenção

regulamentada pelos artigos 133 a 137 do CPC, é aplicada aos processos de competência dos Juizados Especiais.

c) É admitida a propositura de ações possessórias sobre bens imóveis perante os Juizados Especiais, desde que o valor da causa não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, nos termos do artigo 3º, *caput*, incisos I e IV, da Lei n. 9.099/95.

d) Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais – artigo 9º, *caput*, e §3º da Lei n. 9.099/95.

e) Art. 33 da Lei n. 9.099/95: Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

3. Gabarito: B.

a) Nos termos do art. 8º, §1º, IV, da Lei n. 9.099/95, as sociedades de crédito ao microempreendedor possuem legitimidade ativa para a propositura de ação perante o Juizado Especial.

b) Art. 12 da Lei n. 9.099/95: Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

c) Art. 10 da Lei n. 9.099/95: Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.062, CPC).

d) O incidente de uniformização de jurisprudência era disciplinado pelo Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil de 2015 extinguiu o referido instituto e passou a prever o Incidente de Assunção de Competência (art. 947, CPC/2015).

e) De acordo com o art. 59 da Lei n. 9.099/95, não se admite ação rescisória nos Juizados Especiais.

4. Gabarito: D.

a) Art. 52, *caput*, e inciso IV, da Lei n. 9.099/95: Caso não seja cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado no âmbito do juizado especial cível e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação.

b) Não tendo sido cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, para que o juiz determine ao vencido o imediato cumprimento, faz-se necessária que tenha havido solicitação do interessado - art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95.

c) O juiz não poderá proceder, de ofício, à execução da sentença, visto que tal providência depende de solicitação do exequente - art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95.

d) Art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95: Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação.

e) Art. 52, *caput*, da Lei n. 9.099/95: A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil.

5. Gabarito: C.

Item I: Correto – nos termos da súmula 428 do STJ “competete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária”.

Item II: Correto – nos termos da súmula 376 do STJ “competete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

Item III: Correto –

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. Agravo a que se nega provimento (ARE nº 792.562/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2/4/14).

INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DEMORADORES DE LOTEAMENTO URBANO. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS COMUNS. MORADOR NÃO ASSOCIADO. O Juizado Especial Cível é competente para o processamento e o julgamento de ação proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de loteamento em face de morador não associado. (RMS 53.602-AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. É possível a impetração de Mandado de Segurança nos Tribunais Regionais Federais com a finalidade de promover o controle da competência dos Juizados Especiais Federais. Precedentes citados: RMS 17.524-BA, Corte Especial, DJ 11/9/2006; e AgRg no RMS 28.262-RJ, Quarta Turma, DJe 19/6/2013. RMS 37.959-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/10/2013.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA PARA FINS DE COMPETÊNCIA. DIVISÃO DO MONTANTE TOTAL PELO NÚMERO DE LITISCONSORTES. O valor da causa para fins de fixação da competência nos juizados especiais federais, na hipótese de existência de litisconsórcio ativo, deve ser calculado dividindo-se o montante pelo número de autores. Dessa forma, se as parcelas percebidas e as supostamente devidas a cada um dos litisconsortes for inferior a sessenta salários mínimos, prevalece a competência absoluta do Juizado Especial Federal Cível para o julgamento da lide (art. 3º da Lei n. 10.259/2001). Precedentes citados: AgRg no REsp 1209914/PB, DJe 14/2/2011; AgRg no CC 104714/PR, DJe 28/8/2009. REsp 1.257.935-PB, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18/10/2012.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO SUPERIOR TRIBUNAL DO JUSTIÇA – EDIÇÃO N. 89

1. O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
2. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada.
3. A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.
4. É da competência dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais.
5. É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada.
6. Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação.
7. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. (Súmula n. 428/STJ).
8. Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. (Súmula n. 376/STJ)
9. Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais ou Federais, respectivamente, excepcionando a hipótese de cabimento da Súmula n. 376/STJ.
10. Por força do art. 6º da Resolução n. 12/2009 do STJ*, são irrecorríveis as decisões proferidas pelo relator nas reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ. *A Resolução n. 12/2009 do STJ foi revogada pela Emenda Regimental n. 22 de 16 de março de 2016.
11. O prazo para o ajuizamento de reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizados Especiais inicia-se com a ciência, pela parte, do acórdão proferido pela Turma Recursal no julgamento do recurso nominado ou dos subsequentes embargos de declaração, e não da decisão acerca do recurso extraordinário interposto (art. 1º da Resolução n. 12/2009 do STJ*). *A Resolução n. 12/2009 do STJ foi revogada pela Emenda Regimental n. 22 de 16 de março de 2016.

12. É incabível o ajuizamento de reclamação fundada na Resolução n. 12/2009 do STJ para atacar decisão de interesse da Fazenda Pública, ante a existência de procedimento específico de uniformização de jurisprudência previsto nos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/2009*. *A Resolução n. 12/2009 do STJ foi revogada pela Emenda Regimental n. 22 de 16 de março de 2016.

13. É inviável a discussão de matéria processual em sede de incidente de uniformização de jurisprudência oriundo de juizados especiais, visto que cabível, apenas, contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização que, apreciando questão de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no STJ.

14. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal.

15. A negativa de processamento do pedido de uniformização dirigido ao STJ enseja violação do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009 e usurpação da competência da Egrégia Corte, que pode ser preservada mediante a propositura da reclamação constitucional (art. 105, I, f, da CF/88).

16. Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. (Súmula n. 203/STJ)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVIM, Arruda. **Manual de direito processual civil: teoria geral do processo, processo de conhecimento, recursos, precedentes**. 18ª edição. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2019.

ALVIM, Eduardo Arruda. **Tutela Provisória**. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017.

ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. **Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo**. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

ASSIS, Araken de. **Manual dos recursos**. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

BARROSO, Luís Roberto, **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro**. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016;

BUENO, Cassio Scarpinella. **Manual de direito processual civil**. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018;

CARNELUTTI, Francesco. **Sistema de direito processual civil**. 1ª ed. São Paulo: Classic Book, 2000, v. I.

_____. **Sistema de direito processual civil**, 1ª ed. São Paulo: Classic Book, 2000, v. II.

CHIOVENDA, Giuseppe. **Instituições de direito processual civil**. 2ª edição. Campinas: Bookseller, 2000, v. III.

_____. **Instituições de direito processual civil**. 2ª edição. Campinas: Bookseller, 2000, v. II.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. **Teoria geral do processo**. 19ª edição. São Paulo: Malheiros, 2003.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento**. 17ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, v. I.

_____; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória**. 10ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2015, v. II.

_____; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de direito processual civil: execução**. 9ª edição. Salvador: JusPodivm, 2019.

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. **Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015**. São Paulo: Método, 2016.

LIEBMAN, Enrico Tullio. **Manual de Direito Processual Civil**. Tocantins: Intelectus, 2003, v. I.

_____. **Manual de direito processual civil**. Tocantins: Intelectus, 2003, v. III.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Técnica processual e tutela dos direitos**. 5ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

_____; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, v. II.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo código de processo civil comentado**. São Paulo: revista dos Tribunais, 2015.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. **Comentários ao código de processo civil**, volume V. Rio de Janeiro: Forense, 1974.

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código de Processo Civil Comentado**. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.



NEVES, Daniel Amorim Assumpção. ***Novo código de processo civil comentado***. 3ª edição rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2018.

SANTOS, Ernane Fidélis. ***Manual de direito processual civil: processo de conhecimento***. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 1.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. ***Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum***. Rio de Janeiro: Forense, 2019, v. I.

_____. ***Curso de direito processual civil***. 53ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, v. II.

_____. ***Processo de execução e cumprimento de sentença***. 29ª ed. rev. e atual. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito. 2017.